

LUIZ GUILHERME MARINONI  
SÉRGIO CRUZ ARENHART

COMENTÁRIOS  
AO CÓDIGO DE  
PROCESSO CIVIL

IV

ARTIGOS 294 AO 333

LUIZ GUILHERME MARINONI  
DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART  
DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS  
REVISTA DOS  
TRIBUNAIS™

2019 - 04 - 08

## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

PRIMEIRAS PÁGINAS

# **COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL**

## **IV - ARTIGOS 294 AO 333**

Autores

Luiz Guilherme Marinoni

Sergio Cruz Arenhart

Direção

Luiz Guilherme Marinoni

Coordenadores

Sergio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

© desta edição [2018]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono

*Diretora responsável*

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda

Tel.: 11 3613-8400 - Fax: 11 3613-8450

CEP 01136-000 - São Paulo

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal) com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).



Visite nosso site: [www.rt.com.br](http://www.rt.com.br)

Central de Relacionamento RT (atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao consumidor: [sac@rt.com.br](mailto:sac@rt.com.br)

Fechamento desta edição: [01.08.2018]



ISBN 978-85-5321-170-8

© desta edição [2018]

2019 - 04 - 08

## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

FICHA CATALOGRÁFICA

### **Ficha Catalográfica**

---

#### **Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**

**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Marinoni, Luiz Guilherme

Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico] : (arts. 294 ao 333) / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. -- (Coleção comentários ao Código de Processo Civil ; v. IV / direção Luiz Guilherme Marinoni ; coordenação Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero)

6 Mb ; e-PUB

2. ed. e-book baseada na 2. ed. impressa. rev. e atual.

Bibliografia

ISBN 978-85-5321-170-8

1. Processo civil - Legislação - Brasil I. Arenhart, Sérgio Cruz. II. Mitidiero, Daniel. III. Título. IV. Série.

18-19271 CDU-347.9(81)(094.46)

#### **Índices para catálogo sistemático:**

1. Brasil : Código de processo civil comentado 347.9(81)(094.46)
2. Código de processo civil : Comentários : Brasil 347.9(81)(094.46)

Maria Paula C. Riyuzo - Bibliotecária - CRB-8/7639

2019 - 04 - 08

## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

EXPEDIENTE

### **Expediente**

---

*Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais* **Juliana Mayumi Ono**

*Editorial:* Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

*Assistente Editorial:* Francisca Lucélia Carvalho de Sena

*Produção Editorial*

*Coordenação*

Iviê A. M. Loureiro Gomes

*Líder Técnica de Qualidade Editorial:* Maria Angélica Leite

*Analista de Projetos:* Larissa Gonçalves de Moura

*Analistas de Operações Editoriais:* Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

*Analistas de Qualidade Editorial:* Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

*Estagiários:* Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

*Capa:* Chrisley Figueiredo

*Adaptação de capa:* Linotec

*Projeto gráfico:* Carla Lemos

*Equipe de Conteúdo Digital*

*Coordenação*

**Marcello Antonio Mastrorosa Pedro**

*Analistas:* Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

*Administrativo e Produção Gráfica*

*Coordenação*

**Mauricio Alves Monte**

*Analista de Produção Gráfica:* Aline Ferrarezi Regis

2019 - 04 - 08

## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

SOBRE OS AUTORES

### **Sobre os Autores**

---

#### **Luiz Guilherme Marinoni**

Professor Titular de Direito Processual Civil – *com defesa de tese* – na UFPR. Pós-Doutorado na Universidade Estatal de Milão e na *Columbia University*. Tem dezessete livros publicados na América Latina e na Europa e mais de trinta livros publicados no Brasil. Diretor das Revistas *Iberamerica de Derecho Procesal* e de *Proceso Comparado* – ambas publicadas pela Ed. Revista dos Tribunais. Diretor do *Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal*. Membro do Conselho da *International Association of Procedural Law*. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2010 e foi indicado ao mesmo prêmio em diversas outras ocasiões. Ex-Procurador da República. Ex-Presidente da OAB-Paraná. Advogado e parecerista, com intensa atuação nos Tribunais e nas Cortes Supremas. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2017.

#### **Sérgio Cruz Arenhart**

Pós-Doutorado pela Università degli Studi di Firenze. Doutor e Mestre em Direito pela Federal do Paraná – UFPR. Professor Associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Publicou mais de 20 livros – um deles no exterior – e diversos artigos em revistas especializadas. Foi o mais jovem Juiz Federal do Brasil e atualmente é Procurador Regional da República na 4.<sup>a</sup> Região, tendo ingressado no Ministério Público Federal mediante concurso nacional aprovado em 1.<sup>o</sup> lugar. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2017.

## Apresentação

---

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

# SUMÁRIO

## LIVRO V - DA TUTELA PROVISÓRIA

TÍTULO I - Disposições Gerais [Art. 294 a 299]

TÍTULO II - Da Tutela de Urgência [Art. 300 a 310]

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

CAPÍTULO II - Do Proced. da Tutela Antecipada Req. em Caráter Antec.

CAPÍTULO III - Do Proced. da Tutela Cautelar Req. em Caráter Antec.

TÍTULO III - Da Tutela da Evidência [Art. 311]

## LIVRO VI - DA FORMAÇÃO DA SUSPENSÃO E DA EXT. DO PROCESSO

TÍTULO I - Da Formação do Processo [Art. 312]

TÍTULO II - Da Suspensão do Processo [Art. 313 a 315]

TÍTULO III - Da Extinção do Processo [Art. 316 a 317]

## PARTE ESPECIAL

## LIVRO I - DO PROCEDIMENTO DE CONHEC. E DO CUMP. DE SENTENÇA

TÍTULO I - Do Procedimento Comum

CAPÍTULO I - Disposições Gerais [Art. 318]

CAPÍTULO II - Da Petição Inicial [Art. 319 a 331]

CAPÍTULO III - Da Improcedência Liminar do Pedido [Art. 332]



## **LIVRO V - DA TUTELA PROVISÓRIA**

### **Título I. Disposições Gerais**

**Art. 294.** A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

#### **1. Tutela cautelar**

##### **1.1. Conceito**

A doutrina clássica afirma que a tutela cautelar se destina a dar efetividade à jurisdição e ao processo.<sup>1</sup> A ideia de que a tutela cautelar objetiva garantir a efetividade da jurisdição é, de certa forma, consequência do conceito que vê na jurisdição apenas a função de dar atuação à vontade da lei.

Ao afirmar que o fim da jurisdição é atuar a vontade da lei<sup>2</sup> e não dar tutela ao direito material, a doutrina do final do século XIX e início do século XX pretendeu ficar definitivamente distante da teoria que confundiu o direito de ação com o direito material.<sup>3</sup> De modo que a necessidade de estabelecer a autonomia do direito processual e a finalidade pública do processo conduziu ao abandono da ideia de que a jurisdição daria tutela aos direitos.<sup>4</sup>

Ora, se a função da jurisdição era atuar a vontade da lei, a tutela que se mostrasse necessária para garantir a efetividade da função jurisdicional obviamente não poderia ser concebida como tutela do direito ou como tutela a serviço da tutela do direito, mas apenas como tutela voltada a garantir a efetividade da atuação da vontade da lei.

Pretende-se, com isto, demonstrar que a noção clássica de tutela cautelar é tributária do próprio conceito de jurisdição da sua época. Se o escopo de tutela dos direitos é esquecido quando se diz que a jurisdição deve apenas atuar a vontade da lei, é evidente que a doutrina não pode concluir que a função cautelar almeja a tutela de um direito, mas tem que necessariamente admitir – para ser coerente com as suas bases ideológicas e jurídicas – que a tutela cautelar tem como razão de ser apenas a função de atuar o ordenamento jurídico.

Contrapondo-se à teoria clássica – que, repita-se, não relacionava a função jurisdicional com a tutela do direito material –, surgiu a teoria que atribuiu à função cautelar a proteção de um direito aparente submetido a perigo de dano iminente. Nesta direção, a tutela cautelar não protege o processo, mas sim o direito. Ovídio Baptista da Silva conseguiu demonstrar a superioridade desta teoria ao evidenciar que a tutela marcada pela característica da “provisoriedade” – qualidade que advém da sumariedade da cognição e significa a contradição da “definitividade” da tutela prestada ao final do processo – nem sempre é uma tutela cautelar.<sup>5</sup> O que define a cautelaridade não é a provisoriedade ou a circunstância de a tutela ser concedida no curso do processo de conhecimento, mas sim a sua função diante do direito material. A tutela que satisfaz o direito material, ainda que no curso do processo – tutela antecipada –, não pode ser confundida com a

tutela cautelar, pois esta última não tem o escopo de realizar ou satisfazer o direito, mas apenas o de assegurá-lo.

No Estado contemporâneo, a função jurisdicional é uma consequência natural do dever estatal de proteger os direitos. Sem a jurisdição não seria possível garantir as formas de tutela do direito material.<sup>6</sup> Ademais, a ação atípica e abstrata apenas poderá constituir um direito capaz de dar efetividade ao direito material, deixando de ser uma mera proclamação retórica, caso permita ao autor a utilização das técnicas processuais adequadas à obtenção das tutelas prometidas pelo direito material.<sup>7</sup>

A doutrina clássica entende que a tutela cautelar não é um direito da parte, mas sim um direito do Estado, imprescindível para que a jurisdição garanta a seriedade e a utilidade da sua função.<sup>8</sup> Esta concepção, além de baseada numa visão autoritária de Estado, é fundada na ideia de que a parte apenas tem direito de obter tutela jurisdicional ao final do processo. O equívoco é facilmente constatável não apenas porque nada impede a tutela do direito material no curso do processo, mas também porque, caso a tutela cautelar fosse direito do Estado, ela não teria sido entregue nas mãos do litigante.

A tutela cautelar é direito da parte, correlacionado com o próprio direito à tutela do direito. Em razão deste direito, a jurisdição tem o dever de dar tutela cautelar à parte que tem o seu direito à tutela do direito submetido a perigo de dano. O titular do direito ao ressarcimento, que vê o infrator se desfazer dos seus bens para futuramente não poder ser alcançado pela execução, tem ameaçado o seu direito à tutela ressarcitória e, por isso, tem direito à tutela de segurança (cautelar) da tutela ressarcitória. Ora, da mesma forma que tem dever de prestar tutela ressarcitória, a jurisdição tem dever de conceder tutela que seja capaz de garantir a efetividade da tutela ressarcitória. Em outros termos, a jurisdição tem o dever de tutelar o direito provável – ameaçado por dano – à tutela do direito (p. ex., tutela ressarcitória).

Note-se, ademais, que o direito à tutela cautelar não deriva do direito de ação. É certo que o direito de ação tem como corolário o direito às técnicas processuais idôneas à obtenção da efetiva tutela do direito material, decorrendo do direito de ação, por exemplo, o direito à técnica antecipatória – isto é, o direito à técnica capaz de permitir a antecipação da tutela final – e o direito à técnica idônea a viabilizar a obtenção da tutela cautelar. Porém, aí se está aludindo às técnicas processuais derivadas do direito de ação e não às tutelas prometidas pelo direito material.

Há direito à técnica processual quando há, em abstrato, direito à tutela do direito material. As técnicas processuais idôneas à obtenção da tutela inibitória, por exemplo, decorrem do fato de que o direito substancial promete tutela inibitória ou de que há direito abstrato à tutela inibitória.

O mesmo raciocínio vale para a tutela cautelar. O direito de ação impõe o dever legislativo de instituição de técnica processual capaz de permitir a obtenção de tutela cautelar exatamente porque há direito material à tutela cautelar.

O direito à tutela cautelar não advém do processo. A tutela cautelar não se destina a garantir a efetividade da ação e, por isto mesmo, não pode ser pensada como uma mera técnica processual necessária a lhe outorgar efetividade. O direito à tutela cautelar está situado no plano do direito material, assim como o direito às tutelas inibitória e ressarcitória. O titular do direito à tutela do direito – por exemplo, ressarcitória – também possui direito à tutela de segurança (cautelar) do direito à tutela do direito.

Assim, se a tutela cautelar é instrumento de algo, ela somente pode ser instrumento para assegurar a viabilidade da obtenção da tutela do direito ou para assegurar uma situação jurídica tutelável, conforme o caso. Aliás, caso a tutela cautelar fosse considerada instrumento do processo, ela somente poderia ser instrumento do processo que, ao final, concede a tutela do direito material. Isto, na verdade, é compreensível, pois o elaborador da teoria da instrumentalidade ao quadrado da tutela cautelar, isto é, da teoria segundo a qual a tutela cautelar é instrumento do processo – que já teria a natureza de instrumento do direito material –, é um dos mais célebres defensores da teoria concreta do direito de ação.<sup>9</sup> Ora, quem entende que a ação depende da tutela

do direito material pode confundir, com facilidade, tutela destinada a assegurar a tutela do direito material com tutela do processo.

Além de não ser possível aceitar a teoria que enxerga na função cautelar a tutela do processo, é preciso frisar que a tutela cautelar não se destina a inibir o ilícito (tutela inibitória) e a remover os efeitos concretos do ilícito (tutela de remoção do ilícito) e, portanto, não constitui uma genuína tutela preventiva. A tutela cautelar assegura a tutela de um direito violado ou, em outro caso, assegura uma situação jurídica tutelável, ou seja, uma situação jurídica a ser tutelada mediante a sentença do “pedido principal”.

### **1.2. Tutela assecuratória da tutela do direito material ou da situação jurídica tutelável**

Como está claro, cautelar é a tutela assecuratória da tutela prometida pelo direito material e da situação a que o direito material confere tutela jurídica. Tal tutela é um direito da parte e um dever do Estado, não se fundando no direito de ação, mas sim no próprio plano do direito material.

Se a tutela cautelar foi reconhecida como tutela a serviço do Estado há aproximadamente um século, não é possível esquecer que o Estado constitucional<sup>10</sup> tem o dever de tutelar os direitos fundamentais e, em razão do direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.º, XXXV, CF), o dever de tutelar de forma efetiva todo e qualquer direito. Assim, não há como deixar de enxergar na tutela cautelar um dever do Estado, imprescindível para se outorgar segurança às situações a que o Estado deve tutela jurídica, bem como para que a tutela do direito material possa ser prestada de forma efetiva.

A tutela cautelar não pode ser vista como dirigida a assegurar a utilidade do processo. Como é evidente, a única utilidade que o autor almeja quando vai a juízo é a tutela do direito material. Assim, a tutela cautelar somente pode ser relacionada com a efetividade da tutela do direito ou com a segurança da situação tutelável.

A doutrina clássica, ao supor a tutela cautelar como dirigida a assegurar a efetividade do processo, frisou a ideia de que esta nasceria para morrer quando da prolação da sentença que decidisse o litígio, pondo fim ao processo. A falta de percepção de que a tutela cautelar se destina a assegurar uma tutela do direito, não sendo, portanto, uma simples decisão marcada pela cognição sumária, levou a doutrina a incidir no grave equívoco de subordinar o tempo de vida da tutela cautelar à sentença condenatória.

Ovídio Baptista da Silva, ao tomar em consideração este problema e ter presente que o arresto não pode desaparecer ou ser consumido pela sentença condenatória, utilizou esta situação para exemplificar o seu entendimento de que a tutela cautelar tem natureza temporária e não provisória. Inicialmente, argumentou Ovídio:

Para a doutrina em geral que descende de Calamandrei a nota específica que define a cautelaridade é sua condição de tutela provisória. O pressuposto de que a tutela cautelar seja uma forma de proteção provisória está intimamente ligado à premissa principal de que parte essa doutrina, que é a conceituação da tutela cautelar como instrumento de proteção do processo ou, como dizia Calamandrei, a tutela cautelar como instrumento do instrumento.<sup>11</sup>

E, mais à frente, referindo-se especificamente ao arresto, concluiu:

A duração do arresto, por exemplo, não fica condicionada à emanção da sentença que venha a julgar procedente a ação condenatória. Ao contrário, se a sentença acolher a pretensão do autor que obtivera o arresto essa medida será, a partir da sentença, mais justificada do que fora antes do julgamento, pois entre o trânsito em julgado da sentença e a penhora que substituirá o arresto pode intercorrer um lapso de tempo considerável. Pense-se no caso de uma sentença que necessite de prévia liquidação para ensejar o procedimento executivo com efetivação da penhora. O arresto, diversamente do que supõe a doutrina de Calamandrei, não antecipa absolutamente nada que a sentença condenatória poderia conter, como eficácia que lhe seja peculiar. Nem se tornará dispensável uma vez proferida a sentença definitiva, pois o arresto, não havendo antecipado nenhum efeito que lhe seja inerente, não será substituído por essa sentença.<sup>12</sup>

Ovídio pretende demonstrar, com o exemplo do arresto, que a tutela cautelar não é provisória, mas sim temporária, devendo vincular-se apenas e tão somente à situação de perigo que ameaça o direito. Entretanto, Ovídio não alude a uma circunstância que é fundamental para a compreensão da tutela cautelar: a de que a tutela cautelar objetiva tutelar uma tutela do direito, como, por exemplo, a tutela ressarcitória.

Como é sabido, a sentença condenatória não é suficiente para prestar a tutela ressarcitória pelo equivalente.<sup>13</sup> A sentença condenatória é apenas uma técnica que contribui para a prestação da tutela do direito. A tutela pelo equivalente monetário depende da execução.<sup>14</sup> Portanto, a tutela pelo equivalente jamais, em tempo algum, foi prestada pela sentença condenatória. É somente por este motivo, simples, mas nunca identificado pela doutrina, que o arresto não pode ser substituído pela condenação, devendo sobreviver até a execução e a consequente tutela do direito.

Aliás, é preciso frisar que a tutela cautelar apenas poderia ser substituída pelas sentenças autossuficientes, ou seja, pelas sentenças declaratória e constitutiva, que, respectivamente, prestam as tutelas declaratória e constitutiva. As sentenças condenatória, mandamental e executiva, porque dependem da execução para que a tutela jurisdicional do direito seja prestada, jamais poderão substituir a tutela cautelar. Quer isto dizer que a tutela cautelar não se destina a resguardar o processo que culmina na condenação, mas a garantir a frutuosidade da tutela do direito material que depende das técnicas condenatória e executiva.

Sublinhe-se que, neste caso, a cautelar tutela o direito à tutela do direito e não simplesmente o direito material ou a pretensão de direito material. Não o direito de crédito ou o poder de exigir o crédito, mas o direito à tutela do direito à prestação pecuniária. É claro que, ao se tutelar a tutela do direito à prestação pecuniária, tutela-se, ainda que por consequência, o direito de crédito e a pretensão de direito material. Porém, quem tem um direito de crédito que ainda não pode ser exigido, ou já tem o poder de exigi-lo, somente pode temer a impossibilidade de obter a tutela do crédito e, assim, deve requerer tutela cautelar para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional do direito.

O direito, em sua dimensão estática ou como realidade normativa, obviamente não interessa a quem pensa em termos de tutela dos direitos. O direito é uma situação juridicamente tutelada, assumindo relevância no instante em que é ameaçado de lesão ou é violado. Quando o direito é violado e surge ao seu titular o direito à sua tutela, pode aparecer uma situação de perigo capaz de obstaculizar a sua efetividade. Neste momento, para assegurar o exercício dinâmico do direito ou o modo pelo qual se realiza ou é tutelado, ou seja, a tutela prometida ao direito em sua dimensão estática, deve ser utilizada a tutela cautelar, que é a tutela de segurança da tutela jurisdicional do direito.

Há casos em que a ameaça não recai sobre a efetividade da tutela do direito, mas sobre a própria situação tutelável. A tutela cautelar, então, deixa de assegurar a efetividade da tutela do direito para assegurar a situação tutelável.

Há certas tutelas que não dependem de um conteúdo que esteja desligado da decisão jurisdicional. São as tutelas declaratória e constitutiva, que se realizam com a mera prolação da sentença. As sentenças declaratória e constitutiva, que prestam as tutelas que têm o mesmo nome, não dependem de execução, sendo ditas autossatisfativas. Tais sentenças não exigem execução exatamente porque prestam tutelas que não têm conteúdos que devem ser buscados fora da decisão jurisdicional.

Isso quer dizer que as tutelas declaratória e constitutiva, enquanto realidades normativas ou, mais precisamente, exclusivamente dependentes da decisão jurisdicional, não são sensíveis ao perigo de dano. O que pode correr risco de dano é a situação jurídica tutelável mediante a declaração e a constituição. Enquanto as tutelas declaratória e constitutiva não são prestadas, a situação para a qual a ordem jurídica garante tais tutelas certamente pode exigir tutela cautelar. Nesta hipótese, a tutela cautelar não estará assegurando a efetividade da tutela do direito, mas a situação que se deseja tutelar mediante a sentença.

O perigo pode fazer surgir a necessidade de segurança da situação que se pretende ver declarada ou constituída. Isto pode ocorrer tanto na ação declaratória positiva ou negativa, quanto na ação constitutiva positiva ou negativa.

De qualquer forma, há como reduzir estas duas “formas” da tutela cautelar – segurança da efetividade da tutela do direito e segurança da situação tutelável – a uma única faceta, uma vez que a cautelar, nas duas hipóteses, acaba dando segurança ao direito à tutela do direito material.

Note-se que situação tutelável não é o mesmo que situação acionável – ou capaz de ser afirmada mediante o exercício do direito de ação –, mas situação a que a ordem jurídica outorga tutela ou proteção. Fala-se aqui, portanto, de situação materialmente tutelável. Ora, tutela prometida pelo direito material e situação materialmente tutelável são aspectos de um mesmo fenômeno, que se expressa através do direito à tutela do direito material. Melhor explicando: o direito à tutela do direito material pode ser negado não apenas por uma tutela do direito inefetiva ou incompleta, mas também por danos provocados à parte enquanto a situação jurídica não é tutelada.

Por outro lado, é importante esclarecer que o titular de um direito ameaçado de violação tem ao seu dispor a tutela inibitória e não a cautelar. A tutela do direito ameaçado de violação é a inibitória, cuja função é distinta da cautelar. A inibitória tutela o direito ameaçado, impedindo a sua violação, enquanto a cautelar assegura a tutela prometida ao direito violado ou para a hipótese de sua violação ou assegura a situação jurídica tutelável mediante declaração ou constituição.

Ademais, além de a tutela cautelar não se confundir com a tutela inibitória (preventiva), nem toda tutela urgente é tutela cautelar. A tutela prestada no curso do processo, sob o signo da urgência, mas cuja substância é a mesma da tutela que se espera obter ao final do processo, constitui tutela satisfativa sumária ou tutela antecipada e não tutela dirigida a garantir a frutuosidade da tutela final ou apenas a assegurar a situação jurídica tutelável.

### **1.3 Não satisfatividade**

Ovídio Baptista da Silva, referindo-se a lição de Cristofolini, advertiu que este processualista italiano mostrou que as provisionais, ao anteciparem a eficácia do provimento final de acolhimento da demanda, em verdade realizam plenamente o direito posto em causa, ainda que sob forma provisória, ao passo que as medidas propriamente cautelares – enquanto tutela apenas de segurança – limitam-se a assegurar a possibilidade de realização para o caso de vir a sentença final a reconhecer a procedência da pretensão assegurada.<sup>15</sup> Esta lição é imprescindível para a compreensão da tutela cautelar. Caso todas as tutelas que se fundam em perigo e, por isto mesmo, são lastreadas em cognição sumária, pudessem ser definidas como cautelares, não haveria como diferenciar, nas palavras de Satta e Verde, o “provimento urgente” da “urgência do provimento”.<sup>16</sup>

A distinção entre “provvedimento urgente” e “urgenza di provvedimento” já havia sido revelada, embora em outras palavras, por Pontes de Miranda. Pontes distinguiu, em seus Comentários ao Código de Processo Civil de 1939,<sup>17</sup> o arresto “segurança para execução” (cautelar) e o arresto “execução para segurança”. De acordo com o art. 830 do Código de Processo Civil (em vigor), “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Este arresto é um ato da execução. Ele substitui a penhora, como ato integrante do procedimento destinado à satisfação do direito, em razão de o oficial de justiça não ter encontrado o devedor – arresto-execução para segurança. Esse arresto, como ato da própria execução, difere do arresto cautelar, que se dirige apenas a assegurar a execução ou a tutela do direito de crédito. A partir da distinção entre o arresto cautelar e o arresto-execução para segurança, Pontes de Miranda elaborou os conceitos de “segurança da execução” e “execução para segurança”, os quais permitiram a Ovídio Baptista da Silva concluir que, “quando se antecipa execução, satisfaz-se por antecipação, atende-se, desde logo, a pretensão, o que significa mais do que dar-lhe simples proteção cautelar”.<sup>18</sup>

A não distinção entre tutela satisfativa de cognição sumária e tutela cautelar advém da regra da



nulla executio sine titulo (não há execução sem título), que eliminava a possibilidade de a doutrina entender que a tutela que satisfaz o direito com base em cognição sumária – realizando-o concretamente no plano dos fatos – é execução para a realização do direito.

Calamandrei, tomando em consideração a regra da nulla executio sine titulo,<sup>19</sup> afirmou que o

único critério seguro para distinguir a execução satisfativa da execução cautelar é o de determinar, em atenção à regra da nulla executio sine titulo, se os atos executivos precedem ou seguem a declaração de certeza do direito a ser satisfeito; em todos os casos em que se vê que a execução precede à declaração há execução cautelar, que não se distingue da satisfativa pela diversidade dos meios executivos (a execução cautelar consiste sempre num exercício antecipado, total ou parcial, dos mesmos meios de que se serve a execução satisfativa), mas unicamente em razão de que estes meios não são colocados em funcionamento para satisfazer um direito já declarado (em via ordinária ou em via sumária), mas para satisfazer um direito que, por hipótese, supõe-se que pode chegar a ser declarado em uma fase processual ulterior.<sup>20</sup>

O critério que serve à conclusão de que a execução anterior à sentença é tutela cautelar também permite supor que a execução provisória da sentença é tutela cautelar. Recorde-se que Carlo Furno, na sua monografia sobre la sospensione del processo esecutivo, incidiu em tal equívoco ao concluir que a suspensão do processo executivo e a execução provisória da sentença possuem natureza cautelar, sendo a primeira voltada a resguardar o devedor e a segunda o credor.<sup>21</sup> Porém, como bem soube demonstrar Adolfo Perez Gordo, enquanto

a medida cautelar não pode ter uma extensão maior do que a de mera garantia ou de segurança de uma sentença hipotética e futura, a execução provisória, além de permitir a invasão da esfera jurídica do executado, pode levar à própria satisfação do exequente.<sup>22</sup>

Na realidade, quem atribui à tutela satisfativa prestada com base em cognição sumária a qualidade de cautelar não só é obrigado a também considerar cautelar a execução provisória da sentença, como ainda é forçado a admitir a cautelaridade da tutela da evidência (art. 311, CPC). Isto porque o que impede a doutrina de admitir a natureza executiva da tutela satisfativa sumária é a cognição não definitiva – ou a provisoriedade –, e não o simples requisito do perigo. Pior seria, de fato, se fosse o perigo que estivesse a definir o que é cautelar, pois nesta hipótese somente a execução provisória da sentença contra o perigo nel ritardo passaria a constituir tutela do tipo cautelar. Ora, já foi demonstrado que

o equívoco que se esconde nessa doutrina é tão primário que não evita esta óbvia e insuperável contradição: legitima-se a execução provisória sempre que houver necessidade de acelerar (antecipar) a tutela jurisdicional; se, no entanto, essa aceleração for demasiadamente intensa, então a execução provisória desaparece para dar lugar à tutela cautelar, de tal modo que o mesmo princípio que fundara seu cabimento passa a ser responsável pela sua extinção.<sup>23</sup>

O legislador, ao estabelecer hipóteses específicas de execução provisória, tem por objetivo permitir, em função de particulares situações de direito substancial, a aceleração da satisfação do direito. Assim, quando se admite, em vista de “perigo de dano”, a antecipação da tutela final, é um grosso equívoco lógico imaginar que a tutela urgente constitui tutela cautelar. Como é evidente, não é porque a aceleração da satisfação do direito decorre da existência de um “perigo de dano” que a tutela deixará de ser satisfativa para se transformar em cautelar.

Admitir a execução provisória contra o periculum in mora; limitá-la a algumas situações; admitir a execução provisória da sentença em todos os casos; restringir ou não a execução da sentença na pendência do recurso à prática de apenas alguns atos executivos: tudo isto é uma questão de política legislativa. Lembre-se, aliás, que o art. 282 do Código de Processo Civil italiano (que regula a execução provisória), desde a reforma de 90 do século passado admite que a sentença produza efeitos imediatamente e independentemente de periculum in mora.

Entretanto, se é possível executar a sentença objeto de recurso com base em periculum, não há diferença entre esta modalidade de execução e a tutela antecipada contra o perigo de dano, que pode, inclusive, ser prestada após ter sido proferida a sentença de primeiro grau. Como é óbvio, não é possível aceitar que a execução provisória contra o periculum perca a sua natureza de execução satisfativa, transformando-se em execução cautelar, simplesmente pelo fato de que é

anterior ao trânsito em julgado da sentença.

Na verdade, admitir que a tutela anterior ao trânsito em julgado não confere satisfação digna de consideração jurídica é não perceber a superação da relação entre “tutela do direito” e coisa julgada material e caminhar no sentido contrário ao fim de tutela dos direitos, próprio ao Estado constitucional.<sup>24</sup> Nesta dimensão, aliás, torna-se importante recordar o que disse Vittorio Denti, sabidamente um dos maiores pensadores do processo civil contemporâneo:

Talvez a propensão, acentuada nos últimos anos, a repensar a função jurisdicional em termos de ‘tutela dos direitos’, mais do que em um quadro meramente processual, possa enriquecer com novas perspectivas a nossa pesquisa e conferir uma colocação adequada às exigências de tutelas que emergem com o desenvolver da sociedade contemporânea.<sup>25</sup>

Como está claro, a circunstância de a tutela ser fundada em perigo e baseada em cognição sumária não é suficiente para caracterizá-la como cautelar. Para se definir a natureza da tutela lastreada em cognição sumária e perigo é necessário investigar a sua função, que pode ser satisfativa ou de segurança. Apenas a última possui natureza cautelar; a primeira constitui tutela antecipada. De modo que a “não satisfatividade” é outro requisito da tutela cautelar.

### **1.4 Instrumentalidade**

A tutela cautelar é caracterizada pela instrumentalidade, mas em um sentido bastante diferente daquele que lhe foi atribuído pela doutrina clássica.<sup>26</sup> A tutela cautelar não é um instrumento do instrumento, ou seja, um instrumento do processo.

A tutela cautelar é um instrumento vocacionado a dar segurança à tutela do direito que se pretende ou que pode vir a ser ambicionada. Exemplificando: o arresto não é instrumento do processo, mas instrumento destinado a garantir a frutuosidade da tutela ressarcitória pelo equivalente.

Contudo, não é porque a tutela cautelar é instrumento da tutela do direito, que não pode existir situação em que, ainda que a tutela cautelar apareça como instrumento da tutela do direito, a ação cautelar seja autônoma, como ocorre na hipótese de ação cautelar de caução de dano infecto. Nesse caso a ação é autônoma, ou melhor, não depende de ação principal ou, na dicção do art. 308, de formulação do pedido principal nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. A tutela cautelar perseguida mediante a ação objetiva assegurar uma tutela de direito que ainda não pode ser exigida; a caução é pedida para a hipótese de o direito vir a ser violado. Ora, se a tutela ressarcitória ainda não pode ser exigida – já que ainda não existe violação ou dano –, mas há perigo de dano em relação à tutela ressarcitória que eventualmente poderá ser exigida, a autonomia da ação cautelar é algo simplesmente lógico e incontestável.

Ademais, o fato de a tutela cautelar se destinar a dar segurança à efetividade da tutela do direito não significa que ela esteja vinculada ao reconhecimento do direito material a ser tutelado. A segurança é prestada para a eventualidade do reconhecimento do direito material e, desta forma, para garantir que, na hipótese de procedência do pedido, a tutela do direito seja útil e efetiva. Basta lembrar que a concessão da tutela cautelar requer a probabilidade do direito à tutela final e, portanto, aceita naturalmente a possibilidade de formação de convicção ulterior diversa.

### **1.5 Referibilidade**

A tutela cautelar sempre está referida a uma provável tutela já requerida ou que poderá vir a ser solicitada. Por isto mesmo, como já demonstrado, a tutela cautelar é “não satisfativa”; destina-se apenas a assegurar a tutela jurisdicional do direito, não sendo capaz de prestá-la ou de satisfazer ou realizar o direito. Na tutela cautelar há sempre referibilidade a uma tutela ou situação substancial acautelada. Inexistindo referibilidade, não há direito acautelado, mas sim tutela satisfativa.

Kazuo Watanabe, em importante livro sobre a cognição no processo civil – escrito à época do código de 1973 –, elegeu a referibilidade para a determinação de quando a “ação principal”

deveria ser proposta quando obtida a tutela cautelar. No seu entendimento, quando não é possível ver “referibilidade” a direito acautelado, a tutela cautelar deve dispensar a propositura de “ação principal”.<sup>27</sup>

Porém, mesmo nas raras hipóteses que dispensam a ação principal ou o “pedido principal” (art. 308, CPC), como na caução de dano infecto, está presente a nota da referibilidade. Ao contrário do que sustenta Watanabe, não há tutela cautelar que possa deixar de fazer referência a uma situação substancial tutelável. A circunstância de a tutela jurisdicional ainda não poder ser exigida, como acontece com a caução voltada a garantir a tutela ressarcitória para a hipótese de ser praticado dano, não significa que a tutela cautelar, ao dispensar o pedido principal, deixe de fazer referência a uma situação cautelandada. Para ser mais claro: a ação do art. 305 deve necessariamente fazer referência a uma tutela de direito ou situação cautelandadas, embora possa, em situações excepcionais, dispensar a ação principal – dita “pedido principal” pelo art. 308 –, sem com que a tutela cautelar concedida perca eficácia.

A dispensabilidade do pedido principal, ao contrário do que se poderia pensar, não é uma consequência da ausência de referibilidade. Como também não é, conforme se viu no item antecedente, consequência da falta de instrumentalidade, uma vez que essa diz respeito à tutela do direito e não ao processo.

O conceito de referibilidade advém da ideia de ligação assecurativa da tutela cautelar à tutela do direito.<sup>28</sup> Na ação ressarcitória, por exemplo, não há qualquer referibilidade a alguma situação acautelada ou, ainda, nenhuma referibilidade da tutela ressarcitória a outra situação substancial. Não obstante, quando se concede o arresto como medida preparatória ou incidente em relação à tutela ressarcitória, torna-se evidente a existência da tutela cautelar que lhe dá segurança. A falta de referibilidade é evidência da existência de satisfatividade e, assim, de ausência de cautelaridade.<sup>29</sup>

### **1.6 Diferença entre cautelaridade e preventividade**

A mais importante das tutelas jurisdicionais a serviço da integridade do direito material – ditas tutelas específicas – é a tutela inibitória, destinada a proteger o direito contra a possibilidade da sua violação. Para ser mais preciso, a tutela inibitória é voltada a impedir a prática de ato contrário ao direito, assim como a sua repetição ou, ainda, continuação.<sup>30</sup>

Em outras palavras, a inibitória constitui a tutela do direito ameaçado de violação. Tal tutela, como é óbvio, é preventiva. Entretanto, a tutela que inibe a agressão do direito ou previne a sua violação nada tem a ver com tutela cautelar, não obstante a costumeira confusão entre esta última forma de tutela e a tutela inibitória.

Por muito tempo a doutrina não teve condições de perceber a distinção entre tutela cautelar e tutela preventiva, uma vez que, em virtude de uma visão distorcida da liberdade, não podia admitir que o juiz atuasse sobre a vontade de alguém que ainda não tinha violado um direito ou infringido uma regra jurídica. O surgimento de situações de direito substancial de conteúdo prevalentemente não patrimonial é que obrigaram à percepção da necessidade de tutela jurisdicional capaz de impedir a violação do direito e levaram à superação do dogma da intangibilidade da liberdade do demandado. O problema é que, como a ação de conhecimento não continha técnicas processuais adequadas a propiciar tutela inibitória – técnica antecipatória, bem como sentença e meios executivos capazes de constranger alguém a não fazer –, a prática forense assistiu ao uso distorcido da ação cautelar, ou melhor, ao uso da ação cautelar como ação de conhecimento com função inibitória – dotada de liminar e sentença que ordena um não fazer sob pena de multa.

Perceba-se que a inibitória é a tutela do direito ameaçado de violação, assim como a ressarcitória é a tutela do direito que sofreu dano. Da mesma forma que a ressarcitória é a única tutela contra o dano, a inibitória é a tutela exclusiva contra a ameaça de violação do direito. Se a cautelar serve para assegurar a tutela do direito, para prevenir a violação do direito não é adequada uma tutela de segurança, mas uma tutela – obviamente “autônoma” – capaz de inibir a



prática de ato contrário ao direito. Toda tutela inibitória ou destinada a impedir a violação do direito não é tutela de segurança de uma outra tutela. Apenas a tutela de outra tutela, ou melhor, somente a tutela de segurança de outra tutela – por esta razão caracterizada pela instrumentalidade –, é uma tutela cautelar.

Deixando-se de lado as tutelas declaratória e constitutiva, a tutela cautelar supõe a ameaça de dano à tutela repressiva, ou seja, a uma tutela posterior à violação. Adolfo di Majo, em profundo estudo sobre as tutelas dos direitos, deixa claro que a tutela cautelar não foi idealizada para exercer função preventiva. Como diz o eminente civilista italiano, para requerer a tutela cautelar é necessário não só afirmar a violação do direito objeto da tutela jurisdicional final, mas ainda demonstrar que esta violação poderá provocar um dano iminente no curso do processo.<sup>31</sup>

Realmente, a tutela cautelar não foi pensada para exercer função preventiva ou capaz de impedir a violação do direito. O direito liberal clássico – a partir do qual o processo civil foi elaborado –, além de eminentemente patrimonialista, preocupava-se com a rígida delimitação dos poderes de interferência do Estado na esfera jurídica dos particulares. Por esta razão, não houve delimitação de uma tutela genuinamente preventiva (inibitória) e as sentenças e meios executivos não foram moldadas para propiciá-la. Ora, quando a tutela do processo de conhecimento não pode ser preventiva, a tutela que lhe é instrumental, por lógica, evidentemente também não pode. Na verdade, caso se atribuísse natureza preventiva à tutela cautelar, estar-se-ia negando os valores que inspiraram o processo civil liberal e a própria proibição de a jurisdição exercer função preventiva.<sup>32</sup>

Para se demonstrar o equívoco da confusão entre cautelaridade e preventividade, é importante tomar em conta o instituto da condenação para o futuro. A condenação para o futuro é uma exceção à regra de que a condenação é condicionada à violação do direito. Cria antecipadamente o título executivo, mas pressupõe que a execução apenas será implementada em caso de violação ou inadimplemento.<sup>33</sup>

O art. 323 do Código de Processo Civil afirma que,

na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.<sup>34</sup>

Isto significa que o credor pode obter uma condenação que diga respeito não só às prestações que se vencerem depois do ajuizamento da ação, ou seja, no curso do processo, mas também àquelas que vencerem posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Neste caso, há um inadimplemento em ato e a condenação abarca as prestações futuras, em relação às quais ainda não há qualquer inadimplemento. Como agudamente percebeu Pontes de Miranda, “não precisa o autor vencedor no litígio intentar ação para haver a condenação no que se vai vencendo”. O autor apenas necessita requerer a execução da sentença, que vai aparecendo como necessária à medida que as prestações se vencem, até que se vença a última prestação vincenda. A condenação é quanto ao vencido e ao vencendo. A executabilidade é que depende de que se vençam as prestações.<sup>35</sup>

Argumenta-se, em favor da condenação para o futuro, que é preciso evitar a multiplicação de ações para cobrar aquilo que é devido periodicamente e, ainda, que a constituição antecipada do título executivo serve para evitar que a própria efetividade da tutela jurisdicional seja frustrada em razão do longo espaço de tempo que, na generalidade dos casos, está presente entre o momento do inadimplemento e o da real e concreta satisfação do direito.<sup>36</sup>

Chiovenda, ao tratar da condenação para o futuro, afirmou que suas principais vantagens estariam:

i) na necessidade de prevenir o dano que decorreria da falta de um título executório no momento em que a prestação será devida

ii) “na conveniência de evitar processos reiterados para conseguir o que é devido periodicamente (quota de aluguel, de alimentos, de juros, de rendas), uma vez que haja razão para supor que esses processos se tornariam, de qualquer forma, necessários: como quando o devedor se mostra moroso no pagamento de algumas quotas.”<sup>37</sup>

Chiovenda inseriu a condenação para o futuro entre os “processos preventivos”.<sup>38</sup> Em um de seus mais importantes trabalhos, encontra-se a afirmação de que

uma prática que remonta à doutrina italiana medieval (in Mancini, Comm. II, n. 99 seg.; Weismann, Feststellungsklage, p. 99 seg.) admite os juízos preventivos, nos quais, por razões especiais, previne-se o dano que derivaria ou da inútil repetição de ações sucessivas, ou mesmo da falta de um título executivo no momento do vencimento da obrigação.<sup>39</sup>

O real problema é que esta afirmação de Chiovenda acabou sendo absorvida e potencializada pela doutrina pós-chiovendiana, especialmente pela doutrina de Calamandrei sobre tutela cautelar. Calamandrei, embora não tenha incluído a condenação para o futuro entre as providências cautelares, ao diferenciar a tutela cautelar da tutela preventiva acabou concluindo que a condenação para o futuro constitui o “caso mais notório” de tutela preventiva. Segundo ele:

em certos casos o sistema processual [italiano] admite que o interesse suficiente para invocar a tutela jurisdicional possa surgir antes que o direito tenha sido efetivamente violado, bastando o fato de que a lesão se afigure como próxima ou possível: nestes casos, a tutela jurisdicional, ao invés de objetivar eliminar a posteriori o dano produzido pela lesão do direito, atua a princípio com o fim de evitar o dano que poderia derivar da lesão de um direito. Fala-se, nestes casos, em contraposição à tutela sucessiva ou repressiva, de tutela jurisdicional preventiva, em relação à qual o interesse de agir surge não do dano, mas do perigo de um dano jurídico: o caso mais notório deste tipo de juízo preventivo está na figura da condenação para o futuro.<sup>40</sup>

Se a condenação para o futuro objetiva garantir maior tempestividade à satisfação do direito violado,<sup>41</sup> Calamandrei certamente se equivoca ao dizer que este tipo de condenação é “o caso mais notório” de tutela preventiva. Uma técnica processual que permite, antes da violação do direito, a possibilidade de acesso imediato à via que implementa a tutela repressiva, desde que a lesão ou o inadimplemento sejam praticados, está muito longe de conter qualquer resquício ou vestígio de preventividade. A condenação para o futuro, ainda que admitida antes da violação do direito, é concedida para atuar depois que o direito foi violado e não para impedir a sua lesão.<sup>42</sup>

A confusão entre tutela preventiva e condenação para o futuro é consequência da ausência de reflexão sobre o real objetivo da tutela preventiva e do descaso com a tutela dos direitos não patrimoniais, fruto de uma ideologia que não leva em consideração a necessidade de tutela efetiva de direitos que, ainda que vitais dentro do contexto do Estado contemporâneo, podem ser transformados pelo inadimplente em pecúnia. Note-se que a condenação para o futuro é plenamente adequada à tutela dos direitos patrimoniais, enquanto os “novos direitos”, frequentemente com conteúdo não patrimonial, exigem a tutela inibitória, isto é, a tutela preventiva.

Ademais, a confusão entre uma técnica processual e uma tutela de direito com finalidades tão distintas também serve para evidenciar que a doutrina clássica não tinha muita consciência do que falava quando estudava a tutela cautelar. Se a doutrina não conseguia perceber – por estar cegada por uma ideologia comprometida com um determinado modelo institucional de Estado de Direito – a diferença entre condenação para o futuro e tutela preventiva, ela não podia conceber uma tutela inibitória contraposta à tutela cautelar e, assim, perceber a nítida distinção entre o arresto e a tutela inibitória que impede a violação do meio ambiente, por exemplo.<sup>43</sup>

A caução, destinada a garantir o ressarcimento diante de eventual dano, não constitui tutela preventiva, mas sim tutela cautelar, voltada a dar segurança à frutuosidade e à efetividade da tutela ressarcitória. A particularidade desta forma de tutela cautelar está em que a segurança, no caso, é de uma tutela ressarcitória eventual, e não de uma tutela ressarcitória já exigível – porque posterior ao dano.

De qualquer forma, o que deve ficar claro é que a tutela inibitória (ou a tutela preventiva) é

satisfativa e autônoma, enquanto a tutela cautelar sempre se refere a uma tutela do direito ou a uma situação substancial tutelável, podendo, em casos raros, dar origem a uma ação cautelar autônoma, porque ligada a uma tutela jurisdicional ainda não exigível. Ou seja, a tutela cautelar é caracterizada pela instrumentalidade e pela referibilidade, embora possa, em hipóteses excepcionais, abrir oportunidade a uma ação cautelar autônoma. Neste caso, a instrumentalidade e a referibilidade estão, por assim dizer, “encobertas”, uma vez que a tutela assegurada ainda não é exigível.

Frise-se, portanto, a distinção fundamental entre preventividade e cautelaridade. A tutela preventiva ou inibitória não é marcada pela referibilidade ou pela instrumentalidade, uma vez que basta por si só ou dá tutela satisfativa ao direito. A tutela inibitória ou preventiva é tão satisfativa quanto a tutela ressarcitória, não obstante a lamentável confusão que a doutrina costuma fazer entre tutela preventiva e tutela cautelar.

## **2. Origem, desenvolvimento e transformação da tutela cautelar. O surgimento da tutela antecipada**

### **2.1 A tutela cautelar no Estado liberal clássico**

O processo civil, no Estado de Direito de matriz liberal, não foi projetado para dar tutela preventiva aos direitos. O direito, nesta época, era voltado a proteger as liberdades e as conquistas da classe burguesa contra a ameaça de arbítrio do Estado. O Estado, para garantir a liberdade, era obrigado a tratar a todos da mesma forma, independentemente das suas diferenças concretas. Tomava-se em conta o conceito de igualdade formal perante a lei, sendo que qualquer tratamento desigual – ainda que a posições desiguais – era visto como privilégio inconcebível.

Este Estado, porquanto não podia tratar as posições jurídicas e sociais de forma diferenciada, obviamente não podia desenhar políticas públicas voltadas a dar proteção específica ou mais incisiva a determinadas classes de pessoas ou espécies de direitos. Além disto, os direitos desta época que importavam ao processo civil eram vistos como coisas dotadas de valor de troca, de modo que, diante da prática de ato ilícito, entendia-se ser suficiente a prestação da tutela ressarcitória pelo equivalente ao valor do dano ou da prestação inadimplida.

Por isso, a tutela contra o ilícito era apenas a tutela contra o dano. Lembre-se que a indistinção entre ilícito e dano é o reflexo de um árduo processo de evolução histórica que acabou por fazer concluir, a partir da suposição de que o bem juridicamente tutelado é uma coisa dotada de valor de troca, que a tutela jurisdicional do bem é o ressarcimento pelo equivalente ao valor econômico da lesão.<sup>44</sup>

Além disto, o Estado, na economia liberal, estava preocupado apenas em manter em funcionamento os mecanismos de mercado. Ora, a tutela pelo equivalente ao valor da prestação mantinha íntegros os mecanismos do mercado, sem alterar a sua lógica.<sup>45</sup> Portanto, há aí um nexo entre a tutela pelo equivalente e os princípios da abstração das pessoas e dos bens ou, ainda, uma visível correlação entre o contrato, a igualdade formal dos contratantes e a sanção pelo equivalente como forma expressiva da realidade da economia de mercado.<sup>46</sup>

Se os bens são equivalentes, e assim não merecem tratamento diversificado, a transformação do bem devido em dinheiro está de acordo com a lógica do sistema, cujo objetivo é apenas sancionar o faltoso, repristinando os mecanismos de mercado.

O art. 1.142 do Código Napoleão, ao dizer que toda obrigação de fazer e não fazer resolve-se em perdas e danos mais juros em caso de inadimplemento, não só expressou as preocupações da economia liberal, como, além disto, refletiu os princípios de liberdade e de defesa da personalidade, próprios do jusnaturalismo e do racionalismo iluminista.

Ou seja, a tutela pelo equivalente, além de reafirmar as intenções da economia liberal, manteve intacta a “liberdade do homem” ao não admitir a coercibilidade das obrigações. A coercibilidade das obrigações de fazer, indispensável para o juiz poder convencer o demandado a cumprir, foi

repudiada pelo art. 1.142 do Código Napoleão em nome dos princípios da liberdade, da defesa de personalidade e da autonomia da vontade.

A tutela destinada a impedir a violação do direito não era admitida não apenas porque se supunha que os direitos podiam ser adequadamente tutelados após a ocorrência do dano mediante o pagamento de indenização, mas também porque uma tutela jurisdicional anterior à prática de qualquer ato contrário ao direito era vista como uma interferência estatal inconcebível sobre a esfera da liberdade e da autonomia do indivíduo.

Nesta época, o Estado sequer tinha fundamento para constranger a vontade daquele que já tinha inadimplido. Portanto, a possibilidade de tutela estatal capaz de atuar sobre a vontade de alguém que sequer havia violado um direito era inimaginável. Aliás, Lodovico Barassi, já em meados do século XX, confessou que a “tutela puramente preventiva”, “certamente la più energica”, seria também “la più preoccupante, come è di tutte le prevenzioni che possono eccessivamente limitare l’umana autonomia”.<sup>47</sup>

Na concepção da doutrina clássica, a sentença declaratória prestava tutela preventiva. A sentença declaratória era a única técnica processual capaz de outorgar tutela preventiva no processo civil clássico. Gian Antonio Micheli, em conferência pronunciada em importante congresso internacional de direito comparado que versou sobre as tutelas preventivas, incluiu a tutela declaratória no gênero tutela preventiva, dizendo que

a primeira figura de ação preventiva é aquela da ‘action en fixation de droit’ (ação declaratória), admitida para a obtenção da declaração de um direito quando este, embora não tenha sido violado ou judicialmente contestado, torna-se objetivamente incerto em sua existência ou conteúdo, na medida em que é discutido ou não reconhecido pelos outros.<sup>48</sup>

A tutela declaratória realiza-se com a prolação da sentença que, contendo um juízo meramente declaratório, é revestida pela coisa julgada material. A sentença declaratória dá ao autor apenas a vantagem de que a relação jurídica, que até então era controvertida, não mais poderá ser discutida. Entretanto, tal sentença é incapaz de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da declaração que contém.<sup>49</sup> A sentença declaratória não tem capacidade para inibir o ilícito ou tutelar de forma realmente preventiva os direitos.<sup>50</sup>

Na verdade, a confusão entre tutela declaratória e tutela preventiva, posta à luz pela doutrina chiovendiana,<sup>51</sup> teve origem em uma exigência de construção sistemática. A doutrina utilizou o argumento de que a existência de uma sentença anterior à violação (declaratória) demonstrava o princípio da autonomia da ação, uma vez que, em face dela, o autor não precisaria ter direito violado para exercer o direito de ação.<sup>52</sup> A ação declaratória, por estar em contraposição à condenação, seria preventiva.

Além disto, como a doutrina clássica formou-se sob a influência de um Estado de Direito de matriz liberal, marcado por uma acentuação dos valores de liberdade individual em relação aos poderes de intervenção estatal, ela não podia conceber uma tutela preventiva que dependesse de técnica processual que constrangesse a vontade do demandado. Foi por isto que circunscreveu a tutela preventiva à sentença declaratória. Na verdade, a tutela declaratória, enquanto tutela que regula apenas formalmente uma relação jurídica já determinada em seu conteúdo pela autonomia privada,<sup>53</sup> era ideal aos valores do Estado liberal.<sup>54</sup> Já a tutela preventiva, vista como tutela capaz de inibir a violação do direito, era incompatível com os pressupostos deste modelo de Estado.

Tudo isto quer dizer que, no direito processual clássico, não existia tutela capaz de impedir a prática do ilícito. Seja porque se supunha que os direitos não necessitavam de tutela preventiva, seja porque se entendia que o Estado não podia atuar previamente ao agir, seja ainda porque o Estado não podia constranger a vontade do indivíduo para alcançar um não fazer.

Lembre-se que o desenho do processo depende do objetivo do direito hegemônico, o que significa que a função e a estrutura do processo de conhecimento clássico são consequências do direito e dos valores de uma época. Quando se entende que o bem jurídico jurisdicionalmente tutelável é uma coisa dotada de valor de troca, e que o juiz deve ter os seus poderes limitados para

não interferir na esfera jurídica privada, o processo não só não precisa, como não deve, exercer função preventiva.

A tutela cautelar, ainda que relacionada com o perigo, foi concebida para assegurar a utilidade da tutela jurisdicional final. A tutela cautelar certamente não poderia evitar a violação do direito, pois nem mesmo o processo de conhecimento clássico foi pensado e estruturado para tanto. Se este processo de conhecimento não tinha como fim evitar a violação do direito, por lógica não há como admitir que a tutela que lhe deveria servir pudesse ultrapassar a sua própria função – outorgando proteção preventiva ou inibitória.

A tutela cautelar, ao servir à tutela ressarcitória ou à tutela do adimplemento da obrigação pecuniária, era obrigada a aceitar a ocorrência da violação ou do inadimplemento, que legitimavam as próprias ações ressarcitória e do adimplemento. Ou seja, a tutela cautelar foi pensada para assegurar uma tutela que pressupunha a violação do direito.

## **2.2 A tutela cautelar não foi concebida para impedir a violação do direito nem para remover os efeitos concretos do ato contrário ao direito**

É preciso esclarecer, porém, que a tutela cautelar não só é incapaz de impedir a violação do direito, como ainda não se destina a remover os seus eventuais efeitos concretos que se prolongam no tempo.

A falta de idoneidade da tutela cautelar para remover os efeitos concretos do ato contrário ao direito, ainda que também seja ligada à constatação de que a jurisdição se importava apenas em dar tutela ressarcitória aos direitos, exige atenção para a questão do conceito de ilícito civil.

Por muito tempo o ilícito civil foi associado ao fato danoso. Isso também foi consequência da suposição de que o bem objeto da tutela jurisdicional civil era uma mercadoria, que, assim, em caso de dano, poderia ser indenizada em pecúnia. O ilícito que não produzisse dano não teria interesse para o direito civil e para o processo civil.<sup>55</sup>

A unificação da categoria da ilicitude com a da responsabilidade civil, fruto da ideia de que a única tutela contra o ilícito consiste na reparação do dano – resultado, sublinhe-se, de uma visão “mercificante” dos direitos –, impediu a doutrina de vislumbrar, até bem pouco tempo atrás, uma tutela contra o ilícito que não produziu dano.<sup>56</sup>

É claro que um ilícito que não produziu dano apenas interessa quando deixa marcas concretas que se prolongam no tempo. Trata-se de um ilícito, por assim dizer, com efeitos concretos continuados. É o caso, por exemplo, da exposição à venda de produto nocivo à saúde do consumidor. Expor à venda produto com composição nociva à saúde é, por si só, ato ilícito. Porém, deste ato podem decorrer danos aos consumidores, mas não necessariamente. Entretanto, não há como admitir que o processo civil nada possa fazer em relação ao ilícito que não produziu dano, tendo que aguardar a sua eventual ocorrência para poder ser instaurado.

As normas de proteção dos direitos fundamentais, como o direito fundamental do consumidor, frequentemente proíbem condutas para impedir a produção de danos. Tais normas, por isto mesmo, têm natureza protetiva – ou, de certa forma, preventiva do dano –, o que obriga o legislador a conferir legitimidade para determinados entes pedirem, através de ação, a tutela jurisdicional necessária para garantir a sua observância.

É exatamente o que acontece quando se pensa na legitimidade do Ministério Público, por exemplo, para requerer a remoção dos efeitos concretos derivados da violação de uma norma de proteção, como a que proíbe a exposição à venda de produto nocivo à saúde. Quando o Ministério Público pede a busca e apreensão de produto nocivo exposto à venda, ele certamente não pede tutela ressarcitória nem tutela capaz de impedir a violação, mas sim tutela capaz de remover os efeitos concretos do ilícito que perduram no tempo.

Esta forma de tutela é contemporânea ao Estado constitucional, identificando algo



absolutamente novo para as dogmáticas civil e processual civil<sup>57</sup>. Por isto, jamais foi cogitada pela doutrina do processo civil clássico e mesmo pela doutrina processual brasileira dos últimos e recentes anos.

### **2.3 A proibição dos juízos de verossimilhança**

A impossibilidade de se conceder a tutela do direito com base em verossimilhança, isto é, a proibição de antecipação da tutela no procedimento comum clássico, fundou-se na suposição de que o único julgamento que poderia atuar a lei seria posterior à verificação da existência do direito. Na trilha do direito liberal, o processo deveria conter somente um julgamento, que apenas poderia ser realizado após a elucidação dos fatos componentes do litígio.

O julgamento posterior à cognição sempre foi associado à ideia de “busca da verdade”. A “certeza” do juiz seria pressuposto da sua capacidade de “enunciar a lei”. De modo que a garantia de liberdade e de segurança, neste caso, estariam em um julgamento que, a partir da “descoberta da verdade”, pronunciasse as palavras da lei.

Não é de estranhar, assim, que a tutela antecipatória não esteja de acordo com os princípios liberais clássicos. Se o juiz é um mero aplicador da lei, pelo mesmo motivo havia de ser proibido de julgar com base em verossimilhança. Dar ao juiz poder para tutelar um direito aparente é o mesmo que dar ao Judiciário o poder para rever, com base em cognição aprofundada, o julgamento baseado em verossimilhança. Porém, se o sistema processual admite que o juiz pode afirmar que não deveria ter concedido a tutela antecipatória, há aceitação de que a “justiça” do juiz pode não ser a da lei.<sup>58</sup>

O processo liberal proibiu os juízos de verossimilhança para permitir o controle do Judiciário e para garantir a liberdade dos cidadãos. A vedação destes juízos derivou da falta de confiança no juiz.<sup>59</sup> Diante desta desconfiança, foram evidenciadas garantias para a participação adequada no processo, que passaram a significar garantias de liberdade do litigante contra a possibilidade do arbítrio judicial.

O direito liberal, diante da desconfiança em relação ao Judiciário, não admitiu qualquer tipo de restrição à defesa e ao contraditório e, assim, tornou inviável a tutela do direito antes da plenitude da cognição. Quando a preocupação do direito se centrava na defesa da liberdade do cidadão diante do Estado, as formas – e assim a rigidez dos conceitos de ampla defesa e de contraditório – possuíam grande importância para o demandado.

A impossibilidade de postecipação da defesa e do contraditório é intimamente ligada à separação entre cognição e execução. Se a ampla defesa e o contraditório não podem ser postecipados, a execução não pode ser anterior ao término da cognição.

Em suma, ainda que as relações jurídicas da época do direito liberal não exigissem a antecipação da tutela, é certo que a sua admissibilidade encontrava obstáculo na necessidade de se garantir a liberdade do litigante contra a possibilidade de arbítrio do juiz e na ideologia que entendia que a liberdade se realizava através da certeza do direito, valores que fundaram a fórmula técnico-jurídica da *nulla executio sine titulo*.<sup>60</sup>

### **2.4 O surgimento de novas situações jurídicas, a inexistência de técnicas processuais idôneas à prestação das tutelas inibitória e de remoção do ilícito e a morosidade do processo de conhecimento: a expansão da tutela cautelar**

A transformação da sociedade e do Estado fez surgir novas situações substanciais carentes de tutela. O Estado constitucional, ao afirmar os direitos fundamentais, frequentemente toma em conta direitos de conteúdo não patrimonial, ou prevalentemente não patrimonial, exigindo a sua proteção através de normas de proteção e de tutelas jurisdicionais voltadas a impedir a sua violação e a viabilizar a remoção dos efeitos concretos derivados da sua agressão.<sup>61</sup>

Pense-se, por exemplo, nos direitos fundamentais do consumidor e ao meio ambiente, que

exigem tutela capaz de impedir a violação, bem como tutela idônea a remover os efeitos concretos de ação contrária à norma instituída para a sua proteção – como a remoção de lixo tóxico despejado em local proibido pela legislação ou a busca e apreensão de produto com composição proibida por norma de proteção ao consumidor.

Isto para não falar de outras situações jurídicas, de caráter individual e patrimonial, mas que também não podem dispensar as tutelas inibitória e de remoção do ilícito para a sua efetiva proteção, como as que dizem respeito à exclusividade do uso de marca comercial ou à concorrência desleal.

Ademais, a necessidade de maior celeridade de tutela dos direitos, advinda das características dos “novos direitos” e das relações jurídicas próprias à sociedade contemporânea, colocaram em xeque o processo civil clássico – destituído de técnica antecipatória e de sentenças diferentes das declaratórias, constitutivas e condenatórias –, evidenciando a imprescindibilidade da adaptação do sistema de distribuição de justiça à evolução da sociedade.

Porém, a falta de idoneidade do processo civil clássico para atender às novas situações de direito substancial não impediu a prática forense de utilizar a ação cautelar inominada para obter as tutelas inibitória e de remoção do ilícito, bem como a própria antecipação da tutela.

Como o procedimento cautelar viabilizava a concessão de liminar, assim como o uso de meios executivos adequados às diferentes situações concretas – uma vez que a execução da tutela cautelar nunca se submeteu ao princípio da tipicidade dos meios executivos –, a prática forense passou a conceber, especialmente em razão das particularidades dos novos direitos, um uso não cautelar da ação cautelar inominada.

Esse uso não cautelar da ação cautelar inominada consistiu na invocação do procedimento cautelar para atender aquilo que poderia e deveria ser tutelado pelo procedimento comum de conhecimento, desde que tivesse as particularidades técnicas do procedimento cautelar,<sup>62</sup> especialmente a técnica antecipatória e as sentenças mandamental e executiva.

Tal fenômeno não ocorreu somente no Brasil, mas em todos os países em que o modelo básico de processo de conhecimento esgotou a sua funcionalidade. A própria prática italiana, ainda que sem romper a classificação trinária das sentenças, foi obrigada a admitir a tutela inibitória sob o rótulo de cautelar diante da ação declaratória.

Lembre-se que, antes da violação do direito, a única alternativa, em face das sentenças de conhecimento clássicas, seria a ação declaratória. Porém, como o procedimento desta ação não contém técnica antecipatória e a sentença declaratória não possui idoneidade para impedir a prática do ilícito, surgiu naturalmente, para viabilizar a tutela inibitória das novas situações carentes de tutela, a possibilidade do emprego da técnica cautelar inominada para outorgar tutela inibitória em face da ação declaratória.

A melhor doutrina italiana foi expressa em advertir que, neste caso, ocorreu uma distorção da fisionomia original da tutela cautelar, já que o emprego da técnica cautelar para a obtenção da tutela inibitória fez desaparecer a principal característica da tutela cautelar, isto é, a instrumentalidade.

Loriana Zanuttigh, ao escrever sobre o uso da cautelar inominada na tutela dos direitos da pessoa, consignou que, graças à progressiva alteração da estrutura e da função da tutela cautelar inominada, criou-se um modelo de tutela mais avançado e eficaz, com resultados de incisa aderência à especificidade dos direitos da pessoa.<sup>63</sup> Há aí uma importante percepção de que a tutela cautelar perdeu a sua original fisionomia para permitir a adequada proteção de direitos que, de outra maneira, não encontrariam adequada tutela jurisdicional na Itália.<sup>64</sup>

No mesmo sentido, Vittorio Denti, após lembrar que o art. 700 – base do poder geral de cautela – do CPC italiano permitiu que os tribunais suprissem a ausência de tutela jurisdicional adequada, adverte que isto ocorreu por ter surgido a necessidade de uma “tutela de urgência com função não

cautelar, ou seja, não vinculada instrumentalmente com a tutela que o art. 700 define como ordinária”.<sup>65</sup>

A necessidade de uma tutela efetiva dos direitos não patrimoniais levou Proto Pisani a insistir na oportunidade de um procedimento sumário não cautelar,<sup>66</sup> o que, segundo Denti, superaria “o equívoco que vicia a atual aplicação do art. 700, submetido a exigências de tutela que não têm a característica da instrumentalidade, própria das medidas cautelares”.<sup>67</sup>

Como está claro, a melhor doutrina italiana reconheceu que a técnica cautelar passou a ser utilizada de modo distorcido em razão das necessidades concretas que irradiaram das novas situações de direito substancial.<sup>68</sup>

No Brasil, a ação cautelar inominada também foi utilizada para dar tutela aos direitos da personalidade, acabando por assumir a configuração de ação autônoma e satisfativa. Assim, por exemplo, foi usada para impedir violação do direito à honra e do direito à imagem. Nestes casos, como se desejava apenas impedir a violação, e não qualquer outra espécie de tutela – como a ressarcitória –, o procedimento cautelar era suficiente para prestar a única tutela desejada pelo autor ou para satisfazer a sua pretensão à tutela jurisdicional do direito.

Note-se que a tutela em questão era inibitória e não de segurança de uma tutela jurisdicional final, ou seja, cautelar. A tutela, por impedir a violação, satisfazia a necessidade de tutela jurisdicional, uma vez que o autor não queria nada além de inibição da prática do ilícito.

Portanto, não foi a tutela cautelar que se transformou em tutela inibitória. O procedimento instituído para a viabilidade da obtenção da tutela cautelar, por admitir liminar e a utilização de meios de execução adequados, é que foi utilizado para permitir o alcance da tutela inibitória. Contudo, como a sentença do procedimento que seria cautelar, quando era de procedência, prestava a tutela inibitória, e assim satisfazia a pretensão à tutela jurisdicional do direito, o procedimento que, a princípio, deveria ser seguido pelo procedimento de conhecimento, passou a ter configuração autônoma, fazendo surgir a falsa ideia de “ação cautelar satisfativa”.

Frise-se que a ação deixou de ser cautelar para atender à necessidade de tutela inibitória, passando a ser satisfativa exatamente porque a tutela inibitória, ao contrário da cautelar, não é marcada pela instrumentalidade. Assim, esta “ação cautelar satisfativa” era, na realidade, uma ação inibitória (de conhecimento).

Por outro lado, a tutela que remove os efeitos concretos do ilícito impede, por mera consequência, a produção de danos. Ou seja, a busca e apreensão dos produtos, por exemplo, coloca os consumidores a salvo de eventuais danos.

Como a doutrina brasileira jamais fez a distinção entre ilícito e dano, ou soube demonstrar a importância de se ter em conta unicamente o ato contrário ao direito para a adequada tutela civil dos direitos, a prática forense foi obrigada a encontrar na tutela cautelar, vista como tutela contra a probabilidade do dano, um meio de garantir a tutela das situações substanciais protegidas por normas violadas.

Contudo, não é porque a doutrina e a prática forense olharam para o ilícito já ocorrido pensando na probabilidade do dano, que se poderá admitir que a “ação cautelar”, ao ter passado a servir para remover o ilícito, realmente tenha dado outra configuração à “tutela cautelar”.

A tutela cautelar sempre foi e será uma tutela de segurança, ou uma tutela assecuratória da tutela jurisdicional final. Em face da indistinção entre ato contrário ao direito e dano, ocorreu a distorção do uso da técnica cautelar para permitir o alcance da tutela de remoção do ilícito.

Não obstante, aqui a distorção não foi simplesmente procedimental, ou de técnica processual. A tutela de remoção se destina a remover os efeitos concretos de um ilícito já praticado e não a proteger contra a probabilidade do dano. Porém, imaginou-se que a tutela de remoção seria voltada contra a probabilidade de dano. Ou seja, a própria tutela de remoção foi desconfigurada



para, a partir desta transformação, admitir-se o emprego do procedimento cautelar.

De qualquer forma, o procedimento cautelar, por conter técnicas processuais efetivas, foi utilizado para viabilizar a tutela de remoção do ilícito. Do mesmo modo que o procedimento da tutela inibitória assumiu característica autônoma, o procedimento que passou a servir para a prestação da tutela de remoção igualmente dispensou a chamada “ação principal”. A necessidade de tutela de remoção – assim como de tutela inibitória – levaram à utilização e à distorção da técnica processual idealizada para a tutela cautelar.

As tutelas inibitória e de remoção, por serem satisfativas, não são instrumentais como a tutela cautelar, o que, por mera consequência lógica, fez com que o procedimento dotado de liminar e meios executivos idôneos adquirisse autonomia, dispensando o procedimento de conhecimento, o qual apenas teria sentido caso houvesse necessidade de outra tutela jurisdicional do direito, que então seria assegurada pela tutela cautelar.

Além do mais, é preciso advertir que a necessidade da obtenção da tutela do direito de modo mais célere também levou à utilização da técnica cautelar como meio de sumarização do processo de conhecimento.<sup>69</sup> É importante destacar interessante acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, julgando recurso ordinário em mandado de segurança, manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9.<sup>a</sup> Região que havia denegado mandado de segurança que objetivava cassar liminar – deferida inaudita altera parte em ação cautelar inominada – para reintegrar dirigente sindical nas suas funções. O Tribunal Superior do Trabalho, na ocasião, assim argumentou:

É bem verdade que o deferimento de liminar, assegurando a satisfação do direito material pleiteado, como, no caso, a reintegração, não se coadunaria com a natureza instrumental e provisória do processo cautelar. Entretanto, essa natureza jurídica da ação cautelar não pode subsistir em face do provimento de maior envergadura previsto na Constituição Federal, norma hierarquicamente superior. Com efeito, a dispensa de empregado, portador de estabilidade provisória, sem o competente inquérito administrativo faz letra morta a garantia constitucional insita no art. 8.º, inciso VIII, da Lei Maior e, em se tratando de dirigente sindical, impede, ainda, que o trabalhador exerça as funções para as quais foi eleito, beneficiando a empresa em detrimento de toda uma categoria profissional. O MM. Juiz da JCJ de Ponta Grossa, ao constatar que o empregado juntou documentação comprobatória de representação sindical, deferiu a liminar, adotando o entendimento de que ‘é preferível rejeitar-se uma teoria [rectius: uma tutela] que não atende à realidade social, principalmente no caso concreto, onde a suspensão dos salários implica em possível supressão dos meios de sobrevivência e a posterior reintegração implicaria pagamento de salário sem a prestação laboral’. Conceder, pois, a segurança impetrada pela empregadora, cassando a liminar e, conseqüentemente, anulando a reintegração efetivada, significaria premiar a empregadora, que, desrespeitando norma constitucional, foi a única causadora de toda a situação. Assim, frente à hierarquia da imperatividade insita no dispositivo da Carta Magna, que foi friamente desrespeitado pela ora impetrante, deve ser mantido o empregado no exercício pleno de suas funções, até que a empregadora, se porventura sair vencedora do competente inquérito, possa despedir legalmente o dirigente sindical.<sup>70</sup>

Esse julgado deixa evidenciada a deformação da técnica cautelar e, mais do que isto, a própria necessidade desta transformação em nome da efetividade da tutela dos direitos.<sup>71</sup>

Realmente, as necessidades de direito substancial também impuseram a distorção da técnica cautelar para a obtenção da tutela satisfativa de modo antecipado.<sup>72</sup> Mas não há como pensar que a prestação da tutela antecipada sob o manto protetor da técnica cautelar constituiu um abuso, uma vez que tal forma de tutela se mostrou imprescindível à efetiva proteção do direito material, e, assim, legítima, à luz do direito fundamental de ação.

Não obstante isto, a grande maioria dos tribunais e a quase totalidade da doutrina, anteriormente à instituição da tutela antecipatória (em 1994) no Código de Processo Civil de 1973, considerando a natureza da tutela cautelar, jamais admitiram que o juiz concedesse tutelas sumárias satisfativas com base na técnica cautelar. Anote-se, por exemplo, o que dizia Humberto Theodoro Júnior:

Por outro lado, como bem adverte Lopes da Costa, ‘a medida cautelar não deve transpor os limites que definem a sua natureza provisória’. Seu fito é apenas garantir a utilidade e eficácia da futura prestação jurisdicional satisfativa. Não pode, nem deve, a medida cautelar antecipar a decisão sobre o direito

material, pois não é de sua natureza autorizar uma espécie de execução provisória.<sup>73</sup>

Os tribunais, seguindo esta mesma ideia, afirmavam:

Não deve ser concedida a medida cautelar inominada em que o autor pretende lhe sejam franqueadas as dependências de um clube para realização de festa de casamento, em virtude do teor satisfativo de tal pedido, sendo que a sua concessão implicaria a perda do objeto da ação principal.<sup>74</sup>

Assim, ainda que a técnica cautelar tenha sido utilizada para permitir o alcance da tutela satisfativa sob cognição sumária – ou da tutela antecipada –, o certo é que isto não era aceito pelos tribunais e pela doutrina, que não conseguiam admitir o uso satisfativo da técnica cautelar, ainda que tal modo de proceder fosse indispensável à realização do direito fundamental de ação.

Ademais, a prática também chegou a admitir a ação cautelar como substituta do mandado de segurança que tivesse escoado o seu prazo decadencial. Os tribunais e o doutrinador, como mágicos, transformavam direito líquido e certo em *fumus boni iuris*. Na verdade, tal falsificação era aceita porque não havia a possibilidade de obtenção de medida liminar no procedimento ordinário. Mas a mesma doutrina que fingia não ver a transformação do direito líquido e certo em *fumus* não conseguia perceber que a ação cautelar, que passara a tratar do direito líquido e certo, na realidade era uma ação de conhecimento (de cognição exauriente) com liminar. Como no mandado de segurança, no procedimento da imaginada ação cautelar, após a apresentação da contestação, estava o juiz em condições de proferir sentença capaz de produzir coisa julgada material. Entretanto, como o juiz continuava supondo que a ação era verdadeiramente cautelar, o autor era compelido a propor a ação principal. E o juiz, prosseguindo com a brincadeira – que contava com o apoio da doutrina –, “julgava” a ação cautelar e a ação principal no mesmo momento, como se não fosse absolutamente ilógico afirmar que algo é provável e também existe. Ora, se o direito já pode ser reconhecido é por não ser mais apenas provável.

De qualquer forma, é indiscutível que a expansão da cautelar inominada significou um fenômeno de democratização do processo e de efetiva tutelabilidade jurisdicional dos direitos. Se o direito material é dependente, em nível de efetividade, do direito processual,<sup>75</sup> uma sociedade plural e democrática obviamente não pode conviver com o mito da uniformidade procedimental e, desta maneira, com um processo civil indiferente às diversas posições sociais e situações de direito material.

Mas, se lamentavelmente era assim no plano normativo-processual, o que se poderia fazer diante da inadequação da estrutura técnica do processo para atender à sociedade? Caberia calar o Poder Judiciário, obrigando-o a dar tutela aos direitos por meio de um modelo processual capaz de potencializar as desigualdades? Ora, a legislação processual não pode obstaculizar a efetividade da tutela dos direitos. Como o juiz tem o dever de interpretar as regras processuais a partir das necessidades do direito material e do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, cabe-lhe encontrar a técnica processual adequada à situação conflitiva concreta.

Foi em razão do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva – o qual evidentemente se impõe diante da impropriedade da técnica processual – que a ação cautelar inominada, diante das pressões sociais por tutela jurisdicional adequada, passou a ser utilizada como “ação autônoma e satisfativa”, capaz de propiciar as tutelas inibitória e de remoção do ilícito e a própria antecipação da tutela, que, em princípio, apenas poderia ser prestada depois de finalizado o processo de conhecimento<sup>76</sup>.

## 2.5 A introdução da tutela antecipada no Código de 1973

A necessidade de tutela antecipatória, evidenciada mediante o uso distorcido da técnica cautelar para a obtenção da tutela que apenas poderia ser concedida ao final do processo de conhecimento, levou o legislador a inserir nova norma (art. 273) no Código de Processo Civil de 1973. Esta norma, introduzida no Código em 1994, abriu oportunidade para o requerimento de tutela antecipatória em caso de perigo de dano<sup>77</sup> diante de qualquer espécie de situação material litigiosa.

A alteração do Código de Processo Civil foi necessária não apenas em razão das novas situações de direito material que se mostraram carentes de tutela satisfativa sumária, mas, frise-se, principalmente porque a doutrina e os tribunais não admitiam a prestação de tutela satisfativa (de tutela antecipatória) com base na técnica cautelar.

Portanto, o art. 273, I, além de corrigir o uso equivocado da técnica cautelar, teve o grande mérito de tornar inquestionável a viabilidade de se requerer tutela antecipatória em face de toda e qualquer situação conflitiva concreta.<sup>78</sup>

## **2.6 A zona de penumbra das tutelas cautelar e antecipada**

Quando se está diante das ações declaratória e constitutiva, é possível dizer que há tutela antecipatória quando da decisão sumária se extrai a realização de um direito ou de uma tutela de direito que teria como pressuposto as tutelas declaratória e constitutiva finais, ou seja, as tutelas declaratória e constitutiva eventualmente prestadas através das suas respectivas ações.

De outra parte, haveria tutela cautelar quando se assegura a situação jurídica tutelável. Isso acontece ao se extrair da decisão sumária a tutela de segurança da situação substancial a que se almeja tutelar através da sentença.

Lembre-se que a tutela de urgência é gênero, do qual são espécies a tutela antecipatória (baseada em perigo) e a tutela cautelar. A tutela antecipatória é antecipação stricto sensu da tutela perseguida no processo de conhecimento, mas também foi vista como tutela do direito que depende da declaração ou da (des)constituição. Lembre-se, por exemplo, da hipótese em que se proíbe a alienação de um imóvel até a resolução do pedido de desconstituição de deliberação assemblear. Nesse último caso há uma zona de penumbra entre tutela antecipada e tutela cautelar. Ao admiti-la, o legislador inseriu o § 7.º no art. 273 do código de 1973 dizendo que, se a título de tutela antecipatória for requerida providência de natureza cautelar, poderá o juiz, presentes os respectivos pressupostos, deferir a tutela cautelar em caráter incidental no processo instaurado.

Note-se, contudo, que tudo isto ocorreu em razão de que, muito embora o art. 273 tenha admitido requerimento de tutela antecipatória no processo de conhecimento, a tutela cautelar só podia ser postulada mediante ação cautelar. Como o legislador deixou de lado a tutela cautelar, a doutrina e a jurisprudência, atentas ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, deram interpretação extensiva ao art. 273 e ao próprio conceito de tutela antecipatória, concluindo que seria possível postular antecipação da tutela que depende da declaração ou da constituição. Caso a interpretação fosse outra, não seria possível requerer tutela de urgência com tal configuração nas ações declaratória e constitutiva – a menos que se estivesse pensando em antecipação da constituição ou da declaração. A tutela só poderia ser postulada mediante ação cautelar.

Vale dizer que a opção por um conceito amplo de tutela antecipatória – não restrito à antecipação da tutela do direito prestada mediante sentença condenatória, mandamental e executiva – é uma mera decorrência da necessidade de se interpretar as regras processuais em conformidade com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Isso porque um conceito teoricamente mais adequado de tutela antecipatória não pode deixar de preferir a ideia de que há tutela antecipatória apenas quando se antecipa a tutela do direito.

## **3. Da tutela cautelar às tutelas contra o ilícito**

### **3.1 Tutela contra o ilícito**

A tutela inibitória destina-se a impedir a violação de um direito. Mais precisamente, ela pode se voltar a impedir a prática de ato contrário ao direito, ou mesmo a sua repetição ou continuação.<sup>79</sup>

A sua compreensão requer a separação entre ato contrário ao direito e fato danoso. O conceito de ilícito civil, durante grande período de tempo, associou o ato contrário ao direito e o dano. Na verdade, embora a doutrina percebesse a distinção entre ato contrário ao direito e dano, supunha que o dano era indispensável para o ilícito ter relevância no âmbito civil ou que um ato contrário ao direito que não produzisse dano ali não teria significado.

A doutrina, para assim concluir, unificou as categorias da ilicitude e da responsabilidade civil, como se a tutela contra o ilícito apenas pudesse ser uma tutela contra o dano, isto é, uma tutela ressarcitória. A prática do ilícito, por ser a prática do dano, dava ao lesado a tutela ressarcitória, e, como o dano podia ser valorado em dinheiro, esta tutela era mais precisamente a tutela ressarcitória pelo equivalente ao valor do dano.

Portanto, a tutela contra o ilícito, para a doutrina clássica, tinha apenas o objetivo de outorgar tutela aos bens patrimoniais, supondo, por consequência, que o bem jurídico objeto da proteção jurisdicional era uma coisa dotada de valor de troca.

Porém, as novas situações substanciais evidenciaram a necessidade de se tutelar apenas contra o ato contrário ao direito e, assim, contra o ilícito que prescinde da sua normal consequência – o fato danoso. Basta lembrar que o Estado constitucional tem o dever de editar normas proibitivas ou impositivas de condutas para evitar danos aos direitos fundamentais. Para a efetiva atuação destas normas é imprescindível a tutela jurisdicional contra o ato contrário ao direito que deixou efeitos concretos que se propagam no tempo, como, por exemplo, o despejo de lixo tóxico em local proibido pela legislação ambiental.

A tutela contra o ilícito, neste caso, não se volta contra um dano, mas apenas contra um ato contrário ao direito que deixa marcas no tempo, constituindo, por assim dizer, uma fonte capaz de gerar danos. Percebe-se com nitidez, a partir daí, que o dano é uma consequência do ilícito e, mais do que isto, uma consequência eventual – não necessária – do ato contra o direito.<sup>80</sup>

Não há porque supor, nesta dimensão, que o interesse de agir na ação contra o ilícito seja dependente de um dano, a menos que se deseje limitar, sem qualquer justificação plausível, a função do processo civil à tutela contra o dano, como se o ato contrário ao direito continuasse a não lhe dizer respeito.

Não obstante, aí não haveria como explicar a tutela civil dos direitos coletivos e difusos, para a qual é imprescindível a atuação do desejo das normas de proteção e, desta forma, a tutela contra o ato contrário ao direito ou, mais precisamente, a tutela capaz de remover os efeitos concretos deixados pela ação contra ius.

De modo que, se a distinção entre ilícito e dano sempre foi identificável na perspectiva lógica, hoje ela é imprescindível para a construção de uma teoria capaz de dar conta da necessidade de tutela das novas situações de direito substancial.

Se existe tutela posterior ao ilícito, que não se confunde com a tutela contra o dano, há tutela anterior ao ilícito, que não requer a probabilidade de dano. Trata-se da tutela inibitória, cujo pressuposto único é a ameaça da prática de ato contrário ao direito.<sup>81</sup>

A tutela que não se volta contra o dano, seja posterior ou anterior ao ilícito, também se desliga do pressuposto da culpa. A culpa é um critério para a imputação ressarcitória, ou melhor, um critério para a responsabilização pelo dano, sendo totalmente prescindível à tutela contra o ilícito e, com mais evidência, para a tutela contra a ameaça de ilícito.

É absurdo imaginar que alguém, para corrigir ou evitar um ilícito, tenha que demonstrar culpa. O direito de evitar a propagação dos efeitos concretos do ilícito e de inibir o ilícito logicamente não depende de culpa. Ninguém pode impedir a concessão de qualquer destas tutelas afirmando não ter culpa. Exemplificando: ninguém pode alegar, para descaracterizar a tutela de remoção do ilícito, que não agiu com culpa ao colocar produto com composição proibida no mercado, ou afirmar que não sabia que determinada marca comercial pertencia a outrem para ver denegada a tutela inibitória.

Diante de tudo isto, não é apenas importante sublinhar que o direito à tutela inibitória não requer sequer afirmação de probabilidade de dano – bastando a alegação de ameaça de violação de direito –, mas também evidenciar que o dano e a culpa não podem ser objeto da cognição do juiz, da investigação probatória ou da discussão das partes na ação endereçada à obtenção da

tutela. O juiz não pode pensar em negar a tutela inibitória por falta de probabilidade de dano, como também não pode exigir do autor a sua demonstração. Do mesmo modo, o réu não pode se defender alegando a inexistência de probabilidade de dano.

Isso não significa que a probabilidade de dano não possa ser alegada pelo autor. Lembre-se que o dano, por muitas vezes ocorrer no mesmo instante do ilícito, facilmente identifica e evidencia o ato contra o direito. O que se quer deixar claro é que o dano não precisa ser necessariamente invocado e demonstrado para a obtenção da tutela contra o ilícito.<sup>82</sup>

Note-se que, do ponto de vista probatório, é muito mais fácil provar a probabilidade da prática de ato contrário ao direito do que a probabilidade de dano. Esclareça-se, porém, que dizer que basta a probabilidade de ilícito obviamente não significa excluir do campo probatório da ação inibitória a questão da própria ilicitude, mediante a limitação da cognição judicial à probabilidade de uma “ação física”. Exige-se, além da probabilidade desta ação ou de um agir, a demonstração de que este agir é ilícito, através do confronto entre a descrição do ato temido e o direito.

De outro lado, é preciso sublinhar que a tutela inibitória, ao ter como pressuposto somente a ameaça da prática de ato contrário ao direito, pode ser utilizada não apenas quando se teme uma primeira violação, mas também quando se teme a sua repetição ou mesmo a continuação da atividade ilícita. Quer isto dizer que a tutela inibitória pode impedir a publicação de notícia lesiva a direito da personalidade ou mesmo a difusão da publicação de notícias lesivas, assim como inibir a utilização de marca comercial ou a repetição do seu uso. E, ainda, pode inibir a continuação de atividade ilícita, como o prosseguimento de atividade poluidora.

A circunstância de a tutela impedir a repetição ou a continuação do ilícito e, portanto, aceitar um ilícito já praticado, certamente não lhe retira a natureza preventiva. A tutela, mesmo nestas duas hipóteses, é voltada para o futuro, ou melhor, para proteger contra algo que ainda não aconteceu, mas apenas pode vir a ocorrer. Contra o que já aconteceu – por exemplo, ilícito que deixou marcas concretas ou dano derivado do ilícito –, terão que ser requeridas, respectivamente, a tutela de remoção do ilícito e a tutela ressarcitória. Em resumo, para efeito de tutela inibitória não tem qualquer relevância o dano ou o ilícito que já ocorreu e cuja repetição ou continuação não se teme.

### **3.2 O direito material à tutela de prevenção do ilícito**

A tutela do direito é decorrência da existência do próprio direito. A tutela inibitória é inerente à existência do direito. Todo cidadão tem o direito de impedir a violação do seu direito.

Como é evidente, não basta que o ordenamento jurídico afirme um direito, sendo imprescindível lhe conferir tutela ou proteção. Porém, um ordenamento jurídico caracterizado pela proibição da autotutela certamente deve propiciar adequada tutela jurisdicional aos direitos.

Assim, a consagração de direitos faz surgir, por consequência lógica, o direito à tutela jurisdicional, isto é, o direito de pedir, conforme o caso, o impedimento da sua violação, a sua reparação etc. De modo que o direito à tutela jurisdicional inibitória é decorrência natural do direito material.<sup>83</sup> Portanto, a tutela inibitória – que é a genuína tutela preventiva – é imanente a qualquer ordenamento jurídico que se empenhe em proteger – e não apenas em proclamar – os direitos.

Sublinhe-se, porém, que o direito à tutela do direito não se confunde com o direito de ação. O direito fundamental de ação (à tutela jurisdicional efetiva) garante as técnicas processuais adequadas à prestação da efetiva tutela do direito material. Ou seja, a tutela inibitória deriva do direito material, enquanto a ação capaz de prestá-la está ancorada no direito fundamental de ação.

O direito de buscar a tutela inibitória através da ação evidencia que o direito de ação, apesar de abstrato e atípico, outorga o direito às técnicas processuais idôneas à perseguição da tutela inibitória. Trata-se, mais precisamente, da ação adequada a permitir, obviamente que no caso de o direito material ser reconhecido, a obtenção da tutela inibitória.<sup>84</sup>



### 3.3 Tutela inibitória como tutela específica do direito material

A tutela do direito material é específica quando preocupada com a proteção da integridade do direito. É a tutela que se contrapõe à tutela pelo equivalente ao valor do dano ou ao valor da prestação. Em outras palavras, a tutela específica não se conforma com a transformação do direito em pecúnia, constituindo uma tutela que i) inibe a ocorrência do ilícito, ii) remove os efeitos concretos derivados do ato ilícito, iii) repara o dano na forma específica ou iv) garante o cumprimento específico da prestação inadimplida ou adimplida de modo imperfeito, isto é, com vício.

Como está claro, a tutela específica não é algo que faz parte do aparato de técnicas disponibilizadas pelo direito processual, e assim não pode ser confundida com a técnica antecipatória, com a sentença mandamental e assim por diante. A tutela específica está no plano do direito material, de modo que deve ser proporcionada pelas técnicas processuais.

Assim, é fácil perceber que a tutela inibitória é a mais importante das espécies de tutela específica, eis que voltada a impedir a violação do direito, não servindo apenas a estabelecer i) a situação anterior à da violação do direito ou a situação que existiria caso a norma houvesse sido observada (tutela de remoção do ilícito); ii) a situação que existiria caso o dano não houvesse ocorrido (tutela ressarcitória na forma específica); e iii) o cumprimento da obrigação na forma específica ou de modo perfeito (tutela do adimplemento na forma específica).

Lembre-se que, quando os arts. 536 do CPC e 84 do CDC aludem a “tutela específica”, eles se referem à tutela específica do direito material, deixando um recado para os operadores do direito no sentido de que as tutelas específicas do direito material poderão ser obtidas mediante o uso das técnicas processuais presentes nos parágrafos dos arts. 536 do CPC e 84 do CDC, conforme a particular necessidade de tutela do direito material e as peculiaridades do caso concreto.<sup>85</sup>

As técnicas processuais presentes em tais normas permitem a construção da ação adequada ao caso concreto e, assim, a construção da ação adequada à obtenção da tutela inibitória.<sup>86</sup> Deixe-se claro, portanto, que os arts. 536 do CPC e 84 do CDC não outorgam o direito à tutela específica, mas apenas instituem técnicas processuais – em resposta ao direito fundamental de ação – para viabilizar a obtenção da tutela específica do direito material.

### 3.4 Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito

Os fundamentos da tutela inibitória servem à tutela de remoção do ilícito. A tutela de remoção do ilícito, assim como a tutela inibitória, é uma tutela que prescinde de dano e da investigação de culpa. Também há direito material à tutela de remoção do ilícito, que constitui, ademais disto, uma tutela específica do direito material, que pode ser alcançada mediante ação construída com base nos arts. 536 do CPC e 84 do CDC.

A tutela de remoção do ilícito é posterior à prática do ato ilícito. Ela não inibe o ilícito, pois se dirige contra seus efeitos concretos, independentemente de eventual dano. A tutela objetiva remover ou eliminar a potencial causa do dano; não visa ao ressarcimento pelo dano. No caso de tutela de remoção do ilícito, é suficiente a transgressão de um comando jurídico, pouco importando se o interesse privado tutelado pela norma foi efetivamente lesado ou se ocorreu um dano. Como explica Michele Mòcciola, em ensaio publicado na Rivista Critica del Diritto Privato, a consequência lógica da distinção entre dano e ilícito conduz à formulação do critério segundo o qual, todas as vezes em que a intervenção judiciária tem por objeto a fonte do dano, não há tutela ressarcitória.<sup>87</sup>

Porém, para que haja interesse em uma tutela que, sendo posterior ao ilícito, não se destine a ressarcir o dano, é preciso que a ação contrária ao direito deixe marcas concretas que, propagando-se no tempo, constituam uma fonte aberta à produção de danos. Ou seja, há casos em que a ação contra ius produz efeitos concretos que, mantendo-se no tempo, constituem exatamente o reflexo da conduta proibida pela norma de proteção do direito.

É o caso, por exemplo, do despejo de lixo tóxico em local não autorizado pela legislação ambiental. Ilícito é despejar o lixo tóxico; o dano que pode ser produzido diante deste despejo é outra questão. A permanência do lixo tóxico em local inadequado é o efeito concreto derivado da ação ilícita, constituindo-se em fonte aberta à produção do dano. Este efeito concreto, por ser derivado de uma ação passada, não pode ser inibido, mas apenas removido.

Note-se, na mesma linha, que expor à venda produto com composição nociva à saúde também não constitui dano, mas conduta que abre oportunidade à produção de dano. O produto ilegalmente exposto à venda deve ser apreendido exatamente para que o ilícito, cujos efeitos concretos perduram no tempo, seja removido.

Se a tutela de remoção do ilícito – que pode se realizar mediante o emprego de técnicas executivas diversas, como a busca e apreensão de produto ilícito – não se dirige contra o dano, ela também não requer a presença de culpa, que é um critério para a imposição do ressarcimento. Em resumo, para a concessão da tutela de remoção do ilícito não há que se cogitar de dano e de culpa, bastando que do ilícito tenham perdurado efeitos concretos.

De outro lado, a tutela de remoção do ilícito é uma resposta ao direito material ou, mais precisamente, à necessidade de atuação do desejo de proteção da própria norma violada pela ação ilícita. Assim como há direito de impedir o ilícito, há evidente direito material de remover os efeitos concretos derivados do ilícito.

Na verdade, a possibilidade de se obter tutela posterior à violação da norma e independentemente da existência de dano tem relação com o próprio conceito de norma, uma vez que, se a única sanção contra o ilícito fosse a obrigação de ressarcir em virtude do dano, a própria razão de ser da norma jurídica estaria comprometida.

Além disto, a tutela de remoção do ilícito, do mesmo modo que a tutela inibitória, representa espécie de tutela específica, obtenível a partir de ação construída com base nas técnicas dos arts. 536 do CPC e 84 do CDC, conforme a ação se destine a tutelar direito individual ou direito difuso ou coletivo.<sup>88</sup>

### **3.5 Tutela inibitória e tutela cautelar**

Repita-se que o autor, para obter tutela inibitória, não precisa demonstrar probabilidade de dano, mas apenas ameaça da prática de ato contrário ao direito. É certo que, em razão de o ato contra o direito e o fato danoso poderem ocorrer no mesmo instante, a tutela inibitória frequentemente impede o próprio dano. Porém, importa destacar que a probabilidade do dano não é exigência para a concessão da inibitória; basta a ameaça do ilícito.

A tutela inibitória é preventiva, pois é capaz de impedir a violação do direito. A tutela cautelar, em princípio, destina-se a assegurar a efetividade da tutela repressiva, isto é, da tutela do direito devida em virtude da prática de um dano, do descumprimento de um dever ou do inadimplemento de uma prestação.

A tutela cautelar, de lado as tutelas declaratória e constitutiva, é requerida após a prática do dano ou da violação do direito, ou para a hipótese da prática de dano ou de violação de direito. Assim, após a prestação ter sido inadimplida, o arresto pode ser requerido para assegurar a efetividade da tutela do direito de crédito. Na segunda situação, para a hipótese da prática de dano, pode ser requerida a caução de dano infecto para assegurar a efetividade da tutela ressarcitória.

Embora em ambos os casos haja um perigo de dano, esse recai sobre a efetividade da tutela que responde ao autor por uma violação de direito ou por um dano. Ou seja, tal tutela não se dirige a impedir o dano ou a violação do direito, mas a assegurar a efetividade da tutela contra o dano ou contra a violação do direito.

Lembre-se que a tutela cautelar não foi idealizada para impedir a violação do direito. Isto não apenas pelo motivo de que, na época em que foi concebida, a doutrina confundia o ilícito civil com



o fato danoso,<sup>89</sup> mas igualmente em virtude de que as técnicas processuais idealizadas para a tutela dos direitos, no processo civil clássico, não foram pensadas para permitir a tutela de inibição do ilícito. Na verdade, a tutela cautelar não podia ser pensada – em vista do ambiente cultural em que foi moldada<sup>90</sup> –, assim como não o foi – como prova a estrutura do processo civil clássico, inclusive o arresto cautelar (que nunca foi preventivo) – como tutela preventiva.<sup>91</sup>

Ovídio Baptista da Silva não aceitou esta conclusão, tendo feita a seguinte advertência:

Será lícito dizer que a tutela cautelar ‘nunca propiciou uma tutela preventiva’, se considerarmos, por exemplo, o arresto que nos acompanha desde o direito medieval; e o sequestro que nos foi transmitido pelo direito romano? Quem negaria o caráter cautelar e preventivo desses tradicionais instrumentos do direito moderno? Quem negaria o caráter preventivo das cauções, tanto no vastíssimo campo do direito material, público e privado, quanto no domínio do direito processual? E, assim como haverá cauções satisfativas, como as negociais, incontáveis serão as hipóteses em que elas assumem a natureza cautelar, e tanto umas quanto as outras preventivas. Se os provvedimenti cautelari de Calamandrei ‘nunca foram capazes de propiciar uma tutela preventiva’, não será justo atribuir a culpa por essa incompetência à tutela cautelar autêntica (tutela de ‘simples segurança’, portanto não satisfativa, por definição), como o concebeu, em páginas insuperáveis, Pontes de Miranda, cuja doutrina sobre ‘pretensão à segurança’, porém, não mereceu menção, ainda que fosse para criticá-la, na obra do talentoso jurista paranaense, não obstante seu elogiável acervo bibliográfico e o permanente diálogo mantido, ao longo da obra, com os autores italianos modernos que, com sabemos, conservam-se religiosamente fiéis ao paradigma.<sup>92</sup>

Reafirmamos o nosso ponto de vista. Observe-se que o arresto e o sequestro aceitam a violação do direito (rigorosamente a pressupõe), não servindo para impedir a prática de ato ilícito. A legitimidade do arresto é subordinada à existência de um dano anterior, cuja afirmação, aliás, é imprescindível para o pedido de tutela ressarcitória. O arresto se destina a assegurar a frutuosidade da tutela ressarcitória.

E a situação é exatamente a mesma no caso de caução de dano infecto. Diz o art. 1.280 do Código Civil:

O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução contra o prejuízo eventual.

E o art. 1.281 do mesmo Código:

O proprietário ou o possuidor de um prédio, em que alguém tenha o direito de fazer obras, pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual.

Assim como a tutela cautelar pode ser requerida depois que o dano já foi praticado, igualmente pode ser requerida para a hipótese da prática de dano ou de forma autônoma a uma eventual – porque não se sabe se o dano ocorrerá – ação ressarcitória. E isto fica claro mediante a simples leitura das normas do Código Civil acima descritas. A caução é requerida em face de um “prejuízo eventual”. Portanto, o arresto e a caução sempre são requeridos em vista do direito à tutela ressarcitória, que nada mais é do que uma proteção ou tutela contra o dano. A caução de dano infecto e o arresto nada têm de preventivos; especialmente quando desnudada a real função preventiva da tutela jurisdicional, que é a de evitar a violação do direito. Compare-se o que se alcança com o arresto e o que se obtém com a tutela inibitória que impede a violação do direito ambiental. É indiscutível que a primeira tutela assegura a tutela ressarcitória, enquanto a segunda impede a violação do direito, constituindo, esta sim, uma tutela preventiva, desligada de qualquer instrumentalidade ou referibilidade. Enquanto a tutela cautelar assegura a tutela ressarcitória, a tutela inibitória independe de outra forma de tutela.

Aliás, a própria lição de Pontes de Miranda está de acordo com o nosso pensamento. Quando Pontes se refere à tutela cautelar como segurança-para-execução, pressupõe título e inadimplemento, isto é, violação do direito, não demonstrando qualquer preocupação com uma tutela jurisdicional capaz de impedir a violação do direito.

Ou seja, o fato de a tutela cautelar não poder propiciar tutela preventiva não tem relação de causa e efeito com os provvedimenti d’urgenza do art. 700 do Código de Processo Civil italiano ou

com a doutrina de Calamandrei. A tutela cautelar não pode propiciar tutela preventiva exatamente porque significa segurança de uma tutela que, em regra, é ressarcitória pelo equivalente ou do adimplemento de obrigação de pagar dinheiro – tutelas estas que se implementam com a execução.<sup>93</sup> Como está claro, o arresto e o sequestro não constituem tutela preventiva, mas sim tutela de segurança da tutela repressiva.

Confirma-se, assim, o que antes foi dito: o arresto admite a ocorrência do dano, cingindo-se a assegurar a concretização da tutela ressarcitória. Esta tutela cautelar aceita a violação do direito, tendo o fim de assegurar a efetividade da tutela repressiva.

A tutela cautelar, ao ser concebida, e, inclusive, incorporar a figura do arresto, certamente não podia abranger a inibitória, pois é ilógico conceber uma tutela preventiva como instrumento de um processo repressivo. É absurdo imaginar que, em um sistema que trabalhava com sentenças (declaratória, constitutiva e condenatória) que não viabilizavam tutela preventiva, a tutela cautelar pudesse ir além da sua função de segurança do processo, extrapolando dos seus limites para dar tutela preventiva ao direito material e, assim, eliminar a própria característica de instrumentalidade que lhe foi conferida.<sup>94</sup>

A tutela cautelar passou a ser admitida como tutela preventiva quando a prática forense percebeu que as novas situações de direito material necessitavam de uma tutela capaz de impedir o ilícito. A transformação da tutela de segurança em tutela preventiva fez com que se percebesse que essa tutela, por ser uma tutela não caracterizada pela instrumentalidade, não necessitava de duas ações processuais, ou de uma ação principal seguindo a ação que passou a ser rotulada de cautelar. Na verdade, o fenômeno da “ação cautelar autônoma” é apenas a mostra sensível de que o veículo processual idealizado para a tutela cautelar (dotado de liminar e sentença mandamental) passou a ser utilizado para a obtenção da tutela inibitória (tutela preventiva). Porém, como a tutela inibitória impede a violação, satisfazendo o desejo de tutela jurisdicional, é claro que a ação que a veicula apenas pode ser autônoma, dispensando qualquer ação principal. Melhor explicando: a prática não apenas admitiu a busca de tutela inibitória a partir de ação rotulada de cautelar – em virtude das suas particularidades, desenhadas para atender a uma situação de urgência –, mas foi além, aceitando a transformação do próprio procedimento cautelar para atender à natureza desta tutela de direito.

Atualmente, quem deseja obter tutela capaz de impedir a violação de direito deve propor ação inibitória, construída com base nas técnicas processuais presentes no art. 536 do CPC; nunca ação baseada no art. 305 do Código de Processo Civil, que, por exigir a formulação de “pedido principal” (art. 308, CPC), obviamente não se presta à obtenção de tutela inibitória ou de qualquer tutela satisfativa do direito material.

### **3.6 Tutela de remoção do ilícito e tutela cautelar**

A tutela de remoção do ilícito objetiva eliminar os efeitos concretos posteriores à prática da ação ilícita, nada tendo a ver com a probabilidade de dano. Não obstante, em virtude da não percepção da distinção entre ilícito e dano ou da não compreensão da necessidade de uma tutela civil dirigida unicamente contra o ilícito, a prática forense não conseguiu admitir outra coisa além de uma tutela voltada contra a probabilidade do dano. Assim, por exemplo, no caso de exposição à venda de produto com composição proibida, afirmava-se a probabilidade do dano à saúde do consumidor para se requerer tutela cautelar.

Ou seja, como a doutrina brasileira jamais pensou em uma tutela voltada a remover o ilícito, imaginou-se que a sua natureza fosse cautelar. Porém, isso é consequência da falta de distinção entre o ilícito e a sua consequência eventual, que é o dano. Como a tutela de remoção do ilícito, por mera consequência, impede a produção do dano, confundiu-se tutela contra o ilícito já praticado (remoção do ilícito) e tutela contra a probabilidade do dano.

A busca e apreensão de produto com composição ilícita constitui técnica processual de remoção do ilícito, que satisfaz por si mesma. Se a busca e apreensão, ao remover o ilícito, acaba colaborando com a prevenção do dano, a verdade é que o seu fundamento não está na

probabilidade do dano, mas sim na prática do ilícito. De modo que o autor, em tal ação (de remoção do ilícito), deve afirmar a prática de um ilícito de eficácia continuada e não simplesmente a probabilidade de dano.

Realmente, o mais grave é que se admitia, nestas situações, a discussão do dano, exigindo-se do juiz a formação de convicção acerca da probabilidade do dano para a concessão da tutela jurisdicional. Porém, quando se toma consciência da imprescindibilidade da tutela civil contra o ilícito, fica fácil ver que, para a sua obtenção, basta afirmar e demonstrar a ocorrência de um ato contrário ao direito cujos efeitos concretos se prolongam no tempo, constituindo uma fonte aberta à produção de danos.

Além disto, como a tutela de remoção do ilícito é satisfativa, não se revestindo da instrumentalidade característica à tutela cautelar, não há como imaginar, neste caso, a necessidade de um “pedido principal”. A tutela de remoção deve ser buscada através de ação estruturada com base nas técnicas do art. 536 do Código de Processo Civil. Portanto, de ação de conhecimento dotada de técnicas processuais idôneas à obtenção de tutela específica, gênero em que está inserida a tutela de remoção do ilícito, assim como a tutela inibitória.

Como está claro, a ação do art. 305 não é adequada para a prestação da tutela de remoção do ilícito. Essa tutela, assim com a inibitória, não pode ser considerada instrumento de nenhuma das tutelas satisfativas do direito material, como a ressarcitória. As tutelas inibitória e de remoção do ilícito não se caracterizam pela instrumentalidade, não sendo marcadas pela referibilidade a uma outra tutela.<sup>95</sup>

#### **4. Tutelas cautelar, antecipada, inibitória e de remoção do ilícito**

##### **4.1 Tutelas cautelar e antecipada como tutelas interinais de urgência**

A tutela cautelar é uma tutela de segurança; assegura a viabilidade da obtenção da tutela satisfativa do direito material. A tutela antecipatória, por sua vez, é a própria tutela almejada através da ação, porém concedida com base em cognição sumária.

Na tutela cautelar, o perigo de dano coloca sob risco a tutela satisfativa do direito, que resta ameaçada de não ser prestada de forma útil e efetiva. Na tutela antecipatória, o perigo, derivado da demora do procedimento, faz ver a necessidade de antecipar, total ou parcialmente, a tutela do direito – que, no caso de sentença de procedência, seria devida ao final do procedimento.

A tutela cautelar assegura, enquanto a tutela antecipatória tem a sua substância dependente da própria natureza da tutela final. Ou seja, a tutela antecipada pode ser inibitória, de remoção do ilícito etc., ao passo que a tutela cautelar é sempre de segurança.

Porém, tanto a tutela cautelar, quanto a tutela antecipatória, são relacionadas a uma tutela final ou principal e neste sentido podem ser ditas interinais, no sentido de que não aspiram a assumir a característica de independência em relação a outra forma de tutela. Se a tutela cautelar satisfaz apenas ao assegurar, a tutela antecipatória, embora satisfaça a pretensão à tutela do direito, não é dotada de definitividade. Ou melhor: a tutela cautelar não é satisfativa da pretensão à tutela do direito e a tutela antecipatória não responde, de modo definitivo, à pretensão à tutela do direito.

##### **4.2 As tutelas inibitória e de remoção do ilícito como tutelas autônomas contra o ilícito**

A tutela cautelar é vocacionada a garantir uma tutela satisfativa (e por isto não é autônoma), embora a ação cautelar, em alguns casos, possa dispensar a propositura de uma ação principal. A tutela antecipatória, por sua vez, não é definitiva, dependendo, para tanto, do juízo final.

Porém, as tutelas inibitórias e de remoção do ilícito nada têm de instrumentais ou provisórias. A primeira inibe a prática de ato contrário ao direito e a segunda remove os efeitos continuados do ilícito. Ambas são autônomas, voltando-se, respectivamente, contra a ameaça de ilícito e contra o ilícito já praticado, independentemente de qualquer outra forma de tutela. E as duas são dotadas

de definitividade, constituindo, antes de tudo, tutelas finais concedidas sob o signo da cognição exauriente, embora possam ser antecipadas.

## **5. O tempo enquanto ônus e a necessidade da sua distribuição: a tutela da evidência e a ideia de abuso de direito de defesa**

### **5.1. O tempo do processo como ônus e a necessidade da sua distribuição entre as partes**

No processo de conhecimento clássico – destituído de tutela antecipatória –, o tempo do processo é suportado unicamente pelo autor, independentemente das particularidades da situação de direito material e do caso litigioso. Isso certamente não é justo nem está de acordo com a necessidade de se prestar tutela jurisdicional adequada às pessoas. O tempo do processo não pode prejudicar o autor e beneficiar o réu, já que o Estado, quando proibiu a justiça de mão própria, assumiu o compromisso de, além de tutelar de forma pronta e efetiva os direitos, tratar os litigantes de forma isonômica<sup>96</sup>.

É possível distribuir o tempo do processo através dos procedimentos especiais, elaborados a partir das técnicas da cognição.<sup>97</sup> Os procedimentos que impedem a discussão de determinadas questões (cognição parcial), que restringem o uso das provas (por exemplo mandado de segurança; cognição exauriente secundum eventum probationis) ou mesmo que são de cognição plena e exauriente mas dotados de tutela antecipatória, permitem uma melhor distribuição do tempo da justiça.<sup>98</sup>

Porém, tratando-se do procedimento comum, não há outra alternativa a não ser inserir no seu interior uma técnica capaz de permitir a distribuição do tempo do processo, como se fez pela primeira vez no direito brasileiro mediante o art. 273 do CPC/1973. A distribuição do ônus do tempo no procedimento comum é imprescindível para a democratização do processo civil, pois evita que o tempo seja tratado de forma diferenciada apenas diante dos procedimentos especiais, que, como o próprio nome indica, preocupam-se apenas com situações especiais, esquecendo que a questão da distribuição do tempo é vital diante de toda e qualquer situação litigiosa concreta.

Afigura-se completamente irracional obrigar o autor a sofrer com a demora quando, por exemplo, os fatos constitutivos são provados por meio de documento e o réu apresenta defesa de mérito indireta infundada que exige instrução dilatória. Para que impere a igualdade no processo é preciso que o tempo seja isonomicamente distribuído entre os litigantes<sup>99</sup>. O tempo deve ser repartido no procedimento de acordo com o índice de probabilidade de que o autor tenha direito ao bem disputado.<sup>100</sup> Esta probabilidade está associada à evidência do direito do autor e à fragilidade da defesa do réu. Quando o direito do autor é evidente e a defesa do réu carece de seriedade, surge a tutela da evidência como técnica de distribuição do ônus do tempo do processo, pois de outra forma uma defesa abusiva estará protelando a tutela jurisdicional do direito.

### **5.2. A falsidade do princípio da nulla executio sine titulo diante do conflito entre o direito à tutela tempestiva e o direito à cognição definitiva**

A teoria processual clássica, ao conceituar os processos, chamou de processo de conhecimento o destinado a verificar a existência do direito e de processo de execução o voltado a realizar o direito declarado pelo primeiro. O processo de conhecimento deveria averiguar a existência do direito alegado para que o juiz pudesse declarar (ou não) a existência do direito afirmado, sendo que a execução somente poderia iniciar após o término do processo de conhecimento.

O que importa, para bem situar o problema, é que a execução teria como pressuposto a declaração do direito ou a coisa julgada material. A coisa julgada material, nesta dimensão, foi considerada o fundamento lógico-jurídico da execução. Se o trânsito em julgado da sentença seria imprescindível para a formação do título executivo judicial, nenhuma diferença poderia haver em se falar que a coisa julgada é o fundamento lógico-jurídico da execução ou que esta depende de uma sentença transitada em julgado.

O princípio da nulla executio sine titulo foi concebido para deixar claro que a execução não

poderia ser iniciada sem título, que deveria conter em si um direito já declarado ou não mais passível de discussão. O pensamento clássico pode ser compreendido através da seguinte lição de Carlo Furno:

A impossibilidade de recorrer diretamente à via executiva e a necessidade consequente de obter um título executivo judicial através de um processo de conhecimento se explicam facilmente pela existência de uma situação jurídica substancial caracterizada pelo elemento de incerteza. Com base neste pressuposto, dada a necessidade de se eliminar a incerteza sobre a situação jurídica substancial, a ação não pode ser exercitada senão em via declaratória, a fim de que o antecedente lógico-jurídico da execução, que é a aptidão da ação para ser exercida ‘in executivis’, encontre sua base na declaração e sua realização na criação do título que condiciona a instauração da via executiva.<sup>101</sup>

Como se vê, há aí uma associação muito íntima e evidente entre “descoberta da verdade”, realização plena do princípio do contraditório, declaração, coisa julgada material e título executivo judicial. Atrás do princípio da nulla executio sine titulo está escondida a ideia de que a esfera jurídica do devedor não pode ser atingida sem a descoberta da verdade e a realização plena do princípio do contraditório.

De qualquer forma, a ideia de que a execução depende do exaurimento do processo de conhecimento está ligada à premissa de que o juízo de cognição sumária, exatamente por ser um juízo que postecipa o direito de defesa, não é suficiente para a instauração da execução. A execução, neste sentido, sempre dependeu da “certeza jurídica”.<sup>102</sup> É o próprio Chiovenda quem confessa:

Entrementes, pode ocorrer a figura duma sentença não definitiva, mas executória, e, pois, a separação entre a definitividade da cognição e a executoriedade. É o que sucede, em primeiro lugar, quando a condenação é confirmada ou proferida em grau de apelação, e isso porque a sentença de apelação, se bem que não definitiva, por sujeita a cassação, é todavia executória, uma vez que o recurso para a cassação não suspende a execução da sentença. Conquanto seja essa uma figura anormal, porque nos apresenta uma ação executória descoincidente, de fato, da certeza jurídica...<sup>103</sup>

A “execução provisória” da sentença seria uma figura anormal exatamente por não pressupor a “certeza jurídica”. Entretanto, a certeza jurídica, ou a coisa julgada material, em vista das novas necessidades de tutela, não mais pode constituir o pressuposto lógico-jurídico para a instauração da execução.

As novas exigências de tutela jurisdicional – responsáveis, inclusive, pela transformação da tutela cautelar em técnica de sumarização – transformaram o princípio da nulla executio sine titulo em mito. Recorde-se que a tutela antecipatória, na maioria dos casos, antecipa a própria execução.<sup>104</sup> Como já disse Ovídio Baptista da Silva,

a introdução em nosso direito de uma forma de tutela antecipatória – tão extensa quanto o permite a sua conceituação, como tutela genérica e indeterminada – invalida todos os pressupostos teóricos que sustentam o processo de conhecimento, pois as antecipações de julgamento, idôneas para provocarem tutela antecipatória, pressupõem demandas que contenham, conjugadas e simultâneas, as atividades de conhecimento e execução.<sup>105</sup>

No procedimento comum, há enorme conflito entre o direito à cognição definitiva (direito de defesa) e o direito à tempestividade da tutela jurisdicional. Para que o autor não seja prejudicado pela demora do processo, deve atuar, no interior do procedimento de cognição plena e exauriente, uma técnica que permita a antecipação da execução.

Ora, se é inegável a existência de conflito entre o direito à tempestividade da tutela e o direito à cognição definitiva e é sabido que o réu tem interesse em utilizar o processo para conservar o status quo pelo maior espaço de tempo possível, deve ser admissível a antecipação da execução nos casos de direitos evidentes e de defesas infundadas. Não há outra alternativa para o processo não prejudicar o autor que tem razão.

Na verdade, uma postura dogmática coerente com a realidade impõe a redefinição do conceito de título executivo, indagando-se se a qualidade de título executivo pode ser conferida a um provimento sumário. Não há qualquer razão, digna de consideração, que impeça um provimento



sumário de constituir título executivo, pois abrir a via executiva a um direito não é uma consequência da sua existência, mas uma simples opção pela sua realização prática. Desta forma, é certo, a tutela jurisdicional passa a ser muito mais execução do que declaração e coisa julgada material, mas esta é uma decorrência das novas exigências de tutela e do conflito – que é ineliminável – entre segurança e efetividade.

### **5.3. Evidência do direito e fragilidade da defesa**

No jogo entre a tempestividade e a segurança, a tutela da evidência ou a distribuição do tempo do processo somente é possível quando a defesa deixar entrever a grande probabilidade de o autor resultar vitorioso e, conseqüentemente, a injusta espera para a realização do direito.

A tutela da evidência tem similar no direito comparado no *référé provision* do direito francês. É possível a antecipação mediante a provision na hipótese em que “a obrigação não é seriamente contestável” (“*l’obligation n’est pas sérieusement contestable*”; artigos 809, II e 849, II, do Código de Processo Civil francês).<sup>106</sup>

Como demonstra Roger Perrot, a provision não requer o requisito da urgência e o juiz não pode exigir uma incontestabilidade absoluta, sob pena de restringir abusivamente o domínio do *référé provision*.<sup>107</sup> O *référé provision*, assim, é uma forma de tutela dos direitos evidentes.

Um direito é evidenciado de pronto quando é demonstrado desde logo. Para a tutela da evidência, contudo, são necessárias a evidência do direito do autor e a fragilidade da defesa do réu, não bastando apenas a caracterização da primeira. A defesa deve ser frágil, de modo que o seu exercício, ao dilatar a demora do processo, configure abuso. Note-se, aliás, que de lado o inciso I do art. 311 – que fala expressamente em abuso de direito de defesa –, os demais incisos deste artigo representam hipóteses em que o direito é evidente e a defesa de mérito indireta deve ser frágil.

### **5.4. Tutela da evidência como técnica de distribuição do tempo do processo**

Como é óbvio, a tutela da evidência não pode ser confundida com a tutela cautelar ou com a tutela antecipatória que se funda em perigo. O art. 311 diz expressamente que a tutela da evidência independe “da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”.

O Código de 2015, na linha do art. 273, II, do Código de 1973, institui uma técnica processual destinada a viabilizar a tutela do direito do autor quando os fatos constitutivos do direito são incontroversos e a defesa é infundada, e, portanto, quando o exercício da defesa pode ser visto como um abuso.

Bem vistas as coisas, tal técnica de tutela jurisdicional destina-se a viabilizar a distribuição do ônus do tempo do processo. Para tanto, a técnica não poderia fugir dos critérios da evidência do direito e da fragilidade da defesa, aptos a permitir que a tutela do direito se dê no curso do processo sem que seja pago o preço do direito de defesa.

Note-se que esta espécie de técnica de tutela dos direitos é o resultado da admissão de que: i) o tempo do processo não pode ser jogado nas costas do autor, como se esse fosse o culpado pela demora inerente à investigação dos fatos; ii) portanto, o tempo do processo deve ser visto como um ônus; iii) o tempo deve ser distribuído entre os litigantes em nome da necessidade de o processo tratá-los de forma isonômica.

## **6. Tutela provisória**

### **6.1. Significado de tutela provisória**

O Código de 2015 resolveu reunir as várias tutelas prestadas mediante cognição sumária – tutela cautelar, tutela antecipada e tutela da evidência – sob o rótulo de tutela provisória<sup>108</sup>.



Entendeu-se que, como todas estas tutelas são baseadas em cognição sumária e, portanto, podem ser revogadas ou reafirmadas pela tutela jurisdicional final, é possível conceituar as tutelas em provisórias e definitivas, conforme sejam elas sujeitas a confirmação ou revogação ou sejam finais ou baseadas em cognição exauriente.

O critério “provisoriidade-definitividade”, como é óbvio, é nitidamente processual e, assim, não responde ao que acontece no plano do direito material. Trata-se, portanto, de um critério que, se serve para abrir oportunidade para uma classificação que parte de um mesmo ponto, não é suficiente quando se tem consciência de que a relativização processo-direito material é imprescindível para a construção de um direito processual capaz de responder às necessidades de tutela dos direitos. De modo que, se é possível pensar em tutela provisória, é evidente que esta não pode dizer algo de frutífero para quem pensa nas relevantes particularidades que iluminam as diferentes formas de tutela sumária que podem ser ditas “provisórias”.

Recorde-se que a doutrina italiana, ao tratar da tutela cautelar nas primeiras décadas do século XX, afirma ser ela caracterizada pela provisoriidade. Calamandrei é bastante claro neste sentido:

“A opinião mais abrangente, dentro da qual se encontram nossos processualistas mais autorizados, é a que vê um caráter constante ou, em absoluto, um caráter distintivo das providências cautelares em sua provisoriidade, ou seja na limitação da duração dos efeitos (declarativos ou executivos) próprios destas providências. As mesmas diferem, segundo esta opinião, de todas as outras providências jurisdicionais não pela qualidade de seus efeitos, senão por uma certa limitação no tempo dos próprios efeitos (...) A qualidade de provisória conferida às providências cautelares quer significar em substância o seguinte: que os efeitos jurídicos das mesmas não apenas têm duração temporal (...), senão que têm duração limitada àquele período de tempo que deverá transcorrer entre a emanção da providência cautelar e a emanção de outra providência jurisdicional, que, na terminologia comum, é designada, em contraposição à qualificação de cautelar conferida à primeira, com a qualificação de definitiva. A provisoriidade das providências cautelares seria, pois, um aspecto e uma consequência de uma relação que tem lugar entre os efeitos da providência antecedente (cautelar) e os da providência subsequente (definitiva), cujo início marcaria a cessação dos efeitos da primeira.”<sup>109</sup>

É muito interessante observar que a distinção entre a tutela cautelar e as tutelas finais, segundo as palavras do próprio Calamandrei, não reside na qualidade dos efeitos da primeira, mas sim em sua “limitação no tempo”. Em outras palavras, a tutela cautelar se contrapõe à tutela definitiva em razão de sua peculiar provisoriidade, pouco importando o significado de sua atuação no plano do direito material.

Calamandrei, ao tratar da “antipazione di provvedimenti decisori”, que constitui um dos grupos que fazem parte de sua classificação dos “provvedimenti cautelari”, admite que essas tutelas se aproximam conceitualmente das chamadas declarações com predominante função executiva:

Neste terreno, como em todas as zonas fronteiriças, são mais difíceis e sutis as distinções, tanto que não faltam aqueles que incluem entre as declarações de certeza com predominante função executiva grande parte das providências que eu incluo, considerando-as cautelares, neste terceiro grupo.”<sup>110</sup>

Para Calamandrei, o ponto distintivo fundamental entre a tutela cautelar e as declarações com predominante função executiva reside no fato de que a “decisão antecipada e provisória do mérito”, ou seja, a tutela cautelar,

não pode aspirar a converter-se ela mesma em definitiva, senão que está sempre preordenada à emanção de uma providência principal, na chegada da qual os efeitos provisórios da medida cautelar estão destinados a cair totalmente, porque ainda quando a decisão principal reproduza substancialmente e faça suas as disposições da providência cautelar, apresenta-se sempre como decisão ex novo da relação controvertida e não como convalidação da providência cautelar.”<sup>111</sup>

Calamandrei, porém, ao tratar da execução provisória da sentença, conclui que essa figura assume natureza cautelar nos casos em que se dá ao juiz o poder de conceder a cláusula de execução provisória contra o periculum in mora.<sup>112</sup> Nesses casos, a função cautelar pode se configurar de duas diferentes formas:

Em alguns casos o dano que a providência busca prevenir é o que derivaria da demora na satisfação do direito, atuando aquela como meio para acelerar a execução forçada, quando a satisfação se coloca

entre as providências cautelares do grupo c); outras vezes, o dano que objetiva prevenir é o que poderia derivar da dispersão, possível enquanto pende a apelação, dos bens do devedor, funcionando aquela neste caso como um meio para assegurar (não para acelerar) a futura execução forçada, quando deve ficar situada entre as providências do grupo b).<sup>113</sup>

É altamente significativa, para quem sabe da importância de se tratar as tutelas na perspectiva do direito material, sem se importar com a questão de serem elas finais ou provisórias, a afirmação de que, embora exista distinção entre a tutela que acelera a satisfação do direito e a tutela que objetiva apenas assegurar a futura execução forçada, ambas podem ser incluídas no gênero cautelar.

A doutrina de Calamandrei, ao dar realce à provisoriedade (que é um critério processual), simplesmente apaga a diferença entre a tutela que satisfaz antecipadamente um direito e a tutela que se limita a assegurá-lo. É por esta razão que Calamandrei entende que a tutela antecipatória possui caráter cautelar.

Adolfo Perez Gordo, na obra “La ejecución provisional en el proceso civil”, apresenta uma razoável distinção entre a tutela cautelar e a execução provisória da sentença ao dizer que, enquanto a primeira não pode ter uma extensão maior do que a de mera garantia ou de segurança de uma sentença hipotética e futura, a execução provisória, além de permitir a invasão da esfera jurídica do executado, pode levar à própria satisfação do exequente.<sup>114</sup> Pensando-se, apenas por exemplo, no procedimento monitório italiano, é irracional admitir a cautelaridade da execução provisória do decreto ingiuntivo, ainda quando ela é baseada na segunda parte do art. 642 do CPC italiano, ou seja, em perigo de grave “pregiudizio nel ritardo”. Ora, se a execução provisória fundada na particularidade da prova também surge da necessidade de evitar que a demora do processo possa trazer dano marginal ao autor, é equivocado pensar que, justamente quando se torna mais evidente a necessidade de antecipar a execução, esta assume as vestes de tutela cautelar, como se o fato de se outorgar ao juiz o poder para apreciar a existência do “periculum in mora” pudesse ser capaz de transmutar uma tutela que realiza um direito com base em cognição não definitiva em tutela de simples segurança.<sup>115</sup> Em outras palavras, a execução provisória do decreto ingiuntivo, ainda que fundada em perigo, é tão execução provisória quanto aquela que se dá, por exemplo, quando o “credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato” (art. 642, primeira parte, do CPC italiano).

Frise-se que o art. 700 do CPC italiano também abre ensejo à tutela antecipatória de pagamento de soma em dinheiro.<sup>116</sup> Essa tutela, não é difícil perceber, difere apenas no que diz respeito à cognição da execução provisória de uma sentença que condena ao pagamento de soma. Isso quer dizer que o motivo que impede que se atribua caráter cautelar à execução provisória da sentença não pode deixar de estar presente quando se pensa na natureza da tutela sumária que implica a realização antecipada do direito do credor.

É correto dizer que tanto a execução provisória da sentença que condena ao pagamento de soma quanto a tutela antecipatória sumária de pagamento de soma<sup>117</sup> satisfazem o direito de crédito, e que isto obviamente não é o mesmo do que lhe dar simples proteção cautelar.<sup>118</sup> Não deve ter sido por outra razão, aliás, que Giovanni Verde afirmou, em tom incisivo, que seria sinal de escassa honestidade intelectual, ou ainda de ingenuidade não escusável, pensar que o pagamento que satisfaz um crédito alimentar, ainda que fundado em um provimento cautelar, não implique satisfação do direito de crédito, “ma serva meramente acautelarlo”.<sup>119</sup> É importante perceber, contudo, que a nota da provisoriedade acaba por atribuir natureza cautelar a todas as tutelas antecipatórias sumárias contra o periculum in mora; este, sem dúvida alguma, é o resultado a que chega aquele que se vale das premissas que foram fixadas por Calamandrei<sup>120</sup> e reafirmadas por Ferruccio Tommaseo na obra denominada I provvedimenti d’urgenza – Struttura e limiti della tutela anticipatoria.<sup>121</sup>

Ora, é certo que o qualificativo provisório é atribuído a partir de um critério processual que indica que a decisão está na espera de outra que deve ser proferida ao final do procedimento. A ideia de decisão ou provimento provisório, assim como de “tutela provisória”, significa que está a

se tratar de decisão ou tutela não final ou definitiva. E isso quando se tem boa vontade para deixar passar o equívoco da ligação da provisoriedade à tutela jurisdicional do direito e, assim, admitir a identidade entre provimento e tutela. A tutela, vista como provimento, pode ser provisória exatamente por estar sujeita a confirmação, dada a fragilidade da cognição que lhe é inerente.

Perceba-se que, quando se usa um critério processual – como o da provisoriedade – para definir o significado de uma tutela jurisdicional, não se está a falar de tutela do direito e, portanto, não se pode discutir sobre a diferença entre tutela inibitória e de remoção do ilícito (por exemplo) e cautelar. Essas tutelas só podem ser compreendidas na perspectiva do direito material e de suas respectivas funções neste plano. A ideia de tutela provisória, ao contrário, nada tem a ver com o direito material e só pode ser oposta à de tutela definitiva.

As tutelas inibitória e de remoção são prestadas por meio de um provimento que pode ser provisório ou definitivo. Quando o provimento é provisório, tais tutelas são antecipadas. Portanto, é evidente o equívoco da doutrina que afirma que a tutela inibitória, quando concedida através de um provimento provisório, possui natureza cautelar. A tutela inibitória, como é óbvio, não perde a sua natureza somente pelo fato de ser concedida por um provimento provisório.

Deixe-se claro, ademais, que a ideia de “tutela provisória” não apenas necessita ser preenchida pelas diversas formas de tutela dos direitos. Ela também constitui um conceito que foi elaborado por Calamandrei em razão das particularidades do direito italiano da sua época. Calamandrei, embora consciente da necessidade de tutelas sumárias distintas da meramente de segurança – da tutela genuinamente cautelar –, não tinha qualquer condição para desenvolver uma elaboração teórica que evidenciasse a possibilidade de tutelas sumárias, prestadas com base no art. 700 – fundamento do poder geral de cautela – do Código de Processo Civil italiano, que não fossem cautelares. Uma tutela de cognição sumária contra o perigo que não fosse cautelar seria vista como tutela executiva, o que certamente representaria um atentado contra o princípio da *nulla executio sine titulo*. Significa que a construção de Calamandrei, ao misturar tutela cautelar e tutela satisfativa sumária, merece elogios do ponto de vista da contribuição para a efetividade do processo. Como todo e qualquer jurista, Calamandrei trabalhou com as possibilidades teóricas que tinha em mãos.

Atualmente, contudo, como o princípio da *nulla executio* não passa de mito e há legislação que expressamente alude às tutelas cautelar, antecipada (satisfativa sumária) e da evidência (art. 294, parágrafo único, e seguintes, CPC), não há como deixar de distingui-las e analisá-las de forma separada, reservando-se ao critério da provisoriedade a condição de ponto de reunião das diversas formas de tutela sumária.

## **6.2. Espécies de tutela provisória**

O Código de 2015 é muito claro quanto às espécies de tutela provisória. Alude, em primeiro lugar, à tutela de urgência. Nesse momento, fala em tutela cautelar e em tutela antecipada. Mais adiante, depois de regular as tutelas cautelar e antecipada nas formas incidente e antecedente, trata da tutela da evidência.

Todas estas tutelas são de cognição sumária, ou seja, podem ser concedidas antes do esgotamento da discussão do mérito a que dizem respeito. A tutela de urgência tem como pressupostos “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC). A tutela da evidência, como técnica de distribuição do tempo do processo, pode ser concedida com base em qualquer dos incisos do art. 311, marcadamente quando presente o “abuso do direito de defesa” (art. 311, I, CPC).

## **6.3. Tutela provisória de urgência: tutelas cautelar e antecipada (satisfativa sumária)**

O Código, ao tratar da tutela de urgência, distingue em vários lugares tutela cautelar e tutela antecipada. No § 3.º do art. 300 encontra-se a afirmação de que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Embora essa norma não tenha qualquer sentido, na medida em que a irreversibilidade é resultado

logicamente possível de toda e qualquer tutela do provável, serve ela para evidenciar que o legislador resolveu prever o óbice da irreversibilidade apenas a uma das formas de tutela de urgência – a tutela antecipada. Mais à frente, confere-se procedimentos distintos às tutelas cautelar e antecipada requeridas na forma antecedente e admite-se a estabilização apenas da tutela antecipada (art. 304, CPC).

Relevante para o efeito de demonstrar a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada, inclusive na concepção do código, é o art. 301. Essa norma, mediante o meio mais didático para demonstrar a distinção entre formas de tutela, alude a exemplos bem claros de tutela de segurança. Diz o art. 301 que

a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito.

Estes exemplos constituem genuínas tutelas de asseguramento da tutela principal, ou melhor, da tutela do direito.

O art. 301 demonstra que a tutela cautelar se destina a assegurar a efetividade da tutela satisfativa do direito material. Por esta razão, é caracterizada pela instrumentalidade e pela referibilidade. A tutela cautelar é instrumento da tutela satisfativa, na medida em que objetiva assegurar a sua frutuosidade. Além disto, a tutela cautelar sempre se refere a uma tutela satisfativa do direito, que desde logo pode ser exigida ou que, dependendo do acontecimento de certas circunstâncias, poderá ser exigida. Note-se que o art. 301 fala expressamente em “asseguração do direito”, confirmando a teoria da tutela cautelar apresentada no item 1 dos presentes comentários – ao art. 294.

A tutela antecipada, porém, é satisfativa do direito material, permitindo a sua realização – e não a sua segurança – mediante cognição sumária. Na verdade, a tutela antecipada tem a mesma substância da tutela final, com a única diferença de que é lastreada em verossimilhança e, por isto, não fica acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada material. A tutela antecipada é a tutela final, antecipada com base em cognição sumária.

Desse modo, a tutela antecipada não é instrumento de outra tutela ou faz referência a outra tutela. A tutela antecipada satisfaz o autor, dando-lhe o que almejou ao propor a ação. O autor não quer outra tutela além daquela obtida antecipadamente, diversamente do que sucede quando pede tutela cautelar, sempre predestinada a assegurar a efetividade de uma tutela jurisdicional do direito. A tutela antecipada também não aponta para uma situação substancial diversa daquela tutelada, ao contrário da tutela cautelar, que necessariamente faz referência a uma situação tutelável ou a uma outra tutela do direito material.

O Código de 2015 admite tanto o requerimento de tutela antecipada quanto o requerimento de tutela cautelar no curso do processo de conhecimento, atribuindo-lhes a característica de tutela urgente. Assim, não há mais qualquer motivo para, em nome do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, dar ao conceito de tutela antecipada a mesma abrangência que lhe era dado à luz do Código de 1973, quando se atribuía natureza antecipatória à tutela urgente que ordena sob pena de multa em face dos pedidos declaratório e constitutivo. Como já dito (item 2.6), conferiu-se conceito amplo à tutela antecipada apenas e tão somente para viabilizar tutela urgente nas ações declaratória e constitutiva – sem a necessidade da propositura de ação cautelar.

Diante do Código de 2015 é oportuno e necessário colocar a tutela antecipada em seu devido trilho. Há tutela antecipada apenas quando a tutela final é prestada antecipadamente. Ou melhor, a tutela antecipada é, em substância, a tutela final prestada mediante a técnica da antecipação. Bem por isso não há tutela antecipada quando se pede tutela urgente para obstar o demandado a fazer algo que não poderia ser feito se já houvesse declaração ou (des)constituição. Note-se que é possível antecipar, por exemplo, tutela inibitória, mas a ordem que ordena o demandado a não praticar um ato que não poderia ser praticado se uma deliberação social já houvesse sido desconstituída não é antecipação da desconstituição.

Embora a tutela antecipada seja clara quando a sentença final é dependente de execução, isso não quer dizer que não seja possível, certamente em situações excepcionais, a antecipação da tutela constitutiva. Lembre-se, por exemplo, da fixação provisória do aluguel na ação de revisão do valor da locação. Nesse caso, a tutela antecipada produz efeitos que operam no plano do direito substancial, estabelecendo nova situação jurídica, e além disso é possível propor ação de despejo em caso de não pagamento do valor fixado provisoriamente<sup>122</sup>.

#### 6.4. Tutela provisória e tutela dos direitos

O elemento provisoriedade diz respeito ao grau de cognição – sumária – em que se funda a decisão que concede a tutela no curso do processo, servindo apenas para reunir as tutelas (*rectius*, as decisões) que se contrapõem às definitivas – fundadas em cognição exauriente. Bem vistas as coisas, a tutela antecipada, ao satisfazer no plano fático, nada tem de provisória – como se pudesse vir a ser substituída por uma tutela final. Provisória é, isto sim, a decisão. Aliás, como antes visto, nem mesmo a tutela cautelar é provisória, mas sim temporária, estando subordinada à manutenção do estado indicativo do perigo de dano.

Recorde-se que Calamandrei, em sua obra clássica sobre “processo cautelar”, classificou as “providências cautelares” em: i) providências instrutórias antecipadas; ii) providências dirigidas a assegurar a execução forçada; iii) antecipação de providências decisórias; e iv) cauções processuais.<sup>123</sup> Ao tratar das tutelas que estariam incluídas no terceiro grupo, afirmou que estas consistiriam, precisamente, em uma decisão antecipada e provisória do mérito,

destinada a durar até o momento em que a esta regulação provisória da relação controvertida se sobreponha a regulação de caráter estável que se possa obter mediante o mais lento procedimento ordinário.<sup>124</sup>

É óbvio que a doutrina de Calamandrei está totalmente contaminada pelo vício da abstração do processo em relação ao direito material. Esta contaminação fica visível quando Calamandrei afirma que toda decisão que antecipa o julgamento do mérito, por dar regulação provisória à relação jurídica controvertida, tem natureza cautelar. Na doutrina de Calamandrei, o que define a natureza da tutela é a provisoriedade, pouco importando o resultado que é proporcionado ao autor. É por isso que Calamandrei, ao escrever a sua obra a partir da premissa de que o que define a cautelaridade é a provisoriedade, acabou falando mais de tutela antecipatória do que de tutela cautelar.<sup>125</sup>

Quando a tutela concedida no curso do processo e, portanto, com base em cognição sumária, é caracterizada pela provisoriedade, toma-se em conta um critério de ordem processual para classificar as tutelas, o que obviamente não é suficiente no estágio em que vive o direito processual civil, preocupado especialmente com a efetividade da tutela jurisdicional do direito material. Lembre-se, na linha do que disse Denti, que somente a propensão de repensar a função jurisdicional em termos de “tutela dos direitos”, mais do que em um quadro meramente processual, poderá permitir uma compreensão adequada das novas necessidades de tutela, próprias à sociedade contemporânea.<sup>126</sup>

Quem desvia os olhos da moldura técnica do processo civil e passa a se preocupar com a “tutela dos direitos” deixa de lado a relação entre satisfatividade e coisa julgada material, já que a efetividade da tutela de um direito não pressupõe a coisa julgada. A tutela do direito se dá independentemente da coisa julgada, até porque a tutela do direito, para ser efetiva, em muitos casos tem de ser prestada com base em cognição sumária.

A demonstração de que a tutela do direito pode ocorrer com base em cognição sumária deixa evidenciado o equívoco daqueles que pensam que a satisfatividade fundada em cognição sumária não tem relevância jurídica, devendo ser vista como uma mera e não importante “satisfatividade fática”. Ora, quem raciocina desta forma somente pode estar confundindo satisfação do direito material (tutela do direito) e satisfação processual (coisa julgada material). Na verdade, aquele que não dá importância à “satisfação” fundada em cognição sumária, chamando-a de “mera satisfação fática”, mostra não estar atento à realidade, uma vez que, na perspectiva do consumidor do

serviço jurisdicional, o que vale é a “tutela do direito”, pouco importando se esta é concedida por meio de uma decisão de cognição sumária ou mediante uma decisão de cognição exauriente.<sup>127</sup>

Tudo isto é evidência de que por detrás da ideia de tutela provisória se escondem não apenas a tutela de segurança (cautelar) e a tutela antecipatória, mas também todas as formas de tutela satisfativa sumária, como por exemplo as tutelas sumárias inibitória, de adimplemento e de ressarcimento na forma específica. Ora, *é óbvio que os pressupostos de uma tutela provisória que se constitui em ordem sob pena de multa variam conforme as formas de tutela do direito que estejam sendo postuladas mediante o signo da provisoriedade*. Enquanto na tutela antecipada inibitória se exige apenas probabilidade da prática de ato contrário ao direito, é pressuposto da tutela antecipada do adimplemento o dano que pode derivar do não cumprimento imediato da obrigação e da tutela antecipada de ressarcimento na forma específica o dano que pode decorrer do dano que se busca ressarcir in natura.

### **6.5. Tutela provisória da evidência**

A tutela da evidência (art. 311, CPC), tal como posta no Código, é uma tutela provisória e, portanto, deve ser concedida com base em cognição sumária. Lembre-se, contudo, que em uma dimensão teórica a tutela da evidência não necessita ser de cognição sumária, uma vez que o legislador pode admiti-la no curso do processo com base em cognição exauriente.<sup>128</sup>

Era assim diante do art. 273, § 6.º, do Código de 1973, que admitia o uso da técnica antecipatória para a hipótese de incontrovérsia de parte do pedido ou de um dos pedidos cumulados. A tutela da parte incontroversa da demanda exigia que parcela do pedido ou um dos pedidos cumulados não mais necessitasse de prova e a outra parte do pedido ou o outro pedido cumulado exigisse que o processo caminhasse rumo à instrução probatória.

Portanto, além de não ser de urgência – nada era exigido em termos de perigo de dano –, a tutela era de evidência – pois exigia direito incontroverso – e de cognição exauriente, na medida em que não só não era mais necessário ao autor demonstrar o fato constitutivo como também não se supunha que o demandado eventualmente poderia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Não é por outra razão, aliás, que tal modalidade de tutela – antes prestada mediante a técnica antecipatória – foi corretamente situada no Código de 2015 como hipótese de “julgamento antecipado parcial do mérito” (art. 356, CPC).

### **6.6. Caráter antecedente ou incidental**

Antes da introdução da tutela antecipatória no sistema processual civil brasileiro em 1994, a tutela urgente se resumia à tutela cautelar, que apenas podia ser requerida mediante ação cautelar – antecedente ou incidente. A tutela antecipatória, por sua vez, foi concebida para ser requerida apenas e tão somente no curso do processo de conhecimento. Ou seja, antes do Código de 2015 a tutela cautelar não podia ser requerida no curso do processo de conhecimento e a tutela antecipada não podia ser requerida na forma antecedente.

O parágrafo único do art. 294 deixa claro que, a partir de agora, as tutelas antecipada e cautelar podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. O tema será abordado com mais profundidade quando dos comentários ao art. 299.

**Art. 295.** A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.

#### **1. Custas diante do requerimento de tutela provisória**

O art. 295 esclarece que a tutela provisória – qualquer que seja ela –, quando requerida no curso do processo que visa à tutela do direito, independe do pagamento de custas. A norma quer dizer que, quando a tutela cautelar e a tutela antecipada são requeridas na forma antecedente, as custas processuais devem ser pagas desde logo, pouco importando se a tutela principal será pedida, ou seja, se a petição inicial será aditada ou o pedido principal formulado.

#### **2. Honorários advocatícios e tutela provisória incidental**



Embora o Código não aluda expressamente aos honorários, é evidente que também eles não incidem diante de requerimento de tutela provisória requerida de maneira incidental.

No Código anterior, em razão da circunstância de a tutela cautelar ser requerida em processo autônomo (tanto quando requerida de forma antecedente, como se postulada incidentalmente na pendência do “processo principal”), havia a condenação de honorários advocatícios quando da prolação da sentença cautelar. Mas esse regime se justificava exatamente porque se tratava de outro processo, com sentença distinta.

Na situação atual, considerando que a tutela provisória é simples requerimento a ser examinado no curso do processo, nada justifica que a decisão que defira a medida também fixe honorários advocatícios autônomos. Logicamente, o trabalho havido com o requerimento de tutela provisória deve ser valorado na fixação dos honorários ao final do processo (art. 85, § 2.º, do CPC). Porém, não há sentido na condenação em honorários apenas diante do requerimento de tutela provisória.

**Art. 296.** A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

## **1. Eficácia temporal das tutelas cautelar e antecipada**

A tutela cautelar, na concepção da doutrina clássica, sempre foi ligada à sentença que resolve o litígio. Daí a provisoriedade, apontada por esta doutrina como característica da tutela cautelar. Nesta concepção doutrinária, a tutela cautelar é destinada a dar segurança ao processo.<sup>129</sup>

Acontece que a tutela cautelar é um direito da parte e um dever do Estado, destinando-se especialmente a dar segurança à tutela do direito material, para a qual a sentença não é bastante. Lembre-se, por exemplo, que a tutela ressarcitória pelo equivalente não é prestada pela sentença condenatória, dependendo de meios de execução idôneos.

Portanto, a tutela cautelar não encontra limite no trânsito em julgado da sentença de procedência, mas sim no trânsito em julgado da sentença de improcedência. No caso de sentença de procedência, como a tutela do direito ainda pode depender da execução, a tutela cautelar deve manter-se efetiva até a utilização dos meios executivos. Como está claro, a eficácia da tutela cautelar tem ligação com o perigo que pode inviabilizar a efetiva tutela do direito e não com a sentença de procedência transitada em julgado.

Algo diferente se passa com a tutela antecipada. Essa não tem razão para sobrevir ao trânsito em julgado da sentença de procedência. Na verdade, a tutela antecipada deixar de ter razão de ser quando transitada em julgado a sentença de procedência.

A tutela urgente não teria motivo para persistir caso a sentença de procedência produzisse efeitos na pendência da apelação. Mas como não é assim, o art. 1.012, § 1.º, V, do Código de Processo Civil afirma que a sentença produz efeitos imediatamente quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória

## **2. Manutenção excepcional da tutela de urgência em caso de sentença de improcedência**

Ademais, embora se possa entender, a princípio, ser ilógica a manutenção da tutela urgência – cautelar e antecipada – em caso de sentença de improcedência, não há razão para não admitir que o juiz possa mantê-la eficaz em casos excepcionais.<sup>130</sup>

Note-se que não há contradição entre a declaração da inexistência do direito e a necessidade da manutenção da tutela urgência. A declaração da inexistência do direito não elimina o perigo de dano, já que o que vale, em caso de recurso, é o julgamento do tribunal, ou seja, a cognição definitiva. Não há como negar que a revogação da tutela, em caso de sentença de improcedência, abre oportunidade para um dano na pendência do recurso. Como é óbvio, dano poderá ocorrer até

que o tribunal reforme a sentença que implicou a revogação da tutela.

É claro que a não revogação da tutela – que, repita-se, é excepcional – exige do juiz atenta consideração à natureza da tutela de direito em disputa e às particularidades do caso concreto, especialmente daquelas relacionadas à situação de perigo de dano. Perceba-se, por exemplo, que a revogação da tutela inibitória faz surgir a imediata oportunidade para a prática do ilícito, eliminando completamente a possibilidade de se obter uma tutela jurisdicional íntegra do direito material em caso de reforma da sentença recorrida.

De qualquer forma, o art. 1.012, § 1.º, V, do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a sentença produz efeitos imediatos também quando revoga a tutela provisória. Ora, se a sentença só tem efeitos imediatos quando revoga a tutela, é evidente que, quando nada diz, mantém. Significa que o juiz, de acordo com o Código, só não mantém a tutela provisória de urgência quando, ao lado da improcedência do pedido de tutela final, revoga-a.

### **3. Fundamentos para a revogação ou modificação da tutela de urgência**

A tutela de urgência deve ser revogada quando desaparecer a situação de perigo de dano ou a própria probabilidade do direito à tutela final que legitimou a sua concessão. Isto quer dizer que tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada podem vir a desaparecer – independentemente de agravo de instrumento – sem que se tenha chegado na sentença.<sup>131</sup>

O juiz deve revogar a tutela de urgência não apenas quando surgir um fato novo capaz de lhe permitir a formação de nova convicção a respeito do perigo de dano, mas também quando surgir nova prova derivada do prosseguimento do debate em torno do litígio. Quer dizer que o juiz não só pode revogar a tutela urgente diante de novos fatos, como também pode redecidir a questão com base em prova nova.

Ao decidir com base em cognição sumária o juiz não declara a existência ou a inexistência do direito à tutela; o juízo sumário é de mera probabilidade. Ao decidir pela tutela de urgência, o juiz aceita implicitamente a possibilidade de chegar a diversa convicção no curso do processo. Assim, quando se está diante de decisão que concede tutela de urgência, quebra-se o princípio de que não é possível decidir a mesma questão duas vezes. Tratando-se de decisão fundada em cognição sumária, a viabilidade de se voltar a decidir é consequência da circunstância de que a convicção judicial pode naturalmente se alterar no curso do processo. A primeira decisão, por ter sido tomada com base em cognição menos aprofundada, é logicamente sujeita a revisão, pouco importando se os fatos não se alteraram, mas apenas novas provas foram produzidas.

Aliás, ao desaparecer qualquer dos fundamentos da tutela urgente, a sua revogação imediata não só é consequência da aplicação da regra de que o réu não pode ser submetido a gravame despropositado, como ainda da circunstância de que a tutela urgente é lastreada em probabilidade, constituindo uma tutela jurisdicional que limita o direito de defesa para permitir a efetividade do direito de ação.

Mesmo que não haja alteração da convicção acerca da probabilidade do direito ou do perigo de dano, o juiz pode ser convencido de que uma modalidade de tutela cautelar menos gravosa é suficiente ou que basta parcela da tutela antecipada para evitar que dano seja provocado ao autor. A possibilidade de modificação da tutela sem alteração das circunstâncias fáticas que envolvem o perigo e a produção de novas provas que possam alterar a convicção sobre o litígio tem fundamento na possibilidade – que na verdade é um dever – de o juiz restringir o prejuízo do demandado desde que não prejudique aquele que obteve a tutela de urgência.

### **4. Revogação ou modificação da tutela de urgência no Tribunal**

A tutela de urgência também pode ser revogada ou modificada no Tribunal. Nessa hipótese, porém, só o surgimento de novos fatos relacionados ao perigo pode justificar a revogação/modificação da tutela.

Quando se fala em revogação ou modificação da tutela, deixa-se de lado o agravo de

instrumento ou mesmo o recurso de apelação. Quando interposto recurso não há dúvida que a tutela de urgência pode ser revogada ou modificada, inclusive em virtude de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.012, §§ 3.º e 4.º e do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

O recurso, contudo, tem a ver com a natural possibilidade de o tribunal reapreciar a oportunidade da tutela de urgência em vista do que já foi demonstrado em juízo. O que aqui importa saber é se o tribunal pode ser instado a revogar/modificar a tutela em virtude de fato novo – surgido após à interposição do recurso, especialmente da apelação – capaz de alterar a convicção acerca da situação indicativa do perigo.

Não há dúvida de que sim. Diante de fato novo, capaz de eliminar ou alterar a situação de perigo, a parte pode apresentar petição simples ao relator, requerendo a revogação ou a modificação da tutela de urgência. O relator, como é óbvio, só poderá decidir depois de ouvir o recorrido.

### **5. Modificação da tutela em proveito da parte que a obteve**

Quando se associa modificação com revogação da tutela, entende-se quase que intuitivamente que se trata de modificação para favorecer a parte contra a qual a tutela foi concedida. No entanto, o art. 296 fala em possibilidade de modificação da tutela sem aludir a quem pode requerê-la.

A parte que já obteve tutela cautelar ou tutela antecipada pode ter obtido tutela que não correspondeu ao seu pedido – v.g., tutela antecipada parcial – ou que, diante de fatos posteriormente ocorridos, deixou de ser adequada. Portanto, aquele que já obteve tutela urgente pode ter necessidade de modificá-la ou ampliá-la, sabido que a ideia de ampliação está presente na de modificação. Nestas situações, nova prova ou fato novo – ainda que preexistente – podem fundamentar o requerimento de tutela de urgência.

### **6. Eficácia da tutela no período de suspensão do processo**

O parágrafo único do art. 296 afirma que, salvo decisão em contrário, a tutela provisória conserva eficácia no período de suspensão do processo. A norma se importa especialmente com a tutela de urgência, tendo em vista que a suspensão do processo, além de poder ser incompatível com o perigo, pode gerar um perigo inverso.

Note-se que, se a tutela de urgência é requerida em virtude da demora para a obtenção da tutela final, o requerimento de suspensão do processo pelas partes pode ser indicativo de que não há perigo. Não obstante, a parte que obteve tutela de urgência não deve ser impedida de requerer a suspensão do processo nem pode ter que deixar de contar com a tutela de urgência por assim ter requerido. Na verdade, como o requerimento de suspensão do processo é consequência da convenção das partes ou de algo que independe de ambas as vontades (art. 313, CPC), apenas na última hipótese é que se pode cogitar de suspensão da eficácia da tutela de urgência por decisão judicial.

Para que o juiz possa suspender a eficácia da tutela de urgência em razão da suspensão do processo, é necessário que o prazo de suspensão constitua sinal de que a manutenção da tutela está a causar prejuízo despropositado à parte. Ou melhor, a manutenção da tutela deve causar prejuízo que, em razão do tempo de suspensão do processo, não seja racionalmente compensado pelo seu benefício.

### **7. A particularidade da tutela da evidência**

A tutela da evidência requer prova documental ou não contestação dos fatos constitutivos – precisamente a sua incontrovérsia – e defesa de mérito indireta – alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos – infundada. Isso está presente em todos os incisos do art. 311.

Significa que a tutela da evidência não tem a maleabilidade da tutela de urgência. Isso porque, além de nunca se fundar em uma situação fática de perigo – que pode se alterar de um instante

para outro –, não tem a possibilidade de variar de figura para tutelar o direito do autor sem prejudicar a esfera jurídica do réu, como sucede particularmente com a tutela cautelar.

A tutela de urgência sujeita-se à variação da situação perigosa e a tutela cautelar pode alterar a sua forma sem deixar de prestar a devida tutela de segurança à tutela final. A tutela da evidência tem maior estabilidade, podendo ser revogada apenas quando descaracterizada a incontrovérsia dos fatos constitutivos ou quando positivada a idoneidade da defesa de mérito indireta – o que obviamente não ocorre de um momento para outro no processo e não é algo tão comum quanto a alteração da convicção suficiente para a tutela do provável. Sublinhe-se que neste último caso se requer probabilidade do direito, enquanto que na hipótese de tutela da evidência é necessária a incontrovérsia dos fatos constitutivos.

Não é por outra razão que a regra que abre oportunidade para a revogação/modificação é típica à tutela de urgência. Pelo mesmo motivo não há a mesma preocupação com a manutenção da eficácia da tutela da evidência no período da suspensão do processo. Não se trata de uma tutela do provável ancorada em perigo, que, diante da demora inversa gerada pela suspensão, pode se tornar um gravame despropositado ao demandado, mas de uma tutela que, baseando-se na evidência do direito e em defesa infundada, a princípio racionalmente se sustenta eficaz com base nos próprios critérios que determinam a distribuição do tempo no processo.

**Art. 297.** O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

## **1. Do princípio da tipicidade das formas executivas às cláusulas executivas abertas**

Quando o direito de ação é visto apenas como uma garantia à apreciação de afirmação de um direito ou como o direito a julgamento de mérito, entendendo-se que a sentença é o bastante em sua resposta, é natural e lógico que não se dê atenção aos meios de execução ou, ainda, que não se visualize a idoneidade dos meios de execução para a tutela do direito material. Na verdade, quando o direito de ação não presta atenção ao direito material basta um único procedimento e uma única espécie de sentença, além de meios executivos que devem servir à execução de toda e qualquer tutela jurisdicional.

O princípio da tipicidade dos meios executivos, além de se fundar na desnecessidade de meios executivos diferenciados e adequados às diferentes formas de tutela do direito material e às particularidades do caso concreto, objetivou garantir a liberdade do litigante contra a possibilidade de arbítrio judicial. O princípio se tornou possível diante da indiferença em relação ao direito material e a partir da preocupação com a defesa da liberdade dos litigantes diante do Juiz.

De acordo com o princípio da tipicidade, os meios de execução devem estar previstos na lei e, por isso, a execução não pode se dar através de modalidades executivas não tipificadas. Objetiva-se impedir que meio executivo não previsto em lei possa ser utilizado e, ao mesmo tempo, proteger o jurisdicionado contra a possibilidade de arbítrio judicial. Note-se que se o jurisdicionado sabe, diante de previsão legal, que a sua esfera jurídica somente poderá ser invadida mediante determinada modalidade executiva, confere-se-lhe não só a possibilidade de antever a reação ao seu inadimplemento, bem como a garantia de que a jurisdição não utilizará outro meio executivo.

Como disse Crisanto Mandrioli ao elogiar o princípio da tipicidade,

a precisa referência às formas previstas no Código de Processo Civil implica no reconhecimento da regra fundamental da intangibilidade da esfera de autonomia do devedor, a qual somente poderia ser invadida nos modos e através das formas tipicamente previstas pela lei processual.<sup>132</sup>

É muito importante estabelecer a ligação entre o culto às ideias liberais clássicas e as formas do processo, que na verdade seriam “formas de garantia das liberdades”. Esta ligação foi posta à luz por Denti em trabalho sobre a história das reformas processuais na Itália, ocasião em que

demonstrou que a antiga concepção burocrática da função jurisdicional, marcada pela excessiva racionalização do exercício dos poderes do juiz, foi a responsável pela ideia de se criar um modelo único de procedimento. Nesta ocasião, Denti lembrou que Chiovenda, em uma de suas mais famosas conferências – *Le forme nella difesa giudiziale del diritto* –, não apenas frisou a importância da forma como garantia contra a possibilidade de arbítrio do juiz, como ainda deixou clara “a estreita ligação entre a liberdade individual e o rigor das formas processuais”.<sup>133</sup>

Porém, com a percepção de que as modalidades executivas devem ser idôneas às necessidades de tutela das diferentes situações de direito substancial, o direito ao meio executivo adequado passou a ser visto como corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Entendeu-se, a partir daí, que o juiz deveria ter um amplo espaço de poder para determinar a modalidade executiva adequada às necessidades de tutela do direito material e do caso concreto.

Não é por outro motivo que o art. 297 estabelece que “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O objetivo da norma é deixar claro que o juiz pode – logicamente que após ouvidas as partes – determinar o meio executivo adequado à tutela provisória, especialmente à efetivação da tutela de urgência. A norma constitui, em outras palavras, uma cláusula executiva aberta, que oportuniza ao juiz a adoção do meio executivo adequado à efetivação da tutela, demonstrando que a função judicial está cada vez mais ligada ao caso concreto.

## **2. Critérios reguladores da eleição do meio executivo adequado à tutela de urgência**

Consideradas as diversas formas que podem ser utilizadas para dar efetividade à tutela de urgência, é imprescindível estabelecer critérios para orientar a atividade executiva. A tutela urgente não pode causar prejuízo desrazoável ao demandado. Assim, a sua ética está em privilegiar o “equilíbrio” e a “justa medida” como critérios que devem iluminar a relação entre a sua efetividade e a necessidade de preservação da esfera jurídica do réu. Isto quer dizer que a tutela urgente sempre deve ser prestada através de um meio adequado. Este deverá ser idôneo para a tutela e, ao mesmo tempo, gerar a menor restrição possível. O meio adequado, portanto, é aquele que, além de tutelar, causa a menor restrição possível. Assim, por exemplo, se, para a prestação da tutela inibitória antecipada, basta determinar a instalação de determinada tecnologia para que a poluição não prossiga, não há cabimento em impor a cessação das atividades produtivas. A tutela antecipada estaria violando a regra da menor restrição.

Tanto a forma de tutela – seu conteúdo, ou seja, a determinação da instalação de equipamento ou da cessação das atividades da empresa – quanto o meio executivo para a implementação da forma – fazer mediante o oficial de justiça ou ordem de fazer ou de não fazer sob pena de multa, por exemplo – devem ser adequados, pautando-se pelos critérios do meio idôneo e da menor restrição. O meio de execução somente é adequado quando configura uma “justa medida” – resposta à “proibição de excesso” – para a efetivação da tutela. Adequado, em outras palavras, é o meio que, idôneo à prestação da tutela, é o que traz o menor prejuízo.

Não há como eleger o meio executivo adequado em abstrato, ou melhor, desconsiderando-se as diversas tutelas do direito que podem ser prestadas na forma antecipada (inibitória etc.), as várias formas mediante a qual estas tutelas e a tutela cautelar podem ser concretizadas (cessação da atividade poluente etc.) e as particularidades dos casos. Assim, o raciocínio decisório e a justificativa devem estar atentos a tais elementos sob pena de o emprego do meio executivo carecer de legitimidade. O poder executivo, embora não seja mais controlado pelo princípio da tipicidade, está sujeito a uma forma de controle muito mais sofisticada e complexa. A regra da necessidade, que impede a utilização de meio idôneo que não seja o menos prejudicial, bem como a “proibição de excesso”, cuja concretização impõe perguntar pela “justa medida”, são os critérios que devem orientar a atividade executiva e, portanto, abrir oportunidade para o litigante controlá-la.<sup>134</sup>

Tais critérios, como é óbvio, dependem de justificativa. Perceba-se que a falha da justificativa é que evidenciará a falha do raciocínio decisório ou a ilegitimidade da escolha do juiz e, assim, que a sua atividade não ficou contida na advertência de “proibição de excesso”. É por isto que se pode

dizer que a necessidade de justificativa da adequação ou da “justa medida” é a outra face do poder de escolha da modalidade executiva.

O poder de escolha, se é fundamental para o adequado exercício do poder e é orientado pelas ideias de “meio idôneo” e de “menor restrição possível”, é legitimado pela necessidade de “justificativa”, vale dizer, de explicação das razões de escolha. Esta forma de viabilizar o exercício do poder e ao mesmo tempo controlá-lo é fundamental em face dos direitos da sociedade contemporânea, constituindo pura manifestação da crescente necessidade de se pensar o direito para o caso concreto.

Reafirme-se, portanto, que é impossível desenhar uma precisa e exata tabela para o uso das medidas de execução diante das tutelas cautelar e antecipada. O que precisa ser deixado claro é que o poder de execução diante da tutela de urgência, a despeito de não limitado pelo princípio da tipicidade, está sujeito a controle por meio dos critérios antes delineados e, sobretudo, pela devida justificativa – cujo grau de aprofundamento também varia conforme a complexidade do caso.

### **3. Efetivação da tutela de urgência nas hipóteses em que se almeja fazer, não fazer, entrega de coisa e soma em dinheiro**

No caso de tutela de urgência que impõe fazer, não fazer e entrega de coisa, aplicam-se os meios executivos previstos entre os artigos 536 e 538 do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 536, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, utilizar as “medidas necessárias” à efetivação da sentença que impõe fazer ou não fazer. Assim, nos termos do § 1.º do art. 536, o juiz pode “determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”. De outra parte, tratando-se de sentença que reconhece a exigibilidade da entrega de coisa, afirma o art. 538 que, uma vez não adimplida a sentença, será “expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel”. Porém, isso não quer dizer que neste último caso não se pode aplicar a multa, na medida em que o § 3.º do art. 538 diz expressamente que são aplicáveis ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de entrega de coisa, “no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Tudo isso significa que, em caso de tutela antecipada que determina fazer ou não fazer, são aplicáveis, entre outras, as várias modalidades executivas exemplificadas no § 1.º do art. 536, enquanto que, na hipótese de tutela antecipada que impõe a entrega de coisa, além de aplicáveis a busca e apreensão e a imissão na posse (art. 538, CPC), igualmente é possível utilizar a multa (art. 538, § 3.º, CPC)<sup>135</sup>.

A aplicação da multa possui grande importância no caso em que o exequente desconhece o lugar em que está a coisa e na hipótese em que a busca e apreensão, diante da natureza da coisa a ser entregue, é praticamente impossível. Assim, por exemplo, se a coisa exige desmonte e transporte que requer conhecimento técnico especializado e grande dispêndio de dinheiro.

No que diz respeito à tutela antecipatória que determina o pagamento de soma em dinheiro, é possível pensar em três modalidades de execução<sup>136</sup>: i) na execução por expropriação, especialmente mediante penhora on line, observando-se as regras do Código de Processo Civil; ii) no uso dos meios executivos predispostos para os alimentos de direito de família; e iii) na execução sob pena de multa, partindo-se do pressuposto de que, se é imprescindível a antecipação de soma, essa não pode ficar na dependência da execução por expropriação, na medida em que tal modalidade executiva nem sempre permite uma execução tempestiva e, assim, capaz de responder aos motivos que legitimam a própria concessão da tutela antecipada.

A multa – apesar de não prevista para a execução da sentença condenatória – pode ser utilizada para a efetivação da tutela que determina a antecipação de soma em razão da evidente diferença entre a natureza da soma que se pretende de forma antecipada e a natureza da soma que se almeja mediante a sentença condenatória. Ora, a circunstância de a multa não estar predisposta para a sentença que condena ao pagamento de dinheiro evidentemente não pode conduzir à



conclusão de que a tutela antecipada de soma não pode ser idoneamente executada. Tal interpretação estaria em evidente contradição com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

Nada impede que a execução se processe em outros autos para que seja evitado o tumulto processual. A impugnação pode ser utilizada como defesa contra os atos executivos. Assim, por exemplo, no caso de penhora em valor superior ao devido, o réu poderá se defender da execução mediante impugnação. Se a tutela antecipatória provocar a constrição indevida de bem de terceiro, cabem os embargos de terceiro.

Em razão da previsão do art. 520, IV, é possível a expropriação ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, assim como o levantamento de depósito em dinheiro. Nesses casos e em outros em que a execução puder causar grave dano ao executado, deve ser prestada caução idônea (art. 520, IV, CPC). Não obstante, de acordo com o art. 521, a caução pode ser dispensada quando o i) o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; ii) o credor demonstrar situação de necessidade; iii) pender o agravo do art. 1.042; e iv) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Quer dizer que a caução poderá ser dispensada em caso de tutela antecipada de soma, bastando-se demonstrar que se trata de crédito de natureza alimentar ou a situação de necessidade que está à base da concessão da própria tutela.

Sublinhe-se que os arts. 520 e 521 não se aplicam sempre à execução da tutela antecipada de soma, mas apenas quando “couber” (art. 297, parágrafo único, CPC). Por outro lado, as regras que dizem respeito ao cumprimento provisório da sentença (arts. 520-522, CPC), quando não se referem apenas ao pagamento de soma, também são aplicáveis às hipóteses em que se pretende fazer, não fazer ou entrega de coisa (art. 520, § 5.º, CPC).

#### **4. A prisão como meio de coerção indireta**

O objetivo da norma constitucional que proíbe a prisão por dívida é vedar a prisão civil por descumprimento de obrigação que dependa, para seu adimplemento, da disposição de dinheiro. Nesse sentido é possível dizer que a norma constitucional proibiu a prisão por “dívidas pecuniárias”.<sup>137</sup>

Caso a sua intenção fosse a de proibir toda e qualquer prisão não haveria como explicar a razão pela qual deu conteúdo à prisão civil, afirmando que “não haverá prisão por dívida”. O entendimento de que toda e qualquer prisão está proibida implica em retirar qualquer significado da expressão “dívida”. Ademais, alegar que existem outras modalidades de dívida que não apenas a pecuniária e concluir que essas vedam a prisão, é nada dizer sobre a espécie de prisão proibida, mas simplesmente insistir na ideia de que a norma constitucional – de lado o caso de dívida alimentar – veda o uso de toda e qualquer prisão civil e, desse modo, prosseguir retirando o significado da expressão “dívida”. Mas, se não há como fugir da ideia de que foi proibida somente uma modalidade de prisão civil, e não toda e qualquer prisão civil, a prisão proibida somente pode ser a prisão por “débito”.<sup>138</sup>

A interpretação do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, deve ser alçada a um nível que considere os direitos fundamentais. Se é necessário vedar a prisão do devedor que não possui patrimônio – e assim considerar um direito fundamental –, é absolutamente indispensável permitir o seu uso para a efetividade da tutela de outros direitos fundamentais.

Não há dúvida de que o direito perde a sua qualidade se não puder ser efetivamente tutelado. A proibição de fazer justiça de mão própria não tem muito sentido se ao réu for dada a liberdade de descumprir a decisão que concedeu razão ao autor, pois nesse caso ele estará fazendo prevalecer a sua vontade como se o Estado não houvesse assumido o monopólio da jurisdição, cuja atuação efetiva é imprescindível para a existência do próprio ordenamento jurídico.

Ninguém pode negar que o processo exige, diante de certas situações de direito substancial, o uso da coerção indireta. Porém, a multa não constitui a única forma de coerção indireta e nem se pode dizer que é ela suficiente para a efetiva prestação da tutela jurisdicional. A multa não tem efetividade diante de um réu que não possui patrimônio. Por essa razão, a violação de direitos é muito fácil a pessoas inescrupulosas, uma vez que também não é difícil que estas possam constituir “testas-de-ferro” sem patrimônio para lesar, sem qualquer preocupação, direitos da personalidade – por exemplo.

Não admitir a prisão como forma de coerção indireta é aceitar que, em determinadas situações, o processo não terá efetividade, e, assim, que nestas hipóteses o ordenamento jurídico estará apenas proclamando os direitos. Soará absolutamente falsa e demagógica – por exemplo – a afirmação da Constituição Federal no sentido de que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações” (art. 225, caput), se não for possível – obviamente quando outro meio executivo não se mostrar adequado – a utilização da prisão como meio de coerção indireta para tutelá-lo. Seria o mesmo que interpretar tal norma constitucional como se ela dissesse que o meio ambiente, embora fundamental para a sadia qualidade de vida e para as futuras gerações, infelizmente não pode ser efetivamente tutelado em face de um réu que não se importa com os efeitos da multa. Ora, essa interpretação seria, para dizer o mínimo, incoerente.

A doutrina contemporânea, consciente da relevância de certos direitos de natureza não patrimonial, não pode ver na norma constitucional que proíbe a prisão por dívida uma porta aberta para a expropriação de direitos fundamentais para o homem.

Em uma interpretação realmente atenta aos direitos fundamentais e de acordo com a moderna hermenêutica constitucional, não há como enxergar apenas o que há de negativo na utilização da prisão.<sup>139</sup> Se ela constitui violência inconcebível em face de dívidas em sentido estrito, não há como deixar de se perceber o seu lado positivo diante da necessidade de tutela inibitória e de prestações que não dependam do desembolso de dinheiro, mas apenas do comportamento do demandado.<sup>140</sup>

Essa interpretação deixa de lado o conceito mítico de que a prisão civil é um simples atentado contra a liberdade dos cidadãos e propõe que se veja, ao lado da proibição da prisão civil por dívida pecuniária, a possibilidade do seu uso para impedir a expropriação dos direitos.

A forma de interpretação que não admite o uso da prisão como meio coercitivo constitui um método hermenêutico clássico, não suficiente quando comparado aos métodos hermenêuticos modernos<sup>141</sup>, absolutamente necessários quando o que se tem a interpretar, diante das características da sociedade contemporânea e da importância que nela assumem os direitos fundamentais, é um contexto de grande riqueza e muita complexidade. Não sendo o caso de apenas considerar o texto da norma, como se ela estivesse isolada do contexto, é necessário recorrer ao método hermenêutico-concretizador.

Deparando-se com a norma do art. 5.º, LXVII, da Constituição Federal, o intérprete deve estabelecer a dúvida que a sua interpretação suscita, isto é, se a norma veda o uso da prisão como meio de coerção indireta ou somente a prisão por dívida em sentido estrito. A partir daí, verificando que a norma aponta para dois direitos fundamentais, ou seja, para o direito à efetividade da tutela jurisdicional e para o direito de liberdade, deve investigar o que significa dar aplicação a cada um deles. Concluindo, a partir da análise da própria razão de ser destes direitos, que a sua aplicação deve ser conciliada ou harmonizada, não há como deixar de interpretar a norma no sentido de que a prisão deve ser vedada quando a prestação depender da disposição de patrimônio, mas permitida para a jurisdição poder evitar – quando a multa e as medidas de coerção direta não se mostrarem adequadas – a violação de um direito.

Note-se que essa interpretação, além de considerar o contexto, e por essa razão ser muito mais abrangente do que a “clássica”, dá ênfase aos direitos fundamentais, realizando a sua necessária harmonização para que a sociedade possa ver a sua concretização nos locais em que a sua própria

razão recomenda. De outra maneira os direitos ficarão desprovidos de tutela e, assim, o ordenamento jurídico, exatamente na parte que consagra direitos invioláveis e fundamentais, assumirá a configuração de mera retórica e, dessa forma, sequer merecerá ser chamado de “jurídico”.<sup>142</sup>

Os arts. 297 e 536 do Código de Processo Civil afirmam que o juiz pode determinar as medidas adequadas e necessárias à efetivação da tutela. Como tais normas configuram verdadeiras cláusulas gerais executivas, destinadas a dar ao juiz poder para a determinação da modalidade executiva adequada ao caso concreto, não há como lhe negar a possibilidade de ordenar sob pena de prisão. A prisão, nesse caso, é apenas um meio de execução das decisões do juiz civil e não um meio destinado a castigar alguém por um crime ou a compelir ao cumprimento de dívida pecuniária.

No caso em que se ordena um fazer cuja observância depende apenas do comportamento do réu e, além disso, não exige o dispêndio de patrimônio, o juiz pode ordenar o cumprimento – obviamente que dando para tanto prazo suficiente – sob pena de prisão. O demandado deve ter a oportunidade de justificar a eventual impossibilidade do cumprimento. Escoado o prazo sem manifestação ou rejeitada a justificativa, o juiz deve determinar a expedição do mandado de prisão. O tempo da prisão, no caso em que se pretende um fazer, deve servir para vencer a resistência do réu, embora deva ter um limite.

Ordenado um não fazer sob pena de prisão, ao demandado obviamente também deve ser conferida oportunidade para falar. Nesse caso, a ameaça não está na prisão em si, mas sim na possibilidade da sua ocorrência. Por isso, alguém poderia pensar que a execução dessa prisão tem caráter penal. Acontece que o fato de a prisão poder apresentar uma face preventiva e outra repressiva nada tem a ver com a sua natureza civil ou penal. A prisão civil, compreendida como meio de coerção indireta, serve para constranger a parte a cumprir as decisões do juiz. De modo que pode assumir a configuração de ameaça e de sanção privativa de liberdade.

Lembre-se de que exatamente o mesmo acontece com a multa civil, pois ainda que a ordem de não fazer sob pena de multa tenha nítida função intimidatória, a sua natureza é modificada quando a ordem não é observada e é praticado o fazer que se desejava impedir. De coerção indireta a multa é transformada em mera sanção pecuniária, embora não passe pela cabeça de ninguém que a multa assumiu natureza penal. A dupla feição da multa deriva da simples circunstância de que a ameaça que não é concretizada perde o seu valor. A multa tem que ser cobrada para que a sua função intimidatória seja conservada.

O juiz, ao ordenar um fazer ou um não fazer sob pena de prisão, deve fixar o seu prazo. O fato de tal prazo poder ser estabelecido pelo juiz decorre da própria natureza de meio executivo da prisão. Se a prisão, aqui, é um mero meio de execução das decisões do juiz civil, resulta natural que o seu prazo deve se amoldar aos casos concretos, do mesmo modo que acontece em relação à multa, cujo valor pode variar conforme o caso. Isso não quer dizer, como é óbvio, que não exista como controlar a racionalidade da fixação de tais prazos pelo juiz.

Lembre-se de que a prisão apenas pode ser usada quando a decisão não exigir dispêndio de dinheiro e depender do exclusivo comportamento da parte. Além disso, somente pode ser utilizada quando nenhum outro meio de execução se mostrar capaz de dar efetividade à decisão judicial. Porém, tudo isso deve ser perfeitamente demonstrado na motivação da decisão judicial. Como a prisão civil é um meio executivo, e esse não pode se desprender do caso concreto, é a motivação que viabiliza o controle da decisão judicial.

Por último, importa justificar a execução da prisão diante da tutela antecipatória. Cabe lembrar que a multa, apesar de ter o objetivo de forçar o cumprimento das decisões judiciais, tem o seu montante voltado à parte – e não ao Estado. Isso se deve à adoção de um modelo que ainda confunde a multa e a indenização, supondo que a multa também funciona como uma medida reparatória para a parte que tinha interesse na decisão não cumprida. De outra parte, a sua natureza intimidatória advém da ameaça da sua cobrança.

Tomando em consideração as circunstâncias de que o valor da multa cabe à parte e de que a força coercitiva da multa está na ameaça da sua cobrança, é correto concluir que a cobrança da multa deve ser admitida apenas após o trânsito em julgado – e não em face da tutela antecipatória, no curso do processo. Perceba-se que se a cobrança da multa – e não apenas a sua imposição ou a ameaça da cobrança – tivesse finalidade coercitiva, o seu valor deveria poder ser dispensado na hipótese de o réu se dispor a cumprir a decisão, mesmo que tardiamente. Porém, a cobrança da multa, reverta para o particular ou para o Estado, sempre terá conotação repressiva, pois se pudesse ser perdoada após o não cumprimento, apenas pela razão de o inadimplente vir a cumprir, perderia o seu efeito intimidatório. Ademais, conforme observado, tal valor é atribuído ao autor, como se tivesse natureza de ressarcimento. Diante dessa natureza, o pagamento do valor da multa ao autor, ainda que ele não tenha o seu direito reconhecido ao final do processo, configura genuíno enriquecimento sem causa. Dar ao autor o direito de executar o réu para cobrar multa devida pelo não cumprimento de decisão reputada injusta no próprio processo não pode significar outra coisa.

Alguém dirá que no caso de multa periódica a imediata execução da multa devida tem finalidade intimidatória. A multa fixada de modo periódico somente permitiria a execução do valor relativo ao período do descumprimento, pelo que o fim intimidatório da execução estaria em constranger o demandado a cumprir para a multa parar de incidir. Nesse caso, porém, além de o autor poder receber injustamente o valor da multa que já se tornou devido, o fim intimidatório da multa estaria sendo transferido para a sua execução parcial. Ocorre que não há racionalidade em imaginar que o réu somente é constrangido a cumprir quando a execução já foi requerida, a menos que esse aposte – não se importando com o acréscimo do valor da multa periódica – no seu sucesso ao final do processo, o que faz pensar em um otimismo quase que paranóico.

De qualquer forma, o que realmente impede a admissão da execução da multa no curso do processo é o fato de que o seu valor reverte à parte, o que significa que a finalidade da multa ainda é obscura no sistema brasileiro. Perceba-se que, quando se fala da finalidade da multa, não se está aludindo a algo semelhante à dupla face da prisão. A multa, ainda que deva ameaçar e ser executada (tendo dupla feição), deveria ter por objetivo apenas a efetividade das decisões do juiz, e não o de dar algo ao autor. Já a prisão, ao assumir dupla configuração, é obviamente sempre voltada à proteção das decisões judiciais.

No caso de não cumprimento de um fazer, não há como pensar em prisão cujo prazo se estende com o passar do tempo – à semelhança do que ocorre com a multa. A coerção da prisão está na aflição gerada pela sua execução, ao passo que o acréscimo do valor da multa é expediente expressamente previsto no Código de Processo Civil (art. 537, § 1º, I, CPC) para que a sua finalidade coercitiva possa ser potencializada e, assim, vencida a vontade do renitente.

Frise-se que a coerção da multa não está na sua cobrança parcial, mas sim no acúmulo do seu valor com o passar do tempo, ao passo que, em relação à violação de uma decisão que impõe um fazer, a prisão deve ser executada para constranger ao cumprimento. Para melhor explicar: o prazo da prisão não precisa ser cumprido se a decisão for observada, mas se a decisão for acatada a multa apenas não mais incidirá – embora possa ser cobrada –, o que significa que a execução da prisão e o acréscimo da multa (e não a sua execução) servem para constranger ao cumprimento.

Nessa dimensão, a diferença entre a prisão civil – vista como meio de execução – e a prisão criminal fica ainda mais nítida. Após a violação a prisão penal não pode ser perdoada, exatamente porque, ao contrário da prisão civil, não tem o objetivo de estimular a um fazer.<sup>143</sup>

A única ressalva que se poderia fazer é relativa à decisão que impõe um não fazer, uma vez que a ameaça, aí, estaria exclusivamente em momento anterior à violação. Acontece que a prisão é relacionada apenas com a atuação do poder do Estado, ou seja, com a efetividade das decisões jurisdicionais, não sofrendo do mesmo problema que obscureceu a finalidade da multa. Portanto, nada desautoriza a imediata execução da prisão no caso de descumprimento de decisão concessiva de tutela urgente – antecipada ou cautelar.

## **5. Execução da tutela antecipada de pagamento de soma em dinheiro**

### 5.1. As diferentes finalidades da tutela antecipada de pagamento de soma, da execução “provisória” da sentença e do arresto

Para que seja possível a compreensão do alcance do art. 300 do Código de Processo Civil é necessário que se perceba, antes de mais nada, a diferença de fim entre tutela antecipada de pagamento de soma em dinheiro, cumprimento provisório da sentença e arresto.

O cumprimento provisório, como foi tradicionalmente concebido, não supõe a necessidade de realização imediata do direito de crédito, mas apenas a necessidade de aceleração da atividade executiva para a segurança do juízo. A lição de Liebman não deixa dúvida:

na execução provisória o efeito suspensivo dos recursos, embora atenuado, todavia existe e opera na fase final da execução, quando, estando seguro o juízo, a espera não mais produz prejuízos<sup>144</sup>.

Também é interessante lembrar de curiosa lição de Alcides de Mendonça Lima:

pela natureza da causa, a lei coloca o requisito da rapidez acima do da justiça da execução em favor do credor no detrimento do devedor, pela expectativa desse no recurso que interpôs. Mas nem por isso deixa o devedor desamparado. Estipula tais restrições que, praticamente, o credor não obtém vantagem alguma com sua pressa.<sup>145</sup>

Estas clássicas lições estão a falar da execução que paralisa na penhora de bem, sem admitir a sua expropriação. Deixam claro que a “execução provisória” pode ser suspensa porque “a espera não mais produz prejuízos” e que, mediante esta forma de execução provisória, o “credor não obtém vantagem alguma com sua pressa”.<sup>146</sup> O objetivo desta execução, portanto, obviamente não é satisfazer aquele que imediatamente necessita de soma em dinheiro, mas apenas garantir a viabilidade da futura e eventual realização do crédito.

Pensando-se na perspectiva do cumprimento provisório que pode ser completo, ou seja, que pode realizar o direito de crédito (art. 520, IV, do CPC), não há como fugir da constatação de que a tutela antecipada e a execução *completa* da sentença impugnada realizam – e não apenas asseguram – o direito. A diferença entre tutela antecipada de soma e execução provisória *completa* é a de que, na segunda hipótese, o fundamento para a realização imediata do direito não é o perigo de dano.

Os alemães já deixaram claro que o fim do arresto nada tem a ver com o objetivo da antecipação do pagamento de soma em dinheiro,<sup>147</sup> demonstrando que o fim da antecipação não é o de acautelar o direito de crédito, mas o de proteger o direito que somente através da realização do direito de crédito pode ser adequadamente tutelado. A antecipação do pagamento de soma em dinheiro não objetiva assegurar a tutela do direito de crédito; essa é a função do arresto cautelar. A tutela antecipada objetiva suprir uma necessidade imediata. De modo que o autor, em caso de tutela antecipada, não pode esperar – sem perigo de dano – a realização do direito de crédito. Na antecipação, ao contrário do que ocorre no arresto, parte-se da premissa certa de que a espera produzirá prejuízos, não sendo suficiente, por causa disto, a mera segurança do direito de crédito. A tutela antecipada de soma em dinheiro, quando fundada no art. 300, é medida idônea para impedir prejuízo a um direito conexo ao direito de crédito,<sup>148</sup> enquanto o arresto é destinado a assegurar a viabilidade da sua realização.<sup>149</sup>

A antecipação fundada em perigo de dano a um direito conexo ao direito de crédito não pode ser suspensa após a penhora não só porque o caso não é de necessidade de segurança do direito de crédito, mas principalmente porque na hipótese de antecipação a espera pode trazer prejuízos ao direito que é conexo ao direito de crédito.

Isto igualmente permite explicar que o perigo de dano não é suficiente para atribuir natureza cautelar à tutela provisória. Antônio Cláudio da Costa Machado – assim como alguns outros processualistas – ingenuamente supõe que toda tutela baseada em perigo de dano é “cautelar”, como se o perigo fosse nota exclusiva desta tutela. Costa Machado diz expressamente que “o periculum in mora é característica exclusiva da cautelaridade”.<sup>150</sup> Na verdade, quem pensa assim tem que atribuir natureza cautelar à execução da sentença baseada em periculum in mora – que



foi admitida por cinquenta anos na Itália. Porém, há forma bem mais fácil de demonstrar o erro de raciocínio daqueles que pensam que a tutela antecipada baseada em *periculum* é cautelar. Uma tutela somente pode ser dita cautelar quando é incapaz de realizar o direito que é postulado através da ação. Ora, como é absolutamente lógico, ninguém pode acautelar o que já foi realizado.

Mas alguém poderia dizer que a tutela, embora realize o direito material, acautela a sentença. Ora, supor que a tutela antecipada acautela a sentença configura completo desprezo pelo direito material e inacreditável valorização da técnica processual. Se o processo é instrumento para a realização do direito material, é evidente que as técnicas processuais devem ser pensadas nesta dimensão. Se a técnica de antecipação realiza o direito material, é absurdo pensar que está acautelando outra técnica de prestação do direito material, a menos que se pense que o direito material apenas pode ser realizado pela sentença.

Aliás, o desvio que leva a supor que a tutela antecipada é cautelar também deriva da falsa ideia de que toda tutela anterior à declaração do direito – que ocorreria na sentença – constitui tutela cautelar, pouco importando a sua função, e assim o que acontece com o direito material.<sup>151</sup> Porém, a tutela antecipada de soma realiza o direito material do mesmo modo que a sentença condenatória seguida da execução por expropriação. Quando se propõe ação para se obter soma em dinheiro e esta é obtida desde logo, é óbvio que o direito é realizado e não apenas acautelado.

Na verdade, o equívoco do raciocínio que conclui que a tutela antecipada é cautelar está precisamente na falta de percepção de que antecipação de soma realiza o próprio direito buscado através da ação, protegendo apenas um direito conexo ao direito almejado, como corretamente observou a doutrina alemã para demonstrar que o arresto cautelar nem sempre é suficiente, podendo ser necessária a antecipação de soma.

## **5.2. O uso da multa para dar efetividade à tutela antecipada de soma em dinheiro**

A tutela antecipada de soma supõe a possibilidade da sua execução – ou a possibilidade da realização do crédito – no curso do processo. Além disso, a execução dessa espécie de tutela antecipada não precisa observar as regras da execução por expropriação, uma vez que o art. 297 afirma que o juiz pode se valer das medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Assim, por exemplo, é certamente possível o uso dos “meios de execução” próprios à tutela alimentar do direito de família para dar efetividade à tutela antecipada na ação ressarcitória.

Porém, não pode ser descartada a coerção patrimonial indireta (multa) para dar efetividade à tutela antecipada de soma, como, aliás, expressamente autoriza o art. 139, IV, do CPC. Realmente não tem cabimento o argumento no sentido de que a decisão concessiva de tutela antecipada de soma não pode ser executada mediante meio executivo diverso do predisposto para a sentença de condenação. A par do erro de supor que as sentenças condenatórias só possam ser efetivadas por meio de expropriação patrimonial, o que justifica a tutela antecipada é algo absolutamente diverso daquilo que está à base da sentença condenatória. A tutela antecipada concedida a partir de uma situação de urgência não “combina” com a execução por expropriação justamente porque deve realizar prontamente – ou sem delongas – o direito. A decisão concessiva de tutela antecipada carece de maior efetividade e, assim, os seus meios executivos devem ser diferentes daqueles que foram tradicionalmente associados à sentença que condena ao pagamento de dinheiro.

Como diz Taruffo, a melhor execução é aquela que não é necessária. A forma ideal de realização de um direito se dá por intermédio do adimplemento voluntário.<sup>152</sup> Ora, se o desejável é o adimplemento voluntário, a melhor via de execução é a indireta, ou seja, aquela que atua sobre a vontade do obrigado visando ao seu adimplemento. Note-se que a execução sob pena de multa, além de propiciar tutela jurisdicional tempestiva e “livrar” a administração da justiça de um procedimento oneroso e longo, elimina os custos e os riscos inerentes à execução por expropriação, culminando por ser mais benéfica também ao devedor.

A execução sob pena de multa somente tem sentido em relação ao devedor que possui patrimônio suficiente para responder ao crédito. Na hipótese de devedor sem patrimônio, não



cabe, como é óbvio, a “execução” sob pena de multa. Assim, na hipótese de tutela antecipada de soma, o juiz deve dar ao réu a oportunidade de justificar o não adimplemento. Ademais, é fundamental que se estabeleça prazo suficiente para o réu adimplir, sendo que a sua justificativa também pode ser no sentido de que necessita de mais tempo para cumprir a obrigação.

Imaginar que o emprego da multa não tem efetividade para a tutela antecipada de soma com base no argumento de que o inadimplente não se importa com a multa não tem qualquer fundamento. Como é evidente, a multa certamente pode atuar sobre a vontade daquele que possui patrimônio, pois este tem plena consciência de que não é “compensador” esperar – e assim contar com o tempo do processo – para pagar o “principal” com multa. Supor que a multa não é meio executivo capaz de dar efetividade à determinação de pagamento de soma é partir do pressuposto equivocado de que o devedor nunca tem patrimônio para adimplir.<sup>153</sup>

Note-se que esta percepção não só é importante para a efetividade da tutela antecipada de soma, mas também abre oportunidade para meditação em torno da execução da sentença condenatória, ou seja, para o questionamento da aplicabilidade da multa para dar efetividade à condenação ao pagamento de dinheiro<sup>154</sup>.

Deixe-se claro que não se está propondo a troca da execução por expropriação pela execução através de multa, mas a possibilidade de utilização da multa como uma das modalidades executivas para dar efetividade à tutela jurisdicional. O que não adianta é apenas tentar dar maior celeridade à execução por expropriação, como se esta fosse a única e melhor alternativa para conferir efetividade à tutela antecipada de soma ou mesmo à sentença condenatória.

### **5.3. O emprego da penhora *on line***

Diante da necessidade da imediata efetivação da tutela antecipatória de soma, a penhora *on line* aparece como alternativa bastante importante. Há algum tempo, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho da Justiça Federal firmaram convênio com o Banco Central, mediante o qual juízes com senhas cadastradas têm acesso, por meio da internet, a um sistema de consultas desenvolvido pelo Banco Central (Bacenjud) para a obtenção de informações sobre eventuais depósitos bancários dos devedores.

Mediante esse sistema, o juiz pode encaminhar ofícios eletrônicos (via internet) às instituições financeiras solicitando informações sobre a existência de contas correntes e aplicações financeiras, determinando bloqueio e desbloqueio de contas, ou requerendo outras informações próprias.

Lembre-se de que, para a requisição de informações ao Banco Central ou a outros bancos, o credor não precisa ter esgotado todas as atividades necessárias para a localização de bens penhoráveis. Não deveria ser preciso dizer que surge ao autor, diante do descumprimento da tutela antecipada, o direito de imediatamente obter dinheiro. Pouco importa que existam ou tenham sido nomeados outros bens penhoráveis, não só porque o credor tem o direito de penhorar dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), como ainda porque a efetividade da tutela antecipatória depende da imediata obtenção de soma. Porém, como ao autor é impossível descobrir se o devedor possui dinheiro depositado em instituição financeira – e em valor suficiente –, não lhe resta outra saída senão pedir ao juiz que requisiite informações ao Banco Central.

Por isto, quando o juiz requisitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, essas devem se limitar à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor do crédito.

A penhora *on line* é um instrumento de grande valor para a execução da tutela antecipatória, especialmente se o juiz ordenar o pagamento sob pena de multa aludindo ao art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que prevê a incidência de outra multa – de até vinte por cento do valor atualizado do débito – nas hipóteses em que o executado “se opõe maliciosamente à execução”, “dificulta ou embaraça a realização da penhora” ou não indica “quais são e onde estão

os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores” (art. 774, II, III e V, CPC).

É evidente que a penhora on line somente tem efetividade quando o réu possui dinheiro em instituição financeira. Contudo, quando o devedor toma consciência de que basta um ofício eletrônico para a descoberta de dinheiro em suas contas bancárias e, mais do que isso, que o seu inadimplemento ou a retirada maliciosa do dinheiro da conta conduzirá ao acréscimo do seu débito em razão de multa que deve ser fixada em valor realmente capaz de intimidar, certamente preferirá pagar imediatamente a correr o risco – que passa a ser real – de ter que pagar bem mais pelo inadimplemento ou pelo “esvaziamento” de suas contas.

A penhora on line, como é evidente, abre oportunidade para o levantamento do dinheiro sem a prestação de caução. A dispensa da caução está autorizada no art. 521, I e II, que estabelece a sua inexigibilidade quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e quando o credor demonstrar situação de necessidade. Como é evidente, exigir caução seria negar a necessidade da soma e a urgência que legitimaram a própria concessão da tutela antecipada de soma.

#### **5.4. A tutela antecipada na ação ressarcitória**

##### **5.4.1. *Justificativa***

Montesano observa que no direito italiano admite-se a antecipação do pagamento de soma em dinheiro quando a prestação em dinheiro é o instrumento para proteger ou reintegrar um bem não patrimonial: por exemplo, prestações alimentares; retribuições devidas em obediência ao art. 36 da Constituição (direito de sustento do trabalhador); antecipação de soma devida para a “reintegração específica” de um bem não patrimonial ilicitamente lesado, indenização antecipada para aliviar um estado de necessidade (e assim a lesão à dignidade humana) causado pelo ilícito.<sup>155</sup>

Há casos, de fato, em que a realização do direito de crédito é imprescindível para permitir a realização de um direito fundamental, como o direito à saúde ou o direito à educação. A vítima de ato ilícito que precisa realizar urgentemente despesas médicas obviamente não pode esperar o tempo do processo e, portanto, quando desde logo pode evidenciar o seu direito e a sua necessidade, tem direito à antecipação do pagamento. O mesmo vale para, v.g., a mulher do falecido em acidente automobilístico que fica impossibilitada de atender às suas necessidades e às dos filhos.<sup>156</sup>

Ovídio Baptista da Silva há muito tempo advertiu que o direito brasileiro não possuía

regra similar à que existe no direito italiano, que prevê a concessão de uma provisional genérica, no art. 278 do Código de Processo Civil, por onde será sempre possível fazer entrar as provisionais de alimentos nos casos em que sejam estes devidos fora do direito de família.<sup>157</sup>

Julgados mais sensíveis e atentos a situações excepcionais, é certo, admitiam os alimentos provisionais em ação de indenização fundada em ato ilícito. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por exemplo, reconhecendo que o Código de 1973 não permitia os alimentos provisionais na ação de indenização, concluiu:

a ação principal é de indenização por ato ilícito, que, normalmente, não comportaria os alimentos provisionais. Mas, como não os conceder, nas circunstâncias espelhadas nestes autos? Como deixar perecer uma mulher viúva, lides domésticas, responsável por cinco menores em idade variável de quatro a onze anos? (...).<sup>158</sup>

Lembre-se, entretanto, que o juiz italiano, ao conceder a provvisionale do art. 278, parte da certeza sobre o an debeatur e concede a tutela (a provvisionale) nos limites da quantia que já está provada. Há, desta forma, cognição exauriente sobre o an debeatur e sobre a quantia objeto da provisional, muito embora a condenação seja parcial, ou seja, de parcela da quantia postulada pelo autor. É o que explica Federico Carpi:

a cognição do juiz é plena e completa, seja no que diz respeito à existência do direito (an debeatur),

seja no pertinente ao valor em relação ao qual se entende a prova suficiente, valor que constitui assim a medida da provvisionale. Um é a premissa do outro, mas para a pronúncia parcial não se faz referência a uma ‘presumibile entità’ (como por exemplo no art. 24 da Lei 990/1969), ou mesmo a um *fumus boni iuris*, se bem que se fala de obtenção da certeza da prova, mesmo que seja sobre uma parte da demanda proposta.<sup>159</sup>

A provvisionale, como se vê, equiparava-se à tutela antecipada de parcela incontroversa de parcela do pedido (art. 273, § 6º, CPC/1973) e, atualmente, encontra similar no julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, CPC). Não há como equiparar a provvisionale italiana à tutela antecipada de soma fundada em perigo (art. 300, CPC).

A tutela antecipada baseada no art. 300, ou seja, a tutela antecipada fundada em probabilidade e que é justificada por uma necessidade imediata, encontra figura similar, no direito italiano, na tutela do art. 24 da Lei 990, de 24.12.69. Esta Lei 990, ao introduzir o seguro obrigatório por responsabilidade civil em caso de acidente de veículos, previu a possibilidade de a vítima requerer, encontrando-se em estado de necessidade e com base na probabilidade do seu direito, a antecipação de até quatro quintos da soma postulada. Eis o que diz o art. 24:

24. [1] No curso do processo em primeiro grau, os que têm direito ao ressarcimento e que, em virtude do acidente, venham a encontrar-se em estado de necessidade, podem pedir que lhes seja entregue uma soma a imputar-se na liquidação definitiva do dano. [2] O juiz instrutor civil ou penal, ouvidas as partes, se de um sumário accertamento resultam graves elementos de responsabilidade a cargo do condutor, com ordinanza imediatamente executiva, determina a entrega de soma nos termos da parte primeira, no limite de quatro quintos do presumível importe do ressarcimento que será liquidado com a sentença.

Tendo em vista que o art. 24 fala de “gravi elementi di responsabilità” e de “sommario accertamento”, é preciso deixar claro que a doutrina italiana admite a tutela antecipada com base em probabilidade, não equiparando a tutela do artigo 24 com a provvisionale do artigo 278. A prova está na seguinte passagem das “Lezioni” de Proto Pisani:

No art. 24 (...) o legislador estabeleceu que, ‘no curso do processo em primeiro grau, os que têm direito ao ressarcimento e que, em virtude do acidente, venham a encontrar-se em estado de necessidade, podem pedir que lhes seja entregue uma soma a imputar-se na liquidação definitiva do dano’. A utilidade prática da regra é evidente: garante-se uma forma de tutela jurisdicional urgente a favor de quem foi posto em estado de necessidade por causa do acidente, desonerando o acidentado da demora do procedimento comum de conhecimento ou do processo penal em relação ao qual a ação civil foi exercitada. Esta hipótese de ‘provvisionale’ se diferencia nitidamente da provisional genérica do art. 278, parte segunda, particularmente porque: a) a declaração relativa à responsabilidade do condutor e ao importe do dano que será liquidado com a sentença é sumária; b) consequentemente, a provvisionale tem caráter provisório e pode ser modificada no curso do processo diante do mesmo juiz, se o accertamento pleno conferir resultados opostos ou diversos do accertamento sumário: isto se deduz textualmente da última parte do art. 24, local em que se afirma que ‘l’ordinanza può essere revocata con la decisione di merito’ (...).<sup>160</sup>

Como está claro, o direito italiano admite a antecipação de pagamento de soma, em favor da vítima de acidente que se encontra em estado de necessidade, a partir da probabilidade da existência do direito, ou seja, do *fumus boni iuris*. O art. 300, ao generalizar a possibilidade de obtenção de tutela antecipada fundada em probabilidade do direito e perigo de dano, obviamente permite a antecipação de pagamento de soma em favor da vítima na ação ressarcitória. Lembre-se que os tribunais brasileiros<sup>161</sup> acolheram a tese da antecipação do pagamento de soma – sustentada quando da introdução da tutela antecipada no Código de 1973<sup>162</sup>.

#### **5.4.2. A natureza alimentar da tutela antecipada na ação ressarcitória**

Como diz Pontes de Miranda, juridicamente

os alimentos compreendem tudo o que é necessário ao sustento, à habitação, à roupa (Ordenações Filipinas, Livro I, Título 88, 15: ‘(...) o que lhes necessário for para seu mantimento, vestido e calçado e todo o mais), ao tratamento de moléstias’ (M. A. Coelho da Rocha, *Direito civil português*, I, 219) e, se o alimentário é menor, às despesas de criação e educação (Ordenações Filipinas, Livro I, título 88, 15: ‘E mandará ensinar a ler e escrever àqueles que forem para isso’).<sup>163</sup>

Por outro lado, como se sabe, o dever de prestar alimentos pode decorrer da lei, de convenção ou de ato ilícito (arts. 948, 949, 950 e 951 do Código Civil). Assim, na perspectiva da fonte da obrigação alimentar, os alimentos costumam ser classificados em legítimos (devidos em razão de norma legal), voluntários (constituídos por negócio jurídico inter vivos ou mortis causa) e indenizativos (derivados de ato ilícito).

#### **5.4.3. A efetivação da tutela antecipatória na ação de ressarcimento**

Na efetivação da antecipação na ação de indenização fundada em ato ilícito, ordena-se que o réu efetue o pagamento ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, CPC). Em caso de não atendimento à ordem, o juiz deverá determinar – obviamente que se for possível no caso concreto – o desconto em folha de pagamento da importância da prestação devida (art. 529, CPC). Será viável, ainda, o desconto de aluguéis ou de outros rendimentos do devedor.

Há quem entenda ser inadmissível o desconto em folha de pagamento no caso de alimentos devidos por ato ilícito. Entretanto, não há motivo para se dar meio de execução diverso aos alimentos indenizativos. Em outros termos, a diferença de fonte não pode servir para determinar a diferenciação de meio executivo. O que importa, sem dúvida, é o fim, a exigir meio executivo efetivo. A razão, portanto, está com Pontes de Miranda:

Os alimentos de que cogita o art. 734 [art. 529, CPC/2015] são quaisquer alimentos a que foi condenada alguma das pessoas a cuja classe ele se refere, sejam alimentos de direito de família, ou alimentos de origem negocial ou em virtude de ação de indenização por ato ilícito se o condenado não pagou e nela se incluiu prestação de alimentos.<sup>164</sup>

Não tendo o réu atendido à ordem e não sendo possível, no caso concreto, o desconto em folha ou o desconto de alugueres ou rendas, poderá ser aplicada a prisão. Alguns julgados sustentam que a prisão civil por dívida, como meio coercitivo para o adimplemento da obrigação alimentar, é cabível apenas no caso dos alimentos pertinentes ao direito de família. De modo que seria inadmissível a sua cominação “por falta de pagamento de prestação alimentícia decorrente de ação de responsabilidade ex delicto”.<sup>165</sup>

Não há razão para discriminar o credor de alimentos indenizativos, deixando sem efetividade a tutela antecipatória que lhe concede alimentos.<sup>166</sup> A menos que se entenda, por exemplo, que os filhos daquele que se afasta do lar merecem tutela jurisdicional mais efetiva do que os filhos que têm o pai morto em acidente automobilístico.

O autor poderá optar entre a coerção pessoal e a expropriação de bens do réu, não estando obrigado a abrir mão do meio idôneo, ao contrário do que já entendeu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – certamente ainda apegado a ideologia superada, que dá valor injustificável ao princípio da intangibilidade física.<sup>167</sup>

Porém, nada impede que o autor peça que o réu seja compelido a pagar a soma antecipada sob pena de multa. O fato de a execução por expropriação estar predisposta para a sentença de condenação não significa que a utilização da multa está proibida para a tutela antecipada ou mesmo para a própria condenação. Na verdade, como a execução por expropriação é inidônea para a tutela antecipada de soma – e exatamente por isso podem ser utilizados o desconto em folha, o desconto de rendas periódicas ou a coerção pessoal –, nada impede que se prefira a multa em relação a essas modalidades executivas.

Lembre-se de que a tutela antecipada, nesses casos, não apenas responde ao direito aos alimentos indenizativos, mas atende ao direito à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Ora, como as regras processuais devem ser interpretadas conforme os direitos fundamentais, e por isso o direito à tutela antecipada não é apenas o direito à decisão que a concede, mas sim o direito à sua execução e obtenção, não há como não admitir o emprego da multa como meio coercitivo. Aliás, a possibilidade do uso da multa também é decorrência da possibilidade do uso da coerção pessoal. Ora, o autor não apenas pode, mas na verdade deve usar meio executivo menos agressivo quando igualmente idôneo. A multa, por constituir meio idôneo e que gera menor restrição ou gravame, sempre deve ser

aplicada antes da prisão, sob pena de violação à regra da necessidade, sub-regra da regra da proporcionalidade<sup>168</sup>.

A tese que discrimina o credor de alimentos indenizativos, ilógica e distante da realidade social, certamente não pode ser admitida pelo juiz atento à razão de ser da tutela antecipada. Todos os que conhecem a realidade da prática forense sabem que os réus de ações de ressarcimento, principalmente quando o autor é economicamente frágil, valem-se da demora do processo para obter vantagens econômicas. De fato, o autor, nestas ações, não raramente é obrigado a abrir mão de parte do seu direito apenas por não poder suportar a lentidão da justiça, a qual lamentavelmente costuma ser lembrada pelos interessados em desestimular o acesso à justiça ou em obter acordos imorais.

#### ***5.4.4. A execução da tutela antecipatória de soma em dinheiro, na ação de ressarcimento, admite a expropriação de bem e não está submetida à prestação de caução***

Partindo-se da premissa de que a prisão e a multa se mostraram insuficientes, suponha-se a penhora de bem imóvel do demandado. Seria possível a sua alienação? A impossibilidade da antecipação do pagamento de soma em dinheiro, como é sabido, pode ocasionar prejuízo irreversível ao autor. Assim, negar ao juiz a possibilidade de admitir a alienação, em determinados casos, é o mesmo que obrigá-lo a assistir a uma lesão a um direito que depende da realização de um direito de crédito devidamente evidenciado.<sup>169</sup>

O cumprimento provisório da sentença autoriza “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado”, desde que prestada “caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, CPC). Assim, como a efetivação da tutela antecipada se submete ao regime do cumprimento provisório da sentença, é certo que, para a efetivação da tutela antecipada, é possível alienar bem de propriedade do demandado. Não obstante, como aquele que necessita de tutela antecipada de soma está em situação incompatível com a prestação de caução, essa pode ser dispensada nos termos do art. 521, I e II, que expressamente prevê a sua inexigibilidade quando i) o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem ou ii) o credor demonstrar situação de necessidade.

Como se vê, se é possível a expropriação de bem antes de findo o processo, mesmo na execução da tutela antecipada (arts. 297, parágrafo único e 520, IV, CPC), também não se discute que a caução pode ser dispensada – seja para o levantamento de dinheiro, seja para a prática de atos que importem alienação de propriedade – nos casos de verba de natureza alimentar ou quando o exequente se encontrar em estado de necessidade.

O Código de 2015 corretamente deixou de relacionar a dispensa da caução com o valor do crédito postulado. O art. 475-O, § 2.o, I, do Código de 1973 afirmava que a caução apenas podia ser dispensada “até o limite de sessenta vezes o valor do salário mínimo”. Contudo, como foi dito para contestar tal limitação à época do Código revogado,

se a necessidade importar soma superior a sessenta salários mínimos e isto restar devidamente demonstrado, não há como obrigar o exequente a prestar caução para ter o seu direito realizado, sob pena de se discriminar aquele que possui maior necessidade de verba alimentar. Ora, a ideia de dispensar a caução não tem relação com o valor da soma, mas com a necessidade do exequente, que pode ser de vinte ou até mesmo de oitenta salários mínimos – no caso em que, por exemplo, é necessária uma operação cirúrgica.<sup>170</sup>

Registre-se que no direito alemão — assim como nos direitos inglês, italiano e francês — é admitida a antecipação do pagamento de soma em dinheiro,<sup>171</sup> mas o *Verfügungsgrund* (a causa da antecipação) deve ser evidenciado e os tribunais são aqui mais severos do que em outros casos.<sup>172</sup> O mesmo deve ocorrer no direito brasileiro em caso de antecipação de pagamento de soma em dinheiro.

## **6. A execução da tutela da evidência**



A tutela da evidência deve ser vista como necessidade derivada do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.<sup>173</sup> Na sua falta, o Estado estaria impedido de distribuir o ônus do tempo entre as partes e, assim, de exercer o poder jurisdicional através de um processo isonômico.

Por isso, é completamente absurdo pensar que a tutela da evidência somente poderá produzir efeitos a partir da sua confirmação pela sentença. Se assim fosse a tutela não teria qualquer utilidade, já que o ônus do tempo do processo jamais seria distribuído. Ora, se a tutela da evidência é concedida porque há direito evidente e defesa de mérito indireta inconsistente, é certo que a sua execução deve ocorrer no curso do processo.

Contudo, seria possível argumentar que a tutela da evidência, ainda que tendo eficácia imediata, deve ter os seus efeitos suspensos por eventual recurso. A decisão concessiva de tutela da evidência configura decisão interlocutória e, assim, desafia recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC). Ainda que esse recurso deva ser recebido apenas no efeito devolutivo e, por isso, não deva obstar o andamento do feito, é preciso demonstrar os motivos que inviabilizam a suspensão dos efeitos da tutela da evidência.

Quando os fatos constitutivos são incontroversos e a defesa de mérito indireta é infundada, existem incontestáveis motivos para a tutela da evidência e, dessa forma, para a sua imediata execução. Qual a razão para supor, então, que o agravo deva ser recebido, nesses casos, no efeito suspensivo? Nenhuma. Se o direito é evidente e há defesa de mérito indireta infundada, não há racionalidade em obrigar o autor a suportar o tempo para o processamento do recurso. A conclusão que o autor deve arcar com o tempo do recurso interposto contra a própria decisão que o liberou de tal ônus seria mais do que incoerente.

A execução da tutela da evidência é imediata, mas deve atender ao art. 520 do Código de Processo Civil, pois é uma execução fundada em título provisório. Nos casos de tutela da evidência que impõe fazer, não fazer ou entrega de coisa, a execução é feita de acordo com as regras dos arts. 536 a 538 do Código de Processo Civil. Mas, na hipótese de soma em dinheiro, a execução é por expropriação, conforme o art. 523 e seguintes.

A execução da tutela de soma em dinheiro subordina-se ao art. 520, IV, que diz que

o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Portanto, a tutela da evidência também autoriza a prática de atos que importem alienação de propriedade ou o levantamento de dinheiro, desde que prestada caução.

Na execução da tutela da evidência de soma em dinheiro, como acontece diante de qualquer espécie de execução, é necessário aplicar a regra da menor restrição possível. Diante da possibilidade – ainda que remota – de o autor poder ter o seu direito não reconhecido ao final, a expropriação deve recair no bem que comporte a consequência menos gravosa ao executado.<sup>174</sup>

De qualquer forma, o agravante pode requerer ao relator que suspenda os efeitos ou limite a execução da tutela da evidência quando puder demonstrar que a execução pode resultar dano grave (art. 1.019, I, CPC). De maneira que a situação está envolvida em um “sistema de pesos e contrapesos”, uma vez que, se a tutela da evidência deve ser executada imediatamente, pode ter os seus efeitos suspensos. Não há como negar que a construção desse sistema privilegia os valores constitucionais, pois não só permite que o juiz trabalhe com um processo realmente isonômico, como ainda cuida dos direitos fundamentais processuais do autor e do réu.<sup>175</sup>

## **7. A restituição das coisas no estado anterior e a reparação dos danos provocados pela execução da tutela provisória – cautelar, antecipada e da evidência**

A execução da tutela provisória e a execução provisória da sentença constituem atos jurídicos lícitos que podem dar causa, quando indevidos, à restituição ao estado anterior e/ou ao ressarcimento (art. 520, I e II, CPC). É possível a restituição ao estado anterior quando é viável a



volta ao estado material que era anterior à tutela provisória. Quando é possível a restituição ao estado anterior e ainda assim ocorreram danos cabe pedir, cumulativamente, ressarcimento.

Nos casos de irreversibilidade,<sup>176</sup> o réu tem direito à indenização. Tratando-se de tutela provisória – antecipada ou da evidência – que foi executada mediante a expropriação de bem, não é viável o desfazimento da arrematação. Diz o § 4º do art. 520 que

a restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

Porém, alguém poderia argumentar que o réu não pode ser prejudicado por uma alienação fundada num direito declarado inexistente. Clito Fornaciari Júnior, tratando da possibilidade do desfazimento da arrematação no caso da alienação na pendência do recurso interposto contra a sentença de improcedência dos embargos, afirmou que

o Estado não podia alienar aquele bem se não houvesse dívida, e, no caso, ficou provado, com o provimento do recurso, que não há dívida; então, ele não poderia alienar, e, se o fez, voltam as coisas ao estado anterior.<sup>177</sup>

No entanto, na execução de título extrajudicial embargada, na execução provisória, ou mesmo na execução das tutelas antecipada e da evidência, não é vedada a expropriação do bem (art. 520, IV, CPC). O terceiro não arremata algo que não poderia ser alienado e, portanto, não pode ser prejudicado pela declaração de inexistência do direito de crédito. A inexistência do direito de crédito e, assim, a pretendida ausência de fundamento, diz respeito somente às partes do processo em que o bem é arrematado, devendo ser resolvida em indenização.

No caso de tutela antecipada ou da evidência, declarando-se a inexistência do direito, fica o autor obrigado a restituir ao réu a quantia, ainda que a tutela antecipada tenha ocorrido na ação ressarcitória. A suposição de que o autor da ação ressarcitória não terá condições financeiras para responder pelo prejuízo causado ao réu nada tem a ver com o seu dever de indenizar.

Importa notar que, tratando-se de tutela de cognição sumária, o autor tem o dever de indenizar o réu porque o Estado concluiu que ele não possui o direito que fundou a tutela.

**Art. 298.** Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

## **1. Convicção de probabilidade, racionalidade da decisão e critérios decisoriais**

Quando se pensa na probabilidade suficiente para a concessão da tutela provisória – de urgência ou da evidência, o real problema está na racionalidade da decisão judicial, ou melhor, no controle da racionalidade da decisão que concede, ou não, a tutela.<sup>178</sup> Acontece que essa racionalidade não pode ser garantida mediante uma artificial e impossível determinação de um grau de probabilidade.

O juiz tem o dever de justificar a decisão que concede a tutela provisória, conforme fez questão de frisar o art. 298 do Código de Processo Civil. Sucede que o juiz, embora ciente dessa necessidade, resente-se da falta de critérios para explicar “seu convencimento de modo claro e preciso”. Tal falta de critérios também impede o advogado de poder controlar a decisão do juiz, uma vez que, se a decisão sequer tem adequada justificativa, torna-se impossível argumentar que a decisão é incorreta. Não é por razão diversa que são comuns as decisões de primeiro grau que concedem ou negam a tutela sumária – especialmente antecipada – sem qualquer fundamento idôneo e as decisões de segundo grau que a revogam ou mantêm sem nada argumentar de forma convincente.

## **2. Justificativa da convicção de probabilidade**

Afastar-se desde logo a absurda e inexplicável ideia de que a justificativa da decisão da tutela de urgência não exige a mesma atenção da justificativa da sentença. Ninguém mais duvida de que o

raciocínio probatório não pode ser demonstrado através do método axiomático-dedutivo, peculiar à matemática, como também é inegável que as exigências postas pelas novas situações de direito material ampliaram o poder decisório do juiz, que agora pode decidir no curso do processo apenas com base em convicção de probabilidade. Porém, isso obviamente não pode conduzir à ideia de que o juiz não pode ser controlado. A garantia da motivação das decisões tem relação com a necessidade de controle do juiz, que deve justificá-las não só para legitimar o exercício do seu poder perante a população, mas também para dar às partes o direito de compreendê-las e impugná-las perante os tribunais. Em outras palavras, aceitar uma decisão sem justificativa é o mesmo que impedir a adequada participação das partes e retirar a legitimidade do Poder Judiciário.<sup>179</sup>

O juiz, ao valorar a credibilidade das provas, ao estabelecer a ligação entre as provas e os fatos e ao valorar as presunções e o conjunto probatório, submete o seu raciocínio a sistemas e critérios racionais, embora não possa explicá-los através da lógica matemática. Tais critérios permitem-lhe decidir e justificar a sua decisão, embora muitas vezes necessitem da adição de outros, próprios ao método sistemático, como os da coerência e da congruência, capazes de também auxiliar na decisão judicial.

A tutela provisória requer convicção de probabilidade (arts. 300 e 311, CPC). Porém, se o juiz não pode deixar de conceder a tutela de urgência com base no argumento de que o autor não se eximiu do ônus da prova, na hipótese típica de tutela da evidência os fatos constitutivos são incontroversos e a dúvida recai sobre as alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos – cujo ônus da prova é do réu. Tratando-se de tutela da evidência, a probabilidade em regra diz respeito à defesa de mérito indireta. E nesse caso a probabilidade deve ser de que a defesa é infundada ou não será acatada.

A tutela de urgência apresenta-se necessária quando a posição do autor está gravemente fragilizada, já que está sendo ameaçada por perigo de dano. Para tornar possível a sua proteção, outorgou-se expressamente ao juiz a possibilidade de decidir com base em probabilidade, o que significa que ele está proibido de pensar em uma convicção de verdade, própria à regra do ônus da prova. Para a concessão da tutela de urgência, basta-lhe a convicção de probabilidade ou verossimilhança preponderante, isto é, que o material trazido ao processo indique que o direito do autor é mais provável do que o do réu.

Mas na tutela provisória – especialmente na tutela de urgência – também assumem importância: i) as razões que levaram o juiz a acreditar, ou não, na prova; ii) a ligação que estabeleceu entre as provas e os fatos; iii) os motivos que levaram o juiz a estabelecer, ou não, uma presunção; e iv) a consideração das regras de experiência que guiaram o raciocínio judicial. Assim, nada significa dizer, seca e simplesmente, que há, ou não, probabilidade, pois essa convicção deve resultar da justificativa da decisão. Grosso modo, é preciso descrever o fato probando e as provas produzidas, explicar a relação entre as provas e os fatos – inclusive indiciários – e a relação entre os fatos indiciários provados e o fato probando, além de deixar claras as regras de experiência – e os seus fundamentos – que conduziram o raciocínio judicial.

Observa-se que, na prática forense, não se dá importância para a definição de fato indiciário e, conseqüentemente, para os raciocínios (presuntivos) que são feitos – na maioria das vezes de forma despercebida – ligando os fatos indiciários ao fato probando. Mais especificamente, nota-se uma completa desatenção para com as regras de experiência que fundamentam os raciocínios destinados a fixar as presunções. Porém, as regras de experiência e os raciocínios presuntivos não só devem ser claramente explicitados, como devidamente fundamentados como aptos à formação das presunções. Se o juiz deve julgar com base em critérios racionais, não há como a motivação esquecer de demonstrar a racionalidade das regras de experiência, sejam comuns ou técnicas.

Tudo isso quer dizer que a justificativa deve explicar o desenvolvimento do raciocínio que conduziu à decisão, e não apenas enunciar o seu resultado. Com efeito, pouco esclarece dizer que há, ou não, probabilidade se não se explicar os motivos desse convencimento.

A peculiaridade da decisão da tutela urgente está em que todos esses critérios de

convencimento, como o da relação entre a prova e os fatos e o da relação entre os fatos indiciários e o fato probando, não exige o esgotamento da regra do ônus da prova, pois aqui ela deve ser vista como uma régua – como queria a doutrina escandinava da verossimilhança preponderante<sup>180</sup> – que, fixando-se no grau 50, aponta em favor do autor quando inclina para a direita (de 50 para cima) e, em favor do réu, quando pende para a esquerda (de 50 para baixo).

Por isso, são relevantes cada um dos critérios antes apontados e, conseqüentemente, os motivos que levaram à conclusão de probabilidade ou verossimilhança da posição de uma parte ou outra. Ou melhor, a motivação da decisão urgente deve ser tão racional quanto a da sentença, com a única diferença de que deve justificar apenas uma convicção de probabilidade.

Frise-se que a justificação tem valor em si mesma, uma vez que dela depende a idoneidade da decisão. Ou seja, para se ter uma decisão como idônea, é preciso verificar a racionalidade da sua justificação, que objetiva explicar a racionalidade dos raciocínios probatório e decisório.

### **3. Critérios para o controle da racionalidade do discurso baseado na convicção de probabilidade**

Contudo, a circunstância de os critérios há pouco lembrados eventualmente não poderem levar o juiz a se convencer da probabilidade, não significa dizer que o juiz deva parar aí, ou que não tenha outros critérios para se convencer. Quando tais critérios levam a duas versões igualmente aceitáveis – o que também pode ocorrer na sentença –, devem ser aplicados os critérios da coerência e da congruência.<sup>181</sup>

O primeiro desses critérios quer expressar que a narrativa judicial deve ser coerente, e assim não pode conter ilogicidades, como a de aceitar um fato como verdadeiro e falso ao mesmo tempo, admitir fatos entre si incompatíveis, utilizar uma regra de experiência em uma situação e a negar em outra – sem que entre elas exista qualquer motivo para discriminação – ou se valer de regras de experiência incompatíveis.<sup>182</sup>

Ademais, além de ausente de contradições, a versão judicial não pode negar uma prova ou um fato provado ou aceitar um fato afirmado, mas não provado. Nesse último contexto, a narrativa do juiz não pode ser incompleta ou “supra-abundante”.<sup>183</sup>

Esclareça-se, porém, que a coerência e a congruência podem ser utilizadas para guiar o raciocínio do juiz rumo à decisão – quando podem ser utilizados como testes para a escolha da melhor versão das partes ou para a definição da própria versão judicial – ou vistas como critérios que devem qualificar a justificativa e servir para o seu controle por parte do tribunal.<sup>184</sup>

Assim, por exemplo, a falta de lógica da versão de uma das partes pode implicar a escolha da outra ou a definição de uma terceira, quando o critério integrará o raciocínio decisório. Mas, a justificativa também deve ser coerente e congruente, razão pela qual o tribunal pode, através de recurso e fundado nesses critérios, não aceitar a justificativa do juiz. No primeiro caso, a coerência constitui critério de decisão, enquanto que, no segundo, integra a justificação ou o raciocínio justificativo.

Note-se que a circunstância de uma prova apontar para duas versões nada tem a ver com falta de coerência ou congruência, uma vez que essas duas últimas não se referem à prova, mas sim à narrativa (ao discurso). A incoerência está no interior da narrativa que aceita dois fatos incompatíveis. Ou seja, enquanto os fatos incompatíveis estão na prova, e não na narrativa, não há que se pensar em incoerência.

Quando uma prova aponta em dois sentidos, isso não quer dizer que essa seja inútil, pois pode permitir que a convicção se forme em um dos sentidos, especialmente na dimensão da verossimilhança preponderante. Ou melhor, o fato de uma prova apontar em dois sentidos apenas pode tornar mais difícil a elaboração da convicção, mas, justamente pela razão de que pode formar ou colaborar para formar a convicção, não pode ser descartada ou simplesmente conceituada como “imprestável”.

#### **4. Convicção de probabilidade e caso concreto**

A consciência de que a convicção, apesar de não se submeter à lógica matemática, deve ser demonstrada através de argumentos capazes de justificar racionalmente a decisão judicial, enterra de vez por todas a ideia de pensá-la à distância do direito material e dos casos concretos.

Todo o percurso do raciocínio que leva à decisão se funda em critérios racionais que devem ser devidamente explicitados e justificados. Esses critérios, como é evidente, são muito mais complexos e sofisticados do que as simplistas ideias que partem do pressuposto de que a convicção pode ser medida em graus.

Tais critérios, assim como a sua justificativa, encontram plena racionalidade quando conectados ao direito material e ao caso concreto a que devem servir. Aliás, a obviedade de que as necessidades do direito material e dos casos concretos são várias é que aponta para a impossibilidade de se definir, segundo critérios matemáticos, o grau exato de convicção que deve presidir a tutela de urgência.

Diante disso, a única coisa que se pode definir, em princípio, é que a convicção do juiz, em razão de a decisão ter que ser tomada mediante cognição sumária – no curso do processo – em virtude de perigo de dano, deve seguir a lógica da verossimilhança preponderante. Não é preciso dizer que isso está muito longe das ideias de graduação da convicção e de restrição da prova capaz de gerá-la, até porque essa maneira de pensar inviabilizaria a própria elasticidade que deve marcar a tutela de urgência e, assim, a sua possibilidade de atender de forma adequada aos vários casos conflitivos concretos.

#### **5. A importância da identificação da tutela do direito a ser antecipada para a racionalização da convicção de probabilidade**

Evidenciada a necessidade de relacionar a convicção de probabilidade com o caso concreto, cabe esclarecer algo que nunca foi bem considerado pela doutrina, certamente pelo péssimo vício de se pensar o processo – e assim a prova etc. – como instituição neutra e indiferente ao direito material e ao caso concreto.

Quando a tutela jurisdicional (final) é realmente olhada pelo ângulo do direito material, torna-se fácil perceber que ela pode ser repressiva ou preventiva, isto é, posterior ou anterior à violação do direito, o que obviamente também acontece com a tutela antecipada.

O que atrapalha tudo, e é reflexo do que acaba de ser denunciado, ou seja, de se imaginar que as categorias do direito processual podem ser tratadas e conceituadas como se dissessem respeito somente ao processo, é a tentativa de dissolver o conteúdo da tutela antecipada na suposição de que não seria preciso identificar as peculiaridades e os pressupostos das diferentes tutelas fundadas em perigo, bastando conceituá-las como tutelas “de urgência” – que, assim, deixaria de ser um gênero que engloba diferentes realidades para poder ser vista como uma categoria homogênea.

Acontece que a ideia de tutela de urgência não pode explicar como o processo trata do direito material e dos casos concretos. A falta de identificação das tutelas que dão composição ao gênero “tutela de urgência” elimina a possibilidade de se explicar a convicção de probabilidade e a justificação da decisão antecipatória, pois essas não são uniformes, ao contrário do conceito de urgência.

A circunstância de a tutela antecipada, na perspectiva processual, poder ser conceituada como urgente, obscurece o fato de que a tutela urgente pode ser repressiva e preventiva (inibitória) e as importantes implicações que essa constatação tem para o tema da fundamentação das decisões de cognição sumária.

#### **6. A convicção de probabilidade diante das várias tutelas de direito que podem ser antecipadas**

Lembre-se de que a ação inibitória é voltada para o futuro, pois preocupada com o que vai acontecer, ou mais precisamente com a ameaça da prática, da repetição ou da continuação de um ato contrário ao direito.<sup>185</sup> Por isso, a tutela inibitória – final ou antecipada – deve ser prestada antes da prática do ato ilícito temido.

É preciso recordar que a própria tutela inibitória final se contenta com a probabilidade da prática do ato temido e que a aceitação da redução da convicção do juiz, nesse caso, resulta do direito material, ou melhor, da irracionalidade de se exigir uma convicção de “verdade” sobre um fato futuro. Note-se que a convicção de probabilidade está centrada na presunção decorrente da ligação entre a prova do fato passado e o fato temido. Em outras palavras, deve haver prova do fato passado (indiciário) e, em virtude desta, convicção de probabilidade da prática do fato temido.

Assim, no que respeita a ação voltada a impedir a repetição ou a continuação do ilícito, o juiz deve estar convicto de que o demandado já praticou ou iniciou um ato ilícito. Frise-se que, nesses casos, deve existir convicção de verdade em relação ao fato passado (indiciário) e à ilicitude. A probabilidade diz respeito apenas à presunção a ser estabelecida entre a prova do fato passado e o fato futuro. Ora, se o juiz não pode chegar à ameaça da repetição ou da continuação a não ser a partir da prova da violação já ocorrida, não é correto penalizar aquele que já sofreu o ilícito, pois a experiência mostra que determinados ilícitos, pela sua natureza, têm grande probabilidade de voltar a ser praticados.

Na outra modalidade de ação inibitória – denominada de “pura” –, em que não se teme a repetição ou a continuação do ilícito, mas sim a prática de um ilícito sem que nenhum ato anterior da mesma natureza tenha sido cometido, deve haver convicção de verdade em relação a atos preparatórios ou a fatos objetivos que possam indicar a probabilidade da prática do ato temido. Da mesma forma que nas outras duas ações, aqui a convicção de probabilidade diz respeito apenas à presunção sobre o fato temido, e não ao fato passado. Não há dúvida de que a convicção de verdade sobre os fatos passados, bem como sobre a ilicitude do fato temido, é suficiente para dar ao juiz a convicção necessária para conceder a tutela inibitória final.

Porém, tratando-se da tutela inibitória antecipada, a probabilidade não atinge apenas a presunção. É preciso perceber que, enquanto na tutela inibitória final basta a ameaça de ilícito e, por conta disso, a probabilidade da prática do ilícito, na tutela inibitória antecipada é necessária a probabilidade que tenham sido praticados fatos que indiquem a ameaça. Na hipótese de ação dirigida a impedir a repetição ou a continuação do ilícito, a probabilidade também recai sobre o fato passado e a sua ilicitude, enquanto que, no caso da chamada ação inibitória “pura”, a probabilidade igualmente incide sobre os atos preparatórios e a ilicitude do ato temido.

Em qualquer uma destas situações, a concessão da tutela inibitória antecipada deverá ser racionalmente justificada, mediante a referência das relações entre as provas e os fatos passados e a explicação do raciocínio-ponte entre tais provas e o fato temido, demonstrando-se, além disso, a probabilidade da sua ocorrência no curso do processo.

A importância de observar o direito material e o caso concreto, nesses casos, é facilmente constatável quando são consideradas as seguintes particularidades: i) que deve ser provado para a concessão da tutela inibitória final apenas um ato ilícito ou um ato preparatório; ii) que o juiz, para conceder a tutela antecipada, deve ter apenas uma convicção de probabilidade acerca desses atos; iii) que o raciocínio presuntivo deve se limitar a uma verossimilhança preponderante de que a prática, a repetição ou a continuação de um ato contrário ao direito – e não de um dano<sup>186</sup> – ocorram no curso do processo.

Por outro lado, há casos em que uma norma de proteção – por exemplo, do consumidor – já foi violada, sendo necessário remover os efeitos concretos do ilícito através de tutela antecipada. Nesse caso basta apenas a convicção de probabilidade da violação da norma, pouco importando o dano ou a sua probabilidade – o qual, aliás, não importa nem mesmo para a tutela final. Quando o legitimado à proteção dos direitos do consumidor pede tutela antecipada de busca e apreensão de produtos nocivos que foram postos à venda pelo réu, é suficiente que o juiz forme uma convicção de probabilidade acerca da violação da norma de proteção, sendo desnecessária a prova acerca de

eventual dano. O dano não pode ser discutido nessa ação de busca e apreensão, pois o que nela importa é apenas a necessidade de atuação do desejo da norma de proteção. Por isso, o juiz não pode deixar de conceder a tutela antecipada, em um caso desse tipo, sob a alegação de que não há probabilidade do dano.

Note-se que, na hipótese dos produtos nocivos, a convicção de probabilidade recai sobre um ilícito já praticado e o perigo de dano deriva da probabilidade do ilícito ou da violação da norma. O que importa evitar, nessas situações, é pensar que o juiz deve se convencer da probabilidade de dano, ou que a tutela antecipada requer a demonstração de que a venda do produto pode gerar dano.

É fundamental perceber que a tutela antecipada na ação de remoção de ilícito, além de tomar em consideração um ilícito que já ocorreu, não objetiva evitar um ato futuro, mas apenas remover os efeitos concretos de um ato passado. Isso quer dizer que a prova, nesse caso, não se volta para o futuro – como acontece na tutela inibitória antecipada –, dirigindo-se apenas para o passado.

A situação é diversa quando se considera a tutela ressarcitória do dano. Quando se pensa na tutela antecipada de soma em dinheiro na ação ressarcitória, por exemplo, importa a convicção de probabilidade do dano e da responsabilidade e o perigo (portanto também a convicção de probabilidade) de que, diante da demora do processo, outro dano possa ocorrer.

Perceba-se que a ação inibitória se preocupa com um ato ilícito futuro, a ação de remoção do ilícito com um ato ilícito passado e a ação de ressarcimento com um dano já ocorrido. Na ação inibitória, portanto, é preciso demonstrar que um fato passado aponta para uma ameaça de violação. Na ação de remoção de ilícito basta provar a ocorrência do ilícito. E na ação ressarcitória é preciso demonstrar o dano e a responsabilidade do demandado.

Tratando-se de tutela antecipada, a convicção deve ser compreendida na mesma perspectiva.<sup>187</sup> Para a tutela inibitória antecipada é preciso a convicção de probabilidade de que foi praticado um ato e, além disso, que esse ato aponta para uma ameaça de violação que poderá ocorrer no curso do processo. Porém, na tutela de remoção do ilícito antecipada é suficiente a convicção de probabilidade de que foi praticado um ilícito. Na medida em que a tutela é contra os efeitos concretos da conduta ilícita, não se pensa em perigo de dano que pode decorrer do ato ilícito.

Por outro lado, o requerimento de tutela antecipada ressarcitória – em dinheiro ou na forma específica – liga-se à probabilidade do dano e da responsabilidade que justificaram a ação ressarcitória e ao perigo que o dano ressarcível seja potencializado ou que dele derive um novo dano a um direito conexo ao objeto da tutela ressarcitória.

A necessidade da identificação de cada uma dessas tutelas é imprescindível não só para que as partes saibam o que deve ser discutido e provado em cada espécie de tutela antecipada, mas também para que o juiz tenha condições de racionalmente expressar a sua convicção. Ora, o juiz somente pode se dizer convencido se sabe do que deve se convencer. E as partes apenas podem controlar a motivação se sabem o que deve ser objeto do convencimento judicial. Daí a importância de se deixar claro, por um lado, i) que a tutela inibitória não se preocupa com o dano e com o elemento subjetivo, mas apenas com a probabilidade do ato contrário ao direito; ii) que a tutela de remoção do ilícito nada tem a ver com o dano e com a culpa, mas apenas com um ato contrário ao direito que já ocorreu; e iii) que a ação ressarcitória se liga ao dano e aos critérios de imputação da sanção ressarcitória. E, por outro lado, que o perigo na demora está i) na ameaça de violação na ação inibitória; ii) na própria violação na ação de remoção; e iii) na probabilidade de que o dano ressarcível se incremente ou de que dele derive um outro dano a direito conexo ao tutelado mediante o ressarcimento. Exemplo da última hipótese é a tutela antecipada de soma em dinheiro na ação ressarcitória, objetivando-se evitar dano à saúde diante da demora na obtenção do ressarcimento.

Ressalte-se, contudo, na linha do que se disse até agora, que o valor da convicção depende da racionalidade da sua justificação, vale dizer, da descrição das relações entre as provas e os fatos e da explicação das presunções e das regras de experiência.



## **7. Dificuldade da prova, credibilidade das alegações e convicção de probabilidade**

Por outro lado, é preciso frisar que o grande entrave da ação inibitória “pura” é a demonstração de atos que indiquem a probabilidade do ato temido. Se a convicção de verdade, própria à sentença, pode ceder diante de certos casos concretos (como os relacionados a danos pré-natais ou a danos ligados ao não cumprimento de deveres de proteção), não há como negar que a convicção de probabilidade, típica à tutela antecipatória, também deve ser pensada conforme as circunstâncias do direito material e do caso concreto, especialmente daquelas que indiquem dificuldade para a produção da prova.

Ou seja, não há como deixar de considerar a dificuldade de produção da prova, peculiar a uma dada situação de direito material, quando se pensa na convicção – seja ao final ou no curso do processo –, sob pena de se negar tutela jurisdicional adequada a determinados direitos. É nesse sentido – isto é, considerando que a dificuldade de prova pode decorrer de uma específica situação substancial – que se afirma que o juiz deve se satisfazer – para conceder a tutela final ou antecipatória – com a “prova possível da alegação”.

Ou de maneira mais clara: a convicção de probabilidade deve ser justificada não só com base nas provas produzidas, mas também mediante a explicação racional da dificuldade de produção de prova, considerando que, quanto maior for essa dificuldade, menos se deve exigir do juiz para a tutela do direito. A lógica é bastante simples, pois todos sabem que não se pode exigir de quem tem um direito algo que inviabilize o seu exercício (no caso o direito à tutela jurisdicional).

Assim, nas situações em que o direito material justifica a redução da exigência da convicção no final do processo e naquelas em que o direito material e o caso concreto apontam para a dificuldade de se produzir prova quando da tutela antecipada, não há como deixar de elaborar critérios que possam auxiliar o encontro de um tratamento justo.

Note-se, por exemplo, que alguém pode estar articulando, ou praticando, atos de agressão a direitos da personalidade de forma velada, cuidando para não deixar provas. Em casos desse tipo, torna-se muito difícil produzir prova, ainda que seja para fazer surgir convicção de probabilidade. Porém, não é justo deixar o titular do direito de personalidade ao desamparo ou nas mãos daquele que, com astúcia e cuidado, pretende infringir o direito.

Nessa dimensão, diante da impossibilidade de produção de prova, importa como nunca a chamada credibilidade das alegações, que deve se basear em regras de experiência devidamente consolidadas na sociedade no momento da decisão. A credibilidade das alegações, assim como as regras de experiência capazes de fundá-las, constituem critérios cuja racionalidade deve ser devidamente justificada.

Se a impossibilidade de prova pode ser suprida pelo critério da credibilidade das alegações – que não pode se desligar da idoneidade das regras de experiência –, tanto a impossibilidade da produção de prova, quanto a legitimidade do emprego de tal critério, dependem da racionalidade da justificativa judicial. Vale dizer: a racionalidade da argumentação é que deve justificar a dificuldade de prova, a credibilidade das alegações e idoneidade das regras de experiência que a fundaram.

## **8. Convicção de probabilidade e consideração das posições em disputa**

Outro importante critério, que pode auxiliar quando as versões do autor e do réu são igualmente prováveis, é o do balanceamento dos valores em litígio. Esse critério, como é óbvio, exige a consideração do direito material, ou melhor, do valor dos direitos em conflito.

Trata-se de critério complexo, que somente pode ser compreendido por quem está convencido da necessidade de o processo civil servir ao caso concreto. O uso de tal critério requer que todos os demais critérios antes expostos – i) da relação entre as provas e os fatos, da explicação das presunções e da fundamentação das regras de experiência; ii) da coerência; iii) da congruência; e iv) da credibilidade das alegações – tenham sido insuficientes para evidenciar de que lado pende a probabilidade.

Como ocorre em relação a todos os critérios destinados a explicar o raciocínio e a decisão judiciais, este também deve ser racionalmente justificado. Sua utilização requer a prévia justificativa da sua necessidade diante dos outros critérios que, logicamente, devem lhe anteceder, e depois a apresentação das razões pelas quais uma posição deve preferir a outra.

A justificativa da escolha de uma posição em relação à outra exige a consideração de outros critérios, que então podem ser chamados de subcritérios. Assim, é preciso verificar se o direito do autor, que está sendo ameaçado por dano, tem natureza não patrimonial ou patrimonial e, diante disso, se ele pode ser: i) integralmente restaurado; ii) ressarcido em dinheiro; iii) dificilmente ressarcido em dinheiro; ou é iv) insuscetível de transformação em pecúnia. Por igual razão, é necessário analisar se o direito do réu possui natureza não patrimonial ou patrimonial, e qual a intensidade do prejuízo que a concessão da tutela poderá lhe trazer, ou melhor, se a concessão da tutela poderá lhe ocasionar um prejuízo suscetível de restauração, ressarcível em dinheiro, dificilmente ressarcível em dinheiro ou insuscetível de ressarcimento, ainda que em pecúnia.

Essa argumentação parte do pressuposto de que a tutela antecipada pode trazer prejuízo irreversível (ver comentários ao art. 300, § 3º adiante). Isso é inegável quando o juiz chega à convicção de que o direito do autor é provável, uma vez que a lógica que preside a tutela antecipada é a do sacrifício do improvável em favor do provável.<sup>188</sup> Ora, ninguém pode concluir que o juiz pode deixar de proteger o direito ameaçado por dano, e que lhe parece provável, apenas para não expor a risco de dano o direito que lhe parece improvável.

Mas, como já foi possível perceber, o problema, aqui, não é relacionado à tutela do provável, mas sim à tutela diante de dúvida sobre a probabilidade. É conveniente sublinhar que essa “dúvida” somente abrirá oportunidade à inserção do critério que agora é exposto quando não resultar da inércia do autor na produção da prova.

Porém, quando tal inércia não acontecer e o critério da credibilidade, por si só, não se apresentar como suficiente, o critério da ponderação pode ser com ele ou isoladamente utilizado. Voltemos, assim, aos subcritérios há pouco apontados.

Não é difícil intuir que tais subcritérios, para poderem explicar uma solução de forma racional, devem ser relacionados. E, diante deles, importa a prestação de caução, ainda que se admita a sua dispensa em casos excepcionais. Como é curial, a caução se destina a assegurar o prejuízo que pode ser imposto ao réu e, assim, pode ser vista como um meio capaz de facilitar o balanceamento das posições das partes.<sup>189</sup>

Quando o direito do autor é não patrimonial ou, ainda que patrimonial, é não restaurável ou dificilmente ressarcível em dinheiro, esse deve preferir o direito restaurável ou ressarcível em dinheiro, quando então deve ser prestada caução. Contudo, alguém poderá dizer que a não patrimonialidade, a não restaurabilidade e a dificuldade do ressarcimento em dinheiro são importantes para configurar o perigo de dano, mas não admitem a presença de dúvida quanto à probabilidade do direito.

Essa postura finge ignorar que o juiz pode ter dúvida e, o que é pior, que essa dúvida pode trazer prejuízo ao titular do direito fundamental à tutela jurisdicional. Quem ignora essa situação, procurando simplesmente uma resposta mais cômoda às estruturas teóricas, obviamente não consegue explicar, ao menos de maneira racional, a razão pela qual a dúvida a respeito da probabilidade – que é problema do Estado-Juiz – deve onerar o autor.

Ora, não se está dizendo que a tutela antecipada deve ser concedida quando o juiz está em dúvida quanto à probabilidade, mas sim que o juiz deve utilizar o método do balanceamento como última alternativa para realmente aferir a necessidade da tutela. Como é evidente, a aplicação do método do balanceamento e dos subcritérios antes referidos pode permitir a conclusão de que a tutela antecipada não deve ser concedida.

Além disso, caso os pressupostos da tutela antecipada em caso de verossimilhança preponderante fossem apenas esses, restaria excluída a possibilidade de se conceder tutela

antecipada ao direito que, lesado, pode ser ressarcido em dinheiro. Em outros termos, a tutela antecipada simplesmente não existiria para alguns direitos, uma vez que estaria sendo aceita a ideia de que o direito provável, quando ressarcível, pode ser lesado – conclusão que, de tão absurda, chega a ser curiosa. Ora, é completamente descabido imaginar que a probabilidade de lesão a um direito que pode ser ressarcido não configura, apenas por isso, perigo de dano.

Na verdade, o fato de o direito ameaçado de lesão ser ressarcível somente tem importância quando é aplicado o método da ponderação, pois é elemento que justifica a não concessão da tutela quando o direito do réu for não patrimonial, insuscetível de restauração ou dificilmente ressarcível.

Não é possível relacionar todas as situações que podem marcar os direitos do autor e do réu e delas extrair critérios que possam guiar os passos do juiz, já que isso é inviável em um plano valorativo-abstrato. Os critérios antes estabelecidos não se esgotam em si mesmos, devendo ser necessariamente preenchidos diante do caso concreto.

Esses critérios, ao contrário do que se poderia pensar à primeira vista, não constituem simples “fórmulas”. Tais critérios trazem à luz algo que é comum quando se interpreta as normas, isto é, a necessidade de juízos de valor.<sup>190</sup> A diferença é a de que, no caso da decisão antecipatória, o juiz não está frente a um método de interpretação, mas apenas diante da necessidade de valoração das posições do autor e do réu.

Com efeito, o sistema proposto não constitui um método de interpretação. A interpretação da norma, ainda que exija valoração, objetiva conferir-lhe sentido, enquanto que o balanceamento valorativo que se faz na tutela antecipada tem o fim de encontrar uma solução para a dúvida que paira sobre as posições em disputa.<sup>191</sup>

Nessa linha tal sistema mais se aproxima a um método de decisão. Na realidade, importa frisar que esse método não pode ser comparado a uma fórmula com critérios previamente definidos e capazes de entrar em ação assim que hipóteses concretas nela se enquadrem. É que os critérios referidos acima, que dariam conteúdo a essa fórmula, constituem valorações que devem ser feitas no caso concreto. E é exatamente aí que tudo fica mais claro, pois se o juiz é obrigado a valorar para resolver, ele deve justificar racionalmente a razão da sua opção, considerando o sistema jurídico e as circunstâncias do caso concreto.

O método ora proposto nada tem a ver com o princípio da proporcionalidade, utilizado para permitir a solução de conflitos entre direitos fundamentais que se chocam no caso concreto, como, por exemplo, entre o direito da personalidade e o direito de liberdade de expressão. O princípio da proporcionalidade visa resolver a colisão entre dois direitos que, em abstrato, têm a mesma estatura e dignidade.

Já o método que se utiliza dos critérios ora apontados toma em consideração a circunstância de o juiz ter que decidir entre duas posições no curso do processo. Nesse último caso não há que se falar entre dois direitos de igual estatura jurídica, mas sim na dificuldade de se formar uma convicção (mesmo que de probabilidade) diante da incompletude do contraditório.

## **9. Convicção de probabilidade e tutela cautelar**

Diante da tutela cautelar deve haver probabilidade do direito à tutela que se pretende assegurar cautelarmente, mais a probabilidade de que um dano possa frustrar a efetividade da tutela final desejada.

A probabilidade do direito à tutela cautelar assemelha-se à probabilidade do direito que legitima a tutela antecipada, porém o perigo na demora não afeta o direito que se pretende tutelar (inibitória ou remoção antecipada) ou um direito conexo ao direito que se pretende tutelar (tutela antecipada de soma na ação ressarcitória). O direito que pode ser prejudicado pela demora, no caso de tutela cautelar, é o direito à tutela jurisdicional efetiva do direito.

Significa dizer que, na tutela cautelar, a justificativa deve recair sobre a probabilidade do

direito à tutela jurisdicional final e sobre o perigo de que esta tutela venha a não ser prestada na forma efetiva ou de que a situação jurídica tutelável mediante as tutelas declaratória ou constitutiva venha a sofrer prejuízo no curso do processo.

## **10. Convicção de probabilidade e tutela da evidência**

A tutela da evidência requer fatos constitutivos incontroversos. Provados mediante documento, não contestados ou reconhecidos expressamente na contestação. Note-se que os incisos II, III e IV do art. 311 falam em prova documental dos fatos constitutivos, enquanto que o abuso do direito de defesa, previsto no inciso I deste artigo, igualmente não pode se desligar da incontrovérsia dos fatos constitutivos.

De modo que a probabilidade só pode recair sobre afirmação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A probabilidade, em outras palavras, diz respeito à defesa de mérito indireta.

A probabilidade, quando olhada na perspectiva de quem deseja a tutela da evidência, deve ser negativa, na medida em que a alegação deve ser improvável. Requer-se a probabilidade de que a defesa de mérito indireta não venha a ser acolhida. É por isso que se diz que a defesa deve ser infundada ou inconsistente.

A justificativa, portanto, deve relacionar os documentos apresentados com os fatos constitutivos ou esses com a não contestação ou com o seu reconhecimento expresso e, além disso, deve demonstrar as razões pelas quais se entende que defesa de mérito indireta carece de consistência. Como exemplo, o juiz pode invocar precedente de Corte Suprema para evidenciar que a alegação de prescrição – fato extintivo – é inconsistente ou infundada.

**Art. 299.** A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

## **1. Tutelas antecipada e cautelar requeridas nas formas antecedente e incidente**

O art. 299 afirma que a tutela provisória pode ser requerida ao juiz da causa e, quando antecedente, ao juiz competente para conhecer do pedido principal. É certo que o art. 299 contém um erro de redação, na medida em que apenas a tutela de urgência pode ser requerida na forma antecedente. Seria absurdo admitir tutela da evidência na forma antecedente. Quer dizer que, no lugar de tutela provisória, deve-se ler tutela de urgência.

Assim, considerando-se o que ocorria no código anterior, a tutela cautelar, embora ainda possa ser postulada na forma antecedente, agora pode ser requerida no curso do processo. Aliás, isso foi proposto em sede doutrinária há mais de vinte anos<sup>192</sup>. No entanto, o Código de 2015 admitiu tutela antecipada incidente (como ocorria no Código de 1973) e também na forma antecedente, ou seja, antes da realização do pedido de tutela jurisdicional do direito.

Quando as necessidades da prática forense – especialmente nos anos 80 do século passado – levaram os advogados a requerer a antecipação da tutela final sob as vestes de tutela cautelar, logo surgiu o problema da desnecessária duplicação de procedimentos para a obtenção de uma única tutela do direito. A prática forense evidenciou várias hipóteses em que processos rotulados de “cautelar” perdiam qualquer sentido após a concessão da tutela satisfativa do direito sob o rótulo de “liminar cautelar”. Lembre-se que a prática aceitou a tese de que a ação cautelar podia substituir o mandado de segurança uma vez escoado o seu prazo decadencial. O que era direito líquido e certo se transformava, em passe de mágica, em *fumus boni iuris*. Porém, passada a fase propícia à concessão da liminar, por inexistir necessidade de elucidação de matéria de fato o juiz restava em condições de proferir sentença capaz de produzir coisa julgada material. Ou seja, a “ação cautelar” seria suficiente para a resolução definitiva do mérito e para a concessão da tutela satisfativa. Como no Código de 1973 a obtenção de tutela cautelar obrigava a propositura de ação principal, percebia-se facilmente a inutilidade desta ação quando se tinha clara consciência de que

a ação rotulada de cautelar era travestida para possibilitar o requerimento de liminar (de tutela antecipada). Nestes casos, a “ação principal” era despicienda e a “ação cautelar” não era cautelar. Na verdade, em todos os casos em que se obtinha a tutela do direito mediante liminar cautelar, a ação principal – cuja propositura, repita-se, era obrigatória – perdia completamente sua utilidade. Ficou claro que bastaria um procedimento de cognição exauriente em que fosse possível requerer tutela antecipada na petição inicial.

O Código de 2015 não chegou a admitir um procedimento autônomo para a obtenção da tutela antecipada, seguido de um outro procedimento. Isto realmente seria pouco mais do que absurdo. Porém, para atender a uma situação excepcional – a da impossibilidade de o advogado preparar a petição inicial da ação de conhecimento em razão da urgência na obtenção da tutela –, o código complicou as coisas, abrindo oportunidade para o requerimento de tutela antecipada na forma antecedente mediante a simples “indicação do pedido de tutela final” (art. 303, caput, CPC). Neste caso, afirma-se que, no caso de concessão da tutela antecipada, o autor terá que “aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final” (§ 1º do art. 303, CPC).

É possível que o legislador tenha imaginado que a parte, em determinados casos, possa não ter tempo para apresentar ao seu advogado os documentos necessários para a finalização da petição inicial. Contudo, a permissão de pedido de tutela final posterior em virtude da falta de documento obviamente não gera uma presunção da sua existência, viabilizando a formação de convicção de probabilidade capaz de dar ensejo à concessão da tutela antecipada. Portanto, seria muito mais racional admitir ao advogado protestar pela juntada de procuração e de documentos, demonstrando que não pode obtê-los em tempo hábil.

O problema é que o requerimento de tutela antecipada mediante petição inicial “inacabada” infelizmente poderá ser generalizado na prática forense, na medida em que “urgência contemporânea à propositura da ação” é algo que não pode ser medido com precisão. Isso permitirá que o litigante peça tutela antecipada sem qualquer risco de ser vencido no processo, bastando não aditar a petição inicial quando a tutela antecipada for indeferida (art. 303, § 6º, CPC).

## **2. Competência diante do recurso**

De acordo com o parágrafo único do art. 299, “ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. Não pode haver dúvida de que a tutela de urgência deve ser requerida ao relator da ação de competência originária de tribunal, como, por exemplo, da ação rescisória.

Agora, no caso em que a necessidade de tutela urgente aparece após a interposição do recurso de apelação<sup>193</sup> no Tribunal Estadual ou Regional Federal, do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça ou do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, a tutela de urgência deve ser requerida perante o Tribunal ou Corte Suprema ao qual o recurso foi endereçado.

Pouco importa se o recurso já chegou ao Tribunal ou à Corte Suprema. Em caso positivo, não há dúvida que a tutela urgente deve ser solicitada perante o tribunal e, quando já distribuído o recurso, ao relator. Porém, mesmo que o recurso ainda esteja diante do juízo a quo, a tutela urgente deve ser solicitada ao juízo ad quem, conforme determina o parágrafo único do art. 299. É que o órgão jurisdicional que proferiu a decisão objeto do recurso já cumpriu a sua função perante a causa e, assim, deixou de ter competência para apreciar os pressupostos da tutela de urgência.

## **3. Tutela de urgência concedida por juiz incompetente**

Quando antecedente, a tutela de urgência deve ser requerida “ao juízo competente para conhecer do pedido principal” (art. 299, CPC). O art. 65 do Código de Processo Civil afirma que a competência relativa se prorroga se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A incompetência absoluta, ao contrário, deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, § 1º, CPC).

Assim, se a tutela de urgência for requerida a juízo relativamente incompetente e o réu silenciar sobre o ponto, a tutela concedida não tem motivo para não ser mantida eficaz. Na verdade, a urgência legitima o requerimento de tutela a juiz relativamente incompetente.<sup>194</sup>

Porém, como não há prorrogação de competência em caso de incompetência absoluta, cabe perguntar se é possível manter eficaz a tutela de urgência concedida por juiz absolutamente incompetente. Afirma o art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil que, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Como esta norma fala em “decisão proferida pelo juízo incompetente”, sem nada dizer sobre incompetência relativa ou absoluta, a tutela urgente concedida por juiz absolutamente incompetente pode se manter eficaz até que os autos cheguem ao juízo para o qual foram remetidos. Assim apenas não ocorrerá se o juiz que declarou a sua incompetência absoluta revogar a tutela de urgência.

É claro que o juiz não deve revogar a tutela apenas por ter reconhecido a sua incompetência absoluta. Diante da circunstância de que o desaparecimento da tutela de urgência sujeita o litigante a dano, não há razão para entender que a tutela urgente deva perder a sua eficácia antes de ter a sua legitimidade aferida pelo juízo competente.<sup>195</sup> Como já era dito diante do Código de 1973, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva sustenta a possibilidade da manutenção da eficácia da tutela urgente concedida pelo juízo absolutamente incompetente.<sup>196</sup>

---

## NOTAS DE RODAPÉ

---

1

Piero Calamandrei, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova: Cedam, 1936.

2

Foi Chiovenda quem afirmou que a função da jurisdição era a de dar atuação à vontade concreta da lei (Giuseppe Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, v. 1, Napoli: Jovene, 1960).

3

Abordando a obra de Chiovenda, Giannini escreveu: “Affrontava decisamente una ricostruzione del diritto processuale, con carattere pubblicistico, sulla base dell’autonomia dell’azione e del rapporto giuridico processuale, elevando la scienza processuale, con un balzo di dignità, su quello già compiuto dal Mortara, ad una ricostruzione sistematica storico-dogmatica (...)” (Amedeo Giannini, *Gli studi di diritto processuale civile in Italia*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1949, p. 109).

4

“La c. d. ‘pubblicizzazione’ del processo civile inverte i presupposti di fondo che erano alla base del codice del 1865 e della dottrina ottocentesca: il processo non è più esclusivamente un ‘affare delle parti’ ma un luogo in cui si esprime l’autorità dello Stato; esso non mira solo alla tutela di interessi privati, ma realizza l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia; il perno del processo non è più l’iniziativa delle parti, ma la funzione del giudice. In sintesi, il processo non è più visto come una forma in cui si esplica l’autonomia privata nell’esercizio dei diritti, ma come uno strumento che lo Stato mette a disposizione dei



privati in vista dell'attuazione della legge. Con tutto ciò si salda perfettamente la ridefinizione del concetto di azione, compiuta essenzialmente da Chiovenda: l'azione non è più una sorta di appendice del diritto sostanziale privato, ma un diritto autonomo di natura pubblica, che mira a produrre conseguenze giuridiche nella sfera della controparte (dove la nota definizione dell'azione come diritto potestativo), ma che soprattutto chiama in gioco l'autorità dello Stato come tramite e garante dell'attuazione della legge" (Michele Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna: Il Mulino, 1980, p. 188).

---

5

Ovídio Baptista da Silva, *A ação cautelar nominada no direito brasileiro*, São Paulo: Forense, 1979; Ovídio Baptista da Silva, *Do processo cautelar*, Porto Alegre: Lejur, 1985; Ovídio Baptista da Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 11, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. Sobre a tutela cautelar, ver ainda no direito brasileiro: Galeno Lacerda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 8, t. 1, Rio de Janeiro: Forense, 1980; Galeno Lacerda e Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 8, t. 2, Rio de Janeiro: Forense, 1980; Alcides Alberto Munhoz da Cunha, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 11, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001; José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 10, t. 1, Rio de Janeiro: Forense, 1977; Egas Moniz de Aragão, *Medidas cautelares nominadas*, *Revista Brasileira de Direito Processual*, v. 57, p. 33 e ss; Humberto Theodoro Júnior, *Processo cautelar*, São Paulo: LEUD, 1976.

---

6

Não há dúvida de que a jurisdição, atualmente, tem a função de tutelar (ou proteger) os direitos, especialmente os direitos fundamentais. Isto não quer dizer, como é óbvio, que a jurisdição não se preocupe em garantir a idoneidade da defesa ou a adequada participação do réu. O que se deseja evidenciar é que a função jurisdicional é uma consequência natural do dever estatal de proteger os direitos, o qual constitui a essência do Estado contemporâneo. Sem ela seria impossível ao Estado não apenas dar tutela aos direitos fundamentais e permitir a participação do povo na reivindicação dos direitos transindividuais e na correção dos desvios na gestão da coisa pública, mas sobretudo garantir a razão de ser do ordenamento jurídico, dos direitos e das suas próprias formas de tutela ou proteção. Quando se diz que a jurisdição tem o fim de dar tutela aos direitos se está muito longe das antigas concepções privatistas, próprias do século XIX, especialmente do conceito de direito subjetivo, característico ao espírito dessa época e desenvolvido particularmente por Windscheid. Ao escrever *Ação do direito romano do ponto de vista do direito civil*, inaugurando a célebre polêmica sobre a ação que travou com Muther, Windscheid apresentou as linhas de uma nova concepção de direito subjetivo, caracterizado pelo poder (do sujeito ativo) de exigir uma conduta e pelo dever (do sujeito passivo) de prestá-la. Esse conceito de direito subjetivo, como não poderia deixar de ser – diante da evidente relatividade histórica das doutrinas jurídicas –, recebeu forte influência do princípio da autonomia da vontade, sabidamente a base de todo o sistema individualista que marcou o século XIX. O dever de proteção ou de tutela dos direitos, que identifica o Estado constitucional, nada tem a ver com a noção clássica de direito subjetivo. O Estado possui o dever de tutelar determinados direitos, mediante normas e atividades fático-administrativas, em razão da sua relevância social e jurídica. Trata-se do dever de tutelar os direitos fundamentais. Mas não é só. O Estado também tem o dever de tutelar jurisdicionalmente os direitos fundamentais, inclusive suprindo eventuais omissões de tutela normativa, além de ter o dever de dar tutela jurisdicional a toda e qualquer espécie de direito – em razão do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5.º, XXXV, da CF). Assim, por exemplo, o Estado tem o dever de tutelar, através de normas e atividades fático-administrativas, o meio ambiente. Mas também tem o dever de dar-lhe tutela

jurisdicional, conforme as necessidades derivadas da situação concreta. Isso porque determinada situação concreta pode demonstrar a necessidade de tutela jurisdicional inibitória, outra de tutela jurisdicional ressarcitória na forma específica e assim por diante. O Estado tem o dever de prestar a tutela jurisdicional prometida pelos direitos – transindividuais ou individuais. Ver Luiz Guilherme Marinoni e Alvaro Perez Ragone, *Fundamentos del Proceso Civil*, Santiago: Abeledo Perrot, 2011; Luiz Guilherme Marinoni, *Introducción al Derecho Procesal Civil*, Lima: Palestra: 2015.

---

7

Ao se dizer que a jurisdição tem o dever de tutelar os direitos, deseja-se igualmente pôr às claras que ela tem o dever de viabilizar as tutelas prometidas pelo direito material e pela Constituição. Em termos concretos, o que se deseja evitar é que a inidoneidade técnica do processo ou a falta de compreensão constitucional do juiz impeçam a efetiva proteção das diferentes necessidades do direito material – como, por exemplo, a tutela preventiva (a tutela inibitória) de um direito da personalidade. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva incide sobre o legislador e o juiz, ou seja, sobre a estruturação legal do processo e sobre a conformação dessa estrutura pela jurisdição. Sobre o direito à construção da ação adequada à tutela do direito, ver Luiz Guilherme Marinoni, *Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella prospettiva della teoria dei diritti fondamentali. Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, v. 1, Milano: Giuffrè, 2005, p. 93-162.

---

8

Piero Calamandrei, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*.

---

9

Piero Calamandrei, *Istituzioni di diritto processuale civile*.

---

10

Sobre o processo civil no Estado constitucional, ver Daniel Mitidiero, *Processo civil e Estado Constitucional*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007; Hermes Zaneti Júnior, *Processo constitucional (o modelo constitucional do processo civil brasileiro)*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

---

11

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, v. 3, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 73.

---

12

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, v. 3, p. 74.

---

13

A antiga ação condenatória, única alternativa para quem desejava soma em dinheiro até meados de 2006, apesar de responder ao conceito tradicional de ação, pois garantia uma sentença de mérito, não viabilizava, por si só, a tutela do direito material. Isto é suficiente para fazer ver a diferença abismal entre

direito a uma sentença de mérito e direito à possibilidade de obtenção da tutela do direito material, o qual depende de um processo tecnicamente adequado e justo, capaz de espelhar o direito à pré-ordenação das técnicas processuais adequadas e o direito à participação no procedimento, mediante a oportunidade de alegações e produção de provas, isto é, de convencimento do juiz. Aliás, quando se pensa no conceito contemporâneo de direito de ação, a falta de sintonia entre condenação e ação obriga a afastar, de vez por todas, as nomenclaturas que ligavam o direito de ação às técnicas processuais, como as espécies de procedimentos – por exemplo, ação ordinária – e de sentenças – por exemplo, ação condenatória –, fazendo com que a ação passe a se relacionar com a sua única razão de ser, isto é, com a tutela do direito material. Ou seja, a ação, quando voltada à obtenção da tutela ressarcitória pelo equivalente, é ressarcitória e não condenatória. Ninguém que deseja ressarcimento pelo equivalente em dinheiro ou pagamento de obrigação pecuniária deseja somente condenação, até porque essa é apenas uma das técnicas processuais instituídas para que seja possível a obtenção da tutela do direito. Ao lado da condenação, estão predispostas, igualmente como técnicas processuais a liquidação – através de suas diferentes espécies – e as várias modalidades executivas. O que a ação realmente almeja, portanto, é a tutela do direito e, assim, na hipótese referida, a tutela ressarcitória pelo equivalente ou a tutela do adimplemento da obrigação de pagar quantia.

---

14

Sobre a importância da estruturação adequada da técnica processual para a efetividade da tutela do crédito pecuniário, ver Benedito Pereira Filho, Repensando o processo de execução para uma maior efetividade da tutela do crédito pecuniário, Tese de doutorado, Universidade Federal do Paraná, Faculdade de Direito, 2002.

---

15

Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 11, p. 66.

---

16

Salvatore Satta, Proveddimenti d’urgenza e urgenza di provvedimenti, Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova: CEDAM, 1968, p. 392 e ss; Giovanni Verde, Considerazioni sul provvedimento d’urgenza, I processi speciali – Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi, Napoli: Jovene, 1979.

---

17

Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 8, Rio de Janeiro: Forense, 1977.

---

18

Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 11, p. 67.

---

19

“Por el contrario, la imposibilidad de recurrir directamente a la via ejecutiva y la necesidad consiguiente de obtener un título ejecutivo judicial mediante un proceso de cognición se explican fácilmente por la existencia de una situación jurídica sustancial caracterizada por el elemento de la incertidumbre. En este

segundo supuesto, dada la necesidad previa de eliminar la incertidumbre sobre la situación jurídica sustancial, la acción no puede ser ejercitada más que en vía declarativa, a fin de que el antecedente lógico-jurídico de la ejecución, que es la aptitud de la acción para ser ejercitada in executivis, encuentre su base en el accertamiento y su realización en la creación del título que condiciona la iniciación de la vía ejecutiva” (Carlo Furno, Teoría de la prueba legal, Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1954, p. 190).

---

20

Piero Calamandrei, La sentencia declarativa de quiebra, Apêndice n. 2 à Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, p. 204-205.

---

21

“E poichè alla clausola di provvisoria esecutorietà è stata da tempo, autorevolmente, riconosciuta funzione cautelare, analoga funzione deve pure riconoscersi alla sospensione dell’esecuzione” (Carlo Furno, La sospensione del processo esecutivo, Milano: Giuffrè, 1956, p. 55).

---

22

“Así, tal y como ya se deduce de lo expuesto, mientras que la naturaleza y función de la ejecución provisional es la propia de la ejecución ordinaria, es decir, esencialmente satisfactiva para el ejecutante dentro de los límites de la ejecución misma, la naturaleza de la medida cautelar es simplemente de tutela, de aseguramiento o garantía, no pudiendo llegarse en la adopción de la misma hasta penetrar en la propia esfera jurídica del perjudicado por la medida, a través de institutos tales como el embargo y la enajenación forzosa” (Adolfo Perez Gordo, La ejecución provisional en el proceso civil, Barcelona: Bosch, 1973, p. 42).

---

23

Cf. Ovídio Baptista da Silva, Teoría de la acción cautelar, Porto Alegre: Fabris, 1993, p. 79.

---

24

Luiz Guilherme Marinoni, A antecipação da tutela, 12ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 135 e ss.

---

25

Vittorio Denti, Intervento, La tutela d’urgenza, Rimini: Maggioli, 1985, p. 171.

---

26

Na teoria de Calamandrei, nas providências cautelares “se encontra uma instrumentalidade qualificada, ou seja elevada, por assim dizer, ao quadrado; são, com efeito, indubitavelmente, um meio predisposto para o melhor êxito da providência definitiva, que, por sua vez, é um meio para a atuação do direito; isto é, são, em relação à finalidade última da função jurisdicional, instrumento do instrumento” (Piero

Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 21-22).

---

27

Kazuo Watanabe, Da cognição no processo civil, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1987, p. 45 e ss.

---

28

Ovídio Baptista da Silva, A ação cautelar inominada no direito brasileiro, p. 67.

---

29

Ver Daniel Mitidiero, Antecipação da tutela, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 112 e ss.

---

30

Ver Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015 e Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitoria, Madrid: Marcial Pons, 2014; Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva* e Sérgio Cruz Arenhart, *A tutela inibitória da vida privada*.

---

31

Adolfo di Majo, La tutela civile dei diritti, Milano: Giuffrè, 1993, p. 144.

---

32

Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual e tutela dos direitos, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 51 e ss.

---

33

Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli: Jovene, 1994, p. 185.

---

34

A hipótese é semelhante à do art. 644, primeira parte, do CPC italiano, a qual, segundo Proto Pisani, “in ipotesi di sfratto per morosità, consente al giudice adito di pronunciare ‘decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto’: anche in questo caso la condanna è richiesta per crediti futuri (...)” (Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 184). No direito italiano – entre outros casos de condenação para o futuro –, o art. 657 do CPC permite que o locador obtenha, antes do término do contrato, um título executivo que lhe permita executar imediatamente o despejo logo depois do término do prazo contratual. Ver Renata Paolini, Note sulla condanna in futuro, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1976, p. 511 e ss.

---

35

36

Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 185.

---

37

Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, v. 1, São Paulo: Saraiva, 1965, p.191.

---

38

Cristina Rapisarda, Profili della tutela civile inibitoria, Padova: CEDAM, 1987, p. 189.

---

39

Giuseppe Chiovenda, L'azione nel sistema dei diritti, Saggi di diritto processuale civile, Roma: Foro Italiano, 1930, p. 79.

---

40

Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 33-34.

---

41

Massimo D'Antona, La reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), Padova: CEDAM, 1979; Renata Paolini, Note sulla condanna in futuro, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1976, p. 526.

---

42

Proto Pisani percebeu a nítida diferença entre a condenação para o futuro e a tutela inibitória, demonstrando a função repressiva da primeira: “O problema da admissibilidade da condenação para o futuro é um problema diferente daquele da admissibilidade, ou não, da tutela inibitória geral: contrariamente à inibitória, a condenação para o futuro possui uma função que pode ser qualificada como preventiva somente se a este termo for dado um significado muito amplo; o que de fato a condenação para o futuro objetiva prevenir não é tanto a violação quanto a diferença temporal entre o momento da violação e possibilidade de instaurar a execução forçada; assim parece mais correto inserir tal tipo de condenação entre as hipóteses em que a condenação cumpre uma função repressiva” (Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 184).

---

43

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 137-138.

---

44



45

Ver Adolfo di Majo: “Le dottrine giuridiche dell’Ottocento, dopo la parentesi medioevale, recuperano appieno il principio romanistico (della prevalenza) della *condemnatio pecuniaria*, dovendo apparire, questa prevalenza, come la più funzionale alle esigenze del mercato. Nel mercato, com’è noto, non contano le qualità dei soggetti nè quelle dei valori od interessi in esso presenti (astrattezza dei valori). In presenza di atti e/o di fatti che comportano inadempimento di obblighi e/o violazioni di diritti, la linea tendenziale è di imporre al responsabile il mero ‘costo economico’ di siffatti comportamenti, tendendosi in tal modo a riprodurre i meccanismi di mercato alterati” (Adolfo di Majo. *La tutela civile dei diritti*, p. 156).

---

46

Diz Salvatore Mazzamuto: “I soggetti dello scambio sono liberi di autodeterminarsi attraverso il contratto e debbono soltanto rispettare le regole del giuoco, le quali sono concepite nel presupposto della parità formale dei contraenti e non impongono di adeguare il regolamento d’interessi a parametri di valutazione sociale. I limiti posti dall’ordinamento all’autonomia dei privati appaiono come limiti squisitamente negativi. Così è per il divieto di conformare il negozio in contrasto con le norme imperative e per la corrispondente sanzione della nullità. Ma così è anche per la misura del risarcimento del danno che consegue all’inattuazione dello scambio” (Salvatore Mazzamuto, *L’attuazione degli obblighi di fare*, p. 37-38).

---

47

Lodovico Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano: Giuffrè, 1964, p. 428. Porém, a doutrina contemporânea, inclusive a italiana, não se rende ao velho argumento de que a inibitória pode colocar em risco a liberdade do homem. Ver Cristina Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria*, p. 90 e ss.; Aldo Frignani, *L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 428.

---

48

Gian Antonio Micheli, *L’azione preventiva*. *Rivista di Diritto Processuale*, 1959, p. 205.

---

49

Desta forma, é correta a lição de Barbosa Moreira, no sentido de que a tutela declaratória somente pode prevenir uma violação quando a parte vencida sai também convencida e resolve cumprir a obrigação em tempo oportuno: “Como meio de intimidação, e pois de coerção, todavia, o remédio é fraco: basta pensar que, na eventualidade de inadimplemento, o titular do direito lesado terá de voltar a juízo para pleitear a condenação do infrator, ao qual se concede assim uma folga em boa medida tranquilizadora” (José Carlos Barbosa Moreira, *Tutela sancionatória e tutela preventiva*. *Temas de direito processual*, São Paulo: Saraiva. 1980. p. 27).

---

50

Andrea Proto Pisani, *L’attuazione dei provvedimenti di condanna*, Roma: *Foro Italiano*, 1988, p. 184;

Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 183; Aldo Frignani, L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano, p. 592 e ss.

---

51

Giuseppe Chiovenda, L'azione nel sistema dei diritti, p. 82.

---

52

Chiovenda discordou da teoria de Redenti sobre o fim sancionatório da justiça civil, exatamente porque, ao aceitar a tese de Wach, que demonstrava uma relação teórica entre a autonomia do direito de ação e a ação declaratória, concluiu que a ação declaratória não supõe a violação de um direito e não tem por fim aplicar uma sanção (Cristina Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria*, p. 53).

---

53

Vittorio Denti reconhece a ligação da tutela declaratória, como remédio de caráter preventivo, com o modelo institucional liberal: “Altro punto che va tenuto fermo è il carattere preventivo dell’azione inibitoria. La dottrina processualistica ha, per lunga tradizione, risolto la tutela giurisdizionale preventiva nel mero accertamento, con una scelta che non ha avuto – come è stato recentemente dimostrato – soltanto carattere concettuale, poiché era condizionata dalla tendenza a delimitare rigidamente i poteri di ingerenza statale nella sfera giuridica privata. Si trattava, quindi, della adesione al modello istituzionale liberale, chiaramente presente nel maggiore teorizzatore dell’azione di mero accertamento e della sua funzione preventiva, Giuseppe Chiovenda” (Vittorio Denti, *Diritti della persona e tecniche di tutela giudiziale. L’informazione e i diritti della persona*, Napoli: Jovene, 1983, p. 267).

---

54

Cristina Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria*, p. 70-72; Cristina Rapisarda, *Premesse allo studio della tutela civile preventiva*. *Rivista di Diritto Processuale*, 1980, p. 128 e ss.

---

55

Ver Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela anticipatoria y tutela inibitoria*, Lima: Palestra, 2016, p. 340 e ss.

---

56

Orlando Gomes, por exemplo, produziu doutrina expressiva no sentido da unificação das categorias da ilicitude e da responsabilidade civil: “Não interessa ao Direito Civil a atividade ilícita de que não resulte prejuízo. Por isso, o dano integra-se na própria estrutura do ilícito civil. Não é de boa lógica, seguramente, introduzir a função no conceito. Talvez fosse preferível dizer que a produção do dano é, antes, um requisito da responsabilidade, do que do ato ilícito. Seria este simplesmente a conduta contra jus, numa palavra, a injúria, fosse qual fosse a consequência. Mas, em verdade, o Direito perderia seu sentido prático se tivesse de ater-se a conceitos puros. O ilícito civil só adquire substantividade se é fato danoso” (Orlando Gomes, *Obrigações*, Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 313-314).

---

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito.

---

Ver Ovídio Baptista da Silva, Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 147.

---

Os magistrados anteriores à Revolução Francesa eram considerados aliados da nobreza e do clero. A desconfiança da burguesia em relação aos juízes – que era totalmente justificada – foi responsável pela feição passiva e neutra que a Revolução Francesa atribuiu ao Judiciário.

---

Ver Juan José Monroy Palacios, La tutela procesal de los derechos, Lima: Palestra. 2004, p. 34 e ss; Juan José Monroy Palacios, Cinco temas polémicos en el proceso civil peruano, Revista de Direito Processual Civil, Curitiba: Genesis, v. 21.

---

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela cautelar e tutela antecipatória, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 21 e ss.

---

O procedimento de cognição plena e exauriente, complementado pelas três sentenças da classificação trinária, é absolutamente incapaz de propiciar uma tutela preventiva adequada. Este modelo de “processo”, que pode ser chamado de “processo civil clássico”, além de refletir, sobre o plano metodológico, as exigências da escola sistemática, baseadas na necessidade de isolar o processo do direito material, espelha os valores do direito liberal, fundamentalmente a “neutralidade” do juiz, a autonomia da vontade, a não ingerência do Estado nas relações dos particulares e a incoercibilidade do facere.

---

Loriana Zanuttigh, La tutela cautelare atipica. L'informazione e i diritti della persona, Napoli: Jovene, 1983, p. 281.

---

Como diz Zanuttigh, “un ulteriore profilo dell’esperienza concreta dell’istituto conferma, ai fini di una valutazione complessiva, che le indicazioni emergenti dalla evoluzione degli orientamenti dei giudici e dalle istanze degli utenti della giustizia sono nel senso di una chiara propensione verso forme sempre più estese di tutela preventiva e non repressiva, almeno per talune categorie di diritti. Ne è prova, l’attitudine dei provvedimenti urgenti a porsi come strumenti di tutela sommaria non cautelare, nella sostanza cioè ad operare come forma autonoma di tutela. Siffatta alterazione della funzione delle misure cautelari

atipiche è resa percepibile e viene accentuata da talune applicazioni dell'istituto" (Loriana Zanuttigh La tutela cautelare atipica, p. 276-277).

---

65

Vittorio Denti, Diritti della persona e tecniche di tutela giudiziale, p. 263.

---

66

Andrea Proto Pisani, La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela. Roma: Foro Italiano, 1990, p. 17 e ss.

---

67

Vittorio Denti, Diritti della persona e tecniche di tutela giudiziale, p. 265. Ver aindà Francesco Paolo Luiso, Diritto processuale civile, vol. 4, Milano: Giuffrè, 2015, p. 210 e ss; Carmine Punzi, Il processo civile, v. 3, Padova: Cedam, 2010, p. 35 e ss.

---

68

Giovanni Verde também analisa a deformação da fisionomia original da tutela cautelar diante da evolução da sociedade e dos direitos: "Nel tirare le somme, avviandomi a concludere, mi accorgo di avere tenuto un discorso confuso, disarticolato e in qualche parte incoerente. Ma la verità è che sono stato travolto dalla stessa maniera disorganica con la quale l'istituto del provvedimento d'urgenza si è venuto modificando e adattando alle concrete esigenze. E mi pare che le indicazioni fornite, dalle quali si sono volutamente tralasciate le ricchissime serie di provvedimenti a tutela dei diritti della personalità (in senso tradizionale) e della concorrenza, che rappresentano il campo naturale di applicazione dei provvedimenti in esame, abbiano confermato che non ci sia stata vicenda di qualche rilievo (...) che non sia passata per tale forma di giustizia. Ne è venuta fuori una tipologia assai varia e che forse meriterebbe di essere organizzata secondo criteri sistematici, che non sono stato in grado di elaborare. Si potrebbero, così, isolare accertamenti sommari con prevalente funzione cognitiva, accertamenti sommari con prevalente funzione esecutiva, ingiunzione, inibizione oltre che meri provvedimenti cautelari" (Giovanni Verde, Considerazioni sul procedimento d'urgenza – Come è e come si vorrebbe che fosse. I processi speciali – Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi, p. 458-460).

---

69

Em razão disto, Tarzia alertou para o fato de que a doutrina colocou-se de frente ao "fenômeno più impressionante di evoluzione e trasformazione di uno strumento processuale" (Giuseppe Tarzia, Intervento, La tutela d'urgenza, p. 150).

---

70

RO-MS 37.219/91.2, rel. Min. Hylo Gurgel.

---

71

Lembre-se, neste exato sentido, a lição de Roger Perrot: “Mais pour cette raison, la philosophie même de la mesure provisoire a changé. Au siècle dernier, elle avait surtout pour rôle d’assurer la conservation des biens litigieux ou d’aménager temporairement une situation contentieuse en attendant le jugement définitif. De nos jours, ce rôle premier n’a pas disparu. Mais une autre fonction s’est développée qui gagne en importance et qui consiste moins en une mission de sauvegarde qu’en une anticipation sur la décision définitive” (Roger Perrot. *Les mesures provisoires en droit français. Les mesures provisoires en procédure civile*, Milano: Giuffrè, 1985, p. 153). Em igual sentido Michelle Aiello: “Ulteriore ed indiretta conseguenza della ravvisata inadeguatezza degli strumenti della cognizione ordinaria è stata però anche quella di snaturare la finalità e l’efficacia dei medesimi provvedimenti di urgenza” (Michelle Aiello. *I provvedimenti di urgenza nell’attuale momento legislativo italiano*, p. 265). Ver, ainda, Giovanni Arieta, *Comunicazione*, p. 269-270; Vittorio Denti, *La giustizia civile*, Bologna: Il Mulino, 1989, p. 129-130.

---

72

No direito argentino, a doutrina também elaborou importante trabalho para demonstrar a distinção entre a tutela antecipatória e a tutela cautelar e para evidenciar a necessidade de procedimentos e técnicas processuais capazes de viabilizá-la. Ver as obras coletivas *Medidas autosatisfactivas* (dirigida por Jorge W. Peyrano), e *Sentencia anticipada* (dirigida por Jorge W. Peyrano e organizada por Carlos A. Carbone). Ver, ainda, Augusto Morello, *Anticipación de la tutela*, La Plata: Platense, 1996; Roberto Berizonce, S. Patricia Bermejo e Zulma Amendolara, *Tribunales y proceso de familia*, La Plata: Platense, 2001, p. 50-59; Jorge W. Peyrano, *Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia – medidas autosatisfactivas*. *Revista de Direito Processual Civil*, v. 9, Curitiba: Gênesis; Jorge W. Peyrano, *Régimen de las medidas autosatisfactivas, nuevas propuestas*. *Revista de Direito Processual Civil*, v. 7, Curitiba: Gênesis; Álvaro Perez Ragone, *Introducción al estudio de la tutela anticipatoria*, *Revista de Direito Processual Civil*, v. 5, Curitiba: Gênesis e *Concepto estructural y funcional de la tutela anticipatoria*, *Revista de Direito Processual Civil*, v. 13 Curitiba: Gênesis; Carlos Alberto Carbone, *Los procesos urgentes y la anticipación de la tutela*, *Revista de Direito Processual Civil*, v. 21. Curitiba: Gênesis; Abraham Luiz Vargas, *Teoría general de los procesos urgentes, Medidas autosatisfactivas*; Abraham Luis Vargas, *Tutela anticipada: Perfiles actuales. Cuestiones Procesales Modernas*, 2005, p. 174; Jorge Rojas, *Los límites de la tutela anticipada. Sentencia anticipada*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2001; Sergio J. Barberio, *La medida autosatisfactiva*, Santa Fé: Panamericana, 2006.

---

73

Humberto Theodoro Júnior, *Processo cautelar*, p. 108.

---

74

TJSC, 1.<sup>a</sup> CC, Ap. 26.034, v. u.

---

75

“Stante il divieto di autotutela privata, un ordinamento che si limitasse ad affermare una situazione di vantaggio (un diritto: si pensi al diritto di riunione, al diritto di assemblea, al diritto del locatore alla reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento, trasferimento o sospensione illegittimi, al diritto dei figli naturali ad essere mantenuti educati ed istruiti dai genitori, al diritto di proprietà, al diritto di libertà sindacale ecc) a livello di diritto sostanziale, senza predisporre a livello di diritto processuale strumenti

idonei a garantire l'attuazione del diritto anche in caso di sua violazione, sarebbe un ordinamento incompleto, monco: sarebbe un ordinamento che non potrebbe essere qualificato come giuridico, poiché non garantirebbe l'attuazione del diritto proprio nel momento in cui questo è più bisognoso di tutela, nel momento della sua violazione. Si comprende quindi l'importanza del diritto processuale: dalla sua esistenza dipende la stessa esistenza – a livello di effettività – del diritto sostanziale” (Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 5).

---

76

Luiz Guilherme Marinoni, *L'evoluzione della tecnica anticipatoria e della tutela preventiva in Brasile*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2013, p. 1353 e ss.

---

77

Assim como nas hipóteses de abuso de defesa e parte incontroversa da demanda; art. 273, II e § 6.º, CPC/73.

---

78

Ver Daniel Mitidiero, *Antecipação da Tutela*; André Luiz Bauml Tesser, *Tutela cautelar e antecipação de tutela*, São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 2014.

---

79

Sobre a tutela inibitória, ver Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela contra o ilícito*; Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela específica*; Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*; Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva*; Sérgio Cruz Arenhart, *A tutela inibitória da vida privada*; Clayton Maranhão, *Tutela jurisdicional do direito à saúde*, São Paulo, RT, 2003; Luciane Gonçalves Tessler, *Tutelas jurisdicionais do meio ambiente – Tutela inibitória, tutela de remoção e tutela ressarcitória na forma específica*, São Paulo, RT, 2005. No diritto italiano: Aldo Frignani, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*; Aldo Frignani, *Inibitoria (azione)*. *Enciclopedia del diritto*, v. 21, p. 559 e ss.; Aldo Frignani, *Azione in cessazione*. *Novissimo Digesto Italiano* (appendice I), p. 639 e ss.; Aldo Frignani, *Inibitoria (azione)*. *Enciclopedia Giuridica Treccani*, v. 17, p. 1 e ss.; Cristina Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria*; Cristina Rapisarda, *Inibitoria*. *Digesto delle discipline privatistiche*. v. 9, p. 475 e ss.; Cristina Rapisarda e Michele Taruffo, *Inibitoria*. *Enciclopedia Giuridica Treccani*, v. 17, p. 1 e ss.; Ugo Mattei, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*; Mario Libertini, *La tutela civile inibitoria*. *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*. p. 315 e ss.; Luigi Montesano, *Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgenti*. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, p. 775 e ss. Na Argentina: Ricardo Luis Lorenzetti, *La tutela civil inibitoria*. *La Ley*, 1995-C; Noemi Lidia Nicolau, *La tutela inibitoria y el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional*. *La Ley*, 1996-A; Jorge W. Peyrano, *La acción preventiva*.

---

80

Ver Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela contra o ilícito*, p. 28. “Com'è noto, a partire dalla metà degli anni 60 un consistente orientamento dottrinale ha posto in luce l'importanza della distinzione tra illecito (come condotta antigiusuridica) e danno, come fatto storico, materiale, che può essere (eventuale) conseguenza



dell'illecito, o può derivare da fatti non suscettibili di tale qualificazione” (Michele Mòcciola, Problemi del risarcimento del danno in forma specifica nella giurisprudenza. *Rivista Critica del Diritto Privato*, p. 367). “Il riferimento all’art. 2.043 codice civile ha un significato innovatore, se si traggono tutte le conseguenze dalla revisione che la dottrina più recente ha operato dell’intera materia dell’illecito civile. Uno dei più proficui risultati di tale revisione appare, infatti, la netta distinzione tra atto illecito e fatto dannoso da cui deriva la responsabilità civile” (Cesare Salvi, Legittimità e “razionalità” dell’art. 844 Codice Civile, p. 590).

---

81

“Note-se, porém, que se o dano é uma consequência meramente eventual e não necessária do ilícito, a tutela inibitória não deve ser compreendida como uma tutela contra a probabilidade do dano, mas sim como uma tutela contra o perigo da prática, da repetição ou da continuação do ilícito, compreendido como ato contrário ao direito que prescinde da configuração do dano” (Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 65).

---

82

“Para evidenciar que o dano não é elemento constitutivo do ilícito, argumentou-se que, quando se diz que não há ilícito sem dano, identifica-se o ato contra ius com aquela que é a sua normal consequência, e isto ocorreria apenas porque o dano é o sintoma sensível da violação da norma. A confusão entre ilícito e dano seria o reflexo do fato de que o dano é a prova da violação e, ainda, do aspecto de que entre o ato ilícito e o dano subsiste frequentemente uma contextualidade cronológica que torna difícil a distinção dos fenômenos, ainda que no plano lógico” (Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 64). Ver Eduardo Bonasi Benucci, Atto illecito e concorrenza sleale. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, p. 569.

---

83

E isto se torna ainda mais evidente “quando se pensa nos direitos que não podem ser tutelados de forma adequada através do ressarcimento em pecúnia (p. ex., concorrência desleal) e, principalmente, nos direitos não patrimoniais. Não viabilizar a tutela inibitória quando em jogo direitos não patrimoniais é admitir a sua expropriação, transformando-se o direito ao bem em direito ao ressarcimento ou, em outras palavras, em simples pecúnia. Tal possibilidade, como é óbvio, está muito distante das Constituições fundadas na dignidade do homem e preocupadas em propiciar a sua inserção em uma sociedade mais justa. A Constituição Federal afirma expressamente que: i) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5.º, X); ii) é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5.º, XII); iii) aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar (art. 5.º, XXVII); iv) a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5.º, XXIX); v) o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (art. 5.º, XXXII); vi) todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras

gerações (art. 225, caput). Supõe-se, como é óbvio, que tais direitos devam ser efetivamente tutelados, até mesmo porque a falta de efetividade da tutela jurisdicional implica a existência de um ordenamento impotente à tutela dos direitos” (Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela contra o ilícito*, p. 97-98).

---

84

“O objetivo da distinção entre tutela do direito e técnica processual é o de verificar se a legislação possui instrumentos processuais (técnica processual) efetivamente capazes de propiciar a tutela dos direitos. Para tanto, é necessário analisar, como antecedente lógico, o que é vital à proteção dos direitos, para depois ver se os instrumentos processuais estão adequadamente preordenados para permitir a tutela que lhes é inerente. Tal distinção traz ao direito processual um novo valor, calcado na necessidade de verificar se o processo está realmente preparado para assumir plenamente a função de tutela dos direitos, ou se é algo incapaz de fazer o Estado cumprir com o dever que assumiu no momento em que proibiu a autotutela. Se não é possível negar, diante da consideração do direito material, o direito à tutela inibitória (por exemplo), fica o legislador infraconstitucional obrigado a estabelecer os instrumentos adequados para garanti-la, sob pena de descumprir o preceito constitucional consagrador do direito fundamental de ação. Isto quer dizer que a tutela jurisdicional inibitória, que é resposta do processo ao direito à tutela inibitória, deve constituir tutela jurisdicional que possa efetivamente inibir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito. É por isso que a tutela jurisdicional inibitória pode ser prestada antecipadamente (quando for o caso) e por meio das sentenças e meios de execução adequados” (Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela contra o ilícito*, p. 98-99).

---

85

“O direito de ação, hoje, é muito mais do que o direito à ação adequada ao plano do direito material. O legislador não se limitou – nem poderia – a estabelecer técnicas processuais adequadas ao plano do direito material, mas instituiu cláusulas gerais, assim como técnicas processuais dotadas de conceitos indeterminados, com o objetivo de dar ao cidadão o direito de construir a ação adequada ao caso concreto. A legitimidade da jurisdição depende dos direitos de o autor influir sobre o convencimento do juiz e utilizar as técnicas processuais adequadas à proteção do direito material. Acontece que, conforme dito acima, não se pode exigir do legislador a estruturação de tantos procedimentos especiais quantas sejam as situações de direito substancial carentes de tutela. Ainda que se pudesse tentar cumprir tal tarefa através de um trabalho hercúleo e não produtor, jamais seria possível criar procedimentos ou técnicas processuais que se ajustassem perfeitamente às variadas situações de direito material, pois essas, ainda que possam ser visualizadas em abstrato, sempre estão na dependência das circunstâncias do caso concreto. (...) A legislação processual civil brasileira impõe a tese do direito à construção da ação adequada ao caso concreto. Além dos arts. 536 do CPC e 84 do CDC, que expressamente dão ao autor o poder de agregar à sua ação a técnica processual idônea, o art. 83 do CDC – ao dizer que ‘são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela’ – não apenas reafirma o dever de o legislador instituir as técnicas processuais capazes de permitir a efetiva tutela dos direitos, mas na verdade evidencia o direito de o autor construir a ação adequada às necessidades do caso concreto” (Luiz Guilherme Marinoni, *Teoria Geral do Processo*, 18ª ed., p. 295-297).

---

86

“Os arts. 536, CPC, e 84, CDC, constituem as fontes de vários instrumentos processuais necessários para a efetividade da concessão de diversas espécies de tutelas. A possibilidade de se criar um aparato técnico

(um procedimento) através da conjugação destes instrumentos, permite conceber ações adequadas à prestação de várias tutelas, entre elas a inibitória. Estes artigos, em outras palavras, instituem apenas técnicas processuais adequadas. Não devem ser vistos como o fundamento substancial da tutela inibitória ou mesmo da tutela das obrigações de fazer e de não fazer, mas sim como as normas de natureza processual que, seguindo a orientação consubstanciada no art. 5.º, XXXV, da CF, estabeleceram os instrumentos necessários para que o direito à tutela pudesse ser efetivamente exercido. Melhor explicando: tais normas permitem a imposição de fazer ou de não fazer por meio das técnicas nele presentes, e esta possibilidade – de imposição de fazer ou de não fazer – é que viabiliza a prestação de várias tutelas, entre elas a tutela inibitória, a tutela de remoção do ilícito, a tutela ressarcitória na forma específica e a tutela específica da obrigação contratual inadimplida. Por esta razão é equivocado supor que o art. 536 é a fonte da tutela das obrigações de fazer e não fazer; não há como se confundir fonte de tutela com fonte dos instrumentos processuais de tutela. O Código de Processo Civil não trata da tutela dos direitos, mas apenas da técnica adequada a esta tutela, ou melhor, do veículo capaz de prestar a tutela jurisdicional” (Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 125-126).

---

87

Michele Mòcciola, Problemi del risarcimento del danno in forma specifica nella giurisprudenza, p. 380-381. Ver Michele Giorgianni, Tutela del creditore e tutela “reale”. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1975, p. 853 e ss.; Renato Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1957, p. 201 e ss.

---

88

O art. 84 do CDC tem grande semelhança com o art. 536 do CPC, dispondo, no seu caput, que, “na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. Este artigo está inserido no sistema de tutela coletiva dos direitos, integrado, fundamentalmente, pela Lei da Ação Civil Pública e pela parte final do Código de Defesa do Consumidor. De modo que o art. 84 do CDC constitui a base de qualquer ação voltada à tutela específica dos direitos difusos e coletivos.

---

89

Imaginou-se por muito tempo que a lei, por obrigar quem comete um dano a indenizar, não diferenciava ilícito de dano, ou melhor, considerava o dano como elemento essencial e necessário da *fattispecie* constitutiva do ilícito. Entretanto, o dano não é uma consequência necessária do ato ilícito. O dano é requisito indispensável para o surgimento da obrigação de ressarcir, mas não para a constituição do ilícito (Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 66).

---

90

Lodovico Barassi afirmou que a “tutela puramente preventiva”, “certamente la più energica”, seria também “la più preoccupante, come è di tutte le prevenzioni che possono eccessivamente limitare l’umana autonomia”. A ideia de que a tutela inibitória encontra obstáculo na liberdade do homem guarda raízes em princípios próprios do direito liberal clássico, os quais não podem servir para inspirar uma doutrina que vive em um outro Estado, sob diversos valores e em uma diferente época. A tutela

preventiva, como já foi dito, é fundamental para a efetividade de direitos muito importantes dentro do contexto do Estado atual (Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela contra o ilícito*, p. 52). Ver Lodovico Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, p. 428.

---

91

Note-se que o arresto, por exemplo, difere nitidamente da tutela inibitória, já que não exerce função inibitória, mas destina-se a assegurar a efetividade da futura tutela ressarcitória. Ou seja, há uma nítida diferença entre a tutela inibitória e a tutela que visa a dar segurança a um direito que já foi violado. Na verdade, e para irmos um pouco mais além, parece mais exato afirmar que a tutela cautelar, além de ter por fim assegurar a efetiva tutela de um direito já violado, pode ter por escopo assegurar um direito para a hipótese de ele ser violado. Basta pensar nos casos em que a caução cautelar pode ser utilizada para assegurar ao autor a efetividade da eventual (e aí não necessária) tutela ressarcitória, que poderá ser requerida se o direito (que apenas se teme ver violado) for realmente lesado. Da mesma forma que a condenação para o futuro – que, por pressupor a violação do direito, não tem natureza preventiva (apesar da expressa discordância de Calamandrei, que afirma que a condenação para o futuro constitui o caso más notorio de tutela preventiva) –, a caução que visa a assegurar uma eventual e futura tutela ressarcitória também não pode deixar de ser diferenciada da tutela inibitória. Tanto a tutela que visa a assegurar a efetividade da tutela de um direito que já foi violado, quanto a tutela que objetiva assegurar um direito para a hipótese de ele ser violado, têm natureza acautelatória, ou seja, de segurança que não se dirige a impedir a violação do direito, mas sim a garantir o direito na suposição de que ele, após ter sido violado, poderá não ser efetivamente tutelado. Lembre-se de que no direito italiano a tutela inibitória passou a ser prestada sob o manto protetor da tutela cautelar, em razão das novas exigências de tutela, e não em virtude de especial disposição legislativa, ou de interpretação doutrinária que tivesse enxergado no art. 700 do CPC italiano a base de um princípio geral de prevenção. Se o art. 700 do CPC italiano passou a servir de base, em razão das necessidades concretas de tutela, à tutela inibitória, isto não quer dizer que a tutela cautelar, na sua gênese, constituía um gênero a que pertencia a tutela inibitória. Ao contrário, a tutela cautelar inominada jamais abrangeu a tutela inibitória, até porque seria contraditório pensar que uma tutela que foi desenhada para ser “instrumento do instrumento” poderia viabilizar a tutela preventiva em um sistema de tutelas finais que foi construído sobre a ideia de que o direito material só pode ser prevenido em hipóteses excepcionais. Na verdade, é completamente ilógico imaginar que, em um sistema que trabalha apenas com as sentenças declaratória, constitutiva e condenatória (as quais não viabilizam a concessão de tutela inibitória), a tutela cautelar – criada para dar efetividade à jurisdição – poderia ir além da sua função de segurança do processo, extrapolando dos seus limites para dar tutela ao próprio direito material, e assim tornar sem sentido a própria “ação principal”. É certo, portanto, que a tutela cautelar, quando originariamente pensada, não podia se confundir com a tutela inibitória. Se essa confusão foi instalada na prática forense em virtude da própria necessidade de tutela adequada dos direitos, é tarefa da doutrina eliminá-la, esclarecendo que a tutela inibitória não se identifica com a tutela cautelar, constituindo a primeira uma forma de tutela que ainda é confundida com a cautelar, em razão de a doutrina não ter separado conceitualmente as noções de prevenção e cautela. No Brasil, aliás, diante dos arts. 536 do CPC e 84 do CDC, e assim da evidência da ação inibitória – que é de conhecimento e, portanto, autônoma – constitui verdadeira heresia continuar confundido tutela cautelar com tutela inibitória. A tutela inibitória, no Brasil, ao contrário do que acontece na Itália, não precisa ser requerida com base em uma norma construída para servir de base à tutela cautelar. No Brasil, assim, justamente porque a inibitória tem endereço nos arts. 536 do CPC e 84 do CDC, jamais surgirá o problema que aparece na prática italiana quando é requerida tutela inibitória sob o rótulo de cautelar, e indaga-se, com surpresa, a respeito da sua instrumentalidade. A distinção entre prevenção e cautela, se realizada no

direito italiano, poderia inviabilizar a tutela inibitória sumária atípica na própria ação declaratória; certamente por isso, ou seja, para não se construir uma teoria contra as próprias necessidades da vida, é que a doutrina italiana se mantém calada sobre o assunto. No direito brasileiro, porém, onde estão presentes os instrumentos processuais dos arts. 536 do CPC e 84 do CDC, deve ser prontamente revelado o equívoco da confusão entre a tutela cautelar e a tutela inibitória, pois somente assim o uso do processo civil será mais adequado e efetivo. Com efeito, a confusão entre tutela inibitória sumária e tutela cautelar também decorre da exigência prática de tutela inibitória em um sistema de tutelas fundado sobre o binômio sentença condenatória-execução forçada. Teoricamente, em um sistema como este, não há lugar para a tutela inibitória atípica sumária, mas apenas para aquela que deseja garantir a tutela final do direito violado. Portanto, a necessidade de separar conceitualmente as tutelas inibitória e cautelar deriva, de um lado, da evidência da imprescindibilidade da tutela inibitória na sociedade contemporânea, e, de outro, do surgimento de novas sentenças e meios de execução, os quais se colocam ao lado das sentenças declaratória, constitutiva e condenatória (as únicas que eram admitidas pela doutrina), viabilizando, assim, a concessão de tutelas que antes não podiam ser prestadas, e desta forma uma maior efetividade ao processo. Ora, se o Código de Processo Civil consagra expressamente as sentenças mandamental e executiva e a antecipação da tutela (art. 536), há bastante luz para afirmar, sem medo de errar, que a tutela inibitória deve ser prestada através de ação inibitória, e assim não pode mais ser confundida com a cautelar. Lembre-se, finalmente, de que as tutelas, sejam elas finais ou antecipadas, devem ser classificadas a partir de sua relação com o plano do direito substancial. Ora, se o nexo de separação-abstração do direito processual do direito material, transmitido pelo pensamento chiovendiano, pode hoje ser considerado historicamente superado, constituindo preocupações da doutrina mais moderna a relativização do binômio direito-processo e a construção de tutelas jurisdicionais aderentes às diversas necessidades do direito material, é evidente que as tutelas não mais devem ser classificadas com base em critérios processuais, como é o da provisoriedade, devendo, sim, merecer atenção o que as tutelas significam no plano do direito material e na vida das pessoas (Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 243-247).

---

92

Ovídio Baptista da Silva, Processo e ideologia, Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 123.

---

93

A tutela que necessita ‘de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia’, é uma tutela que não é prestada por uma sentença que basta por si só, como a sentença declaratória – que não pode e não precisa ser executada –, uma vez que exige meios de execução. Tal tutela é prestada pela sentença e pelos meios executivos, ou melhor, por uma sentença cuja natureza é delineada com base nos meios de execução que a complementam (...). Portanto, a execução, no Estado constitucional, não pode ser reduzida a um ato de transferência de riquezas de um patrimônio a outro, devendo ser vista como a forma ou o ato que, praticado sob a luz da jurisdição, é imprescindível para a realização concreta da tutela jurisdicional do direito, e assim para a própria tutela prometida pela Constituição e pelo direito material.

---

94

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 154-158.

---

“As ações inibitória e de remoção do ilícito são autônomas, e assim devem ser veiculadas por meio do processo de conhecimento, especificamente por intermédio de um procedimento dotado de técnica antecipatória e das sentenças mandamental e executiva. Atualmente, diante de uma leitura adequada dos arts. 536 do CPC e 84 do CDC, não há como ignorar que os direitos à inibição e à remoção do ilícito podem ser efetivamente exercidos mediante ação de conhecimento, o que não mais justifica o uso distorcido da ação cautelar” (Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 56 e ss.).

Sobre o problema do tempo no processo civil há interessantes estudos no direito francês. Ver Soraya Amrani-Mekki, *Le temps et le procès civil*, Paris: Dalloz, 2002; Didier Cholet, *La célérité de la procédure en droit processuel*, Paris: L.G.D.J., 2006.

Ver Luiz Guilherme Marinoni, *A antecipação da tutela*, 12ª ed., p. 33 e ss.

“A tendência para a ‘plenarização’ das demandas que vem inspirando a evolução de nosso direito processual, com a correspondente universalização da ordinariedade e supressão dos ‘procedimentos especiais’, acabou por tornar a demanda especial de depósito uma demanda plenária, de modo que é muito freqüente suceder que uma ação desta espécie tenha uma duração de vários anos, durante os quais o proprietário-depositante ver-se-á, sem remédio e sem consolo, privado da utilização do bem que lhe pertence e que fora entregue ao depositário apenas para guarda e nem mesmo para o uso. Neste caso, nosso direito prefere sacrificar o demandante, em homenagem ao princípio da segurança máxima do resultado, impedindo que o juiz lhe conceda a posse provisória do bem que lhe pertence, mesmo que o índice de verossimilhança de seu direito alcance um grau tão elevado que a probabilidade de sua vitória final seja inquestionável” (Ovídio Baptista da Silva, “A ‘plenitude de defesa’ no processo civil”, in *As garantias do cidadão na justiça*, São Paulo: Saraiva, 1993, p. 160).

Por outro lado, um processo que se alonga no tempo além do necessário representa um custo altíssimo para a administração da justiça. Quanto maior é o número de casos de abuso de direito de defesa, maior é o número de processos em desenvolvimento e, assim, o número de juízes e funcionários envolvidos, e, conseqüentemente, o congestionamento e a morosidade da “justiça”. Além disso, não é possível esquecer que a demora pode afetar a qualidade do serviço do juiz, já que as possibilidades de erro se multiplicam rapidamente na medida em que transcorre o tempo entre a ocorrência do fato a ser investigado em juízo e a sua declaração através da sentença. Lembram Rafael Bielsa e Eduardo Graña que “la Corte Suprema de los Estados Unidos ha señalado – hace ya algunos años – que la demora no sólo perjudica al afectado, sino que también dificulta la administración de justicia en sí misma, ya que no se posterga únicamente la rectificación del daño o la reivindicación de la persona injustamente acusada, sino que – además – se colman de causas los tribunales, se aumentan los costos para todos los litigantes, se obliga a los jueces a simplificar, y se interfiere con la pronta decisión de aquellos litigios en los que todas las partes muestran la debida diligencia y preparación para el juicio, viéndose todo el proceso recargado por la falta de



organización y de solución a los problemas” (Rafael A. Bielsa e Eduardo R. Graña, “El tiempo y el proceso”, Revista del Colegio de Abogados de La Plata, v. 55, p. 200-201).

---

100

“L’interesse di urgenza, supponendo costante la sua entità quantitativa, acquista una rilevanza complessiva tanto più grande quanto maggiore è la probabilità che il successivo giudicato conduca ad un accertamento positivo del diritto dell’attore; analogamente, l’interesse alla completa cognizione, supponendo costante la sua entità quantitativa, acquista una rilevanza complessiva tanto più grande quanto maggiore è la probabilità che il successivo giudicato conduca ad un accertamento negativo della situazione sostanziale controversa” (Italo Andolina, *Cognizione ed esecuzione forzata nel sistema della tutela giurisdizionale*, Milano: Giuffrè. 1983, p. 36-37).

---

101

Carlo Furno, *Teoría de la prueba legal*, p. 190.

---

102

“Il terzo libro del Codice di Procedura Civile è legato alla filosofia del titolo esecutivo. È una filosofia dai contorni incerti come tutte le filosofie. Di essa può peraltro con facilità cogliersi il nucleo essenziale nell’esigenza che l’esecuzione abbia di mira un assetto stabile delle situazioni materiali e non un qualcosa di provvisorio e/o di strumentale e caducabile” (Giovanni Verde, “L’attuazione della tutela d’urgenza”, in *La tutela d’urgenza*, p. 81).

---

103

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil*, v. 1, p. 235.

---

104

Ver Luiz Guilherme Marinoni, *A antecipação da tutela*, 12ª ed., p. 139 e ss.

---

105

Ovídio Baptista da Silva, “Tutela antecipatória e juízos de verossimilhança”, in *O processo civil contemporâneo* (coordenado por Luiz Guilherme Marinoni), Curitiba: Juruá, 1994, p. 127-128.

---

106

Ver Loïc Cadiet, Jacques Normand, Soraya Mekki Amrani, *Théorie générale du procès*, Paris: Presses Universitaires de France, 2010.

---

107

“Quelles sont les conditions exigées? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la condition d’urgence n’est pas requise. La seule et unique condition exigée est que “l’obligation ne soit pas sérieusement

contestable” (articles 771 et 809 nouv. c. pr. civ.). Cette condition fondamentale, que le juge doit constater, est extrêmement difficile à définir de façon abstraite. Il est certain que le juge ne peut exiger une incontestabilité absolue, sous peine de restreindre abusivement le domaine du référé-provision” (Roger Perrot, “Les mesures provisoires en droit français”, p. 164).

---

108

Para uma visão geral da tutela provisória no Código de 2015, ver André Luiz Bauml Tesser, As diferenças entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela no CPC/2015, Coletânea Novo CPC: Doutrina Seleccionada, vol. 4, Salvador: Juspodivm, 2015, p. 23 ss; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Tutela provisória, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016; Cândido Rangel Dinamarco, O novo Código de Processo Civil brasileiro e a ordem processual civil vigente, Revista de Processo, v. 247; Artur César de Souza, Análise da tutela antecipada prevista no relatório final da câmara dos deputados em relação ao novo CPC, Revista de Processo, v. 235; José Roberto dos Santos Bedaque, Tutela provisória: considerações gerais, O novo Código de Processo Civil. Questões controvertidas, São Paulo: Gen-Atlas, 2015, p. 253 ss.; Paulo Henrique dos Santos Lucon, Tutela provisória e julgamento parcial no CPC de 2015: avanços e perspectivas, O novo Código de Processo Civil. Questões controvertidas, p. 325 ss.

---

109

Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 40-41.

---

110

Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 39.

---

111

Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 40-41.

---

112

Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 42-44. Ver, reafirmando expressamente esta posição, Carlo Furno, La sospensione del processo esecutivo, p. 55; Giuseppe Vignera, Sui rapporti tra provvedimento d'urgenza e sentenza di merito (alla ricerca di una soluzione ragionevole), Rivista di Diritto Processuale, 1993, p. 514.

---

113

Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 43-44.

---

114

Adolfo Perez Gordo, La ejecución provisional en el proceso civil, p. 42.

---

115

Referindo-se à “ordinanza di ingiunzione” (art. 186-ter do CPC italiano), demonstra Gabriella Rampazzi que o juiz deve “dichiarare l’ordinanza provvisoriamente esecutiva se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario e circolare, certificato di liquidazione di borza o su atto ricevuto da notaio od altro pubblico ufficiale autorizzato; ha, invece, un potere discrezionale di concederla qualora vi sia pericolo di grave pregiudizio per il creditore nel ritardare l’inizio delle procedure esecutive, nonché, per la sola ipotesi di debitore costituito, se le sue difese non sono fondate su prova scritta o di pronta soluzione” (Gabriella Rampazzi, *Le riforme del processo civile* (a cura di Sergio Chiarloni), Bologna: Zanichelli, 1992, p. 254).

---

116

Ver Achille Saletti, *Le riforme del codice di rito in materia di esecuzione forzata e di attuazione delle misure cautelari*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1992, p. 458 e ss; Bruno Capponi, *Sull’esecuzione-attuazione dei provvedimenti d’urgenza per condanna al pagamento di somme*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1989, p. 88 e ss; Giampiero Rossiello, *Tema di esecuzione di provvedimenti d’urgenza recanti l’ordine di corrispondere somme di denaro*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1987, p. 1.046 e ss; Pasquale Frisina, *La tutela cautelare d’urgenza dei diritti a prestazione pecuniarie*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1986, p. 972 e ss.

---

117

Sobre a tutela antecipada de pagamento de soma fundada em abuso de direito de defesa, ver Luiz Guilherme Marinoni, *Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda*, 2a. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

---

118

Como escreve Ovídio Baptista da Silva, “se tivermos nossa visão voltada exclusivamente para o plano das normas jurídicas, sem qualquer preocupação com o que acontece no mundo da realidade, talvez possamos dizer que a satisfação obtida pelo credor que logre receber os alimentos sob forma de provisionais poderá ser uma satisfação diversa da que ele próprio obteria se o juiz do processo de conhecimento o declarasse, em sentença, verdadeiro credor dos alimentos definitivos. Se, no entanto, examinarmos a questão sobre outro ângulo para determinar se os provisionais apenas asseguram ou, ao contrário, satisfazem – ainda que provisoriamente – a pretensão alimentar, veremos que o uso que o credor irá fazer da pensão, tanto provisional quanto definitiva, será rigorosamente o mesmo. A contraposição entre alimentos provisórios e alimentos definitivos dá-se exclusivamente no plano lógico das normas jurídicas. O que são provisórios ou definitivos não são os alimentos, mas os respectivos provimentos judiciais” (Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, v. 3, p. 23).

---

119

Giovanni Verde, *L’attuazione della tutela d’urgenza*, p. 92.

---

120

Piero Calamandrei, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*.

---

121

Trata-se de obra publicada em 1983 pela CEDAM. Tommaseo, ao referir-se à possibilidade de se imprimir aos provvedimenti d'urgenza um conteúdo antecipatório, afirma que, neste caso – ao contrário do que ocorre quando se trata “di prevenire con la misura cautelare il danno ulteriore che può derivare dal verificarsi, nelle more del processo, di fatti lesivi del diritto controverso” –, importa “contenere il pregiudizio che il perdurare di una situazione antigiusdica provoca al titolare del diritto” (Ferruccio Tommaseo, I provvedimenti d'urgenza – Struttura e limiti della tutela anticipatoria, Padova: CEDAM. 1983, p. 135).

---

122

Ver adiante os comentários ao art. 304, item 7, “Inexistência de tutela antecipada declaratória e constitutiva”.

---

123

Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 29 e ss.

---

124

Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, p. 38.

---

125

Ver Luiz Guilherme Marinoni, A Antecipação da tutela, 12ª ed., 59-71.

---

126

Vittorio Denti, Intervento. La tutela d'urgenza, p. 171.

---

127

Não há mais como sustentar a natureza cautelar da tutela antecipatória, supondo que a satisfação de um direito com base em cognição sumária não importa, sendo relevantes apenas as clássicas ideias de que somente a sentença – e não a decisão que concede a tutela antecipatória – é capaz de compor a lide (Carnelutti) ou pode significar atuação concreta do direito (Chiovenda). Ora, ninguém nega que, na dimensão das teorias de Carnelutti e Chiovenda, a decisão fundada em cognição sumária não pode compor a lide ou atuar o direito, mas apenas contribuir para a composição da lide (Carnelutti fala em composição provisória da lide) ou para a atuação concreta do direito. Porém, deixando-se tais teorias e os critérios que as caracterizam e voltando-se para a teoria da tutela dos direitos, resta claro que há diferença entre decisão (técnica processual) e tutela do direito e, por maior razão, entre provisoriedade da decisão e tutela do direito com base em cognição sumária.

---

128

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

---

129

“I provvedimenti cautelari sono destinati a durare per un tempo limitato. Infatti quando il processo principale giunge a conclusione, viene meno il problema stesso per cui furono concesso: o il diritto è stato riconosciuto esistente, e potrà ricevere piena soddisfazione; oppure è stato dichiarato inesistente e la misura cautelare dovrà essere revocata” (Enrico Tullio Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano: Giuffrè, 1984, v. 1, p. 93).

---

130

Veja-se, neste sentido, a posição de Ovídio Baptista da Silva: “Não se leva em consideração a circunstância de que a revogação prematura do provimento liminar, ou mesmo da medida cautelar concedida em sentença final cautelar, deixará o direito litigioso sem qualquer proteção assegurativa durante a tramitação dos recursos, em muitos casos extremamente demorada, de tal modo que a reforma da sentença, nos graus superiores de jurisdição, poderia deparar-se com uma situação de prejuízo irremediável ao direito somente agora reconhecido em grau de recurso. Para que situações desta espécie sejam evitadas, recomenda-se que o magistrado – sensível às circunstâncias especiais do caso concreto – disponha, em sua sentença contrária à parte que obtivera a provisional, que esta medida liminar, não obstante a natureza do julgamento posterior divergente, conserve-se eficaz até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida no juízo do recurso. Esta parece ser a tendência contemporânea da doutrina italiana (...)” (Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, v. 3, p. 124).

---

131

Ver Donaldo Armelin, A tutela jurisdicional cautelar, *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo*, v. 23, p. 123.

---

132

Crisanto Mandrioli, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano: Giuffrè, 1953, p. 23.

---

133

Vittorio Denti, Il processo di cognizione nella storia delle riforme, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1993, p. 808.

---

134

Luiz Guilherme Marinoni, L'insufficienza di tutela normativa al diritto fondamentale di azione, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2015, p. 915 e ss.

---

135

Lembre-se que a multa pode ser imposta contra a pessoa física investida de autoridade para representar o Poder Público. Como já dito, “o problema da efetividade do uso da multa em relação ao Poder Público repousa na sua própria natureza. Se a multa tem por meta compelir o réu a cumprir, é evidente que a sua

efetividade depende da sua capacidade de intimidação e, assim, somente pode incidir sobre uma vontade. Caso a multa incida sobre a pessoa jurídica de direito público, apenas o seu patrimônio poderá responder pelo não cumprimento da decisão. Entretanto, não há cabimento na multa recair sobre o patrimônio da pessoa jurídica se a vontade responsável pelo não cumprimento da decisão é exteriorizada por determinado agente público. Se a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, é lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional. Não há procedência no argumento de que a autoridade pública não pode ser obrigada a pagar a multa derivada de ação em que foi parte apenas a pessoa jurídica. É que essa multa somente constituirá sanção pecuniária, e assim poderá ser cobrada, quando a autoridade pública, que exterioriza a vontade da pessoa jurídica, não der atendimento à decisão. Note-se que a cobrança da multa não tem relação com o fato de o inadimplente ser ou não parte, mas com a circunstância de o inadimplente ser o responsável pelo cumprimento da decisão. Não se está exigindo nada da autoridade em virtude do que foi discutido no processo. Portanto, a tese que sustenta que a multa não pode recair sobre a autoridade somente poderia ser aceita se partisse da premissa – completamente absurda – de que o Poder Público pode descumprir decisão judicial em nome do interesse público” (Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual e Tutela dos Direitos, p. 487-488).

---

136

A respeito da antecipação do pagamento de soma em dinheiro no direito italiano, ver Giampiero Rossiello, tema di esecuzione di provvedimenti d’urgenza recanti l’ordine di corrispondere somme di denaro, p. 1.046 e ss; Pasquale Frisina, La tutela cautelare d’urgenza dei diritti a prestazioni pecuniarie, Rivista di diritto processuale, 1986, p. 972 e ss; Bruno Capponi, Sull’esecuzione-attuazione dei provvedimenti d’urgenza per condanna al pagamento di somme, p. 88 e ss.

---

137

Pontes de Miranda sustentou que a proibição da Constituição estaria na prisão por não contestação de dívida pecuniária e que, por isso, seria possível utilizar a prisão como meio coercitivo (Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, t. 5, p. 253).

---

138

Ver Sérgio Arenhart, A tutela inibitória coletiva, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 270; Marcelo Lima Guerra, Execução indireta, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 245 e ss.

---

139

Ver Marcelo Lima Guerra, Execução indireta, p. 245-246.

---

140

“Quanto à prisão para cumprimento de ordem judicial, não tem caráter obrigacional. Ao contrário, deriva do imperium estatal e tem por fim resguardar a dignidade da justiça. Enfim, encontra apoio na regra do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, no que pertine à garantia de um provimento jurisdicional útil. Isto porque, em tese, pode haver situações em que a única forma de se obter provimento jurisdicional capaz de ser eficaz no caso concreto será contando com a colaboração do réu (sujeito a uma ordem



judicial); e, também, não é difícil imaginar hipóteses (especialmente em sede de tutela inibitória) em que a imposição de astreintes ou de outra medida de apoio, que não a prisão civil, seja totalmente inadequada para garantir o cumprimento da determinação. Para estes casos, então, será legítima a imposição da prisão civil como meio coercitivo, sem que se vislumbre qualquer óbice a isto na regra constitucional do art. 5º, LXVII (ou mesmo nos textos das convenções inicialmente mencionadas)” (Sérgio Cruz Arenhart, A tutela inibitória coletiva, p. 270); “Encarada a prisão como um importante meio de concretização do direito fundamental à tutela efetiva e não apenas como uma odiosa lesão ao direito de liberdade, uma exegese que restrinja a vedação do inc. LXVII do art. 5º da CF aos casos de prisão por dívida em sentido estrito preserva substancialmente a garantia que essa vedação representa, sem eliminar totalmente as possibilidades de se empregar a prisão civil como medida coercitiva para assegurar a prestação efetiva da tutela jurisdicional” (Marcelo Lima Guerra, Execução indireta, p. 245-246); “A constituição garante ao cidadão comum o direito de não perder a liberdade caso não disponha de patrimônio suficiente para saldar sua dívida. A interpretação do dispositivo constitucional deve ser restrita, a fim de não acobertar a falácia de outro, que, a despeito de não possuir nenhum patrimônio, pode e tem todas as condições de, por exemplo, cumprir a ordem judicial de separação de corpos e não voltar ao lar conjugal” (Milena de Oliveira Guimarães, O contempt of Court e a efetividade da tutela executiva. Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 2003; orientação: Professor Donaldo Armelin).

---

141

Ver José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional, Coimbra: Almedina, 1993 e Jorge Miranda, Manual de direito constitucional. t. II, Coimbra: Coimbra Editora, 1983.

---

142

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o Ilícito; Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitoria.

---

143

Como observou Milena de Oliveira Guimarães, “pode ocorrer uma sanção coercitiva por ‘civil contempt’ no caso de desobediência à ordem de praticar determinado ato, ou seja, o ‘contemnor’ deve permanecer preso até que cumpra a ordem” e “uma prisão punitiva por ‘civil contempt’ pode ocorrer no caso de o sujeito deixar de cumprir ordem judicial de se abster de praticar determinado ato, como, por exemplo, uma ordem de não molestar o peticionário” (Milena de Oliveira Guimarães. O contempt of Court e a efetividade da tutela executiva). Portanto, não há dúvida que a prisão por civil contempt pode configurar, no caso de obrigação de não fazer, uma ameaça para que a parte não pratique um ato e uma punição pela sua eventual prática, embora essa punição não confira caráter criminal ao contempt. Em ambas as situações há um civil contempt.

---

144

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, São Paulo: Saraiva, 1968, p. 58.

---

145

Alcides de Mendonça Lima, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 6, t. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 434.

---

146

“A execução por quantia certa não pode chegar até a arrematação, podendo, no máximo, ir até a penhora, como medida de cautela, a favor do credor” (Alcides de Mendonça Lima, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 444).

---

147

Com base no § 940 da ZPO alemã, Jauernig, “Der zulässige Inhalteinstweiliger Verfügungen”, ZZP, 1966, p. 303 e ss.

---

148

Há julgado, na Itália, admitindo com base no art. 700 do Código de Processo Civil, antecipação de pagamento de soma em dinheiro em favor de um hospital que necessitava imediatamente da soma para não interromper as suas atividades (Pret. Roma, 15.12.82, Temi Romana, 1982, p. 637). Também há julgado admitindo a antecipação para evitar a falência de uma empresa que necessitava de soma devida pelo Município de Roma e que trabalhava quase exclusivamente para ele, o seu devedor “di gran lunga principale”. (Pret. Roma, 31.7.86, Giustizia Civile, 1986, I, p. 2.583). Ver Arnaldo Miglino, La tutela giurisdizionale anticipatoria, Roma, 1986, p. 198).

---

149

Arnaldo Miglino, La tutela giurisdizionale anticipatoria, p. 196 e ss.

---

150

Antônio Cláudio da Costa Machado, “Observações sobre a natureza cautelar da tutela antecipatória do art. 273, I, do CPC”, in Salvio de Figueiredo Teixeira (coord.). Reforma do Código de Processo Civil, São Paulo: Sariva, 1996, p. 182.

---

151

“Para os luminares mestres italianos, a execução que se processasse antes da declaração definitiva do direito seria cautelar (!) pelo simples fato de que ainda não existia o título judicial ou a sentença prolatada com juízo de certeza. Não compreendiam os doutos mestres italianos e a doutrina tradicional que o que se tutela e satisfaz é a realização do direito, não sua existência normativa e abstrata do mundo meramente jurídico, mas sim na sua realização no mundo da realidade social e histórica, no plano da vida real. A dificuldade de se admitir a satisfação provisória de direitos resulta de um comprometimento ideológico e conceitual advindo da concepção inicial e tradicional do direito processual moderno calcada no liberalismo puro” (Jorge Pinheiro Castelo, Tutela antecipada, v. 1, São Paulo: LTR. p. 175).

---

152

Michele Taruffo, Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione, Rivista Critica del Diritto Privato, 1986, p. 668.

---

Lembre-se que, justamente na Itália, onde a doutrina ainda se mantém presa ao velho, inefetivo e ideologicamente superado esquema da correlação necessária entre a condenação e a execução forçada – assim, por exemplo Crisanto Mandrioli, *Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1976 – propõe-se algo similar há muito tempo. Registre-se a ideia de Taruffo: “Não se exclua, em outros termos, a eventualidade de medidas de coerção indireta, cumuláveis com a possibilidade da execução direta, dirigidas a provocar o adimplemento espontâneo. Não se trata, como é óbvio, de evocar o fantasma da prisão por dívida, mas de considerar se a ameaça de uma sanção (ainda que apenas de caráter pecuniário, segundo o modelo da astreinte) pode ter efetividade para induzir ao adimplemento, com isto evitando o recurso à execução forçada. A possibilidade de obter o adimplemento, evitando assim as complicações, os custos e os riscos de ineficácia inerentes à execução por expropriação, constitui a razão de fundo que deverá animar a que se percorra de forma decisiva o caminho da introdução de adequadas medidas coercitivas, ainda que destinadas a garantir a efetividade das sentenças que condenam ao pagamento de dinheiro” (Michele Taruffo, *Note sul diritto alla condanna e all’esecuzione*, p. 668).

Ver, longamente, Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*, p. 459-476. Reafirmando a tese diante do novo CPC, ver Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, v. 2, 2a. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016; Marinoni, Arenhart, Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil Comentado*, 2a. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

Luigi Montesano, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, *Trattato di diritto civile italiano*, Torino: UTET, 1994, v. 14, t. IV, p. 257.

“Se si parla di un *référé provision* – istituto, come è stato illustrato, di larghissimo sviluppo in Francia, e di controversa applicazione in Belgio – o di quelle provvisorie per ordinanza che fanno capolino nella legislazione italiana, in materie determinate, con varietà di fortuna (con ampia applicazione nella materia dell’assicurazione della responsabilità civile automobilistica, e con minore successo nel processo del lavoro), ma costituiscono, comunque, una linea di tendenza, o se si parla di una *Befriedigungs o Leistungsverfügung*, che ha pure per oggetto la condanna provvisoria, per via di anticipazione, al pagamento di una somma di denaro, è vero che la possibilità, per il condannato, di ottenere la restituzione, e il risarcimento dei danni, se ne è il caso, qualora la causa si concluda poi in senso a lui favorevole, è sovente del tutto teorica, ma, tuttavia, essa esiste. Non si può dire che il *préjudice au principal*, sotto il punto di vista della realizzabilità della sentenza sul merito, sia inevitabile. Il giudice di merito non è spogliato della sua essenziale funzione di *dicere jus*, *de dire droit*, nello specifico senso che l’esecuzione della sua pronuncia non è irrimediabilmente impedita” (Giuseppe Tarzia, “Considerazioni conclusive”, p. 316).

158

*Revista dos Tribunais*, v. 598, p. 177.

---

159

Federico Carpi, Provvedimenti interinali di condanna, esecutorietà e tuteladelle parti, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1977, p. 621.

---

160

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 189-190.

---

161

O Tribunal do Paraná, em acórdão brilhante, assim decidiu após a introdução da tutela antecipada no código de 1973: “Tutela antecipada. Ação de reparação de danos por acidente de veículos. Contrato de transporte. Ônibus. Responsabilidade objetiva. Convencimento da verossimilhança da alegação. Prova documental idônea. Autora hipossuficiente. Princípios da necessidade e da efetividade do processo. Condenação provisória no pagamento de um salário mínimo mensal. Admissibilidade. Requisitos do art. 273 do CPC configurados. Concessão. Agravo de instrumento. Decisão reformada. Recurso provido. A agravante provou que viajava de passageira em ônibus da ré; que sofreu acidente e lesões na coluna, encontrando-se incapacitada para o trabalho de doméstica. Daí decorre o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porque a agravante e sua família enquanto em curso os processos poderão passar privações. Na antecipação da tutela impõe-se ao julgador fazer uma análise dos valores jurídicos colocados em julgamento na demanda. No caso, encontra-se de um lado uma vítima pobre e impossibilitada de trabalhar e, de outro lado, uma empresa que explora a concessão de serviço público, um dos mais rentáveis, ou seja, o transporte público. Deve o juiz estar atento aos princípios da necessidade e ao da efetividade do processo” (*Revista de Direito Processual Civil (Genesis)*, v. 2, p. 488 e ss). O extinto 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, seguindo esta mesma orientação, igualmente admitiu a tutela antecipada de pagamento de soma em ação de indenização por acidente de veículos: “Tutela antecipada – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Colisão de veículos – Vítima fatal – Pretensão ao recebimento de alimentos provisoriais pela autora grávida, esposa do de cujus – Caracterização da verossimilhança das alegações cujo conceito é diverso daquele de certeza – Confirmação do receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face da condição pessoal da autora – Art. 273 do Código de Processo Civil – Alimentos provisionais concedidos – Recurso improvido” (1º. TACSP, AI 638.219, 4ª C. Civ, rel. Juiz Franco de Godoi) Estes acórdãos, que revelam grande sensibilidade jurídico-social, ainda servem de paradigma para as decisões que envolvem tutela antecipada de soma em ação de reparação de danos.

---

162

Luiz Guilherme Marinoni, *A antecipação da Tutela*, 1ª. ed., São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 1994, p. 122 e ss.

---

RT 646/124. O mesmo entendimento é adotado por Willard de Castro Villar: “As demais formas de alimentos previstos em testamentos (legados) ou provindos de ato ilícito não podem estar protegidas pelos meios coativos previstos neste capítulo, uma vez que se permitiria a prisão do devedor por dívidas, e não foi esse o espírito da lei” (Processo de execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 267). Contra Araken de Assis, “o verdadeiro espírito da lei é o de franquear meios executórios mais lesto e eficazes aos alimentários em geral, deixando de discriminá-los em razão da fonte da obrigação alimentar” (Execução de alimentos e prisão do devedor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 111).

“Contra o meio executório da coação pessoal se opõe tenazmente a força do preconceito, ignoradas a utilidade e a natureza do mecanismo. Entretanto, o estudo científico dos meios executórios, avaliados e pesados como expedientes práticos, predispostos com o único propósito de realizar as operações materiais destinadas ao implemento executivo da eficácia sentencial condenatória, revela a verdade. A prisão civil do alimentante não, merece a pátina de coisa obsoleta, entulho autoritário e violento só a custo tolerado e admitido no ordenamento jurídico contemporâneo. Em nome da ideologia liberal, preocupada em preservar o princípio da intangibilidade física, ainda que provoque a dor, a penúria e mesmo a morte do alimentário, avalia-se desfavoravelmente o aprisionamento do executado” (Araken de Assis, Execução de alimentos e prisão do devedor, p. 120-121).

Quando se pensa no meio executivo capaz de garantir a efetividade da tutela do direito não é possível esquecer da esfera jurídica do réu. Se o juiz deve eleger o meio executivo idôneo à tutela jurisdicional, não é possível admitir que esta eleição possa prejudicar o demandado. Isso quer dizer que a utilização do meio executivo, diante de uma cláusula geral executiva, tem a sua legitimitade condicionada a uma prévia análise, que considera tanto o direito do autor quanto o direito do réu. Essa análise deve ser feita a partir da regra da proporcionalidade, mais precisamente com base na sub-regra da necessidade, que se desdobra em regra do meio idôneo e regra da menor restrição possível. É claro que, antes de tudo, o meio executivo deve ser idôneo à tutela do direito. Porém, quando dois meios se mostram a princípio igualmente idôneos, só o uso do meio que causa menor restrição possível não viola a regra da proporcionalidade.

“A proteção imediata do direito que se mostre ao magistrado apenas como plausível poderá evidenciar-se, depois, como uma solução injusta e violadora do verdadeiro direito daquele contra quem fora ela consumada. A renúncia a essa forma arriscada de proteção da aparência, no entanto, não isentará o Estado de cometer igualmente injustiças contra o litigante que realmente tenha direito. Lá, a injustiça será determinada pela pressa com que se teve como verdadeiro aquilo que se mostrava apenas provável; aqui, a injustiça decorrerá da mora do juízo, do inevitável atraso em prover, em favor do titular do direito, que só o teve reconhecido pelo juiz tardiamente (...)” (Ovídio Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, v. 3, p. 103-104).

---

170

Luiz Guilherme Marinoni, A antecipação da Tutela, 11a. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 234.

---

171

Habscheid, referindo-se às hipóteses — encontradas no direito alemão — em que é declarada a inexistência do direito do autor (após o seu pagamento) e o réu constata que o seu direito as perdas e danos não tem valor real — porque o autor não tem patrimônio suficiente —, indaga se o Estado deveria indenizar esse cidadão que foi obrigado a sacrificar o seu patrimônio pelo bem comum (Walther Habscheid, *Les mesures provisoires en procédure civile: droits allemand et suisse*, p. 47).

---

172

Ver Walther Habscheid, *Les mesures provisoires en procédure civile: droits allemand et suisse*, p. 45.

---

173

“O ‘devido processo legal’ é um privilégio processual reconhecido apenas aos demandados? Ou, ao contrário, também os autores terão direito a um processo igualmente ‘devido’, capaz de assegurar-lhes a real e efetiva realização prática – não apenas teórica – de suas pretensões? Um processo capenga, interminável em sua exasperante morosidade, deve ser reconhecido como um ‘devido processo legal’, ao autor que somente depois de vários anos logre uma sentença favorável, enquanto se assegura ao réu, sem direito nem mesmo verossímil, que demanda em procedimento ordinário, o ‘devido processo legal’, com ‘plenitude de defesa?’” (Ovídio Baptista da Silva, *A ‘plenitude de defesa’ no processo civil*, p. 154).

---

174

Sobre os princípios da menor restrição possível e do meio mais idôneo, Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 236-239.

---

175

Como a garantia constitucional de acesso à justiça incide sobre a estrutura técnica do processo de iure condendo e de iure conditio, é dever do processualista extrair das normas uma interpretação que permita a construção de um “processo justo”, isto é, de um processo que atenda aos valores constitucionais em uma perspectiva concreta e não meramente formal.



176

Ver adiante comentários ao art. 300.

---

177

Clito Fornaciari Júnior, O destinatário da norma do art. 686, n. V, do Código de Processo Civil [1973], Revista de Processo, v. 6, p. 122.

---

178

Sobre o tema do controle da racionalidade da decisão, ver Michele Taruffo, “Il controllo di razionalità della decisione fra logica, retorica e dialettica”.

---

179

Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Revista de Direito Processual Civil (Genesis), v. 30, p. 392 e ss.

---

180

Ver Salvatore Patti, Prove. Disposizioni Generali, Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro Italiano, 1987, p. 223 e ss.

---

181

Ver Michele Taruffo, “Funzione della prova: la funzione dimostrativa”, Rivista di Diritto Processuale, 1997, p. 568 e ss.

---

182

Michele Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano: Giuffrè, 1992, p. 295.

---

183

Michele Taruffo, La prova dei fatti giuridici, p. 295.

---

184

Sobre a distinção entre o raciocínio decisório e o raciocínio justificativo, ver Michele Taruffo, Cinco lecciones mexicanas, México: Escuela Judicial Electoral, 2003, p. 1 e ss.

---

185

Ver Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o Ilícito; Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva*.

---

186

No que concerne à diferença entre probabilidade de ato contrário ao direito e probabilidade de dano, é conveniente esclarecer mediante um exemplo: em ação inibitória voltada a impedir a repetição do uso de marca comercial, é suficiente, para a concessão da tutela antecipatória, a convicção de verossimilhança de que o réu utilizou indevidamente a marca comercial de titularidade do autor. É claro que o juiz deve referir a prova que lhe convence do uso indevido da marca – ainda que na dimensão da verossimilhança –, além de ter que explicar a razão pela qual lhe parece verossímil que o réu volte a utilizá-la antes do encerramento do processo. Porém, o autor sequer precisa aludir ao fato de que o uso indevido da marca pode gerar dano; basta a probabilidade da repetição desse uso. Ver Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela contra o Ilícito*.

---

187

De acordo e citando o livro “Técnica Processual e Tutela dos Direitos” (Marinoni), ver Cécile Chainais, *La protection juridictionnelle provisoire dans le procès civil en droits français et italien*, Paris: Dalloz, 2007, p. 774.

---

188

Ver Ferruccio Tommaseo, “Intervento”, p. 307.

---

189

Não que a caução não possa ser exigida quando o direito do autor for provável.

---

190

“È noto che il linguaggio delle norme è spesso di carattere valutativo (non solo quando esse enunciano principi generali o concetti indeterminati), e che di conseguenza scelte di carattere assiologico sono inevitabili e frequenti nel ragionamento che il giudice svolge intorno alle norme che applica. In ciò non vi è nulla di strano o di patologico: occorre però che il giudice sia anzitutto consapevole delle proprie valutazioni (e non le scambi quindi per giudizi di fatto o per dati a priori), e che – essendone consapevole – ne fornisca giustificazioni adeguate, indicando il criterio valutativo che ritiene di dover applicare (eventualmente spiegando le ragioni di questa scelta), e specificando come tale criterio fonda e giustifica il giudizio di valore che egli ha formulato nel caso concreto”. (Michele Taruffo, *La motivazione della sentenza*, p. 687 e ss).

---

191

“Le teorie per cui i giudizi di valore sarebbero null’altro che reazioni soggettive non razionalizzabili hanno fatto il loro tempo, e soprattutto non sono applicabili alle valutazioni che il giudice formula in sede di decisione, poiché siffatta concezione delle scelte assiologiche non farebbe che legittimare l’arbitrio individuale del giudicante sottraendo il fondamento della decisione a qualunque sindacato esterno (...) Di conseguenza, poiché i giudizi di valore sono spesso essenziali e determinanti per l’interpretazione e l’applicazione di norme, va ribadita l’importanza fondamentale della giustificazione esplicita di tali giudizi nell’ambito della motivazione. Lo stesso principio vale – naturalmente – per le valutazioni che spesso hanno luogo nell’ambito dei giudizi sui fatti” (Michele Taruffo, *La motivazione della sentenza*,

p. 687 e ss).

---

192

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela cautelar e tutela antecipatória.

---

193

Na hipótese de agravo de instrumento, aplica-se o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

---

194

É interessante registrar a norma do art. 196 do Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Argentina): “Medida decretada por juez incompetente. Art. 196. Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente”.

---

195

Veja-se o que disse Alcides Munhoz da Cunha: “Diante disso, há que se ter em mente que em casos extremos, a incompetência relativa ou absoluta do juiz que decreta uma medida cautelar apresenta-se totalmente legítima, justificada por um estado de necessidade processual, o que impede a decretação de nulidade se reconhecido esse estado de necessidade ou, ainda que eventualmente fosse apenas relativa a necessidade, deve ser mantida a medida pelo órgão competente, se a providência cautelar revelou-se adequada ou se a medida puder ser eficientemente ajustada ao caso concreto, em face do princípio da fungibilidade ou variabilidade das medidas cautelares” (Comentários ao Código de Processo Civil, p. 610).

---

196

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil (Processo Cautelar), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v. 4, p. 120-122.

© desta edição [2018]

## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

### **LIVRO V - DA TUTELA PROVISÓRIA**

#### **TÍTULO II - DA TUTELA DE URGÊNCIA**

### **Título II - DA TUTELA DE URGÊNCIA**

#### **Capítulo I. Disposições Gerais**

**Art. 300.** A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

#### **Pressupostos das tutelas cautelar e antecipada**

##### **1. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo**

O legislador deixou de falar em “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” (art. 273, CPC/1973). Alude agora a perigo de dano e a risco ao resultado útil do processo. São expressões destituídas de exato conteúdo técnico-jurídico. Servem apenas para evidenciar que no curso do processo pode ocorrer gravame que ponha em risco i) a efetividade da tutela do direito (cautelar), ii) a situação objeto das tutelas declaratória e (des)constitutiva (cautelar), e iii) o direito que se pretende tutelar ou um direito a ele conexo (antecipada).

A tutela cautelar supõe que a situação tutelável ou a tutela devida ao direito material estejam expostas a perigo. É o que pode ocorrer, por exemplo, quando o executado passa a praticar atos que evidenciam intenção de tornar infrutífera a eventual e futura execução da sentença de condenação ao pagamento de soma. No caso, temendo o autor pela inefetividade da tutela final, poderá requerer tutela cautelar de arresto para que, em caso de reconhecimento do direito material, a tutela do crédito pecuniário tenha efetividade. Nesta situação, o perigo de dano se liga à inefetividade ou à inutilidade da tutela do direito almejada através da ação a ser proposta ou já em curso.

Suponha-se, agora, uma ação voltada a declarar que os bens de uma sociedade, acima de determinado valor, não podem ser alienados sem a concordância de todos os sócios. O rumor, no seio da sociedade, de que dois de seus administradores estão em vias de alienar um bem, representa perigo de dano à situação jurídica objeto da tutela declaratória, abrindo oportunidade à exigência de tutela de segurança (cautelar) do patrimônio social.

O perigo de dano também pode legitimar a tutela antecipada. Assim, admite-se a antecipação da tutela para evitar dano ao bem que se pretende ver entregue ao final do processo. Porém, a tutela antecipada é imprescindível sobretudo para evitar dano a direito conexo ao direito objeto da tutela final e, ainda, para evitar a prática de ato contrário ao direito ou a prorrogação dos efeitos concretos de uma conduta ilícita. Nesta última hipótese, como obviamente não há perigo de dano, mas da prática de ato contrário ao direito ou da prorrogação dos seus efeitos concretos, cabe aludir risco ao resultado útil do processo – embora se saiba que o legislador, referindo-se a perigo

de dano, certamente não quis excluir o perigo de ilícito.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar fundado em elementos objetivos, capazes de serem expostos de forma racional, e não em meras conjecturas de ordem subjetiva. De qualquer modo, basta evidenciar a probabilidade da ocorrência do dano ou do ato contrário ao direito, demonstrando-se circunstâncias que indiquem uma situação de perigo capaz de fazer surgir dano ou ilícito no curso do processo.

## **2. Perigo de ato contrário ao direito e da prorrogação dos efeitos concretos da conduta ilícita**

A tutela inibitória antecipada não tem como pressuposto perigo de dano. A tutela inibitória antecipada tem como pressuposto perigo de prática, repetição ou continuação de ato contrário ao direito no curso do processo. Lembre-se que o dano é consequência meramente eventual do ato contrário ao direito que a tutela inibitória objetiva impedir.<sup>1</sup>

No caso em que o ato contrário ao direito ainda não foi praticado, devem estar presentes elementos ou circunstâncias de fato que permitam ao juiz concluir, ainda que com base em probabilidade, que o ilícito é iminente.<sup>2</sup> Quando o ato contrário ao direito já foi praticado, da sua modalidade e da sua natureza é possível inferir com notável aproximação a probabilidade da sua continuação ou repetição no futuro.<sup>3</sup> Em outras palavras, nos casos em que o comportamento ilícito se caracteriza como atividade de natureza continuativa – poluição ambiental – ou como pluralidade de atos suscetíveis de repetição – atos de concorrência desleal ou difusão de notícias lesivas à personalidade individual –, é mais fácil a constatação do perigo de ilícito.<sup>4</sup>

Há necessidade de tutela de remoção do ilícito quando é violada uma norma de direito material e os efeitos concretos da transgressão se perpetuam no tempo. É o caso, por exemplo, da exposição à venda de produto nocivo à saúde do consumidor. Nessa hipótese, tanto a tutela final, quanto a tutela antecipada, tomam em consideração um ilícito que já ocorreu. Para a tutela antecipada é suficiente a probabilidade da ocorrência do ilícito, sendo desnecessário demonstrar a probabilidade de ilícito futuro e, muito menos, a probabilidade de dano. É que a probabilidade da ocorrência do ilícito configura, por si só, a abertura à possibilidade de danos, uma vez que a própria norma de proteção que se afirma violada, possui o objetivo de evitá-los. Assim, a probabilidade da violação da norma é o que basta para evidenciar o risco ao resultado útil do processo.

## **3. Perigo de dano a direito conexo ao direito à tutela final**

Há casos em que se pode temer um dano a direito conexo ao direito à tutela final. Recorde-se, por exemplo, que a vítima de acidente automobilístico que, em virtude do dano sofrido, fica impossibilitada de manter o seu próprio sustento, pode ter irreversivelmente prejudicado o seu direito à saúde. O direito à saúde é conexo ao direito ao ressarcimento do dano. Quando se presta imediatamente ressarcimento em pecúnia, ainda que em parte, antecipa-se a tutela ressarcitória para se evitar dano a direito conexo ao direito à tutela ressarcitória.<sup>5</sup>

A jurisprudência italiana, ao admitir a antecipação do pagamento de soma em dinheiro com base no art. 700 do seu Código de Processo Civil, em regra, alude à tutela de direitos constitucionalmente protegidos. Segundo Proto Pisani, o direito patrimonial com função não patrimonial, enquanto destinado a garantir a satisfação de uma necessidade primária ou de uma “situação de liberdade”, deve ser tutelável através da tutela sumária urgente.<sup>6</sup>

Nesses casos, o crédito pecuniário, embora ressarcindo antecipadamente o autor, realiza uma função não patrimonial, impedindo dano a um direito conexo ao direito à tutela ressarcitória. Note-se que a tutela antecipa o ressarcimento, ou seja, realiza antecipadamente esse direito, sem objetivar a sua segurança. O direito ao ressarcimento é antecipadamente realizado em razão de perigo de dano a um direito a ele conexo.

Para a valoração do perigo de dano é impossível a não consideração da situação concreta que

diz respeito à parte que pode ser prejudicada. Isso não significa uma “personalização” do prejuízo, mas apenas a necessidade do perigo de dano ser considerado em relação à pessoa que se diz titular do direito.<sup>7</sup>

Ainda que a antecipação de soma tenha por fim proteger direitos de conteúdo não patrimonial, excepcionalmente pode ser admissível quando o perigo ameaça direitos de natureza patrimonial. Nesses casos, a tutela antecipada somente pode ser concedida caso a violação ou dano objeto da tutela final constitua a causa do perigo de dano ao direito conexo, o que equivale a dizer que a tutela antecipada de soma não poderá ser deferida quando não houver uma relação clara de causa e efeito entre a demora na obtenção da tutela final e o dano temido.

#### **4. Probabilidade do direito**

Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou *fumus boni iuris*. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficiente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.

As tutelas antecipada e cautelar são incompatíveis com o aprofundamento do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.

O juízo de probabilidade é inerente à tutela de urgência. Se a tutela do direito não depende da elucidação de fatos ou se, para tanto, é desnecessária a produção de prova diversa da documental, o juiz – após ouvir o réu –, mais do que poder formar convicção de probabilidade, tem convicção que lhe permite decidir sobre a própria tutela final.

Fala-se que o juiz, ao formar convicção de probabilidade, funda-se em uma cognição sumária, que é uma cognição menos aprofundada em sentido vertical, constituindo uma etapa do caminho do magistrado rumo à cognição exauriente da matéria fática envolvida no litígio. O provimento jurisdicional baseado em cognição exauriente garante a realização plena do princípio do contraditório e, desta forma, aguarda o tempo necessário para que as partes apresentem alegações e produzam provas. Tal provimento não admite a postecipação da discussão do litígio e, por assim dizer, da busca da “verdade e da certeza”.

Mas se é indiscutível que a probabilidade é suficiente para a tutela de urgência, é indispensável perceber que a probabilidade se relaciona com os pressupostos da tutela que se pretende obter ao final. Ou seja, tanto para a tutela cautelar quanto para a tutela antecipada é imprescindível ter em consideração os verdadeiros pressupostos da tutela final – dano, inadimplemento, probabilidade de ilícito, ilícito já praticado etc. Embora isso seja óbvio, o certo é que as decisões judiciais costumam apenas afirmar que há probabilidade ou *fumus boni iuris* – sem invocar quaisquer pressupostos da tutela final.

Como é evidente, quando a norma se refere a “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, há de se ter presente a necessidade de tomar em conta as provas, presunções, regras de experiência e argumentos que evidenciam a probabilidade dos pressupostos para a tutela (final) do direito.

#### **5. Tutela de urgência antes da ouvida do réu**

De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”. Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar não podem privar-se da possibilidade de concessão antes da ouvida do demandado. Porém, como a tutela de urgência obviamente repercute sobre a esfera jurídica do réu, a sua concessão inaudita altera parte somente é possível quando há motivo suficiente para fazer o juiz crer que o adiamento do seu deferimento para depois do momento oportuno à defesa obstaculizará a tutela



do direito.

A efetividade da tutela de urgência pode exigir o adiamento ou a postecipação do contraditório e do esclarecimento dos fatos. Esta postecipação não é possível apenas quando o dano ou o ilícito podem ocorrer imediatamente ou antes da ouvida do réu, mas também quando, dando-se prazo para o réu se manifestar, haverá oportunidade para a frustração da própria finalidade da tutela (suspicio de dilapidatione bonorum seu de fuga), retirando-se a sua capacidade de atender ao fim almejado.<sup>8</sup> Nicolò Trocker reconhece que a validade destes motivos foi acolhida pelo Bundesverfassungsgericht alemão, mas que este advertiu que, por se tratar de interferência na esfera jurídica de alguém, a derrogação ao princípio geral da audiência prévia somente pode ser admitida quando resultar indispensável (unabweisbar) para o alcance da própria tutela.<sup>9</sup>

Realmente, a concessão da tutela de urgência antes da ouvida do réu é excepcional e assim deve ser tratada. É preciso atentar para o fato de que o deferimento da tutela inaudita altera parte restringe o direito fundamental de defesa e que isto apenas tem legitimidade quando o direito fundamental de ação, sem a emissão da tutela, não pode encontrar efetividade no caso concreto.<sup>10</sup>

Por outras palavras, a liminar *inaudita altera parte*, por implicar violação ao contraditório (que exige o direito de participar da formação da decisão judicial), situa-se no campo da colisão de garantias fundamentais. Por isso, sua outorga exige a devida ponderação de direitos fundamentais, a fim de justificar que o contraditório seja restringido em favor de outro valor também fundamental.

## **6. Justificação prévia para a concessão da tutela de urgência**

Mas a tutela de urgência também pode ser concedida antes da ouvida do réu mediante “justificação prévia”. Essa justificativa é adequada especialmente quando a ouvida do demandado pode tornar a tutela ineficaz.

Como o juiz, diante da urgência e da consequente necessidade da concessão da tutela de urgência antes da ouvida do réu é obrigado a formar a sua convicção apenas com base nos argumentos do autor, é natural que, em situações faticamente mais complexas e delicadas, tenha que exigir a justificação da situação fática que ampara o pedido de tutela de urgência.

Esta justificação, em princípio, é feita sem a presença do réu. Porém, como a tutela é concedida inaudita altera parte porque o prejuízo pode ocorrer durante o tempo necessário para a ouvida do réu ou porque este, ao ser citado, pode frustrar a sua efetividade, não há racionalidade em admitir tutela de urgência sem a ouvida do demandado quando há tempo para convocá-lo para participar da justificação e não há perigo de inutilização da efetividade da tutela. Portanto, apenas quando não há tempo para convocar o réu para a justificação prévia ou esta convocação possa permitir-lhe praticar ato capaz de frustrar a utilidade da tutela, é que se legitima a justificação sem a presença do réu.

Quanto à forma de participação do réu na justificação ou ao significado de ouvida do réu na justificação, é preciso estar atento à circunstância de a justificação prévia, ser ato mediante o qual, o juiz busca esclarecimento acerca da situação fática que ampara o pedido de tutela de urgência, constituindo espaço processual em que o autor deve demonstrar os pressupostos para obtê-la. Assim, o réu não tem oportunidade de apresentar defesa ou de produzir provas na justificação, embora tenha a possibilidade de contraditar as testemunhas e de impugnar a idoneidade do especialista – afirmando-o suspeito ou impedido –, assim como de formular perguntas às testemunhas e ao especialista com o objetivo de suprir omissões ou eliminar contradições eventualmente presentes nos depoimentos testemunhais e nos esclarecimentos técnicos.

## **7. Tutela de urgência na sentença**

A sentença produz efeitos na pendência da apelação quando, além de confirmar ou revogar a tutela provisória – cautelar, antecipada ou de evidência –, concede-a (art. 1.012, § 1.º, V). No Código de 1973, afirmava-se que a sentença tinha eficácia na pendência da apelação na hipótese de

confirmação da tutela antecipada (art. 520, VII, CPC/1973), porém nada se dizia a respeito da possibilidade da sua concessão apenas por ocasião da sentença.<sup>11</sup>

O Código de 2015, além de ter permitido a tutela de evidência na sentença<sup>12</sup>, atentou para a circunstância de que, após a formação de juízo apto a declarar a existência do direito, pode estar presente perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência na sentença. Não fosse assim, o juiz poderia negar a tutela urgente por falta de probabilidade do direito e, depois de realizada a instrução e convencido do direito e do perigo de dano, não ter possibilidade de concedê-la, o que obviamente não teria racionalidade.

## **8. Caução para a concessão da tutela de urgência**

De acordo com o art. 300, § 1.º, do Código de Processo Civil,

para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Note-se que esta caução é exigível para a concessão da tutela, ao contrário da caução do art. 520, IV, que é exigida para a sua execução. A caução do art. 300 pode ser exigida quando a tutela é concedida antes da ouvida do réu, depois da sua ouvida ou mesmo na sentença. O que legitima a exigência da caução não é a não ouvida do réu, ou a ausência de justificação, mas a circunstância de a decisão poder ser negada ou modificada.

O conteúdo da caução se liga ao dano que pode ser produzido pela efetivação da tutela cautelar ou antecipada. Note-se que a caução é uma cautela em face da tutela de urgência, de modo que se destina a ressarcir o dano que pode ser produzido pela sua efetivação.

Embora a norma fale em caução real ou fidejussória, aquele que obtém tutela cautelar ou antecipada, pode garantir a parte adversária de outro modo, desde que idôneo, a prestar efetiva segurança pelo eventual prejuízo capaz de ser acarretado pela efetivação da tutela. A princípio não há porque descartar, por exemplo, que o beneficiado pela tutela urgente ofereça como caução, um contrato de seguro que cubra a responsabilidade pelo dano que pode ser produzido pela execução.<sup>13</sup>

A parte final do § 1.º do art. 300 afirma que a caução pode ser dispensada “se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. A caução é resultado da consideração do direito à tutela de urgência e do direito à segurança do ressarcimento dos danos que podem ser acarretados pela efetivação da tutela. É claro que esses dois direitos, devem ser amparados nos casos em que a parte tem condições econômicas de garantir a eventual necessidade de ressarcimento do dano provocado pela execução. Contudo, haverá situações em que a parte não terá capacidade financeira para prestar caução. Diante desta hipótese, a norma optou pelo direito à tutela jurisdicional efetiva em detrimento do direito à segurança do ressarcimento dos danos.

Assim, nos casos em que a parte é economicamente hipossuficiente o juiz deve dispensar a prestação de caução. Bem por isso, a parte que se afirma destituída de condições financeiras, deverá provar a sua hipossuficiência e, neste caso, o juiz deve estar bastante atento.

## **9. O problema do perigo de irreversibilidade**

### **9.1. Irreversibilidade dos efeitos jurídicos da decisão**

O § 3.º do art. 300 afirma que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Não seria preciso dizer que irreversibilidade dos efeitos jurídicos e irreversibilidade dos efeitos fáticos da decisão são coisas que não se misturam, se não fosse a confusão, que sempre reinou na doutrina e nos tribunais, entre a estrutura e a função da tutela antecipada.

No direito francês, o ab-rogado art. 809,<sup>14</sup> que afirmava que o référé não pode causar

“préjudice au principal”, foi interpretado no sentido de que a tutela de cognição não pode incidir de modo irreversível na esfera jurídica do demandado. A interpretação ecoou também na Itália e – como alerta Tommaseo – ainda é responsável por algumas decisões que negam a possibilidade da concessão de um “provvedimento d’urgenza” que, antecipando os efeitos da sentença de mérito, conduza à satisfação integral da pretensão do requerente, reintegrando o trabalhador no emprego ou, ainda por exemplo, restituindo antecipadamente um bem.<sup>15</sup>

O novo Código de Processo Civil francês eliminou os equívocos que a antiga fórmula do “préjudice au principal” havia feito surgir. Considera-se agora o art. 488, que diz que “l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée”.<sup>16</sup> A interpretação que se dá a esta regra, é no sentido de que a tutela de cognição sumária não pode prejudicar a cognição exauriente do mérito ou não pode vincular o juízo final; não pode, em resumo, prejudicar a decisão da causa.<sup>17</sup> A tutela antecipada, assim como o référé francês, não pode causar “préjudice au principal”, ou “n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée”.<sup>18</sup> Porém, não há contradição entre provisoriedade da decisão, em vista da cognição sumária que lhe é própria, e tutela antecipada ou realização antecipada do direito. A tutela é provisória apenas e tão somente porque o juiz, ao concedê-la, não afirma que o direito existe e, portanto, não pode prejudicar a decisão sobre o direito com base em cognição mais aprofundada. A decisão que concede a tutela antecipada, não pode produzir efeito capaz de impedir outro juízo sobre o direito ou mesmo um efeito que, embora possa admitir decisão com sentido contrário, é incompatível com a situação de direito substancial tutelanda.

A provisoriedade da tutela antecipada deve ser entendida como a sua incapacidade de definir a controvérsia, por absoluta falta de idoneidade para a declaração ou, em outros termos, para a produção de coisa julgada material.<sup>19</sup> Mas a satisfatividade da tutela sumária, e mesmo a eventual irreversibilidade dos seus efeitos fáticos, não é contraditória com a sua estrutura. Nada impede que uma tutela que antecipe a realização do direito e produza efeitos fáticos irreversíveis seja – do ponto de vista estrutural – provisória, ou melhor, incapaz de dar solução definitiva ao mérito.

O que o § 3.º do art. 300 veda quando afirma que a tutela de urgência “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” é, além de prejuízo ao juízo final, a criação de determinados efeitos jurídicos incompatíveis com a situação de direito substancial, objeto de tutela jurisdicional. Mais claramente, o que se proíbe são determinadas constituições provisórias. Como é evidente, não há como decretar provisoriamente o divórcio ou desconstituir provisoriamente o casamento, embora seja adequado ordenar, também por exemplo, que um cônjuge se afaste do outro em vista de decisão de separação de corpos.<sup>20</sup>

Portanto, ao falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a norma proíbe, por exemplo, a antecipação da constituição de uma relação de filiação ou a antecipação da desconstituição de um casamento. É certo que é possível, na perspectiva técnico-processual, a antecipação da constituição. Porém, também não há dúvida que é impossível admitir, de forma generalizada, a antecipação da constituição, já que é inconcebível a tutela antecipada nas ações relativas ao estado ou à capacidade das pessoas.

Perceba-se que a possibilidade técnico-processual da antecipação da constituição não pode eliminar a inviabilidade de constituição provisória diante de certas situações de direito substancial. Ou seja, a impossibilidade da constituição provisória nada tem a ver com a técnica processual. Assim, pouco importa se a sentença que desconstitui o casamento pode ser objeto de ação rescisória.

Como é óbvio, todas as sentenças constitutivas ou declaratórias podem, em tese, ser objeto de ação rescisória, assim como nada impede a antecipação da constituição em uma perspectiva apenas processual. Mas o fato de uma sentença produtora de coisa julgada material poder ser objeto de ação rescisória não significa, apenas por isto, que a tutela por ela concedida pode ser objeto de antecipação ou de “execução provisória”.

Quando se sustenta que a antecipação da constituição está proibida em algumas hipóteses e não em outras, obviamente não se pensa em termos processuais. Apenas nesta última perspectiva

alguém poderia ser levado a equivocadamente concluir que a tutela antecipada – diante da sentença (des)constitutiva – é sempre ou nunca possível. A conclusão seria no sentido do tudo ou nada.

Entretanto, como a tutela jurisdicional – e, especialmente, a tutela antecipada –, somente adquire relevância quando compreendida como tutela dos direitos, não há a mínima possibilidade de interpretar a regra processual que fala em “perigo de irreversibilidade” sem visualizar a situação de direito substancial objeto de tutela jurisdicional. Melhor explicando: o fato de o art. 300, § 3.º, do Código de Processo Civil não ter aludido aos casos em que a constituição não pode ser antecipada, não permite concluir que ela jamais poderá ser antecipada nem que ela sempre poderá ser antecipada. É por essa razão, absolutamente lógica, que se afirma que a antecipação não pode ocorrer nas ações relativas ao estado ou à capacidade das pessoas.

Contudo, para a adequada interpretação do § 3.º do art. 300 não basta afirmar que a tutela antecipada não pode prejudicar o juízo de cognição exauriente nem criar determinadas situações jurídicas. É também necessário deixar claro, que a tutela antecipada pode produzir efeitos fáticos irreversíveis.

## **9.2. A irreversibilidade dos efeitos fáticos é uma consequência inerente à natureza da tutela antecipada**

Disse Cândido Dinamarco, em livro escrito quando se debatia a regra que falava em “perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” no Código de 1973: “É preciso receber com cuidado o alvitre de Marinoni, para quem se legitimaria o sacrifício do direito menos provável, em prol da antecipação do exercício ‘de outro que pareça provável’. O direito não tolera sacrifício de direito algum e o máximo que se pode dizer é que algum risco de lesão se pode legitimamente assumir. O direito improvável é direito que talvez exista e, se existir, é porque na realidade inexistia aquele que era provável”.<sup>21</sup>

No caso da tutela antecipada, é claro, ainda não se sabe se o direito afirmado pelo autor existe ou não existe. É por isso que há tutela do direito provável. Falar de sacrifício do direito improvável não seria correto para Dinamarco porque “o direito improvável é direito que talvez exista e, se existir, é porque na realidade inexistia aquele que era provável”. Ora, a alusão a um direito improvável já traz em si a ideia de que o direito pode existir. O que poderia ser dito, e com razão, é que o direito material não pode ser qualificado de “provável” ou de “improvável”, pois ele existe ou não existe. Porém, a “existência” do direito é algo que pertence ao plano do direito material. Quando se está diante do processo civil e, em particular, do juízo sumário, está em jogo a probabilidade da existência do direito afirmado e, portanto, o “direito provável”, que é uma categoria, assim como a do “direito líquido e certo”, pertencente ao direito processual. A razão que impediria alguém de falar em sacrifício do direito improvável também estaria banindo, para sempre, a já consagrada locução *fumus boni iuris*. Afinal, se é impossível sustentar que um direito improvável pode ser prejudicado porque o direito pode existir é também impossível falar em tutela de direito com base em “*fumus boni iuris*” porque o direito pode inexistir.

Não há razão para não admitir tutela antecipada que possa gerar efeitos fáticos irreversíveis, pois a tutela cautelar não raramente produz tais efeitos.<sup>22</sup> Lembre-se, aliás, que a liminar do interdito possessório constitui hipótese clara de tutela jurisdicional que pode produzir efeitos fáticos irreversíveis. Como deveria ser óbvio, não só conceder, mas também deixar de conceder tutela de urgência pode causar prejuízos irreversíveis.<sup>23</sup>

Admitir que o juiz não pode antecipar a tutela, quando a antecipação é imprescindível para evitar um prejuízo irreversível ao direito do autor, é o mesmo que afirmar que o legislador obrigou o juiz a correr o risco de provocar um dano irreversível ao direito que justamente lhe parece mais provável.<sup>24</sup> Ora, se o autor, além de ter que demonstrar a probabilidade do direito, deve frisar o perigo de dano, não há como deixar de tutelar o direito mais provável. Não só a lógica, mas também o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, exigem a possibilidade de sacrifício, ainda que de forma irreversível, de um direito que pareça improvável em benefício de outro que pareça provável.<sup>25</sup> Caso contrário, o direito que tem a maior probabilidade de ser definitivamente reconhecido poderá ser irreversivelmente lesado.<sup>26</sup> Portanto, a ética da tutela de

urgência consiste no sacrifício do improvável em benefício do provável.<sup>27</sup>

Alguém poderia dizer que não é conveniente dar ao juiz um poder tão amplo. Entretanto, se o juiz da Itália, da França, da Alemanha, da Inglaterra e de outros países – em que os jurisdicionados, em tese, podem suportar com mais facilidade o tempo de demora da Justiça – podem conceder tutelas antecipadas ou sumárias que causem prejuízos irreversíveis ao réu,<sup>28</sup> por que o juiz brasileiro estaria impedido de assim proceder? Na verdade, aqueles que temem o juiz brasileiro com o poder necessário para bem cumprir a sua função partem de uma premissa – não revelada – não apenas preconceituosa, mas também ofensiva à Magistratura. Está por detrás do raciocínio que pretende ver o juiz amarrado a ideia de que a Magistratura brasileira não é suficientemente preparada para ter poder. Tal maneira de pensar não só é arbitrária, como também primária. Ora, se o juiz brasileiro, apenas em virtude da diferença entre a situação social do Brasil e a dos países europeus, não tem poder para aplicar um remédio essencial para a boa prestação da justiça, o médico brasileiro (apenas para tomar um exemplo) deveria estar impedido de utilizar instrumentos – que podem trazer riscos aos pacientes quando mal administrados e que, por isso, também supõem profissionais bem preparados – necessários para a manutenção da vida dos brasileiros.

Na realidade, não se está dando nada ao juiz, já que o poder para a prestação da tutela jurisdicional efetiva é inerente à sua função.<sup>29</sup> O que acontece é que alguns querem um juiz que não é “juiz”, mas um simples burocrata. A ideologia que se esconde atrás destas ideias é bastante antiga, podendo-se dizer que deita raízes no liberalismo europeu do século XIX. O juiz francês anterior à Revolução Francesa, como se sabe, tinha mais semelhança com o juiz inglês do que com o seu outro parceiro do direito continental europeu. Basta lembrar que o sistema judicial francês era considerado rival do direito do governo central de Paris. A Revolução Francesa e o dogma da separação dos poderes<sup>30</sup> é que restringiram a função do juiz francês, tornando-o um mero servidor público. Essa imagem do juiz burocrata, construída sobretudo pelo direito liberal clássico, enraizou-se pelo direito continental europeu e no direito da América Latina e ainda é a responsável pela passividade e pela falta de poder do juiz.<sup>31</sup>

Um juiz sem poder é um juiz sem responsabilidade social ou, pelo menos, com responsabilidade social limitada. O juiz pode tomar consciência da sua responsabilidade perante a sociedade quando tem poder. É claro que, nestas circunstâncias, também cresce a responsabilidade dos cursos preparatórios para o ingresso na Magistratura, que devem ser capazes de dotar os magistrados de conhecimentos culturais, sociológicos e econômicos que os esclareçam sobre o significado político da Magistratura e sobre a necessidade de uma postura crítica diante de uma sociedade que a cada dia se torna mais complexa e rica em diversidades.

É inegável que a tutela antecipada que pode causar um prejuízo irreversível requer prudência. Mas ninguém está autorizado a confundir prudência com medo. A tutela antecipada deve ser utilizada nos limites em que é necessária para evitar ato contrário ao direito ou dano e, em casos excepcionais, até mesmo produzindo efeitos fáticos irreversíveis, já que o juiz, por lógica, não pode permitir prejuízo irreversível ao direito provável sob a justificativa de que a sua decisão não pode causar prejuízo irreversível ao direito improvável. Isso seria obrigar a jurisdição a tutelar o direito improvável!

## **10. Inconstitucionalidade da proibição de concessão de tutela urgente contra a Fazenda Pública**

De acordo com o art. 1.059 do Código de Processo Civil, “à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009”. O Código de 2015 reprisa regras inconstitucionais, voltadas a impedir a concessão de liminar de natureza cautelar e antecipada contra a Fazenda Pública. O art. 1.059 é uma regra que representa o viés autoritário da maioria parlamentar que o aprovou. Imaginou-se que, por ser ré a Fazenda Pública, seria possível ignorar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva – exatamente o direito fundamental imprescindível à tutela de todos os demais direitos –, bem como retirar do Judiciário o poder de definir, diante dos casos concretos, quando a tutela urgente deve ser concedida para tutelar os



direitos.

É certo que o tempo despendido para a cognição do litígio mediante investigação probatória é reflexo da existência do Estado e da necessidade que ele se impôs de, antes de tutelar os conflitos, averiguar a existência dos direitos afirmados em juízo. Mas é reflexo da existência do Estado porque foi este que vedou a autotutela privada, não deixando outra saída ao jurisdicionado a não ser levar o seu direito a juízo. O Estado, ao estabelecer tal proibição, obviamente adquiriu a obrigação de tutelar de forma efetiva e tempestiva toda e qualquer espécie de situação conflitiva concreta. Se o Estado proibiu a autotutela privada é correto afirmar que está obrigado a prestar a tutela jurisdicional adequada a cada conflito de interesses. Nessa perspectiva surge a resposta intuitiva de que a inexistência de tutela adequada a determinada situação conflitiva significa a própria negação da tutela a que o Estado se obrigou no momento em que chamou a si o monopólio da jurisdição, já que o processo nada mais é do que a contrapartida que o Estado oferece aos cidadãos diante da proibição da autotutela.

Tendo em vista que o Estado é obrigado a prestar a devida tutela jurisdicional, entendida como a tutela apta a tornar efetivo o direito material, todos têm direito à tutela jurisdicional efetiva. O jurisdicionado não tem apenas direito à resposta jurisdicional, mas direito à tutela jurisdicional efetiva e tempestiva.<sup>32</sup> O Estado, para cumprir a sua obrigação de prestar a devida tutela jurisdicional, deve outorgar ao cidadão o poder de utilizar a técnica processual adequada ao caso concreto. As diferentes situações de direito substancial exigem instrumentos processuais – os diversos meios executivos e a técnica antecipatória – diferenciados ou que se diferenciem no caso concreto.<sup>33</sup>

Portanto, se uma situação de direito material requer tutela urgente, não é possível que o Estado se negue a prestar a devida tutela jurisdicional, ou seja, a tutela fundada no art. 300 do Código de Processo Civil. Tal espécie de tutela permite que o direito material seja tratado de forma diferenciada, segundo as suas necessidades.

Recorde-se que o art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, afirma o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, obrigando o Estado a instituir técnicas processuais idôneas à tutela dos direitos. O cidadão que afirma ter um direito deve ter ao seu dispor as medidas e os instrumentos necessários à realização do seu eventual direito.<sup>34</sup> Se o direito à tutela jurisdicional efetiva é garantido constitucionalmente, o legislador infraconstitucional é obrigado a estruturar o sistema processual de modo a permitir a efetividade da tutela dos direitos. Um sistema que não possui procedimento e técnica processual adequados à tutela de uma determinada situação de direito substancial não está estruturado de acordo com a exigência constitucional. Não fosse esta a conclusão correta, seria necessário admitir que o cidadão pode ter direitos, mas não possui meios para os fazer valer, o que equivale dizer, simplesmente, não ter direitos.<sup>35</sup>

Se a realidade da sociedade contemporânea não comporta a espera do tempo despendido para a cognição aprofundada do litígio, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva está na dependência das tutelas antecipada e cautelar. O legislador certamente tem o dever de instituir técnicas processuais que não permitam que o cidadão seja prejudicado pela demora do processo. Portanto, a lei, ainda que possa disciplinar os procedimentos, obviamente não pode, sob pena de negação ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, vedar o direito de postulação das tutelas antecipada e cautelar contra quem quer que seja, especialmente contra a Fazenda Pública.

A existência de perigo de dano diz respeito ao mérito cautelar, que deve ser apreciado pelo juiz. Ou seja, o direito à tutela urgente não pode ser suprimido por lei com base na impossível afirmação de que não existirá perigo de dano. Qualquer regra que afirme a proibição de liminar está a dizer que jamais existirá necessidade de tutela urgente, ou seja, está valorando aquilo que somente pode ser objeto da cognição do juiz. Ora, a lei não tem poder para controlar as situações concretas de perigo. Assim, não pode partir da premissa de que nunca haverá perigo de dano. Bem por isso, ao proibir a tutela urgente contra a Fazenda Pública, a lei deixa desamparado o particular que, exposto a perigo de dano, necessita das tutelas antecipada e cautelar.<sup>36</sup>

De acordo com o art. 7.º, § 2º, da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009),

não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Ao negar a possibilidade de liminar diante destas hipóteses, sem dar ao juiz condições de avaliar as particularidades do caso concreto, a regra – que agora o art. 1.059 do Código de Processo Civil pretende ver aplicada diante da tutela de urgência – incide em inconstitucionalidade.

Não há como afirmar que é possível restringir o uso da tutela antecipada desde que a afirmação de lesão a direito possa vir a ser apreciada ao final do procedimento comum.<sup>37</sup> O § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 afirma que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. A regra é, em si, equivocada, na medida em que uma liminar jamais pode esgotar o objeto da ação. Basta ver que a liminar ou a tutela de urgência é sempre concedida com base em cognição sumária. Na verdade, o legislador não soube dizer o que pretendia. Sabe-se que o legislador quis dizer que a liminar não pode satisfazer antecipadamente (ou com base em cognição sumária) o direito. Porém, como já claramente demonstrado, a proibição de tutela antecipada contra a Fazenda Pública representa violação inequívoca ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

Frise-se que a tutela dos direitos contra o abuso ou o uso inadequado do Poder Público somente se realiza através de garantias instrumentalizadas em processos céleres e com expedientes destinados a tutelar contra o periculum in mora. Como já declarou o Conselho Superior de Magistratura Italiana,<sup>38</sup> é impossível negar que um “juízo” lento, como aquele imposto à atual organização processual judiciária, dá lugar a fenômenos de compressão dos direitos fundamentais do cidadão.<sup>39</sup>

**Art. 301.** A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito.

## **1. A definição legislativa de tutela cautelar**

O artigo 301 exemplifica hipóteses de tutela cautelar, deixando claro que estas devem ser idôneas para a “asseguração do direito”. Refere-se ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e registro de protesto contra alienação de bens, todas elas indiscutivelmente voltadas a assegurar o alcance da tutela efetiva do direito.

Inicialmente, convém apontar que o preceito perde grande parte de seu significado na atualidade, na medida em que não se tem mais os referenciais semânticos incluídos no dispositivo. Eliminadas as medidas cautelares específicas do código anterior, é difícil dizer – apenas com base na legislação em vigor – o que é um arresto, um sequestro e em que medida essas figuras se distanciam do arrolamento de bens. Ainda assim, o preceito serve para indicar a amplitude que pode ter a tutela cautelar.

Isso não apenas significa que é possível requerer, além das exemplificadas, qualquer medida idônea para assegurar a viabilidade do alcance da efetiva tutela do direito material, mas especialmente que o Código de Processo Civil resolveu definir tutela cautelar, delineando-a diante da tutela antecipada. O art. 301 diz que a tutela cautelar objetiva assegurar o direito, diferenciando-a da tutela que, ao invés de assegurar, satisfaz o direito por antecipação.

Trata-se, portanto, de norma de enorme importância dentro do cenário da tutela provisória, na medida em que define questão que há muito atormenta a doutrina e os tribunais. Agora não há mais dúvida que tutela cautelar não tem o mesmo significado de tutela antecipada. Segundo a própria lei processual, a tutela cautelar não realiza ou satisfaz o direito por antecipação; a sua função é assegurar o direito ou a tutela efetiva do direito material.

## **2. Tutelas cautelares ou de segurança exemplificadas no art. 301**

O arresto deita raízes no direito medieval, embora tenha traços romanos em sua concepção. O objeto do arresto é garantir a efetividade da tutela prestada em dinheiro – tutela ressarcitória pelo



equivalente ou tutela do adimplemento da prestação pecuniária. É possível requerer o arresto antes do ajuizamento da ação voltada à obtenção da tutela ou na forma incidental. Para tanto, além da probabilidade do direito, devem estar presentes elementos que indiquem que o demandado pretende frustrar a efetividade da tutela pecuniária. O arresto objetiva tornar indisponíveis bens suficientes para responder à futura execução. Não há preocupação com a qualidade do bem, bastando que possa ser objeto de expropriação e transformado em valor suficiente para satisfazer a execução.

Na história há confusão entre arresto e sequestro, a ponto de algumas legislações antigas, como as Ordenações do Reino, empregarem o termo “sequestro” para designar hipótese de arresto. Esta confusão também está presente em leis contemporâneas. Aliás, há exemplo clássico desta falta de técnica jurídica no art. 100, § 6.º, da Constituição Federal. Note-se que o arresto se preocupa em garantir a efetividade da tutela pecuniária e, portanto, da execução por quantia certa, enquanto que o sequestro almeja garantir a efetividade da tutela mediante a qual se obtém coisa ou se determina a sua entrega. Busca-se com o sequestro um bem específico, sobre o qual recai a disputa judicial, ao passo que o arresto, por estar preocupado com uma soma em dinheiro, pode repousar em quaisquer bens do responsável pela implementação da tutela pecuniária.

Importa esclarecer que o sequestro é cabível não apenas quando se controverte sobre posse ou propriedade, mas também quando se discute relação obrigacional a partir da qual decorra direito à tutela do adimplemento da obrigação de entrega de coisa. O sequestro assegura a tutela mediante a qual se pretende um bem, pouco importando se esta tutela é fundada em direito real ou em direito obrigacional. O sequestro incide sobre o bem – móvel, semovente ou imóvel – que se deseja obter mediante a tutela final, tendo o objetivo de evitar o seu desaparecimento, destruição, prejuízo ou mesmo alienação. Portanto, para a sua obtenção, além da probabilidade do direito, devem estar presentes elementos que evidenciem o perigo.

O arrolamento de bens, por sua vez, relaciona-se à necessidade de apreensão e descrição de bens pertencentes a uma universalidade. Destina-se a conservar bens indeterminados, que estejam sendo ou possam vir a ser discutidos judicialmente. O escopo do arrolamento é conservar os bens da universalidade de modo a assegurar a efetiva tutela jurisdicional do direito. De modo que, além da probabilidade da tutela do direito, deve haver perigo de extravio, ocultação, adulteração, abandono, dissipação ou mesmo alienação fraudulenta dos bens. É preciso que exista perigo de dano a um conjunto de bens cujos elementos ainda não podem ser definidos. A finalidade do arrolamento fica mais clara, especialmente em face do fim do sequestro, quando se toma em consideração a hipótese de dilapidação dos bens do casal nas ações de separação judicial, divórcio e de anulação de casamento. Note-se que, quando o caso é de dilapidação de bem específico, basta o sequestro, mas quando o cônjuge não tem condições de precisar os bens que estão sob perigo de dilapidação, na medida em que não dispõe de dados sobre a extensão do patrimônio, é necessário o arrolamento para a apreensão e individualização dos bens.

Poderão ser objeto do arrolamento todas as espécies de bens móveis e imóveis que possam constituir uma universalidade. Excepciona-se dessa condição o dinheiro corrente, por sua característica de fungibilidade. Também podem constituir objeto de arrolamento os documentos que formam um conjunto impreciso. Em regra, o arrolamento liga-se a relações fundadas em direito de família, direito de sucessão e direito societário. No último caso, por exemplo, é comum o seu uso diante de ação de dissolução de sociedade – quando não se pode precisar os bens que integram o patrimônio social que sofre perigo de dano.

Por fim, o protesto contra a alienação de bem goza da mesma preocupação com a segurança da efetiva tutela do direito. Quem é titular de pretensão à tutela de direito que recai sobre a propriedade de determinado bem – já exercida ou que ainda pode ser exercida – pode pedir o registro de protesto contra a sua alienação, bastando evidenciar elementos que evidenciem o perigo de alienação e a probabilidade da obtenção da tutela jurisdicional do direito sobre o bem.

**3. Concessão de providência diversa da requerida desde que adequada à asseguuração do direito ou à prestação da tutela cautelar**

No contexto do art. 301 é importante perguntar se o juiz pode determinar providência diversa da requerida para prestar a tutela cautelar. Interessa verificar se o juiz pode apenas determinar providência menos restritiva ao réu ou também mais prejudicial – desde que idônea à prestação da tutela cautelar.

Quando o autor requer providência que, embora idônea à tutela de segurança, não é a que traz a menor restrição possível ao réu, o juiz certamente deve conceder providência diversa da solicitada, identificada como idônea à tutela de segurança e, ao mesmo tempo, caracterizada pela imposição da menor restrição à esfera jurídica do demandado.

Ovídio<sup>40</sup> e Fritz Baur,<sup>41</sup> quando tratam do princípio da fungibilidade da tutela cautelar, fazem referência a exemplo em que o autor pede a retirada de uma janela do prédio vizinho sob o fundamento de direito de vizinhança e o juiz deixa de deferir a supressão da janela para ordenar a colocação de vidros foscos que impeçam a visão para o prédio do autor. Embora esta tutela não seja propriamente cautelar, mas de remoção do ilícito,<sup>42</sup> o juiz está simplesmente pautando a sua atuação a partir da regra da necessidade, a qual impede que um direito seja tutelado por um meio que cause um gravame despropositado ao demandado. Portanto, a atuação jurisdicional não está simplesmente proporcionando a tutela idônea ao autor, mas sim se fundando em uma das sub-regras da regra da proporcionalidade. Ou melhor, como o juiz tem o dever de tutelar o direito sem causar restrição desnecessária ao demandado, a jurisdição apenas está sendo exercida de modo legítimo.

Considerando-se a distinção entre a tutela de segurança (tutela cautelar) e a providência ambicionada para prestar esta tutela, é possível dizer que o pedido de providência é negado para se atender de forma “justa” ao pleito de tutela. É que a tutela somente é prestada de modo “justo” através do meio que é idôneo e causa a menor restrição possível. Fala-se em justo, aí, no sentido em que Larenz trata da ideia de “justa medida”. Segundo Larenz, a regra da necessidade – que se desdobra nas regras da menor restrição possível e do meio idôneo – tem relação com o que Lerche chama de proibição de excesso, invocando as noções de “equilíbrio” e de “justa medida” para evitar que o direito seja tutelado mediante a imposição de consequências “desmedidas” ao réu. Esclarece Larenz que a ideia de “justa medida” tem uma relação estreita com a ideia de justiça, tanto no exercício dos direitos como na imposição de deveres e ônus, de equilíbrio de interesses reciprocamente contrapostos na linha do menor prejuízo possível.<sup>43</sup>

Contudo, se não há porque negar a possibilidade de o juiz conceder uma providência cautelar menos restritiva, a situação oposta, ou seja, a possibilidade de o juiz conceder medida que, apesar de mais restritiva, é a única idônea à tutela cautelar, também deriva da circunstância de o juiz estar subordinado apenas à causa de pedir e ao pedido de tutela de segurança, sem se vincular ao pedido de providência para a tutela cautelar.

Quando a exposição do direito ameaçado e do perigo de dano indicam que a providência requerida não tem idoneidade, em termos qualitativos ou de extensão, para prestar efetiva tutela de segurança, tendo ocorrido lapso no requerimento da providência, o juiz deve conceder providência outra, porque idônea, ainda que mais gravosa ao demandado. Frise-se que o réu deve se defender diante da fundamentação e do pedido de tutela cautelar. A providência pode ser impugnada quando violadora da regra da menor restrição possível. De modo que, ao se defender do pedido de tutela cautelar, o réu deve, com base no princípio da eventualidade, deduzir a providência que entende ser menos restritiva para a prestação da tutela cautelar.

**Art. 302.** Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I – a sentença lhe for desfavorável;

II – obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III – ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV – o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

## **1. Pressupostos da responsabilidade da parte que requereu a tutela de urgência efetivada em prejuízo do adversário**

O art. 302, sem excluir a responsabilidade por dano processual, elenca as hipóteses em que a parte é considerada responsável pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Trata-se de responsabilidade independente de culpa, derivada única e exclusivamente dos eventos consignados nos quatro incisos do art. 302. O dever de indenizar depende apenas da ocorrência de hipótese prevista em um destes incisos, devendo a indenização ser liquidada nos autos em que a tutela houver sido executada – sempre que possível (art. 302, parágrafo único, CPC).

É claro que o ressarcimento pelo dano provocado pela efetivação da tutela urgente, apesar de não depender de culpa, exige a demonstração do dano, ou melhor, requer a sua delimitação e quantificação.

Tratando-se de hipótese especificamente regulada em lei, a responsabilidade objetiva está limitada aos danos causados à parte pela efetivação da tutela. Assim, está excluída da regra a hipótese de danos causados a terceiros. Esses danos estarão sujeitos ao regime geral da responsabilidade civil, não podendo socorrer-se da previsão excepcional.

## **2. Hipóteses de responsabilidade objetiva**

O primeiro inciso do art. 302 afirma que a parte responde pelo prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência quando a sentença lhe for desfavorável. A sentença desfavorável – obviamente que transitada em julgado – é suficiente para fazer surgir o dever de indenizar. Da sentença decorre inexoravelmente o dever de indenizar.

Mas o legislador se esqueceu da hipótese em que a parte, após a efetivação da tutela cautelar concedida inaudita altera parte, teve o pedido de tutela cautelar julgado improcedente e o pedido principal julgado procedente. Note-se que o autor pode ter direito à tutela do direito, mas não ter tido razão para pedir a tutela cautelar em razão de inexistência de perigo de dano. Ou seja, a tutela cautelar concedida antes da ouvida do réu pode ser efetivada e, após a contestação, restar clara a inexistência de perigo de dano, negando-se o pedido cautelar. Isso certamente não elimina a possibilidade de o pedido principal ser julgado procedente. Perceba-se que isso só vale para a tutela cautelar, uma vez que não há previsão de contestação ao pedido de tutela antecipada e, por consequência, de decisão.

À primeira vista, a falta de previsão legislativa poderia ser suprida pelo juiz, uma vez que o vencido em face do pedido cautelar, ainda que obtendo sentença de procedência em relação ao pedido principal, pode causar dano.

Porém, não há dever de indenizar como resultado direto de decisão de improcedência do pedido cautelar. Neste caso, para obter ressarcimento, aquele que sofreu prejuízo pela efetivação da tutela cautelar – depois revogada – tem que propor ação (autônoma) de ressarcimento, na qual terá que demonstrar não apenas o dano, mas também o dever de indenizar, ou seja, a inexistência de causa para a efetivação da tutela cautelar.

Como é evidente, caso a tutela cautelar tenha sido efetivada e, em virtude de fato novo, perca sua justificativa, não há que se pensar em responsabilidade por eventuais danos. Responsabilidade pelos danos só existirá caso a tutela se mantenha eficaz depois de se tornar injustificável em virtude do fato novo. Nessa última hipótese, em que se pergunta sobre a causa ou a justificativa da tutela cautelar, a responsabilidade depende de culpa, exigindo uma ação (autônoma) de ressarcimento. A responsabilidade objetiva, própria ao art. 302, não permite a análise da causa ou da justificativa da tutela cautelar.

O segundo caso de responsabilidade objetiva ocorre quando, obtida liminarmente a tutela, a

parte não fornece os meios necessários para a citação no prazo de cinco dias. Note-se que o inciso II confirma – como não poderia deixar de ser – a possibilidade de concessão de tutela cautelar antes da ouvida do réu.

A urgência, em alguns casos, pode exigir a efetivação da tutela de urgência – cautelar ou antecipada – antes da ouvida do réu.<sup>44</sup> Se a efetivação de tutela urgente inaudita altera parte pode ser imprescindível,<sup>45</sup> a sua excepcionalidade decorre do fato de postergar o contraditório.<sup>46</sup> Em nome da efetividade do contraditório, ao réu deve ser permitido demonstrar, com a maior brevidade possível, a eventual inexistência dos fundamentos que autorizaram a concessão da tutela urgente e mesmo a sua inadequação, por não representar a medida que produz a “menor restrição possível”.

Portanto, há razão para o legislador se preocupar em exigir breve citação do réu quando a tutela de urgência é deferida inaudita altera parte, impondo responsabilidade objetiva pelo dano ocasionado pela efetivação da tutela na hipótese de o autor não fornecer os meios necessários para a realização da citação no prazo de cinco dias.

Ao assim proceder, o autor responde por perdas e danos ainda que o pedido principal seja julgado procedente. A tutela urgente não pode permanecer eficaz por mais tempo que o necessário; não pode causar gravame despropositado ao réu, devendo obedecer à regra da “menor restrição possível”. Isto para não falar que o réu tem direito de pedir a substituição do meio concedido por outro menos gravoso.

Embora a responsabilidade seja objetiva, a medida do dano – a ser considerada na liquidação – deve tomar em conta apenas o dano provocado durante o espaço de tempo em que o réu não esteve no processo, em virtude do atraso na sua citação.

De acordo com o art. 302, III, o autor responde pelos prejuízos acarretados pela efetivação da tutela quando ocorrer a cessação da sua eficácia “em qualquer hipótese legal”. Na conjugação do art. 302, III com o art. 309, a primeira hipótese de responsabilidade objetiva ocorre quando o autor não deduz o pedido principal no prazo legal. O pedido principal deve ser apresentado no prazo de trinta dias contado da efetivação da tutela cautelar (art. 308, CPC). De modo que o pedido não precisa ser realizado quando a tutela não é concedida e efetivada. Porém, em caso de efetivação da tutela cautelar, a não formulação do pedido principal gera responsabilidade pelo dano.

O art. 302, III, quando combinado com o art. 309, II, causa polêmica, por pressupor responsabilidade quando a tutela “não for efetivada dentro de trinta dias”. Galeno Lacerda entendeu, diante da mesma norma do código de 1973 (art. 808, II), que não pode existir responsabilidade, pois se “pressupõe, exatamente, a não execução da cautela”. Advertiu Galeno Lacerda que, como o “simples deferimento da liminar não causa dano” e “o ressarcimento exige prejuízo real oriundo da execução da medida, situação excluída pelo referido inciso II” (do art. 808, CPC/1973), “nesta hipótese o máximo que poderá haver é a condenação do autor na sucumbência cautelar, se o réu tiver contratado advogado para defendê-lo”.<sup>47</sup> Frederico Marques, no mesmo sentido, escreveu que a cessação de eficácia da tutela, em razão da sua não execução em trinta dias, não pode acarretar obrigação de indenizar.<sup>48</sup>

Na verdade, a conjugação do art. 302, III, com o art. 309, II, impõe a interpretação de que há responsabilidade quando a efetivação da tutela cautelar ocorre depois de trinta dias. Quando a tutela cautelar não é efetivada realmente não há como pensar em responsabilidade. Porém, há que se ter em conta a hipótese em que a tutela é efetivada depois de trinta dias. Nesta situação há responsabilidade, pois a medida é efetivada quando a decisão não tem mais eficácia. Como é óbvio, se a decisão é ineficaz a efetivação não tem fundamento e a interferência na esfera jurídica do réu é ilegal.

Ainda se cogita de responsabilidade quando cessa a eficácia da tutela em virtude de improcedência do pedido principal ou de extinção do processo sem resolução de mérito. A responsabilidade derivada da cessação da eficácia em razão da improcedência do pedido principal está abarcada pela previsão do inciso I do art. 302, que afirma haver responsabilidade em caso de

sentença “desfavorável”. De forma que se acrescenta apenas a hipótese de responsabilidade em razão de extinção do processo sem resolução do mérito.

Diz ainda o art. 302, IV, que o autor responde pelo dano causado pela efetivação da tutela de urgência se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. A declaração da prescrição ou da decadência opera, diante da efetivação da tutela, como se houvesse sido proferida sentença de improcedência ou sentença “desfavorável”. Assim, por conta disto o autor também responde objetivamente pelo dano eventualmente ocasionado pela efetivação da tutela urgente.

### **3. Liquidação da indenização**

Diz o parágrafo único do art. 302 que “a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”. Não se trata de liquidação de sentença condenatória ilíquida nem de liquidação de obrigação de indenizar já declarada em sentença declaratória – hipótese, esta última, em que o lesado pede apenas a declaração da obrigação de indenizar e não tutela ressarcitória.

A liquidação do art. 302 é liquidação de obrigação de indenizar, mas se diferencia da liquidação da obrigação de indenizar declarada em sentença em razão de poder chegar à conclusão de que nada é devido pelo demandado. É que na liquidação de indenizar do art. 302 é preciso demonstrar o dano e, obviamente, o nexo de causalidade entre o dano e a efetivação da tutela.

A única coisa que é incontestável na liquidação do parágrafo único do art. 302 é a responsabilidade pelo eventual dano causado pela efetivação da tutela ou o dever de indenizar eventual dano a ser identificado e quantificado na liquidação. O dever de indenizar deriva, de forma inexorável, das causas consignadas nos incisos do art. 302. Existindo qualquer um dos eventos definidos nestes incisos surge indiscutível e incontestável responsabilidade ou dever de indenizar eventual dano provocado pela efetivação da tutela.

No caso de o dano restar quantificado na liquidação, bastará requerer a execução nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. Mas o problema da execução aparece quando se lembra que a liquidação não é de sentença condenatória – que, em razão da sanção executiva, abre oportunidade para o requerimento de execução –, mas de mera obrigação de indenizar – quando se torna necessário identificar em que lugar está a eficácia executiva que permite a execução.

Na hipótese de responsabilidade derivada de sentença desfavorável, não há necessidade de que esta sentença condene a parte que pediu a tutela urgente. Se a responsabilidade decorre dos eventos expressos nos incisos do art. 302, não há dúvida que o objetivo da liquidação é sempre definir e precisar o dano, relacionando-o com a efetivação da tutela, além de quantificá-lo. Portanto, toda e qualquer sentença que quantificar o dano derivado da efetivação da tutela urgente, simplesmente por definir o direito à tutela ressarcitória, deve abrir oportunidade para a execução da quantia certa.

A sentença de liquidação, ao quantificar o dano, colabora com a prestação da tutela ressarcitória, que resta na dependência do adimplemento voluntário ou da execução. De modo que a execução deriva da definição do direito à tutela ressarcitória, que, obviamente, abre oportunidade para execução. A menos que se pense que a parte que sofre a tutela de urgência, ao requerer a liquidação da obrigação de indenizar, pede tutela declaratória da obrigação de indenizar e não tutela ressarcitória.

Porém, não há racionalidade em supor que alguém que sofre a efetivação de tutela que, segundo a lei (art. 302 do CPC), é indevida e de responsabilidade da outra parte, possa ter interesse em solicitar a identificação e quantificação do dano que lhe foi ocasionado apenas para vê-lo declarado, sem a possibilidade de exigi-lo através de execução.

Além do mais, quem pede tutela ressarcitória e requer sentença declaratória e não condenatória simplesmente solicita uma técnica processual inidônea (sentença inidônea). E esta situação, como faz ver o art. 515, I, do Código de Processo Civil, torna a sentença declaratória

(requerida obviamente por equívoco, já que para prestar tutela ressarcitória) executável, ou melhor, identificável como título executivo judicial. Ou seja, quando se pede tutela ressarcitória se requer, necessária e implicitamente, sentença executável. Portanto, caso atualmente seja requerida sentença declaratória para prestar tutela ressarcitória, o juiz, diante do evidente equívoco do autor, pode admitir a sua execução. Na verdade, concederá sentença condenatória, uma vez que, como é pouco mais do que óbvio, “sentença declaratória executável” é uma contradição em termos.

Perceba-se que isto não elimina a possibilidade de se requerer tutela declaratória após a violação do direito, como permite o art. 19 do Código de Processo Civil. O lesado continua com a possibilidade de pedir tutela declaratória. A diferença é a de que, a partir da exata distinção entre tutela e sentença, percebe-se que o lesado pode pedir tutela declaratória e sentença declaratória, mas não pode pedir tutela ressarcitória e sentença declaratória. A tutela ressarcitória reclama, necessariamente, sentença executável, sendo a sentença condenatória a técnica adequada à prestação da tutela ressarcitória pelo equivalente em pecúnia.

Melhor explicando: se a parte pede tutela de ressarcimento do dano pelo equivalente e solicita sentença declaratória, o juiz deve prestar, ao reconhecer “a exigibilidade de obrigação de pagar quantia” (art. 515, I, do CPC) – compreendida como dever de ressarcir em dinheiro –, sentença condenatória ou, mais precisamente, sentença executável de natureza condenatória.

Mas isto não quer dizer que o autor da liquidação não deva pedir a condenação (sentença condenatória) do responsável pelo dano provocado pela efetivação da tutela urgente. E também que o juiz não deva, neste caso, proferir sentença condenatória. O que se quis demonstrar, apenas, é que, diante da omissão do requerente da liquidação em pedir a sentença adequada, o juiz não tem alternativa a não ser proferir sentença condenatória.

---

## NOTAS DE RODAPÉ

---

1

V., sobre isso, Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva*.

2

Giovanni Arieta, I provvedimenti d’urgenza, Padova: Cedam, 1982, p. 133.

3

Aldo Frignani, L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano, Milano: Giuffrè, 1974, p. 323 e ss.

4

Ver Cristina Rapisarda, Tutela preventiva, inibitoria cautelare ‘ex’ art. 700 C.P.C. ed inibitoria finale, *Rivista di Diritto Processuale*, 1986, p. 138 e ss.

5

Lembre-se que, como nada impede uma ação ressarcitória na forma específica, a tutela antecipada



também pode ser ressarcitória na forma específica, instrumentalizando-se através de uma ordem de fazer (art. 536, CPC). A tutela resarcitória na forma específica antecipada pode ser necessária para que o dano não se potencialize ou cause um outro dano. Ver Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela contra o ilícito*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

---

6

Andrea Proto Pisani, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari: Cacucci, 1982, p. 382.

---

7

Ver Arnaldo Miglino, *La tutela giurisdizionale anticipatoria*, p. 171.

---

8

Cf. Nicolò Trocker, *Processo civile e costituzione*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 406.

---

9

Nicolò Trocker, *Processo civile e costituzione*, p. 408.

---

10

Ver Luigi Paolo Comoglio, *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova: Cedam, 1970.

---

11

Registre-se a seguinte passagem do livro *Antecipação da Tutela*: “Entretanto, é irracional admitir que a tutela do direito não pode ser prestada após a fase instrutória ter encerrado. Realmente, há um grande equívoco no sistema processual que não admite a execução da sentença na pendência do recurso de apelação ao menos nos casos em que estão presentes os fundamentos que justificam a tutela antecipada. A lei que alterou o art. 520 do Código de Processo Civil perdeu uma grande oportunidade para corrigir tal defeito. Como é óbvio, não basta afirmar que o recurso de apelação não será recebido no efeito suspensivo quando a sentença confirmar a antecipação da tutela, como diz o inciso VII do art. 520. É evidente que o recurso de apelação, neste caso, não deve suspender a eficácia ou a ‘execução’ da tutela antecipada. Note-se que o inciso VII, acrescentado ao art. 520, fala em sentença que ‘confirmar a antecipação dos efeitos da tutela’ e, portanto, pressupõe uma tutela antecipadamente concedida. Há casos, porém, em que embora requerida a antecipação da tutela, essa é negada com base no fundamento de que o direito não foi demonstrado como provável. Contudo, se mais tarde o direito restar evidenciado e ainda persistir o perigo, não há razão lógica para não se deferir a tutela, embora o inciso VII do art. 520 aluda somente à sentença que confirmar a antecipação da tutela. Portanto, o correto seria estabelecer, no art. 520, que a sentença pode produzir efeitos na pendência da apelação também quando conceder a tutela. Era neste sentido a nossa proposta de alteração do art. 520” (Luiz Guilherme Marinoni, *A Antecipação da Tutela*, 12 ed. Capítulo IV, item 4.7.2).

---

12

Sobre a possibilidade de concessão da tutela da evidência na sentença, ver comentários ao art. 811.

---

13

Ovídio Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, v. 3, p. 166.

---

14

“Les ordonnances sur référés ne ferant aucun préjudice au principal” (art. 809 do Código de Processo Civil francês de 1806).

---

15

Ferruccio Tommaseo, Intervento, p. 305.

---

16

No direito francês, fala-se diante do référé em provisoriedade da coisa julgada. Ver Louis Boré, L'autorité provisoire de la chose jugée, in L'autorité de la chose jugée (direção de Loïc Cadet e Dominique Loriferne), Paris: IRJS, 2012, p. 61 e ss.

---

17

Cf. Ferruccio Tommaseo, Intervento, p. 304-306.

---

18

Philippe Jestaz, L'urgence et les principes classiques du droit civil, p. 56 e ss.

---

19

Como diz Giuseppe Tarzia, “il punto essenziale” è che il regolamento provvisorio non ostacola il regolamento definitivo” (Giuseppe Tarzia, Considerazioni conclusive, p. 315).

---

20

Cf. Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, 2. ed., v. 11, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 122.

---

21

Cândido Dinamarco, A reforma do Código de Processo Civil, 2 ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 144.

---

22

23

“todos sabem que a concessão liminar do interdito possessório (ou sua negação, tanto faz) pode destruir o outro litigante” (Egas Moniz de Aragão, Medidas cautelares inominadas, p. 51).

---

24

“Basti per ora rilevare che il legislatore preferisce sia evitato un pregiudizio irreparabile a un diritto la cui esistenza appaia probabile anche al prezzo di provocare un danno irreversibile a un diritto che, in sede di concessione della misura cautelare, appaia invece improbabile: in altri termini, il diritto probabile prevale sul diritto improbabile” (Ferruccio Tommaseo, Intervento, p. 307).

---

25

Ver Daniel Mitidiero, Antecipação da tutela, p. 125 e ss.

---

26

De fato, a doutrina moderna aceitou a tese de que, em determinados casos, o juiz está autorizado a assumir o risco de causar um prejuízo irreversível ao réu. Cf., por exemplo, Ovídio Baptista da Silva (Curso de processo civil, v. 3, p. 108 e ss.), Alcides Munhoz da Cunha (A lide cautelar no processo civil, p. 144 e ss.) e Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (Efetividade e processo cautelar, Ajuris 61/176-177). Esse último autor assim afirmou em importante Congresso: “A meu ver, dentro do contexto específico da realidade brasileira, impõe-se realçar com mais força o valor da efetividade. O provimento cautelar, inclusive liminar, deve ser emitido mesmo à custa de uma satisfação provisória, se a situação perigosa só pode ser evitada ou minimizada com a antecipação dos efeitos da futura sentença de mérito. A tanto, aliás, autoriza o Código [de 73], ao facultar ao juiz ‘determinar as medidas adequadas’ para a prevenção do dano. Entre as duas concepções opostas que se digladiam nessa matéria, uma exigindo a contraposição dos interesses em conflito, outra privilegiando quem se apresente como provável titular do direito, inclino-me pela segunda, quando, sublinho, outra solução não puder ser encontrada para evitar o prejuízo”. (Efetividade e processo cautelar, Ajuris 61/176-177). O Ministro Eduardo Ribeiro há muito tempo argumentou: “uma situação angustiosa em que o juiz pode encontrar-se é exatamente quando isso se lhe depara: as duas soluções são irreversíveis”. (Proteção cautelar, tutela preventiva, contracautela, RTDP, v. 3, p. 123). É o que sucede em caso de apreensão de jornal. Negar a tutela antecipada, nestes casos, é impedir a tutela jurisdicional efetiva para uma série de casos conflitivos concretos e esquecer que a própria doutrina brasileira sempre admitiu o risco de irreversibilidade dos efeitos fáticos da tutela urgente.

---

27

Ferruccio Tommaseo, Intervento, p. 307.

---

28

Giuseppe Tarzia, Considerazioni conclusive, p. 309 e ss.

---

“O temor que muitos manifestam, quando se sugere a ampliação dos poderes dos juizes para conceder liminares, sob o argumento de possíveis injustiças que elas possam causar, não leva em conta a circunstância fundamental e que deveria estar sempre presente no raciocínio de quem lida com a ciência processual de não poder o julgador, jamais, conceder algum benefício a uma das partes senão à custa de seu adversário. Uma vez instaurado o litígio judicial, tanto o agir do magistrado, concedendo algum benefício a quem o postula, quanto sua omissão, ao recusá-lo, serão feitos a dano ou a vantagem da outra parte. A recusa de uma liminar é concessão de uma vantagem, às vezes decisiva, ao demandado. A neutralidade judicial é mais do que uma quimera; é uma impossibilidade lógica e prática. Os que, na esteira de Chiovenda, afirmam que o processo é um instrumento perigoso, a exigir que o juiz somente proveja com absoluta segurança, só veem perigo na mudança da situação de fato, não em sua conservação. A ideologia que inspira essas doutrinas é bem visível no repúdio às liminares” (Ovídio Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, v. 3, p. 108).

---

Como diz Giovanni Verde, segundo o pensamento iluminista as funções do Estado eram três e podiam ser distinguidas nitidamente entre si: a do Poder Legislativo, voltado à edição das leis, a do Poder Executivo, voltado à atuação concreta de todas as exigências de governo, e a do Poder jurisdicional, voltada à aplicação das leis. Havia uma tal segurança em poder traduzir em concreto este quadro que, ao início do século XIX, pensou-se, em alguns países onde o ensinamento de Montesquieu era mais vivo, até em se proibir ao juiz a interpretação da lei (Giovanni Verde. *Profili del processo civile (Parte generale)*, Napoli: Jovene, 1988, p. 39).

---

John Henry Merryman, *La tradición jurídica romano-canónica*, México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 66 e ss.

---

Ver Delosmar Mendonça Júnior, *Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil brasileiro*, São Paulo: Malheiros, 2001.

---

Ver Ferruccio Tommaseo, *Appunti di diritto processuale*, Torino: Giappichelli, 1995, p. 19.

---

“Il discorso sulla tutela dei diritti implica dunque necessariamente la riflessione sui mezzi di tutela che l'ordinamento prevede nell'ipotesi di violazione del diritto. l'argomento della tutela avrebbe mero valore declamatorio ove esso non si confrontasse con le previsioni di diritto positivo sui mezzi attraverso i quali i diritti sono tutelati” (Adolfo di Majo, *La tutela civile dei diritti*, p. 4).

---

Luiz Guilherme Marinoni, *Il diritto di azione come diritto fondamentale*, Torino: Giappichelli, 2016; Luiz Guilherme Marinoni, *Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella prospettiva della teoria dei diritti fondamentali*, p. 93-162; Luiz Guilherme Marinoni, *El derecho de acción como derecho fundamental*, Bogotá: Temis, 2015.

---

Como é evidente, o mandado de segurança jamais poderá ser admitido com a supressão do instrumento propício à tutela contra o *periculum in mora*, sob pena de deixar de ser um relevante remédio constitucional posto a serviço do cidadão para tornar-se um procedimento completamente inadequado, por pressupor urgência e não dispor de instrumento destinado a realizar uma tutela imediata para as hipóteses em que a própria sentença de cognição exauriente não se apresentar como eficaz. Se o direito que se visa a amparar através do *mandamus* requer procedimento acelerado, a possibilidade de aferição da eventual periclitación deste direito em virtude de *periculum in mora* não pode ser suprimida. De outro modo, o direito que deve ser protegido mediante a via célere, quando reconhecido, poderá jamais ter relevância no plano da realidade da vida, ocasião em que a sentença transitada em julgado e produtora de coisa julgada material adquirirá o perfil de mero adorno, a compensar a insatisfação do homem com a ineficiência da justiça e a alegrar aqueles que não desejam um processo efetivo porque têm medo das mudanças sociais que ele poderá realizar. Perceba-se, aliás, que a efetividade do processo caminha na razão proporcional inversa do uso arbitrário do poder.

---

Como já disse Donaldo Armelin, “sempre que existir a possibilidade de ocorrerem danos graves ou irreparáveis para o titular de um direito, ainda que meramente in *status assertionis* e não houver possibilidade de se incoar o processo veiculador de pretensão à prestação de tutela jurisdicional do tipo satisfativo, ou ainda sempre que o desequilíbrio entre as partes seja gritante, a tutela do tipo cautelar terá seu cabimento e indeclinabilidade garantidos” (Donaldo Armelin, *A tutela jurisdicional cautelar*, p. 116).

---

Cf. Federico Carpi, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, p. 12.

---

Pode afirmar-se, até mesmo, que as regras ora referendadas pelo art. 1.059 do Código de Processo Civil ferem o princípio da separação dos poderes. É que este princípio tem base no princípio da separação de poderes, reconhecido pela doutrina como garantia das garantias constitucionais (José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 410). Realmente, a busca pela efetividade do processo é necessidade que advém do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, indissociavelmente ligado ao *due process of law* e insito no princípio da inafastabilidade, que é garantido pelo princípio da separação dos poderes e constitui princípio imanente ao próprio Estado de Direito, aparecendo como contrapartida à proibição da autotutela privada ou ao dever que o Estado se impôs quando chamou a si o monopólio da jurisdição.

---

40

Ovídio Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, v. 3, p. 147.

---

41

Fritz Baur, Tutela jurídica mediante medidas cautelares, p. 9.

---

42

Ver acima os comentários ao art. 294, item 3, especialmente n. 3.6.

---

43

Karl Larenz, Metodologia da ciência do direito, p. 585 e ss.

---

44

Nicolò Trocker, Processo civile e costituzione, p. 406.

---

45

Ver Luigi Paolo Comoglio, La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile.

---

46

”Si è detto che il principio del contraddittorio è rispettato anche quando il provvedimento è pronunciato inaudita altera parte, purché prima che il provvedimento diventi definitivo, la parte contro cui è emesso abbia la possibilità di proporre le sue difese” (Giuseppe Martinetto, Contraddittorio (Principio del), Novissimo Digesto Italiano, v. 4, p. 461).

---

47

Galeno Lacerda, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 254 e ss.

---

48

José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, v. 4, São Paulo: Saraiva, 1974, p. 397.



## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

### **LIVRO V - DA TUTELA PROVISÓRIA**

#### **TÍTULO II - DA TUTELA DE URGÊNCIA**

##### **CAPÍTULO II. DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE**

## **Capítulo II. Do Procedimento da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente**

**Art. 303.** Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I – o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II – o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;

III – não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

### **1. Justificativa e importância do uso adequado da tutela antecipada na forma antecedente**

A tutela antecipada de caráter antecedente pode ser solicitada antes da propositura da ação mediante a qual a tutela final é postulada. A admissão desta técnica de tutela pressupõe uma situação de urgência incompatível com a demora inerente à elaboração da petição inicial da ação. Não se trata, portanto, de mera urgência “contemporânea à propositura da ação”. Na verdade, a urgência deve ser contemporânea a todo e qualquer requerimento de tutela cautelar ou antecipada, incidente ou antecedente. Não se pede tutela cautelar ou antecipada para uma urgência futura, mas para evitar um dano ou ilícito futuro. O perigo de dano ou ilícito e, portanto, a urgência, deve ser sempre presente e contemporâneo.

Esse esclarecimento é importante para que não exista abuso no requerimento de tutela antecipada na forma antecedente, na medida em que essa técnica de tutela traz várias complicações procedimentais – que podem prejudicar a efetividade da distribuição da justiça. A tutela antecipada só deve ser utilizada na forma antecedente quando a urgência for excepcional, ou seja, capaz de impedir a apresentação dos documentos necessários ao pedido de tutela final,

bem como o adequado desenvolvimento dos argumentos da causa de pedir.

## **2. Requisitos da petição inicial em que se pede tutela antecipada antecedente**

Ao requerer a tutela antecipada na forma antecedente, o autor deve esclarecer que está assim agindo em vista de excepcional urgência que não lhe permite, desde logo, apresentar os documentos e os argumentos imprescindíveis à adequada propositura da ação voltada ao alcance da tutela – final – do direito. Nessa linha, deve demonstrar que está utilizando a técnica da tutela antecipada antecedente nos termos do art. 303 e que aditará oportunamente a petição inicial (art. 303, § 5.º, CPC).

O art. 303 deixa claro que, na petição inicial, o autor pode se limitar a requerer a tutela antecipada e a indicar o pedido de tutela final, “com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Significa que, quando o autor requer tutela antecipada na forma antecedente, deve indicar o litígio, o direito que será afirmado e o pedido que formulará para obter a tutela final que pretende antecipadamente. O autor deve indicar a espécie de sentença e a tutela de direito que pretende ao final. Assim, por exemplo, sentença mandamental (ordem sob pena de multa) e tutela inibitória ou sentença condenatória e tutela ressarcitória pelo equivalente em pecúnia. Aliás, isso é imprescindível para que se possa saber se a tutela pode ser antecipada e em que limite.

A probabilidade do direito será aferida a partir da consideração dos referidos elementos que devem constar da petição inicial, que, muito embora apontem para o conteúdo da discussão a ser travada para o alcance da tutela final, têm em si o direito que deve ser demonstrado como provável. Ademais, para a obtenção da tutela antecipada, além da probabilidade do direito, é ainda necessário demonstrar o perigo de dano (art. 303, CPC).

Lembre-se que na petição inicial em que se requer a tutela antecipada na forma antecedente é preciso indicar o valor da causa, tomando-se em conta a tutela final.

## **3. Procedimento em caso de concessão da tutela antecipada na forma antecedente**

No caso em que a tutela antecipada é concedida e não se estabiliza (art. 304, CPC), o autor tem o ônus de aditar a petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2.º, CPC) e, assim, cessação da eficácia da tutela. Frise-se que o aditamento só é necessário quando a tutela antecipada não se estabiliza, ou seja, quando o réu interpõe agravo de instrumento quando intimado da efetivação da tutela antecipada. É importante perceber que o prazo para o autor aditar a petição inicial não corre a partir da intimação da concessão da tutela antecipada, uma vez que não há motivo para aditamento quando a tutela antecipada se estabiliza. A fluência do prazo para o aditamento, como é pouco mais do que evidente, deve aguardar intimação a respeito da interposição de agravo de instrumento pelo demandado.

O prazo para o aditamento, a princípio, é de quinze dias, mas o juiz pode fixar outro maior, conforme o art. 303, § 1.º, I, in fine, do Código de Processo Civil. Isso só é possível, como é óbvio, quando há justificativa de que o prazo de quinze dias é insuficiente em virtude de alguma particularidade do caso concreto. O aditamento, como não poderia ser diferente, deve ser feito nos mesmos autos e sem incidência de novas custas processuais (art. 303, § 3.º, CPC).

O autor pode aditar a petição inicial apresentando novos fundamentos para a obtenção da tutela final indicada, bem como juntando documentos. Como o autor deve apenas confirmar o pedido de tutela final, não há possibilidade de formulação de pedido de outra tutela de direito – tutela inibitória no lugar de tutela ressarcitória. Nem mesmo poderá ser pedida tutela de menor ou maior extensão quantitativa do que a tutela final indicada e deferida antecipadamente. Caso a tutela final tenha sido antecipada em parte, poderá o autor – se desejar – restringir o pedido de tutela final.

Diante do aditamento da petição inicial, deve ser feita a citação do demandado e a sua intimação para a audiência de conciliação ou de mediação, consoante o art. 334 do Código de Processo Civil. Inexistindo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do

art. 335 (art. 303, § 1.º, II e III, CPC).

A partir daí o procedimento prossegue normalmente, como se a ação houvesse sido regularmente proposta e a tutela antecipada requerida na petição inicial.

#### **4. Procedimento quando a tutela antecipada é indeferida**

Entretanto, é claro que, não obstante a tutela antecipada tenha sido requerida na forma antecedente sob o fundamento de urgência excepcional, o juiz pode negá-la. Nessa hipótese, como é evidente, também é imprescindível o aditamento da petição inicial, tendo o autor a mesma oportunidade de deduzir fundamentos e apresentar documentos e o ônus de confirmar o pedido de tutela final. A diferença em relação ao aditamento próprio à hipótese em que a tutela antecipada é concedida está no prazo, que é apenas de cinco dias – e assim pode ser dito não adequado, especialmente por ser bem menor do que o deferido para a hipótese em que a tutela é concedida, situação em que o art. 303, § 1.º, I, inclusive confere ao juiz a possibilidade de fixar prazo maior do que o de quinze dias. Afinal, o direito à participação no processo, como é sabido, tem como corolário o direito ao prazo adequado.<sup>1</sup>

Não havia motivo para o legislador utilizar a expressão “aditamento” no caso de tutela concedida e a palavra “emenda” na hipótese de tutela negada. Ora, a negação da tutela antecipada nada tem a ver com defeito da petição em que foi requerida. Como é evidente, se a petição inicial permitiu ao juiz formar convicção para não conceder a tutela antecipada, obviamente não há como vê-la como inepta.

De qualquer forma, também resta esclarecido que, não ocorrendo o aditamento ou a emenda da petição inicial, o processo é extinto sem resolução do mérito. Não há indeferimento da petição inicial, já que esta foi tão útil que permitiu ao juiz valorar os pressupostos da tutela antecipada para negá-la. Na realidade, a petição inicial só deve ser indeferida quando deixa entrever a falta de urgência capaz de adiar a adequada propositura da ação, ou seja, quando evidencia a ausência de motivo para o requerimento de tutela antecipada na forma antecedente. Porém, é certo que não foi para esta hipótese que o § 6.º do art. 303 previu o indeferimento da petição inicial. Há um simples e grosso equívoco – mais um do Código – na hipótese em que a regra fala em indeferimento da petição inicial quando o autor não a aditou depois de o juiz entender não existir “elementos para a concessão de tutela antecipada” (art. 303, § 6.º, CPC).

Como é óbvio, também no caso de aditamento posterior ao indeferimento da tutela antecipada deve ser feita a citação do réu e a sua intimação para a audiência de conciliação ou de mediação (art. 334, CPC), contando-se o prazo para contestação, na falta de autocomposição, na forma do art. 335 do Código de Processo Civil.

**Art. 304.** A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

## **1. Fundamento da estabilização da tutela**

O objetivo da regra que prevê a estabilização da tutela antecipada é, por um lado, eliminar a necessidade de discussão de uma questão que, diante da conduta do réu, não gera mais controvérsia, e, de outro, outorgar capacidade de produzir efeitos a uma decisão interna a um processo que resulta extinto sem resolução do mérito.

Portanto, se a estabilidade da tutela antecipada é o preço da inércia do demandado, esse somente é realmente pago porque se deixa claro que a tutela não impugnada produz efeitos para além do processo em que foi concedida. Ou melhor, se a razão da técnica processual é otimizar a prestação jurisdicional quando presente o desinteresse do demandado, a ideia de estabilização da tutela representa a manutenção atemporal dos efeitos da tutela.<sup>2</sup>

## **2. O problema da generalização do significado de inércia do demandado**

A técnica da estabilização da tutela envolve uma questão fundamental: a da generalização da premissa de que a inação do demandado configura desinteresse. Certamente não é possível admitir que a inércia do réu, em todo e qualquer caso conflitivo concreto, configure desinteresse e, assim, possa ter o significado de aceitação da tutela antecipada.

É importante recordar que há muito tempo, quando se discutia os efeitos da revelia, doutrina de grande respeito sustentava, com base em argumentos de natureza sociológica, a impossibilidade de se extrair da revelia a indiscutibilidade dos fatos. Dizia-se que o padrão econômico e cultural do país não permite a construção de uma premissa que supõe que todos os demandados têm condições de contratar advogados ou de compreender a necessidade de apresentar defesa.<sup>3</sup>

Em face desta argumentação, passou-se a mitigar os efeitos da revelia, permitindo-se ao juiz investigar as alegações de fatos não contestadas, especialmente quando dos documentos juntados à petição inicial e do seu contexto pudessem decorrer dúvidas sobre as alegações fáticas. O Código de Processo Civil de 2015 positivou a tese, afirmando que a revelia não gera a presunção da veracidade das alegações dos fatos quando “forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos” (art. 345, IV, CPC). Significa que o juiz não só pode considerar inverossímeis as alegações não contestadas, como ainda determinar que o autor produza prova para elucidá-las e, nesse caso, obviamente está autorizado, diante do resultado da prova, a considerá-las falsas ou até mesmo não evidenciadas.

Essa breve alusão à questão dos efeitos da revelia, como é fácil perceber, decorre da circunstância de que a técnica de estabilização da tutela, tal como desenhada no art. 304, confere à não atuação do réu efeitos que são baseados na mesma lógica dos efeitos da revelia. Parte-se da premissa de que o réu não interpôs agravo em razão de não ter qualquer interesse na discussão da questão e preocupação com os efeitos concretos da tutela antecipada.

A técnica da estabilização da tutela, em boa e adequada teoria, deve ser utilizada apenas diante de particulares situações de direito substancial ou de situações gerais que revelem a “evidência do direito”, como ocorre no procedimento monitorio. Note-se que a técnica do procedimento monitorio admite a conversão da decisão não embargada em título executivo em virtude da existência de prova escrita dos fatos constitutivos. Sucede que a técnica do art. 304, além de indiferente ao direito material, não se baseia na evidência do direito alegado. Trata-se de técnica fundada em perigo de dano, a justificar a sumarização da cognição para a concessão da tutela.

O legislador tratou mal da tutela provisória. E isso ocorreu em vários pontos, sendo este apenas um deles. Bem por isso, a doutrina tem que elaborar freios para que desastres não aconteçam. Diante da generalização dos efeitos da não atuação do demandado, é preciso que qualquer forma de reação, ainda que não o agravo de instrumento, seja vista como sinal de inconformidade com a estabilização, a determinar o prosseguimento do processo não apenas para a discussão do caso, mas para que o autor se desincumba do ônus de provar as alegações de fato que foram admitidas como prováveis. É certo que a contestação, em tese, não pode ser apresentada antes do aditamento

da petição inicial e, portanto, quando há estabilização da tutela. Mas se o autor, ao receber a intimação da efetivação da tutela antecipada, apresenta petição impugnando a forma concedida para a prestação da tutela ou a sua efetivação e, por lapso, perde o prazo do agravo de instrumento, há que se considerar a sua petição como inconformismo com a tutela antecipada. Imagine-se a hipótese de tutela inibitória antecipada, em que o juiz determina a paralisação das atividades de uma indústria quando bastaria a instalação de determinada técnica de engenharia. Se o réu imediatamente adverte o juiz de que a tutela concedida para impedir a poluição ambiental poderia e deveria ser prestada mediante um meio “mais suave”, ou seja, mediante um meio que, além de idôneo à tutela do direito constitui menor restrição à esfera jurídica do demandado, há alegação de violação à regra da proporcionalidade e obviamente manifestação de inconformismo com a tutela concedida – que, assim, não tem qualquer motivo para se estabilizar.

### **3. Se a tutela antecipada pode se estabilizar quando é requerida na forma antecedente, não existe motivo algum para não poder se estabilizar quando é requerida na petição inicial da ação em que se pede a tutela do direito**

Não fosse tal generalização, há algo que beira ao curioso no tratamento da estabilização da tutela. Diz expressamente o art. 304 que “a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável (...)”. O art. 303 pressupõe apenas tutela antecipada requerida na forma antecedente. Aliás, uma forma (antecedente) excepcional de tutela antecipada, imaginada para situações aberrantes da normalidade.

Ora, não há motivo razoável algum para se entender que apenas a tutela antecipada requerida na forma antecedente pode se tornar estável. Isso seria afirmar que somente o autor que, diante da situação de urgência, não tem tempo para elaborar adequadamente a petição inicial da ação, pode gozar dos benefícios da inércia do demandado. Entretanto, como os sistemas da tutela provisória e do próprio Código repudiam uma interpretação literal no sentido de que somente a tutela antecipada antecedente pode se estabilizar, há como evitar a contradição que uma primeira leitura apressada poderia provocar.

Ao admitir a estabilização da tutela antecipada requerida na forma antecedente, o art. 304 aceitou implicitamente a estabilização da tutela antecipada requerida na petição inicial da ação regularmente proposta. Raciocínio diverso retiraria a coerência da estabilização da tutela ou, pior do que isso, estimularia o autor a fingir que não possui documentos e oportunidade para desenvolver adequadamente a causa de pedir da ação apenas para requerer a tutela na forma antecedente.

Quando a tutela antecipada é requerida na petição inicial da ação em que se pede a tutela final do direito, a estabilização da tutela somente é possível quando deferida inaudita altera parte. Nesse caso, sendo o réu intimado da efetivação da tutela e citado para contestar mediante o mesmo mandado, a estabilização dependerá da não interposição de agravo e da não apresentação de contestação.

### **4. Requisitos para a estabilização da tutela**

A princípio, para que ocorra estabilização da tutela é preciso que o réu, devidamente intimado da efetivação da tutela antecipada, não interponha agravo de instrumento. Lembre-se que o prazo para contestar, em caso de tutela antecedente, só pode fluir após o aditamento da petição inicial. Nessa hipótese, caso o réu – intimado da efetivação da tutela – apresente petição ao juiz impugnando o cabimento da tutela antecipada e deixe de interpor o agravo, há reação ou inconformismo a justificar a não estabilização da tutela.

No caso de tutela antecipada requerida na petição inicial da ação que pede a tutela final do direito, o réu é intimado da efetivação da tutela e citado para se defender no mesmo instante, o que faz fluir um único prazo de quinze dias para a interposição do agravo e para a apresentação da contestação. Nesse caso, apresentada contestação e não interposto o agravo, há inegável reação ou não conformismo com a extinção do processo e a manutenção da eficácia da tutela concedida.

Não há necessidade de que o autor, ao lado de requerer a tutela antecipada, solicite a estabilização da tutela para o caso de ausência de reação do demandado. A estabilização da tutela é um efeito automático da falta de reação do réu.

### **5. Concessão parcial da tutela antecipada e requerimento de tutela antecipada que não abrange a integralidade do mérito**

O § 1.º do art. 304 afirma que, no caso de estabilização da tutela requerida na forma antecedente, “o processo será extinto”. Porém, como a tutela antecipada concedida liminarmente na ação que pede a tutela do direito também pode se estabilizar, nesta hipótese também há extinção do processo.

Mas o problema da extinção do processo em virtude da estabilização da tutela não é tão simples. É possível pensar, em primeiro lugar, na hipótese em que o juiz concede a tutela antecipada em parte. Estabilizada parcela da tutela antecipada, o processo não pode ser julgado (totalmente) extinto pelo simples fato de que a integralidade da tutela solicitada não foi satisfeita. O autor tem o direito de ver o processo prosseguir para que, aprofundada a cognição, possa o juiz prestar a parcela da tutela que inicialmente não foi deferida. Nesse caso, a falta de reação do demandado, suficiente para a estabilização da tutela, obviamente não basta. Para que o processo não tivesse necessidade de continuar, seria necessária uma posição ativa do réu, ou melhor, o reconhecimento jurídico do pedido.

Situação similar ocorre quando o autor requer tutela antecipada parcial, ou seja, tutela antecipada que não abrange todo o mérito ou que diz respeito apenas a um dos pedidos desde logo cumulados – ou que apenas foram indicados e que serão cumulados quando do aditamento da petição inicial. Neste caso, deferida a tutela antecipada nos limites solicitados pelo autor, o processo obviamente deve prosseguir para tratar da parte do mérito ou do pedido não contemplado pela tutela antecipada.

É claro que, nesta última hipótese, há maior problema em caso de tutela antecipada antecedente. Quando a tutela antecipada é requerida na petição inicial da ação em que se pede a tutela final do direito, todos os pedidos são imediatamente formulados, de modo que o autor obviamente pode requerer tutela antecipada parcial ou pertinente a um dos pedidos cumulados sem que alguém possa estranhar a sua pretensão de obter tutela de maior amplitude ou outras tutelas ao final do processo. Porém, quando o autor requer tutela antecipada antecedente e mais tarde pretende tutela de maior amplitude ou mesmo formular outros pedidos, deve “indicar” o pedido de tutela final e os pedidos que serão cumulados (art. 303, caput, CPC), lembrando que a tutela antecipada requerida é parcial. Isso para que não se pense que a falta de reação do demandado em relação à tutela antecipada pode levar à extinção total do processo. Frise-se que a extinção do processo, em qualquer das hipóteses antes tratadas, deve ser declarada apenas em relação à tutela antecipada.

É importante perceber que a tutela deferida e estabilizada, não obstante a não extinção total do processo, desde logo produz efeitos para além do processo. A tutela deixa de depender do processo e nele não pode mais ser discutida ou revogada. A única alternativa é propor ação “com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada”, nos termos do § 2.º do art. 304.

### **6. Efeitos temporalmente ilimitados da tutela estabilizada**

O § 3.º do art. 304 diz que a tutela conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida em ação proposta por qualquer das partes. Ademais, o § 6.º do mesmo artigo afirma que

a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes.

O que interessa, nesse momento, é compreender o significado de “estabilidade dos efeitos” da tutela. Quando se pensa em tutela antecipada, como é evidente, considera-se a própria tutela de

direito solicitada, porém concedida mediante cognição sumária. Assim, por exemplo, a tutela inibitória ou a tutela ressarcitória na forma específica, pouco importando a sentença – a técnica processual – escolhida para prestá-la.<sup>4</sup>

São os efeitos da tutela de direito material que prosseguem no tempo. Os efeitos da tutela inibitória etc. Note-se que se o juiz, por exemplo, determina a demolição de um muro que representa ato contrário ao direito (remoção do ilícito), a não reação do demandado torna a tutela de remoção do ilícito – a demolição – estabilizada atemporalmente. O mesmo ocorre quando o juiz ordena o ressarcimento na forma específica etc.

Na hipótese em que a tutela depende de um comportamento futuro imprevisível do demandado, como é o caso da tutela inibitória que ordena um não fazer, o problema não está na tutela antecipada que se estabilizou. Esse é um problema que também atinge os casos em que a tutela inibitória é concedida por sentença transitada em julgado.

Isso não quer dizer que apenas a tutela já exaurida na dimensão física se estabiliza. Uma tutela que depende de prestações periódicas, como a tutela antecipada que impõe o pagamento de soma, também pode se estabilizar. Nesse caso, a tutela antecipada mantém seus efeitos para o futuro, embora seja dependente do uso de meios de execução para a hipótese de eventual inadimplemento.

Vale dizer que, nesta última situação, a parte pode ter necessidade de requerer a aplicação de meios executivos ao juiz do processo que se extinguiu em virtude da estabilização ou mesmo ao juiz do processo que prosseguiu em razão da tutela antecipada não ter exaurido a pretensão do autor. Na segunda hipótese, o juiz pode, entendendo conveniente, determinar a autuação da execução da tutela estabilizada em apenso.

Deixe-se claro, enfim, que não é o conteúdo da decisão que se torna imutável e indiscutível. A decisão não produz coisa julgada, como anuncia o § 6.º do art. 304. É a tutela do direito que se prolonga no tempo ou, mais claramente, são os seus efeitos concretos – fisicamente exauridos ou não – que perduram.

## **7. Tutela estabilizada, declaração sumária e constituição provisória**

De lado a tutela antecipada que depende de efetivação ou que já foi efetivada, é possível indagar se há como admitir tutela antecipada estabilizada de natureza puramente declaratória e constitutiva.<sup>5</sup>

Ferruccio Tommaseo, ao tratar de questão que diz respeito à possibilidade da antecipação do efeito declaratório para atribuir ao autor o bem jurídico da certeza, afirma que há uma intrínseca inidoneidade da cognição sumária para permitir ao juiz antecipar a certeza a respeito das relações jurídicas – em que se reduz o bem jurídico outorgado pela sentença declaratória. Porém, Tommaseo sustenta que uma “declaração sumária” pode ser útil ao autor da ação declaratória para determinar o seu comportamento em face de algumas situações de direito substancial. Assim, por exemplo, a tutela requerida pelo empregador que declara antecipada e sumariamente a legitimidade da despedida de um empregado.<sup>6</sup>

Gianpiero Samorì, em ensaio intitulado “La tutela cautelare dichiarativa”, publicado na Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, advertiu que não seria possível nem mesmo uma “declaração sumária”, nos moldes preconizados por Tommaseo. Segundo Samorì, tal tipo de tutela não teria utilidade prática alguma. Para esse autor, a tutela sumária declaratória não é justificada na perspectiva funcional em vista da inidoneidade da decisão para garantir uma concreta utilidade ao autor, que não pode pretender utilizá-la como fonte de legitimação de um comportamento.

É certamente impossível a antecipação da eficácia declaratória ou conceder antecipadamente ao autor o bem da “certeza jurídica”, o qual somente é capaz de ser atribuído pela sentença declaratória. A cognição inerente ao juízo antecipatório é por natureza imprestável para atribuir



ao autor a “declaração” ou a “certeza jurídica”.<sup>7</sup> Aliás, a sentença impugnada mediante recurso igualmente não é bastante para eliminar a incerteza jurídica; só a sentença declaratória atrelada à coisa julgada material presta a tutela (declaratória)<sup>8</sup> que põe fim ao estado de incerteza, definindo a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica.

Nem mesmo a declaração sumária tem alguma utilidade, a despeito da posição de Tommaseo. No exemplo apresentado pelo processualista italiano, de “declaração sumária” da legitimidade da despedida de um empregado, não se confere qualquer efeito útil ao autor. Ora, a declaração sumária da legitimidade de um ato vale muito pouco – ou talvez nada –, quando se percebe que o juiz pode julgar improcedente o pedido declaratório ainda que já tenha, no juízo antecipatório, “declarado sumariamente” algo no sentido inverso. Se o juiz julga improcedente o pedido declaratório, fica definida a ilegitimidade do ato que na “decisão sumária” foi suposto legítimo, devendo o autor responder como se a declaração sumária não houvesse sido pronunciada. Se é assim, e se o autor não precisa de autorização judicial para, por exemplo, despedir um empregado, não há como vislumbrar alguma utilidade na “declaração sumária”. A declaração sumária certamente não legitima o ato praticado pelo autor quando a sentença é de improcedência. De modo que a despedida de alguém que goza de estabilidade, por exemplo, não se torna legítima apenas por se fundar numa “declaração sumária”. Nesse caso, proferindo-se sentença de improcedência, o autor responderá pelo ato ilegítimo como se a declaração sumária não existisse.

Já no caso de tutela antecipada em ação constitutiva, seria possível dizer que não se pode antecipar a “aquisição” de um direito ou mesmo o exercício de um direito que ainda deve ser constituído – pois dependente de uma sentença constitutiva. Estaria sendo adotada a doutrina já difundida por Calvosa, que não admite o uso do provvedimento d’urgenza para garantir o exercício de um direito que poderá ser constituído na dependência do acolhimento da ação constitutiva ou da realização de determinadas circunstâncias de fato que, no momento em que se pede a concessão da tutela de cognição sumária, não foram ainda realizadas e nem é absolutamente certo que se realizarão.<sup>9</sup> Ademais, ao se pensar numa tutela urgente do direito potestativo à mudança jurídica, poderia surgir o óbice lembrado por Satta<sup>10</sup> e reafirmado por Ovídio Baptista da Silva<sup>11</sup> no sentido de que a constituição provisória de um direito é inconcebível e contraditória.

Sabe-se que a sentença constitutiva produz um duplo efeito. Um primeiro, de natureza declaratória, sobre a existência do direito potestativo à modificação jurídica e, um segundo, que seria propriamente constitutivo, capaz de operar tal modificação na esfera jurídico-patrimonial das partes.<sup>12</sup> Se o direito potestativo requer, para produzir efeitos, uma sentença constitutiva, e assim uma atuação jurisdicional que se protraia no tempo,<sup>13</sup> não há dúvida que no tempo necessário para que seja proferida a sentença constitutiva pode ocorrer dano.

Lembre-se que o art. 282 do Código de Processo Civil italiano afirma que “a sentença de primeiro grau é provisoriamente executiva entre as partes”.<sup>14</sup> Durante os trabalhos preparatórios à reforma processual italiana, ficou clara a intenção do legislador em não limitar o art. 282 à sentença condenatória.<sup>15</sup> A questão foi debatida no Senado italiano e a proposta do senador Acone, que restringia o art. 282 à sentença de condenação, foi rejeitada sob o argumento apresentado pelo senador Lipari de que numerosas sentenças constitutivas poderiam ser beneficiadas pela norma.<sup>16</sup> Ora, aceitar que a sentença constitutiva “produza efeitos” antes do trânsito em julgado ou da formação da coisa julgada material nada mais é do que admitir uma “constituição provisória”. Trata-se de constituição fundada em cognição exauriente mas não definitiva,<sup>17</sup> o que, para efeito de provisoriedade, é exatamente o mesmo que constituição baseada em cognição sumária.

Note-se que, embora também seja impossível antecipar a eficácia constitutiva (que depende de coisa julgada material), uma constituição fundada em cognição sumária – uma cognição provisória – produz modificações no direito material que podem ser implementadas mediante meios executivos que não têm relação com o processo em que a tutela antecipada constitutiva é prestada, ou mediante atos de execução imprópria. Realmente, não há razão para impedir uma constituição fundada em cognição sumária, nem mesmo a alegação de que a sentença constitutiva produz efeitos ex nunc.

Pense-se, por exemplo, na tutela antecipada de fixação provisória de aluguel, admissível na ação revisional do valor da locação. Perceba-se que a decisão que fixa provisoriamente o aluguel não antecipa qualquer efeito executivo tendente a possibilitar a obtenção do novo aluguel. Com a fixação provisória do novo aluguel não se objetiva abrir ao autor o caminho da execução para a obtenção de soma em dinheiro, até porque sequer se supõe inadimplemento de obrigação de pagar aluguel na ação revisional. Nesse caso há somente a modificação provisória do valor da locação.

É certo que tal mutação provisória poderia não ter utilidade se, por exemplo, o locador não pudesse propor ação de despejo com base em falta de pagamento do aluguel fixado provisoriamente. Observe-se, contudo, que quando é possível extrair da tutela antecipada alguma pretensão condenatória, mandamental ou executiva, dá-se vida à constituição provisória.

De qualquer forma, a hipótese da constituição provisória do aluguel difere em muito do exemplo da declaração sumária da legitimidade da despedida do empregado, já que a fixação provisória do aluguel modifica, ainda que provisoriamente, uma relação jurídica. A decisão sumária constitutiva “opera” no plano do direito substancial, modificando uma situação jurídica, que a executividade que vem de fora do processo em que concedida a tutela antecipada pode fazer valer.

Ninguém pode pensar em termos de efetividade e não admitir a antecipação dos efeitos da constituição. Quem percebe que a utilidade buscada pelo autor da ação constitutiva está no plano dos efeitos, obrigatoriamente conclui que é viável a antecipação dos efeitos da sentença constitutiva. Deixe-se claro, no entanto, que em alguns casos – em face da situação de direito substancial controvertida – a ação constitutiva não abre oportunidade a tutela antecipada com a mesma natureza. Assim, não há como admitir tutela antecipada constitutiva ou desconstitutiva nas ações de estado. É absurdo imaginar, por exemplo, que alguém pode estar provisoriamente divorciado ou que se possa desconstituir provisoriamente o estado de filho – em ação de negação de paternidade.

Diante disso, torna-se possível cogitar sobre a estabilização da tutela antecipada constitutiva. Como visto, a tutela declaratória só tem valor quando revestida pela coisa julgada material, de modo que só isto é suficiente para evidenciar a impossibilidade de pensar a respeito de declaração sumária que se estabiliza. Não há tutela declaratória de cognição sumária; a declaração sumária não tem utilidade.

É certo que nenhuma tutela estabilizada é revestida de coisa julgada material e, por isso, jamais inibe a rediscussão do direito afirmado provável. A estabilização é da tutela de direito concedida e não do direito que foi suposto para concedê-la. Porém, a tutela declaratória, ao contrário, por exemplo, das tutelas ressarcitória e inibitória, não existe sem coisa julgada material, pois o bem da “certeza jurídica” somente pode ser atribuído pela declaração qualificada pela coisa julgada material.

Uma tutela declaratória sumária estável é uma contradição em termos, na medida em que a declaração sumária é incapaz de colaborar para a dissipação da incerteza jurídica. Note-se que a declaração sumária de que o demandado não pode praticar determinado ato só tem racionalidade quando constitui tutela inibitória, ou seja, quando não é simples declaração sumária, mas é ordem de não fazer sob pena de multa. Nesse caso, na ausência de reação do demandado, a tutela inibitória se estabiliza porque constitui uma tutela de direito que independe da coisa julgada material.

Algo diferente se passa com a tutela antecipada de natureza constitutiva. Essa pode se estabilizar porque os efeitos constitutivos ou a modificação de uma situação jurídica independem da coisa julgada material. Em outras palavras, admite-se uma constituição provisória, capaz de se projetar sobre o demandado independentemente da sua vontade. Assim, em caso de não reação à tutela antecipada que modifica o valor da locação, há estabilização da tutela ou, mais precisamente, do novo valor do aluguel. Enquanto não transcorrido o prazo de dois anos (art. 304, § 5.º, CPC), hábil a permitir a reforma ou a invalidação da tutela “constitutiva provisória”, o não pagamento do aluguel de acordo com o valor definido na tutela antecipada abre oportunidade à

ação de despejo.

## **8. Possibilidade de reforma e invalidação da tutela antecipada estabilizada**

Como já dito, afirma o § 2.º do art. 304 que “qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada”. A norma confere às partes o direito de pedir a reforma ou invalidação da tutela antecipada. Contudo, apenas o réu pode ter interesse em se voltar contra a tutela antecipada. O autor pode renunciar à tutela do direito, não tendo qualquer motivo para propor ação para reformá-la ou invalidá-la. Como é óbvio, se a tutela do direito é insuficiente ao autor, ele não fica impedido de propor ação para pleitear uma outra forma de tutela (v.g., inibitória quando antes pedida remoção do ilícito), outro modo de prestação da tutela (v.g., paralisação de atividades quando antes requerida instalação de filtro) ou a própria tutela de direito em maior extensão (v.g., ressarcitória na forma específica quando antes pedida ressarcitória pelo equivalente, ou seja, antecipação de soma). Evidentemente que sem a restrição de dois anos, prevista no § 5.º do art. 304. Ora, se a decisão que concede a tutela que se estabiliza não produz coisa julgada, o autor fica livre para pedir outro modo de prestação da tutela ou tutela que vá além da estabilizada.

Interessado em questionar a tutela antecipada é o réu, ou seja, aquele que a sofre. O § 2.º fala em “rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada”. Sucede que o rever é pressuposto do reformar e do invalidar. O réu pode propor ação para reformar – ou seja, modificar – ou para tornar a tutela antecipada destituída de validade, que assim fica sem efeitos. De qualquer forma a ação tem em conta a decisão que concedeu a tutela antecipada, objetivando demonstrar que a tutela estabilizada deve ser alterada ou não pode continuar valendo.

A ação proposta pelo réu não lhe outorga o ônus de demonstrar que as alegações dos fatos constitutivos do direito suposto como provável não são verdadeiras. A propositura da ação revela o intuito do réu em modificar ou invalidar a tutela antecipada, mas este não assume o ônus de provar que as alegações dos fatos constitutivos do direito do autor – agora réu – não correspondem à realidade. A situação é similar àquela que ocorre quando utilizada a técnica da inversão do ônus da propositura da ação principal – depois de concedida a tutela do direito com base em cognição sumária. Há inversão do ônus de propor a ação, mas o ônus da prova continua sendo de quem afirmou o direito e ainda não se desincumbiu do ônus de demonstrá-lo.

A ação do § 2.º do art. 304 logicamente abre oportunidade para tutela cautelar (art. 300, CPC), ou seja, para a suspensão dos efeitos da tutela estabilizada ou mesmo, conforme o caso, para a remoção dos seus efeitos concretos. Há de estar presente probabilidade do direito à reforma ou invalidação da tutela estabilizada e perigo de dano.

É prevento para a ação de revisão, o juízo em que a tutela foi concedida, podendo ser obtido o desarquivamento dos autos em que foi concedida a tutela – como não poderia ser de outra forma – para o alcance de dados ou documentos necessários à instrução da petição inicial (art. 304, § 4.º, CPC).

## **9. Fluência do prazo para a propositura da ação objetivando reforma ou invalidação da tutela estabilizada**

De acordo com o art. 304, § 5.º, “o direito” de reformar ou invalidar a tutela estabilizada “extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo”. Não haveria problema em relação ao prazo para o exercício do direito de pedir a reforma ou a invalidação da tutela estabilizada, não fosse a possibilidade desta tutela não contemplar a integralidade da tutela final.

Quando a tutela antecipada, requerida na petição inicial da ação em que se pede a tutela do direito ou na forma antecedente, não abrange a totalidade do pedido ou diz respeito a um dos pedidos cumulados, o processo obviamente não pode ser extinto. No caso de tutela antecedente, o autor tem direito de aditar a petição inicial para formular o pedido de tutela final e os pedidos cumulados – previamente indicados.

Ocorre que o § 5.º do art. 304 diz que o prazo para a propositura da ação voltada à reforma ou à invalidação da tutela antecipada deve ser contada “da ciência da decisão que extinguiu o processo”. Seria possível pensar, no caso de tutela estabilizada parcial, que o prazo deve ser contado da data da intimação da decisão que declara a estabilização da tutela em virtude da não reação do demandado. Porém, como a letra da lei fala de “decisão que extinguiu o processo” e a insegurança em relação a prazos é algo perverso, é adequado entender que o juiz, ao invés de simplesmente declarar a estabilização da tutela, deve extinguir o processo em relação à tutela estabilizada. Desta forma resta claro que a tutela antecipada não mais poderá ser discutida no processo, bem como que o prazo fluirá “da ciência da decisão que extinguiu o processo” em relação à tutela que se estabilizou.

#### **10. Não há coisa julgada, mas apenas extinção do direito de reformar ou invalidar a tutela estabilizada, depois de exaurido o prazo de dois anos do § 5.º do art. 304**

É certo que a decisão que concede a tutela que se estabiliza não fica acobertada pela coisa julgada material. O § 6.º do art. 304 diz expressamente que “a decisão que concede a tutela” não faz coisa julgada. Admitir a estabilização da tutela antecipada, portanto, significa apenas aceitar que os efeitos exauridos da tutela e os efeitos processuais que ainda podem ser produzidos para o seu integral alcance, não podem ser questionados sem a propositura da ação de reforma ou de invalidação da tutela.

O art. 186-bis do Código de Processo Civil italiano reproduz situação similar ao afirmar que a tutela antecipada de soma não contestada “conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo”<sup>18</sup>. O art. 186-bis, ao passar a admitir a tutela antecipada de soma não contestada em qualquer situação de direito substancial, avançou em relação ao art. 423<sup>19</sup>, que admitia a tutela de soma não contestada no âmbito do processo do trabalho, pois ao contrário do último expressamente afirmou que a tutela mantém eficácia depois da extinção do processo.<sup>20</sup>

Não obstante, a expressão “conserva la sua efficacia” deu origem a divergências na doutrina.<sup>21</sup> Enquanto alguns admitiram que a decisão se torna definitiva, transformando-se em decisão imutável, dotada de verdadeira e própria autoridade de coisa julgada material<sup>22</sup>, outros concluíram que a tutela conserva apenas a sua eficácia executiva.<sup>23</sup> Perceba-se que esta forma de tutela está muito mais próxima do julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, CPC) do que de uma tutela de cognição sumária – tutelas cautelar, antecipada e de evidência –, razão pela qual a preocupação com a imutabilidade da decisão sequer se justificaria ou, ao menos, não deveria despertar tanto receio.

Aliás, na Itália as tutelas de urgência de caráter antecipatório têm eficácia desvinculada da propositura de uma “ação principal” (art. 669-octies, 6, CPC italiano)<sup>24</sup>, mas o Código de Processo Civil expressamente afirma que a autoridade do provimento não é invocável em um outro processo (art. 669-octies, 9, CPC italiano)<sup>25</sup>. De modo que os chamados provimentos cautelares antecipatórios italianos – na mesma linha dos référés franceses<sup>26</sup> –, embora dotados de efeitos temporais indeterminados, não constituem decisões imutáveis ou que fazem coisa julgada material.<sup>27</sup>

No direito brasileiro, o § 3.º do art. 304 afirma que “a tutela antecipada conservará seus efeitos”, enquanto que o § 6.º do mesmo artigo esclarece que “a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada”. A tutela antecipada, após a extinção do processo, conserva os seus efeitos executivos. Melhor dizendo, após a extinção do processo há estabilização da tutela, ou seja, exatamente a conservação dos seus efeitos executivos e dos seus efeitos materiais exauridos.

Isso significa claramente que à estabilização da tutela não pode ser atribuído qualquer efeito preclusivo próprio à coisa julgada. O direito afirmado provável ou a questão jurídica decidida com base em cognição sumária podem ser rediscutidos pelo demandado em qualquer processo. O § 2.º do art. 304 quis apenas advertir que o demandado pode rediscutir o direito e pretender a invalidação ou a reforma da tutela. Mas obviamente não pretendeu dizer – até porque não poderia – que o demandado só pode se valer da ação do § 2.º do art. 304 para tanto.

Entretanto, existe ainda o problema do significado do § 5.º do art. 304 ou, mais precisamente, da extinção do direito de reformar ou invalidar a tutela antecipada. A impossibilidade de se pedir a revisão da decisão que concedeu a tutela antecipada para reformá-la ou invalidá-la nada tem a ver com coisa julgada. Ora, se o legislador optou por não atribuir à decisão que concede a tutela que se estabiliza a qualidade de coisa julgada material, certamente em virtude da precariedade da cognição que está à sua base, não há razão para supor que o decurso do prazo para o exercício do direito de revê-la tenha a força de conferir à decisão não revista a autoridade de coisa julgada material.

É certo que a coisa julgada material, em certos limites, é uma questão de política legislativa. É também verdade que a coisa julgada material não decorre, necessariamente, da plena e exauriente discussão do direito decidido. Ocorre que o legislador, além de ter dito que a decisão que concede a tutela não produz coisa julgada, afirmou que o esgotamento do prazo de dois anos para a propositura da ação de revisão simplesmente extingue “o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada”.

Ora, não ter mais direito de reformar ou invalidar a tutela antecipada não significa não poder mais discutir o direito que foi suposto como provável para se conceder a tutela.<sup>28</sup> Este direito pode ser rediscutido em qualquer processo, desde que não para reformar ou invalidar a tutela antecipada. Lembre-se que o art. 503, § 1.º, do Código de Processo Civil, diz expressamente que – em determinadas condições – a decisão de questão prejudicial produz coisa julgada. É claro que, no caso de tutela antecipada, não há “contraditório prévio e efetivo” (art. 503, § 1.º, II, CPC), razão pela qual este contraditório obviamente não poderia ser exigido em caso de tutela estabilizada que faria precluir a discussão de questão prejudicial decidida com base em cognição sumária. Mais claramente: a fluência do prazo de dois anos, caso gerasse coisa julgada, também impediria a discussão da questão prejudicial, não importando a falta de contraditório prévio e efetivo. Contudo, como a passagem do prazo de dois anos para o exercício do direito de revisão da tutela estabilizada não faz surgir coisa julgada, a questão jurídica decidida enquanto prejudicial à concessão da tutela não só pode voltar a ser analisada enquanto pedido ou mesmo como questão prejudicial à formulação de pedido em ação de cognição exauriente, como também pode permitir decisão inversa ou contrária sem que se possa falar em violação de coisa julgada. Assim, por exemplo, se a decisão que concedeu a tutela que se estabilizou afirmou com base em cognição sumária a responsabilidade contratual do demandado, nada impede que se chegue à conclusão, diante de outro pedido formulado pelo autor contra o demandado, que não existe a responsabilidade contratual antes admitida como provável.

Realmente, se a norma simplesmente afirma que o prazo de dois anos extingue o direito de reformar ou invalidar a tutela antecipada, não cabe pensar em qualquer efeito preclusivo próprio à coisa julgada. Há somente impedimento de rever a tutela do direito material, seja para reformar, extirpar ou remover os efeitos concretos da tutela que já se exauriu, seja eventualmente para paralisar a sua eficácia executiva.

## **11. Estabilização da tutela contra a Fazenda Pública**

De acordo com o art. 392 do Código de Processo Civil, a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis não vale como confissão. O § 1.º deste artigo afirma que a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Quer dizer que o advogado da Fazenda Pública, a menos que autorizado a confessar, não pode produzir confissão dotada de eficácia. Como diz o art. 341, I, do Código de Processo Civil, as alegações de fato feitas pelo autor, ainda que não impugnadas, não são presumidas verdadeiras quando não for admissível a seu respeito a confissão. De modo que a não contestação de fatos relativos a direitos indisponíveis não vale como confissão e, por consequência, as alegações que lhe dizem respeito, ainda que não impugnadas, devem ser investigadas pelo juiz. Assim, a não contestação atribuída ao advogado da Fazenda Pública igualmente não torna os fatos incontroversos.

Portanto, quando se pergunta se a não reação pode estabilizar a tutela antecipada diante da Fazenda Pública, tornando-a imutável depois de esgotado o prazo da ação de revisão (§ 5.º do

art. 304, CPC), cabe verificar se a não interposição do agravo de instrumento impediu o juiz de investigar alegações de fato.<sup>29</sup> Se a tutela antecipada não se baseou na probabilidade das alegações de fato serem verdadeiras não há motivo para pensar que a estabilização da tutela antecipada está a contradizer a regra que afirma que não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis nem mesmo a regra que diz que as alegações de fato não impugnadas não se presumem verdadeiras quando não podem ser objeto de confissão.

Interfere aí a regra do art. 374 do Código de Processo Civil, que diz que não dependem de prova os fatos: i) notórios; ii) afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; iii) admitidos no processo como incontroversos; e iv) em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. É evidente que os incisos II e III não se aplicam, uma vez que os fatos pertinentes a direitos indisponíveis não podem ser objeto de confissão nem podem ser vistos como incontroversos porque admitidos. Porém, no caso de fatos notórios e em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, bem como nos casos – que certamente representam a grande maioria – em que a probabilidade do direito é consequência exclusiva da resolução de uma questão de direito que não depende de investigação de alegação de fato – que se costuma chamar de questão “puramente” de direito –, certamente não há qualquer razão para não admitir a “plena” estabilização – dotada de imutabilidade – da tutela antecipada.

Nos casos em que a questão é “puramente” de direito, a não interposição do agravo de instrumento não retira do juiz a oportunidade de investigar qualquer alegação de fato, ou melhor, não elimina a possibilidade de uma instrução aprofundada – derivada do prosseguimento do processo – permitir a modificação ou a revogação da tutela liminarmente concedida.

Note-se que, no que tange aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, jamais haverá não contestação ou admissão, podendo se falar apenas em inércia de dedução. A não reação, neste caso, certamente não é uma admissão, mas uma não dedução de fatos que poderiam impedir, modificar ou extinguir o direito. Significa que a não dedução não se confunde com a confissão ou com a admissão que importa na presunção de veracidade das alegações de fato realizadas pelo autor. Portanto, a estabilização da tutela não pode ser vedada em razão de a Fazenda Pública deixar de deduzir defesa de mérito indireta. Aliás, é preciso perceber que a estabilização da tutela, além de ter como pressuposto a idoneidade – num juízo de probabilidade – dos fatos alegados para produzir os efeitos jurídicos afirmados, sempre e em qualquer caso requer a ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos releváveis de ofício.

Tudo isso quer dizer que o regime que subordina a modificação ou invalidação dos efeitos concretos e processuais da tutela antecipada a uma ação de revisão proponível no prazo de dois anos deve ser aplicado de forma diferenciada em relação à Fazenda Pública. Só a tutela antecipada que supõe probabilidade de direito a partir da análise de questão de direito que não requer investigação de alegação de fato está integralmente subordinada ao regime da estabilização da tutela. Nesse caso, a não propositura de ação de revisão pela Fazenda Pública torna a tutela estabilizada insuscetível de rediscussão e mutação.

Contudo, na hipótese em que a probabilidade do direito resulta da suposição de que as alegações de fato são prováveis, o regime da estabilização da tutela não é integralmente aplicável. A não interposição de agravo pela Fazenda Pública, qualquer que seja o caso, conduz à extinção do processo e a perdurabilidade dos efeitos da tutela antecipada até que seja proposta ação de revisão, mas a tutela antecipada baseada em fatos que não foram plenamente investigados – embora se torne estável diante da não interposição do agravo de instrumento – nunca se torna imutável diante da Fazenda Pública.

Ainda que a conservação dos efeitos da tutela em virtude da não interposição do agravo seja equivalente a atribuir efeitos a uma tutela em vista da não contestação de fatos por parte de quem não tem poder para confessar, é certo que a admissão de fatos que dizem respeito a direitos de que não se pode dispor – que exatamente por isso não vale como confissão – apenas não pode gerar a indiscutibilidade dos fatos ou equivaler a uma renúncia à discussão dos fatos. A circunstância de a Fazenda Pública ter que propor “ação de revisão” para que os fatos possam ser investigados sequer gera a inversão do ônus da prova, que continua sendo do autor da ação em que concedida a



tutela. De modo que a não interposição do agravo, ao impor a extinção do processo e a conservação dos efeitos da tutela, não tem os efeitos de uma confissão, na medida em que basta à Fazenda Pública propor ação para que o autor da primitiva ação tenha que demonstrar os fatos que foram supostos prováveis quando da concessão da tutela antecipada.

Em resumo: toda e qualquer tutela antecipada concedida inaudita altera parte – portanto ainda que não requerida na forma antecedente –, quando não impugnada mediante agravo de instrumento pela Fazenda Pública, conserva efeitos após a extinção do processo. Porém, a tutela antecipada fundada em fatos não aprofundadamente investigados, a despeito de também conservar efeitos diante da extinção do processo provocada pela inércia, não se torna imutável, o que significa dizer que o prazo de dois anos – previsto no § 5.º do art. 304 – não se aplica à Fazenda Pública.

Mas também importa aqui analisar a “remessa necessária”, prevista no art. 496 do Código de Processo Civil. A remessa necessária significa que a sentença proferida contra a Fazenda Pública, para se tornar imutável, depende de reanálise do caso pelo tribunal. Quando o art. 496 fala que a sentença não produz “efeito senão depois de confirmada pelo tribunal”, quer dizer que a sentença não produz coisa julgada senão após confirmada. É claro que os efeitos da sentença ou da decisão são produzidos independentemente da coisa julgada. Caso os efeitos da decisão não pudessem ser imediatamente produzidos contra a Fazenda Pública não haveria como ter qualquer forma de tutela urgente diante dela. Ora, não admitir que a tutela antecipada conserve efeitos diante da inércia da Fazenda Pública é não perceber que, diante dela, a tutela antecipada sempre produz efeitos independentemente de remessa necessária.

A Fazenda Pública, como qualquer outro, sempre tem à sua disposição a ação de revisão.<sup>30</sup> Proposta essa ação, a sentença proferida contra a Fazenda Pública estará sujeita, se for o caso (§§ 3.º e 4.º do art. 496, CPC), à remessa necessária. Caso a ação não seja proposta – quando necessária, ou seja, em caso de tutela antecipada em que não se tomou em conta alegação de fato dependente de posterior elucidação –, a tutela se tornará imutável e indiscutível ainda que a decisão que a concedeu não tenha sido revista pelo tribunal. Na verdade, a garantia buscada pela remessa necessária é plenamente compensada pela possibilidade de se propor a ação de revisão. Lembre-se que, nos casos em que a ação de revisão é necessária, não há que se pensar em admissão de fatos ou em confissão. O que realmente importa é que, como a própria Administração Pública fica no pleno controle da gestão dos seus casos judiciais, não há racionalidade em obrigar o particular a pagar por eventual atuação omissiva (não propositura da ação de revisão) destituída de adequação ou probidade. Isto significaria uma gritante violação da igualdade perante os procedimentos judiciais, indispensável ao desenvolvimento da vida social num Estado de Direito, alimentada por possíveis condutas desviadas dos agentes públicos. Ora, casos deste tipo, como é pouco mais do que evidente, devem ser tratados mediante investigação da responsabilidade do funcionário público e não por meio de imposição de prejuízo ao particular. Não raciocinar assim é tutelar ilegítimamente o Estado e prejudicar os jurisdicionados. Ou pior: *é desconsiderar o direito à igualdade perante o processo para preservar ou acobertar maus funcionários públicos e alimentar uma visão de Estado que não tem qualquer preocupação com o desenvolvimento da sociedade e da sua economia.*

Alguém ainda poderia dizer que a tutela antecipada não pode ser concedida contra a Fazenda Pública ou que essa sempre deve ser intimada a se pronunciar antes da concessão da tutela (art. 1.059, CPC; art. 1.º, § 3.º e art. 2.º, Lei 8.437/1992). Porém, o direito à tutela urgente é corolário do direito fundamental à tutela judicial efetiva, de modo que a lei obviamente não pode dizer que a tutela antecipada não pode ser concedida contra a Fazenda Pública. Além disso, a lei jamais pode subordinar a tutela urgente à ouvida do demandado, na medida em que a sua concessão imediata pode ser indispensável para que o direito não sofra dano – exatamente como ocorre quando é concedida inaudita altera parte e, assim, pode se estabilizar.



1

No direito italiano, Vincenzo Vigoriti extrai o direito ao prazo adequado do direito ao devido processo legal. Ver Vincenzo Vigoriti, *Garanzie costituzionali del processo civile*, Milão: Giuffrè, 1973, p. 64.

---

2

A doutrina tem produzido bastante sobre o tema da estabilização da tutela. Ver Gustavo Paim, *Estabilização da tutela antecipada*, Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2012; Daniel Mitidiero, *Autonomia e estabilização da antecipação da tutela no novo Código de Processo Civil*, *Revista de Direito Civil e Processual Civil (Magister)*, v. 63; Eduardo Talamini, *Tutela de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil: a estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro*, *Revista de Processo*, v. 209; Heitor Vitor Mendonça, *Doze problemas e onze soluções quanto à chamada “estabilização de tutela antecipada”*, p. 177 ss; Dierle Nunes e Érico Andrade, *Os contornos da estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de formação da coisa julgada*, p. 61 ss; Humberto Theodoro Jr e Érico Andrade, *A autonomização e a estabilização da tutela de urgência no Projeto de CPC*, *Revista de Processo*, v. 206; Frederico Augusto Gomes e Rogério Rudiniki Neto, *Estabilização da tutela de urgência: algumas questões controvertidas*, p. 161 ss; Weber Luiz de Oliveira, *Estabilização da tutela antecipada e teoria do fato consumado. Estabilização da estabilização?* *Revista de Processo*, v. 242; Guilherme Cardoso Antunes da Cunha, *Tutelas de urgência satisfativas autônomas*, *Revista de Processo*, vol. 227; Mirna Cianci, *A estabilização da tutela antecipada como forma de desaceleração do processo (uma análise crítica)*, *Revista de Processo*, v. 247; Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa, *Tutela de urgência definitiva? Medidas autossatisfativas (Argentina), medidas provisionais (Brasil) e a proposta de estabilização da antecipação de tutela*, *Revista de Processo*, v. 231; Bruno Garcia Redondo, *Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência antecipada antecedente: principais controvérsias*, *Revista de Processo*, v. 244; Horival Marques de Freitas Junior, *Breve análise sobre as recentes propostas de estabilização das medidas de urgência*, *Revista de Processo*, v. 225; Marcelo Pacheco Machado, *Simplificação, autonomia e estabilização das tutelas de urgência: análise da proposta do Projeto de novo Código de Processo Civil*, *Revista de Processo*, v. 202.

---

3

Eis o que dizia sobre o problema o professor Barbosa Moreira: “Quem é esse réu que perdeu o prazo? Foi voluntária a omissão? Se não foi, que lhe terá dado causa: imperfeita compreensão do chamamento ao juízo? Problema de saúde? Dificuldade em conseguir os serviços de um advogado? Impossibilidade material de remunerá-lo conforme o solicitado? Desconhecimento da existência de órgão apto a prestá-las gratuitamente? Atuação ineficiente de tal órgão, ou do advogado constituído – ou, ainda, de algum funcionário a quem a contestação foi entregue e que deixou de encaminhá-la ou de juntá-la aos autos? Veja-se que amplo leque de indagações se abre a partir daquele acontecimento de aparente (mas enganosa) singeleza. Uma infinidade de aspectos da vida social podem ser questionados com fundamento nele. Entrariam aí, a rigor, temas como o de nível de instrução do povo, o da abundância ou escassez de recursos financeiros, o da disponibilidade de serviços, o da formação profissional, o das condições de trabalho nos órgãos judiciais, e assim por diante” (José Carlos Barbosa Moreira, *Sobre a multiplicidade de perspectivas no estudo do processo*, *Revista Brasileira de Direito Processual*, v. 56, p. 19-20).

---

Sobre o ponto, ver Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual e tutela dos direitos.

---

Andrea Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, p. 195; Luigi Montesano-Giovanni Arieta, Diritto processuale civile, v. 2, p. 185-186; Giuseppe Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, p. 186-187; Federico Carpi, La provvisoria esecutorietà della sentenza, p. 59 e ss; Ferruccio Tommaseo, I provvedimenti d'urgenza, p. 257; Gianpiero Samori, La tutela cautelare dichiarativa, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1995, p. 949 e ss.

---

“Se é, então, verdadeira aquela doutrina segundo a qual não pode ser antecipado o efeito declaratório da sentença de mérito, não obstante nos podem perguntar se não é suficiente, para o fim de satisfazer provisoriamente o interesse do requerente, a obtenção daquela certeza de grau mais modesto que resulta na valoração em termos de probabilidade do *fumus boni iuris* afirmado pela parte. Sem dúvida, a concessão da tutela urgente é subordinada, aqui como nos outros casos, à irreparabilidade do prejuízo e à idoneidade da medida para remediar o perigo de dano. Foi visto que a situação de incerteza pode ser indicadora de prejuízo irreparável, mas se pode duvidar se a valoração em termos de mera verossimilhança do direito do requerente seja por si só idônea para remediar o prejuízo e para justificar um apreciável interesse do requerente em obter em sede urgente a antecipação da mera declaração. Os exemplos retirados da jurisprudência mostram que tal interesse pode surgir em concreto quando a parte esteja em condições de valer-se do *dictum* judicial para determinar o seu próprio comportamento em vista de particulares situações de direito substancial. Assim, a tutela urgente de mera declaração se apresenta no seu conteúdo mais restrito e, ao mesmo tempo, mais significativo lá onde o requerente pede ao juiz a valoração em sede de cognição sumária da legitimidade de um próprio ato. Assim, a tutela de urgência pode conter a valoração antecipada da nulidade da cláusula de um contrato ou de um estatuto societário. Nestes casos, sempre que subsista em concreto um prejuízo irreparável para ser eliminado, o interesse da parte parece encontrar satisfação também em uma forma atenuada de certeza, fundada sobre um juízo de mera verossimilhança. A ação de conhecimento que a parte terá o ônus de propor servirá para transformar a probabilidade em certeza e para produzir aquele efeito declaratório que apenas impropriamente, como foi visto, pode ser dito antecipado em sede de cognição sumária” (Ferruccio Tommaseo, I provvedimenti d'urgenza, p. 257).

---

Ferruccio Tommaseo, I provvedimenti d'urgenza, p. 257.

---

As sentenças declaratória e constitutiva não podem ser enquadradas na classificação das tutelas dos direitos, uma vez que, assim como a sentença condenatória, constituem apenas técnicas para a tutela do direito material. O problema é que, se as tutelas dos direitos podem ser facilmente separadas das sentenças condenatória, mandamental e executiva, o mesmo não acontece quando se está diante das tutelas declaratória e constitutiva e das sentenças declaratória e constitutiva. Isso porque, se obviamente não existe tutela condenatória, mandamental e executiva, há tutela declaratória e tutela constitutiva. Ou

seja: as sentenças declaratória e constitutiva prestam tutelas declaratória e constitutiva. Se alguém pode ter, no plano do direito material, direito à tutela pelo equivalente ao valor do dano ou da obrigação, e, no plano do direito processual, direito à sentença condenatória, isso não significa que não se possa ter direito a uma tutela do direito que possa ser prestada mediante uma sentença satisfativa, cujo nome seja idêntico ao da tutela devida na dimensão do direito material. O fato de não ser possível obrigar alguém a reconhecer uma relação jurídica ou a desconstituir um contrato, ou mesmo a circunstância de não ser possível constituir determinadas situações jurídicas fora da jurisdição, certamente não interfere no problema, pois não descarta a possibilidade de alguém ter direito e pretensão às tutelas declaratória e constitutiva no plano do direito material e, assim, exigí-las mediante as sentenças declaratória e constitutiva. Ver Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, v. 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, v. 1, Parte II, Capítulo 5, item 5.5.

---

9

Carlo Calvosa, *I provvedimenti d'urgenza*, *Novissimo digesto italiano*, v. XIV, p. 448 e ss.

---

10

Salvatore Satta, *Commentario al Codice di Procedura Civile*, v. 4, p. 270 e ss.

---

11

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, v. 3, p. 57 e ss.

---

12

Ferruccio Tommaseo, *I provvedimenti d'urgenza*, p. 262.

---

13

*Idem*, p. 264.

---

14

Art. 282. “Esecuzione provvisoria [1] La sentenza di primo grado e provvisoriamente esecutiva tra le parti”.

---

15

Cf. Bruno Lasagno, *Le riforme del processo civile* (a cura di Sergio Chiarloni), p. 342.

---

16

*Idem*, p. 343.

---

17

Adverte Domenico Borghesi que a execução imediata da sentença de primeiro grau “rappresenta un caso in cui l’esecutività consegue a una cognizione non definitiva che si differenzia in modo netto da quelli precedentemente esaminati perché la cognizione, pur non essendo definitiva, nel senso che la sentenza può essere riformata nei successivi gradi di giudizio, è tuttavia piena ed esauriente” (Domenico Borghesi, *L’anticipazione dell’esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1991, p. 197).

---

18

O texto do art. 186-bis, que se vale da técnica da não contestação para a formação antecipada do título executivo judicial, reproduz a fórmula do projeto provisório de reformas urgentes do processo civil – redigido por Fabbrini, Proto Pisani e Verde em nome da “Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile” –, assim como disposição do Projeto Rognoni. Sobre o Projeto Rognoni, ver Edoardo Ricci, *Il progetto Rognoni di riforma urgente del processo civile*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1987, p. 628 e ss.

---

19

Sobre o art. 423 do Código de Processo Civil italiano, consultar Giuseppe Tarzia, *Manuale del processo del lavoro*, Milano: Giuffrè, 2008, 1987; Luigi Montesano e Romano Vaccarella, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli: Jovene, 1989.

---

20

Na verdade, a disposição do art. 186-bis diferencia-se da disposição que serve ao processo do trabalho nos seguintes pontos: i) a não contestação deve vir de uma parte que constituiu advogado em juízo, enquanto que a norma do processo do trabalho abria oportunidade para a discussão sobre se a “contumacia” do réu poderia configurar hipótese de não contestação; ii) a “ordinanza”, no processo de conhecimento, é modificável e revogável, não podendo prejudicar a decisão sobre o mérito; argumentava-se, no processo do trabalho, mediante uma determinada interpretação do art. 423, que a “ordinanza” não poderia ser modificada ou revogada; iii) de acordo com a nova disposição, a “ordinanza” não pode ser pronunciada em qualquer fase do processo, como acontecia no processo do trabalho; iv) a “ordinanza” conserva eficácia mesmo após a extinção do processo, o que não era especificamente previsto pelo art. 423. Ver Edoardo F. Ricci, *I provvedimenti interinali e cautelari*, in *La riforma del processo civile*, Milano: Giuffrè, 1991, p. 52; Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, Bologna: Il Mulino, 1995, p. 588; Domenico Borghesi, *L’anticipazione dell’esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, p. 193.

---

21

“Il problema – è evidente – sta tutto nel significato da attribuire all’espressione ‘conserva la sua efficacia’, nessun dubbio potendosi avanzare sul fatto che il concetto di estinzione è comprensivo sia della renuncia agli atti che dell’inattività delle parti” (Gabriella Rampazzi, *Le riforme del processo civile* (a cura di Sergio Chiarloni), p. 238). Ver Filippo Colli, *L’ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1994, p. 554.

---

22

23

Giuseppe Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, p. 135; Crisanto Mandrioli, Le nuove ordinanze 'di pagamento' e 'ingiunzionale' nel processo ordinario di cognizione, *Rivista di Diritto Processuale*, 1991, p. 649; Aldo Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, Cedam, 1991, p. 94; Luigi Montesano e Giovanni Arieta, Il nuovo processo civile, Napoli: Jovene, 1991, p. 54; Claudio Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Torino: Giappichelli, 1992, p. 123; Gabriella Rampazzi, Le riforme del processo civile (a cura di Sergio Chiarloni), p. 238-240.

---

24

Ver Antonio Carrata, Profili sistematici della tutela cautelare, I procedimenti cautelari, Bologna: Zanichelli, 2013.

---

25

Giovanni Bonato, Tutela anticipatoria di urgenza e sua stabilizzazione nel nuovo c.p.c. brasiliano: comparazione con il sistema francese e con quello italiano, *Revista de Processo Comparado, Revista dos Tribunais*, v. 4.

---

26

No direito italiano, a doutrina há algum tempo alude à técnica do *référé* para sustentar a importância de uma forma de tutela provisória dotada de eficácia executiva e não marcada pela coisa julgada. Ver Remo Caponi, La tutela sommaria nel processo societario in prospettiva europea, in *Studi in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano: Giuffrè, 2005, vol. 3, p. 1.605 e ss; Sergio Menchini, Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato, *Rivista di Diritto Processuale*, 2006, p. 869. No direito francês, sobre a inexistência de coisa julgada no *référé*, ver Louis Boré, L'autorité provisoire de la chose jugée, in *L'autorité de la chose jugée* (direção de Loïc Cadiet e Dominique Loriferne), p. 61 e ss; Cécile Chainais, La protection juridictionnelle provisoire dans le procès civil en droit français et italien, p. 294.

---

27

Ver Roberta Tiscini, I provvedimenti senza accertamento, Torino: Giappichelli, 2009; Bruno Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, Milano: Giuffrè, 2014, p. 645 e ss.

---

28

Giovanni Bonato, Tutela anticipatoria di urgenza e sua stabilizzazione nel nuovo c.p.c. brasiliano: comparazione con il sistema francese e con quello italiano, *Revista de Processo Comparado, Revista dos Tribunais*, v. 4.

---

29

No direito italiano, sobre o problema da tutela antecipada baseada em não contestação diante de direitos indisponíveis, ver Andrea Proto Pisani, I provvedimenti anticipatori di condanna, p. 397; Giuseppe Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, p. 135

---

30

Lembre-se que, quando a tutela antecipada é deferida com base na probabilidade de alegação de fato dependente de posterior elucidação, a Fazenda Pública não está sujeita ao prazo de dois anos para a ação de revisão.

© desta edição [2018]

## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

### **LIVRO V - DA TUTELA PROVISÓRIA**

#### **TÍTULO II - DA TUTELA DE URGÊNCIA**

##### **CAPÍTULO III. DO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE**

### **Capítulo III. Do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente**

**Art. 305.** A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

#### **1. Distinção entre o procedimento da tutela cautelar antecedente e o procedimento da tutela antecipada antecedente**

No caso de tutela antecipada antecedente não há contestação do pedido de tutela. Esta é concedida ou negada em face apenas da petição inicial em que requerida a tutela antecipada. O réu só é citado quando a inicial é aditada, tenha a tutela sido concedida ou negada. No caso de não ter sido possível a autocomposição, o réu poderá apresentar contestação para se contrapor ao pedido de tutela final e aos seus fundamentos.

Algo bem diverso sucede em caso de tutela cautelar antecedente. Nessa hipótese, além de não se exigir a indicação do pedido de tutela final na petição em que é requerida a tutela de urgência, fala-se expressamente em contestação do pedido cautelar (arts. 306 e 307, CPC) e, a par disso, esclarece-se que o pedido principal deve ser apresentado apenas quando a tutela cautelar for efetivada – não bastando a sua concessão e pouco importando a sua negação (art. 308, CPC). Só quando efetivada a tutela cautelar o autor terá o ônus de apresentar o pedido principal e a causa de pedir – embora a norma fale, por lapso, em aditá-la (art. 308, § 2º, CPC). Diante deste novo pedido, caso não se chegue à autocomposição, o réu novamente terá oportunidade de contestar – desta vez o pedido de tutela principal (art. 308, §§ 3º e 4º, CPC). Como está claro, o réu tem duas oportunidades para contestar: uma para contestar o pedido de tutela cautelar e outra para contestar o pedido de tutela “principal” e seus fundamentos. Ademais, o juiz deve julgar o pedido de tutela cautelar à luz do contraditório travado entre os litigantes e não apenas decidir sobre o requerimento de tutela urgente em face de argumentos exclusivamente do autor – como ocorre no caso de tutela antecipada antecedente.

Tudo isso quer dizer, bem vistas as coisas, que há um mérito cautelar, autônomo em relação ao mérito “principal”. Aliás, curiosamente nada se fala acerca de tutela cautelar antes da ouvida do réu, como se esta só pudesse ser concedida depois da oportunidade de defesa ao demandado. Na realidade, o procedimento da tutela cautelar antecedente, embora também viabilize a apresentação do pedido principal, claramente conserva a autonomia do mérito cautelar – que não se confunde com autonomia procedimental.

Tanto existe um mérito cautelar que o réu é chamado a contestar o pedido cautelar e a indicar as provas que pretende produzir (art. 306, CPC). Mais do que isso: afirma-se que os fatos que amparam o pedido de tutela cautelar devem ser admitidos como ocorridos em caso de não apresentação de contestação (art. 307, CPC). É óbvio que estes fatos dizem respeito tanto ao perigo



quanto ao direito que se busca assegurar, o que evidencia de modo incontestável a existência de um litígio cautelar a ser resolvido.

## **2. Ações cautelar e principal num único processo e ação única com requerimento de tutela antecipada antecedente**

É indiscutível que não há uma tutela antecipada autônoma em relação à tutela final. Substancialmente, a tutela antecipada é a tutela final. O que as distingue é a cognição e a convicção com base em que são concedidas. A tutela prestada mediante a técnica antecipatória, que se diz antecipada, é a tutela do direito, ou seja, a tutela final prestada com base em juízo de probabilidade.

Exatamente por isso não há uma ação que almeja a tutela antecipada e outra ação que busca a tutela final. Há apenas uma ação em que se pede a tutela do direito – que pode ser concedida ao final ou antecipadamente. Prova eloquente disso é o ônus do autor formular o pedido principal, mesmo que indeferida a tutela antecipada, para que o processo não seja extinto sem resolução do mérito.

A tutela cautelar obviamente não se confunde com a tutela do direito ou com a tutela assegurada. A chamada tutela cautelar antecedente sempre depende de uma ação própria destinada à sua obtenção. Note-se que, em caso de tutela cautelar, a formulação do pedido principal só constitui ônus do autor quando a tutela é concedida e efetivada. A tutela cautelar não constitui mera técnica instituída em favor da efetividade da ação, quando pouco importaria o seu indeferimento para o efeito do prosseguimento da ação em busca da tutela do direito material.

Não há como pensar que, em caso de tutela cautelar antecedente, há um mero requerimento de tutela cautelar que, quando efetivada, passa a depender do requerimento de tutela principal. A tutela cautelar e a “tutela principal” dependem de ações específicas, cada uma delas com suas particularidades e técnicas processuais diferenciadas. Além de o pedido cautelar e o pedido principal serem contestados e decididos autonomamente, a tutela cautelar pode ser concedida tanto antes da ouvida do réu – técnica antecipatória em favor da tutela cautelar – quanto depois da contestação ao pedido cautelar e aos seus fundamentos. É claro que, nesta perspectiva, a ação é vista em sua adequada dimensão, ou seja, como a ação que é exercida mediante técnicas processuais idôneas ao alcance da tutela jurisdicional, e não apenas como um mero direito à resolução do mérito.<sup>1</sup>

Imaginar que existe apenas uma ação voltada ao alcance da tutela cautelar e, eventualmente, da tutela do direito assegurada, significa ter uma ação cautelar que, sob duas condições – efetivação da tutela e dedução do pedido e da causa de pedir pelo autor –, pode permitir o alcance da tutela de direito assegurada. Sucede que a segunda “condição” é o exercício da pretensão à tutela do direito, ou seja, exatamente a ação principal.

Na realidade há um procedimento com duas ações: a primeira cautelar e a segunda principal – mas eventual, sujeita à efetivação da tutela cautelar. Não é comum uma ação ser proposta no curso de um procedimento, embora isso seja tecnicamente possível.

## **3. Diferença da urgência que legitima a tutela cautelar na forma antecedente**

A tutela antecipada, por ser apenas a tutela final prestada mediante cognição sumária, a princípio não tem qualquer motivo para não ser requerida incidentalmente ao processo em que se busca a tutela final. É por isso que a tutela antecipada antecedente é fruto de uma situação excepcional, em que a urgência impede o autor de dispor dos documentos necessários ou de elaborar adequadamente os argumentos para propor a ação em que deve pedir a tutela do direito e requerer a sua antecipação.

Contudo, a urgência que legitima a tutela cautelar antecedente nada tem a ver com impossibilidade de elaborar adequadamente a petição inicial da ação em que se pede a tutela do direito. A ação cautelar antecedente faz parte da tradição do direito processual brasileiro. A tutela

cautelar pode ser requerida na forma antecedente até mesmo para assegurar a tutela jurisdicional de um direito que pode vir a ser lesado, quando, portanto, ainda sequer há interesse de agir no pedido de tutela principal. Pense-se no pedido cautelar de caução para a hipótese de dano temido e, desta forma, cabimento de pedido de tutela ressarcitória. Note-se que a tutela cautelar nem sempre assegura um direito já violado, que, portanto, pode já ter sido afirmado para legitimar o interesse de agir na ação ressarcitória. Aliás, mesmo que a tutela cautelar não objetive assegurar direito para a hipótese da sua violação, mas vise apenas assegurar a tutela repressiva de um direito já violado, nada impede o seu requerimento na forma antecedente. Ora, não é difícil imaginar a situação em que um direito já foi objeto de dano e, portanto, desde logo pode justificar a propositura de ação ressarcitória, mas o lesado, antes de aforar a ação de ressarcimento, pretende assegurar o direito à obtenção da efetiva tutela do seu direito em vista do claro perigo de o infrator desviar o seu patrimônio para frustrar a frutuosidade do ressarcimento.

#### **4. Requisitos da petição inicial da tutela cautelar antecedente**

A petição em que é requerida a tutela cautelar antecedente deve indicar o litígio principal e a causa de pedir que deve sustentar o pedido de tutela principal. Também deve demonstrar a probabilidade do direito que se pretende assegurar e igualmente apresentar detidamente o perigo de dano. Perceba-se que não se trata exatamente de uma exposição “sumária” ou resumida do direito cautelando, mas de uma exposição que, embora deva convencer o julgador da probabilidade do direito, deve ser tão bem fundamentada e adequada quanto qualquer exposição que pretenda convencer o juiz.

#### **5. Fungibilidade das tutelas cautelar e antecipada**

Afirma o parágrafo único do art. 305 que, caso o juiz entenda que a tutela requerida na forma antecedente tem natureza antecipada e não cautelar, poderá diretamente observar o disposto no art. 303, ou seja, considerar que o autor requereu tutela antecipada – ainda que a tenha chamado de cautelar.

A possibilidade de conceder determinada forma de tutela urgente quando solicitada outra era uma solução prática na época do código de 1973, quando não se admitia tutela cautelar incidente e, por esse motivo, ampliava-se o conceito de tutela antecipada para permitir a busca de tutela urgente independentemente da propositura de ação autônoma. Atualmente, como já explicado nos comentários ao art. 294, não há motivo para não bem delinear as figuras das tutelas cautelar (de segurança) e antecipada (satisfativa), de modo que a eventual confusão razoável entre as tutelas é praticamente nula.

De qualquer forma, o legislador quis premiar o autor que equivocadamente requer tutela antecipada sob o rótulo de cautelar, dando-lhe a oportunidade de ver os trilhos do procedimento pertinente à tutela substancialmente pleiteada utilizados pelo juiz. Porém, se isto está escrito na lei, certamente não há motivo para não admitir o inverso, ou seja, a possibilidade de o juiz entender que o pedido de tutela equivocadamente batizada pelo autor como antecipada seja processado mediante o procedimento e sob as técnicas processuais idealizados para a tutela cautelar.

#### **6. Concessão da tutela cautelar antes da citação do réu**

O art. 802, parágrafo único, do Código de 1973 dizia que o prazo de contestação poderia ser contado da data da juntada aos autos i) do mandado de citação devidamente cumprido ou ii) do mandado de execução da tutela cautelar, quando concedida liminarmente ou após justificação prévia. É certo que o prazo de contestação deve, em qualquer hipótese, ser contado a partir do momento em que o réu é comunicado do seu prazo para tanto. Aliás, a interpretação do parágrafo único do art. 802 do código de 1973 era no sentido de que, em caso de efetivação da tutela antes da ouvida do réu, o prazo para contestação era de cinco dias da juntada aos autos do mandado (formalmente único) de citação e de “execução” da tutela. Porém, o que se pretende deixar claro é que o fato de haver omissão, entre os artigos 305 e 310, sobre a possibilidade de concessão de tutela cautelar antes da ouvida do réu e o art. 306 nada dizer sobre a contagem do prazo para

contestar quando a tutela é efetivada antes da citação, não significa que a tutela cautelar não possa ser concedida inaudita altera parte quando necessário.

Ora, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva impõe a concessão de tutela urgente, mesmo antes da ouvida do réu, quando imprescindível à tutela do direito material. Embora a regra deva ser a da ouvida do demandado, a tutela cautelar e a tutela antecipada podem ser concedidas inaudita altera parte quando a audiência do réu puder inviabilizar a segurança ou a satisfação do direito, seja em razão da demora na sua convocação, seja porque ele, ciente do requerimento da medida, possa frustrar a tutela adequada do direito buscado pela parte contrária.

A Corte Constitucional italiana já declarou que a tutela de urgência representa um componente essencial e ineliminável da tutela jurisdicional nos limites em que necessária para neutralizar um perigo de dano.<sup>2</sup> Aliás, a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – não pode ser proibida nos lugares em que é necessária para evitar dano. Não apenas porque a lei não pode prever as situações em que a tutela de urgência será necessária – uma vez que isso depende do caso concreto –, como também porque o direito à tutela de urgência é corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional. Assim, a tutela cautelar pode e deve ser concedida, evidentemente que mediante a adequada justificativa, quando as circunstâncias do caso demonstrarem a sua necessidade antes da ouvida do demandado.

**Art. 306.** O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

### **1. Procedimento acelerado**

O prazo de cinco dias, conferido à apresentação de contestação, indica que o procedimento pertinente à tutela cautelar é acelerado, ou seja, mais abreviado do que o procedimento comum. A aceleração do procedimento, apesar de ter origem na mesma razão que justifica a sumarização da cognição, com essa última não se confunde. A suficiência da convicção de probabilidade para a prestação da tutela jurisdicional associa-se à celeridade da prática dos atos processuais em nome da tutela urgente, mas isto obviamente não quer dizer que não possa existir procedimento acelerado que não confere ao juiz poder para decidir com base em probabilidade. Procedimento célere – ou formalmente sumário – não se confunde com procedimento de cognição sumária.<sup>3</sup>

### **2. Contestação e defesa**

O réu é citado para contestar. Não obstante, obviamente também pode apresentar “petição específica” para arguir a incompetência ou a suspeição do juiz, nos termos dos arts. 144, 145 e 146 do Código de Processo Civil. É claro que as alegações de suspeição e impedimento, caso não tenham sido feitas, podem voltar a ser apresentadas quando da apresentação de defesa ao pedido principal (art. 308, § 4º, CPC). Lembre-se, aliás, que não há preclusão da alegação de impedimento. Tendo em vista que a alegação de decisão proferida por juiz impedido constitui fundamento para a ação rescisória (art. 966, II, CPC), não há racionalidade em privar a parte de alegar impedimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Contudo, não há como admitir reconvenção diante do pedido de tutela cautelar em virtude da própria natureza desta tutela, incompatível com a demora inerente à forma reconvenicional.

Na contestação o réu pode deduzir defesa de mérito e defesa processual. A defesa processual pode articular qualquer preliminar que, respeitante à ação ou ao processo, possa obstaculizar a apreciação do mérito cautelar. A defesa de mérito diz respeito à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Assim, pode negar os fatos constitutivos do direito dito provável, pode deduzir fatos impeditivos, modificativos ou extintivos deste direito, bem como ainda pode negar os fatos que representam o afirmado perigo de dano.

Perceba-se que a defesa de mérito não precisa convencer o juiz de que o direito não existe, uma vez que se situa na dimensão da probabilidade. Os argumentos alinhados para negar os fatos constitutivos do direito provável, assim como para sustentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos deste direito, são dirigidos a convencer o juiz de que o direito não é provável. Portanto,

o réu pode se valer de todas as defesas que podem ser opostas ao “pedido principal”, mas apenas para demonstrar a inexistência de probabilidade do direito.

### **3. Provas admissíveis**

O réu tem o direito à plena defesa, ou melhor, o direito de contestar adequadamente o pedido de tutela cautelar. Não há qualquer restrição ao direito de invocar argumentos e apresentar provas hábeis a impedir a tutela cautelar. Sumária é a cognição judicial bastante à decisão sobre o pedido de tutela cautelar. Portanto, o réu tem o direito de invocar as defesas e produzir as provas que lhe permitam convencer o juiz de que a tutela não deve ser concedida.

Lembre-se que o juiz, para julgar improcedente o pedido e negar a tutela cautelar, não pode exigir um grau de convicção que lhe permitiria chegar à conclusão de que o direito afirmado pelo autor não existe. A discussão relativa à tutela cautelar ocorre no plano da probabilidade do direito. Exatamente por isso as partes não têm razão para produzir provas mais elaboradas, que, além de inadequadas à formação do juízo de probabilidade, são incompatíveis com a urgência que legitima a tutela cautelar.

Embora o art. 306 não restrinja as provas admissíveis, essas logicamente devem ser próprias aos juízos de probabilidade e de urgência. Devem ser aptas a permitir a verificação da existência do perigo e à formação de juízo limitado à probabilidade do direito. Toda e qualquer prova capaz de permitir a formação de juízo apto à tutela definitiva do direito cautelando é um excesso.

### **4. Reconhecimento da procedência do pedido**

Entretanto, além de apresentar defesa ou permanecer inerte, o réu pode reconhecer a procedência do pedido. O reconhecimento só tem relevância quando a tutela que se almeja assegurar diz respeito a direitos disponíveis, não acontecendo o mesmo quando a providência cautelar objetivada visa a assegurar direitos indisponíveis.

Recorde-se que o reconhecimento da procedência do pedido não se confunde com a não apresentação de contestação. Diante do pedido de tutela cautelar, a não apresentação de contestação faz surgir o efeito da presunção da probabilidade dos fatos afirmados na inicial (art. 307, CPC). Daí não decorre a conclusão automática de que o pedido cautelar deva ser julgado procedente. Ao reconhecer a procedência do pedido o réu não se limita a admitir os fatos articulados pelo autor como prováveis, porém reconhece o pedido de tutela cautelar, tomando-o como legítimo e procedente.

O reconhecimento do pedido redundará na vinculação do magistrado à procedência do pedido cautelar. Mas não basta ao juiz simplesmente homologar o reconhecimento do pedido, devendo dar ao réu prazo breve para eliminar a situação de perigo, sob pena de determinar a efetivação da tutela cautelar reconhecida.

**Art. 307.** Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

#### **1. Pedido de tutela cautelar e efeitos da revelia**

O art. 307 reproduz a ideia contida no art. 344, que afirma que, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Enquanto o art. 344 diz que a não apresentação de contestação, isto é, a revelia, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados, o art. 345 elenca exceções a este efeito da revelia, aplicáveis em face da tutela cautelar.

A existência de revelia deriva da caracterização do estado de inação quanto ao oferecimento da contestação. É uma situação processual da qual decorrem efeitos – de ordem material e processual –, sendo a presunção de veracidade das alegações de fato apenas um deles. Só é possível saber se a revelia ensejará a realização completa ou parcial de seus efeitos mediante a avaliação das várias

circunstâncias que em torno dela orbitam. O réu pode ser revel sem sofrer o efeito da presunção da veracidade das alegações de fato, conforme deixa claro o art. 345, especialmente o seu inciso IV, que nega a possibilidade de o juiz admitir a presunção quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”. Imagine-se, por exemplo, que o autor, ao instruir a petição inicial, junte documento totalmente contrário ao seu interesse ou que demonstre o pagamento da dívida pelo réu. Ainda que o réu seja revel, o juiz certamente há de considerar a presença do documento ou do comprovante de pagamento e, com isso, afastar a incidência da presunção legal, aplicando o art. 345, IV. Na verdade, a presença de qualquer elemento que conflite com a aplicação *tout court* da presunção material da revelia deve afastar sua incidência, fazendo preponderar a realidade sobre a ficção.

De lado a circunstância de que da ausência de contestação não decorre a automática falta de obrigação de o juiz verificar as afirmações fáticas do autor, há uma circunstância, particular à tutela cautelar, que impede que se admita uma presunção de veracidade dos fatos alegados. É que a tutela cautelar não reclama um juízo de veracidade acerca dos fatos, mas apenas um juízo de probabilidade. Ora, se o autor não tem pretensão de convencer o juiz da veracidade dos fatos que alega, e ao réu basta demonstrar que o direito ameaçado não é provável, a ausência de contestação jamais poderá redundar na presunção de veracidade, mas, no máximo, na presunção de probabilidade dos fatos alegados na petição inicial.

A falta de contestação só pode gerar um efeito compatível com a discussão travada no âmbito da tutela cautelar, precisamente a presunção de probabilidade das alegações de fato. Portanto, o art. 307 deve ser interpretado no sentido de que a não apresentação de contestação presume os fatos “ocorridos” para o efeito de permitir o juízo suficiente – de probabilidade – para a concessão da tutela cautelar.<sup>4</sup> Aliás, raciocinar de forma contrária implicaria equívoco grosseiro, já que faria surgir uma qualidade de convicção judicial que sequer pode ser formada dentro dos limites inerentes à tutela cautelar.

A não contestação faz surgir a presunção de probabilidade dos fatos, mas não elimina a possibilidade de o juiz confrontar tais fatos com a situação concreta e, inclusive, determinar o imediato comparecimento das partes em juízo.

## **2. Apresentada a contestação será observado o procedimento comum**

O parágrafo único do art. 307 diz que, apresentada contestação no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. O procedimento, em seu aspecto formal, passa ser o comum – menos acelerado –, mas isto obviamente não interfere sobre a cognição – que continua a ser sumária – ou sobre a convicção suficiente para a resolução do mérito cautelar.

Essa regra deve ser complementada com a advertência de que, uma vez efetivada a tutela cautelar – inclusive a concedida antes da ouvida do réu –, o pedido principal deverá ser apresentado “nos mesmos autos” no prazo de trinta dias. Neste caso, o procedimento, diante da ação principal – ou da dedução do pedido de tutela principal – proposta na pendência do processo instaurado com a ação cautelar, deve observar as regras dos §§ 3.º e 4.º do art. 308.

Quando a tutela cautelar foi deferida antes da ouvida do réu e, por conta disso, a ação principal é proposta antes do julgamento do pedido cautelar, passa a existir um único procedimento voltado a regular a maneira como se deve proceder para preparar o juízo sobre o pedido de tutela cautelar e o juízo sobre o pedido principal. Ainda que na prática – da época do Código de 1973 – a tendência sempre tenha sido a de julgar o pedido cautelar conjuntamente com o pedido principal, isto não é correto, uma vez que a cognição – sumária – da tutela cautelar não se confunde com a cognição – exauriente – da tutela principal. Basta perceber que as provas pertinentes ao juízo sumário são distintas das provas hábeis à formação da convicção de certeza, típica à cognição exauriente. A parte que sofre a tutela cautelar tem direito de ver o pedido de tutela cautelar julgado em prazo adequado ao juízo de cognição sumária, que obviamente não pode ser o prazo para a resolução do pedido de tutela principal.

**Art. 308.** Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de

30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

## **1. Duas ações e um processo**

O art. 308 afirma que, uma vez efetivada a tutela cautelar, o autor deve deduzir o pedido principal em trinta dias nos próprios autos em que formulado o pedido cautelar. Se no Código de 1973 era necessário propor ação cautelar e posteriormente “ação principal” em processos distintos (art. 806, CPC/1973), agora o autor propõe ação cautelar e mais tarde ação principal no próprio processo instaurado pela ação cautelar.

Como é evidente, nada impede que sejam propostas duas ações em um só processo, como frequentemente ocorre em caso de ações cumuladas. É certo que se pode pensar apenas em pedidos cumulados e, num caso como o presente, em pedido cautelar seguido de pedido principal. Sucede que, bem vistas as coisas, não se trata apenas de pedidos, mas de ações (compostas por pedido e causa de pedir) em que se busca tutela de segurança e tutela do direito material. Por existir apenas um processo, instaurado quando da propositura da ação cautelar, o autor é dispensado do adiantamento de novas custas processuais.

## **2. Aditamento da causa de pedir?**

O § 2º do art. 308 diz que “a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal”. Trata-se obviamente de regra mal redigida, uma vez que, ao contrário do que ocorre na hipótese de tutela antecipada, aqui não há busca de uma mesma tutela de direito nem apenas uma causa de pedir. A causa de pedir da ação cautelar não se confunde com a causa de pedir da ação principal.

Ao redigir o § 2.º do art. 308 o legislador não percebeu que, ao reproduzir o conteúdo do revogado art. 801, III e IV – do Código de 1973 – no art. 305, estava apenas a exigir a “indicação” da causa de pedir da ação principal e não a sua formulação. A causa de pedir, referida mediante a expressão “fundamento” no art. 305, deve ser “indicada” para dar ao juiz oportunidade de situar a ação cautelar no contexto do direito cautelando. Não há qualquer razão para o autor deduzir a causa de pedir da ação principal desde logo, ao contrário do que ocorre no “procedimento da tutela antecipada antecedente”, em que é perseguida uma única tutela mediante uma só ação.

Uma vez efetivada a tutela cautelar o autor tem trinta dias para propor a ação principal, quando obviamente pode formular não só pedido, mas também a causa de pedir – antes apenas indicada – em sua integralidade.

## **3. Relação entre ação principal e efetivação da tutela cautelar**

A ação principal deve ser proposta apenas quando *efetivada* a tutela cautelar. E isso sob pena de cessação da eficácia da tutela e de responsabilidade objetiva pelos eventuais danos ocorridos (arts. 309, I, e 302, III, CPC). É assim para que a tutela cautelar não se mantenha eficaz sem o necessário aprofundamento da cognição e do debate em torno do direito assegurado. De modo que a propositura da ação principal é ônus daquele que obteve tutela cautelar que foi efetivada.

Em caso de tutela cautelar não concedida ou concedida e não efetivada, o autor pode propor a ação de modo formalmente autônomo. Aliás, quando a tutela é efetivada e a ação principal não é proposta, o autor não perde o direito de propor a ação de modo autônomo, mas apenas é gravado com a responsabilidade objetiva por eventual dano produzido pela efetivação da tutela.

Note-se, porém, que em caso de tutela antecipada antecedente pouco importa se a tutela não foi concedida ou efetivada. Não deferida a tutela antecipada, o autor tem o ônus de aditar a petição inicial sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 303, § 6º, CPC). Essa é uma importante distinção entre os procedimentos das tutelas antecipada e cautelar antecedentes, pois evidencia que, enquanto o ajuizamento da ação principal é apenas requisito para a eficácia da tutela cautelar, o requerimento de tutela antecipada é indissociável da ação em que se pede a tutela final.

#### **4. Procedimento após o ajuizamento da ação principal**

Depois do ajuizamento da ação principal no processo instaurado pela ação cautelar, as partes devem ser intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação (art. 334, CPC), pessoalmente ou na pessoa dos seus advogados. Não ocorrendo autocomposição, o prazo para contestar deve ser contado na forma do art. 335 do Código de Processo Civil.

Lembre-se, contudo, que quando a ação principal é proposta – em virtude de a tutela ter sido concedida inaudita altera parte e efetivada – antes do julgamento do pedido cautelar, passa a existir um único procedimento para regular a preparação dos juízos sobre os pedidos de tutela cautelar e de tutela principal.

#### **5. Cumulação das ações cautelar e principal**

Não haveria racionalidade em não admitir a cumulação das ações cautelar e principal, formulando-se petição inicial em que estejam presentes as causas de pedir de cada uma das ações e seus respectivos pedidos. É nesse sentido o teor do § 1.º do art. 308, embora aluda a pedidos principal e de tutela cautelar.

Ainda que se diga que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar, há duas ações que ambicionam duas tutelas – passíveis de concessão ao final do procedimento. Não há apenas ação em que se pede tutela do direito com requerimento de tutela cautelar incidental. Há pedidos de duas tutelas finais, sendo a cautelar passível de ser concedida também no curso da ação cautelar ou do processo. A ação cautelar é exercida, com base em técnicas processuais que lhe são próprias – como a possibilidade de antecipação da tutela cautelar final –, ao lado da ação em que se almeja o alcance da tutela do direito.

**Art. 309.** Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I – o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II – não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III – o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

#### **1. Cessação da eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente**

Os incisos do art. 309 estabelecem hipóteses de cessação da eficácia da tutela cautelar. Objetiva-se evitar que a tutela cautelar se mantenha eficaz quando perde sua justificativa. O principal motivo a animar a “cessação da eficácia” é o de que a tutela cautelar afeta a esfera jurídica do réu, causando-lhe gravame a partir de um juízo de probabilidade.

Porém, é preciso ter cautela na interpretação dos incisos do art. 309, uma vez que, por exemplo, nem toda tutela cautelar efetivada necessita ser seguida por uma ação principal, de modo que nem sempre a não dedução do pedido principal pode redundar em cessação da eficácia da tutela cautelar – ao contrário do que a interpretação literal do inciso I do art. 309 permite concluir.

#### **2. Não formulação do pedido principal no prazo legal**



Realmente, nem sempre a efetivação da tutela cautelar exige a propositura da ação principal, como ocorre no caso de caução de dano infecto. Lembre-se que a caução de dano infecto é idônea para assegurar a viabilidade da tutela ressarcitória diante de possível dano futuro. Neste caso, não tendo ainda ocorrido o dano e, portanto, não havendo sequer possibilidade de exercício da pretensão à tutela ressarcitória, um “pedido principal” é obviamente impensável.

A cessação da eficácia da tutela cautelar só pode ocorrer quando a propositura da ação principal for exigível no processo instaurado pela ação cautelar. Quando a tutela cautelar foi efetivada e o autor pode exigir a tutela do direito acautelada, a ação principal deve ser proposta para que se demonstre a razão de ser da tutela obtida e reste justificada a restrição da esfera jurídica do demandado<sup>5</sup>, dando-se-lhe, ademais, oportunidade para demonstrar a inexistência do direito que foi suposto existente ao se conceder a tutela de urgência.

O prazo de trinta dias para a dedução do pedido principal ou, mais precisamente, para a propositura da ação principal, corre da juntada aos autos do mandado de efetivação da tutela cautelar. Quando são concedidas várias tutelas, como por exemplo diversos arrestos, o prazo começa a correr da juntada aos autos do primeiro mandado de efetivação. Lembre-se que a imposição de brevidade para a propositura da ação principal atende à necessidade de não se permitir a sobrevivência de uma tutela eventualmente infundada por longo período de tempo, exigindo-se que o autor assuma, no menor tempo possível, o ônus de demonstrar o direito assegurado pela tutela cautelar. Portanto, como a primeira tutela obviamente interfere na esfera jurídica do réu, o prazo deve começar a correr a partir da juntada aos autos do primeiro mandado.

O prazo para a propositura da ação principal nada tem a ver com a preclusão da decisão, já que a tutela pode ser efetivada apesar do recurso. Caso a tutela efetivada seja revogada antes de escoado o prazo para a propositura da ação principal, essa não precisa ser proposta. Se a decisão primitiva voltar a prevalecer e a tutela for novamente efetivada, novo prazo de trinta dias é aberto à propositura da ação principal.

Não deduzido o pedido principal no prazo legal, o juiz deve declarar a perda da eficácia da tutela. Aliás, essa declaração apenas não é necessária quando o pedido principal for julgado improcedente ou quando o processo for extinto sem resolução de mérito. A declaração é necessária nas hipóteses dos incisos I e II do art. 309 porque essas requerem juízo sobre a observância ou não do prazo. Mas a perda da eficácia sempre se dá com a não propositura da ação principal no prazo legal e não com a decisão que declara a cessação ocorrida, de modo que, por exemplo, há responsabilidade objetiva do requerente da tutela cautelar desde o momento em que escoou o prazo legal para a propositura da ação principal, não importando para este efeito a declaração da cessação da eficácia.

É possível indagar sobre a natureza do prazo para a propositura da ação principal, se decadencial ou não. Critérios de direito material, relativos à prescrição e à decadência, não são adequados à regulação dos prazos processuais.<sup>6</sup> Note-se que o prazo para a propositura da ação principal deve ser suspenso, por exemplo, nas hipóteses dos incisos I, II e VI do art. 313 do Código de Processo Civil.

### **3. Não efetivação da tutela em trinta dias**

Afirma-se que cessa a eficácia da tutela quando essa não é efetivada no prazo de trinta dias. Note-se que a tutela cautelar não foi efetivada e, assim, não afetou a esfera jurídica do demandado. Portanto, a cessação não é da eficácia da tutela cautelar, mas da eficácia da decisão que concedeu a oportunidade para a efetivação da tutela.

A razão de ser da cessação, desta forma, está na inércia do requerente da tutela cautelar, ou melhor, na sua presumível falta de interesse na pronta obtenção (efetivação) da tutela cautelar. O legislador parte do pressuposto de que, se o juiz profere decisão concedendo a tutela cautelar e o autor não a efetiva no prazo de trinta dias, há desinteresse superveniente na pronta obtenção da tutela cautelar. A perda superveniente de interesse é que justifica a cessação da eficácia da decisão cautelar.

Contudo, não ocorrerá cessação da eficácia se a tutela não for efetivada em razão de fato atribuível ao juízo ou à parte contrária. Incidirá, neste caso, o art. 313, VI, do Código de Processo Civil, suspendendo o prazo para a efetivação da tutela. Assim, está exato o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que afirmou que a exigência da efetivação da tutela cautelar, sob pena de cessação de sua eficácia,

não vinga quando se evidencia que o réu oculta o veículo que é a razão da expedição do mandado judicial e que não foi cumprido, máxime, ainda, quando provado está que o autor realiza esforços para localizar o bem.<sup>7</sup>

Por outro lado, quando a tutela cautelar for de efetivação complexa – por exemplo, necessidade de vários arrestos ou de vários sequestros –, a sua efetivação parcial no prazo de trinta dias impede a cessação da eficácia da decisão que concedeu a tutela cautelar.

A não efetivação da tutela cautelar concedida antes da ouvida do réu não elimina a necessidade da sua citação para apresentar contestação. Perceba-se que a cessação da eficácia da decisão impede a efetivação da tutela cautelar, mas não o prosseguimento do procedimento e, inclusive, a reiteração da concessão da tutela depois da apresentação da defesa. O objetivo do inciso II do art. 309 é impedir a efetivação após trinta dias da decisão cautelar e não impor a extinção do processo.

#### **4. Improcedência do pedido principal ou extinção do processo sem resolução de mérito**

O inciso III do art. 309 corrige o problema que estava presente no inciso III do art. 808 do código de 1973. O art. 808, ao também tratar das hipóteses de cessação da eficácia tutela cautelar, dizia que cessava a eficácia no caso em que “o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito” (art. 808, III, CPC/73). O problema é que a sentença de procedência do pedido certamente não pode gerar a cessação da eficácia da tutela, nem mesmo depois do seu trânsito em julgado. Há casos em que, transitada em julgado a sentença de procedência, a tutela cautelar deve prosseguir eficaz para garantir a tutela do direito que depende da execução. O arresto, por exemplo, garante a tutela ressarcitória pelo equivalente em pecúnia ou a tutela do direito de crédito, que obviamente dependem da execução em caso de não cumprimento voluntário da condenação. O inciso III do art. 309 do código atual corretamente restringe o âmbito da cessação da eficácia, limitando-o às hipóteses de improcedência do pedido principal e de extinção do processo sem resolução do mérito.

A improcedência do pedido e a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo antes do trânsito em julgado, a princípio são suficientes para determinar a cessação da eficácia da tutela cautelar. No momento em que se reconhece que a tutela do direito inicialmente acautelada não deve (improcedência) ou não pode (extinção do processo sem resolução do mérito) ser prestada, a princípio há contradição em manter eficaz a tutela cautelar. Não há como não admitir que a sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito, ao dizer que o autor sequer pode exigir a tutela do direito, e a sentença de improcedência do pedido, ao afirmar que o autor não tem direito à tutela do direito, descalçam a tutela cautelar do pressuposto da probabilidade do direito, o que, em uma perspectiva lógica, deveria obrigatoriamente conduzir à cessação da tutela cautelar.

Ocorre que o perigo de dano pode persistir no período de processamento do recurso de apelação. Nesta situação, caso o tribunal reforme a sentença, a tutela do direito provavelmente não será prestada de modo efetivo. Portanto, não há dúvida que o tribunal pode, ao visualizar probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, conceder tutela cautelar (art. 299, parágrafo único, CPC). Uma vez interposta a apelação, cabe ao tribunal apreciar o pedido de tutela cautelar, ainda que o recurso esteja sendo processado em primeiro grau.

É certo que a cessação da eficácia da tutela cautelar depende da intimação do autor acerca da sentença de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem julgamento do mérito. Porém, não é absurdo considerar o período entre a intimação da sentença e a interposição do recurso de apelação. É verdade que este período não é muito longo. Não obstante, neste espaço de tempo obviamente pode haver perigo de dano, que, assim, pode ser eliminado pelo próprio juiz de

primeiro grau de jurisdição. Diante disto, há de se aceitar que o juiz, em hipóteses excepcionais – em que vislumbre a iminência da prática de dano –, possa manter a eficácia da tutela cautelar ou simplesmente deixar de revogá-la na sentença de improcedência ou de extinção do processo sem julgamento do mérito, a despeito de ser possível ao autor, igualmente em casos excepcionais, requerer a tutela cautelar diretamente ao tribunal mesmo que o recurso de apelação não tenha sido interposto.

### **5. Renovação do pedido de tutela cautelar sob novo fundamento**

De acordo com o parágrafo único do art. 309, “se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento”. É importante analisar se, tratando-se de tutela cautelar, há coisa julgada material ou apenas proibição de renovação do pedido, bem como o significado de “novo fundamento” capaz de oportunizar a renovação do pedido de tutela.

É claro que a coisa julgada material não se confunde com a proibição do *bis in idem*. A coisa julgada material é fenômeno típico do processo jurisdicional, enquanto que o princípio do *ne bis in idem* marca uma série de situações em que não se pode admitir a renovação ou repetição de um pleito. Há proibição do *bis in idem* na esfera administrativa, assim como na chamada “jurisdição voluntária”, mas certamente não existe coisa julgada material nestas situações. Quer isto dizer que a simples circunstância de um pedido ter sido decidido não é suficiente para produzir coisa julgada material ou tornar a questão decidida indiscutível.

A coisa julgada material é a qualidade que torna indiscutível a declaração ou o efeito declaratório contido na sentença. A coisa julgada somente incide em face de algumas sentenças. Não diante das sentenças da “jurisdição voluntária” e das que decidem o pedido de tutela cautelar, uma vez que a “declaração” contida nestas sentenças é inapta para produzir coisa julgada material, ou melhor, não é propriamente declaração ou declaração para efeito de coisa julgada material.

A sentença, para produzir coisa julgada material, deve ser capaz de declarar a existência ou a inexistência de um direito. Se o procedimento não outorga às partes adequada oportunidade de alegação e produção de prova, ou melhor, de exercício do contraditório, nele jamais se poderá chegar a um juízo capaz de permitir a “declaração do direito”, mas apenas a um juízo idôneo a autorizar uma “declaração sumária”, que, por sua própria natureza e origem, não terá força suficiente para gerar a imutabilidade típica da coisa julgada.

Se o juiz rejeita a tutela cautelar por entender que o fato, ainda que evidenciado, não gera situação perigosa suficiente à sua concessão, não há como admitir a renovação do pedido de tutela cautelar com base na mesma circunstância fática. Mas a proibição de reutilização da mesma circunstância fática ou do mesmo fato indicador do perigo obviamente nada tem a ver com coisa julgada. Nem mesmo se pode aceitar a tese de que a negação da tutela cautelar impede a invocação de fato que poderia ser utilizado para demonstrar o perigo, conforme pretendeu Giuseppe Tarzia no ensaio “Rigetto e Riproponibilità della Domanda Cautelare”, publicado na *Rivista di Diritto Processuale*.<sup>8</sup>

O autor, para pedir tutela cautelar, não precisa alegar todos os fatos que poderiam convencer o juiz da sua necessidade. Fatos não alegados, mas já existentes, podem fundar novo pedido de tutela cautelar. Não há como aglutinar ou imantar os fatos que podem fundar o pedido de tutela. Cada um deles constitui um fundamento para o pedido de tutela cautelar. Portanto, não há preclusão na não alegação de fato que já existia à época do requerimento da tutela cautelar negada. Proíbe-se apenas a reiteração de fato já descartado como capaz de indicar situação perigosa suficiente para a concessão da tutela, o que obviamente não se confunde com coisa julgada material, constituindo apenas manifestação da proibição do *bis in idem*.

Nos casos de não propositura da ação principal no prazo legal (art. 309, I, CPC) e de não efetivação da tutela cautelar em trinta dias (art. 309, II, CPC), a parte pode renovar o pedido de tutela cautelar com base em “novo fundamento”. Este novo fundamento não pode ser o fato

reconhecido como perigoso para a concessão da tutela cautelar que perdeu a eficácia. O fato deve ser outro, suficiente para a concessão de nova tutela cautelar. Este fato, distinto do que fundou o pedido de tutela cautelar que perdeu a eficácia, é o “novo fundamento” que permite a renovação do pedido nos termos do parágrafo único do art. 309.

Note-se que o parágrafo único do art. 309, ao aludir a “novo fundamento”, não tem preocupação alguma com a probabilidade do direito. O seu objetivo é impedir a renovação do pedido com base no mesmo fato que levou à concessão da tutela cautelar que perdeu a eficácia. Assim, ainda que cesse a eficácia da tutela cautelar, a parte pode requerer novo pedido de tutela cautelar com base em fato novo ou com base em fato já existente mas não alegado. Só não lhe é possível requerer tutela cautelar com base no mesmo fato perigoso que fundou a tutela cautelar cuja eficácia cessou.

**Art. 310.** O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

### **1. A decisão cautelar não interfere sobre o julgamento do pedido principal**

Como já dito, a declaração judicial somente é apta a receber a qualidade de coisa julgada material quando tem força suficiente para se tornar definitiva. Portanto, a declaração fundada em cognição sumária – típica à decisão cautelar – não é capaz de gerar coisa julgada material, até porque não objetiva produzir “definitividade”. Diante do pedido de tutela cautelar, o juiz decide com base em cognição sumária ou fundado na probabilidade do direito, sem que possa chegar a um juízo de “certeza” e, desta forma, “declarar” direito, o que é imprescindível para a formação da coisa julgada material.

Ao julgar o pedido cautelar, o juiz “declara” que o direito é provável ou improvável. Porém, declarar uma probabilidade não é o mesmo do que declarar um direito. Aliás, declarar uma probabilidade é, implicitamente, confessar que o que foi afirmado como provável certamente pode ser dito em contrário – no mesmo ou em outro processo, pelo mesmo ou por outro juiz. Daí deflui com naturalidade a regra de que “o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse”.

Não há dúvida que a decisão que declara o provável não pode interferir sobre a discussão do mesmo direito em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual se fala no direito francês que “l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée” (art. 488, CPC francês) ou que a coisa julgada do référé é uma “coisa julgada provisória”<sup>9</sup> – expressão que, bem vistas as coisas, guarda uma contradição intrínseca e apenas serve para negar a existência de coisa julgada material diante da decisão fundada em cognição sumária e, além disso, reafirmar a ideia de que o indeferimento da tutela cautelar não pode influir sobre o julgamento do pedido principal.

### **2. Reconhecimento de decadência ou de prescrição em sede de tutela cautelar**

O art. 310 do Código de Processo Civil, quando dá ao juiz o poder de reconhecer a decadência ou a prescrição em sede de tutela cautelar, permite que matéria que diz respeito à “tutela principal” tenha o seu julgamento deslocado. De forma excepcional, admite-se que o mérito da ação principal seja definido quando do julgamento do pedido de tutela cautelar. Isso, como é óbvio, quando o juiz tem convicção que lhe seria suficiente para declarar a prescrição ou a decadência caso estivesse diante do pedido principal. Ou melhor: o juiz pode declarar a prescrição ou a decadência, ao tratar da tutela cautelar, quando tem convicção de certeza e não quando tem apenas convicção de probabilidade, caso em que, quando muito, poderia “declarar” a probabilidade da prescrição ou da decadência.

A exceção aberta pelo art. 310, portanto, não apenas permite ao juiz tratar de matéria que diz respeito à tutela principal, mas também lhe outorga a possibilidade de decidir com base em cognição exauriente, ou seja, com base em cognição impertinente – mais aprofundada – à tutela cautelar.

Como o juiz trata do mérito da tutela principal com base em cognição exauriente, a sua decisão, ao reconhecer a prescrição ou a decadência, produz coisa julgada material, impedindo a propositura da ação principal ou a dedução do pedido de tutela principal. Por essa razão, e considerando que a cognição do juiz é exauriente, também se deve considerar preclusa a discussão em caso de expressa rejeição da alegação de prescrição ou de decadência. Vale dizer que, se o acolhimento implica a impossibilidade de dedução do pedido de tutela principal, a expressa rejeição obstaculiza a rediscussão da questão.

A previsão do art. 310 tem nítido sabor de celeridade e economia processuais, pois permite que o juiz desde logo declare algo que, a princípio, apenas poderia ser discutido mais tarde, evitando-se com isto a manutenção do estado de litigiosidade, além do dispêndio de tempo e dinheiro das partes e da administração da justiça.

É claro que a aplicação do art. 310 só tem sentido quando o pedido cautelar é antecedente. Ademais, é importante esclarecer que a norma não permite a declaração de decadência ou de prescrição do direito do réu. Portanto, caso o autor entre com ação cautelar e alegue, entre outras coisas, que a pretensão do réu está prescrita, o juiz assim não poderá declará-la. Poderá, é claro, reconhecer a probabilidade do direito do autor, fundado na aparente existência da mencionada decadência; porém, isso não implicará juízo de certeza a respeito dessa circunstância, nem implicará a força típica da coisa julgada em relação a ulteriores debates sobre o tema. A previsão do art. 810 constitui exceção e regra especial, não admitindo interpretação extensiva.<sup>10</sup>

---

## NOTAS DE RODAPÉ

---

1

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, p. 275 e ss.

2

Cf. Andrea Proto Pisani, “Intervento” – Atti del XV Convegno Nazionale, La tutela d’urgenza, p. 118. No mesmo sentido, Vittorio Denti, “Intervento” – Atti del XV Convegno Nazionale, La tutela d’urgenza, p. 164.

3

Como esclareceu Víctor Fairen Guillén, “los procedimientos plenarios rápidos se diferencian del ordinario, simplemente por su forma, más corta, pero no por su contenido, que es el mismo cualitativamente, jurídicamente plenario” (...) “los procedimientos sumarios se diferencian del ordinario plenario, por su contenido, cualitativamente, jurídicamente parcial, siendo indiferente la forma, aunque tendente a la brevedad, por lo cual se aproximaban – en ocasiones hasta confundirse procedimentalmente – con los plenarios rápidos” (Juicio ordinario, plenarios rápidos sumario, sumarísimo, Temas del ordenamiento procesal, Madrid: Tecnos, 1969, p. 828). Ver, ainda, Víctor Fairen Guillén, El juicio ordinario y los plenarios rápidos, Barcelona: Bosch, 1953.

4

Note-se que, embora o art. 344 fale que “presumir-se-ão verdadeiras”, o art. 307 não alude a veracidade das alegações, mas diz que os fatos alegados “presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos”.

5

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a cessação da eficácia da medida também deve ser imputada aos casos em que, a despeito de ter sido proposta, a ação principal permanece paralisada por mais de dois anos consecutivos por negligência da parte autora, o que configura o desinteresse na rápida solução do litígio, fulminando o requisito do *periculum in mora*” (REsp 225357, 2.<sup>a</sup> Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 15.08.2005).

---

6

Ver Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 224.

---

7

RT 552/222.

---

8

Giuseppe Tarzia, Rigetto e riproponibilità della domanda cautelare, Rivista di Diritto Processuale, 1988.

---

9

Ver Louis Boré, L'autorité provisoire de la chose jugée, in L'autorité de la chose jugée (direção de Loïc Cadiet e Dominique Loriferne), p. 61 e ss.

---

10

Ver Ovídio Baptista da Silva, Do processo cautelar, p. 215.

---

© desta edição [2018]



## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

### **LIVRO V - DA TUTELA PROVISÓRIA**

#### **TÍTULO III. DA TUTELA DA EVIDÊNCIA**

### **Título III. Da Tutela da Evidência**

**Art. 311.** A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

- I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
- II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
- III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
- IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

#### **1. Tutela da evidência**

##### **1.1. Evidência dos fatos constitutivos, inconsistência da defesa e distribuição do ônus do tempo processo**

O processo – ou fase do processo – em que se “declara” a tutela do direito é fundado no princípio de que o autor deve provar o fato constitutivo do direito que alega possuir e o réu deve provar o eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo afirmado na contestação. É o que evidencia o art. 373 do Código de Processo Civil quando diz que o ônus da prova incumbe i) ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ii) ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A necessidade de distribuir o ônus da prova decorre do princípio de que o juiz, mesmo em caso de dúvida resultante de carência de prova, não pode deixar de dar solução à causa. Se o juiz tem o dever de sentenciar, solucionando o mérito, alguém tem que pagar pela carência da prova que o impede de ter um juízo perfeito sobre o conflito de interesses.<sup>1</sup> Nesse sentido a regra do art. 373 é apenas um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida, e, assim, poder definir o mérito.

Mas a regra de que o autor deve provar o que alega, independentemente da situação de direito substancial controvertida, não gera um processo justo ou de acordo com a Constituição Federal. Não se nega que o ônus da prova é uma consequência do ônus de afirmar, mas há situações que têm particularidades suficientes para demonstrar que a aplicação do art. 373 seria contrário ao desejo do próprio direito material<sup>2</sup>. Além disto, há casos em que é muito difícil, ou quase impossível, ao autor provar a sua alegação, sendo mais fácil ao réu demonstrar que o fato alegado pelo autor não é verdadeiro<sup>3</sup>. Tais circunstâncias levam aos conceitos de inversão do ônus da prova na sentença (julgamento com base em verossimilhança) e na decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, III, CPC).

Porém, aqui não importa saber quem deve provar ou quando o ônus da prova deve ser invertido, mas quem deve suportar o tempo necessário à produção da prova. Se o ônus da prova dos fatos litigiosos deve ser repartido entre o autor e o réu na medida do que estes alegam, cabe indagar se o tempo para a produção da prova também não deve ser repartido de acordo com a



mesma regra. Ou melhor: se o réu deve provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, há racionalidade em obrigar o autor a pagar pelo tempo necessário à produção da prova de tais fatos? Essa questão, de grande relevância para a realização do princípio da efetividade<sup>4</sup> e do princípio chiovendiano de que o processo não pode prejudicar ao autor que tem razão, está à base da tutela da evidência.

Se o fato constitutivo é incontroverso não há racionalidade em obrigar o autor a esperar o tempo necessário à produção da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, uma vez que o autor já se desincumbiu do ônus da prova e a demora inerente à prova dos fatos cuja prova incumbe ao réu certamente o beneficia.<sup>5</sup> Assim, a regra do ônus da prova deixa de ser lida em uma perspectiva meramente estática para ser compreendida em uma dimensão dinâmica, em que importa o tempo da instrução probatória. Não só a produção da prova, mas também o tempo para tanto, constituem ônus que devem ser repartidos entre os litigantes.

A tutela da evidência tem importante base na ideia de que a demonstração dos fatos constitutivos, ao desobrigar o autor do ônus da prova, repercute sobre a inversão do ônus do tempo do processo. A tutela da evidência permite ao juiz, a partir da incontrovérsia do fato constitutivo, antecipar a realização do direito, deixando à fase processual sucessiva a cognição da defesa de mérito indireta infundada. É claro que tal tutela tem eficácia imediata, resolutivamente condicionada ao acolhimento da defesa.

Mas a tutela da evidência não requer apenas a incontrovérsia dos fatos constitutivos, pois exige, ainda, que a defesa de mérito indireta tenha duas características: em primeiro lugar não pode se basear em prova documental, uma vez que deve exigir produção de outras provas e, por consequência, o alongamento do tempo do processo; em segundo lugar, ainda que abra oportunidade à produção de prova pericial ou testemunhal, as alegações dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos devem ser infundadas.

Tal técnica de tutela faz com que o réu, e não o autor, suporte o tempo necessário para a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Trata-se de uma decisão marcada por uma cognição sumária e parcial, em que o tempo do processo, necessário para a declaração dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos, deixa de ser ônus do autor e passa a ser ônus do réu, ou seja, daquele que tem necessidade do prosseguimento do processo para que se desenvolva a fase instrutória<sup>6</sup>.

O juiz, ao conceder a tutela da evidência, tem cognição exauriente sobre a alegação dos fatos constitutivos e cognição sumária em relação ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo. De modo que a cognição é sumária sobre parcela do mérito.<sup>7</sup>

De lado a tutela da evidência em caso de defesa de mérito indireta, há hipóteses em que os fatos constitutivos são evidenciados e, ainda assim, postos em dúvida por uma defesa direta inconsistente, ou seja, pela contestação infundada dos fatos constitutivos. Nesta situação não há defesa indireta (alegação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos), porém apenas defesa direta (negação dos fatos constitutivos). Essa, embora suscite a produção de prova, não é capaz de abalar a convicção formada pela prova dos fatos constitutivos.

No caso de prova emprestada capaz de gerar convicção de certeza acerca dos fatos constitutivos ou de prova do núcleo do fato constitutivo, a defesa destituída de fundamento ou a contestação infundada dos elementos secundários ao núcleo do fato constitutivo não pode protelar a realização do direito. A defesa que protela a realização de um direito evidenciado, controvertendo os fatos constitutivos sem fundamento capaz de abalar a convicção decorrente da prova produzida pelo autor, deve ser considerada abusiva.

A tutela da evidência excepciona o princípio de que a execução ou a tutela jurisdicional do direito deve seguir a sentença de cognição plena e exauriente. Trata-se de técnica que visa a impedir que aquele que tem razão seja prejudicado pelo tempo da instrução da causa.

É certo que esta técnica – como acontece com toda técnica antecipatória – apresenta riscos para

o réu. Contudo, a circunstância de o juiz somente poder conceder a tutela quando a defesa de mérito for infundada atenua bastante este risco. Ademais, tal risco, ainda que exista, é plenamente justificável, pois não é racional que o autor tenha que suportar o tempo do processo quando os fatos constitutivos são incontroversos ou estão evidenciados e a defesa é infundada.<sup>8</sup> Ora, da mesma forma que o réu pode ser prejudicado pela tutela, o autor pode ser prejudicado pela demora para a prestação da tutela jurisdicional do direito material.

## **1.2. A importância de situar corretamente os fatos litigiosos para a distribuição do tempo do processo**

Discorrendo sobre os fatos jurídicos, afirma Chiovenda que os fatos constitutivos são aqueles que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém e exemplifica fazendo referência ao empréstimo, ao testamento, ao ato ilícito e ao matrimônio. Os fatos extintivos, por sua vez, segundo a doutrina chiovendiana, são aqueles que “fazem cessar uma vontade concreta de lei e a consequente expectativa de um bem. Por exemplo: pagamento; remissão de dívida; perda da coisa devida”.<sup>9</sup>

As circunstâncias de fato que têm por escopo específico dar vida a um direito e que normalmente produzem este efeito podem ser chamadas de fatos constitutivos. Entretanto, para que estas circunstâncias possam dar vida a um direito, é preciso que estejam presentes outras que, quando ausentes, impedem que o direito possa ter vida. Quando falta uma das circunstâncias que devem concorrer com os fatos constitutivos há um fato impeditivo.<sup>10</sup> Vejamos a explicação, à luz do direito italiano, realizada por Chiovenda:

Todo direito nasce de determinadas circunstâncias que têm por função específica dar-lhe vida: contudo, para produzirem o efeito que lhes é próprio, normal, devem concorrer outras circunstâncias (...) A posse da coisa móvel pelo vendedor é a condição específica (fato constitutivo) para que o comprador lhe adquira a propriedade, ainda que a coisa não pertencesse ao vendedor: não obstante, se o comprador obrou de má-fé, esse efeito não se produz;<sup>11</sup> assim, se o proprietário perdera a coisa. Em tais hipóteses, a incapacidade, a violência, o dolo, o erro, a simulação, a ilicitude, a má-fé, a qualidade de coisa perdida funcionam como fatos impeditivos do direito; e da mesma forma toda circunstância que obste a um fato produzir o efeito que lhe é normal, que constitua a razão de sua existência.<sup>12</sup>

É preciso, porém, uma advertência: os fatos impeditivos não integram os elementos da *fattispecie*. O fato impeditivo pode ser identificado com a inexistência de um pressuposto de eficácia. O fato está no exterior da *fattispecie*, mas incide no seu interior. O fato impeditivo não é um elemento integrativo da *fattispecie*, mas um elemento autônomo que incide sobre a produção dos efeitos de uma *fattispecie* completa.<sup>13</sup>

Já os fatos modificativos são aqueles que pressupõem válida a constituição do direito, mas tendem a alterá-lo, como, por exemplo, a moratória concedida ao devedor.<sup>14</sup> Assim, se o autor pede o pagamento da dívida e o réu alega o seu parcelamento e, portanto, que a dívida somente pode ser exigida em parte, o fato é modificativo; se o réu afirma o pagamento, o fato é extintivo; se o réu alega exceção de contrato não cumprido, o fato é impeditivo.<sup>15</sup>

Situar um fato corretamente entre os fatos constitutivos, extintivos, impeditivos ou modificativos é fundamental para a correta distribuição do ônus da prova e, consequentemente, para a adequada repartição do ônus do tempo do processo.

## **1.3. A condenação com reserva no direito italiano**

No direito italiano são conhecidas hipóteses típicas de condenação com reserva, como, por exemplo, a do art. 1.462 do Código Civil, que assim estabelece:

Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni – La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

Essa norma disciplina as cláusulas limitativas da apresentação de exceções. São as cláusulas com as quais uma parte – de acordo com o princípio chamado de *solve et repete* – subordina o direito de suscitar exceções em juízo ao prévio cumprimento das obrigações contratuais.<sup>16</sup> A cláusula assegura a uma das partes o cumprimento imediato da prestação contratual, obtido através da suspensão provisória dos meios de tutela predispostos pelo ordenamento. Isto quer dizer que a exceção do réu somente poderá ser conhecida pelo juiz depois da condenação, que é considerada, por isso mesmo, uma condenação com reserva.<sup>17</sup>

Afirma o art. 1.462 que na presença de “graves motivos” o juiz pode “suspender a condenação”. Embora a própria norma fale em “suspensão da condenação”, é óbvio que a expressão é aí utilizada de forma não técnica. Não é possível suspender a condenação. A suspensão pode dizer respeito à eficácia executiva ou à execução “provisória”, mas não à condenação. De qualquer forma, não é errado dizer que a referida suspensão da condenação deseja significar a “desaplicação” da cláusula.<sup>18</sup>

Não é o caso, evidentemente, de analisar as várias outras hipóteses concretas previstas no ordenamento italiano. O que importa é salientar que parte da doutrina italiana reclama uma norma que consagre a atipicidade da condenação com reserva. Segundo Giuliano Scarselli – autor de uma importante obra sobre o tema –, o sistema italiano atual, apenas com a predisposição de hipóteses determinadas e específicas de condenação com reserva, arrisca-se a tratar de modo diverso situações em tudo análogas e, portanto, pode tornar em parte inúteis as justificativas lógicas e sistemáticas que estão à base do próprio instituto da condenação com reserva.<sup>19</sup>

É inegável que uma série de situações concretas, que estão à margem das hipóteses tipificadas no direito italiano, exigem a condenação com reserva para que o tempo do processo seja suportado pela parte que tem necessidade da instrução da causa. É oportuno lembrar, aliás, que algo muito análogo à generalização da técnica da condenação com reserva já chegou a ser proposto por um grupo de estudos do Conselho Superior da Magistratura italiana. Trata-se de uma proposta que teve a rubrica “*Ordinanza di condanna con riserva*” e disse o seguinte:

Quando i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio siano non contestati dalle parti costituite o risultino già pienamente approvati, ma la causa non si presenti di pronta decisione per le necessità istruttorie collegate alle eccezioni del convenuto, ove le eccezioni stesse, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altro elemento risultante in causa, appaiono verosimilmente infondate, il giudice istruttore, su istanza di una parte e nel contraddittorio dell'altra, pronuncia ordinanza di condanna all'adempimento totale o parziale della prestazione richiesta. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'efficacia dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione di una cauzione. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma. Essa è altresì reclamabile nelle forme e nei termini dell'art. 669 bis 13. Se il processo se estingue, si applica l'ultimo comma dell'art. 186 bis.

Note-se que tal proposta exige, para a condenação com reserva, i) a prova dos fatos constitutivos ou a não contestação destes fatos e ii) uma exceção de não pronta solução que se afigure provavelmente infundada.<sup>20</sup>

#### **1.4. Pressupostos da tutela da evidência**

A tutela da evidência é ligada à ideia de abreviação do tempo necessário à realização do direito material. A técnica abre oportunidade à antecipação da tutela jurisdicional do direito material, ignorando a exigência de que a execução somente seria possível após a cognição plena e exauriente.

O art. 350 do Código de Processo Civil afirma que, “se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 quinze dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”. É certo que o réu pode alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo e, ao mesmo tempo, negar o fato constitutivo. Porém, ao apresentar defesa de mérito indireta, o réu em regra admite, por mera consequência lógica, o fato constitutivo do direito.

A apresentação de defesa de mérito indireta em regra equivale, por um princípio de incompatibilidade lógica, à não contestação dos fatos constitutivos. Por exemplo: se o autor pede o

pagamento de crédito pecuniário afirmando a venda de determinada mercadoria e o réu alega que o bem entregue apresenta vícios, a contestação admite o contrato e o recebimento da coisa, ou seja, os fatos constitutivos.<sup>21</sup> Nesta situação, a defesa substancial indireta torna, por uma razão de (in)compatibilidade lógica, os fatos constitutivos incontroversos – ainda que tenham sido contestados.

Entretanto, é também possível que o réu não conteste os fatos constitutivos e apresente apenas defesa de mérito indireta. Nesta hipótese a tutela é baseada na evidência do direito e na defesa de mérito indireta infundada; a evidência do direito, porém, não decorre da incompatibilidade lógica entre a defesa indireta e a negação dos fatos constitutivos, mas simplesmente da ausência da defesa direta.

Além disso, os fatos constitutivos podem ser provados mediante documento. Acontecendo isso, a mera apresentação de defesa indireta somente reafirma a evidência dos fatos constitutivos. Porém, quando o réu nega a validade ou a autenticidade do documento oferecido para demonstrar os fatos constitutivos, descaracteriza-se a evidência apta à concessão da imediata tutela do direito. Além disso, quando o fato constitutivo é demonstrado mediante prova emprestada ou mesmo documental, negando-se na primeira hipótese o próprio fato constitutivo e, na segunda, apenas os elementos secundários do fato, também há evidência do direito que, quando conjugada à inconsistência da defesa direta, abre oportunidade à tutela da evidência.

Realmente, a não contestação,<sup>22</sup> a negação logicamente incompatível com a defesa indireta e a demonstração dos fatos constitutivos não são suficientes para a tutela da evidência. Bem por isso, como demonstram as duas primeiras situações, a tutela da evidência não constitui simples repartição do tempo do processo de acordo com a necessidade da instrução da causa. Exige-se, ainda, que a defesa – indireta ou direta – seja infundada ou a probabilidade de que não será acolhida ao final do processo. A falta de fundamento ou a inconsistência da defesa é critério imprescindível à tutela da evidência.

Como é óbvio, além de infundada, a defesa deve exigir instrução probatória. A tutela da evidência somente tem sentido quando a defesa indireta não admite a imediata resolução do mérito. Isto porque a tutela da evidência é justificada pelo tempo que o réu vai utilizar com a instrução probatória para permitir ao magistrado um juízo de cognição exauriente sobre a defesa. Não há como esquecer que é o tempo do processo que justifica a tutela da evidência.

### **1.5. A defesa de mérito, além de inconsistente, não pode ser de pronta solução**

#### ***1.5.1. A defesa de mérito não pode ser de imediata solução***

A tutela da evidência somente tem razão de ser quando a defesa requer instrução dilatória, podendo adiar o momento de realização do direito. Quando a defesa pode ser imediatamente apreciada, independentemente da produção de prova pericial ou testemunhal, obviamente não há motivo para tutela da evidência, bastando ao juiz proferir a sentença.

#### ***1.5.2. A defesa de mérito deve ser inconsistente***

Para que seja possível a tutela da evidência, é ainda necessário que a defesa seja infundada ou inconsistente. É correto dizer que a defesa deve ser provavelmente infundada, quando não se está falando de algo muito diferente de *fumus boni iuris*, uma vez que esta expressão tem clara relação com a ideia de “probabilidade”. A diferença é que *fumus boni iuris* significa probabilidade do direito do autor, ao passo que o conceito que agora interessa diz respeito às alegações do demandado.<sup>23</sup>

Em determinado sentido, não há como falar em verdade como categoria contraposta à probabilidade ou à verossimilhança. Por isso mesmo, argumenta-se que o juiz, mesmo ao final do processo, somente encontra a probabilidade ou a verossimilhança.<sup>24</sup>

Piero Calamandrei, abordando lição de Wach,<sup>25</sup> advertiu que, quando se diz que um fato é

verdadeiro, afirma-se, em substância, que ele atingiu, na consciência de quem assim o julga, aquele grau máximo de verossimilhança que, em relação aos meios limitados de conhecimento de que o julgador dispõe, é suficiente para lhe dar a certeza subjetiva de que aquele fato se verificou. Advertiu Calamandrei que, mesmo para o juiz mais atento e escrupuloso, vale o limite fatal de relatividade que é próprio da natureza humana, pois o que se vê é somente aquilo que parece estar se vendo. É por isso que todo o sistema probatório civil é preordenado não somente a permitir, mas verdadeiramente a impor ao juiz de se contentar, ao apreciar os fatos, com a probabilidade.<sup>26</sup>

Isto não quer dizer, como é óbvio, que o juiz não deva formar, para proferir a sentença, uma convicção de certeza.<sup>27</sup> No plano do processo, aliás, é importante distinguir afirmação de fato provada e afirmação de fato provável, embora em outra perspectiva ambos os conceitos – como visto acima – possam levar apenas a um juízo de probabilidade.<sup>28</sup>

Uma afirmação de fato está provada quando supera o controle legal e formal de veracidade, ao passo que uma afirmação é provável quando, ainda que não tenha se submetido à plenitude do contraditório, faz surgir a convicção – a partir da relação que possui com outros fatos, provas e regras de experiência – de que será demonstrada na fase seguinte do processo.

Na realidade, mais importante do que estabelecer a diferença entre afirmação provada e afirmação provável, é distinguir afirmação que pôde ser plenamente provada de afirmação que não pôde ser plenamente provada. Uma afirmação pôde ser plenamente provada quando em relação a ela não houve qualquer restrição do direito à produção da prova. Em contrapartida, uma afirmação não pôde ser plenamente provada quando teve que ser apreciada em momento anterior ao esgotamento da instrução probatória e à plenitude do contraditório.

Quando há restrição do direito à produção da prova, ou limitação do contraditório, há cognição sumária. Na tutela da evidência com base na reserva da cognição da defesa de mérito indireta infundada somente há cognição exauriente sobre os fatos constitutivos<sup>29</sup>. A defesa indireta deve ser examinada com base em cognição sumária exatamente porque exige instrução dilatória. Por ser anterior ao esgotamento do contraditório, tal cognição somente pode permitir a formação de uma convicção de probabilidade. Neste sentido, cabe ao juiz analisar se tal defesa é infundada ou inconsistente, ou seja, se faz surgir a convicção de que as alegações de fato não serão demonstradas na fase seguinte do processo.

Note-se que a probabilidade, neste caso, não se relaciona com um fato que deve ser provado pelo autor, mas sim com um fato que deve ser provado pelo réu. Frise-se que não é o autor que deve demonstrar que a defesa é infundada. A convicção judicial acerca da defesa indireta decorre unicamente da atividade do réu.

Lembre-se que a incontrovérsia dos fatos constitutivos gera uma espécie de presunção da existência do direito, exigindo do réu o ônus de demonstrar que o fato extintivo, modificativo ou impeditivo se sobrepõe à incontrovérsia dos fatos constitutivos. Como a incontrovérsia dos fatos constitutivos – condição para se pensar na análise da ausência de inconsistência da defesa indireta – tem grande peso e influência sobre a convicção do juiz, apenas a defesa indireta fundada pode ser capaz de abalar a convicção judicial acerca da existência do direito. Caso isto não ocorra, a defesa deve ser considerada infundada, ou melhor, incapaz de dissolver a força da incontrovérsia dos fatos constitutivos e, assim, de protelar a prestação da tutela jurisdicional do direito.

A situação é semelhante em se tratando de defesa direta. Diante da prova emprestada e da prova documental do fato constitutivo, só as alegações – inclusive quanto aos elementos secundários do fato constitutivo – merecedoras de credibilidade podem descaracterizar a evidência do direito e, deste modo, racionalmente adiar a tutela do direito.

## **2. A tutela da evidência baseada na técnica da reserva da cognição da defesa de mérito indireta infundada**

### **2.1. Os critérios da não contestação e da incompatibilidade entre apresentação de defesa**



## **de mérito indireta e negação dos fatos constitutivos**

Lembre-se que a incontrovérsia dos fatos constitutivos é condição imprescindível para a tutela da evidência com base na reserva da cognição da defesa de mérito indireta infundada. Em outras palavras, a análise da seriedade da defesa de mérito indireta só tem razão de ser quando há incontrovérsia dos fatos constitutivos.

A evidência, diante da técnica da reserva da cognição da defesa indireta infundada, pode decorrer da não contestação dos fatos constitutivos. Embora apresentada defesa indireta, o fato constitutivo se torna incontroverso em razão da não apresentação de defesa direta, ficando o autor dispensado e o réu impedido de produzir prova em relação a ele. Há aí “não contestação” e, assim, aplicação do art. 374, III, do Código de Processo Civil, que afirma que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.

De acordo com o art. 341 do Código de Processo Civil, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: i) não for admissível, a seu respeito, a confissão; ii) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; e iii) estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.<sup>30</sup> Portanto, existe no direito brasileiro um princípio que estabelece a necessidade de o réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, ficando dispensados de prova os fatos não contestados.

O art. 341, III, diz que as alegações de fato não contestadas não são presumidas verdadeiras quando estão em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Para que um fato possa ser considerado não contestado, não basta simplesmente a não contestação individualizada – ou um mero comportamento passivo em relação a determinado fato –, sendo necessário verificar se outras alegações, contidas na contestação e inclusive na reconvenção (art. 343, CPC), não significam, mesmo que implicitamente, a sua negação. Se o réu deixa de contestar um fato de forma específica, o efeito da não contestação – ou seja, a admissão do fato como verdadeiro – somente se produzirá se as demais alegações da defesa não forem tomadas como negação do fato não contestado de maneira específica.<sup>31</sup>

Para que um fato não contestado possa ser presumido verdadeiro, é necessário analisar a defesa globalmente, verificando-se, a partir do conjunto das alegações do réu, se é certo concluir que o fato não especificamente impugnado foi aceito como verdadeiro. É apenas a partir da análise da defesa na sua totalidade que se pode dizer que um fato não contestado deve ser considerado incontroverso.

A evidência também pode advir da incompatibilidade lógica entre a apresentação das defesas indireta e direta. Isso ocorre quando a defesa indireta implicitamente admite os fatos constitutivos. Quando é apresentada apenas defesa indireta – sem com que os fatos constitutivos tenham sido negados pela globalidade da defesa – ou no caso em que, deduzidas as defesas direta e indireta, a segunda é incompatível com a primeira, não há dúvida que os fatos constitutivos são admitidos como verdadeiros.

Quando a defesa indireta é logicamente compatível com a defesa direta, ou seja, com a negação dos fatos constitutivos, obviamente não há como concluir pela tutela da evidência com base na técnica da reserva da cognição da defesa de mérito infundada. Se diante da defesa indireta não há não contestação ou incompatibilidade com a negação dos fatos constitutivos, esses somente poderão ser ditos evidentes se provados mediante prova documental – excepcionalmente por meio de prova testemunhal ou pericial emprestada. Neste caso, entretanto, é importante notar que a tutela da evidência não se funda na técnica da reserva da cognição da defesa indireta infundada, mas na técnica da prova documental dos fatos constitutivos – que também pode ser dita técnica monitória.

### **2.2. A defesa de mérito indireta equivale, em regra, à não contestação dos fatos constitutivos**

A apresentação de defesa de mérito indireta equivale, na grande maioria dos casos e por um princípio de incompatibilidade lógica, à não contestação dos fatos constitutivos alegados pelo autor.<sup>32</sup> Se o autor afirma que, em virtude da venda de determinada mercadoria, possui determinado crédito em relação ao réu, e esse alega, na sua contestação, que o crédito não pode ser exigido porque a mercadoria apresenta vícios, não há contestação dos fatos constitutivos. O réu, ao dizer que a mercadoria possui vícios, admite que realizou o contrato de compra e venda e recebeu a mercadoria, sendo estes os fatos constitutivos do direito do autor. Da mesma forma, se o trabalhador pede o pagamento do valor devido pela atividade que desenvolveu e o réu alega a má execução da obra, a defesa admite o contrato e a sua execução, isto é, os fatos constitutivos. Nos dois exemplos, a alegação contida na defesa indireta admite, por uma questão lógica, a presença dos fatos constitutivos.<sup>33</sup>

Ao alegar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, o réu assume comportamento processual que equivale, normalmente, à não contestação dos fatos constitutivos, exatamente porque, em regra, a própria defesa indireta pressupõe a existência dos fatos constitutivos.<sup>34</sup>

### **2.3. Resolução do impasse diante da incompatibilidade entre as defesas de mérito direta e indireta**

Nada impede que o réu apresente defesa indireta e, ainda assim, conteste os fatos constitutivos. Nem sempre a concomitância das duas defesas revela incompatibilidade lógica ou inconciliabilidade.

Não há inconciliabilidade entre a negação do contrato e a afirmação de prescrição ou entre a negação do crédito tributário e alegação de moratória, embora exista incompatibilidade lógica entre a alegação de vício no serviço e a negação do contrato e do serviço.

Nos dois primeiros exemplos é adotado o princípio da eventualidade, em virtude do qual se permite a dedução de uma defesa para a hipótese da outra não ser acatada. O réu apresenta duas defesas para que, na eventualidade do não acolhimento de uma, seja admitida a outra. No exemplo da prescrição, o fato negado na defesa direta não é “aceito” na indireta. O fato é sempre negado, requerendo-se que, na eventualidade de não ser acolhida a defesa indireta, seja aceita a direta. Articula-se que o crédito afirmado pelo autor, se existisse, estaria prescrito. Ou seja, afirma-se, com base na eventualidade, a prescrição do crédito (defesa indireta), mas é expressamente contestado o fato constitutivo (defesa direta).

Contudo, quando se tem em conta a defesa de mérito indireta que não se concilia com a negação dos fatos constitutivos, importa saber o que acontece quando o réu apresenta defesas de mérito direta e indireta logicamente incompatíveis. No direito italiano, Giuliano Scarselli argumenta que o juiz deveria considerar, nestes casos, os arts. 88 e 116, segunda parte, do CPC. O art. 88 do CPC afirma que as partes e os seus advogados têm o dever de se comportar em juízo com lealdade e probidade, enquanto a segunda parte do art. 116 do CPC diz que o juiz pode retirar argumentos de prova das respostas que as partes lhe dão por ocasião do chamado “interrogatorio non formale”, da renúncia injustificada destas a admitir inspeções, assim como, em geral, do próprio comportamento das partes no processo.<sup>35</sup>

O art. 77 do Código de Processo Civil afirma que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: i) expor os fatos em juízo conforme a verdade; ii) não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; iii) não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; iv) cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; v) declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; e vi) não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Ademais, diz o art. 80 que é considerado litigante de má-fé aquele que: i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; ii) alterar a verdade dos fatos; iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; iv) opuser resistência injustificada ao



andamento do processo; v) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; vi) provocar incidente manifestamente infundado; e vii) interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

Como está claro, é dever da parte expor os fatos conforme a verdade e não apresentar defesa ciente de que é destituída de fundamento. Acontece que a parte que nega o fato constitutivo na defesa direta e, ao mesmo tempo, aceita-o implicitamente na defesa indireta, certamente está faltando aos seus deveres de expor os fatos conforme a verdade e não apresentar defesa ciente de que é destituída de fundamento.

Quando pode existir incompatibilidade entre as defesas direta e indireta, o juiz, com base no princípio da lealdade processual, deve determinar que a parte esclareça a sua defesa. Se o réu não se manifestar ou não esclarecer a defesa adequadamente, os fatos constitutivos devem ser reputados não contestados. Se a defesa indireta for infundada e exigir instrução dilatória, a tutela da evidência deverá ser concedida.

#### **2.4. O dever de o réu se manifestar sobre os fatos narrados na petição inicial, o dever de veracidade e o dever de o réu esclarecer a sua defesa**

A ZPO alemã, em seu § 138,<sup>36</sup> afirma que as partes devem esclarecer as circunstâncias de fato da causa de modo completo e conforme a verdade. Diz, ainda, que cada parte deve se manifestar sobre os fatos afirmados pelo adversário e que aqueles que não forem expressamente contestados devem ser considerados admitidos se a intenção de querer contestar não resultar de outras declarações da parte.<sup>37</sup>

No direito brasileiro, segundo disposição expressa do Código de Processo Civil, cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados (art. 341, CPC). Demais disto, o réu tem o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade e não alegar defesa ciente de que é destituída de fundamento (art. 77, I e II, CPC).

Assim, à semelhança do que ocorre no sistema alemão, no direito brasileiro estão presentes o dever de veracidade e o dever de o réu se manifestar sobre os fatos narrados na petição inicial. Isto é muito importante, já que valoriza ao máximo a busca da verdade material e reduz a massa dos fatos controversos, sabido que a defesa pode ser exercida com o objetivo de alterar a verdade e com intuito meramente protelatório.<sup>38</sup>

O réu, porque tem o dever de expor em juízo os fatos conforme a verdade, não pode negar o fato que sabe verdadeiro, mas apenas silenciar. O seu silêncio, contudo, conduz à presunção de veracidade do fato não contestado.<sup>39</sup> O réu pode ser tentado a contestar expressamente o fato constitutivo implicitamente admitido na sua defesa indireta. Neste caso, porém, o réu deveria deixar de apresentar defesa direta, hipótese em que a presunção de veracidade decorreria, antes de tudo, da própria admissão implícita do fato constitutivo na defesa indireta.

O dever de veracidade e o dever de o réu se manifestar precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial impedem que o réu aceite o fato constitutivo na defesa indireta e o negue através de defesa direta, bem como eliminam a necessidade de o juiz considerar fatos que poderiam ser contestados apenas por abuso, o que torna racional a prestação jurisdicional.

Por isso mesmo, como antes adiantado, caso o réu aceite o fato constitutivo na defesa indireta e conteste-o na defesa direta, o juiz, considerando o dever de a parte expor os fatos conforme a verdade, deve determinar o esclarecimento da defesa, até porque o dever de esclarecimento nada mais é do que um desdobramento do dever de veracidade. A partir daí, conforme dito no item anterior, caberá a concessão da tutela da evidência.

### **3. Tutela da evidência baseada na técnica da prova dos fatos constitutivos**

#### **3.1. A prova documental dos fatos constitutivos**

Lembre-se, antes de tudo, que o objeto da prova são as afirmações de fato e não os fatos em si. O fato não pode ser qualificado de “certo”, “indivudioso” ou “verdadeiro”; ele apenas existe ou não existe. Como o direito existe independente do processo, esse serve para declarar que o direito afirmado existe. Isto é, prova-se a afirmação de fato para que se declare que o direito afirmado existe. A sentença de cognição exauriente limita-se a declarar a verdade de um enunciado, ou melhor, que a afirmação de que o direito existe é, de acordo com as provas produzidas e o juízo de compreensão do juiz, verdadeira. Em outras palavras, o direito que o processo afirma existir pode, no plano substancial, não existir e vice-versa. Não se prova que o direito existe, mas sim que a afirmação de que o direito existe é verdadeira, declarando-se a existência do direito (coisa julgada material).

Como a tutela da evidência se funda na incontrovérsia ou na evidência dos fatos constitutivos, antes de mais nada é necessário precisar o conceito de prova documental. Ressalte-se que a prova pericial ou a prova testemunhal realizadas mediante o procedimento da “produção antecipada da prova” (art. 381, CPC), não raramente confundidas com a prova documental, constituem apenas provas pericial ou testemunhal “documentadas”. Na realidade, o chamado “documento” que, por exemplo, contém a declaração testemunhal feita antecipadamente, prova apenas a declaração testemunhal e não a afirmação de fato que tal declaração pretende provar. A prova testemunhal antecipada permite a dedução da veracidade da afirmação do fato a partir da declaração testemunhal, constituindo fonte secundária de prova.

O testemunho é ato humano que serve para demonstrar uma afirmação de fato, enquanto o (verdadeiro) documento é uma coisa (embora também produto da atividade humana<sup>40</sup>) capaz de representar um fato.<sup>41</sup> O testemunho, como ato humano, não demonstra, por si só, um fato, enquanto o documento, que é uma coisa, é suficiente para representá-lo.

É importante advertir, no que diz respeito ao documento particular, quer seja escrito e assinado ou somente assinado, que as declarações dele constantes presumem-se verdadeiras em relação ao signatário (art. 408, CPC). Se o documento contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato declarado, incumbindo ao interessado em sua veracidade o ônus de prová-lo (art. 408, parágrafo único, CPC). A declaração de ciência, como é óbvio, não prova o fato em si. Prova apenas que alguém tem conhecimento de como o fato se passou. Por isto cabe à parte interessada requerer a prova do fato, surgindo como necessária outra modalidade de prova capaz de demonstrar a sua ocorrência. A declaração de ciência, assim, não é prova suficiente para a tutela da evidência.

O documento público gera presunção de autenticidade, ao passo que o particular necessita do reconhecimento da parte contrária para ser considerado autêntico. De acordo com o art. 430, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de quinze dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, uma vez contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, cabendo o ônus da prova à parte que o produziu, durante a instrução da causa.<sup>42</sup> Tendo em vista que a tutela da evidência, mediante a presente técnica, exige prova dos fatos constitutivos, é correto afirmar que o documento apontado como falso não é suficiente para a sua concessão.

### **3.2. A necessidade de tutela da evidência no procedimento monitório**

O legislador apostou no procedimento monitório como técnica destinada a propiciar a aceleração da realização dos direitos e, assim, capaz de evitar o custo do procedimento comum. Partindo da premissa de que um direito evidenciado mediante “prova escrita” em regra não deve sofrer contestação, o procedimento monitório objetiva, através da inversão do ônus de instaurar a discussão do direito, desestimular as defesas infundadas e permitir a tutela do direito sem as delongas do procedimento comum.

Mas o procedimento monitório, para realmente ter efetividade, depende do instrumento da tutela da evidência para inibir as defesas infundadas. Sem a tutela da evidência o procedimento monitório não alcançará os fins sonhados pelo legislador. Apenas a possibilidade desta tutela poderá desestimular os embargos infundados e protelatórios.

Por outro lado, nada impede que a tutela da evidência, baseada na prova do fato constitutivo e em defesa infundada, seja admitida no curso do procedimento comum, uma vez que também nada impede que o autor, munido de prova documental, pretenda realizar o seu direito mediante este procedimento e seja surpreendido por uma defesa infundada.

### **3.3. A diferença entre prova escrita, prova suficiente para a tutela da evidência e prova suficiente para a procedência do pedido**

O conceito de “prova escrita”, estabelecido pela doutrina e pela jurisprudência italiana a partir dos arts. 633 a 636 do Código de Processo Civil, é singular.<sup>43</sup> A doutrina brasileira, ao tratar do procedimento monitório e da “prova escrita”, sempre acatou as formulações italianas.<sup>44</sup> O conceito de prova escrita formulado a partir do código italiano é realmente diverso do conceito de prova documental. Como escreve Garbagnati,

é comum na jurisprudência a afirmação de que a ‘prova escrita’ do direito do autor pode ser constituída, na linha do art. 633, por qualquer documento merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. Mas não se esclarece, com isto, se um escrito privado não reconhecido e não autenticado deva, ou possa, considerar-se merecedor de fé ...<sup>45</sup>

Na verdade, a doutrina italiana entende que o documento particular não reconhecido constitui prova escrita, mas não costuma explicar as razões desta conclusão.

De acordo com o art. 411, III, do Código de Processo Civil, considera-se autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Nos termos do art. 412, o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Porém, este documento – ainda que não reconhecido pela parte contra a qual foi produzido – é considerado prova suficiente para se afirmar o direito de exigir o pagamento de quantia, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer e de não fazer – de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil brasileiro. Pode ser considerado prova escrita porque, embora não reconhecido – nem mesmo tacitamente –, é merecedor de fé. Ora, se conforme o enunciado *id quod plerumque accidit* as assinaturas são genuínas, o juiz também deve considerar autêntica, de acordo com a experiência comum, a assinatura do documento não reconhecido em relação ao qual, dada a falta do contraditório, ainda não pôde operar a regra do reconhecimento tácito.<sup>46</sup>

No caso de apresentação de embargos à ação monitória, contestando o embargante a autenticidade da assinatura, o processo deverá caminhar de acordo com a regra probatória do art. 429, II, do Código de Processo Civil, recaindo sobre o embargado o ônus da prova. Nesta hipótese, como é óbvio, o documento particular não reconhecido pelo embargante não é prova suficiente para a improcedência dos embargos. Como explica Garbagnati,

a parte credora tem o ônus de pedir a ‘verificação’ judicial do escrito privado, colocado como fundamento do decreto injuntivo e desconhecido pelo réu; com efeito, se o pretendo credor não prova o fato constitutivo do seu direito, a oposição deve ser acolhida, porque em um processo de conhecimento comum o juiz não tem o poder de fundar a sua decisão em um escrito privado desconhecido, cuja autenticidade não tenha sido, em seguida ao ato de desconhecimento, formalmente ‘verificada’ de acordo com a lei.<sup>47</sup>

A hipótese do documento particular não reconhecido bem demonstra a diferença entre prova escrita, prova suficiente para a tutela da evidência (no procedimento monitório ou no procedimento comum) e prova suficiente para a procedência do pedido no procedimento comum ou para a improcedência dos embargos à ação monitória.

A tutela da evidência com base em prova do fato constitutivo e em defesa infundada somente é possível, como é óbvio, após a ouvida do réu. Se o autor pretender provar o seu crédito mediante documento particular e o réu alegar a sua falsidade na contestação, não é possível a tutela da evidência.

É ainda interessante outro exemplo. De acordo com o art. 2.710 do Código Civil italiano, os livros obrigatórios e outras escrituras contábeis, regularmente mantidos, somente podem

constituir prova a favor de um empresário contra outro e nas relações inerentes ao exercício da empresa. Apesar da dicção do art. 2.710 do Código Civil italiano, o art. 634 do Código de Processo Civil considera prova escrita os extratos autênticos das escrituras contábeis, ainda que a “ação monitoria” seja proposta por um empresário – que exerce uma atividade comercial – contra uma pessoa que não seja comerciante.<sup>48</sup>

A doutrina que admite que os extratos autênticos das escrituras contábeis podem constituir prova escrita em uma demanda proposta por um comerciante contra uma pessoa que não exerce atividade comercial, seguramente não pode admitir que esta prova é suficiente para a tutela da evidência (no procedimento monitorio ou no procedimento comum) e, por muito mais razão, para a procedência do pedido no procedimento comum ou para a improcedência dos embargos na ação monitoria.

Se o devedor não comerciante afirma que não adquiriu a mercadoria cujo preço está sendo exigido com base em um extrato autêntico de escritura contábil, descabe a tutela da evidência – ou a antecipação da execução – por ausência de prova do fato constitutivo. Ora, o extrato contábil não é suficiente para provar a compra e venda, no procedimento comum ou no procedimento monitorio, porque a regra, tanto no direito brasileiro<sup>49</sup> quanto no direito italiano, é a de que os livros comerciais fazem prova no litígio entre comerciantes.

Na verdade, o extrato contábil, justamente porque não prova o fato constitutivo do direito de crédito, não é prova suficiente para a tutela da evidência (no procedimento monitorio ou no procedimento comum) nem para a procedência do pedido no procedimento comum ou para a improcedência dos embargos à ação monitoria.<sup>50</sup>

### **3.4. A tutela da evidência e a tutela antecipada no procedimento monitorio**

Como é sabido, o procedimento monitorio foi pensado como alternativa para atribuir maior tempestividade do processo, chegando a ser visto como tutela jurisdicional diferenciada.<sup>51</sup> O procedimento monitorio tem por fim permitir a formação do título executivo sem as delongas do procedimento comum. O seu objetivo, em outras palavras, é acelerar a realização do direito.

De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitoria pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. No procedimento monitorio, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, constituindo-se o título executivo judicial no caso de não oposição ou de rejeição de embargos.

Exige-se para o cabimento da ação monitoria prova escrita que sustente o crédito e que não constitua título executivo. Uma vez deferida a expedição do mandado e citado o devedor, esse poderá: i) atender à determinação judicial, hipótese em que pagará honorários de cinco por cento sobre o valor da causa e ficará isento do pagamento de custas; ii) permanecer inerte, quando será constituído, “de pleno direito o título executivo judicial”; ou iii) apresentar embargos, caso em que será instaurado um procedimento de cognição plena e exauriente para discutir o direito afirmado pelo credor (arts. 701 e 702, CPC).

No procedimento monitorio é empregada a técnica da cognição exauriente secundum eventum defensionis, já que, uma vez apresentados os embargos – em que o réu poderá alegar qualquer matéria que pode ser deduzida como defesa no procedimento comum (art. 702, § 1.º, CPC) –, a cognição será exauriente.

Os embargos, a princípio, são processados nos mesmos autos da ação monitoria e dispensam a prévia segurança do juízo (art. 702, CPC). Na hipótese de não apresentação de embargos, o devedor, após a formação do título executivo, somente poderá alegar as matérias que podem ser deduzidas para a impugnação do cumprimento da sentença, nos termos do Título II do Livro I da

## Parte Especial.

O procedimento monitorio, ao supor que a ausência de iniciativa do réu confirma a existência do direito que já era aceito como provável (em virtude da prova escrita), apenas reafirma a tão sentida necessidade de tratamento diferenciado aos direitos que podem ser evidenciados de pronto. Parte-se da premissa de que a prova escrita e a inércia do devedor são suficientes para a formação do título executivo. É preciso ter em mente que o título executivo judicial, formado pelo procedimento monitorio, parte da existência de prova escrita capaz de demonstrar, em alto grau de probabilidade, a existência do direito. O legislador, quando criou o procedimento monitorio, aceitou o risco que a defesa corre em nome da necessidade de tutela adequada dos direitos.

Contudo, o procedimento monitorio somente terá efetividade se tiver um mecanismo capaz de conter o abuso de direito de defesa e, desta forma, os embargos protelatórios. Este mecanismo consiste na tutela da evidência, única capaz de permitir que o credor que prova os fatos constitutivos do seu direito não seja prejudicado pelo tempo necessário à elucidação de alegações infundadas do devedor.

Os embargos, que nada mais são do que meio de impugnação, poderiam ser simples contestação não fosse a ideia de se inibir a inércia do devedor, exigindo-se dele a propositura dos embargos para o desenvolvimento do contraditório. Assim, seria completamente desrazoável a tese que apontasse para a impossibilidade da tutela da evidência sob o argumento de que o art. 311, I, do Código de Processo Civil fala em abuso de direito de defesa e em manifesto propósito protelatório do réu.

Não é muito difícil perceber a realidade: o devedor exerce a sua defesa através de embargos ao mandado, não estando livre de se ver tentado a dela abusar. Com efeito, também é possível que o réu queira se valer dos embargos apenas para protelar a realização do direito afirmado pelo autor. Ora, o intuito protelatório, no procedimento monitorio, evidentemente não pode ser desconsiderado, especialmente porque este procedimento visa a tratar de forma diferenciada um direito evidente.

A tutela da evidência – no procedimento monitorio – somente é cabível quando há prova documental do fato constitutivo do direito (não bastando qualquer prova escrita, conforme ficou demonstrado no item anterior) e os embargos são infundados.

De outra parte, é possível que o autor precise desde logo do bem da vida perseguido sob pena de sofrer dano – como também pode acontecer no procedimento comum. No procedimento monitorio é certamente possível a tutela antecipada fundada no art. 300, à semelhança do que ocorre no direito italiano diante da norma do art. 642, segunda parte, do Código de Processo Civil.<sup>52</sup>

À primeira vista, muitos poderão não compreender a razão para a tutela antecipada baseada em perigo de dano no procedimento monitorio, imaginando que a tutela cautelar de arresto é suficiente para proteger o credor. Para que se perceba o motivo para a tutela antecipada é importante lembrar que a antecipação de pagamento de soma pode ser imprescindível para proteger um bem não patrimonial. É a hipótese do ressarcimento antecipado para aliviar um estado de necessidade causado pelo dano.<sup>53</sup>

Nestes casos, a realização do direito de crédito tem por escopo a tutela de um direito não patrimonial, como por exemplo o direito à saúde. O objeto da tutela não é o direito de crédito, mas o direito que lhe é conexo. A tutela não se destina a assegurar o juízo ou a viabilidade da realização do direito de crédito, mas a realizar antecipadamente o crédito para permitir a efetiva tutela de um direito que lhe é conexo e merecedor de especial proteção. Note-se, de fato, que a antecipação de pagamento de soma fundada no art. 300 é medida idônea para impedir prejuízo irreparável a um direito conexo ao direito de crédito,<sup>54</sup> ao passo que o arresto (cautelar) é a medida capaz de assegurar a viabilidade da realização do direito de crédito.

Realizadas estas explicações, fica fácil admitir, no procedimento monitorio, não apenas a tutela



da evidência (art. 311, CPC) – lastreada na prova do fato constitutivo e em embargos infundados –, mas também a tutela antecipada de soma fundada em perigo de dano (art. 300, CPC).

### **3.5. A execução imediata no caso de improcedência dos embargos ao mandado**

Como diz Proto Pisani, não apenas estudos clássicos, mas especialmente o bom senso indica que o processo de cognição plena e exauriente tem um custo altíssimo para as partes e para a administração da justiça. Em todos os casos em que é afirmado um direito e falta uma contestação séria o custo do procedimento comum revela-se injustificado ou excessivo; a realização plena e antecipada do princípio do contraditório funciona no vazio e ainda apresenta o risco: i) de servir de estímulo para contestações ou resistências sem qualquer consistência, apresentadas pelo réu que sabe não ter razão apenas com o intuito de lucrar com o tempo necessário para a conclusão do processo; e ii) de abarrotar, além da medida, a administração da justiça com processos de conhecimento inúteis, aumentando o seu número, paralisando o seu desenvolvimento e de qualquer forma alongando a sua duração.<sup>55</sup>

Se o objetivo do procedimento monitorio é evitar o “custo” do procedimento comum quando esse não é justificado por uma defesa plausível, e para tanto a tutela da evidência é imprescindível, é importante atentar para a possibilidade da execução imediata na pendência do recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência dos embargos.

Qualquer tese que sustentasse que a execução só é possível após o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos estaria em desconformidade com o espírito do procedimento monitorio. Ora, se o escopo deste procedimento é abreviar o tempo necessário para a formação do título executivo, não há lógica em subordinar a realização do direito ao trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos.

O código de 2015 deixou clara a possibilidade da execução na pendência da apelação interposta contra a sentença de improcedência dos embargos. O art. 702, § 8.º, afirma que

rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

A norma não diz que, transitada em julgado a sentença de rejeição dos embargos, “constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo ...”. Também não afirma que, rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, que terá sua eficácia executiva subordinada ao trânsito em julgado da sentença.

Ao contrário, o art. 702, § 4.º, afirma que a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão que determina a expedição do mandado “até o julgamento em primeiro grau”. Portanto, se com a apresentação dos embargos é suspensa a eficácia executiva, essa resta subordinada ao “julgamento em primeiro grau”. Na hipótese de improcedência dos embargos é reestabelecida a eficácia executiva da decisão de expedição do mandado, que passa a autorizar a execução imediata. É nesse sentido que deve ser compreendido o § 3.º do art. 702 quando afirma que, “rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial”. Note-se que a sentença de improcedência evidentemente não tem eficácia executiva, tendo apenas carga declaratória capaz de permitir a restauração da eficácia executiva que estava paralisada pela apresentação dos embargos.

### **3.6. A tutela da evidência mediante a técnica monitoria (prova do fato constitutivo) no procedimento comum**

O art. 311 admite a tutela da evidência no procedimento comum com base em prova do fato constitutivo e defesa infundada. O art. 311, nos incisos I e IV, fala respectivamente em “abuso do direito de defesa” e em “prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

Quando oposta em face da prova documental dos fatos constitutivos, a defesa de mérito infundada, ao exigir tempo para a produção de prova, faz com que a demora do processo

irracionalmente conspire contra o autor. Assim, o exercício desta defesa constituirá abuso de direito caso o ônus do tempo não seja invertido – mediante a tutela da evidência – em favor do autor. Não obstante, o inciso IV do art. 311 fala em “prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

A tutela da evidência exige prova do fato constitutivo, isto é, prova que, dentro das regras probatórias que incidem no procedimento comum, seja capaz de demonstrar o fato que constitui o direito. Assim, por exemplo, o comerciante não pode, alegando ter crédito não adimplido, obter tutela da evidência com base em extrato contábil, uma vez que esta prova não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo.

Como é evidente, a prova do demandado “capaz de gerar dúvida razoável” não é a prova documental, ou seja, a prova capaz de demonstrar de plano o fundamento da defesa. Essa prova seria suficiente para o julgamento antecipado do mérito em favor do réu. A tutela da evidência só tem razão de ser quando a defesa exige instrução dilatória, ou melhor, tempo do processo. De modo que a prova oposta pelo réu, para permitir a tutela da evidência, além de não poder ser um documento capaz de evidenciar de plano o fundamento da defesa, não pode ser uma prova “capaz de gerar dúvida razoável”.

No direito italiano, a antecipação da execução no procedimento comum e a execução provisória na pendência da oposição apresentada em face do “decreto di ingiunzione” (embargos ao mandado de pagamento) também exigem que a defesa requeira instrução dilatória, afirmando-se que a defesa não pode ser fundada em prova escrita. Diz o art. 648, I, do Código de Processo Civil italiano que, se a oposição (embargos) non è fondata su prova scritta ou di pronta soluzione, o juiz pode conceder, com “ordinanza” não impugnável, a execução provisória do “decreto di ingiunzione”, caso essa já não tenha sido concedida com base no art. 642.<sup>56</sup>

Melhor seria que o art. 648, I, ao invés de falar em prova escrita, houvesse aludido a “prova documental”. Como já foi explicado, a “prova escrita”, suficiente para a concessão do “decreto di ingiunzione” ou do mandado de pagamento, não se confunde com a “prova documental”. A prova necessária para a concessão da tutela da evidência, assim como a prova capaz de demonstrar a defesa de plano, e assim impedir a concessão da tutela da evidência, é a prova documental. Em outros termos: a prova escrita, suficiente para demonstrar a defesa de plano, não é a mesma que pode fundar o “decreto di ingiunzione” ou o mandado de pagamento. Como elucida Garbagnati,

prova ‘escrita’ é qualquer documento escrito idôneo para provar, nos termos do art. 2699 et seq. do CC, a inexistência do fato constitutivo do direito do credor, e assim o fundamento da relativa exceção (em sentido lato) do devedor, ou mesmo a existência dos fatos extintivos ou impeditivos (pagamento, prescrição etc.), deduzidos pelo devedor em sustentação das suas exceções (em sentido estrito); portanto, uma escritura privada com subscrição não autenticada, se pode servir de prova escrita com base no art. 633 et seq. não contém eficácia probatória para os efeitos do art. 648, primeira parte, quando o credor, constituindo-se na oposição (nos embargos), não tenha reconhecido a sua autenticidade.<sup>57</sup>

Como se vê, além de a defesa de mérito não poder ser baseada em documento, é necessário que seja infundada ou não lastreada em prova ou argumento que exija prova – capaz de gerar dúvida razoável –, embora seja correto admitir que, em regra, a defesa apresentada diante da prova dos fatos constitutivos e não baseada em documento ou em prova capaz de gerar dúvida razoável seja infundada.

### **3.7. A tutela da evidência quando a ação impõe entrega de coisa, fazer ou não fazer**

É importante lembrar que os artigos 536, 537 e 538 do Código de Processo Civil objetivam atribuir efetividade ao processo<sup>58</sup> nos casos em que se almeja prestação de fazer ou de não fazer ou a entrega de coisa.<sup>59</sup> Não há lógica em não admitir tutela da evidência nestas ações quando o direito do autor está evidenciado e a defesa do réu requer instrução dilatória e se mostra infundada.

Na realidade, a tutela da evidência, tratando-se de entrega de coisa e prestação de fazer e de não fazer, é viável no procedimento comum e no procedimento monitório. A tutela da evidência



cabe no procedimento monitório quando há prova documental dos fatos constitutivos e no procedimento comum quando, de lado a hipótese de prova documental, os fatos constitutivos não são contestados ou são implicitamente aceitos na defesa de mérito indireta. Em todos os casos, é claro, a defesa não pode estar baseada em documento e deve ser infundada, ou seja, não pode estar lastreada em provas ou argumentos capazes de gerar dúvida razoável.

#### **4. A tutela da evidência fundada em prova do fato constitutivo e em defesa direta infundada**

##### **4.1. Defesa direta infundada**

Há situações excepcionais em que se pode ter defesa de mérito direta infundada capaz de justificar a tutela da evidência. A defesa de mérito direta deve exigir instrução dilatória, ou seja, tempo do processo.

Quando os fatos constitutivos estão evidenciados – embora não definitivamente provados – e a defesa direta carece de fundamento para colocá-los em dúvida, há defesa de mérito direta infundada ou destituída de seriedade. A prova dos fatos constitutivos, ainda que não documental, gera forte convicção, o que significa que a defesa direta, para abalá-la, deve ser fundada. Mais uma vez se tem uma espécie de presunção da existência do direito, a atribuir ao réu o ônus da argumentação fundada, ou melhor, o ônus da argumentação capaz de demonstrar que a prova produzida pelo autor poderá ser negada pela instrução. Em caso contrário, a defesa deve ser considerada infundada ou imprestável para retirar a força da prova do autor.

Frise-se que a tutela da evidência, neste caso, não se funda em defesa de mérito indireta infundada, embora nada impeça que o réu, ao lado da defesa direta, articule a primeira forma de defesa. O que importa perceber, nesta situação, é que a defesa de mérito indireta infundada não é suficiente para permitir a tutela da evidência, uma vez que os fatos constitutivos são contestados.

O art. 311, IV do Código de Processo Civil, que se aplica à hipótese de prova documental dos fatos constitutivos e prova do réu incapaz de gerar dúvida razoável sobre os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, igualmente fundamenta a tutela da evidência quando há prova (não documental) dos fatos constitutivos e a defesa do réu é incapaz de colocá-los em dúvida. Não fosse assim, ou seja, se a prova dos fatos constitutivos tivesse que ser documental strictu sensu – documento –, não haveria motivo para cogitar de prova (in)capaz de gerar dúvida razoável sobre os fatos constitutivos. A única alternativa seria invocar a falsidade do documento. Sucede que os fatos constitutivos também podem ser evidenciados mediante prova (pericial ou testemunhal) documentada – e não apenas por documento – e a sua negação pode ser baseada em prova ou argumento que exija instrução, porém incapazes de trazer dúvida razoável.

##### **4.2. A tutela da evidência baseada em prova emprestada**

A doutrina diz que a prova emprestada é aquela que, tendo sido utilizada como prova em determinado processo, é transportada na forma documentada para outro, de idêntica ou diversa natureza.<sup>60</sup>

As provas pré-constituídas, como o documento público, não se confundem com a prova emprestada, não importando se já foram utilizadas em um processo anterior entre as mesmas partes. Estas provas são formadas à distância do juízo e, desta forma, não podem ser qualificadas de emprestada simplesmente pelo fato de já terem sido utilizadas em algum processo. Apenas as provas que são formadas em um processo anterior é que podem ser ditas emprestadas.

Para que uma prova, formada em determinado processo, possa ser utilizada de forma eficaz em outro, é necessário que tenha sido formada mediante a participação em contraditório das mesmas partes que figuram no processo para o qual deve ser transportada.<sup>61</sup> A eficácia da prova depende de que as partes do processo para o qual deve ser transportada tenham participado do processo no qual foi formada mediante um contraditório efetivo e adequado.

Se a tutela da evidência é admissível quando há prova documental do direito e a defesa é

infundada, é também razoável admiti-la quando o autor demonstra o fato constitutivo do seu direito mediante prova pericial ou testemunhal emprestada e a defesa – indireta ou direta – é infundada. Em outras palavras, se o autor pode demonstrar o fato constitutivo mediante prova emprestada e a defesa é infundada, não há motivo para não admitir a tutela da evidência.

Não há dúvida de que a prova pericial ou a prova testemunhal não têm o mesmo valor probatório da prova documental; contudo, a prova emprestada é suficiente para tornar um direito evidente e, assim, legitimar a sua pronta tutela. Nesta hipótese, a defesa infundada, capaz de legitimar a tutela da evidência, pode ser indireta ou direta. Lembre-se que o réu poderá requerer contraprova para tentar demonstrar a não existência dos fatos constitutivos.

#### **4.3. A tutela da evidência na hipótese de prova do núcleo do fato constitutivo e de contestação infundada dos seus elementos secundários**

A doutrina distingue o núcleo do fato constitutivo dos seus elementos secundários, afirmando que cabe ao autor provar o primeiro, enquanto que os segundos são presumidamente aceitos como existentes.<sup>62</sup> Para que fique clara a premissa a ser firmada, é oportuno recordar a seguinte passagem da doutrina de Moniz de Aragão:

assim, se o autor alega um negócio jurídico, terá de provar os fatos nucleares de que se origina, mas não terá de demonstrar, por exemplo, que o tabelião procurado para lavrá-lo agiu no perfeito exercício de suas atribuições, que o coparticipante é capaz, subscreveu-o e quis o ato etc. Esses fatos, por serem presumidamente aceitos como existentes, só terão de ser demonstrados se postos em dúvida. Mas, se o fato estiver incluído ‘no tipo’, cumprirá ao autor demonstrá-lo a despeito de normalmente ser tido como existente por força da aludida presunção.<sup>63</sup>

Como está claro, os denominados elementos secundários do fato constitutivo, se postos em dúvida pelo réu, devem ser provados pelo autor. Porém, o réu pode se sentir tentado a pôr em dúvida um fato secundário – que goza de presunção de existência – apenas para protelar o momento da tutela do direito.

Tratando-se de tutela da evidência, tal possibilidade não pode ser desconsiderada. É que o fato secundário, quando o núcleo do fato constitutivo está provado, goza de presunção, que evidentemente não pode ser elidida por qualquer alegação. Aliás, se qualquer alegação atinente aos fatos secundários fosse capaz de significar que o autor deve arcar com o tempo necessário para a elucidação do fato secundário contestado, estaria aberto o caminho para o demandado negar qualquer fato desta espécie, ainda que sem qualquer fundamento ou seriedade, apenas para protelar a realização do direito evidente.

Assim, cabe ao juiz indagar sobre a seriedade da defesa que investe contra fato secundário, devendo conceder a tutela da evidência quando a defesa for infundada e, desta forma, não merecer credibilidade suficiente para adiar a realização do direito. Nesta hipótese, não obstante a concessão da tutela da evidência com base em prova dos fatos nucleares do direito, o processo prosseguirá para que o autor possa provar os elementos secundários do fato constitutivo.

Sublinhe-se que a relação entre direito evidente e defesa infundada ou inconsistente não permite definir um grau de convicção suficiente. Não obstante, é certo que os casos em que os fatos constitutivos são admitidos ou são provados por meio de documento têm maior capacidade de permitir a formação de convicção suficiente à tutela da evidência. Isto, é claro, no que diz respeito ao pressuposto “direito evidente”, na medida em que a fragilidade da defesa está relacionada com a alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ou com a negação dos fatos constitutivos ou mesmo dos seus elementos secundários.

### **5. Justificativa da tutela da evidência baseada em defesa indireta infundada**

#### **5.1. O critério da distribuição do ônus da prova como vetor para a repartição do tempo do processo**

O art. 373 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que, em relação ao fato constitutivo, o

ônus da prova<sup>64</sup> incumbe ao autor e, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo, este ônus é do réu, permite que se determine, com facilidade, qual a parte que precisa da instrução da causa e, por consequência lógica, do tempo do processo.

Se o código afirma que cabe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, o mesmo critério deve servir de base para a distribuição do tempo do processo, pois aí o réu precisa não apenas da instrução da causa, mas também do tempo do processo.

Se os fatos constitutivos são incontroversos, não há razão para o autor ter que sofrer os males do tempo que o réu utilizará para tentar demonstrar os fatos que alegou na defesa indireta. Em outras palavras: ao autor não pode ser imposto o peso do tempo que serve unicamente ao réu.<sup>65</sup>

Scarselli, analisando esta questão à luz do art. 2.697 do CC italiano, argumenta que, na medida em que este artigo<sup>66</sup> é visto como uma norma ditada pelo bom senso para uma justiça distributiva dos ônus probatórios, pode ser lido extensivamente como a disposição que reparte entre o autor e o réu os ônus em geral da atividade instrutória processual, os quais não dizem respeito somente ao aspecto estático da prova, mas também àquele dinâmico do tempo necessário à sua produção. Assim, como é injusto que ao autor venha imposto o ônus da prova de todos os fatos controversos para obter o acolhimento da demanda, é também injusto que a este venha sempre atribuído o tempo da duração do processo sem a possibilidade de uma repartição imediata,<sup>67</sup> que no direito brasileiro pode ser feita mediante a tutela da evidência.

## **5.2. O princípio de que o tempo do processo deve ser suportado pela parte que necessita da instrução da causa**

A tutela da evidência permite a realização antecipada do direito, evitando que o tempo do processo seja utilizado pelo réu em prejuízo do autor. Quando baseada na técnica da reserva da cognição da defesa de mérito indireta infundada, responde precisamente ao princípio pelo qual o tempo do processo deve se voltar contra a parte que tem necessidade da instrução da causa para demonstrar a sua alegação.<sup>68</sup> Com efeito, se os fatos constitutivos são incontroversos e é apresentada uma defesa de mérito indireta infundada que requer instrução dilatória, é racional que o réu suporte o tempo que correrá em seu benefício.

A tutela da evidência, exatamente porque abre oportunidade para a generalização de um mecanismo de distribuição do tempo do processo, evita que se veja na aceleração da execução qualquer privilégio atribuído a uma determinada posição social em detrimento de outra.

É importante recordar que a teoria dos títulos executivos extrajudiciais, atrelando-se à técnica da reserva de todas as defesas do devedor, foi fundamental para viabilizar a estruturação do processo de execução à margem do processo de conhecimento.<sup>69</sup> Melhor explicando: a reserva da cognição das defesas do devedor para os embargos do executado foi o que tornou possível a execução apenas a partir do título executivo extrajudicial.

De modo que o conceito de título executivo extrajudicial e a individualização da ação de execução constituem genuíno exemplo de distribuição do ônus do tempo da justiça entre o detentor do título extrajudicial e o devedor.<sup>70</sup> É o que explica Scarselli:

Se a qualidade dos títulos executivos extrajudiciais decorre do fato de que estes representam a prova dos fatos constitutivos, então parece indiscutível que para o ordenamento jurídico esta prova é pressuposto suficiente para a instauração da execução. Nestes termos, os títulos executivos extrajudiciais – de cuja legitimidade ninguém nunca duvidou – demonstram melhor do que qualquer outro instituto processual a existência do princípio pelo qual o tempo do processo deve ser suportado pela parte que tem necessidade da instrução da causa, porque evidenciam que, em regra, o ordenamento supõe suficiente a prova dos fatos constitutivos para antecipar a execução à sentença de cognição exauriente.<sup>71</sup>

A existência da técnica dos títulos executivos extrajudiciais demonstra a correção do princípio de que o tempo do processo deve ser suportado pela parte que necessita da instrução da causa.<sup>72</sup> Aliás, a relação da técnica dos títulos executivos extrajudiciais com este princípio é reafirmada quando se estabelece que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo” (art. 919, CPC),

deixando-se ao juiz a possibilidade de, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, estando a execução já garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, houver probabilidade de êxito dos embargos e possibilidade de o prosseguimento da execução causar dano ao executado – obviamente que significativo.

Este sistema executivo dá valor à evidência do direito, representado pelo título executivo extrajudicial, assim como ao conteúdo e ao significado da defesa, já que a suspensão da execução resta na dependência da relevância dos fundamentos dos embargos e de o prosseguimento da execução poder causar dano.

Quem evidencia um direito deve ter à sua disposição – no procedimento comum ou monitorio – técnicas que correspondam a esta situação, ou seja, técnicas (antecipatórias) que permitam a aceleração da realização do direito evidenciado. A falta de predisposição destas técnicas certamente agrava o dano marginal que é sempre imposto ao autor que tem razão e nega o princípio de que o autor que evidencia o seu direito não pode ser prejudicado pelo tempo necessário à instrução de uma defesa abusiva.

Porém, através da técnica dos títulos executivos<sup>73</sup> muitas vezes são privilegiadas determinadas posições sociais sem que ocorra uma precisa visualização do benefício outorgado. Os cultores do direito processual meramente técnico não poucas vezes deixam de se importar com a “substância das coisas”. É interessante recordar, de fato, que aqueles que condenaram os processos sumários jamais rejeitaram a teoria dos títulos de crédito, abstração criada para que os empresários pudessem deixar de lado o procedimento comum para usar do mais sumário de todos os procedimentos que a doutrina já concebeu.<sup>74</sup>

Proto Pisani, além de expressamente denunciar que os títulos executivos extrajudiciais sempre privilegiaram determinados grupos sociais e seus respectivos direitos,<sup>75</sup> propõe o alargamento da técnica dos títulos extrajudiciais a todas as hipóteses em que um documento idôneo seja capaz de fornecer um grau de probabilidade considerado suficiente, independente do peso político dos sujeitos que deles poderão usufruir.<sup>76</sup>

Note-se, entretanto, que a tutela da evidência mediante a técnica da reserva da cognição da defesa de mérito indireta infundada, porque atípica e genérica, responde precisamente à exigência de distribuir o tempo do processo sem privilegiar uma determinada posição.

Se é preciso distribuir o tempo do processo de acordo com a necessidade da instrução probatória, esta distribuição pode ser feita por meio da concepção de um procedimento especial ou de uma técnica que atue no interior do procedimento comum. O procedimento especial, contudo, parte do pressuposto de que existe uma situação específica que requer tratamento processual diferenciado. Entretanto, se todos concordam que o autor não pode pagar pelo tempo que serve ao réu, não há como supor que apenas algumas situações específicas podem exigir técnica que permita a distribuição do ônus do tempo do processo. Melhor explicando: a necessidade de distribuição do ônus do tempo processual não constitui situação especial, mas sim algo absolutamente comum a toda e qualquer situação de direito substancial, motivo pelo qual o procedimento comum não pode deixar de ser dotado de técnica processual capaz de permitir a distribuição do tempo.

Ao se admitir a distribuição do ônus do tempo somente em procedimentos especiais estará se tratando de forma diferenciada apenas determinadas situações de direito substancial, esquecendo-se que a inversão do ônus do tempo pode ser necessária diante de qualquer caso conflitivo concreto. Nesta dimensão, tal tratamento diferenciado constitui evidente privilégio discriminador, obrigando a ver que a tutela da evidência com base na reserva da cognição da defesa de mérito indireta infundada é imprescindível para a democratização do processo civil.

### **5.3. O processo não pode prejudicar o autor que tem razão**

O princípio de que “la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione”, analisado por Chiovenda – em antigo ensaio intitulado “Sulla perpetuatio iurisdictionis”<sup>77</sup> – a

partir do princípio geral segundo o qual “la necessità di servirsi del processo non deve tornar a danno di chi è costretto ad agire o difendersi in giudizio”, objetiva demonstrar que o processo deve dar ao autor tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter.

Este princípio obviamente não pode ser compreendido à distância da ideia de que o tempo do processo deve ser suportado pela parte que necessita da instrução da causa. Essa ideia explicita algo fundamental para a concretização do princípio, na medida em que a distribuição do tempo de acordo com o ônus da produção da prova é indispensável para que o processo não cause dano ao autor que tem razão ou para que lhe dê exatamente o que tem o direito de obter.<sup>78</sup>

Afirma-se que o processo prejudica o autor que tem razão quando não lhe dá, apesar da sentença de procedência transitada em julgado, o bem da vida a que tem direito. É que durante o curso do processo, como é sabido, podem surgir situações – como a dissipação dos bens que seriam objeto da execução – que impeçam ao autor obter aquilo que a própria sentença reconheceu ser seu direito.

Entretanto, ainda que nenhuma situação anômala possa colocar em risco o direito do autor, a simples duração do processo, eliminando a possibilidade de o autor poder ver realizado imediatamente o seu direito, é fonte de prejuízo. Neste sentido se diz que o processo sempre causa um dano “marginal” ao autor que tem razão.<sup>79</sup> Este dano marginal somente pode ser atenuado ou eliminado através de técnicas que permitam a distribuição do ônus do tempo do processo e, assim, também através da tutela da evidência.

É por isto que o princípio de que o processo não pode prejudicar o autor que tem razão deve ser lido à luz da ideia de que o tempo deve ser suportado pela parte que necessita da instrução da causa. Quando o tempo é corretamente distribuído entre os litigantes, o autor deixa de ser prejudicado pela demora do processo, compreendido o prejuízo, aí, como o dano que é imposto pelo tempo da “justiça” a todo autor que tem razão.

#### **5.4. A necessidade de evitar o agravamento da situação da administração da justiça**

É sabido que o procedimento comum, por ser completamente alheio às necessidades do direito material, não é adequado à tutela das diferentes situações conflitivas concretas.<sup>80</sup> Em razão da sua neutralidade, este procedimento tem um custo alto não apenas para o demandante, mas também para a administração da justiça.

O custo do procedimento comum, derivado da sua estrutura e da necessidade do duplo grau de jurisdição, incide de forma evidente sobre a crise da justiça civil, especialmente quando é injustificado em face da evidência do direito do autor e da falta de fundamento da defesa. A multiplicação de procedimentos comuns, tratando de situações com tais características, colabora – em razão do acúmulo de processos – para a quase paralisação dos feitos, trazendo graves e perturbadoras consequências.

É necessário advertir que as disfunções da administração da justiça não podem ser encaradas em perspectiva técnica e neutra, devendo ser vistas em uma dimensão social e política, que repercute não apenas sobre a efetividade das garantias constitucionais, mas também sobre o próprio funcionamento do sistema democrático e do Estado de Direito.<sup>81</sup>

Uma justiça lenta é fonte de desestímulo para o cidadão recorrer à justiça, propiciando a chamada litigiosidade contida,<sup>82</sup> com todas as suas indesejáveis e perigosas mazelas. O direito de acesso à justiça<sup>83</sup> depende de uma justiça eficiente, não apenas porque os direitos devem ser tutelados de forma efetiva, mas também porque a lentidão é fonte de descrença no Judiciário e alimento para a injustiça social<sup>84</sup>.

#### **5.5. A necessidade de evitar o abuso do direito de defesa**

A tutela da evidência baseada na técnica da cognição com reserva da defesa de mérito indireta infundada, além de permitir a repartição do tempo do processo entre os litigantes, desestimula o



réu de abusar do seu direito de defesa.<sup>85</sup>

Se não basta a circunstância de a defesa indireta exigir instrução dilatória, devendo ser necessariamente infundada, a tutela da evidência certamente não tem apenas o objetivo de repartir o tempo do processo entre o autor e o réu, mas também o escopo de inibir o exercício abusivo do direito de defesa. Ora, caso a realização do direito tivesse que ser protelada em virtude de uma defesa indireta infundada, o réu estaria com o campo aberto para abusar do seu direito de defesa.

Aliás, Proto Pisani argumenta, no direito italiano, que

a técnica que pode satisfazer a exigência de evitar o abuso do direito de defesa é a da ‘condenação’ com reserva das defesas. Com base nesta ‘condenação’, o juiz, conhecendo apenas os fatos constitutivos, profere uma tutela relativa ao mérito, remetendo a uma fase processual sucessiva a cognição das defesas indiretas.<sup>86</sup>

## **6. Justificativa da tutela da evidência na hipótese de defesa direta infundada**

### **6.1. A imprescindibilidade de defesa direta necessariamente fundada diante da força argumentativa implícita na prova do autor**

Na hipótese em que o direito afirmado na petição inicial é evidenciado mediante prova distinta da documental, como acontece quando o autor se vale de prova emprestada, bem como no caso em que o autor prova documentalmente o núcleo do fato constitutivo e o réu nega os seus elementos secundários, também há “direito evidente”.

No caso em que o fato constitutivo é objeto da instrução dilatória e, ainda assim, está evidenciado, evidentemente não é possível distribuir o ônus do tempo do processo a partir da ideia de que o ônus da prova é do réu. A instrução dilatória, neste caso, recairá sobre os fatos constitutivos. Não é possível aplicar o critério “da distribuição do ônus da prova como vetor para a repartição do tempo do processo” e o “princípio de que o tempo do processo deve ser suportado pela parte que necessita da instrução da causa”.

Porém, como a prova realizada pelo autor faz surgir um “direito evidente”, esse direito goza de presunção e legitima a inversão do ônus do tempo do processo. O direito evidente possui força argumentativa implícita. Assim, especialmente porque a defesa é direta – negando apenas os próprios fatos constitutivos –, o réu tem o ônus de argumentar para dissolver a evidência do direito e, portanto, o ônus de articular uma “defesa fundada” e não uma “defesa qualquer”. Isto porque o “direito evidente” obviamente não pode ser descaracterizado por qualquer defesa direta, como aconteceria se o direito não fosse evidente. Para abalar a credibilidade do direito do autor, o réu deverá necessariamente apresentar uma “defesa fundada”.

O réu tem o ônus de argumentar para demonstrar que o direito evidenciado não merece pronta tutela, assim como acontece no caso de tutela da evidência baseada na técnica da reserva da cognição da defesa de mérito infundada. A diferença é a de que, no caso de defesa indireta, a argumentação é dirigida a demonstrar um fato alegado na própria defesa, ao passo que, na defesa direta, a argumentação nega o fato articulado na petição inicial.

Ora, há clara distinção entre argumentar para demonstrar algo que deve ser provado e argumentar para dissolver o que está evidenciado. Para se concluir que a defesa indireta é fundada é preciso atentar para a argumentação relacionada com os fatos nela alegados. Ao inverso, para se admitir que a defesa direta é fundada, é preciso ver se a argumentação nela desenvolvida tem idoneidade para descaracterizar fatos já evidenciados.

Por outro lado, se na defesa indireta o ônus da prova e, por consequência lógica, o ônus do tempo do processo são do réu, na defesa direta o ônus da prova ainda pesa sobre o autor e, assim, a justificativa para retirar do autor e atribuir ao réu o ônus do tempo processual certamente é diferente da que se funda no “princípio de que o tempo do processo deve ser suportado pela parte que necessita da instrução da causa”.

Nesta hipótese não existe propriamente distribuição, mas sim inversão do ônus do tempo do processo. Embora o tempo seja gasto para elucidar os fatos constitutivos, justifica-se a sua inversão em razão da circunstância de a defesa não ser revestida de fundamento ou seriedade capaz de colocar em dúvida a prova produzida pelo autor.

Quando os fatos constitutivos estão demonstrados através de prova emprestada ou o núcleo do fato constitutivo está positivado através de documento, a defesa direta deve ser revestida de uma argumentação capaz de abalar a convicção judicial decorrente da prova já produzida pelo demandante. Daí a razão para se falar de defesa necessariamente fundada e de inversão do ônus da argumentação em virtude da força argumentativa implícita na prova do autor.

## **6.2. A força da prova do autor como critério para se ter como abusiva a defesa direta apresentada sem fundamento sério. A necessidade de evitar o abuso do direito de defesa**

Diante de prova emprestada ou de prova do núcleo do fato constitutivo, a defesa destituída de fundamento ou seriedade não pode protelar a realização do direito. É por isto que, no caso de defesa infundada, legitima-se a concessão da tutela da evidência.

É claro que a defesa é abusiva porque exige instrução dilatória e, assim, consome tempo do processo e retarda a satisfação do direito. Note-se, porém, que a circunstância de a instrução ser necessária diante dos argumentos de defesa não significa que estes sejam fundados. É abusiva a defesa que protela a realização de um direito evidenciado, negando os fatos constitutivos sem fundamento capaz de abalar a convicção decorrente da prova produzida pelo autor<sup>87</sup>.

A tutela da evidência, nesta dimensão, colabora para inibir o exercício abusivo do direito de defesa, voltado a extrair vantagem às custas de prejuízo ao autor que faz ver o direito que afirma como evidente.

## **7. A tutela da evidência na dimensão dos direitos fundamentais processuais**

Como é sabido, o art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, garante o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Não basta afirmar que todos têm direito de ação quando a organização judiciária e os procedimentos não estão adequadamente predispostos para viabilizar a adequada e efetiva tutela jurisdicional.<sup>88</sup>

O tempo que o Estado consome para tutelar os direitos não pode ser jogado nas costas do autor, como se a culpa pela demora do processo fosse sua. O processo deve ter o seu tempo igualitariamente distribuído entre as partes. Aliás, a melhor doutrina italiana adverte que as reformas legislativas têm privilegiado as formas de tutela de cognição sumária exatamente em razão da intolerância cada vez maior em relação à demora e à disfunção do processo civil, intolerância esta que acompanha a tomada de consciência de que a tempestividade da tutela jurisdicional é elemento indispensável para a atuação concreta e efetiva da garantia constitucional da ação e de que a falta de efetividade dos instrumentos processuais pode levar à acentuação das desigualdades entre os litigantes.<sup>89</sup>

A distribuição do tempo do processo, realizada quando o réu necessita da instrução da causa a partir de defesa indireta infundada e quando nega os fatos constitutivos sem fundamento sério, além de imprescindível para evitar o exercício de defesas abusivas, é absolutamente indispensável para dar às partes igual responsabilidade perante o processo e para que os ônus processuais recaiam sobre ambas as partes de forma isonômica.

É intuitivo que quando o tempo é visto de modo neutro e indiferente em relação ao resultado concreto do processo, o réu não só recebe sinal positivo para protelá-lo como é isento de qualquer responsabilidade pela sua conduta. O art. 5.º, LV, da Constituição Federal, ao dizer que aos litigantes são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, obviamente não impede o emprego da técnica processual indispensável à distribuição do ônus do tempo do processo entre as partes.



A tutela da evidência – não obstante o inconstitucional parágrafo único do art. 311 – não pode ser prestada inaudita altera parte. O réu sempre tem a oportunidade de contestar os fatos constitutivos e apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, requerendo, se a defesa não depender de instrução, o imediato julgamento do mérito.

Lembre-se, por outro lado, que esta forma de tutela antecipada – dita de evidência – sempre se funda em cognição sumária. No caso de defesa indireta, a cognição sumária recai sobre os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, ao passo que, tratando-se de defesa direta, a cognição sumária fica retida nos próprios fatos constitutivos. Quer isto dizer que a tutela da evidência é provisória e capaz de ser revogada ao final do procedimento. De modo que, após a sua concessão, o réu continua a se defender no processo, atuando para que a defesa seja acolhida. O contraditório é apenas postecipado, à semelhança do que ocorre em todas as outras hipóteses em que se concede tutela provisória.<sup>90</sup> Além disto, para combater os efeitos da tutela da evidência, o réu tem o direito de interpor recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (arts. 1.015, I, e 1019, I, CPC).

A necessidade de distribuição do tempo do processo e, portanto, de técnica processual idônea a tanto, é indispensável para dar concretude ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e ao princípio da isonomia. A circunstância de tal técnica trazer risco ao direito de defesa não pode inviabilizar a sua utilização, pois o procedimento comum, ao obrigar o autor a arcar sozinho com o tempo do processo, é desconforme aos valores constitucionais, constituindo fonte de injustiça e evidente estímulo para o abuso do direito de defesa.

## **8. As hipóteses dos incisos do art. 311**

### **8.1. A cláusula geral do “abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório”**

O inciso I do art. 311, ao falar em abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório, simplesmente repete a dicção do inciso II do art. 273 do código de 1973, que abria oportunidade para tutela antecipada em caso de abuso de direito de defesa. Nunca houve razão para distinguir abuso de defesa e manifesto propósito protelatório, na medida em que aos dois é possível outorgar um mesmo sentido geral, capaz de ser concretizado nos vários casos conflitivos.

Trata-se de conceito jurídico indeterminado. Bem por isso, cabe tutela da evidência quando, em qualquer caso, o juiz puder declarar, diante da evidência do direito e da inconsistência da defesa, que o seu exercício, ao exigir instrução dilatatória, constitui um abuso. Portanto, o inciso I é a base da tutela da evidência, capaz de ser utilizado apenas quando se compreende a elaboração teórica desta forma de tutela (exposta supra, especialmente nos itens 4-8).

Realmente seria absurdo imaginar que a tutela da evidência é cabível apenas nas hipóteses dos incisos II, III e IV do art. 311. Note-se que o inciso III nada mais é do que um dos muitos exemplos de tutela da evidência baseada em prova dos fatos constitutivos e defesa infundada que requer instrução dilatatória. Na verdade, caso o art. 311 fosse um mero amontoado de exemplos, haveria uma simples descrição de hipóteses traçadas em privilégio de determinados titulares de documentos ou contratos. Assim, caso não existisse o inciso I, ou melhor, a cláusula geral da tutela da evidência, a oportunizá-la em todos os casos em que há direito evidente e defesa inconsistente que exige instrução dilatatória, haveria violação da isonomia. Não é por outro motivo que o inciso I do art. 311 deve ser visto como uma regra geral de democratização do processo – que viabiliza técnica processual idônea a toda e qualquer situação de direito substancial.<sup>91</sup>

### **8.2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante**

A regra do inciso II do art. 311 pretende sintetizar uma hipótese de direito evidente. Porém, não servirá a um devido fim caso não interpretada de acordo com a elaboração teórica supra desenvolvida.

Percebe-se desde logo que a norma misturou alegações de fato com questão jurídica que pode

ser resolvida mediante a aplicação do entendimento devidamente consolidado em Corte Suprema. A ideia de súmula vinculante e de decisão tomada em “casos repetitivos”, como melhor demonstrado no volume de Comentários desta Coleção ao artigo 926 e seguintes (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero), indica meros exemplos do entendimento das Cortes Supremas, que, mais do que em qualquer outro lugar, está em seus precedentes.

A regra afirma que as alegações de fato devem poder ser demonstradas apenas documentalmente, sem precisar que parte as produziu. Ocorre que, se as alegações de fato não exigem prova distinta da documental e o fundamento do autor, não obstante questionado, está amparado em precedente de Corte Suprema, o caso é de julgamento antecipado do mérito, o mesmo acontecendo se a defesa de mérito indireta – por exemplo prescrição – contraria entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

Também seria possível raciocinar mediante o argumento de que as alegações de fato do autor devem estar provadas documentalmente, sem depender de qualquer outra prova. Ao não existir qualquer outra alegação de fato passível de demonstração – nem do réu –, entendimento de Corte Suprema serviria apenas para mais uma vez viabilizar o julgamento antecipado do mérito.

Isso significa que a norma só tem algum valor se interpretada no sentido de que as alegações do autor, evidenciadas por documento, têm fundamento jurídico amparado em entendimento de Corte Suprema, mas as alegações de fato do réu, a despeito de destituídas de seriedade, exigem instrução dilatória.

Note-se que a prova dos fatos constitutivos, somada ao entendimento de Corte Suprema, retira do autor qualquer necessidade de atuar no processo para convencer o juiz sobre o seu direito. A única razão para o processo prosseguir está na necessidade de instrução dilatória, derivada das alegações de fato cujo ônus da prova é do réu. De modo que, se tais alegações não são dotadas de seriedade suficiente para fazer crer que podem ser ao final acolhidas, a tutela indispensável à distribuição do ônus do tempo do processo (tutela da evidência) deve ser concedida.

### **8.3. Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa**

O inciso III é um particular – e especial – benefício outorgado pelo legislador aos titulares dos documentos que espelham contrato de depósito. Nada contra estes. Contudo, há dezenas de documentos de igual natureza não contemplados pelo legislador. Daí que a regra só pode ser uma encomenda de posições sociais que se valem destes documentos. Note-se que a curiosidade está em se ter uma previsão específica, quando as demais situações de direito substancial, à falta de uma elaboração teórica capaz de outorgar inteligência ao inciso I do art. 311, ficariam destituídas de tutela da evidência. Aliás, a compreensão do inciso I a partir de uma visão teórica que beneficia toda e qualquer situação de direito substancial obviamente exclui a necessidade do inciso III. De forma que nada elimina a ideia de que o legislador – um Parlamento habitado por maioria de orientação socialista – agiu apenas para bem tratar uma específica posição social. Contraditoriamente ou não – não se sabe a real intenção dos parlamentares –, vale a pena advertir para a “evidência” da “falta de seriedade” – o trocadilho é oportuno – com que este Parlamento agiu.

De qualquer forma, o conteúdo técnico da norma do inciso III não é menos vexatório. Isto porque, se o objetivo é privilegiar o titular do contrato de depósito, não é suficiente aludir a “prova documental adequada do contrato de depósito”. A tutela da evidência depende de prova documental ou de incontrovérsia de todos os fatos constitutivos. Tratando-se de contrato de compra e venda, por exemplo, os fatos constitutivos do exercício da pretensão ao recebimento do preço estão no contrato e na entrega da coisa. No caso de contrato de depósito, é indispensável a prova do contrato e da mora na entrega da coisa. É simples: só há evidência, capaz de justificar a distribuição do ônus do tempo do processo mediante a imediata outorga da tutela do direito, quando os fatos constitutivos não estão na dependência de demonstração.

Se o demandado alegar a falsidade do documento que ampara o fato constitutivo, mostrando-se necessária a produção de prova, deixa de existir evidência hábil a justificar a tutela da evidência. A alegação de falsidade desconstitui a evidência intrínseca à prova documental.

Além disso, quando o contrato e a mora estão provados ou são incontroversos, só há razão lógica para pensar em tutela da evidência quando o processo deve prosseguir para a elucidação de alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que careça de consistência ou seriedade. Se assim não acontecer, a hipótese é de julgamento antecipado do mérito.

Note-se que o inciso III não faz qualquer indicação a prosseguimento do processo e a defesa de mérito infundada. Ora, a demora do processo e a resistência destituída de seriedade são imprescindíveis para pensar em tutela da evidência. Portanto, há que se interpretar o inciso III do seguinte modo: além da prova documental do contrato de depósito e da incontrovérsia sobre a mora, há de se ter defesa de mérito indireta infundada que requeira instrução dilatória. Se esta instrução não é necessária, o caso é de julgamento antecipado do mérito. Ora, se os fatos constitutivos estão evidenciados e não há alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que exijam tempo do processo, a solução obviamente está no julgamento antecipado, não havendo qualquer motivo para cogitar de tutela da evidência.

#### **8.4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável**

O inciso IV é a norma que mais se aproxima da razão teórica da tutela da evidência. Fala em prova documental suficiente dos fatos constitutivos. É certo que, tendo-se em conta o significado teórico de prova documental, aludir a prova suficiente constitui equívoco. É que, quando se leva à sério o conceito de prova documental, dessa decorre necessariamente o fato. O documento é um objeto que tem em si o fato. Daí que a única maneira de negar o fato representado em documento é a alegação da sua falsidade. Lembre-se que a prova documental ou o documento não se confunde com a prova documentada, ou seja, com a prova que contém a declaração de uma testemunha sobre um fato ou mesmo a declaração de um especialista sobre determinada situação fática. Estas provas, não obstante retidas em papel, constituem declarações de testemunha e de especialista sobre um fato, vale dizer, precisamente uma mera versão a respeito do fato.

Admitida a falta de técnica jurídica, é possível ler no lugar de prova documental prova capaz de ser apresentada mediante papel, ou seja, prova que pode constituir documento e também prova testemunhal ou pericial documentada. Nessa dimensão, a defesa que pode ser oposta aos fatos constitutivos não se limita à alegação de falsidade. O réu tem a possibilidade de requerer prova testemunhal ou pericial para negar os fatos constitutivos. Isso porque a prova testemunhal ou pericial documentada de que se vale o autor, ou seja, a prova produzida em outro processo de que o réu também participou, não é prova suficiente à demonstração dos fatos constitutivos.

O inciso IV fala em oposição de prova “capaz de gerar dúvida razoável”. Entretanto, o que pode se opor à prova dos fatos constitutivos é a alegação de falsidade do documento ou a negação dos fatos constitutivos evidenciados mediante prova testemunhal ou pericial documentada. A alegação de falsidade, ao abrir oportunidade a prova, retira a força do documento, excluindo a possibilidade de tutela da evidência. Porém, a negação do fato constitutivo e o consequente requerimento de produção de prova, conforme o caso concreto, podem ser incapazes “de gerar dúvida razoável” diante da prova “documentada” dos fatos constitutivos. Nessa hipótese o juiz está autorizado a conceder tutela da evidência.

Mas o inciso IV melhor se aplica à hipótese em que há prova documental dos fatos constitutivos e o réu apresenta defesa de mérito indireta – alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos – infundada. Como é óbvio, a defesa indireta, não obstante infundada, tem que exigir instrução dilatória, uma vez que de outra forma o caso será de julgamento antecipado do mérito. Em outras palavras, quando há prova dos fatos constitutivos e o réu apresenta defesa indireta que requer produção de prova, mas é “incapaz de gerar dúvida razoável”, cabe tutela da evidência.

## 9. A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 311

Afirma o parágrafo único do art. 311 que, “nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. Ou seja, o parágrafo único, sem qualquer racionalidade e base constitucional, afirma que o juiz pode conceder tutela da evidência se “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (inciso II, art. 311, CPC) e quando “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito ...” (inciso III, art. 311, CPC).

Em primeiro lugar há absoluta falta de racionalidade no dispositivo. É que obviamente não se pode aferir evidência do direito antes de o réu ter sido citado e apresentado defesa. Note-se, por exemplo, que a alegação de falsidade é suficiente para descaracterizar a evidência das “alegações de fato” e da “prova documental” do contrato de depósito. Isso para não falar que a tutela da evidência sempre depende da análise da consistência da defesa de mérito, direta ou indireta. Os incisos II e III, conforme demonstrado, dizem respeito a situações em que o réu apresenta defesa de mérito indireta infundada que requer instrução dilatória. De modo que é absolutamente impossível aferir os pressupostos para a tutela da evidência liminarmente.

Na verdade, o legislador se confundiu bastante ao editar as normas relativas à “tutela provisória” e, ao tratar da “tutela da evidência”, continuou perdido. Bem vistas as coisas, parece que o legislador não sabia o que estava fazendo. Daí a importância de a doutrina colocar as coisas em seus devidos lugares. Tudo indica que o legislador supôs que poderia, sob o rótulo de tutela da evidência, construir uma espécie de procedimento documental, em que o juiz estaria autorizado a proferir sentença, com base na evidência do direito – prova documental –, logo após a ouvida do réu.

A lógica equivocada do legislador parte do pressuposto de que, como a sentença pode ser proferida logo após a ouvida do réu, antes da citação deve caber liminar quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (inciso II, art. 311, CPC) e quando “houver prova documental adequada do contrato de depósito” (inciso III, art. 311, CPC). Como é óbvio, isto só teria algum sentido se a tutela nada tivesse a ver com evidência do direito e com fragilidade da defesa. Ora, estes pressupostos devem ser aferidos depois da apresentação da defesa para que o autor não seja prejudicado pela demora do processo. Não é por outro motivo que a tutela da evidência é provisória, ou melhor, concedida mediante decisão fundada em cognição sumária e sujeita a confirmação pela sentença.

Lembre-se, aliás, que a cognição sumária diz respeito em regra à defesa indireta; os fatos constitutivos devem ser incontroversos ou estar provados mediante documento, o que significa que em relação aos fatos constitutivos deve haver cognição exauriente. Sucede que a cognição exauriente, ou melhor, a aferição da incontrovérsia – não contestação e incompatibilidade entre a negação do fato constitutivo e a defesa indireta – e da qualidade do documento – não alegação de falsidade – dependem da devida oportunidade à manifestação do demandado, especialmente da análise da defesa. Isso demonstra que liminar antes da ouvida do réu jamais pode ser tutela da evidência, embora possa ser concedida quando o tempo para a ouvida do demandado puder causar dano.

O parágrafo único do art. 311 não é apenas uma peça que não foi feita para o jogo ou que não cabe no tabuleiro. Ao exigir direito evidente e, assim, não poder dispensar a análise da defesa, tutela da evidência antes da ouvida do réu não é apenas uma contradição em termos; é igualmente uma tutela que viola o contraditório e o direito da defesa. Não há como admitir que um fato constitutivo está provado mediante documento antes da ouvida do demandado<sup>92</sup>. De outro modo, o procedimento monitorio, em caso de prova escrita que configura prova documental ou documento, também deveria abrir oportunidade para a tutela do direito antes da citação do réu. No mínimo para que os direitos não fossem tratados de modo diferente. E nem se diga que os incisos II e III representam formas de tutela jurisdicional diferenciada ou especial. O inciso II afirma pressupostos para a tutela da evidência que podem ser encontrados nas mais diversas

situações de direito substancial. De outra parte, embora relativo à hipótese específica do contrato de depósito, o inciso III está inserido num quadro em que a lógica da tutela da evidência deve ser preservada sob pena de se ter outra forma de tutela – que não a tutela da evidência.

#### **10. Momento oportuno à concessão da tutela da evidência**

De acordo com o art. 357 do Código de Processo Civil, não sendo o caso de julgamento antecipado do mérito ou de extinção do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: i) resolver as questões processuais pendentes, se houver; ii) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; iii) definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; iv) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e v) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

A “delimitação das questões de fato” importa para a seleção dos fatos litigiosos que ainda devem ser elucidados, tendo grande relevo para a racionalização do processo, evitando discussões estéreis, provas produzidas sem propósito, custos econômicos aos litigantes e ao Poder Judiciário, e especialmente o dispêndio do tempo da justiça e das partes sem razão de ser.

A definição de um fato como controvertido constitui premissa para a produção da prova, mas a exata localização do fato controvertido entre os fatos constitutivos, extintivos, modificativos e impeditivos é pressuposto para a atribuição do ônus da prova a um dos litigantes, nos termos do inciso III do art. 357.

Além disto, a delimitação do material fático controvertido e a caracterização da sua qualidade constituem elementos imprescindíveis ao tratamento do ônus do tempo do processo. Frise-se que a tutela da evidência é viável em duas situações: i) quando a controvérsia recai unicamente sobre os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, mas a defesa indireta é infundada e ii) quando a controvérsia atinge os fatos constitutivos, mas a prova sobre eles gera forte convicção e a defesa direta é infundada.

Se a decisão de saneamento e organização do processo define os fatos litigiosos controversos e onde eles se situam, não há dúvida que este é o momento ideal para o juiz decidir sobre a tutela da evidência, lembrando-se que o juiz pode inclusive dialogar com as partes para melhor compreender a situação fática. Não é demais recordar que, nos termos do § 3º do art. 357 do Código de Processo Civil,

se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

Note-se, ainda, que a possibilidade da tutela da evidência restaura o equilíbrio das partes e neste sentido favorece a conciliação – não obstante o momento processual definido pelo código para a conciliação já tenha sido ultrapassado. Como a demora prejudica o autor e beneficia o réu, o tempo obviamente assume valor diante da possibilidade de conciliação. A tutela da evidência coloca as partes em posição de equilíbrio, viabilizando uma “conciliação justa”, ou melhor, uma conciliação em que o tempo do processo não é utilizado como “moeda de troca” em favor do réu. Roger Perrot, aliás, ao falar sobre os resultados do *référé-provision*<sup>93</sup>, adverte que na França foram desencorajados os maus litigantes que se esforçavam em fazer o processo durar muito tempo apenas para poder arrancar concessões dos seus adversários.<sup>94</sup>

#### **11. Possibilidade de revogação da tutela e agravo de instrumento com efeito suspensivo**

Quando os fatos constitutivos são incontroversos ou estão evidenciados, o exercício da defesa, mediante a produção de provas, somente não é abusivo quando a defesa não é infundada ou destituída de seriedade. A defesa infundada que protela a tutela jurisdicional do direito evidente é abusiva, abrindo oportunidade à tutela antecipada de evidência (art. 311, CPC).

A decisão que concede a tutela da evidência é fundada em cognição sumária. Quando se exige

fatos constitutivos incontroversos e defesa indireta infundada, há cognição exauriente sobre os fatos constitutivos e cognição sumária sobre os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Quando os fatos constitutivos são controvertidos e a defesa direta é infundada, a cognição exauriente não atinge qualquer parcela dos fatos, havendo cognição sumária sobre os fatos constitutivos.

Por ser baseada em cognição sumária, a decisão é provisória e suscetível de modificação ou revogação quando da sentença (art. 296, CPC). Justamente porque não põe fim à fase de conhecimento, constitui decisão interlocutória. Desafia recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC), que deve ser recebido no efeito devolutivo.<sup>95</sup>

A efetivação da tutela da evidência pode causar prejuízo ao demandado. Não é por outra razão que não se pode descartar eventual concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que a concede. O relator do agravo de instrumento deve ter em conta que a suspensão se volta contra uma tutela baseada em direito evidente e defesa inconsistente, ao contrário do que ocorre quando o agravo é interposto em face da tutela urgente – baseada em probabilidade do direito e perigo de dano. No agravo interposto contra a tutela da evidência não há valoração de perigo de dano enquanto pressuposto para a concessão da tutela. No que diz respeito ao efeito suspensivo, no caso de tutela urgente há nova análise do fumus e do perigo de dano – que legitimou a concessão da tutela ao recorrido – e análise do perigo de dano “inverso” – ao recorrente. Na hipótese de tutela da evidência, há – além da consideração da evidência do direito e da inconsistência da defesa – somente valoração do dano que pode derivar da efetivação da tutela.

## **12. Execução imediata da tutela da evidência e a questão da caução**

A decisão que concede a tutela antecipada de evidência, mesmo que não impugnada mediante agravo de instrumento, é uma decisão provisória que pode ser imediatamente executada. Ou melhor, a decisão concessiva da tutela, embora essencialmente provisória, pode ser executada no curso do processo e mesmo na pendência de eventual agravo de instrumento, observando-se – no que couber – as regras do “cumprimento provisório da sentença” (art. 297, parágrafo único, CPC).

Segundo o art. 520, IV, do Código de Processo Civil,

o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea,

que poderá ser dispensada nas hipóteses dos incisos do art. 521, ou seja, nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; ii) o credor demonstrar situação de necessidade; iii) pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042; iv) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos”, exceto quando da dispensa da caução “possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, CPC).

Portanto, a execução da tutela da evidência de soma em dinheiro é “completa” e fundada em título (decisão) provisório, porque capaz de satisfazer integralmente o direito do exequente, isto é, porque não se limita à penhora.<sup>96</sup> A circunstância da execução se submeter a restrição (prestação de caução suficiente e idônea) certamente não significa limitação ao seu alcance.

A caução relativa à tutela da evidência é a prevista apenas para a execução da tutela que impõe o pagamento de soma em dinheiro. O juiz não pode exigir caução para conceder a tutela da evidência, aplicando o § 1º do art. 300 – essa regra diz respeito apenas à tutela urgente. A caução, diante da tutela da evidência, além de somente poder ser cogitável para a execução, apenas pode ser exigida quando a execução é de soma em dinheiro, verificando-se se estão presentes os elementos constantes do inciso IV do art. 520 e, também, se não incidem os pressupostos de exceção dos incisos do art. 521.



No que diz respeito ao inciso IV do art. 521, ou seja, à decisão em “consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos”, é óbvia a sua inaplicabilidade à tutela da evidência. É que a relação entre a decisão e o entendimento das Cortes Supremas, para o efeito de dispensa de caução, certamente não importa quando se está diante de uma decisão que está na dependência de produção de prova.

### **13. Tutela da evidência na sentença**

#### **13.1. A tutela da evidência diante da contestação genérica**

O art. 416, terceira parte, do Código de Processo italiano, veda a contestação genérica ao frisar que

il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Discute-se na Itália se é possível a tutela antecipada de soma não contestada em caso de contestação genérica.<sup>97</sup> Parte da doutrina entende que a contestação genérica deve ser equiparada à não contestação para efeito de tutela antecipada.<sup>98</sup> Outra parte da doutrina nega que a contestação genérica possa ser enquadrada na esfera de comportamentos em que está situada a não contestação.<sup>99</sup> Porém, há autores que, embora não equiparando a contestação genérica à não contestação, concluem que a contestação genérica abre oportunidade à tutela antecipada. Afirma-se que o art. 423, primeira parte, contém uma sanção para a violação da proibição de contestação genérica – estabelecida na parte supracitada do art. 416 do código italiano. Argumenta-se que tal sanção – a tutela antecipada de soma não contestada – é necessária<sup>100</sup>, já que a sua falta reduziria a proibição de contestação genérica a uma inútil enunciação de princípio, sem qualquer eficácia vinculante para as partes, frustrando assim os escopos de colaboração e de concentração processual almejados pelo art. 416.<sup>101</sup>

Como relata Wellington Moreira Pimentel, durante a vigência do Código de 1939 a doutrina se dividiu

quanto à admissibilidade da negação geral. Frederico Marques considerava-a incabível. Outras vozes, não menos autorizadas (Gabriel de Rezende Filho, Lopes da Costa, Moacyr Amaral Santos), a admitiam. O legislador de 1973 tomou posição. A exigência feita no sentido de o réu manifestar-se precisamente sobre os fatos alegados pelo autor torna inviável a contestação por negação geral. A imposição relaciona-se diretamente com a questão do ônus probatório. É indispensável que se saiba se o réu reconhece ou admite cada um dos fatos apontados pelo autor na inicial, ou se os reconhece mas outros lhe contrapõe, ou, ainda, se os nega, ante a regra do ônus probatório. O texto primitivo do artigo, no Projeto enviado ao Congresso Nacional, estabelecia que ‘compete também ao réu manifestar-se especificamente sobre os fatos articulados na petição inicial’ e a alteração introduzida (manifestar-se precisamente) torna desenganadora a posição do legislador de repulsa à contestação por negação geral. Nem se poderá falar em contestação por simples negação geral que, no magistério de João Monteiro, se dá quando o réu nega geralmente os artigos da ação, sem, todavia, especializar a resposta (Teoria do Processo Civil, I, p. 324) diante de todo um sistema introduzido no Código que desce aos mínimos detalhes quanto à matéria a ser detidamente especificada pelo réu em sua resposta, desde todo um elenco de preliminares, até a própria defesa contra o mérito<sup>102</sup>.

Ora, o art. 341 do Código de Processo Civil de 2015 é uma reprodução do art. 302 do código de 1973, que claramente afirmou o ônus de o réu se manifestar de modo preciso sobre os fatos alegados na inicial.

A regra contida no art. 341 do Código de Processo Civil, segundo a qual cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, afasta completamente a possibilidade de contestação genérica no direito brasileiro. Segundo o parágrafo único do art. 341, a regra de que são presumidos verdadeiros os fatos não contestados não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. A estes é admitida a contestação genérica.



Se não há dúvida acerca da proibição da contestação genérica, cabe perguntar se o seu descumprimento pode acarretar a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor. A proibição da contestação genérica é ligada à ideia de que as partes têm o dever de colaborar com o juízo, expondo com veracidade e lealdade as suas posições.<sup>103</sup> O réu tem o dever de não alterar a verdade dos fatos e o ônus de não se omitir em relação aos fatos articulados pelo autor. A contestação deve impugnar especificamente os fatos deduzidos na petição inicial para que a massa dos fatos controversos seja limitada, definindo-se os contornos do tema litigioso. A contestação genérica, por ser capaz de tornar os fatos controversos a partir de uma simples negativa geral, não colabora para a redução dos fatos controversos e, assim, para a racionalização do processo mediante a investigação do que realmente importa para a elucidação do litígio.

A inobservância da proibição de contestação genérica obviamente deve ser sancionada com a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. De outra forma tal proibição não só deixa de ter valor, como ainda são frustrados os escopos de colaboração processual e concentração que estão à sua base.

Na hipótese de contestação genérica cabe julgamento antecipado do mérito. Note-se, porém, que o julgamento antecipado do mérito, nesta situação, não decorre de revelia (art. 355, II, CPC). Como é evidente, não há como pensar em revelia no caso de contestação genérica, já que houve apresentação de contestação, ainda que inepta. É preciso observar que o réu deve apresentar uma defesa apta. Se o réu apresenta contestação genérica incidem o arts. 341 e 355, I – e não os arts. 344 e 355, II –, uma vez que os fatos não contestados são presumidos verdadeiros e considerados incontrovertidos, independentemente de prova.<sup>104</sup>

Não tem sentido supor que o juiz, ao final do procedimento em que foi apresentada contestação inepta, não possa dar tutela ao direito. Isto seria premiar aquele que descumpre o seu dever de apresentar contestação idônea. Assim, há de se admitir a concessão da tutela da evidência na sentença (art. 1.012, § 1º, V, CPC), evitando-se que o custo do duplo grau de jurisdição possa recair sobre os ombros daquele que possui um direito que não foi controvertido devido à participação indevida do réu.

Lembre-se que no direito italiano, mesmo com a regra da execução imediata da sentença,<sup>105</sup> a doutrina insistiu para a necessidade da tutela antecipada total de soma não contestada (porque a não contestação podia ser total). Argumentou-se que entre o término da instrução e a sentença se passa um longo tempo, que não deve ser suportado pela parte autora<sup>106</sup>. Como observou Rampazzi,

deixando-se de lado o fato de que da letra da lei não se retiram elementos que façam pensar na necessidade de uma não contestação parcial como pressuposto indispensável para a emanção do provimento, contra a opinião antes recordada se coloca o interesse concreto que a parte credora tem de obter uma tutela executiva antecipada, ainda que na presença das condições para a pronúncia de mérito: a ninguém passa despercebido quanto é longo o tempo que intercorre entre o fim da instrução e a sentença, até mesmo se, na melhor das hipóteses, são exatamente respeitados os prazos que na intenção do legislador devem dar o ritmo à atividade decisória.<sup>107</sup>

Cabe advertir, aliás, que o código italiano passou a admitir a tutela antecipada (total) após o encerramento da instrução<sup>108</sup>.

Se o sistema permite que o réu descumpra o ônus de se manifestar precisamente sobre os fatos alegados na petição inicial, mas não admite que o autor desde logo obtenha a tutela do direito, abre caminho para o abuso do direito de defesa (art. 311, I, CPC). Com a tutela da evidência, evita-se que o réu apresente contestação genérica e ainda assim possa usufruir do tempo do processo – interpondo recurso – para protelar a prestação da tutela jurisdicional.

### **13.2. O réu que comparece no processo e não apresenta contestação**

Embora a revelia seja associada à não apresentação de contestação, pouco importando se o réu veio a juízo e não a apresentou ou simplesmente não veio a juízo, cabe aqui distinguir as duas hipóteses.

A revelia não implica necessariamente a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor. Entende-se que o simples não comparecimento não pode ser fonte de prejuízo processual para o réu porque uma série de razões, dignas de consideração, podem justificá-lo.<sup>109</sup>

Contudo, o comparecimento e a não apresentação de contestação não devem merecer a mesma complacência. Aquele que vem a juízo e não contesta assume uma posição que deve ser definida como ativa, já que há uma opção pela não contestação.

É sabido que um dos principais princípios do processo civil moderno impõe às partes o dever de colaborar com o juízo. A parte que opta por não contestar não só despreza este princípio, como também coloca em risco a validade daquele outro que diz caber ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial. Este último princípio, como já foi dito, não só visa possibilitar a redução da massa dos fatos controvertidos, como também permitir a sua melhor elucidação, contribuindo para uma melhor prestação jurisdicional.<sup>110</sup>

Ora, se o réu que deixa de se manifestar precisamente sobre os fatos alegados e o réu que apresenta contestação genérica são sancionados com a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, não é possível que o comparecimento seguido de não contestação não seja igualmente sancionado. Haveria não só infringência ao princípio da isonomia, mas também estímulo ao silêncio. Como diz Rampazzi, o silêncio da parte devedora, em um sistema processual caracterizado por um ônus bastante preciso de impugnação dos fatos, oferece elementos de não contestação capazes de justificar uma ‘condenação’ antecipada.<sup>111</sup>

Admitir que o réu pode comparecer em juízo, optar por não contestar e ainda não adimplir a sua obrigação, é desconsiderar o direito do autor e abrir espaço para que o tempo do processo seja utilizado pelo réu para retardar um direito que se mostra desde logo incontroverso.

Igualmente aqui, à semelhança do ocorre em caso de contestação genérica, deve o juiz conceder a tutela da evidência na sentença (art. 1.012, § 1º, V, CPC). A tutela da evidência, neste caso, também almeja evitar o abuso do direito de defesa (art. 311, I, CPC), pois não há racionalidade em atribuir ao autor o ônus do tempo de processamento do recurso interposto pelo réu que optou por não contestar.

---

## NOTAS DE RODAPÉ

---

1

“D'altra parte, almeno secondo l'insegnamento tradizionale, la mancata “convinzione” del giudice circa la verità del fatto impone di non decidere la controversia in base alla norma che avrebbe dovuto essere applicata ove del fatto fosse stata fornita “piena” prova, bensì in base alla regola che prevede il rigetto della domanda o dell'eccezione quale conseguenza del mancato soddisfacimento dell'onere” (Salvatore Patti, Prove-Disposizioni generali, Commentario del Codice Civile (a cura di A. Scialoja e G. Branca), p. 24-25).

2

Como o juiz deve se convencer de algo que está no plano do direito material, não há como exigir uma convicção uniforme para todas as situações de direito substancial. Em alguns casos, como os de lesões pré-natais, de seguro e relativos a atividades perigosas, a redução das exigências de prova ou de convicção de certeza é justificada pela própria estrutura e natureza dessas situações. Por isso, diante delas é admitida a convicção de verossimilhança. Tais situações têm particularidades próprias, suficientes para demonstrar

que a exigência de prova plena seria contrária ao próprio desejo do direito material. Nelas o próprio direito material não se concilia com a aplicação da regra do ônus da prova.

---

3

É evidente que o fato de o réu ter condições de provar a não existência do fato constitutivo não permite, por si só, a inversão do ônus da prova. Isso apenas pode acontecer quando as especificidades da situação de direito material, objeto do processo, demonstrarem que não é racional exigir a prova do fato constitutivo, mas sim exigir a prova de que o fato constitutivo não existe. Ou seja, a inversão do ônus da prova é imperativo de bom senso quando ao autor é impossível, ou muito difícil, provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável, ou muito mais fácil, provar a sua inexistência.

---

4

Sobre o princípio da efetividade, ver, na doutrina italiana, Luigi Paolo Comoglio, *La garanzia costituzionale dell'azione e il processo civile*; Luigi Paolo Comoglio, *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca), Bologna-Roma: Zanichelli-Foro Italiano, 1981, p. 1 e ss; Andrea Proto Pisani, *Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria*, *Foro Italiano*, 1983, p. 128 e ss; Andrea Proto Pisani, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1975, p. 633; Adolfo di Majo, *La tutela civile dei diritti*, p. 1 e ss; Michele Taruffo, *Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione*, p. 635-637; Ferruccio Tommaseo, *Appunti di diritto processuale civile*, Torino: Giappichelli, 1995, p. 169 e ss; Italo Andolina e Giuseppe Vignera, *Il modello costituzionale del processo civile italiano*, Torino: Giappichelli, 1990, p. 61 e ss.

---

5

Ver Andrea Proto Pisani, *Appunti sulla tutela sommaria* (note “de iure condito” e “de iure condendo”), *I processi speciali*, Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi, p. 311 e ss.

---

6

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 627.

---

7

Ver Luiz Guilherme Marinoni, *A antecipação da tutela*, 11a. ed., p. 33 e ss.

---

8

“Lo squilibrio esistente tra attore e convenuto nell’ambito delle ipotesi in cui la tecnica è utilizzata ha indotto i giudici di merito a sollevare questioni di legittimità costituzionale per queste ipotesi, ma la Corte costituzionale le ha sempre dichiarate infondate, per non violazione dei principi ex artt. 3 e 24, 2 comma, Cost., sulla base di un rilievo costante: il potere e non il dovere del giudice di emettere il provvedimento di condanna con riserva, una volta accertata la mancanza di ‘gravi motivi in contrario’. La razionalizzazione che può essere data a tale espressione è nel senso di ritenere che il giudice in tanto possa pronunciarsi in quanto le eccezioni sollevate dal convenuto e non provate documentalmente appaiano, a livello di delibazione, prima facie infondate. Pertanto, affinché sia soddisfatta l’esigenza di

evitare l'abuso del diritto di difesa da parte del convenuto, senza peraltro che alcun principio costituzionalmente garantito venga violato, è preferibile una ricostruzione della tecnica della condanna con riserva i cui presupposti siano: a) la prova piena o la non contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato; b) la delibazione sommaria del giudice sulla infondatezza delle eccezioni del convenuto” (Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 627-628).

---

9

Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, v. 1, p. 7.

---

10

Cf. Idem, Ibidem, p. 8.

---

11

De acordo com o art. 622 do CC brasileiro, “feita por quem não seja proprietário, a tradição não alheia a propriedade. Mas, se o adquirente estiver de boa-fé, e o alienante adquirir depois o domínio, considera-se revalidada a transferência e operado o efeito da tradição, desde o momento do seu ato”. A boa-fé, no direito brasileiro, é fato constitutivo para a transferência da propriedade.

---

12

Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, p. 9.

---

13

Cf. Salvatore Patti, Prove-Disposizioni generali, Commentario del Codice Civile (a cura di A. Scialoja e G. Branca), p. 91-92.

---

14

Ver Egas Moniz de Aragão, Exegese do Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: AIDE, 1986, v. 4, t. 1, p. 92.

---

15

Segundo Manuel de Andrade, são impeditivos os fatos suscetíveis de obstar a que o direito do autor se tenha validamente constituído (v.g., incapacidade, simulação, erro, dolo etc.), e ainda, ao menos parcialmente, os que, operando ab initio, apenas retardem o surgir desse direito ou a sua exercibilidade; são modificativos os que podem ter alterado o direito do autor tal como ele validamente se constituiu (v.g., a mudança de local de uma servidão); são extintivos os que tenham produzido a cessação do direito do autor, depois de este já validamente formado (v. g., condição resolutiva, termo peremptório, pagamento, prescrição etc.) (Manuel de Andrade, Noções elementares de processo civil, Coimbra: Imprensa Oficial, 1979, p. 131).

---

16

17

Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 322-323; Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 628

---

18

Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 323.

---

19

Idem, p. 562.

---

20

Ver Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 434.

---

21

Ver Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 432-433.

---

22

Saliente-se que o conceito de não contestação, ora proposto, nada tem a ver com o fenômeno da não contestação tal como tradicionalmente concebido (equivalente à revelia). Não é demais lembrar que ocorre contestação ainda que apresentada apenas defesa de mérito indireta.

---

23

“Si tratta, allora, di vedere che significato si possa attribuire all’espressione di eccezione verosimilmente (in)fondata. A questo problema è dedicata l’ultima parte di questo paragrafo, che intende sottoporre a breve esame il concetto stesso di verosimiglianza. Questo, sotto l’angolo visuale del quale ci stiamo occupando, non si distanzia affatto da quelli di prova prima-facie o fumus boni iuris o semplena probatio, ecc., facendo riferimento tutte queste espressioni, con sfumature di scarso rilievo, allo stesso identico fenomeno, consistente nel prendere atto che un insieme di fatti dedotti in giudizio non possono dirsi provati, ma egualmente la loro fondatezza può ritenersi probabile” (Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 503).

---

24

Discorrendo sobre a experiência alemã a respeito do chamado “juízo de verossimilhança”, Salvatore Patti assim adverte: “as resistências em relação a um ‘balanceamento objetivo’ das provas com base em critérios de verossimilhança, no processo civil, derivam da influência exercida pelo conceito filosófico de verdade, como também das diversas exigências do processo penal, que impõem a eliminação de qualquer dúvida para se chegar ao juízo de culpabilidade. As dúvidas que sempre subsistem em face dos limites do

conhecimento humano não devem deixar marcas na sentença penal; devem ficar na camera di consiglio. No processo penal, em definitivo, os resultados de tipo objetivo devem ser ‘integrados’ por uma fase subjetiva, por uma ‘tomada de consciência interior’ que deve conduzir à certeza. Tudo isto, ao contrário, não é necessário no processo civil, no qual, vice-versa, almeja-se a eliminação destas ‘vozes internas’ que, além do mais, podem levar a resultados diversos em hipóteses análogas” (Salvatore Patti, Prove – Disposizioni generali, Commentario del Codice Civile (a cura di A. Scialoja e G. Branca), p. 168).

---

25

“Aller Beweis ist richtig verstanden nur Wahrscheinlichkeitsbeweis” (todas as provas, a bem sentir, não são mais do que provas de verossimilhança) (ver Piero Calamandrei, Verità e verosimiglianza nel processo civile, Rivista di Diritto Processuale, 1955, p. 164).

---

26

Piero Calamandrei, Verità e verosimiglianza nel processo civile, p. 164-166. Ver ainda Gerhard Walter, Livre apreciación de la prueba, Bogotá: Temis, 1985, p. 169-170.

---

27

A impossibilidade de o juiz descobrir a essência da verdade dos fatos não lhe dá o direito de julgar o mérito sem a convicção da verdade. Estar convicto da verdade não é o mesmo que encontrar a verdade, até porque, quando se requer a convicção de verdade, não se nega a possibilidade de que “as coisas não tenham acontecido assim”. Lembre-se que Calamandrei, após afirmar que “a natureza humana não é capaz de alcançar verdades absolutas”, salientou que “é um dever de honestidade acentuar o esforço para se chegar o mais perto possível dessa meta inalcançável”. Ou seja, a verdade, quando compreendida na linha da teoria do conhecimento, não pode se colocar no mesmo plano da convicção de verdade. Ao lado dessa última categoria deve ser colocada a convicção de verossimilhança, pois não há como aceitar a antítese “convicção-verossimilhança”, como se fosse possível pensar que a convicção somente pode ser qualificada pela verdade. Ora, pode haver convicção de verdade e convicção de verossimilhança, ainda que ambas, na perspectiva gnoseológica, somente possam resultar em verossimilhanças. A convicção da verdade é relacionada com a limitação da própria possibilidade de buscar a verdade e, especialmente, com a correlação entre essa limitação e a necessidade de definição dos litígios. O juiz chega à convicção da verdade a partir da consciência da impossibilidade da descoberta da sua essência, uma vez que é essa que demonstra a falibilidade do processo para tanto. Dessa tomada de consciência, para a conclusão de que o processo, apesar de tudo isso, não pode impedir a eliminação dos conflitos, é um passo. Em resumo: o juiz, para pôr fim ao conflito, deve estar convicto, dentro das suas limitações, a respeito da verdade, uma vez que a sua essência é impenetrável.

---

28

Como diz Scarselli, “fatto provato e fatto verosimile sono due concetti distinti e tali devono restare: su questa distinzione si basa la differenza tra il fumes boni iuris e la prova piena e non crediamo che qualche giudice o qualche giurista abbia mai inteso dubitare della sostanziale diversità dei due concetti” (La condanna con riserva, p. 507).

---



29

No caso de defesa direta infundada, pode não existir cognição exauriente nem mesmo sobre os fatos constitutivos, na medida em que, em alguns casos, tais fatos podem estar demonstrados por meio de prova emprestada.

---

30

O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. (art. 341, parágrafo único, CPC).

---

31

A não contestação “nasce da un sistema di argomentazioni del difensore o della parte, comparsa de persona, che sia conciliabile con la verità dei fatti allegati dall'altra parte o dal difensore di questa, né importa che la conciliabilità sia implicita o esplicita” (Virgilio Andrioli, Prova, Novissimo Digesto Italiano. vol. 143, p. 274).

---

32

Cf. Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 432.

---

33

Cf. Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 432-433.

---

34

“L'eccezione di merito, infatti, avendo ad oggetto un fatto estintivo, impeditivo o modificativo, presuppone normalmente l'esistenza del fatto costitutivo, che è il suo naturale presupposto logico imprescindibile, proprio perché, in tanto un fatto può modificarsi o estinguersi, in quanto sia torto, e in tanto ha un senso postulare uno o più fatti impeditivi in quanto si faccia riferimento all'esistenza di un fatto costitutivo al quale il fatto impeditivo si ricollega. Ed è in questi termini che sollecitiamo, di nuovo, a tener presente che, di regola, la proposizione di un'eccezione di merito presuppone la non contestazione dei fatti costitutivi” (Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 437).

---

35

Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, 439.

---

36

“§ 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht

(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.

(2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.

(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.

(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind”.

---

37

Cf. Scarselli, La condanna con riserva, p. 419.

---

38

Cf. Scarselli, La condanna con riserva, p. 420.

---

39

É interessante recordar a didática lição de Wellington Moreira Pimentel: “A imposição da especificação dos fatos impugnados é uma consequência do princípio da igualdade processual das partes. Assim como o autor deve fazer constar da inicial o fato, ou fatos, bem como os fundamentos jurídicos do pedido, compete ao réu impugná-los com a mesma especificidade, ou se terá aqueles por verdadeiros. Se é certo que o réu não tem o dever de se defender, vale dizer, de contestar, se o faz deve colaborar para que se atinja o objetivo do processo. E esse dever de colaboração o obriga, inclusive, a expor os fatos em juízo conforme a verdade [art. 77, I, CPC/2015], e o impede de, licitamente, alegar defesa ciente de que é destituída de fundamento [art. 77, III, CPC/2015]” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, v. 3, p. 268-269).

---

40

“Il documento, a differenza dalla testimonianza, non è un atto, ma una cosa. L’attività dell’uomo è la fonte comune delle due forme di rappresentazione, ma è con la rappresentazione in rapporto diverso: nella testimonianza l’atto è lo stesso fatto rappresentativo, onde la rappresentazione ne è l’effetto immediato; nel documento l’atto non è punto il fatto rappresentativo, ma un momento precedente a questo, poiché non rappresenta per sé, ma crea un oggetto capace di rappresentare. Chi vuol avere una brusca impressione di questa differenza paragoni l’atto del narratore all’atto del preparatore fonografico: il primo agisce rappresentando, il secondo agisce preparando una cosa, che rappresenterà. Il punto di contatto fra i due tipi di fatti rappresentativi è pertanto la formazione mediante la attività dell’uomo; il punto di distacco è il presupposto di questa attività, che nel documento opera su un fatto presente e si proietta nel futuro, nella testimonianza opera su un fatto non presente e si proietta nel passato” (Francesco Carnelutti, La prova civile, Roma: Edizioni dell’ateneo, 1947, p. 181). Ver, também, Francesco Carnelutti, Istituzioni del processo civile, Roma: Soc. ed. del “Foro Italiano”, v. 1, p. 155; Teoria generale del diritto, Roma, 1951, v. 1, p. 383 e ss; Diritto e processo, Napoli: Morano, 1959, p. 128 e ss.

---

41

“Il documento non è soltanto una cosa, ma una cosa rappresentativa, cioè capace di rappresentare un fatto” (Francesco Carnelutti, La prova civile, p. 183).

---

No direito italiano, existindo prova do fato constitutivo, é possível a execução imediata do mandado de pagamento (decreto injuntivo) no procedimento monitorio. O legislador italiano, a partir da experiência do procedimento monitorio e visando a aceleração da prestação jurisdicional, introduziu no CPC regra que dá ao autor a possibilidade de propor “ação de condenação” dizendo-se credor de soma em dinheiro, de determinada quantidade de coisas fungíveis ou de coisa móvel determinada, desde que demonstre o seu direito através de “prova escrita”. Ou seja, o art. 186-ter do CPC italiano transplantou a técnica do procedimento monitorio para o procedimento comum. No que diz respeito à prova do direito, admite-se apenas a chamada “prova escrita” – art. 633, primeira parte, n. 1 –, considerando-se com esta qualidade também as previstas no art. 634, que assim dispõe: “634. Prova scritta [1] Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile. [2] Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e segg. del Codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”. São excluídas as hipóteses previstas no art. 633, 2 e 3, e nos arts. 635 e 636. Assim, por exemplo, os créditos do Estado e dos entes públicos, e os relativos a honorários profissionais, não podem ser tutelados mediante a prova descrita nas referidas normas. Como explica Claudio Cecchella, “não se trata de um provimento monitorio denominado ‘puro’ (no qual a prova dos fatos constitutivos não tem importância), como no caso das ‘ordinanze’ ao pagamento de soma não contestada, pois a parte que pretende obter a ‘ingiunzione’ ou a ‘ordine’ de entrega deve fornecer prova ‘por escrito’ dos fatos constitutivos do seu direito” (Claudio Cecchella, *Il processo civile dopo le riforme*, p. 125). No direito italiano, a “ordinanza di ingiunzione” e o “decreto ingiuntivo” não são imediatamente executivos. A eles se pode dar execução provisória apenas quando presentes os pressupostos dos arts. 642 e 648, primeira parte, do CPC, isto é, quando: i) “il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, ou su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato” (art. 642, primeira parte, do CPC italiano); ii) há perigo de grave prejuízo no atraso do início do procedimento executivo (art. 642, segunda parte, do CPC italiano); iii) há documento subscrito pelo devedor comprovando o direito (art. 642, segunda parte in fine, do CPC italiano); e iv) não havendo contumácia, a oposição não é fundada sobre prova escrita ou de pronta solução (art. 648, primeira parte, do CPC italiano). Diz o art. 186-ter, segunda parte, que a “ordinanza” pode ser declarada provisoriamente executiva se presentes os pressupostos do art. 642, “nonché”, se o réu não é contumaz, quando as suas defesas não são fundadas em prova escrita ou de pronta solução. O uso do advérbio “nonché” levou parte da doutrina a sustentar que a “ordinanza” – no caso de réu constituído – somente poderia ser concedida na presença dos pressupostos cumulados dos artigos 642 e 648. Outros, como Proto Pisani, concluíram que para esta tutela bastariam apenas os pressupostos do art. 648 (Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 640). Finalmente, outra parte da doutrina chegou ao entendimento no sentido de que a tutela poderia ser concedida tanto frente aos pressupostos do art. 642 como diante daqueles do art. 648 (Gabriela Rampazzi, *Le riforme del processo civile* (a cura di Sergio Chiarloni), p. 255; Aldo Attardi, *Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma*, *Giurisprudenza italiana*, 1992, p. 6). Afirma o art. 186-ter, após fazer referência às hipóteses em que o juiz pode dar imediata eficácia à “ordinanza”, que esta não pode ser

concedida quando o réu alegar desconhecimento da escritura privada ou propuser “querela di falso” contra o ato público. O objetivo da regra é evitar o início da execução quando houver a fundada probabilidade de que o documento contestado, sobre o qual se funda a execução da “ordinanza”, possa perder a sua eficácia. Ver Giuseppe Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, p. 137 e ss; Edoardo Ricci, *A tutela anticipatória na Itália*, *Revista de Direito Processual Civil (Genesis)*, v. 4; Edoardo Ricci, *Per una efficace tutela provvisoria ingiunzionale dei diritti di obbligazione nell’ordinario processo civile*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1990, p. 1025 e ss; Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 639 e ss; Romano Vaccarella, Bruno Capponi e Claudio Cecchella, *Il processo civile dopo le riforme*, p. 125 e ss; Gabriella Rampazzi, *Le riforme del processo civile (a cura di Sergio Chiarloni)*; Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, p. 597 e ss; Crisanto Mandrioli, *Le modifiche del processo civile*, Torino: Giappichelli, 1991, p. 78 e ss; Sergio Chiarloni, *Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile (con particolare riguardo ai provvedimenti cautelari ed interinali)*, *Foro Italiano*, 1991, p. 501 e ss; Claudio Consolo, *Un codice di procedura civile “seminuovo”*, *Giurisprudenza italiana*, 1990, p. 443 e ss.; Aldo Attardi, *Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma*, p. 2 e ss.

---

44

Ver José Rogério Cruz e Tucci, *Ação monitória*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 41.

---

45

Edoardo Garbagnati, *Il procedimento d’ingiunzione*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 51-52.

---

46

Cf. Edoardo Garbagnati, *Il procedimento d’ingiunzione*, p. 44.

---

47

Edoardo Garbagnati, *Il procedimento d’ingiunzione*, p. 203.

---

48

Edoardo Garbagnati, *Il procedimento d’ingiunzione*, p. 58-59.

---

49

De acordo com o art. 418 do Código de Processo Civil, “os livros empresariais que preenchem os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários”.

---

50

“Invero, poiché l’opposizione dà vita nel quadro di un unico processo ad un procedimento in contraddittorio con cognizione ordinaria, in cui tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull’ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova, che sarebbero state applicabili se l’azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento d’ingiunzione, fosse stata esercitata subito in

forma di citazione, può accadere che un documento, costituente prova scritta in base agli art. 633 e seg. e posto, come tale, a fondamento di un decreto d'ingiunzione, perda in seguito all'opposizione la sua speciale efficacia probatoria: con la conseguenza che, se il ricorrente non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del suo preteso credito, contestato dall'opponente, la sua domanda può essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697 c. civ., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito alla opposizione, dalle norme vigenti in un processo ordinario di cognizione" (Edoardo Garbagnati, *Il procedimento d'ingiunzione*, p. 200-201).

---

51

Sobre as chamadas tutelas jurisdicionais diferenciadas, Luiz Guilherme Marinoni, *Efetividade do processo e tutela de urgência*, Porto Alegre: Fabris, 1994, p. 1-10; Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela cautelar e tutela antecipatória*, p. 17 e ss.; Federico Carpi, *Flashes sulla tutela giurisdizionale differenziata*; Nicola Picardi, *I processi speciali*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1982; Andrea Proto Pisani, *Sulla tutela giurisdizionale differenziata*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1979; Augusto Mario Morello, *Las nuevas exigencias de tutela*, *RePro*, v. 31; Adolfo Gelsi Bidart, *Tutela procesal diferenciada*, *RePro*, v. 44.

---

52

O art. 642, II, do CPC italiano, diz que "l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo..."

---

53

Cf. Luigi Montesano, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, p. 257.

---

54

Na jurisprudência italiana, ver Pretura di Roma, 15.12.82, in *Temi Romana*, 1982, p. 637; Pretura di Roma, 31.07.86, in *Giustizia Civile*, 1986, I, p. 2.583.

---

55

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 505.

---

56

Eis o que diz o art. 648, I, do CPC italiano: "648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione – [1] Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta ou di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642 ...".

---

57

Edoardo Garbagnati, *Il procedimento d'ingiunzione*, p. 178-179.

---

Sobre a inefetividade da sentença condenatória para a tutela de determinadas situações de direito substancial, ver Michele Taruffo, Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione; Elisabetta Silvestri e Michele Taruffo, Esecuzione forzata, Enciclopedia Giuridica Trecanni, v. 13; Andrea Proto Pisani, Appunti sulla tutela di condanna, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1978; Cristina Rapisarda, Profili della tutela civile inibitoria; Massimo D'Antona, La reintegrazione nel posto di lavoro; Michele Taruffo, Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla reintegrazione del lavoratore, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1976; Adolfo di Majo, Reintegrazione nel posto di lavoro e controllo del potere nell'impresa (a proposito di una pubblicazione), Rivista Giuridica del Lavoro, 1979. No direito brasileiro, ver Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito; Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, v. 1.

---

Sobre a tutela das obrigações de fazer e não fazer, ver Salvatore Mazzamuto, L'attuazione degli obblighi di fare; Lanfranco Ferroni, Obblighi di fare ed eseguibilità, Pubblicazioni della Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile dell'Università di Camerino, 1983; Giuseppe Borrè, Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, Napoli: Jovene, 1966; Giuseppe Borrè, Verso la riforma del codice di procedura civile? Riflessi sulla disciplina dell'esecuzione forzata nel disegno di legge delega n. 1.463, Foro italiano, 1983; Giuseppe Tarzia, Presente e futuro delle misure coercitive civile, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1981; Vittorio Colesanti, Misure coercitive e tutela dei diritti, Rivista di Diritto Processuale, 1980; Girolamo Monteleone, Recenti sviluppi nella dottrina dell'esecuzione forzata, Rivista di Diritto Processuale, 1982; Luigi Montesano, Considerazioni su storia moderna e proposte di riforme della giustizia civile in Italia, Rivista di Diritto Processuale, 1981.

---

Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, p. 295.

---

“Dessarte só será admitido o traslado da prova de um processo para outro quando em ambos sejam as mesmas as partes litigantes e haja sido fielmente respeitada a igualdade de suas oportunidades no processo de onde provém. Isso não significa que somente em tais casos possa ser transportada prova de um processo para outro. Não. O que acontece é o seguinte: quando a prova emprestada foi colhida escorreitamente e as partes são as mesmas, conserva a eficácia que lhe é peculiar; fora disso não. Neste caso (como em vários outros) considera-se atípica a prova produzida, por não o ter sido em estrita conformidade com as regras que regem o procedimento probatório” (Egas Moniz de Aragão, Exegese do Código de Processo Civil, v. 4, t. 1, p. 62).

---

Cf. Egas Moniz de Aragão, Exegese do Código de Processo Civil, v. 4, t. 1, p. 98.

---

Egas Moniz de Aragão, Exegese do Código de Processo Civil, v. 4, t. 1, cit., p. 97-98.

---

64

Sobre o ônus da prova, ver Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Prova e Convicção. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2018; Salvatore Patti, Prove, Disposizioni generali; Gian Antonio Micheli, Onere della prova, Padova: Cedam, 1966, p. 177 e ss; Luigi Paolo Comoglio, Le Prove, Trattato di diritto privato (diretto da Rescigno), v. 19, p. 193 e ss; Giovanni Verde, Prova, Enciclopedia del diritto, v. 37, p. 628 e ss.

---

65

Cf. Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 560.

---

66

Art. 2.697 (Código Civil italiano): “Onere della prova. – Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

---

67

Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 560-561.

---

68

Cf. Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 551.

---

69

A técnica dos títulos executivos extrajudiciais também é uma técnica de sumarização, à medida que elimina a possibilidade de o juiz averiguar a existência do direito que o próprio título faz presumir presente (Luiz Guilherme Marinoni, A antecipação da tutela, 12ª ed., p. 45).

---

70

Veja-se a doutrina de Andolina: “Nelle pagine seguenti, attraverso una adeguata elaborazione del modello concettuale del “conflitto esecutivo”, tenterò per l’appunto di mostrare come il titolo esecutivo tragga la sua ragion d’essere dalla distensione diacronica del processo, o se si vuole, dalla necessità di pagare, in termini di tempo, il prezzo d’un soddisfacente accertamento della verità. Parafrasando il Calamandrei, ritengo possibile affermare che “in un ordinamento processuale puramente ideale, in cui l’accertamento definitivo potesse sempre essere istantaneo, in modo che, nello stesso momento in cui l’avente diritto presentasse la domanda, subito potesse essergli resa giustizia in modo pieno ed adeguato”, non vi sarebbe più bisogno del titolo esecutivo (sia giudiziale che stragiudiziale): o meglio, la qualità di titolo esecutivo verrebbe attribuita soltanto al giudicato, sicché l’esecuzione forzata sarebbe sempre fondata sull’accertamento definitivo del diritto soggettivo insoddisfatto” (Italo Andolina, “Cognizione” ed “esecuzione forzata” nel sistema della tutela giurisdizionale, Milano: Giuffrè, 1983, p. 14-15).

---



71

Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 561-562.

---

72

Giuliano Scarselli, La condanna con riserva, p. 562.

---

73

Ver, sobre a discussão a respeito do papel desenvolvido pelo título executivo, Francesco Carnelutti, Titolo esecutivo, Rivista di Diritto Processuale Civile, 1931, p. 313; Enrico Tullio Liebman, Le opposizioni di merito nel processo d'esecuzione, Foro Italiano, Roma, 1936; Enrico Tullio Liebman, La sentenza come titolo esecutivo, Rivista di Diritto Processuale Civile, 1929, p. 117; Enrico Tullio Liebman, Il titolo esecutivo riguardo ai terzi, Rivista di Diritto Processuale Civile, 1934, p. 127. Mais recentemente, ver Ferdinando Mazzarella, Contributo allo studio del titolo esecutivo, Milano: Giuffrè, 1965; Ferdinando Mazzarella, Ancora sul titolo esecutivo, Rivista di Diritto Processuale, 1967, p. 314; Ferdinando Mazzarella, Scienza e teologia del titolo esecutivo, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1971, p. 177; Italo Andolina, Contributo alla dottrina del titolo esecutivo, Milano: Giuffrè, 1982; Romano Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, 2.a ed., Torino: Giappichelli, 1993.

---

74

Ver Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, v. 1, p. 105.

---

75

“Di fatto storicamente il ricorso a questa tecnica è stato (nè, a mio avviso, poteva essere diversamente) influenzato anche dalla opportunità di privilegiare i soggetti reali portatori del titolo ed i relativi diritti (è sintomatico, a tale riguardo, che la stragrande maggioranza dei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale è a disposizione di imprenditori commerciali e di Pubbliche Amministrazioni)” (Andrea Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria, I processi speciali, Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi, p. 318).

---

76

Andrea Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria, I processi speciali, Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi, p. 315 e ss.

---

77

Giuseppe Chiovenda, Sulla perpetuatio iurisdictionis. Saggi di diritto processuale civile, Roma, 1930, p. 264 e ss.

---

78

“In primo luogo la condanna con riserva è diversa dal principio secondo il quale la durata del processo non dovere andare a danno dell’attore che ha ragione. La prima, infatti, facendo seguire l’esecuzione forzata alla prova dei fatti costitutivi, addossa immediatamente al convenuto i tempi del processo che

servono per la verifica della fondatezza delle sue eccezioni; il secondo, invece (ove si eccettuino le ipotesi di provvedimenti cautelari anticipatori), continua a far sopportare all'attore il peso dell'intera durata del processo, però evita che, a seguito della sentenza definitiva che accoglie la sua domanda, questi possa subirne nocimenti" (Giuliano Scarselli, *La condanna con riserva*, p. 577-578).

---

79

"Ma, per il momento, è opportuno mettere da parte queste considerazioni e concentrare l'attenzione sul danno che l'attore subisce nelle more del procedimento: esso può convenientemente definirsi come "marginale", in quanto va progressivamente ad aggiungersi a quello eventualmente già sofferto anteriormente alla proposizione della domanda. Ora va rilevato che, in pendenza del processo, l'unico dato di sicura rilevazione è l'entità quantitativa del danno marginale (e del correlativo vantaggio accumulato dal convenuto), mentre non si è ancora assolutamente in grado di stabilire se esso sia *secundum ius* o *contra ius*; una qualificazione giuridica nell'uno o nell'altro senso potrà essere operata soltanto successivamente, cioè quando, compiutosi il cammino del processo, si potrà disporre dell'accertamento definitivo (dell'esistenza o dell'inesistenza) del diritto dell'attore" (Italo Andolina, *Cognizione ed esecuzione forzata nel sistema della tutela giurisdizionale*, p. 17).

---

80

"Non esiste un unico processo che offra una unica forma di tutela per tutte le situazioni di vantaggio, ma esistono invece una pluralità di processi ed una pluralità di forme di tutela giurisdizionale; la diversità di questi processi e di queste forme di tutela, e delle loro variegate combinazioni, riflettono la diversità dei bisogni di tutela delle situazioni di vantaggio" (Andrea Proto Pisani, *Breve premessa a un corso sulla giustizia civile*, *Appunti sulla giustizia civile*, p. 11-12).

---

81

Michelle Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, p. 330.

---

82

A expressão "litigiosidade contida", fruto da inteligência de Kazuo Watanabe, espelha fenômeno extremamente perigoso para a estabilidade social, pois é um ingrediente a mais na "panela de pressão" social, que já está mostrando sinais de deteriorização do seu sistema de resistência ("quebra-quebra" ao atraso dos trens, cenas de violência no trânsito e recrudescimento de outros tipos de violência) (Kazuo Watanabe, *Filosofia e características básicas do juizado especial de pequenas causas*, *Juizado Especial de Pequenas Causas*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 2).

---

83

Sobre a questão do acesso à justiça, ver Luiz Guilherme Marinoni, *Novas linhas do processo civil*, 4. ed., São Paulo, Malheiros, 2000; Mauro Cappelletti, *Acesso à justiça*, Porto Alegre: Fabris, 1988; Mauro Cappelletti, *Acesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*, *Rivista di Diritto Processuale*, 1982, p. 233-245; Donaldo Armelin, *Acesso à justiça*, *Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo*, v. 31, p. 171-182; Kazuo Watanabe, *Assistência judiciária como instrumento de acesso à ordem jurídica justa*, *Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo*, v. 22, p. 87-89; Roberto Omar

84

Ver, ainda, Sergio Chiarloni, Introduzione allo studio del diritto processuale civile, Torino: Giappichelli, 1975, p. 65; Kazuo Watanabe, Acesso à justiça e sociedade moderna, Participação e processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Procedimento e ideologia no direito brasileiro atual, Ajuris, v. 43; Boaventura de Souza Santos, Introdução à sociologia da administração da justiça, RePro, v. 37.

---

85

Assim Scarselli, La condanna con riserva, p. 584.

---

86

Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 627. Ver do mesmo autor: Verso la riforma del Codice di Procedura Civile? Prospettive in tema di processi a cognizione piena e sommaria in un recente disegno di legge delega, Appunti sulla giustizia civile, p. 436 e ss; La tutela di condanna, Appunti sulla giustizia civile, p. 190 e ss; Appunti sulla tutela sommaria, I processi speciali, p. 320 e ss; Sulla tutela giurisdizionale differenziata, p. 207 e ss.

---

87

Admite-se no direito francês o référé-provision, quando “l’obligation n’est pas sérieusement contestable” (a obrigação não for seriamente contestável). Trata-se de espécie de référé baseado em “direito evidente”, conforme artigos 809, II e 849, II, do Código de Processo Civil francês. A segunda parte dos artigos 809 e 849 – o primeiro relativo ao presidente do tribunal e o segundo ao juiz do tribunal de instância – assim dispõe: “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Ver Roger Perrot, Les mesures provisoires en droit français, in Les mesures provisoires en procédure civile, p. 164; Loïc Cadet, Code de Procédure Civile, Paris: LexisNexis, 2016; Loïc Cadet, Jacques Normand e Soraya Mekki Amrani, Théorie générale du procès; Loïc Cadet e Emmanuel Jeuland, Droit Judiciaire Privé, Paris: LexisNexis, 2016.

---

88

Luiz Guilherme Marinoni, Il diritto di azione come diritto fondamentale; Luiz Guilherme Marinoni, El derecho de acción como derecho fundamental; Luiz Guilherme Marinoni, Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella prospettiva della teoria dei diritti fondamentali, p. 93-162.

---

89

Ver Federico Carpi, Flashes sulla tutela giurisdizionale differenziata, p. 239.

---

90

“Si è detto che il principio del contraddittorio è rispettato anche quando il provvedimento è pronunciato inaudita altera parte, purchè, prima che il provvedimento diventi definitivo, la parte contro cui è emesso abbia la possibilità di proporre le sue difese” (Giuseppe Martinello, “Contraddittorio (Principio del)”, *Novissimo digesto italiano*, v. 4, p. 461).

---

91

Sobre a tutela da evidência no Código de 2015, ver Leonardo Greco, A tutela de urgência e a tutela da evidência no Código de Processo Civil de 2015, p. 199 ss; Andrea Carla Barbosa, Direito em expectativa: as tutelas de urgência e evidência no projeto de novo código de processo civil. Breves comentários, *Revista de Processo*, v. 194; Roberto Antonio Vallim Bellocchi, A tutela da evidência: irreversibilidade, *Revista de Processo*, v. 252; Antonio de Moura Cavalcanti Neto, Possibilidade de concessão de tutela da evidência contra a Fazenda Pública no projeto de novo Código de Processo Civil: sobre acreditar ou não no acesso à justiça, *Revista de Processo*, v. 238; Lucas Buril de Macedo, Antecipação da tutela por evidência e os precedentes obrigatórios, *Revista de Processo*, v. 242; Antônio Pereira Gaio Júnior, Apontamentos para a tutela provisória (urgência e evidência) no novo Código de Processo Civil brasileiro, *Revista de Processo*, v. 254; Leonardo de Souza Naves Barcellos, As hipóteses de tutela de evidência previstas no novo CPC, *Revista de Processo*, v. 254.

---

92

O art. 186-ter do Código de Processo Civil italiano, depois de aludir às hipóteses em que o juiz pode dar imediata eficácia à “ordinanza”, afirma que esta não pode ser concedida quando o réu alegar desconhecimento da escritura privada ou propuser “querela di falso” contra o ato público. O objetivo da regra é evitar o início da execução quando houver a fundada probabilidade de que o documento contestado, sobre o qual se funda a execução da “ordinanza”, possa perder a sua eficácia. Ver Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 639 e ss; Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, p. 597 e ss; Claudio Consolo, *Un codice di procedura civile “seminuovo”*, p. 443 e ss.

---

93

Sobre o référé francês, ver Jacques Vuitton e Xavier Vuitton, *Les référés*, Paris: LexisNexis, 2006; Roger Perrot, L'évolution du référé, in *Mélanges Hébraud*, Toulouse: Université Toulouse 1, 1981; Serge Guinchard, Frédérique Ferrand e Cécile Chainais, *Procédure civile*, Paris: Dalloz, 2008.

---

94

“Grâce au ‘référé-provision’, ces méthodes détestables n’ont pas totalement disparu, mais du moins ont elles été sérieusement découragées. À cet égard, le ‘référé provision’ a constitué un immense progrès et il n’est pas excessif d’y voir l’une des meilleures réformes judiciaires des dernières années” (Roger Perrot, *Les mesures provisoires en droit français*, p. 168-169).

---

95

Lembre-se, contudo, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando

ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, CPC).

---

96

Há muito demonstrou-se a distinção entre execução provisória (*rectius*: fundada em decisão provisória) e execução completa (Luiz Guilherme Marinoni, A antecipação da Tutela), embora a doutrina em geral e o novo código não a tenham percebido. Mas não faz mal: ela é inescandível.

---

97

Ver Colia, *L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro*, p. 540 e ss.

---

98

Vittorio Denti, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 138.

---

99

Giuseppe Tarzia, *Manuale del processo del lavoro*, p. 183.

---

100

Filippo Colia, *L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro*, p. 541.

---

101

Ver Andrea Proto Pisani, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma, 1987, p. 421.

---

102

Wellington Moreira Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 267-268.

---

103

Giuliano Scarselli, *La condanna con riserva*, p. 439.

---

104

Ver Rita Ganesini, *Da revelia no processo civil brasileiro*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 78.

---

105

Art. 282 do CPC italiano.

---

106

Sobre o ponto, assim escrevem Comoglio, Ferri e Taruffo: “La sua funzione pratica è, quindi, per evidenti motivazioni di economia processuale, diretta ad assicurare l’effettività della tutela di condanna con la creazione anticipata di un titolo esecutivo, neutralizzando i ‘tempi morti’ (misurabile anche in ragione di anni) che – secondo una prassi consolidata, ormai imposta dal sovraccarico degli uffici giudiziari – perlopiù intercorrono tra la chiusura dell’istruzione e la decisione della causa” (Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri e Michele Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, p. 607).

---

107

Gabriella Rampazzi, *Le riforme del processo civile* (a cura di Sergio Chiarloni), p. 237-238.

---

108

Mediante o art. 186-quater, cuja primeira parte assim estabelece: “186-quater. Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione [1] Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali”.

---

109

Ver José Carlos Barbosa Moreira, “Sobre a multiplicidade de perspectivas no estudo do processo”, p. 19-20.

---

110

Giuliano Scarselli, *La condanna con riserva*, p. 439.

---

111

Gabriella Rampazzi, *Le riforme del processo civile* (a cura di Sergio Chiarloni), p. 237.

---

## **Livro VI. Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo**

### *1. Apresentação do tema*

O Livro VI, da Parte Geral do código, trata da formação, da suspensão e da extinção do processo.

A rigor, o tema da extinção do processo vem tratado, com maiores detalhes, na parte especial, quando o código discute a sentença (arts. 485, 487, 924 e 925, do CPC). Na parte geral, o tema da extinção do processo ficou reservada, apenas – ao contrário do que fez o Código de 1973 – para afirmar o óbvio: que o processo se extingue com provimento jurisdicional e que a extinção do processo por causa processual deve ser antecedida da tentativa de correção do eventual defeito. Sem dúvida a alusão à necessidade de tentar sanar o defeito (antes de extinguir o processo) é importante, sobretudo para efeitos didáticos. O comando, porém, está presente em diversos outros dispositivos, de sorte que a menção feita no art. 317 é, no mínimo, redundante.

A rigor, no que se refere ao tema em estudo, a mais importante diferença entre o código atual e o anterior é precisamente a alteração geográfica mencionada. Deslocou-se o tratamento das causas que levam à extinção do processo para outro lugar, agrupando-o com a disciplina das sentenças.

Partindo da premissa da separação entre a “parte geral” e a “parte especial” do código, parece claro que melhor seria tratar da extinção do processo – em sua inteireza – na parte geral. Afinal, não é apenas o procedimento comum ou o processo de execução que se encerram por sentença. O tema é afeito à análise geral da relação processual, de modo que aqui deveria estar todo o trato do tema. O legislador de 2015, porém, optou por solução diversa, tratando das causas da extinção juntamente com a disciplina formal do ato sentencial, na parte especial.



## **Título I. Da Formação do Processo**

### **1. Formação da relação processual e suas consequências**

Ao tratar da “formação do processo”, pretende o código regular o momento a partir de quando se considera formada a relação processual. As consequências dessa definição são grandes e vão muito além de simples questões acadêmicas.

Do ponto de vista acadêmico, é evidente que releva saber a partir de quando se tem como formada a relação processual. Afinal, se o processo é uma relação “tripartite”, como se costuma dizer, então seria mais natural concluir que o processo só existe efetivamente como tal a partir do momento em que a relação se “angulariza”, ou seja, quando o réu é citado.

No entanto, proliferam situações – sobretudo no CPC/2015 – em que, antes mesmo da citação do réu a lei autoriza a adoção de providências não apenas provisórias, mas com pretensão de estabilidade. Assim ocorre, por exemplo, com o indeferimento liminar da petição inicial (art. 330) ou com o julgamento liminar de improcedência (art. 332).

Muitas dessas hipóteses sequer são novas, já tendo sido contempladas no código de 1973. Mas não há dúvida da ampliação desses casos no código de 2015, que permite, por exemplo, a rejeição pronta da demanda – no seu mérito – quando a pretensão esbarra em decisão vinculante e não haja demonstração consistente da necessidade de distinção ou superação daquela orientação.

Ora, sem dúvida seria impensável que esse tipo de decisão, com estabilidade típica de coisa julgada, pudesse operar-se fora do processo e, portanto, antes de “formada” a relação processual.

Parece, por isso, relevante reexaminar a doutrina clássica e simplista, que conclui que sem a angularização seria possível pensar na inexistência de relação processual.

### **2. Angularização e querela nullitatis**

Será mesmo possível, então, qualificar como pressuposto de existência do processo a citação válida do réu?

É certo que essa orientação se firmou no código de 1973, tomando força a partir do entendimento de que processos julgados sem que o réu fosse citado poderiam ser qualificados como inexistentes.<sup>1</sup> Em jurisprudência, chegou-se mesmo a afirmar que processos em que a citação do réu (embora existente) fosse nula também implicariam a inexistência da relação processual.<sup>2</sup> Chegou-se também a afirmar que a falta de citação de litisconsorte necessário implicaria inexistência processual, de modo a desautorizar a coisa julgada em face deste.<sup>3</sup> Para esses casos, autorizava-se o ajuizamento de ação de querela nullitatis, sob o entendimento de que sequer seria rescindível uma decisão tomada nesse tipo de “processo”.

Todavia, parece que a resposta que tem sido aceita pela jurisprudência merece séria reflexão.

Isso porque, ao contrário do que comumente se sustenta, não parece correto concluir – sobretudo diante do sistema processual atual – pela inexistência da relação processual em razão da inexistência ou de vício na citação de réu (seja ele o único requerido ou um dos litisconsortes

necessários). Esse defeito, como acertadamente afirma o art. 115, I, do CPC, quando muito implica nulidade do feito em relação a esse réu – ou, eventualmente, também aos outros, no caso de litisconsórcio necessário. Não há, porém, aí nenhuma situação de inexistência.

A relação processual existe, sem dúvida. Pode, porém, a decisão ser inoponível em relação àqueles que não participaram da relação processual e, portanto, que não puderam exercer o contraditório. Em virtude disso, podem estar infensos à coisa julgada formada neste processo. Porém, certamente não se está aí diante de caso de inexistência.

Tanto é assim que esses terceiros – que não participaram do processo – podem eventualmente insurgir-se contra a decisão ali proferida por meio de embargos de terceiro (art. 674 e ss., do CPC) ou outra ação própria, o que demonstra que aquela decisão efetivamente existe. Se, realmente, essa decisão apenas não existisse, seria absurdo supor a necessidade de ajuizar ação objetivando declarar essa circunstância. Se ela é necessária, é porque algum resultado ou efeito está sendo produzido pela decisão e, portanto, a atuação jurisdicional é exigida.

À luz dessas circunstâncias, parece correto concluir que a inoponibilidade de decisão a terceiro que não participou da decisão judicial,<sup>4</sup> é problema tangente aos limites subjetivos da coisa julgada e não questão de pressuposto processual de existência. Como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, o problema da ausência de citação é questão que toca à “eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório”.<sup>5</sup> A matéria, portanto, passa longe da questão da inexistência processual, ligando-se antes à inviabilidade de sujeitar quem não participa da relação processual – exceção feita aos casos de coletivização de interesses – à indiscutibilidade da consequente decisão.

O meio para a impugnação dessa questão, portanto, não é uma ação que busque reconhecer a inexistência da relação processual. É, apenas, qualquer demanda em que o terceiro pretenda demonstrar que os efeitos da primeira decisão não podem afetar sua situação de forma inafastável.

**Art. 312.** Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

## **1. Observações gerais**

O art. 312, do CPC atual, equivale, em linhas gerais, ao art. 263, do CPC/73. A previsão atual é ainda semelhante ao que afirma o art. 259º, 1, do CPC português, que afirma proposta a demanda “logo que seja recebida na secretaria a respectiva petição inicial”.

Basicamente, a única diferença trazida no texto atual da lei brasileira diz respeito à supressão da expressão – contida na regra anterior – “despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída”. O código de 1973 consentia que o início do processo se desse com o despacho inicial ou a simples distribuição da demanda. A lei atual, ao contrário, refere-se apenas ao protocolo da petição inicial.

A rigor, a diferença não é tão significativa, nem implica modificação concreta do momento no qual se considera proposta a demanda e, assim, formado o processo. Embora antes a lei aludisse à distribuição, o simples registro da ação (por seu protocolo junto ao órgão adequado) já era suficiente para ensejar efeitos típicos do início do processo, a exemplo da presunção de ciência de terceiros a respeito da litispendência<sup>6</sup> e da interrupção da prescrição.<sup>7</sup> Em verdade, a alusão ao “despacho inicial”, contida no código revogado, buscava apenas retratar situações comuns – na época daquela legislação – em que a petição inicial, antes mesmo de ser autuada, era levada ao juiz para que nela fosse apostado um despacho inaugural, de cunho estritamente formal, que se limitava a determinar o registro e a autuação da peça. Porque essa situação não existe mais na atualidade, não havia razão para repetir aquela previsão.

Por isso, embora o texto tenha sido mais claro ao estipular o que se deveria considerar por “despacho inicial” ou “distribuição”, fato é que em termos concretos pouca coisa mudou. É o protocolo da petição inicial que deve ser tomado como marco inicial do processo.

Extirpou-se da referência legal, por outro lado, o “despacho” inicial. A figura, como dito, que era típica de momentos pretéritos, em que, em razão da presença de um só juiz em certas comarcas, dispensava-se a distribuição da ação, gerava ampla confusão. Porque a expressão poderia conduzir à equivocada impressão de que o “despacho” mencionado no texto implicava o “despacho” inicial de admissibilidade da inicial, era necessário sempre esclarecer que não era esse o “despacho” a que se referia o texto legal. Por isso, melhor o texto atual que elimina a discussão e fixa com clareza o momento em que se deve ter por proposta a demanda.

Bastará, por isso, o protocolo da petição inicial para que se tenha por proposta a demanda.

## **2. Formação gradual da relação processual. A formação em relação ao autor**

Se, porém, é certo que o processo tem início com o simples protocolo da petição inicial, não se pode esquecer que, por sua estrutura de relação complexa, a formação do processo se dá de forma gradual.<sup>8</sup> Assim, também, os efeitos operados pelo início do processo operam-se em momentos diferentes, a partir de cada etapa da formação dessa relação.

Os efeitos do processo para o autor se operam no momento em que é formada a relação entre ele e o Estado, por meio do ajuizamento da ação.<sup>9</sup> Assim, é o protocolo da petição inicial que marca a interrupção da prescrição, ainda que a lei exija a formalização dessa interrupção por meio de decisão judicial ulterior (art. 240, § 1º, do CPC). Por outras palavras, ainda que a lei condicione a interrupção da prescrição à existência de decisão que determina a citação, o momento em que a prescrição está interrompida é a propositura da ação, ou seja, o protocolo da petição inicial.

Correta é a determinação legal. É o protocolo da inicial que demonstra o rompimento da inércia do autor. Por isso, esse é o momento em que se deve ter por interrompido o prazo prescricional. A decisão judicial que determina a citação do réu, por seu turno, só deve servir para demonstrar que o processo é viável, e que, assim, efetivamente constitui exercício de pretensão manifestada em juízo.

De todo modo, entende a jurisprudência que processos em que não há a citação do réu são inaptos a ensejar a interrupção da prescrição.<sup>10</sup> Com isso, conclui-se que, sob essa orientação, embora baste o ajuizamento da ação para a interrupção da prescrição, essa somente ocorre se existente decisão judicial que determine a citação do réu. Assim, se não ocorrer a citação, porque a petição inicial é absolutamente inviável e sequer reúne condições de ser examinada, não operará o efeito de interrupção da prescrição.<sup>11</sup>

## **3. A formação gradual da relação processual. A formação em relação ao réu**

Se a relação processual se forma, para o autor – e em seu vínculo com o Estado –, a partir do protocolo da petição inicial, para o réu essa relação só será formada a partir de sua citação para o processo, nos termos do que esclarece a parte final do art. 312.

De fato, apenas a partir do momento em que o réu é citado é que se pode considerar que ele faz parte da relação jurídica formada no processo. Por isso, também só com a sua citação é que os efeitos típicos do processo podem operar-se sobre o réu. Segundo o art. 240, do CPC, esses efeitos consistiriam na formação da litispendência, na constituição em mora do devedor e na formação da litigiosidade sobre o objeto do processo.

A rigor, nem todos esses efeitos são propriamente efeitos processuais e, portanto, nem todos eles decorrem, necessariamente, da incidência da relação processual sobre o réu. Como se vê da parte final do art. 240, do CPC, a indução em mora do devedor pode originar-se de elementos muito anteriores ao ajuizamento da demanda ou à citação do réu. Com efeito, o inadimplemento da obrigação ou a prática do ato ilícito são, de regra, suficientes para ensejar a mora do devedor (arts. 397 e 398, do CC). Eventualmente, quando assim não ocorrer, bastará a interpelação extrajudicial para que as consequências da mora possam incidir (art. 397, parágrafo único, do CC).

Em regra, assim, a indução em mora do devedor é problema resolvido pelo direito material. Só

excepcionalmente, quando inexistente causa anterior capaz de gerar essa mora, é que a citação do réu no processo servirá para esse fim. E fará isso apenas porque, com essa citação, tem-se a certeza do direcionamento da pretensão do alegado credor no sentido de sujeitar o afirmado devedor à prestação requerida. Qualquer outra manifestação anterior nesse sentido, porém, surtirá o mesmo efeito, de modo que não há nada de particularmente específico da relação processual na formação desse efeito.

Também o efeito de tornar litigiosa a coisa não pode mais ser atribuído, exclusivamente, à formação de processo judicial. A rigor, a instauração de qualquer mecanismo de composição da controvérsia, seja judicial ou não, tem o mesmo potencial. Até mesmo a formação de processo administrativo pode ser suficiente para ensejar a litigiosidade da coisa. De fato, parece correto dizer que, desde que presente a inequívoca controvérsia a respeito da coisa, deve ela ser considerada como litigiosa para todos os fins. Seria no mínimo insensato concluir que, existindo procedimento extrajudicial de mediação ou de conciliação (com a participação de ambos os polos envolvidos), não se poderia caracterizar a litigiosidade da coisa, apenas porque ausente processo judicial regularmente formado.

Por essa razão, é correto concluir que a orientação firmada pela jurisprudência quanto à caracterização da fraude à execução reflete com precisão essa visão. Entende o Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375, do STJ). Mais do que isso, entende que “é indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC” (referência ao CPC/73).<sup>12</sup> Ora, a conclusão – que se baseia na litigiosidade da coisa – efetivamente conclui que é imprescindível para essa condição que haja certeza (tanto para o devedor, como para terceiro) de que a coisa é objeto de disputa. Assim, ainda que a disputa não se traduza em processo judicial – estando veiculada em outra seara – é de se reconhecer que o mesmo efeito seja produzido.

Em conclusão, resta que apenas a litispendência, por constituir típico e exclusivo efeito processual, só opera seus efeitos em relação ao réu a partir da sua citação para o processo.

Por isso, só pode haver litispendência – e suas consequências – em relação ao réu depois de sua efetiva citação para o processo.

#### **4. A formação gradual da relação processual. A formação em relação a terceiros**

Já em relação aos terceiros, a fixação do termo inicial dos efeitos do processo, evidentemente, não segue a diretriz fixada na parte final do art. 312, do CPC. Para eles tais efeitos podem resultar do protocolo da petição inicial, da publicidade dada a esse protocolo ou, eventualmente, da sua cientificação pessoal a respeito da demanda.<sup>13</sup> Tudo dependerá das circunstâncias do caso e do tipo de efeito envolvido.

Se é certo que a litigiosidade da coisa dependerá da ciência desses terceiros sobre a controvérsia,<sup>14</sup> outros efeitos podem ter seu termo inicial variando, a depender das circunstâncias do caso.

---

## **NOTAS DE RODAPÉ**

1

Assim, REsp 1.333.887/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.12.14; REsp 1.136.276/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.04.12.

---

2

Afirmando esse entendimento, v. REsp 1.015.133/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 23.04.10; REsp 459.351/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho. RT 819/178; RMS 14.359/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 28.04.03, p. 202.

---

3

Nesse sentido, AgRg no REsp 1.233.641/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30.09.14; AR 3234/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14.02.13.

---

4

Em seu prejuízo, já em em seu benefício, a coisa julgada pode ser invocada, a teor do que afirma o art. 506, do CPC.

---

5

REsp 1105944/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Campbell Marques, DJe 08.02.11.

---

6

RMS 27.358/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrichi, DJe 25.10.10.

---

7

REsp 772.202/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 31.08.09; REsp 598.798/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJU 21.11.05, p. 226.

---

8

V. Egas Dirceu Moniz de Aragão, Comentários ao código de processo civil, 8ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, vol. II, p. 331-332 e 335.

---

9

Hélio Tornaghi, Comentários ao código de processo civil, 2ª ed., São Paulo: RT, 1978, vol. II, p. 303.

---

10

REsp 1.067.911/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 03.09.09; REsp 202.564/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. RT 798/213.

---

11

EDcl no REsp 1.527.154/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03.11.15; REsp 1.267.490, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27.03.15.

---

12

REsp 956.943/PR, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 01.12.14, julgado sob o regime de repetitivo.

---

13

Nessa linha, v. Egas Dirceu Moniz de Aragão, Comentários, ob. cit., p. 337.

---

14

Seguindo essa orientação é a Súmula 375, do STJ.

© desta edição [2018]

## **Título II. Da Suspensão do Processo**

### **1. Suspensão e interrupção do processo**

No direito estrangeiro, há sistemas que distinguem a suspensão da interrupção do processo, tanto em relação às suas causas, quanto no que se refere às suas consequências.<sup>1</sup>

A questão é polêmica, variando inclusive quanto ao sentido dado ao termo. Perante o direito italiano, Carnelutti, por exemplo, que inclui a interrupção como uma das espécies de conversão, entende que esta decorre da modificação dos elementos com os quais ou sobre os quais se desenvolve a atividade processual, necessária ao prosseguimento da relação processual.<sup>2</sup> Para Liebman, a interrupção do processo decorre da necessidade de preservar a inteireza do contraditório, que pode vir a ser prejudicada em razão da ocorrência de fato que prejudique a participação da parte, de seu representante legal ou de seu procurador.<sup>3</sup>

Em outros países, embora ambos os conceitos se liguem a fato que impõe sobrestamento na marcha processual, cada qual se liga a fenômenos diversos.

O direito brasileiro não contém semelhante diferenciação, que aqui não produz consequências práticas distintas. Interrupção e suspensão do processo são tratados pelo código como fenômenos idênticos, com o mesmo regime.

O que importa, para o direito brasileiro, é a ocorrência de algum evento que determine a paralisação temporária do processo.<sup>4</sup> A suspensão, como é evidente, não implica o desaparecimento da relação processual. Por isso, permanecem vigorando os efeitos da formação da relação processual, a exemplo da litispendência e da prevenção do juízo.

**Art. 313.** Suspende-se o processo:

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II – pela convenção das partes;

III – pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV – pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI – por motivo de força maior;

VII – quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII – nos demais casos que este Código regula.



§ 1.º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2.º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I – falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

§ 3.º No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste.

§ 4.º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5.º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4.º.

§ 6.º No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

§ 7.º No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

## **1. Suspensão e capacidade das partes**

A capacidade das partes – em suas três espécies (capacidade de ser parte, de estar em juízo e postulatória) – é pressuposto para a formação e para o desenvolvimento válido da relação processual.<sup>5</sup> Por isso, é indispensável que, ao longo de todo o processo, haja a cautela de preservar essa capacidade, a fim de manter também a validade dos atos praticados pelos sujeitos do processo. Havendo fato que incida sobre essa capacidade, podendo alterá-la, impõe-se a sustação do processo, de modo a sanar essa questão, dando então a sequência normal à relação processual.

Por isso, o código elege como primeira causa para a suspensão do processo a verificação de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

Cada uma dessas situações recebe tratamento próprio no regime do código, o que recomenda que se examine cada hipótese separadamente.

## **2. Suspensão por morte da parte**

A morte da parte é problema de capacidade de parte que pode ocasionar duas espécies diferentes de consequências. Pode gerar, em primeiro lugar, a necessidade de extinguir o processo, nos casos do art. 485, IX, do CPC, ou seja, quando a ação for considerada intransmissível por disposição de lei.

Em regra, porém, a morte da parte ocasiona a suspensão do processo, de modo que os seus sucessores possam habilitar-se para prosseguir na relação processual. É certo que, para o direito material, a transmissão dos interesses da pessoa falecida para seus herdeiros se dá de imediato (art. 1.784 do CC). Todavia, no plano processual, é necessário que ocorra essa sucessão da parte original por aquele que deve ocupar seu lugar.

O texto legal alude apenas à morte da parte. Porém, é evidente que a mesma regra (e o mesmo regime) se aplica à extinção da pessoa jurídica.<sup>6</sup> Também aqui o que ocorre é a extinção da capacidade civil do sujeito, o que implica também a extinção da sua capacidade de ser parte.

Recorde-se, porém, que a extinção da pessoa jurídica se dá com a conclusão da sua liquidação (art. 51 do CC), de modo que até esse momento é existente a sociedade e presente a capacidade de ser parte. Todavia, como nesse período há a modificação da administração original da sociedade, com sua substituição por um liquidante ou administrador, é evidente que, para o Código de Processo Civil, a paralisação da relação processual se dá desde o início desse procedimento, de modo que possam habilitar-se esses novos administradores ou os próximos titulares do direito envolvido no processo.

### **3. Suspensão por perda de capacidade da parte**

Também afirma o art. 313, I, do CPC, que deverá o processo ser suspenso se houver a perda de capacidade da parte. Embora para as pessoas jurídicas, essa diferença não tenha utilidade, para a pessoa natural essa situação efetivamente pode ocorrer.

A pessoa natural, embora exista, pode deixar de ter capacidade para os atos da vida civil. Nesse caso, essa incapacidade superveniente também se reflete para o processo, retirando do sujeito a sua capacidade de estar em juízo. A pessoa continuará possuindo “capacidade de ser parte”, mas não terá mais a capacidade para estar em juízo, ou seja, a aptidão para exercer, em seu próprio nome, os direitos, ônus, deveres e obrigações processuais.

Por isso, novamente, deverá o processo ser suspenso a fim de que possa ser suprida a deficiência de capacidade, que deverá ser integrada por representante ou por assistente, conforme o caso.

Recorde-se que a Lei 13.146/2015 alterou substancialmente o regime das incapacidades, sobretudo para excluir da condição de incapazes as pessoas com qualquer tipo de deficiência, física ou mental. Essas pessoas só serão consideradas relativamente incapazes se “não puderem exprimir sua vontade” (art. 4.º, III, do CC). E, mesmo assim, segundo prevê o art. 6.º, da Lei 13.146/2015, o reconhecimento dessa restrição não afeta a plena capacidade da pessoa com deficiência para

I – casar-se e constituir união estável; II – exercer direitos sexuais e reprodutivos; III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV – conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V – exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e VI – exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

De todo modo, nos casos em que seja necessário suprir a capacidade da pessoa com deficiência, dever-se-á nomear curador (ou curadores, como prevê o art. 1.775-A do CC) ou ainda instaurar procedimento para a tomada de decisão apoiada, nos termos do art. 1.783-A do CC.

### **4. Morte e perda da capacidade de representante**

Sabendo que a capacidade, dentro do processo, divide-se em três análises distintas (capacidade de ser parte, de estar em juízo e postulatória), pode suceder que a deficiência da capacidade não ocorra com a parte em si, mas sim com o sujeito que eventualmente age por ela, para dar-lhe a capacidade de estar em juízo que eventualmente não possua.

Isso pode ocorrer, em primeiro lugar, em relação a pessoas naturais que, quando incapazes na vida civil, precisarão estar acompanhadas de representante, tutor, de curador ou ainda de apoiador.

Poderá ainda ocorrer essa integração da capacidade na hipótese de pessoa jurídica. Como ficção que é, a pessoa jurídica necessita de uma pessoa natural que exprima a vontade em seu nome, apresentando-a para os atos da vida civil. Para os fins do Código de Processo Civil, essas

pessoas são aquelas arroladas pelo art. 75 do CPC, ainda que outras possam ser designadas para atuar em nome da pessoa jurídica nos atos da vida civil em geral.

Havendo essa cisão de sujeitos no exercício da capacidade, pode ocorrer que a pessoa natural que atua como auxiliar da parte venha a falecer ou a perder a sua capacidade.

Nesses casos, em se tratando de (re)presentante de pessoa jurídica, não há a incidência do art. 313, I, do CPC. Como recorda Moniz de Aragão,

se uma pessoa física, órgão de pessoa jurídica, desaparece, outra lhe toma o lugar, sem que haja solução de continuidade do processo. O mandato outorgado ao advogado não sofre o menor efeito em vista do acontecimento e razão alguma justificaria a suspensão do processo. Uma coisa é a extinção da pessoa jurídica; outra o falecimento ou incapacidade da pessoa física que desempenha o papel de seu órgão.<sup>7</sup>

Assim, falecendo o representante da pessoa jurídica, o processo prossegue normalmente, sem que isso interfira em nada na relação processual ou na sua continuidade. Não há razão para a suspensão do processo nesse caso.

Já se a morte ou a perda da capacidade se dá em relação ao representante, ao tutor, ao curador ou ao apoiador, a solução é diversa. Nesses casos, não haverá mais quem exerça, em nome da parte, os poderes, ônus, deveres e obrigações do processo. Por isso, impõe-se a paralisação do processo, até que outro sujeito venha para auxiliar a parte a desempenhar suas atividades.

Logicamente, a suspensão nesse caso só tem sentido caso, em razão da morte ou da perda de capacidade, “não haja sujeito que possa prosseguir no desempenho imediato dessas funções”. Assim, por exemplo, havendo curatela compartilhada (art. 1.775-A do CC), a morte ou perda da capacidade de um dos curadores não repercute na capacidade do outro. Por isso, nesse caso, não há razão para a suspensão do processo. O mesmo se dá na hipótese de tomada de decisão apoiada, quando forem vários os apoiadores nomeados e subsistam, ao menos, dois capazes, que possam desempenhar suas tarefas (art. 1.783-A do CC).

## **5. Morte e perda de capacidade do advogado**

O art. 313, I, do CPC, alude ainda à morte ou perda de capacidade do “procurador”. Evidentemente, não se trata aqui da figura do mandatário ou do procurador negocial. Neste caso, falecido esse mandatário ou tendo ele perdido sua capacidade, subsiste o mandante, com sua capacidade plena. Logo, não haveria nenhum motivo que devesse importar a paralisação do processo.

O “procurador” a que alude o texto legal é, evidentemente, o advogado da parte ou, mais amplamente, aquele que tem a autorização legal para exercer a capacidade postulatória em nome da parte.

Porque o advogado da parte possui mandato especial para atuar em nome da parte, é evidente que em razão de sua morte ou da perda da sua capacidade, cessa o mandato judicial e, por isso, fica ausente a capacidade postulatória. Por isso, mais uma vez, impõe-se a suspensão do processo para a regularização da representação processual.

Três observações merecem ser feitas a propósito desse caso em particular.

Em primeiro lugar, evidentemente, a regra se aplica ao advogado que constitua único procurador da parte. Se a parte é representada por mais de um advogado ou por advogados pertencentes a sociedade de advocacia (art. 105, § 3.º, do CPC) a morte ou a perda da capacidade de um, por óbvio, não interfere na situação dos demais. Por isso, nesse caso, não há razão para a suspensão do processo.

O mesmo se passa na hipótese de advogado público – ou, por assimilação, a defensor público ou membro do Ministério Público. É evidente que o falecimento do agente não inibe o prosseguimento da apresentação ou da representação judicial por outro sujeito ligada ao mesmo

quadro funcional. Aí, novamente, a regra do art. 313, I, não se aplica.

Finalmente, em relação ao advogado particular, deve-se recordar que não é apenas a sua morte ou a perda de sua capacidade que interferem na prerrogativa que tem de representar judicialmente alguém. Perdendo ele o poder de atuar em juízo – seja porque se tornou impedido de advogar, seja porque exerce atividade incompatível com a advocacia, seja ainda porque está suspenso ou, enfim, porque sofre outra restrição ao exercício da advocacia – também incidirá a causa de suspensão aqui estudada.

Ocorrendo a morte ou a perda da capacidade do advogado, impõe-se a imediata suspensão do feito, a fim de preservar o direito da parte à defesa técnica. Todavia, em certas circunstâncias, essa imediata paralisação pode não ser tão simples assim. Imagine-se que o advogado recebe alguma punição, que o inhabilita ao exercício da advocacia; nesses casos, dificilmente ele comunicará, de bom grado, ao seu cliente, por razões óbvias. O processo, então, muito provavelmente, seguirá seu curso tendo uma parte (rigorosamente) sem advogado com capacidade postulatória. O que deve suceder em casos como esse, a fim de compatibilizar o direito de defesa da parte e a necessidade de preservação da duração razoável do processo e da seriedade da atividade jurisdicional?

Se é certo que não é justo que a parte fique sem defesa em razão da pena de inhabilitação aplicada ao advogado, também não se pode impor ao Judiciário (ou à parte contrária) o dever de fiscalizar, constantemente, a manutenção da capacidade postulatória do advogado.

Inicialmente, parece que, em tais casos, tem plena aplicação o princípio do prejuízo (*pas de nullité sans grief*), segundo o qual não há nulidade a ser declarada – em razão da não suspensão do feito, mesmo diante da falta de capacidade postulatória do advogado – sem que se demonstre efetivo prejuízo em razão da ausência do advogado com capacidade para representar a parte. Em segundo lugar, parece necessário também exigir-se da parte a efetiva demonstração de sua boa-fé, ou seja, de seu desconhecimento a respeito da condição de seu advogado.

Porém, presentes a efetiva demonstração do prejuízo e da boa-fé da parte, deve-se anular o feito a partir do momento em que ele deveria estar suspenso.

## **6. Habilitação de herdeiros e sucessores**

A suspensão do processo por morte ou perda de capacidade das partes, seus representantes legais ou seus advogados pode ser determinada de ofício pelo juiz, observado o art. 9.º, do CPC.

Sobrestado o feito – de ofício ou a requerimento de parte – deve o sujeito interessado proceder à habilitação de seus herdeiros ou sucessores, no caso de morte (ou extinção) da parte original, ou à correção do defeito, no caso de perda de capacidade da parte, de seu representante legal ou de seu advogado.

A habilitação seguirá o procedimento previsto a partir do art. 687 do CPC, independentemente da razão que ocasionar seu surgimento. Não existe mais, no modelo atual, situações em que habilitação acontece independentemente da formação de novo processo (incidente), tal como ocorria nas hipóteses do art. 1.060 do CPC/1973.

No modelo atual, a habilitação poderá ser postulada pela parte contrária, que pleiteará o ingresso dos sucessores da parte falecida, ou pelos próprios sucessores, que pretenderão seu ingresso no feito no lugar da parte original (art. 688 do CPC). Recebido o pedido de habilitação, devem ser citados os requeridos,<sup>8</sup> para manifestarem-se em cinco dias, devendo então o magistrado decidir sobre a questão de imediato, salvo quando necessária a produção de prova não documental. Neste último caso, em vista da necessidade dessa dilação probatória, o pedido de habilitação será autuado em apartado, o que, no entanto, não faz nenhum sentido, à vista da paralisação do processo até decisão final da sucessão (art. 691 do CPC).

Somente depois de transitada em julgado a sentença de habilitação é que haverá o ingresso definitivo dos novos sujeitos, retomando o processo o seu curso regular (art. 692 do CPC). Embora normalmente esse “trânsito em julgado” se dê com a decisão judicial, é evidente que poderá haver

recurso, o que alongará o período de suspensão do processo até o esgotamento dos recursos ou a sua análise final. Porém, respeitando os termos exatos do dispositivo, só depois de preclusa a decisão de habilitação é que se poderá dar seguimento válido ao processo.<sup>9</sup>

Não tendo havido a iniciativa das partes em proceder a essa sucessão de parte, deve o juiz, tão logo tome ciência do falecimento (ou da extinção) da parte, determinar a suspensão do processo.

Em se tratando do falecimento do réu, deve o juiz determinar ao autor que proceda à citação do correspondente espólio, sucessores ou herdeiros, no prazo por ele determinado, que deverá variar entre dois e seis meses (art. 313, § 2.º, I, do CPC). Não havendo essa habilitação, o processo deve ser extinto, porque faltará um polo passivo para a demanda.

Quando a morte for do autor original, deverá o juiz verificar se o direito é ou não transmissível ou ainda se a relação jurídica material extingue-se ou não em razão da morte.<sup>10</sup> Não o sendo, será o caso de extinguir o processo, ante a perda de seu objeto (art. 485, IX, do CPC). Sendo transmissível o objeto, então deverá o juiz intimar o espólio, os sucessores ou os herdeiros do falecido – valendo-se do meio de comunicação que entender mais adequado – para que possam manifestar seu interesse em prosseguir no feito, fixando prazo para essa manifestação.<sup>11</sup> Em caso afirmativo, deverão proceder à habilitação, na forma acima vista. Não havendo interesse no prosseguimento, ou não tendo ocorrido a habilitação no prazo designado pelo juiz – que também deverá variar, por analogia, entre dois e seis meses – o processo será extinto sem resolução de mérito.

## **7. Incapacidade da parte, morte ou incapacidade do representante ou do advogado e sanção do defeito**

Na hipótese em que a parte não tenha morrido, mas tenha perdido sua capacidade (ou alterado sua incapacidade), bem como nos casos em que ocorra a morte ou a incapacidade do representante da parte ou de seu procurador, não é propriamente o caso de habilitação. Não há sucessão de parte, mas apenas a necessidade de corrigir o defeito da capacidade verificado.

Para isso, é desnecessário seguir o regime do art. 687 e ss., do CPC, sobretudo no que se refere à necessidade de aguardar a preclusão da decisão para o prosseguimento do processo.

Desse modo, verificando a parte essa irregularidade, deverá postular ao magistrado prazo para a correção do defeito. Não o fazendo, deverá o juiz, assim que verificar o problema, sustar o processo e provocar a atuação da parte.

Suspenso o processo, o juiz dará prazo para a parte corrigir o defeito. Esse prazo, assim como as providências a serem adotados, como é óbvio, variará segundo o tipo de medida necessária.

Eventualmente, será necessário nomear curador ou tutor à parte, o que demandará mais tempo, à vista do procedimento estabelecido pelo art. 747 e ss., do CPC. Em se tratando de defeito referente ao representante da parte, a questão assumirá menor complexidade, já que bastará a substituição do representante por alguém que goze de sua capacidade plena. O mesmo ocorrerá na hipótese de morte ou incapacidade do advogado da parte.

Desse modo, será necessário que o prazo de suspensão do processo, nesses casos, atente às providências que serão necessárias para a correção do defeito verificado.

Logicamente, ultrapassado o período de suspensão e não corrigido o problema, em qualquer dos casos de incapacidade da parte ou ainda de morte ou perda de capacidade do representante, deverá o juiz aplicar, por analogia, as consequências estabelecidas pelo art. 313, § 3.º, do CPC. Assim, não sanado o defeito do polo ativo do processo – e, sendo a parte em relação a quem se verifica o problema a única autora da causa – será o caso de extinguir o feito por falta de pressuposto processual superveniente (art. 485, IV, do CPC). Caso o defeito que persiste afetar o polo passivo da relação processual, então será o caso de se reconhecer a revelia do réu (ainda que a extensão dos efeitos dessa revelia deva ser avaliada conforme as circunstâncias do caso, como se

verá adiante).

Observe-se, por fim, que a situação da morte ou perda de capacidade do advogado possui regime próprio no código. Segundo prevê o art. 313, § 3.º, do código, falecendo o advogado (ou tendo ele perdido sua capacidade plena) deverá o juiz, mesmo que iniciada a audiência de instrução e julgamento, determinar à parte que constitua novo procurador, no prazo de quinze dias. Não havendo essa nomeação, se o problema afetar o polo ativo do processo, deverá o juiz determinar a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), no caso de único autor, ou excluir o autor cuja falta de capacidade é reconhecida, no caso de litisconsórcio ativo. Se a inércia na nomeação atingir o polo passivo do processo, então deverá o juiz decretar a revelia do réu que não está mais acompanhado de advogado no regular exercício de sua profissão.

É evidente que a extensão dos efeitos da revelia, neste caso, não é intuitiva, devendo decorrer da avaliação das circunstâncias de fato da causa. Assim, por exemplo, no caso de litisconsórcio passivo unitário, a revelia de um dos réus (na forma do art. 313, § 3.º, do CPC), não implicará a presunção de veracidade dos fatos, por força do que prevê o art. 345, I, do CPC. O mesmo ocorrerá se o interesse envolvido for indisponível, se ausente documento essencial à propositura da demanda, ou ainda se já ultrapassada a fase da defesa do réu. Em regra, somente o efeito da dispensa de intimações (art. 346 do CPC) é indefectível. Todos os outros incidirão ou não conforme os outros elementos presentes no processo.

## **8. Incapacidade superveniente e tomada de decisão apoiada**

A Lei 13.146/2015 estabeleceu novo regime destinado a suprir a falta de capacidade de pessoa com deficiência. Trata-se do regime de tomada de decisão apoiada, hoje constante do art. 1.783-A do CC.

Caso a incapacidade superveniente – que enseja a suspensão do processo – autorize o emprego dessa técnica, então, diante da paralisação do feito, deverá a parte requerer ao magistrado da causa que lhe assine prazo razoável para que traga o termo (assinado pela pessoa com deficiência e pelos apoiadores), com os limites do apoio, os compromissos dos apoiadores, o prazo de vigência do termo e a previsão de respeito à vontade do sujeito a ser apoiado (art. 1.783-A, § 1.º, do CC). O juiz, então, que deverá estar assistido por equipe multidisciplinar que tenha condições de avaliar o grau de comprometimento da pessoa com deficiência, ouvirá o Ministério Público, o interessado e os apoiadores, decidindo em seguida.

Caso, eventualmente, essa decisão já tenha sido tomada em outro processo – ou em via autônoma – será desnecessário novo incidente, bastando a exibição no processo suspenso do acordo de apoio devidamente homologado (art. 1.783-A, § 4.º, do CC).

De todo modo, com a presença dos apoiadores, suprido resta o defeito de capacidade, devendo o processo prosseguir em seus termos.

## **9. Morte ou perda de capacidade da parte ou de representante legal e fase do processo**

O Código de Processo Civil de 1973 previa que, falecendo ou perdendo a capacidade, o autor ou seu representante legal depois de já iniciada a audiência de instrução e julgamento, não haveria suspensão imediata do processo (art. 265, § 1.º, do CPC/1973). Nesse caso, o advogado constituído da parte deveria prosseguir até o encerramento da audiência, devendo o juiz suspender o processo só depois de publicada a sentença ou o acórdão.

O código atual não repete semelhante preceito. Ao contrário, consigna expressamente no art. 313, § 3.º, que a morte do procurador da parte, inclusive se já iniciada a audiência de instrução e julgamento, deve sempre implicar a suspensão do processo. Para o procurador judicial, portanto, a solução já vem dada pela lei, sendo evidente a superação do modelo anterior.

Porém, e se, iniciada a audiência de instrução e julgamento, falecer ou perder sua capacidade a parte ou seu representante legal?



Não parece haver razão para solução diversa.

A solução alvitrada pelo Código de Processo Civil de 1973 tinha por objetivo preservar a economia processual, evitando a interrupção de audiência ou o julgamento da causa em razão da morte ou perda de capacidade da parte ou de seu representante.<sup>12</sup> Porém, não parece correto que a economia processual se sobreponha à necessidade de preservação dos pressupostos processuais e à imposição do respeito à plena participação dos sujeitos no processo em contraditório. Por isso, parece mais correta a solução do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa circunstância decorre a conclusão de que, verificada a morte ou a perda de capacidade processual da parte, de seu representante ou de seu advogado, é sempre o caso de suspensão do processo, independentemente do momento em que a causa se encontre.

Por óbvio, pode surgir eventual dificuldade em o Judiciário saber que há esse defeito em relação aos sujeitos do processo. Nem sempre é imediata a comunicação ao juiz da causa sobre a morte da parte ou a sua perda de capacidade. Também é fácil imaginar situações em que o falecimento do advogado, justamente por essa circunstância, demora a ser transmitida para o órgão jurisdicional.

Porém, essa dificuldade não serve de crítica para a opção legal da paralisação do processo, inobstante a fase em que ele se encontre.

Sempre que essa demora na comunicação possa vir a prejudicar a parte, será o caso de aplicar os princípios que regem as invalidades no direito processual, de modo a invalidar eventual ato judicial (v.g., sentença) praticado. Se, ao contrário, do ato judicial não decorrer prejuízo nenhum imediato, então o ato deverá ser tido por válido e eficaz. Assim, falecendo a parte ou seu representante no curso do processo, sem que disso tenha ciência o advogado, o processo deverá ser tido por válido se não houver risco à defesa da posição da parte diante de sua ausência ou da perda de sua capacidade. Se, porém, houver efetiva demonstração do prejuízo, o processo será invalidado (desde o momento em que se verificar o gravame), suspendendo-se a causa até que seja sanado o defeito de capacidade.

Assim, por exemplo, se, diante do falecimento da parte ou de seu representante legal, não foi possível fornecer alguma informação relevante para o advogado do processo ou não foi possível efetivar o pagamento de certa diligência, estará demonstrado o prejuízo e será necessário desconstituir esses atos ou retornar a esse momento. Do contrário, a suspensão do processo só passará a incidir a partir do momento da comunicação do problema da capacidade, sem que os atos anteriores sejam afetados, ainda que já presente o defeito.

## **10. Suspensão convencional**

Outra hipótese em que a lei autoriza a suspensão do processo é aquela que decorre da vontade das partes do processo. Convindo elas (todas) com essa paralisação, há de prevalecer sua vontade, mesmo porque se supõe que esse sobrestamento seja melhor para a composição do litígio.

Embora o preceito não seja novo – já constando, por exemplo, no art. 265, II, do CPC/1973 – tem-se aí clara manifestação específica da autonomia da vontade no campo do processo e, particularmente, de uma convenção das partes.

Como toda convenção, parece razoável estender para cá a aplicação dos critérios expostos pelo art. 190, do CPC. Por isso, a suspensão convencional só tem cabimento em se tratando de direito que admita autocomposição e que envolva partes plenamente capazes. Do contrário, porque irrelevante a vontade da parte na condução do processo, a suspensão consensual também não deverá incidir.

Por outro lado, também parece razoável permitir ao magistrado sindicarem o pedido conjunto de suspensão convencional, nos casos enumerados no art. 190, parágrafo único, do CPC. Assim, por exemplo, verificada a manifesta situação de vulnerabilidade da parte, pode o juiz negar força ao pedido conjunto de suspensão do processo, valendo o mesmo no caso de nulidade do acordo que



busca a paralisação do curso processual.

Logicamente, como manifestação da vontade que altera o curso da demanda, impõe-se a manifestação e a aquiescência de “todas as partes do processo”.<sup>13</sup> Não havendo essa unanimidade, descabe a suspensão, sendo quando muito o caso de se cindir eventual litisconsórcio, na forma do art. 113, § 1.º, do CPC. Evidentemente, só os sujeitos que efetivamente gozem da condição de parte devem aquiescer ao pedido de suspensão convencional. Os terceiros intervenientes (que não adquirem a condição de parte, a exemplo do assistente), o Ministério Público (na condição de fiscal da ordem jurídica) ou outros auxiliares do processo não precisam concordar com esse tipo de pleito.

Demais disso, como alerta há muito a doutrina nacional, a suspensão convencional do processo pode mostrar-se ineficaz enquanto algum ato processual estiver em curso ou enquanto produza efeito certo ato.<sup>14</sup> Assim, “não opera efeito” o pedido de suspensão formulado durante o curso de audiência ou enquanto se desenvolve o julgamento de recurso em tribunal. Também não surte efeito o pedido de suspensão enquanto corre prazo peremptório. Se é certo que o pedido pode ser formulado nesses momentos, “seus efeitos” (e, portanto, a paralisação do processo) só ocorrerão depois de encerrado o ato ou de escoado o prazo peremptório.<sup>15</sup>

Consigne-se que o código fixa prazo máximo para essa causa de suspensão. Segundo prevê o art. 313, § 4.º, do CPC, a suspensão por convenção das partes não pode exceder a seis meses, findo o qual deve o juiz determinar o prosseguimento do feito (§ 5.º). Evidencia-se da previsão legal que o prazo mencionado é máximo. Isso significa dizer que as partes podem convencionar prazo “menor” para a suspensão do processo. Não poderão, porém, estipular prazo maior do que o legal. Vale dizer que, ainda que se trate de negócio processual (regido em princípio pela lógica do art. 190, do CPC), tem-se aqui negócio “típico”, que deve submeter-se aos limites temporais – postos no interesse público da duração razoável da prestação jurisdicional – fixados pelo § 4.º, mencionado. Descabe, por isso, negócio processual tendente a ampliar aquele prazo.

Ademais, ausente expressa referência no pacto sobre o prazo da suspensão, deve o juiz aguardar o prazo legal e, findo ele, dar seguimento ao processo, independentemente de qualquer manifestação das partes. Aliás, além de não depender de manifestação das partes, o prosseguimento do processo, uma vez findo o período de suspensão, se dá independentemente de qualquer intimação a elas ou prévio aviso. Conforme já assentou a jurisprudência,

se a suspensão é derivada de negócio jurídico processual lavrado pelas próprias partes, compete-lhes acompanhar o andamento do processo cessada a suspensão convencional, por força do impulso oficial que norteia o processo civil brasileiro.<sup>16</sup>

Obviamente, porque o art. 313, § 4.º, do CPC, alude a prazo máximo, não se pode cogitar de prorrogação do período de suspensão para além do termo fixado pela lei. Assim, embora as partes possam – dentro dos seis meses – formular vários pedidos de prorrogação do período de suspensão, o total da paralisação do processo não poderá exceder a seis meses.

Por derradeiro, recorde-se que a regra da suspensão convencional em exame só se aplica para o processo de conhecimento – ou para a fase de conhecimento do processo. Quanto à execução (ou à fase de cumprimento de títulos judiciais), tem aplicação o art. 922 do CPC, de modo que a paralisação terá a duração do prazo concedido pelo credor.

### **11. Suspensão e arguição de impedimento e suspeição do juiz**

O art. 313, III, do CPC, afirma que também deve o processo ser suspenso em razão da arguição do impedimento ou da suspeição.

Embora o Código não o diga expressamente, somente a arguição de suspeição ou impedimento “do juiz” opera a suspensão do processo. Conquanto outros sujeitos possam ter sua imparcialidade questionada no processo (art. 148, do CPC), essa discussão não implica a paralisação do processo, como expressamente consigna o art. 148, § 2.º, do CPC.

Por outro lado, o Código inova no tratamento dessa matéria em dois sentidos diversos. Em primeiro lugar, a discussão desses temas deixa de ser feita por meio de “exceção”, tal como feito no código anterior. É fato que essa novidade é mais aparente do que real, sequer resultando em consequências práticas diversas. Com efeito, embora o incidente no qual se discute a suspeição e o impedimento do juiz tenha perdido o nome de “exceção”, seu regime é praticamente idêntico ao que se fazia no Código de Processo Civil de 1973. A matéria continua sendo objeto de discussão em petição própria, que formará incidente processual, com a suspensão do curso do processo (art. 146 do CPC).

A segunda novidade, porém, é mais significativa: deixa de existir no Código de Processo Civil de 2015 a figura da exceção de incompetência relativa. O tema passa a ser arguido – tal como a incompetência absoluta – em preliminar na contestação (art. 64 do CPC) ou, no caso da incompetência absoluta, em qualquer momento no processo, podendo mesmo subsidiar ação rescisória (art. 966, II, do CPC). E, nessa condição, a discussão sobre a incompetência, seja relativa, seja absoluta, não implica mais a paralisação do processo. Essa já era a solução do Código de Processo Civil de 1973 em relação à incompetência absoluta. Porém, no código atual, optou-se por tratar de modo uniforme o instrumento pelo qual se argui todas as incompetências. Por isso, a discussão sobre a incompetência não suspende mais o curso do processo.

## **12. Duração do efeito suspensivo e arguição de suspeição e impedimento do juiz**

A duração do efeito suspensivo decorrente da arguição de impedimento ou suspeição é tema que exige reflexão. Conforme afirma o art. 146, § 2.º, do CPC,

distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I – sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II – com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

Com isso, tem-se que a partir da arguição da suspeição ou do impedimento do juiz deve ele determinar a suspensão do processo. Reconhecida a parcialidade, os autos serão remetidos ao substituto legal (art. 146, § 1.º, do CPC). Ao chegar a esse novo juízo, o processo retomará o seu curso, devendo o novo magistrado comunicar as partes do prosseguimento do feito.

Se, porém, o juiz suscitado entender-se imparcial, deverá dar suas razões, remetendo o processo ao tribunal. O processo, nesse interregno, permanecerá suspenso. Chegando ao tribunal, cabe ao relator examinar se permite ou não o prosseguimento do processo enquanto se debate sobre a imparcialidade do juiz arguido.<sup>17</sup> Se determinado o efeito suspensivo, o processo ficará suspenso até o julgamento do incidente. Do contrário, o processo prosseguirá perante o juiz arguido, que reassumirá o feito até eventual decisão contrária do tribunal.

Desse modo, o efeito suspensivo de que trata o art. 313, III, do CPC, é apenas o efeito suspensivo determinado pelo juiz arguido, até que a questão seja reapreciada pelo relator da questão no tribunal, se o incidente chegar àquela instância. Ali chegando, não há mais o efeito automático da arguição de suspeição ou de impedimento, cabendo ao relator examinar se é ou não o caso de manter a paralisação do processo, enquanto se examina o problema da eventual parcialidade do magistrado arguido.

Logicamente, poderá suceder que a decisão do tribunal, a propósito dessa parcialidade, seja objeto de novo recurso, para as instâncias superiores. Todavia, como esses recursos não têm, em regra, efeito suspensivo (art. 995 do CPC), a decisão do tribunal recorrido será imediatamente eficaz. Assim, se reconhecer a parcialidade do juiz, determinará a remessa dos autos ao substituto legal, devendo o processo retomar seu curso assim que chegar ao novo magistrado. Do contrário, reconhecida a imparcialidade do juiz arguido, os autos ser-lhe-ão restituídos, devendo ele então dar andamento ao processo, dando ciência às partes.

## **13. Suspensão e instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas**

Outra causa de suspensão obrigatória do processo é a admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 982, I, do CPC). Note-se que não basta a arguição do incidente. É

necessário que ele seja admitido pelo relator.

Por outro lado, o efeito suspensivo de que aqui se trata, não está limitado ao processo em que o incidente é arguido. Atingirá “todos os processos que discutam a mesma questão de direito” no âmbito de competência do tribunal que julgará o incidente.

Esse incidente é uma técnica de cisão do julgamento, atribuindo-se a um só órgão (o tribunal local) a análise da questão de direito que é recorrente a vários processos e que impõe risco à isonomia e à segurança jurídica. Desse modo, embora o órgão original conserve sua competência para apreciar as demais questões do processo, a análise da questão de direito repetitiva fica afetada ao tribunal, tanto para aquele processo, como para todos os outros em que o mesmo tema seja (ou venha a ser suscitado) na esfera de competência daquele tribunal. Haverá, portanto, repartição de atribuições no mesmo processo, de modo que ao tribunal competirá a apreciação da questão de direito, enquanto o restante da controvérsia permanecerá nas mãos do juízo original. Todavia, como a questão de direito é imprescindível para a análise do restante do conflito, o processo ficará paralisado até que se decida sobre a adequada interpretação da questão de direito.

Logicamente, dessas observações resultam algumas consequências. Em primeiro lugar, se a análise da questão de direito “não é imprescindível para o julgamento da causa”, não há razão para a suspensão do processo em que essa questão foi suscitada. Assim, por exemplo, se é nítida a existência de vício processual, ou se a solução da controvérsia não depende da análise da questão de direito ventilada, então não há razão para a suspensão do processo.

Identicamente, se apenas parte do conflito é atingido pela solução da questão de direito, não há sentido na paralisação de todo o processo. Imagine-se a admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas sobre índice de correção monetária ou sobre taxa de juros ou sobre honorários de sucumbência. É evidente que praticamente todos os processos discutirão esses temas, de modo que alguém poderia imaginar que todos eles deveriam ficar suspensos integralmente, até a solução da questão de direito. Essa alternativa, porém, seria francamente contrária ao princípio da duração razoável do processo. De um lado, porque o tempo de duração desses incidentes – sobretudo em razão do efeito suspensivo, que é natural aos eventuais recursos especial e extraordinário cabíveis – pode implicar paralisação por tempo exageradamente longo, frustrando qualquer expectativa de solução da controvérsia em tempo razoável. De outro, porque não há o que justifique a suspensão de todo o processo, apenas para que uma questão, referente só a parte da discussão, seja apreciada.

Desse modo, impõe-se que somente a parte da discussão, que pode ser diretamente afetada pela decisão do incidente, tenha seu curso suspenso. Quanto ao resto, é caso de julgamento total ou parcial do litígio (inclusive aplicando, no que for possível, o art. 356 do CPC), com eventual diferimento da decisão da questão afetada ao incidente à fase de liquidação.

A fortiori, essa é a solução se o incidente tratar apenas de questão de direito referente a um dos pedidos cumulados. Nada justificaria a paralisação da outra ação e o exame do outro pedido, apenas porque existe incidente de resolução de demandas repetitivas que interfere na análise do outro pedido.

Por outro lado, se essa modulação do efeito suspensivo é admitida, também se deve admitir modulações diversas, a depender do tipo de questão de direito envolvida. Suponha-se a afetação de questão processual ao incidente de resolução de demandas repetitivas. Essa questão, eventualmente, repercutirá em incontáveis processos de modo que, em princípio, alguém imaginará que todos eles devem ficar suspensos. Todavia, parece mais adequado concluir que o tribunal poderá “modular” o referido efeito suspensivo, por exemplo, para autorizar a tramitação dos processos envolvidos apenas em primeiro grau, ou para permitir que esses processos caminhem ao menos até a fase de instrução, ou que possam seguir até o julgamento definitivo, ficando sustada apenas a efetivação de eventual decisão de procedência.<sup>18</sup>

Enfim, não se deve tomar o efeito suspensivo aqui analisado como uma constante, sempre incidente da mesma forma sobre todos os casos.

Ao contrário, esse efeito suspensivo deve ser modelado, de forma a não conflitar com a garantia fundamental da tempestividade da jurisdição.

Recorde-se, ademais, que, segundo prevê o art. 982, § 3.º, do CPC, o efeito suspensivo pode ser ampliado para todo o território nacional, a fim de garantir a segurança jurídica, mediante pedido a ser formulado perante o tribunal competente para conhecer do eventual recurso especial ou extraordinário. O mesmo ocorrerá caso seja interposto recurso especial ou extraordinário da decisão do incidente, já que esses recursos, excepcionalmente aqui, têm efeito suspensivo atribuído por lei (art. 987, § 1.º, do CPC). Sob essas circunstâncias, parece ainda mais necessário que se dê ao Poder Judiciário a prerrogativa de modular o efeito suspensivo do incidente (ou dos eventuais recursos extraordinário e especial). Não se pode imaginar que todos os processos em que se discuta certa questão de direito devam necessariamente ficar suspensos até o trânsito em julgado da solução da questão, a ocorrer apenas depois de esgotados os recursos cabíveis contra a decisão de referida questão.

Ressalvados esses casos em que o órgão jurisdicional module o efeito suspensivo do incidente ou do recurso cabível, a paralisação dos processos a que alude o art. 982, I, do CPC e seu §3.º, vigorará até a preclusão da decisão sobre a questão de direito.

#### **14. Questões prejudiciais**

Outra causa de suspensão regulada pelo art. 313 do CPC diz respeito à pendência de questão prejudicial, cuja análise está sendo feita em outro processo (art. 313, V, a, do CPC). Afirma o Código que a suspensão se dá em razão de que a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica que constitui objeto principal de outro processo pendente. A hipótese repete, quase que literalmente, o que constava do art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil de 1973.

Propriamente, não se trata de causa de suspensão do processo, ao contrário do que faz supor o caput do art. 313 do CPC, mas apenas causa que impede a prolação de julgamento de mérito. De fato, como se vê do inc. V, do presente dispositivo, somente a “sentença de mérito” é que fica inviabilizada nesse caso, de modo que a tramitação do processo pode seguir sem nenhum obstáculo, sendo inaplicável aqui o contido no art. 314, do Código.

As questões prejudiciais, como se sabe, são relações jurídicas controvertidas no processo, cuja análise constitui pressuposto necessário para a análise do pedido principal. É o caso da existência e validade do contrato, na ação em que se exige seu cumprimento, ou da existência e da validade do casamento, na ação em que se busca o divórcio. Não se confundem com as questões preliminares, que são processuais e, por isso – ao contrário do que sucede com as questões prejudiciais – não podem constituir objeto de processo autônomo.

A doutrina costuma dividir as questões prejudiciais em internas e externas. Internas são aquelas examinadas pelo próprio juiz que analisará o pedido principal. Externas, ao contrário, são aquelas que pendem de exame por juízo diverso daquele em que fará a análise do pedido principal. As questões prejudiciais externas podem ainda ser subdivididas em homogêneas – ou seja, que podem ser examinadas por órgão da mesma competência do juízo do pedido principal, ou seja, inseridas na competência cível – ou heterogêneas – vale dizer, de competência criminal e, portanto, entregues a outra competência material.

O preceito em exame trata apenas das questões prejudiciais externas homogêneas. As questões prejudiciais externas heterogêneas são tratadas pelo art. 315 do CPC, enquanto as questões internas, por serem examinadas pelo próprio órgão a quem se atribuiu o exame do pedido principal, não implicarão a suspensão do processo, serão examinadas juntamente com o pleito principal e, eventualmente, submeter-se-ão ao regime de coisa julgada a que alude o art. 503 do CPC.

As questões prejudiciais externas homogêneas, para determinarem a suspensão do processo, devem ser objeto de outro processo já instaurado, como expressamente refere o dispositivo em

exame. Do contrário, não tendo essa outra ação sido proposta, não há a causa de suspensão.<sup>19</sup> Ademais, embora o Código afirme que essa questão principal deva ser “o objeto principal de outro processo pendente”, afirma Moniz de Aragão que

isso não quer dizer que seja o único objeto, pois a questão principal arguida em um processo pode prejudicar também a solução de outro e nem por ter sido alegada como prejudicial desautorizaria a suspensão deste último. Suponha-se o caso de uma sociedade, ao pretender receber contribuições sociais, ver-lhe oposta a questão incidental de sua inexistência; é evidente que em outro processo, de cuja solução a existência da sociedade seja um pressuposto, se fará necessária a suspensão, para aguardar o deslinde da declaratória incidental.<sup>20</sup>

Embora hoje não se fale mais em “declaratória incidental”, a advertência continua válida. Ainda que a relação jurídica não constitua propriamente o objeto principal da outra demanda, se lá ela for tratada como questão prejudicial, porque ali poderá ter incidência o art. 503 do CPC, com a coisa julgada também sobre essa questão prejudicial, a outra demanda haverá de aguardar a solução daquela primeira questão para o exame da controvérsia principal.

Vale dizer: porque o atual regime das questões prejudiciais é ou pode ser substancialmente o mesmo das questões principais – tendo ambos o potencial de resultar em declaração com força de coisa julgada, independentemente de nova ação sobre a questão prejudicial – então não há nenhum sentido na restrição posta no art. 313, V, a, do Código, em exigir, para a suspensão do processo, que a relação jurídica prejudicial seja “objeto principal de outro processo pendente”. Ainda que não constitua objeto principal desse outro processo, mas seja lá questão prejudicial, haverá peculiar hipótese de litispendência, a atrair a causa de suspensão em apreço.

Entende José Roberto dos Santos Bedaque que a causa de suspensão em razão da existência de questão prejudicial não implica regra cogente. Isso porque, segundo ele,

ainda que admissível, pode não ser conveniente a suspensão, especialmente se o processo em que se discute a questão prejudicial esteja ainda em fase inicial e o outro pronto para julgamento. Cabe ao juiz avaliar as circunstâncias e escolher pela solução mais adequada ao caso concreto, fundamentando-a. Às vezes, é preferível optar pela celeridade, mesmo havendo risco de contradição entre julgados.<sup>21</sup>

Ao que parece, porém, a solução do Código é outra. Segundo o art. 313, § 4.º, o prazo de suspensão do processo em razão da existência de questão prejudicial não pode exceder a um ano. Em razão disso, parece mais correto concluir que é obrigatória a suspensão do processo por prazo razoável para a solução da questão prejudicial no outro processo. Esse prazo razoável há de ser, no máximo, um ano, de modo que, ultrapassado o prazo fixado pelo juiz – ou, na sua ausência, o limite de um ano – deve o magistrado determinar o prosseguimento do processo incontinenti (art. 313, § 5.º, do CPC).

Durante o prazo fixado pelo juiz, porém, o processo deve ficar suspenso, exatamente porque, do contrário, corre-se o risco de gerar decisões conflitantes, “ambas com potencialidade de serem acobertadas pela coisa julgada”, em face do art. 503, do Código. Ademais, veja-se que essa é a sistemática dada pelo Código a outros casos semelhantes, a exemplo da cisão de competência operada pelo incidente de resolução de demandas repetitivas.

Por isso, parece que, durante o período de suspensão estipulado pelo juiz ou, não havendo a fixação desse prazo, pelo tempo máximo de um ano, “deve” o processo ser suspenso aguardando a solução da questão no outro processo.

Porém, e depois de ultimado o prazo, já que o risco de decisões conflitantes continua a existir, o que fazer?

Parece que a solução, então, será dar interpretação adequada ao art. 503, § 1.º, III, do CPC. Considerando que a mesma questão estará submetida a dois juízos diversos, em processos diferentes, há, como dito acima, hipótese peculiar de litispendência, a determinar que o único juízo realmente competente para o exame da causa (com força de coisa julgada) seja o prevento. Por isso, só a análise feita no primeiro processo distribuído a respeito da questão, poderá ter força de coisa julgada, nos termos do dispositivo acima mencionado. A eventual análise feita pelo outro

juízo, depois do prazo da suspensão, resultará em análise de simples questão incidente, sem autoridade de coisa julgada.

### **15. Verificação de fato ou produção de prova requisitada perante outro juízo**

Também ocorre a suspensão do processo em razão da dependência de verificação de fato ou de produção de certa prova, que tenha sido solicitada a outro juízo.

Como lembra Moniz de Aragão,

a ocorrência de fato tanto pode ser uma condição, a que esteja subordinada a relação jurídica, objeto principal ou secundário do processo, como a prática, por uma das partes, de ato que constitua contraprestação ou contrapartida de outro, o qual, posto exigível, não seja um dos requisitos da própria possibilidade jurídica do pedido, como seria o depósito preparatório da ação, por exemplo. <sup>22</sup>

Quanto à produção da prova, requisitada a outro juízo, trata-se aqui da situação descrita no art. 377 do CPC. <sup>23</sup> Ou seja, o juiz da causa pode solicitar a outro juízo a produção de certa prova, seja por meio de carta (precatória ou rogatória) ou ainda por auxílio direto. Nesse caso, deverá o juiz decidir o prazo para cumprimento da carta (art. 261 do CPC), atendendo às circunstâncias do caso e a facilidade da comunicação. O art. 377 afirma que as cartas podem ser expedidas “sem efeito suspensivo”, o que certamente constitui um minus em relação à fixação de prazo. Desse modo, além de o juiz poder fixar um prazo em que se aguardará o retorno da diligência (para a decisão da causa), também poderá simplesmente deixar a carta sem prazo específico, o que implicará concluir que o processo não será paralisado apesar da prova requisitada, de modo que a prova poderá ser juntada aos autos a qualquer momento em que a carta (ou o pedido de auxílio direto) retornar.

O prazo fixado pelo juiz, por certo, não paralisa o curso do processo. Como afirma o art. 377 do CPC, ele apenas impede a prolação de julgamento, de modo que a regra está evidentemente mal colocada no art. 313, do Código. Ou seja, o prazo para o cumprimento da carta ou do pedido de auxílio direto é um prazo durante o qual a prolação de sentença não será admitida sem o retorno da prova. Outros atos processuais, porém, poderão ser livremente realizados, não se aplicando por óbvio o contido no art. 314 do CPC.

Ademais, o sobrestamento do “julgamento” pelo prazo da carta (ou do pedido de auxílio) depende da conjugação de dois elementos: a) a prova ter sido requerida antes do saneamento do processo e b) ser a prova imprescindível. Assim, somente em relação a afirmações de fatos apresentadas em seu momento regular – fase postulatória – é que estão abrangidas por essa regra. Isso se dá exatamente por força do princípio da celeridade, que desaconselha a paralisação do processo em estágio avançado, apenas porque há provas solicitadas a outro juízo que precisam ser produzidas. De outro lado, exige-se que a prova seja imprescindível, vale dizer, que o fato a que se refere a prova seja determinante para a solução da controvérsia.

Presentes essas duas condições, o julgamento de mérito aguardará o retorno da carta (ou do pedido de auxílio) pelo período deferido pelo juiz. Findo esse prazo, a sentença poderá ser proferida independentemente da prova, que poderá ser juntada ulteriormente no processo para análise em outra instância. Terminado o prazo antes do retorno da prova, poderá eventualmente caber ação rescisória para a desconstituição do julgamento, com base no que prevê o art. 966, VII, do CPC.

Enfim, pendendo a verificação desse fato ou a produção da prova, nesses casos, deve o processo ficar suspenso, ainda que o período de paralisação não possa superar o máximo legal, que é de um ano (art. 313, § 4.º, do CPC). Ou seja, o prazo fixado pelo juiz para o cumprimento da carta (ou do pedido de auxílio) nunca poderá exceder a um ano, sendo ineficaz qualquer termo superior a esse teto. <sup>24</sup>

### **16. Força maior**

A presença de causa que inviabiliza o curso regular do processo, seja natural (v.g., inundação



ou desmoronamento do foro) ou humana (v.g., greve no serviço judiciário), deve ensejar a paralisação do curso do processo. Aqui, a causa de suspensão é antes uma questão de impossibilidade material no prosseguimento das atividades processuais e, portanto, só nesse limite deve implicar a suspensão do processo.

Por outras palavras, razões naturais ou humanas que dificultem o andamento normal do processo, mas não o inviabilizem, não atraem a incidência do art. 313, VI, do CPC. Havendo alternativas viáveis e sendo possível o prosseguimento do feito – ainda que dificultado por alguma razão – violaria a garantia da duração razoável do processo a sua paralisação.

A causa de suspensão em exame difere da previsão contida no art. 221 do CPC. Neste dispositivo, há circunstância que impede a prática de determinado ato pela parte; no art. 313, ao contrário, há causa que inviabiliza a prática de qualquer ato do processo e, por isso, importa a sua paralisação como um todo.<sup>25</sup> Para a suspensão do processo, por força maior, então, deve haver razão que transcenda os limites de uma parte determinada, atingindo todo o processo e seus sujeitos.

## 17. Decisões de Tribunal Marítimo

O projeto de Código de Processo Civil de 2015 dava prestígio jurisdicional aos atos do Tribunal Marítimo. Essa intenção, porém, não teve a chancela do Poder Executivo, que vetou essa configuração justamente por equiparar à atividade jurisdicional ato tipicamente administrativo,<sup>26</sup> realizado por órgão criado para auxiliar o Poder Judiciário na análise de questões marítimas.

Com efeito, o dito Tribunal Marítimo, criado pela Lei 2.180/1954, é claramente definido como

órgão, autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Ministério da Marinha no que se refere ao provimento de pessoal militar e de recursos orçamentários para pessoal e material destinados ao seu funcionamento, tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões relacionadas com tal atividade, especificadas nesta Lei (art. 1.º da Lei 2.180/1954).

Seu papel é claramente auxiliar, exercendo função investigativa de fatos de navegação, com atividade semelhante àquela prestada pela prova pericial.<sup>27</sup> Trata-se, em verdade, de prova pericial qualificada, porque realizada por agentes com especial conhecimento técnico sobre a matéria, à luz de amplo contraditório, e prestada por órgão administrativo de notória especialização e que tem função preventiva e regulatória das atividades de navegação (arts. 13 e 16, da Lei 2.180/1954).

Apesar disso, pela consistência das informações a serem prestadas por esse órgão, sua oitiva em processos que envolvam acidentes e fatos da navegação é imprescindível. A rigor, portanto, não se está aqui diante de causa de “suspensão do processo”. Antes se trata de mais um caso (semelhante às hipóteses do art. 313, V, do CPC), em que a prolação de sentença de mérito fica dependente da constituição dessa prova especial, que é o julgamento do Tribunal Marítimo.

Assim, havendo discussão judicial que envolva acidentes e fatos da navegação, a suspensão do processo (ou melhor, a vedação de julgamento) é obrigatória, já que, nos termos do art. 19, da Lei 2.180/1954,

sempre que se discutir em juízo uma questão decorrente de matéria da competência do Tribunal Marítimo, cuja parte técnica ou técnico-administrativa couber nas suas atribuições, deverá ser juntada aos autos a sua decisão definitiva.<sup>28</sup>

Ou seja, embora o Judiciário possa “relativizar” o valor probatório da decisão proferida pelo Tribunal Marítimo, dando a ele o valor que entender adequado, é imprescindível que seja juntada aos autos a decisão definitiva deste órgão para subsidiar o exame judicial da causa. Sem essa decisão administrativa, portanto, o processo judicial não pode ser julgado, em que pese a independência das instâncias judicial e administrativa conduzir à conclusão da não vinculatividade da decisão deste órgão sobre a esfera jurisdicional.

Porque a lei impõe, como visto, a juntada da decisão definitiva do Tribunal Marítimo no



processo judicial, não há prazo para essa causa de “suspensão” do processo. O pronunciamento judicial de mérito deve aguardar até a juntada da decisão administrativa “definitiva”.

## **18. Outros casos**

As hipóteses descritas no art. 313, do CPC, não são as únicas que determinam a paralisação do processo ou que impedem o julgamento de mérito. Deixa-o claro o inc. VIII, do artigo em apreço.

Constituem outros casos de suspensão obrigatória do processo, por exemplo, a interposição de recurso especial ou extraordinário tido como repetitivo (art. 1.036, § 1.º, do CPC), a instauração do incidente de desconconsideração de personalidade jurídica (art. 134, § 3.º, do CPC) e, na execução, a inexistência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC). De outra parte, há também outros fatos que impedem que a sentença de mérito seja proferida, a exemplo da existência de questão prejudicial externa heterogênea (art. 315 do CPC).

O que parece fundamental é apenas recordar que esses outros casos, embora não arrolados no art. 313 do CPC, submetem-se também em princípio ao regime das hipóteses descritas neste artigo. Por isso, “em regra”, não se admite que, suspenso o processo, mesmo por outra causa, seja possível a prática de ato processual regular.

## **19. Prazo de suspensão**

A lei atual, à semelhança do que fazia o Código de Processo Civil de 1973, não regula o prazo de suspensão para todas as hipóteses descritas no Código. Fá-lo apenas em relação aos casos da suspensão convencional e da suspensão por questão prejudicial.

Assim ocorre porque, em relação aos outros casos, o prazo de duração da suspensão é incerto e depende da solução das questões que originam a paralisação do feito. Especificamente no que se refere à pendência da verificação de questões de acidentes e fatos da navegação (art. 313, VII, do CPC), havia no projeto de Código previsão que limitava em um ano o período de suspensão. A proposta, porém, não vingou, de modo que, também para esse caso, a paralisação dura até a decisão definitiva do Tribunal Marítimo a ser juntado no processo.

## **20. Suspensão do processo em razão da paternidade ou da maternidade**

A Lei 13.363/16 acrescentou ainda duas outras hipóteses de suspensão do processo: a maternidade e a paternidade do advogado que constitua o *único patrono* da causa. Para a incidência da regra contida no inc. IX, é necessário que a advogada tenha dado à luz ou adotado criança, sendo a única advogada da parte. E para que ocorra a causa prevista no inc. X, será necessário que o advogado da parte tenha-se tornado pai – por qualquer causa que seja – também sendo o único patrono constituído ou dativo.

Conforme estabelece o § 6º, do art. 313, o período de suspensão do processo para a mãe-advogada é de trinta dias, contados do nascimento ou da adoção, sendo necessária a apresentação de documento que comprove a maternidade e a prévia notificação do cliente. Para o pai, nos termos do que prevê o § 7º, impõe-se a suspensão do processo pelo prazo de oito dias, a contar do parto ou da concessão da adoção, também se exigindo a prova da assunção da paternidade, bem como a prévia notificação ao cliente.

O prazo de suspensão conta-se em dias úteis, por tratar-se de prazo processual (art. 219). Por outro lado, embora o código aluda a “único(a) patrono(a) da causa”, é evidente que a alusão deve ser lida como único(a) patrono(a) do sujeito processual. A regra, portanto, aplica-se ao advogado-pai ou à advogada-mãe que seja único(a) patrono(a) de litisconsorte ou de terceiro interveniente (admitido) que atue no processo representando, de forma exclusiva, seu cliente.

A regra tem por finalidade proteger os interesses do filho (recém-nascido ou adotado) e da família, permitindo que os pais possam conviver com a criança, tal como ocorre a licença concedida a empregado público ou não. Trata-se, portanto, de homenagem ao interesse público e social na preservação do convívio familiar nesse momento inaugural.

Em todos os casos, como já se disse, para que o(a) advogado(a) possa valer-se da prerrogativa em questão, requerendo a suspensão do processo, é imprescindível que tenha comunicado previamente seu cliente, até para que este possa, à vista das circunstâncias do caso, contratar outro profissional para atuar provisória ou definitivamente no feito, caso em que, por evidente, não haverá a suspensão em debate.

**Art. 314.** Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

### **1. Duração da suspensão e vedação da prática de atos**

O preceito em exame regula quais atos processuais são vedados durante o período de suspensão. Como esclarece o dispositivo, “todos os atos processuais”, a exceção daqueles tidos como urgentes e destinados a impedir dano irreparável, têm sua prática vedada.

Em regra, a vedação legal não significa, de fato, a proibição da prática do ato. Ao contrário, significa apenas que esses atos são “ineficazes”, de forma que não produzem qualquer efeito se realizados durante o período de suspensão. Não há sentido em supor como nula a juntada de petição da parte, requerendo medida “não urgente”. Também não se pode imaginar como nulo requerimento de terceiro para ingresso no feito ou mesmo pedido das partes de convenção processual, realizada durante período de suspensão. Tampouco há razão para concluir que seja nula a juntada feita pela secretaria ou pelo cartório de ato nos autos do processo.

É verdade que, diante da morte da parte, a procuração concedida ao advogado fica automaticamente sem efeito. Daí se pode supor que os atos praticados pelo advogado, após a morte da parte, transbordem qualquer poder de representação. Todavia, na vigência do Código anterior, autorizava a lei que, mesmo diante do falecimento da parte, pudesse o seu advogado constituído prosseguir excepcionalmente atuando (art. 265, § 1.º, in fine, do CPC/1973). Dizia-se que agia ali em condição assemelhada a do gestor de negócio. Ainda que se possa discutir a condição em que o advogado prosseguia no processo, fato é que não se qualificava como nulo o ato praticado pelo advogado naquela circunstância, cabendo eventualmente apenas à ratificação dos atos praticados por procuração outorgada pelos sucessores. Não há razão para ser diferente no modelo atual. Os atos praticados pelo advogado nessas circunstâncias – diante, por exemplo, do não conhecimento do óbito da parte – devem ser tidos como válidos, mas ineficazes, podendo ser ratificados posteriormente (diante da correção da capacidade postulatória) para que possam produzir efeitos.

Quanto aos atos do juiz, despachos de mero expediente – mesmo porque sequer podem causar prejuízo à parte e, assim, sequer passariam pela exigência posta pelo art. 282, § 1.º, do CPC – também não poderiam ser qualificados como nulos.

Desse modo, somente os atos efetivamente decisórios, eventualmente praticados no curso de período de suspensão, é que se poderiam cogitar nulos. Porém, até mesmo essa nulidade só vai atingir os atos decisórios que tenham dependência com a causa de suspensão, de modo que os outros, eventualmente praticados, serão também tidos como ineficazes.<sup>29</sup>

Assim, por exemplo, a sentença proferida durante o período de suspensão motivada pela pendência de questão prejudicial deve ser tida como nula “se a decisão da questão prejudicial poderia influenciar a solução da controvérsia”. Do contrário, será tida apenas como ineficaz durante o prazo de suspensão, adquirindo força depois desse período.

Identicamente, supondo a prolação de sentença no período entre a morte da parte e a habilitação dos sucessores – supondo que a questão não tenha sido levada a juízo antes da decisão – depois de já encerrada a instrução do feito, não há razão para a decretação de nulidade do ato judicial. A sentença será válida e eficaz após a habilitação dos herdeiros, sem necessidade de renovação do ato.

### **2. Termo inicial da suspensão**

Em regra, o período de suspensão independe da prévia decisão judicial. A decisão, aqui, é simplesmente declaratória da ocorrência do fato que opera a paralisação do feito, não sendo em sua virtude que ocorre essa suspensão. Assim, é o falecimento da parte, a força maior ou a convenção das partes que determina a suspensão do processo e não o futuro ato judicial que reconhece a necessidade de interromper o curso do processo.<sup>30</sup>

Excepcionalmente, porém, a decisão passa a ter função “constitutiva” da suspensão. Tal é o que ocorre com as hipóteses do inc. V, do art. 313, do CPC, em que o magistrado, reconhecendo a pendência de questão prejudicial, paralisa o processo por seu ato, para aguardar a solução da controvérsia.<sup>31</sup>

Finalmente, veja-se que as hipóteses que autorizam a paralisação do processo fora do rol do art. 313 (art. 313, VIII, do CPC) dependerão da avaliação de cada um dos casos, já que poderá haver situações que dependerão da manifestação judicial, enquanto em outros a suspensão será automática, decorrendo da simples ocorrência do fato legal.

### **3. Termo final da suspensão**

Talvez o termo final da suspensão ponha mais dificuldade, na medida em que este variará conforme a hipótese de paralisação. De fato, não há solução homogênea para a questão, embora a maior parte dos casos previstos no Código já indique também o momento em que o processo retomará seu curso.

Assim, segundo o art. 313, § 2.º, do CPC, diante da morte das partes, a suspensão durará até a habilitação dos sucessores ou, no caso do réu, pelo prazo máximo de seis meses, e, no caso do autor, pelo prazo determinado pelo juiz. Falecendo o advogado da parte, a suspensão durará até a constituição do novo patrono ou, eventualmente, até o fim do prazo máximo de quinze dias, fixado pelo art. 313, § 3.º, do CPC.

Em se tratando de suspensão por convenção das partes, o termo final será aquele indicado pelas partes ou, não havendo essa fixação ou sendo ela superior ao máximo legal, o final dos seis meses a que se refere o art. 313, § 4.º, do CPC.

Havendo arguição de suspeição ou impedimento do juiz, a paralisação durará até a decisão “primeira” do incidente. Por outras palavras, se, diante da arguição, o juiz se reconhecer parcial, a suspensão durará até que o processo chegue às mãos do substituto legal. Não reconhecido o defeito, a decisão da questão competirá apenas ao tribunal, razão pela qual só depois dessa decisão, com o retorno dos autos ao juiz original ou a remessa ao substituto legal, terá seguimento o processo. Note-se que pode, eventualmente, haver recurso dessa decisão do tribunal; isso, porém, não determina a manutenção da suspensão do processo, mesmo porque eventuais recursos aí cabíveis não têm efeito suspensivo (art. 995 do CPC).

A suspensão em razão da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas vigorará, em princípio, até a decisão do incidente. Afirma o art. 985, I, do CPC que, julgado o incidente, deve a tese ser aplicada a todos os processos em curso na esfera de competência territorial do tribunal prolator da decisão. Todavia, recorde-se que dessa decisão (do incidente) pode caber recurso especial e/ou extraordinário. Esses recursos são dotados, por lei, de efeito suspensivo (art. 987, § 1.º, do CPC), de modo que, interpostos esses recursos, a suspensão dos processos em que se discute a questão de direito perdurará até o seu julgamento.<sup>32</sup> Concluído esse julgamento, a tese fixada deverá ser aplicada a todos os processos presentes e futuros existentes no território nacional, ao menos até que sobrevenha eventual revisão do entendimento (art. 987, § 2.º, do CPC), o que implica dizer que, até essa decisão, os processos ficarão sobrestados. Sublinhe-se, por fim, que a eventual interposição contra estas decisões de embargos de declaração não implica, ipso facto, obstáculo ao prosseguimento do processo. Somente se for deferido eventual efeito suspensivo a esse recurso (art. 1.026, § 1.º, do CPC) é que a paralisação dos processos em que a questão de direito é discutida se mantém, até a decisão desse novo recurso.

Quanto à hipótese descrita no art. 313, V, a, do CPC, (questão prejudicial externa), a duração da

suspensão tem prazo máximo de um ano (art. 313, § 4.º, do CPC). Se, porém, houver julgamento definitivo da questão prejudicial em prazo menor do que esse, o processo seguirá a partir de então.

No caso da verificação de fato ou da produção da prova, a duração da paralisação será aquela determinada pelo juiz na decisão que requisita a colheita da prova ou a verificação do fato, sempre tendo por prazo máximo o de um ano (art. 313, § 4.º, do CPC). Trazida a prova ou verificado o fato em tempo menor, porém, não há mais sentido em manter a suspensão.

No caso da força maior, a suspensão deve durar enquanto existir o motivo.

Por fim, na hipótese de acidente e fato de navegação, o óbice à prolação de sentença de mérito durará até que seja trazida aos autos a decisão administrativa definitiva do Tribunal Marítimo.

#### **4. Medidas de urgência**

Embora a regra seja a vedação a que se pratique atos processuais na pendência de causa de suspensão, a lei abre exceção. Permite que se pratique, durante o período de suspensão, ato urgente que objetive evitar dano irreparável.

Não se deve confundir a prática dos atos urgentes a que alude o art. 314, do CPC, com as tutelas provisórias de que tratam o art. 294 e ss., do CPC.

De um lado, porque nem todas as tutelas provisórias são fundadas em urgência, nem visam a evitar a ocorrência de dano irreparável.

De outra, porque há medidas urgentes, previstas no Código, mas que não são tratadas como tutelas provisórias. É o que sucede, por exemplo, com a assecuração de prova, descrita nos arts. 381 a 383 do CPC.

Esses atos referentes à constituição de prova, certamente, poderão impedir dano irreparável, podendo ser realizados durante o período de suspensão.

Isso implica dizer que o dano irreparável a que alude o texto legal não é apenas o dano “ao direito ou ao interesse” que constitui objeto do processo. Também o dano irreparável ao processo se enquadra na exceção legal e, por isso, permite a prática de atos tendentes a evitar que ocorra.

Também por essa razão, ingressa como medida urgente que pode ser adotada na pendência do processo a figura do “atentado”, disciplinada pelo art. 77, VI, do CPC. Como é evidente, verificada a inovação artificiosa no curso do processo, cabe a atuação imediata do juiz, com a adoção das providências indicadas pelo art. 77, § 7.º, do CPC, ainda que suspenso o processo.

Enfim, qualquer medida que possa ser considerada como necessária para evitar a ocorrência de dano irreparável, seja ao objeto do processo, seja ao próprio processo, pode e deve ser realizada mesmo no período de suspensão.

#### **5. Competência para os atos urgentes**

Verificando a necessidade de adoção de medidas urgentes, na forma prevista pelo art. 314 do CPC, é necessário saber a quem se recorrerá para essas providências.

Alguns casos têm previsão expressa na lei processual.

Assim, nos termos do art. 982 § 2.º, do CPC, que se refere à suspensão por admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, no período de suspensão “o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso”.

Já no caso de suspensão determinada pela instauração de arguição de impedimento ou suspeição, determina a lei que qualquer providência urgente seja solicitada ao substituto legal do juiz arguido (art. 146, § 3.º, do CPC), salvo quando o incidente seja instaurado sem efeito suspensivo. Como afirma Bedaque,

essa ressalva não constava da legislação anterior, mas é plenamente justificável, visto que, questionada a imparcialidade do julgador, não deve ele praticar nenhum ato no processo, mormente os de natureza urgente, dos quais podem resultar sérios danos à parte.<sup>33</sup>

É nesse sentido que se deve interpretar a parte final do art. 314, quando faz a ressalva à arguição de suspeição e impedimento. Nesse caso, na verdade, não é que não cabia a realização de atos urgentes; o que ocorre é que a análise a respeito do pedido dessas medidas não competirá, em regra, ao juiz da causa, mas sim ao substituto legal. Quando, porém, ausente o efeito suspensivo, então, a despeito do que diz aquela exceção, caberá ao próprio juiz arguido a análise das ditas medidas urgentes.

Nos demais casos de suspensão do processo, considerando que, mesmo com o processo suspenso, o juiz da causa não perde sua competência sobre o caso, é ele quem deve decidir sobre eventuais medidas urgentes a serem praticadas.

**Art. 315.** Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.

§ 1.º Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia.

§ 2.º Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1.º.

## **1. Independência das instâncias cível e criminal**

Sabe-se que, em regra, as instâncias cível e criminal são independentes, de modo que o julgamento proferido em uma não repercute na outra.

Isso se dá, normalmente, porque os pressupostos avaliados em cada uma dessas esferas são distintos, de forma que o julgamento proferido em uma instância não deve produzir resultados obrigatórios na outra. Nessa linha, por exemplo, é categórico o art. 148 do CPP, a dizer que, em relação ao incidente de falsidade documental processado no juízo criminal, “qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil”.

Essa regra, porém, comporta exceções, já que a lei brasileira contempla vários exemplos em que o julgamento criminal dispensa outra análise no campo cível, produzindo seus efeitos também nesta esfera. É o que ocorre, por exemplo, com a condenação criminal transitada em julgado, que constitui título executivo cível (art. 515, VI, do CPC e art. 63 do CPP), ou ainda com a previsão do art. 65 do CPP, a afirmar que “faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”. Da mesma forma, na linha do que prevê o art. 66 do CPP, observa-se que o reconhecimento da inexistência do fato na esfera criminal também gera efeitos no campo cível, inviabilizando a propositura da ação civil. Constitui outro exemplo desses efeitos reflexos a regra contida no art. 387, IV, do CPP, que impõe ao juiz criminal, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para a reparação dos danos eventualmente causados pelo ato infracional, à luz dos prejuízos sofridos pelo ofendido.

Por outro lado, também a lei processual penal estabelece a necessidade de aguardar a definição de questão sobre o estado da pessoa para dar seguimento à ação penal (art. 92 do CPP).

Não obstante esses casos de vinculação das esferas, é certo que, mesmo nos outros casos, não é conveniente que convivam soluções conflitantes para idêntica questão. Seria injustificável do ponto de vista lógico – e mesmo em termos de seriedade da prestação jurisdicional – que se admitisse como aceitável que dois juizes, apenas porque têm competência diversa, pudessem considerar um mesmo fato com colorações diversas.

Por isso, tanto o Código de Processo Civil, no dispositivo em exame, como a lei processual penal,<sup>34</sup> estabelecem preceitos que tendem a homogeneizar a solução de questões comuns, criando regime de prejudicialidade externa, com a “possível” paralisação do processo no aguardo da

solução dada pela outra esfera.

Essas regras, como é evidente, não têm incidência “cogente”, no sentido de tornar obrigatória a suspensão do processo.

São, ao contrário, regras de “conveniência” que, em prol de uma solução uniforme para a mesma questão, “autorizam” que um juízo aguarde pela solução dada pelo outro na definição do tema.

## 2. Questão prejudicial externa

O dispositivo em apreço constitui situação particular da hipótese tratada pelo art. 313, V, a, do CPC. Como se disse no tópico anterior, também aqui se discute a existência de questão prejudicial, cuja solução pode influir no julgamento do litígio. Porém, neste caso, há concorrência entre juízo cível e criminal, que examinam a mesma questão. Daí a razão pela qual a doutrina chama essa hipótese de questão prejudicial “externa”, já que aqui a competência dos órgãos envolvidos na análise do tema é diversa.

O preceito repete, em linhas gerais, o contido no art. 110, do Código de Processo Civil de 1973, embora o faça de forma mais ampla e em local mais adequado. Enquanto o tema, no Código anterior, era tratado na disciplina da competência, a lei atual examina a matéria junto às outras causas de suspensão do curso do processo.<sup>35</sup>

Da leitura do dispositivo, pode-se concluir que aqui se trata de causa de suspensão “facultativa”. Vale dizer: o juiz cível não é obrigado a paralisar o andamento do processo civil, aguardando que se pronuncie o juízo criminal. Trata-se, como dito antes, de juízo de conveniência, que tende a evitar que ocorram decisões conflitantes, que desprestigiam a autoridade jurisdicional.<sup>36</sup> A conclusão de que aqui se tem mera razão de conveniência vem respaldada na parte final do art. 315, § 1.º, do CPC, que afirma que, não cumpridos os prazos indicados na lei, caberá ao juiz cível analisar incidentemente a questão prejudicial. Ora, se o juiz cível, por expressa previsão legal, tem autorização para conhecer (ainda que de forma incidental) da questão prejudicial externa, é porque a sua vinculação à decisão criminal não é absoluta.<sup>37</sup>

Entendendo o juiz pela utilidade e conveniência na suspensão da ação civil, isso pode dar-se quando ainda não proposta a ação penal, ou quando esta já tiver sido instaurada.

No primeiro caso, incide o contido no art. 315, § 1.º, do CPC. Assim, o processo civil será suspenso pelo prazo de três meses,<sup>38</sup> aguardando que se ajuíze a ação criminal. Diz o Código que esse prazo de três meses é contado a partir da “intimação do ato de suspensão”; porém, não diz a quem se destina essa intimação. Na vigência do código anterior, Hélio Tornaghi já criticava preceito idêntico do Código de Processo Civil de 1973, que não apontava a quem se destinava a comunicação.<sup>39</sup> De fato, como regra, a ação penal será ajuizada por sujeito distinto daquele que atua na demanda cível. Logo, será certamente inútil a intimação da parte cível a respeito do prazo de suspensão. Por outro lado, também não há muito sentido na intimação dirigida ao Ministério Público, como se isso pudesse compeli-lo a propor desde logo a ação criminal.

À vista disso, parece correto concluir que a intimação a que se refere o art. 315, § 1.º, do CPC, é destinada à parte, por três razões. Em primeiro lugar, porque, caso a suspensão se dê no aguardo do ajuizamento de ação penal privada, caberá à parte promover a medida em que a questão prejudicial será examinada na esfera criminal. Em segundo lugar, mesmo que não se trate da hipótese acima mencionada, a parte da ação civil tem o direito de saber que seu processo foi suspenso, da causa que gerou essa paralisação e do tempo que aguardará para o prosseguimento de seu feito, até para que, querendo, possa insurgir-se contra essa determinação. Em terceiro lugar, porque – à semelhança do que prevê o art. 93, § 3.º, do CPP – a intimação para a parte possibilita que ela possa habilitar-se como assistente na esfera criminal, agilizando o andamento da ação penal e a solução da questão prejudicial (art. 268 e ss., do CPP) ou até mesmo propor a ação penal privada subsidiária, diante da omissão injustificável do Ministério Público (art. 29 do CPP).

Feita a intimação e não ajuizada a ação penal no prazo de três meses, deve a ação civil prosseguir, conferindo-se ao juízo cível plena atribuição para examinar a questão prejudicial externa, “ainda que de forma incidental”. Embora o Código não o diga – e nem seja preciso nesse aspecto – o termo “incidentemente” empregado pelo art. 315, § 1.º, do CPC tem significado específico. Não pretende apenas dizer que o juiz cível poderá examinar a questão como incidental. Mais do que isso, pretende afirmar que a solução dessa questão prejudicial “não fará coisa julgada na esfera cível”, não tendo aqui incidência o disposto no art. 503, § 1.º, do CPC. De fato, embora se autorize excepcionalmente aí que o juiz cível examine a questão, é certo que ele não tem competência para apreciar a questão como principal; por isso, falta o requisito exposto pelo art. 503, § 1.º, III, do CPC, inviabilizando a formação de coisa julgada sobre a análise feita pelo juízo cível sobre a questão criminal.

Se a ação penal for ajuizada no prazo legal – ou se já havia sido ajuizada anteriormente – o processo civil deve, em princípio, ficar sobrestado, pelo prazo “máximo” de um ano,<sup>40</sup> aguardando a solução da questão na esfera criminal. A lei expressamente consigna que esse é o prazo máximo, o que significa que o juiz cível pode abreviar o período de suspensão, se entender que a ação penal tem tramitação excessivamente demorada.<sup>41</sup>

Findo o prazo de um ano sem solução da questão prejudicial na esfera criminal – ou entendendo o juízo cível que não se justifica mais aguardar a solução do juízo criminal – dará seguimento ao processo, passando a examinar sem autoridade de coisa julgada, a questão prejudicial externa (art. 315, § 2.º, do CPC).

---

## NOTAS DE RODAPÉ

---

1

Houve no passado, até mesmo, quem distinguisse a suspensão, a interrupção e o repouso da relação processual (v. Hélio Tornaghi, Comentários, ob. cit. p. 313).

2

Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, Trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires: UTEHA, 1944, vol. IV, p. 489.

3

Enrico Tullio Liebman, Manuele di diritto processuale civile, 4ª ed., rist. Milano: Giuffrè, 1984, vol. II, p. 195.

4

Egas Dirceu Moniz de Aragão, Comentários, ob. cit., p. 347.

5

É verdade que há processos, como a interdição (art. 751 do CPC) ou a arrecadação de bens de ausentes, em que um dos sujeitos não tem capacidade e, ainda assim, participa ativamente do processo, sem invalidade. São, porém, casos excepcionais, que devem ser tratados como situações peculiares, existentes em razão de



particularidades da relação material envolvida.

---

6

Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários*, ob. cit., p. 349; Hélio Tornaghi, *Comentários*, ob. cit., p. 314.

---

7

Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários*, ob. cit., p. 350.

---

8

Serão requeridos na habilitação os sucessores, quando o pedido for formulado pela parte contrária ou a própria parte contrária, quando o pedido for feito pelos sucessores.

---

9

Nessa linha, v. Gerson Fischmann, *Comentários ao código de processo civil*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 300; Hamilton de Moraes e Barros, *Comentários ao código de processo civil*, Rio de Janeiro: Forense, p. 336.

---

10

Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários*, ob. cit., p. 354.

---

11

Note-se que o prazo mencionado é para a manifestação do espólio, dos herdeiros ou dos sucessores. Outro será, porém, o prazo para a habilitação, caso haja manifestação positiva no sentido de prosseguir na causa.

---

12

Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários*, ob. cit., p. 354.

---

13

Nessa linha, é expresso o art. 296, do CPC italiano, que exige o pedido “de todas as partes”.

---

14

Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários*, ob. cit., p. 355.

---

15

É a orientação da jurisprudência, que concluiu que, embora seja possível o pedido de suspensão no curso de prazo peremptório, não haverá a suspensão do prazo, de modo que “deve a parte apresentar o ato

processual pertinente, sob pena de preclusão. Depois da apresentação ou após o transcurso do prazo, o processo será suspenso” (REsp 596.628/RJ, 5.a Turma, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, DJU 09.05.2005, p. 458).

---

16

REsp 617.722/MG, 1.<sup>a</sup> Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJU 29.11.2004, p. 247.

---

17

Enquanto pende essa análise ou se deferido o efeito suspensivo no tribunal, eventual pedido de tutela de urgência deve ser requerido sempre ao substituto legal do juiz arguido (art. 146, § 3.º, do CPC).

---

18

*Mutatis mutandis*, essa foi a solução dada, por exemplo, pelo Superior Tribunal de Justiça ao afetar ao regime de recursos repetitivos a questão do rol (taxativo ou exemplificativo) do art. 1.015, do CPC, sem porém suspender o curso dos agravos em curso ou a serem interpostos (STJ, ProAfR no Recurso Especial 1.704.520/MT. Rel. Min. Nancy Andrighi. *DJe* 28.02.18). No caso, concluiu a relatora, após ponderações feitas pelo Min. Luis Felipe Salomão, que “tendo em vista que a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não previstas expressamente nos incisos do art. 1.015 do CPC/15 pode estar relacionada a questões de natureza urgente e considerando que o exame antecipado dessas matérias não traz prejuízos às partes ou ao curso do processo, reconsidero minha anterior manifestação a respeito da abrangência da suspensão, para entender desnecessária a paralisação dos recursos de agravo de instrumento ou dos eventuais recursos especiais interpostos dos acórdãos que os apreciaram”. Essa flexibilidade, sem dúvida, também incide na suspensão decorrente da instauração de IRDR. Cumpre ao relator, admitido o incidente, esclarecer se haverá a suspensão de que trata o art. 982, I, e, em caso positivo, a sua extensão, sempre tendo em conta o eventual prejuízo decorrente dessa paralisação e a expectativa de demora no julgamento do incidente.

---

19

Assim, tb. Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários...* ob. cit., p. 360.

---

20

Idem, *ibidem*.

---

21

José Roberto dos Santos Bedaque, *Comentários ao novo código de processo civil*. Coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 496.

---

22

Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários...* ob. cit., p. 357.

---

“Art. 377. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no art. 313, inciso V, alínea “b”, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento”.

Adroaldo Furtado Fabrício entende, contrariamente ao que sustentado no texto, que é possível ampliar o prazo em comento, “se a mora é imputável ao serviço judiciário” (“Suspensão do processo”. *Código de processo civil anotado*. Coord. José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho Aprigliano, Rogéria Fagundes Dotti, Sandro Gilbert Martins. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2016, p. 466). Embora razoável a justificação, não parece correta a conclusão. É que o legislador, sem dúvida, quando fixou o prazo de suspensão em apreço, sem dúvida já considerou que grande parte da demora é imputável ao Judiciário, já que é ele quem deve produzir a prova. Logo, não parece o argumento justifique a ampliação do prazo.

Assim também é a lição de Pontes de Miranda, que afirma que “Desde que atos, e não só um ato, não possam ser praticados, por força maior, em vez da figura da instância continuada, a despeito dessas falhas ocasionais, que se compensam pela realização posterior, quando as partes o requererem, fundamentado por que o fazem, a lei lançou mão de outra imagem, que se acomodasse à força maior ofendente do processo: a suspensão do processo por força maior” (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao código de processo civil*, 3. ed. atual; Sérgio Bermudes, Rio de Janeiro: Forense, 1996, tomo III, p. 448.

Assim, por exemplo, ocorreu com o art. 515, X, do CPC, que dava status de título judicial às decisões do Tribunal Marítimo.

Afirma o art. 18, da Lei 2.180/1954 que “As decisões do Tribunal Marítimo quanto à matéria técnica referente aos acidentes e fatos da navegação têm valor probatório e se presumem certas, sendo porém suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário”.

Contra, entendendo ser facultativa a suspensão nesses casos, v. José Roberto dos Santos Bedaque, ob. cit., p. 497.

Em sentido diverso, qualificando como “inexistente” o ato praticado durante o período de suspensão, v. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários...* ob. cit., p. 460; Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários...* ob. cit., p. 368; Hélio Tornaghi, *Comentários...* ob. cit., p. 323.

---

30

Calha salientar que a hipótese de suspensão do processo em razão da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas “não depende de decisão do juiz da causa”. Dependerá, é claro, de decisão do relator do incidente (art. 982, I, do CPC), mas certamente não há a necessidade de que o juiz da causa “concorde” com aquela determinação. A decisão do juiz da causa, aqui, é meramente declaratória de que o caso discute a “questão de direito” que está afetada ao julgamento coletivo a ser operado pelo incidente.

---

31

Hélio Tornaghi, *Comentários...*, ob. cit., p. 321; Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários...*, ob. cit., p. 365-367.

---

32

Recorde-se, como se viu nos comentários ao artigo anterior, que o efeito suspensivo decorrente da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser modulado, de forma a amainar as consequências da paralisação por tempo excessivo de todos os processos em que a questão de direito seja posta.

---

33

José Roberto dos Santos Bedaque, ob. cit., p. 499.

---

34

“Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. § 1.º O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. § 2.º Do despacho que denegar a suspensão não caberá recurso. § 3.º Suspenso o processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento.”

---

35

Atendeu-se aí à crítica de Celso Barbi, que há muito reclamava da colocação do dispositivo do Código de Processo Civil de 1973 no regime da competência e não no da suspensão do processo (Celso Agrícola Barbi,

36

Nesse mesmo sentido, v. Celso Agrícola Barbi, ob. cit., p. 478; Antonio Dall'agnol, Comentários ao código de processo civil, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2007, vol. 2, p. 56-57; Hélio Tornaghi, Comentários ao código de processo civil, 2.ed., São Paulo: Ed. RT, 1976, vol. I, p. 354. No Código atual, v. José Roberto dos Santos Bedaque, ob. cit., p. 500.

---

37

Em sentido semelhante, afirmam Eduardo Cambi, Rogéria Dotti, Paulo Eduardo d'Arce Pinheiro, Sandro Gilbert Martins e Sandro Marcelo Kozikoski que, sendo o fato criminal irrelevante para a solução da questão cível, não há razão para a suspensão. Em sua ótica, “se a existência do fato ilícito não é controvertida, havendo dúvida apenas em relação às respectivas responsabilidades civil e penal, não há razão para a suspensão do processo” ( *Curso de processo civil completo* . São Paulo: RT, 2017, p. 259).

---

38

Esse prazo, evidentemente, não é processual. Por isso, não incide aqui o contido no art. 219, do CPC, que impõe que os prazos sejam computados apenas em dias úteis.

---

39

“Não diz o Código quem deve ser intimado. A parte no processo civil pode não ser titular do direito de ação penal. No exemplo citado mais acima, o cônjuge do autor da ação de desquite por ter sido vítima da tentativa de homicídio, não é o autor da ação penal, que é pública, movida pelo Ministério Público. A ação do ofendido é subsidiária e somente cabível no caso do § 3.º do art. 102, do CP vigente em 1973. No Código vigendo, que acaba com a ação privada subsidiária nem isso será possível! E então? Que adiantará intimar a parte interessada? Deve entender-se que a intimação, neste caso, terá de ser feita ao Ministério Público? Este Código não o diz. Provavelmente nem suspeitou do problema” (Hélio Tornaghi, Comentários..., vol. I, ob. cit., p. 355).

---

40

O prazo de um ano, a que se refere o art. 315, § 2.º, do CPC, não é prazo processual. Por essa razão, seu cômputo não observa o art. 219 do CPC, ou seja, não se trata de “um ano” contado apenas em dias úteis, mas sim contado da forma tradicional.

---

41

Celso Agrícola Barbi, Comentários... ob. cit. p. 478; Janir Dall'agnol, Comentários..., ob. cit., p. 58.

---

## **Título III. Da Extinção do Processo**

### **1. A conclusão da relação processual**

Alterando substancialmente a racionalidade do Código anterior, ao disciplinar a “extinção do processo”, o Código atual não arrola mais os casos que levam à extinção da relação processual. A lei processual de 1973, neste mesmo espaço, discutia e arrolava as hipóteses de sentenças terminativas (que “extinguíam o processo” sem resolução do mérito) e definitiva (que resolviam o mérito). Com isso, o código discutia a um só tempo a formação, a suspensão e a extinção da relação processual, trazendo suas causas.

No Código atual, esse tema (a extinção do processo) foi alocado no tratamento da sentença, entre os artigos 485 a 487. Ali o Código vai definir a sentença, trazer suas causas e suas consequências.

Isso praticamente esvaziou este “Título III”, que contém duas regras que, examinadas no sistema do Código, mostram-se inúteis, ou porque repetitivas ou porque insuficientes. Neste espaço, o código se limita a afirmar que o processo se conclui com sentença e que o princípio da instrumentalidade do processo deve orientar o juiz a evitar a extinção do processo sem apreciação do mérito. Ambas as regras já estão contidas em vários outros dispositivos do código, o que implica certa redundância dos preceitos aqui alocados. Parece que, no intuito de manter a estrutura do Código anterior, a lei atual resolveu insistir em um tópico sobre a “extinção do processo”, sem, porém, inserir conteúdo relevante nesse momento. Afastou-se, nesse particular, de outras leis processuais, que discutem os casos de extinção do processo no espaço referente à formação, à suspensão e à extinção do processo, a exemplo do Código português (art. 277 e ss.), do francês (art. 384 e ss.) e do italiano (art. 306 e ss.).

De toda sorte, não há dúvida de que, assim como a relação processual tem um termo inicial, tem também um termo final. O fim do processo marca a conclusão da prestação jurisdicional, que evidentemente não se resume ao “julgamento” da controvérsia. Como os direitos de ação e de defesa se exercem durante todo o processo, é no curso de toda relação processual que se impõem os deveres fundamentais do Estado em dar adequada, efetiva e tempestiva resposta aos interesses das partes.

Por isso, a conclusão da relação processual marca também o fim dos deveres impostos ao Estado na solução da controvérsia posta sob sua análise. Até esse momento, é imposição atribuída ao Estado-jurisdicção oferecer a maior proteção eficiente possível a todos os direitos fundamentais processuais envolvidos.

Também a conclusão da relação processual marca o final da litispendência e da litigiosidade sobre a coisa. Quanto à prevenção, o Código brasileiro se utiliza de regime especial, que faz sobreviver esse elemento mesmo após a extinção do processo (art. 286, II, do CPC). Por fim, a extinção do processo ainda faz retomar seu curso o prazo prescricional, que havia sido interrompido com a instauração da relação processual (art. 202, parágrafo único, do CC).

**Art. 316.** A extinção do processo dar-se-á por sentença.

### **1. Sentença como ato de extinção do processo**

Afirma o Código que a extinção do processo sempre se dá por sentença.

A afirmação – criticada há muito tempo – seria de todo desnecessária, não estivesse ela parcialmente equivocada.

É desnecessária porque afirmação semelhante é feita pelo art. 203, § 1.º, do CPC, que diz que

ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

A rigor, ambas as definições de sentença – como, aliás, é comum em definições postas no texto legal – são incompletas, ainda que ambas caminhem para um mesmo sentido. Em ambas se vê que a sentença tende a constituir o ato final do processo – ou de cada uma das fases do processo. Essa tendência, porém, merece ser vista com cautela, já que há, pelo menos, dois reparos a serem feitos.

Em primeiro lugar, é necessário assimilar ao conceito de sentença à ideia das decisões (monocráticas ou colegiadas) de tribunais. Segundo o Código (art. 205 do CPC), o acórdão não se confunde com a sentença (sendo certo que o mesmo deve ser dito em relação a decisões monocráticas de magistrados de tribunais). Porém, é certo que muitas vezes o processo não termina por sentença, mas sim por acórdão ou decisão monocrática no tribunal. Isso ocorre tanto em casos de recursos, como de ações originárias.

Em segundo lugar, mesmo depois da sentença (ou do acórdão ou da decisão monocrática) haverá atos, praticados, sobretudo pelo cartório, pela secretaria ou pelas partes, antes que efetivamente se possa ter o processo como terminado. Eventualmente, haverá despesas processuais a serem pagas pelas partes e haverá a baixa da distribuição e o arquivamento dos autos, medidas a serem realizadas pelo cartório ou pela secretaria. Enfim, concretamente, a “sentença” judicial não é o último ato do processo, de modo que não é ela que marca a extinção do processo ou da relação processual.

Dessa forma, não se deve supor que, efetivamente, o contido no art. 316 do CPC (ou mesmo no art. 203, § 1.º) sirva, do ponto de vista teórico, como elemento definidor da sentença no direito nacional. Não é essa a finalidade dessa definição.

## **2. O conceito de sentença no código e na doutrina. Utilidade**

Mas então qual é a utilidade do conceito de sentença no Código?

É preciso observar que esse conceito, no Código, “tem papel exclusivamente instrumental”. Vale dizer que esse conceito, aqui, se presta apenas para instrumentalizar a operacionalidade do sistema processual brasileiro, sem que se possa ver aqui, de fato, finalidade teórica.

Um conceito de sentença preocupado com a sistematização do Código de Processo Civil, a partir do eixo da tutela dos direitos, deveria levar em consideração a necessidade de coordenação das atividades processuais necessárias para prestação da tutela jurisdicional “como um todo”, isto é, desde a demanda até a concretização dos direitos. Nessa perspectiva teórica, a sentença deveria ser vista como um ato processual, que assinala o momento em que o perfil da técnica processual se altera: abandonam-se as técnicas voltadas à “cognição” e adotam-se técnicas pré-ordenadas à “efetivação” dos direitos. Aliás, tivesse o legislador aproveitado a oportunidade do Código de Processo Civil de 2015, para adotar a “regra da execução imediata da sentença”, isto é, da previsão de apelação sem efeito suspensivo, seria ainda mais nítida essa divisão de atividades que a sentença marca no procedimento comum no juízo de primeiro grau.<sup>1</sup>

A principal preocupação do Código Buzaid nesse terreno estava em relacionar atos decisórios com determinadas espécies recursais – das decisões interlocutórias caberiam agravos, das sentenças, apelações.<sup>2</sup> A solução conceitual encontrada por Alfredo Buzaid, porém, aos poucos se mostrou insuficiente para compreensão do conceito de sentença em toda a sua extensão, ao mesmo tempo em que acabou sendo paulatinamente incapaz de abarcar decisões definitivas sobre



o mérito da causa que não punham fim ao processo – mas apenas à sua fase de conhecimento – e aquelas que decidiam apenas parcela do mérito da causa. Isso por duas razões: a primeira, porque o Código Buzaid estava comprometido com uma compreensão “processualmente fragmentada” da atividade processual (para cada atividade uma espécie de processo); a segunda, porque estava alicerçado no princípio da “unidade e unicidade da sentença” (a sentença era apenas uma só ao longo do procedimento e necessariamente estava voltada a extingui-lo).

Visto na perspectiva da tutela jurisdicional dos direitos, porém, o processo deveria ser encarado como uma “unidade” em que se misturam as atividades de cognição e execução. O processo – como está pré-ordenado à obtenção de um resultado no plano material – só termina com a consecução dessa tutela prometida pelo direito material. Não por acaso o “procedimento comum” engloba uma fase de conhecimento e outra de cumprimento de sentença, tendo o legislador expressamente referido que a tutela jurisdicional do direito só é ultimada efetivamente com a execução do julgado (art. 4.º do CPC – em atenção ao art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988). Em outras palavras, o processo não termina com a “sentença” – ou com qualquer outra espécie de decisão judicial que a substitua, como os acórdãos dos tribunais. “Tendencialmente, o processo termina apenas com a obtenção da concretização do direito da parte”. Se a proteção ao direito da parte ocorre mediante uma tutela “autossuficiente”, até seria menos inadequado afirmar que o processo termina com a prolação da “sentença”. Todavia, se essa proteção só é alcançada por uma tutela jurisdicional “não autossuficiente”, então deve seguir-se à sentença – “dentro do mesmo processo” – uma fase destinada ao seu cumprimento. Daí que quem encara o processo a partir dos “resultados” que ele tem que produzir no mundo das partes jamais pode satisfazer-se com uma elaboração teórica que o veja “somente a partir de um ângulo interno de visão”, como é necessariamente o ângulo fornecido por qualquer critério puramente processual – como a extinção do processo, tal como faz o preceito em exame. A preocupação com a tutela efetiva dos direitos implica compreensão do processo como uma “unidade”, como um “fenômeno unitário” totalmente voltado para a realização dos direitos.<sup>3</sup>

O reflexo dessa preocupação no campo da sentença é muito claro: o seu conceito passa a ser dado a partir da “função” que ela ocupa na vida do procedimento. Não se trata, portanto, de um conceito determinado pela “estrutura” do procedimento – como aquele que é alimentado pelo critério topológico ou topográfico.<sup>4</sup> A sentença é o ato do juiz que, resolvendo ou não o mérito da causa (arts. 203, 485 e 487 do CPC), define-a, gerando em regra preclusão para o juiz (art. 507 do CPC, ressalvadas as hipóteses do art. 494 do CPC), assinalando ainda o fim da atividade de conhecimento ou de efetivação no primeiro grau de jurisdição.

Porém, partindo da percepção de que não foi essa a definição adotada pelo Código, e que a preocupação do Código é outra, nota-se, como já dito, que a preocupação única da lei processual ao definir “sentença” foi determinar “o recurso cabível contra esse ato judicial”.

Em síntese, o conceito de sentença (seja o oferecido no artigo em exame, seja aquele dado pelo art. 203 do CPC), só passa a ser compreensível a partir do que prevê o art. 1.009 do CPC, que afirma que “da sentença cabe apelação”. Como se sabe, a apelação é um recurso desenhado – desde o Código anterior – para subir nos próprios autos do processo. Não há previsão de formação de instrumento separado, ou algo semelhante. Ora, é evidente que um recurso pensado para subir nos autos do processo só pode destinar-se a atacar o ato judicial que corresponda ao fim do processo (ou, ao menos, ao fim de uma das suas fases).

Por isso, há que se concluir que, para o Código, só é sentença o que viabiliza apelação. E só viabiliza apelação o ato judicial que se encontra no final de uma das fases do processo, porque só esse ato permite que os autos subam à instância superior, sem necessidade de prosseguimento de nenhum outro ato na origem.

### **3. Formas de sentença e extinção do processo**

A solução judicial da controvérsia normalmente exigirá decisão sobre o litígio. Eventualmente, para chegar a essa decisão, deve o juiz eliminar defeitos existentes no próprio processo, de modo a manter saudável a relação processual e preservar as garantias processuais das partes. Contudo,

não sendo possível sanar esses vícios ou ultrapassar eventual óbice à prestação da tutela jurisdicional do direito, o juiz não resolverá o mérito (arts. 330 e 485 do CPC). Nesse caso, prolatada a sentença, a parte poderá apelar e o juiz poderá retratar-se no prazo de cinco dias (art. 331 do CPC). Em todos os casos em que o juiz não resolver o mérito fundado nos motivos do art. 330 do CPC, poderá o juiz retratar-se à vista da apelação. A possibilidade de ampla retratação nesses casos constitui “saúdável inovação” do novo Código, na esteira do prestígio ao “diálogo” como pedra de toque do novo processo civil brasileiro (arts. 7.º, 9.º e 10 do CPC).<sup>5</sup>

O juiz não resolverá o mérito da causa, prolatando “sentença terminativa”<sup>6</sup> quando: I – indeferir a petição inicial (art. 330 do CPC); II – o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes; III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias;<sup>7</sup> IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V – reconhecer a existência de perempção,<sup>8</sup> de litispendência ou de coisa julgada; VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 17 do CPC); VII – acolher alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência (art. 3.º da Lei 9.307/1996);<sup>9</sup> VIII – homologar a desistência da ação;<sup>10</sup> IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X – nos demais casos prescritos no Código (art. 485 do CPC). O juiz conhecerá de ofício – isto é, independentemente de requerimento das partes – da matéria constante dos incs. IV, V, VI e IX em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3.º, do CPC).

Quando o juiz não resolve o mérito da causa, o seu pronunciamento limitase ao conhecimento de “questões processuais” concernentes aos “requisitos para a prestação da tutela jurisdicional”. Em outras palavras, o juiz não conhece de questões atinentes ao plano do direito material.

A principal distinção entre as hipóteses em que o juiz examina e aquelas em que não examina o mérito da causa está na eficácia do seu pronunciamento em relação ao direito da parte de propor ou “não nova ação” para obtenção da “tutela jurisdicional do direito”. Isso porque, conforme o art. 486 do CPC, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”. Na verdade, nem mesmo o pronunciamento judicial que “resolve o mérito” da causa obsta a que a parte proponha de novo a ação. O que o pronunciamento judicial que resolve o mérito da causa obsta, por força da coisa julgada (art. 502 do CPC), é que a parte proponha “nova ação e obtenha nova tutela jurisdicional do direito”, isto é, obtenha um novo “exame de uma controvérsia já analisada pelo” Poder Judiciário. É sempre possível exercer o direito de ação, dada a sua “abstração”, ainda que seja para o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito justamente pela existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

A fim de que a nova ação seja capaz de proporcionar um pronunciamento de mérito, porém, é imprescindível que o “vício” que deu origem à anterior extinção do processo sem resolução de mérito tenha sido corrigido (art. 486, § 1.º, do CPC). Para que a petição inicial da nova ação seja despachada é necessário que o autor acoste a prova do pagamento ou do depósito das despesas processuais, aí incluídas as verbas concernentes aos honorários advocatícios (art. 486, § 2.º, do CPC).

A resolução do mérito da causa pode se dar por ato das partes ou por ato do juiz. No primeiro caso, o ato das partes tem de ser homologado para que surta o efeito de extinguir processualmente a controvérsia existente entre as partes. Homologar significa verificar a concordância do ato praticado com as suas condições legais de existência, validade e eficácia a fim de lhe outorgar autoridade judicial. No segundo caso, a resolução do mérito ocorre mediante julgamento, isto é, mediante uma “valoração judicial” a respeito da procedência ou improcedência do pedido formulado pela parte. Seja quando a resolução do mérito ocorre por ato das partes, seja quando ocorre por ato do juiz, diz-se tradicionalmente que há “sentença definitiva”.<sup>11</sup>

Há julgamento de mérito quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou na reconvenção, assim como quando decide, de ofício ou a requerimento das partes, sobre a ocorrência da prescrição da pretensão ou da decadência do direito (art. 487, I e II, do CPC). Quando

há o “julgamento do mérito”, o juiz não fica apenas no plano do processo: a sua cognição a respeito da causa “entra no plano do direito material”, isto é, enfrenta as questões que compõem a causa de pedir; e o pedido do autor e as defesas diretas e as defesas indiretas eventualmente formuladas pelo réu. Vale dizer: enfrenta especificamente o objeto litigioso do processo (o Streitgegenstand, como dizem nossos colegas alemães<sup>12</sup>).

O mérito da causa pode ser resolvido pelas próprias partes unilateral ou bilateralmente. Se o réu reconhece a procedência do pedido formulado na ação ou o autor reconhece a procedência do pedido formulado na reconvenção e se há renúncia ao direito ou à pretensão em que se funda a ação ou a reconvenção, há resolução do mérito por força de ato unilateral da parte. Se há transação (arts. 840 a 850 do CC), por ato bilateral (como refere a legislação civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”). Em todos esses casos, porém, o juiz não pode sindicair o conteúdo da manifestação de vontade das partes: deve apenas indagar se estão presentes os requisitos legais necessários para a prática do ato jurídico em geral (capacidade das partes, licitude ou possibilidade do objeto e finalidade não defesa em lei). Estando presentes, deve homologar o ato.

Com a prolação da sentença, a atividade de conhecimento da causa exaure-se para o juiz de primeiro grau (art. 494 do CPC). Vale dizer: encerra-se a função de conhecimento. Se a sentença i) é “terminativa”, ii) se é “definitiva de improcedência” ou iii) “para realização do direito da parte (autossuficiente), a sentença determina igualmente a extinção do processo – ou melhor, do procedimento comum em primeiro grau. Nenhuma outra atividade é necessária pelo juízo de primeiro grau. Se, porém, a “sentença é definitiva de procedência” e “depende de cumprimento” (não autossuficiente), então o procedimento comum em primeiro grau deve oportunamente seguir rumo ao cumprimento da sentença. Vale dizer: à prolação da sentença não se segue a extinção do processo. Nesse caso, o juiz de primeiro grau tem apenas o perfil da sua atividade alterado: a sua função não é mais “conhecer” das alegações das partes para dar razão a uma delas, mas de “executar” o comando emergente da sentença.

**Art. 317.** Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

## **1. Princípio da sanabilidade**

O Código de Processo Civil assenta-se em uma premissa essencial, que deveria informar o direito processual desde sempre: o processo é um instrumento e deve ser tratado como tal. Não pode sobrepor-se à tutela do direito, nem pode ser obstáculo à adequada solução dos conflitos.

Ademais, em termos processuais, o fundamental é a preservação das garantias processuais fundamentais das partes e dos terceiros. Formalidades outras, que não reflitam nessas garantias, precisam apoiar-se em alguma finalidade essencial, sob pena de tornarem-se formalismo desnecessário. O importante, afinal, é evitar a formação de dicotomia entre o direito material e o processo, permitindo que o processo trabalhe em harmonia com o direito material.

Como decorrência da necessidade de relativizar o binômio direito e processo, o que implica viabilizar às partes sempre que possível, a sanção de vícios capazes de obstar ao exame do mérito (arts. 317 e 488 do CPC), evitando assim o formalismo excessivo e pernicioso na condução do processo,<sup>13</sup> o ideal é que o juiz analise o mérito da causa e resolva efetivamente o conflito existente entre as partes. É por essa razão que o art. 488 do CPC refere que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria o pronunciamento que não a resolve. É também por esse motivo que o dispositivo em apreço afirma que o juiz não deve extinguir o processo, sem resolução de mérito, sem antes dar às partes a oportunidade de sanar o defeito.

Trata-se de inequívoca manifestação da “matriz cooperativa” do novo Código de Processo Civil brasileiro e da necessidade de “racionalização” da tutela jurisdicional.

## **2. Viabilidade da correção**

O próprio preceito em exame, porém, contém uma ressalva que é, antes, uma questão de lógica.

Sua aplicação está condicionada à possibilidade de se corrigir o defeito verificado. É certo que há defeitos processuais que não podem ser corrigidos a exemplo do óbice da coisa julgada. Tratando-se de defeito desse porte, evidentemente não há a possibilidade de aplicar o preceito em exame. Ainda assim, porém, antes de determinar a extinção do processo diante desse vício insanável, impõe-se ouvir as partes, nos termos do que prevê o art. 9º, do CPC, já que a parte pode, eventualmente, demonstrar que o imaginado vício insanável encontrado pelo juiz, na verdade, não existe.

De todo modo, em se tratando de vício sanável, é “dever” do juiz assegurar às partes a possibilidade de corrigir o defeito encontrado, assinando-lhes prazo razoável para tanto.

Só diante da omissão das partes em sanar o óbice processual é que terá cabimento a sentença terminativa.

Recorde-se, ademais, como seria evidente, que a regra em apreço só tem incidência na hipótese de defeitos processuais que possam implicar a extinção do processo. Há vários defeitos processuais (a exemplo da incompetência ou da parcialidade do juiz) que jamais terão o condão de levar à extinção do processo, de forma que não se cogitará, nesses casos, de outorga de prazo para a correção do problema “sob pena de extinção do feito”. Logicamente, será necessário corrigir também esses defeitos; porém, ainda que não corrigido, ele jamais importará na extinção prematura da relação processual.

---

## NOTAS DE RODAPÉ

---

1

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença, p. 230 e ss.

2

Sobre a origem do conceito de sentença e de decisão interlocutória no Código Buzaid, Alfredo Buzaid, Do agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil, p. 101-129, especialmente, p. 128-129; para uma apreciação crítica, Ovídio Baptista da Silva, Decisões interlocutórias e sentenças liminares. Da sentença liminar à nulidade da sentença, p. 3-24; Daniel Mitidiero, Processo civil e estado constitucional, p. 41-57.

3

Crisanto Mandrioli, L'azione esecutiva – Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo, p. 119.

4

Com que a doutrina dominante procurava distinguir as decisões interlocutórias e as sentenças no Código Buzaid, por todos, José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 241-242, vol. V.

5

Daniel Mitidiero, Colaboração no processo civil, p. 79-86.

Na tradição do direito brasileiro, são chamadas de “sentenças terminativas” aquelas que não examinam o mérito da causa, conforme Egas Dirceu Moniz de Aragão, Comentários..., ob. cit., p. 37.

Em caso de paralisação ou abandono do processo, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias (art. 485, § 1.º). No caso de abandono, depois de oferecida a contestação, a extinção do processo dependerá de requerimento do réu (art. 485, § 6.º). Em caso de extinção do processo por paralisação, as partes pagarão proporcionalmente as despesas processuais, ao passo que no caso de extinção por abandono, o autor será condenado ao pagamento das despesas (art. 485, § 2.º).

Embora o legislador não tenha nominado expressamente o fenômeno, dá-se a “perempção da ação” quando o autor, por três vezes, der causa ao abandono da causa, hipótese em que não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito (art. 486, § 3.º). Sobre o conceito de perempção na tradição brasileira, Egas Dirceu Moniz de Aragão, Comentários..., ob. cit., p. 387-388.

O art. 485, VII, in fine, do CPC, procurou resolver verdadeira *quaestio* entre os arbitralistas – definir a extensão dos poderes do árbitro na apreciação da sua própria competência. O art. 8.º, parágrafo único, da Lei 9.307/1996, refere que “caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória”. Adiante, em conformidade com o art. 5.º, XXXV, da CF/1988, o art. 32, I, da Lei 9.307/1996, afirma que é nula a sentença arbitral se “for nula a convenção de arbitragem”, cabendo ao Poder Judiciário aferir se semelhante vício existe ou não (art. 33 da Lei 9.307/1996). Em outras palavras, a Lei 9.307/1996, em primeiro lugar reconheceu ao árbitro a possibilidade de decidir a respeito da própria competência ao longo da arbitragem (*Kompetenz-Kompetenz*). Porém, logo em seguida, como não poderia deixar de ser, sob pena de subtrair da análise do Poder Judiciário essa questão, viabilizou a sua revisão jurisdicional, possibilitando a sua invocação como causa de pedir da ação de nulidade da sentença arbitral. O que o art. 485, VII, in fine, do CPC, estabelece, portanto, é uma simples preferência pela decisão arbitral enquanto durar a arbitragem: reconhecida a competência arbitral pelo árbitro, eventual processo jurisdicional deve ser extinto sem resolução de mérito. Encerrada a arbitragem, poderá a parte interessada questionar o acerto da decisão arbitral a respeito da sua própria competência no âmbito do Poder Judiciário (arts. 32, I e 33 da Lei 9.307/1996). Note-se que aí não há um afastamento definitivo da apreciação do Poder Judiciário: há apenas o estabelecimento de uma preferência temporal pelo juízo arbitral.

A desistência da ação integra o princípio dispositivo em sentido processual, que assegura à parte o juízo de conveniência a respeito da propositura da ação, do momento em que essa propositura ocorrerá e do seu prosseguimento. No entanto, uma vez contestado o pedido, o autor não poderá, sem o consentimento do

réu, desistir da ação (art. 485, § 4.º, do CPC). Isso porque, a partir daí, tem o réu igualmente direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença (art. 485, § 5.º, do CPC). Depois de apresentada a tutela jurisdicional na sentença, extingue-se a possibilidade de desistir da ação. A questão passa a ser regida a partir daí, em sendo o caso, pelo instituto da desistência do recurso (art. 998 do CPC).

---

11

Egas Dirceu Moniz de Aragão, Comentários... ob. cit., p. 37.

---

12

Sobre o assunto, amplamente, Karl Heinz Schwab, Der Streitgegenstand im Zivilprozess, passim; Walter Habscheid. Der Streitgegenstand im Zivilprozess und im Streitverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, passim.

---

13

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Do formalismo no processo civil, p. 128.

© desta edição [2018]



## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

### **PARTE ESPECIAL - LIVRO I. DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**

#### **PARTE ESPECIAL - Livro I. Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença**

##### *1. A classificação dos processos e sua utilidade no modelo atual*

A distinção entre os vários tipos de processo tem – e sempre teve – relevância notória para o direito processual civil. A par de outras classificações menos importantes, sempre foi usual classificar os processos em cognitivo, executivo e cautelar. Essa classificação, afirmava-se, tem por fundamento os “fins da prestação jurisdicional invocada pelo autor”.<sup>1</sup> Assim, se a atuação jurisdicional visasse ao conhecimento do litígio, com a decisão da controvérsia, o processo seria classificado como de conhecimento [cognitivo ou declaratório]; se, ao contrário, ela tendesse à efetivação dos direitos já reconhecidos, então seria qualificado como de execução; por fim, se buscasse a mera assecuração de direitos, seria tratado como processo cautelar.

A lógica dessa racionalidade, como recorda Ovídio Baptista da Silva, tinha por essência a ideia de que o Código de Processo Civil de 1973, em sua visão cientificista do direito processual, buscou eliminar do “processo de conhecimento” qualquer resquício de atuação do direito. Esse processo seria ligado, exclusivamente, à “descoberta” dos fatos, para que a incidência da regra pudesse ser feita automática e subsuntivamente.<sup>2</sup> Já as outras duas classes de processos ficariam reservadas a situações que englobassem cognição e efetivação – já que não se poderia imaginar um processo em que só houvesse execução – variando, porém, a profundidade e o objeto de conhecimento ali havido.

Enfim, o que importa para o momento atual é apenas sublinhar que a classificação mencionada – e ainda repetida quase que por inércia – perdeu há muito tempo seu sentido. Desde quando se passou a admitir atividades “executivas” no “processo de conhecimento”, e desde quando o “processo de conhecimento” passou a internalizar uma fase de efetivação, toda fundação em que essa classificação se assenta, ruuiu. A divisão entre “processo de conhecimento” e “processo de execução” – já que o Código atual não recepcionou a figura do “processo cautelar”, ao menos na legislação positiva – assim, perde seu interesse.

De fato, até mesmo a manutenção da vetusta figura dos embargos à execução (na execução de título extrajudicial) – já que na efetivação de títulos judiciais ela já foi abolida ainda na vigência do Código anterior – é algo inexplicável no momento atual. Se não há processos “puramente” de conhecimento, então dificilmente se justifica a necessidade de formação de nova relação processual, apenas para que o executado possa exercer seu direito de defesa, em face de título extrajudicial. Seria suficiente, para ensejar procedimento especial hábil a conferir vantagem a quem possui título executivo, que se fizesse como na efetivação de título judicial: postergar a defesa para momento posterior ao início da satisfação da obrigação, fazendo com que efetivação e defesa tramitassem de forma independente.

Seja como for, dificilmente hoje se justifica a figura de um “processo de conhecimento”. O que o Código realmente regula é – como afirma o nome atribuído ao Título I desta Parte Especial – o procedimento comum, permeado que é de medidas de conhecimento e de efetivação de direitos.



---

## NOTAS DE RODAPÉ

---

1

José Frederico Marques, Instituições de direito processual civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, vol. II, p. 62.

---

2

Dizia o autor que “sucede que, ao contrário do que acontecia no Código anterior [refere-se ele ao Código de 1939] – fiel a uma tradição multissecular do direito luso-brasileiro –, o legislador de 73 introduziu em nosso direito o instituto conhecido como ‘Processo de Conhecimento’, com sua vocação genética para o procedimento ordinário, com o objetivo principal de retirar dele todas as formas e manifestações de atividade jurisdicional executiva, que passaram a integrar, em livro especial, o Processo de Execução, onde o Código unificou todos os meios admitidos pelo legislador como executórios. Esta simples proposição teórica – qual seja a criação do ‘Processo de Conhecimento’, sem execução – é suficiente para ordinarizar o primeiro, pois é sabido que não havendo atividades de cognição e execução na mesma demanda não haverá, jamais, a possibilidade de quebrar-se a ordinariedade, com a emissão de uma sentença liminar” (Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, 2. ed., São Paulo: RT, 1998, vol. 3, p. 22).

© desta edição [2018]

## **TÍTULO I - DO PROCEDIMENTO COMUM**

### **Capítulo I. Disposições Gerais**

**Art. 318.** Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

#### **1. O procedimento comum como procedimento padrão do Código**

O Código de Processo Civil pode e deve ser sistematizado a partir do eixo da tutela jurisdicional dos direitos – o que remete sua organização à noção de procedimento, isto é, do meio através do qual a tutela jurisdicional dos direitos será prestada.<sup>1</sup> A tutela jurisdicional dos direitos, que pode ser satisfativa ou cautelar, preventiva ou repressiva, contra o ilícito ou contra o dano, definitiva fundada em cognição exauriente ou provisória fundada em cognição sumária, pode ser alcançada mediante diferentes formas procedimentais.

Nosso Código viabiliza a prestação da tutela jurisdicional mediante procedimento comum e mediante procedimentos diferenciados.

Nos casos em que há exercício de jurisdição diante de litígios entre as partes – jurisdição contenciosa – a tutela jurisdicional pode ser prestada mediante procedimento comum (art. 318 do CPC) ou, no rol trazido pelo Código, mediante quatorze procedimentos diferenciados diferentes: (i) ação de consignação em pagamento (art. 539 e ss. do CPC); (ii) ação de exigir contas (art. 550 e ss. do CPC); (iii) ações possessórias (art. 554 e ss. do CPC); (iv) ação de divisão e demarcação de terras particulares (art. 569 e ss. do CPC); (v) ação de dissolução parcial de sociedade (art. 599 e ss. do CPC); (vi) ação de inventário e partilha (art. 610 e ss. do CPC); (vii) ação de embargos de terceiro (art. 674 e ss. do CPC); (viii) ação de oposição (art. 682 e ss. do CPC); (ix) ação de habilitação (art. 687 e ss. do CPC); (x) ações de família (art. 693 e ss. do CPC); (xi) ação monitória (art. 700 e ss. do CPC); (xii) ação de homologação de penhor legal (art. 703 e ss. do CPC); (xiii) ação de regulação de avaria grossa (art. 707 e ss. do CPC); e (xiv) ação de restauração de autos (art. 712 e ss. do CPC). Ao lado desses, muitos outros procedimentos diferenciados podem ser encontrados em legislação extravagante, de forma que há inúmeros caminhos que podem conduzir à tutela dos direitos na legislação processual nacional.

Se comparado com o direito anterior, o Código deixou de bipartir o procedimento comum em ordinário e sumário – atualmente o procedimento comum é apenas um só. No que tange aos procedimentos diferenciados, o Código deixou de mencionar os procedimentos para a ação de depósito, ação de anulação de títulos ao portador, ação de prestar contas, ação de nunciação de obra nova, ação de usucapião de terras particulares e ação que cuida das vendas a crédito com reserva de domínio. Para deixá-los de fora dos procedimentos diferenciados, nosso legislador introduziu ao longo do procedimento comum técnicas processuais que contemplassem as especificidades que os particularizavam – mencionou o direito à tutela sumária fundada na evidência do bem depositado (art. 311, III, do CPC), a citação editalícia essencial para suprir a

ausência dos procedimentos das ações de usucapião e de anulação de títulos ao portador (art. 259, I e II, do CPC), além de entender que a ação de prestar contas, ação de nunciação de obra nova e a ação que visa à tutela das vendas a crédito com reserva de domínio podem ser protegidas adequadamente pelas técnicas processuais disponíveis para as ações que visam à tutela das imposições de fazer, não fazer, do direito à coisa e ao pagamento de quantia (arts. 139, IV, 536, 537 e 538 do CPC). Introduziu no sistema dos procedimentos diferenciados, porém, os procedimentos para a ação de dissolução parcial de sociedade, a ação de oposição (considerada no direito anterior como forma de intervenção de terceiros), as ações de família, a ação para homologação de penhor legal (considerada no direito anterior espécie de procedimento cautelar específico) e para a ação de regulação de avaria grossa.

Ademais, para suprir eventual insuficiência dos procedimentos estabelecidos, o Código permite, dentro de certos limites, que o magistrado flexibilize o procedimento (art. 139, VI, do CPC) e ainda aposta na possibilidade de as partes, de comum acordo, adaptarem o procedimento por meio de negócios processuais (art. 190 do CPC). Melhor seria, sem dúvida, estabelecer cláusulas abertas, que permitissem a adequação do procedimento ao caso concreto, por meio da construção desse rito diante da interação das garantias fundamentais processuais. Com efeito, no momento atual do Código de Processo Civil, não se justifica mais uma legislação que esmiúce o procedimento, como se o juiz ainda fosse alguém que deve ter todos os seus passos regrados e todas as suas atitudes pré-estabelecidas. Não foi essa, porém, a orientação do Código processual atual.

Nos casos em que há exercício da jurisdição na ausência de litígio entre as partes – jurisdição voluntária – a tutela jurisdicional pode ser prestada mediante procedimento comum (art. 318 do CPC) ou mediante dez diferentes procedimentos diferenciados para: (i) notificação e interpelação (art. 726 e ss. do CPC); (ii) alienação judicial (art. 730 do CPC); (iii) divórcio e separação consensuais, extinção consensual da união estável e alteração do regime de bens do matrimônio (art. 731 e ss. do CPC); (iv) testamentos e codicilos (art. 735 e ss. do CPC); (v) herança jacente (art. 738 e ss. do CPC); (vi) bens dos ausentes (art. 744 e ss. do CPC); (vii) coisas vagas (art. 746 do CPC); (viii) interdição (art. 747 e ss. do CPC); (ix) organização e fiscalização das fundações (arts. 764 e 765 do CPC); e (x) ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo (art. 766 e ss. do CPC).

Se comparado com o direito anterior, o Código passou a arrolar como procedimentos diferenciados de jurisdição voluntária os procedimentos para a extinção consensual da união estável e alteração do regime de bens do matrimônio e a ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo, além das notificações e interpelações judiciais (espécies consideradas no direito anterior como providências cautelares específicas). Poderia o legislador ter aproveitado a oportunidade para regular como procedimentos diferenciados de jurisdição voluntária, procedimentos ligados ao biodireito – como, por exemplo, autorização de aborto terapêutico e fertilização assistida. Diante da ausência de previsão especial, situações dessa ordem seguem sendo tuteláveis mediante o procedimento comum de jurisdição voluntária. Ou poderia – sem dúvida, alternativa melhor – atribuir essa função a outro órgão, já que delegar ao Poder Judiciário, já sobrecarregado com a massa de conflitos que deve gerir, mais essa atividade realmente é um contrassenso nos dias atuais.

De toda sorte, de acordo com o legislador, o procedimento comum aplica-se a todas as causas, salvo disposição contrária do Código ou de legislação extravagante (art. 318 do CPC). O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos diferenciados (art. 318, parágrafo único, do CPC). É por essa razão que se diz que o procedimento comum é o procedimento padrão para a tutela dos direitos – inexistindo disposição especial, emprega-se o procedimento comum para prestação da tutela jurisdicional e para colmatar eventuais lacunas legais na construção dos demais procedimentos.

## **2. Estrutura básica do procedimento comum**

Para prestação da tutela jurisdicional mediante o procedimento comum, o órgão jurisdicional pode conhecer e executar, além de poder proteger as partes mediante pronunciamentos provisórios e definitivos.

No Código Buzaid, reservava-se ao juiz no procedimento comum ordinário do processo de conhecimento tão somente a tarefa de conhecer das alegações das partes e decidir a controvérsia mediante sentença. Toda e qualquer atividade executiva deveria ser buscada, em, sendo o caso, no processo de execução, ao passo que toda e qualquer providência provisória deveria ser postulada mediante o emprego do processo cautelar.<sup>2</sup> As sucessivas reformas, a que essa lei foi submetida, concentraram no procedimento comum do processo de conhecimento atividades de execução (a título de cumprimento de sentença) e a possibilidade de o juiz tutelar provisoriamente as partes ao longo do procedimento (mediante antecipação da tutela).

Perfil semelhante a esse estágio final da lei anterior foi herdado pelo Código de 2015. Hoje, assim, o processo “de conhecimento” abriga tanto atividades cognitivas, como executivas. Oferece também a possibilidade de, em seu bojo, postular tutelas provisórias ao direito. Nesse processo, portanto, pode-se veicular qualquer atividade que se mostre necessária à proteção dos interesses.

Em sua estruturação geral, o procedimento comum começa mediante o exercício da ação (art. 319 do CPC). Estando em termos a petição inicial, o réu é citado para comparecer em audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 do CPC) ou para oferecer defesa (art. 335 do CPC). Em sendo o caso, pode o juiz, antes ou depois da citação do réu, prestar tutela provisória à parte interessada (art. 294 e ss. do CPC). Logo em seguida, não sendo o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 354 do CPC) ou de julgar imediatamente o pedido, ou parcela do pedido, [ou dos pedidos] (art. 355), tem o juiz de organizar o processo (art. 357 e ss. do CPC) a fim de viabilizar condições adequadas para a produção da prova (arts. 369 e ss. do CPC) e para a decisão da causa (art. 485 e ss. do CPC). Em sendo o caso, tem de determinar o cumprimento da sentença, determinando a prática de atos executivos (art. 513 e ss. do CPC). As decisões prolatadas no procedimento comum no primeiro grau de jurisdição podem ser controladas mediante recursos para o segundo grau de jurisdição (art. 994 e ss. do CPC). As decisões tomadas pelo segundo grau de jurisdição podem ser objeto ainda de novos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, III, e 105, III, da CF/1988).

Nada obstante essa sequência legalmente estruturada, haja vista a adoção do princípio da adequação, o procedimento pode ser em parte adaptado pelo juiz (art. 139, VI, do CPC) e pelas partes (art. 190 do CPC) para atender às necessidades evidenciadas pelo caso concreto. Por exemplo, o procedimento pode avançar com as comunicações dos atos processuais sendo realizadas oportunamente a cada ato ou com a dispensa de comunicações por prévio acordo (mediante a fixação de um calendário processual). A organização do processo pode ocorrer por escrito – ou oralmente em audiência (art. 357 do CPC). O ônus da prova, normalmente distribuído de maneira fixa pelo legislador, pode ser modificado pelo juiz (art. 373 do CPC). A prova, que normalmente é colhida depois de organizado o processo, pode ser colhida de forma antecipada (art. 381 e ss. do CPC). Dependendo do caso, pode ou não ser necessária a realização da audiência de instrução e julgamento (art. 358 e ss. do CPC), pode ser necessária uma fase de liquidação da obrigação pecuniária em que condenado o réu (art. 509 e ss. do CPC) ou pode ser necessária uma fase de cumprimento da sentença (art. 513 e ss. do CPC).

No procedimento comum, o juiz pode praticar atos de conhecimento e atos de execução – daí a razão pela qual, aliás, é um equívoco teórico discipliná-lo dentro do processo de conhecimento.<sup>3</sup> O juiz conhece das alegações das partes e das provas produzidas para, logo em seguida, dar razão a uma das delas, julgando procedente ou improcedente o pedido – não sendo o caso, é claro, de extinção do processo sem resolução de mérito. Se necessário, ainda, depois de prolatada sentença de procedência, pratica atos executivos a fim de promover o seu cumprimento.

### **3. Alterações de procedimento por iniciativa judicial e pela vontade das partes. Negócios processuais em tema de procedimento**

A lei brasileira entendeu por regular, de forma minuciosa, o procedimento pelo qual o juiz examina os fatos e decide a controvérsia. A legislação nacional ainda segue a orientação típica das leis liberais, que buscam traçar exatamente os passos que devem ser tomados para a decisão, de modo a tentar evitar qualquer abuso por parte do órgão jurisdicional.<sup>4</sup>

Obviamente, essa tendência soa anacrônica. Porém, o mais grave disso é a possibilidade de que o procedimento estabelecido em lei possa não refletir os anseios do direito material carente de tutela.

O Código anterior tentava responder a essa deficiência concebendo um rito mais simples (então chamado de rito sumário) para a proteção de interesses específicos ou de pequeno valor. A lei atual aboliu essa possibilidade, mantendo apenas o procedimento comum.

Em contrapartida, em uma tentativa de amenizar esse excesso, permite a lei que o juiz possa, sob certos aspectos, flexibilizar o procedimento, adaptando-o às necessidades do direito material.<sup>5</sup> Nesse sentido, prevê o art. 139, VI, do CPC, que o juiz possa alargar prazos processuais e modificar a ordem de produção das provas do processo.

Trata-se de flexibilização nitidamente tímida e, no mais das vezes, insuficiente para atender às necessidades do direito material ou da sua tutela efetiva. Ainda assim, não se pode deixar de mencionar que essa possibilidade permite a construção, ainda que nos estreitos limites fixados pela lei, de um procedimento mais adequado às necessidades do caso concreto.

Note-se que, pela atuação exclusiva do juiz, as permissões dadas pela lei limitam-se à ampliação de prazos processuais e à alteração da ordem de obtenção das provas. A par dessas medidas, logicamente, é possível que o juiz convoque as partes, a qualquer tempo, para a tentativa de autocomposição (art. 139, V, do CPC) ou ainda que adote medidas tendentes a realizar seus objetivos institucionais, a exemplo daqueles arrolados no art. 139 do Código. Todavia, não tem o juiz a possibilidade de, sponte propria, criar um procedimento adequado ao litígio, ainda que isso possa resultar em medidas mais efetivas ou que isso possa oferecer resposta em tempo mais adequado.

A par dessa possibilidade admitida ao magistrado, porém, prevê a lei que as partes possam, de comum acordo – em se tratando de direito que admita autocomposição e sendo elas capazes – celebrar negócios processuais, capazes de ajustar o procedimento a seus interesses e às necessidades do conflito (art. 190, do CPC). Espera-se, com isso, que eventual insuficiência ou inadequação do procedimento regrado pelo Código possa ser suprida pela atuação das partes, de modo a criar elementos que adaptem o rito estabelecido em lei às necessidades do caso concreto.<sup>6</sup>

Nesse sentido, podem as partes limitar o emprego de recursos, comprometer-se a não empregar certos meios de prova (o que, evidentemente, não exclui a prerrogativa do juiz de fazer uso desses meios), alterar prazos dispositivos, renunciar ao emprego de cumulações de demandas – seja pelo polo ativo, seja por meio de reconvenções – etc. Logicamente, esse poder das partes de dispor de “ônus, poderes, faculdades e deveres” só pode se dar em relação àquilo que é próprio dos sujeitos negociantes; vale dizer, as partes podem dispor sobre poderes seus, mas jamais sobre prerrogativas oferecidas a outros sujeitos. Não podem, por isso, dispor sobre poderes (deveres) do juiz, do Ministério Público ou de terceiros, que não participaram do dito negócio.

Seja como for, contanto que essas medidas não interfiram nos limites fixados em lei, que não inviabilizem atos de outrem e que não limitem a finalidade jurisdicional, essas adaptações do procedimento são viáveis e merecem prestígio.

Servem, nesse sentido, como instrumento posto em substituição a alguns ritos especiais, antes existentes, de forma a tentar obter a adequação do procedimento à efetividade da prestação jurisdicional, sem descuidar das garantias inerentes ao devido processo legal.<sup>7</sup>

#### **4. Fases e estágios do procedimento comum**

O procedimento comum está estruturado em fases e em estágios, podendo a sua estrutura ser analisada em uma perspectiva horizontal e vertical. A perspectiva horizontal revela as fases e os respectivos estágios que o procedimento comum percorre no primeiro grau de jurisdição para prestação da tutela jurisdicional. A perspectiva vertical evidencia as fases que o procedimento comum supera para prestação da tutela jurisdicional levando em consideração a estrutura

escalonada da organização judiciária.

## 5. Perspectiva horizontal

O procedimento comum está horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional.

A fase de conhecimento desenvolve-se normalmente em quatro estágios destinados à postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que há prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado à liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais à preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente à sua exclusividade.<sup>8</sup>

O estágio postulatório destina-se à oitiva de ambas as partes: o autor expõe o seu caso mediante o exercício do direito de ação (art. 5.º, XXXV, da CF/1988) e o réu se defende exercendo o seu direito de contraditório e ampla defesa (art. 5.º, LV, da CF/1988). A partir da exposição dos seus respectivos fundamentos, ambas as partes postulam – o autor pede a procedência do pedido e o réu pede a sua improcedência mediante contestação. Em sendo o caso, pode o réu igualmente fazer um pedido de tutela jurisdicional do direito mediante reconvenção (art. 343 do CPC). O legislador entendeu por bem ainda inserir nessa fase, quando cabível, uma tentativa de solução consensual do litígio antes do exercício do direito de defesa mediante audiência de conciliação e de mediação (art. 334 do CPC). O direito brasileiro não prevê qualquer estágio obrigatório de autocomposição anterior ao exercício da ação e à apresentação do caso em juízo pelo demandante.<sup>9</sup>

Pode ocorrer de o juiz, depois de viabilizar a emenda da petição inicial (art. 321 do CPC), ter de indeferi-la (art. 330 do CPC) ou de julgar improcedente liminarmente o pedido (art. 332 do CPC). Em quaisquer desses casos o procedimento não avança e o processo é extinto respectivamente sem resolução de mérito (art. 485 do CPC) ou com resolução de mérito (art. 487 do CPC).

O estágio organizatório tem por função preparar a causa para a sua instrução e julgamento. Por essa razão, tem tanto um perfil retrospectivo como prospectivo: visa a aferir a existência de óbices e vícios processuais que impeçam o julgamento de mérito a fim de sanear a causa (art. 357, I, do CPC) e a delimitar as alegações de fato litigiosas para guiar a produção da prova, dispondo-se, inclusive, em sendo o caso, sobre questões concernentes à distribuição do ônus da prova (art. 357, III, do CPC). Essa organização da causa pode ocorrer por escrito, mediante despacho saneador, ou oralmente em audiência (art. 357, caput e § 3.º, do CPC).<sup>10</sup>

Pode mostrar-se desnecessário no todo ou em parte o estágio organizatório, porque inútil ou desnecessária a colheita da prova, tendo em conta que pode ser o caso de o juiz prolatar julgamento conforme o estado do processo (art. 354 e ss. do CPC). Pode ocorrer de ser o caso de extinguir o processo no todo ou em parte (art. 354 do CPC) ou de julgar imediatamente o mérito no todo (art. 355 do CPC) ou em parte (art. 356 do CPC).

O estágio instrutório destina-se à produção da prova, notadamente da prova oral, da prova pericial ou da inspeção judicial, já que a prova documental acompanha as postulações iniciais das partes (art. 434 do CPC). Nesse estágio, o processo é instruído com provas das alegações. Em sendo o caso, pode o juiz designar audiência de instrução e julgamento para sua colheita (art. 358 e ss. do CPC).

Nada obstante o momento do estágio instrutório, pode ser necessária a produção antecipada da prova (art. 381 e ss. do CPC). Nesses casos, a lei prevê uma inversão procedimental para que a prova seja colhida em momento diverso daquele em que previsto na ordem do procedimento.

O estágio decisório é aquele em que o juiz decide o caso levado a juízo. A decisão do caso pode levar à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485 do CPC) ou à extinção do processo, ou da fase de conhecimento com resolução de mérito (art. 487 do CPC). Se a tutela jurisdicional



prestada é autossuficiente (declaratória ou constitutiva), então o pronunciamento judicial basta para atender à postulação das partes. Se a tutela jurisdicional prestada é não autossuficiente (condenatória, mandamental ou executiva), então o pronunciamento judicial não basta e é necessário submeter a cumprimento a sentença.

Pode ocorrer, por fim, de ser prolatada uma sentença condenatória genérica (art. 324, § 1.º, do CPC) no estágio decisório. Nesse caso, a fase de conhecimento abrigará ainda um quinto estágio destinado à liquidação da obrigação (art. 509 e ss. do CPC), cujo objetivo é apontar qual é o valor exato que é devido ao demandante em função da procedência de seu pedido.

Sendo a sentença condenatória, mandamental ou executiva, o procedimento comum segue para a fase de cumprimento. A fase de cumprimento pode se desenvolver em um único estágio destinado à prática de atos executivos ou em três estágios voltados igualmente à prática de atos executivos sequenciados em postulação, instrução e satisfação da obrigação. Como o Código consagrou a técnica executiva atípica para tutela dos direitos (arts. 139, IV, 536, 537 e 538 do CPC), saber qual será a forma que seguirá o cumprimento de sentença depende de uma concreta apreciação do juiz a respeito do meio mais idôneo e da menor restrição possível.

A sentença mandamental e a executiva carregam executividade intrínseca, isto é, contêm em si a previsão das próprias técnicas executivas que devem ser empregadas para tutela do direito, de modo que a fase de cumprimento de sentença realiza-se em um único estágio voltado à prática dos atos executivos mediante o uso das técnicas mencionadas na decisão (por exemplo, multa coercitiva, busca e apreensão, desfazimento de obras, arts. 536, 537 e 538). O cumprimento da sentença ocorre de ofício, independentemente de requerimento da parte.

A sentença condenatória tem executividade extrínseca, isto é, apenas autoriza a adoção de técnicas processuais executivas para realização da tutela do direito. A prolação da sentença condenatória autoriza a adoção da técnica expropriatória para tutela do direito (art. 523 e ss. do CPC). Nesse caso, a fase de cumprimento passará por três estágios distintos.

O estágio postulatório, em que o exequente apresenta o pedido de execução e o executado é intimado para pagar ou apresentar defesa contra a execução mediante impugnação. É o momento em que as partes postulam e são ouvidas na fase de cumprimento.

O estágio instrutório, em que se procura encontrar bens passíveis de penhora e submetê-los à expropriação. Aqui o processo é instruído com bens capazes de responder patrimonialmente ao débito constante da sentença condenatória.

Por fim, há o estágio de satisfação da obrigação: o bem penhorado é adjudicado ao exequente, alienado e, seu produto, entregue ao exequente ou seus frutos e rendimentos são apropriados ao exequente, a fim de satisfazer o seu crédito. A satisfação do exequente é declarada por sentença e o procedimento comum é extinto (arts. 924 e 925).

De rigor, no momento atual, a escolha entre as técnicas condenatória, mandamental ou executiva, para qualquer espécie de prestação, é medida que cabe normalmente ao juiz. É ele que deve determinar que instrumento será utilizado para a satisfação da prestação e, portanto, que medida seguirá a sentença de procedência. Logicamente, as técnicas mandamental e executiva implicam maior dose de autoridade do Estado, enquanto a técnica condenatória representa menor autoridade e, em regra, menor efetividade. Por isso, tem preferência as técnicas mandamental e executiva, seja para a tutela de prestações de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou mesmo de pagar soma em dinheiro. Só excepcionalmente é que se deve empregar a técnica condenatória, porque implica restrição evidente à garantia da adequação da tutela jurisdicional.<sup>11</sup>

## **6. Perspectiva vertical**

O procedimento comum está estruturado verticalmente também em duas grandes fases: a fase ordinária e a fase extraordinária. A primeira tem por função viabilizar a prolação de uma decisão justa e sua adequada e tempestiva efetivação; e está confiada aos juízes de primeiro grau e aos



desembargadores de segundo grau que compõem as Cortes de Justiça. A segunda tem por função possibilitar a formação de precedentes e está confiada aos ministros das Cortes Supremas.

Ao longo do procedimento comum, os juízes no primeiro grau de jurisdição pronunciam decisões interlocutórias que podem ser recorridas imediatamente por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) ou que podem ser recorridas posteriormente por apelação (art. 1.009, § 1.º, do CPC). A fim de decidir a controvérsia e por fim à fase de conhecimento, o juiz pronuncia sentença, cujo recurso cabível é a apelação (art. 1.009 do CPC). Isso quer dizer que o juiz de primeiro grau pode ter suas decisões revisadas pelas Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais), que constituem o segundo grau de jurisdição. As decisões de primeiro grau podem ser controladas mediante recursos pelos desembargadores e desembargadores federais por decisão monocrática ou por decisão colegiada.

Acima das Cortes de Justiça estão alocadas as Cortes Supremas (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), que são cortes que ocupam o vértice da organização judiciária e visam à outorga de unidade ao direito mediante adequada interpretação do direito constitucional e do direito infraconstitucional federal. Os ministros das Cortes Supremas interpretam o direito a partir de casos veiculados por recurso extraordinário (art. 102, III, da CF/1988) e por recurso especial (art. 105, III, da CF/1988), podendo igualmente julgá-los monocraticamente ou em colegiado. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não constituem um terceiro grau de jurisdição – isso porque a tarefa desses tribunais não é a mesma que é conferida aos juízes de primeiro grau e às Cortes de Justiça. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não são cortes de controle de decisões, mas cortes de interpretação, cuja principal função é decidir casos com razões que podem ser invocadas posteriormente como precedentes.<sup>12</sup>

## 7. Aplicação subsidiária

Afirma o Código que a aplicação das regras referentes ao procedimento comum aos procedimentos especiais e ao processo de execução se dá de forma subsidiária.

Isso implica dizer não apenas que estas regras cedem diante da existência de regras expressas em outro lugar em sentido contrário. Importa também dizer que a aplicação subsidiária há de atentar também ao *sistema* eventualmente existente nesses outros ambientes, e eventuais conflitos que possam surgir entre a aplicação dessas regras e aquele mencionado sistema.

É o que ocorre, por exemplo, no regime do processo de execução. Sabendo que o sistema executivo exige a prevalência da posição do exequente em detrimento da posição do executado (art. 797, do CPC), é certo, por exemplo, que a ideia de contraditório forte, próprio do processo de conhecimento, há de ser aplicada *cum granum salis*, de forma a não desvirtuar a lógica daquele modelo. Regras como a disciplina da revelia, por exemplo, embora sem previsão no procedimento executivo, certamente não tem lá cabimento, porque totalmente alheias à finalidade e ao sistema do processo de execução.

---

## NOTAS DE RODAPÉ

1

É claro que a compreensão do Código de Processo Civil como um sistema estruturado a partir da ideia de tutela jurisdicional dos direitos é resultado de uma determinada interpretação a ele conferida. Inexiste sistema – assim como não existe norma – antes da interpretação (Riccardo Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, p. 136 146).

2

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Curso de processo civil, vol. I; Daniel Mitidiero, O processualismo e a formação do Código Buzaid, RePro, 183, passim.

---

3

Para uma ampla crítica do conceito de processo de conhecimento, Ovídio Baptista da Silva, Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, passim; Processo e ideologia, passim.

---

4

Em verdade, o procedimento comum do Código ainda está atrelado a antigos mitos, a propósito da atuação do direito em juízo. Como sintetiza Ovídio Baptista da Silva, “as considerações precedentes mostraram-nos que o procedimento ordinário, a que se resume o chamado Processo de Conhecimento – propriamente ‘processo declaratório’ –, sustenta-se, basicamente, em dois pressupostos ideológicos, ambos falsos, tanto hoje quanto sempre o foram: um deles, decorrente da suposta virtude atribuída ao processo de transformar as relações de direito material em relações obrigacionais; o outro, igualmente falso, através do qual o sistema estrutura-se sobre a fantasia de que a lei somente admita uma solução ‘correta’, portanto, uma proposição normativa que não se interpreta, mas que terá sua ‘vontade’ revelada. Esta ideia preside o sistema desde a compreensão do que seja uma ‘antecipação de tutela’, até a concepção de nosso trágico sistema de recursos” (Ovídio Baptista da Silva, “Fundamentos do procedimento ordinário”, Processo e ideologia. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 149-150).

---

5

Sobre a flexibilização do procedimento, v. Fernando da Fonseca Gajardoni, São Paulo: Atlas, 2008, passim.

---

6

Parece desnecessário dizer que essa esperança tende a ser ingênua. Isso porque, se uma das partes pretende um procedimento que seja o mais apto possível à proteção do direito discutido em juízo, certamente essa não será a intenção da outra, que espera que a atuação jurisdicional seja a menos invasiva possível a seus interesses.

---

7

Sobre esses acordos, v. Antonio do Passo Cabral, Convenções processuais – entre publicismo e privatismo, Tese de livre docência, apresentada à Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015; Robson Godinho, Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de processo civil, São Paulo: RT, 2015.

---

8

Como observa José Carlos Barbosa Moreira, em lição totalmente aplicável ao direito vigente, “o exame dos modelos conhecidos no direito moderno evidencia que, se em geral se podem distinguir no itinerário processual diversas etapas, correspondentes aos tipos de atividade acima indicados, a caracterização de cada uma delas antes se liga à predominância que à exclusividade do respectivo exercício. Ter-se-ão, assim, uma fase predominantemente postulatória, uma fase predominantemente instrutória e uma fase

predominantemente decisória. Mas, de um lado, as fronteiras entre elas nem sempre são muito rígidas; e, de outro, não se trata de compartimentos estanques: a produção de provas, por exemplo, começa a realizar-se desde a fase postulatória” (José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil brasileiro*, p. 5).

---

9

Como prevê, por exemplo, o legislador inglês, que instituiu um estágio anterior ao exercício da ação chamado de pre-action protocols – destinado a viabilizar uma solução consensual da controvérsia (Neil Andrews, *Andrews on civil processes*, p. 66 67, vol. I). Sobre as vantagens desse estágio prévio, v. entre outros, Fernanda Tartuce, *Mediação nos conflitos civis*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, *passim*.

---

10

Para uma comparação com o direito francês, inglês e italiano, Beatrice Ficcarelli, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, *passim*.

---

11

V. sobre isso, Sérgio Cruz Arenhart, *Sentença condenatória para quê?. Teoria quinária da ação – estudos em homenagem a Pontes de Miranda nos 30 anos de seu falecimento*. Coord. Eduardo José da Fonseca Costa, Luiz Eduardo Ribeiro Mourão e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, Salvador: JusPodium, 2010, *passim*; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, ob. cit., vol. 2, p. 663 e ss.; Ovídio Baptista da Silva, *Jurisdição e execução*, ob. cit., *passim*.

---

12

Sobre isso, v. Luiz Guilherme Marinoni, *Julgamento nas cortes supremas*, São Paulo: Ed. RT, 2015, *passim*; *idem* *O STJ enquanto corte de precedentes*, São Paulo: RT, 2013, *passim*; Daniel Mitidiero, *Cortes superiores e cortes supremas*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2014, *passim*.

## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

### **TÍTULO I - DO PROCEDIMENTO COMUM**

#### **CAPÍTULO II. DA PETIÇÃO INICIAL**

## **Capítulo II. Da Petição Inicial**

### *Seção I*

#### *Dos Requisitos da Petição Inicial*

**Art. 319.** A petição inicial indicará:

I – o juízo a que é dirigida;

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV – o pedido com as suas especificações;

V – o valor da causa;

VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1.º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2.º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3.º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

### **1. Petição inicial e sua relevância**

Se a sentença é o ato judicial por excelência, a petição inicial representa o ato mais importante realizado no processo pela parte autora. É aqui que ela apresenta seu direito de ação e faz romper a inércia da Jurisdição. É neste ato que a parte deduz sua pretensão, indicando ao Estado-juiz sobre o que, por que e em face de quem ela controverte.

Considerando o princípio da demanda – segundo o qual não deve o magistrado julgar aquém, além ou fora do pedido – é a petição inicial [e, mais precisamente, o pedido ali veiculado], juntamente com eventual defesa apresentada pelo réu, que marca os limites do exercício da atividade jurisdicional.

Embora, atualmente, o processo tenda a rejeitar formalismos, a petição inicial é dita um ato formal. Isso não porque se exija dela o preenchimento de certo ritual ou a precisão nos termos empregados. Ela é considerada formal porque a lei regula os elementos que deve conter. Isso significa que, presentes esses elementos, a petição deve ser admitida e processada. Ainda que o juiz entenda simplória a peça ou ainda que a petição esteja colocada em termos não usuais, ainda assim não pode deixar o juiz de admitir a petição inicial, desde que preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320, do Código de Processo Civil de 2015.

De todo modo, vale sempre a advertência de Calmon de Passos, que afirmava que

já se disse, com propriedade, que a inicial é o projeto da sentença que o autor pretende do juiz. Deve ela, conseqüentemente, ter a coerência lógica e a correção jurídica que se impõem para a decisão acertada do conflito de interesses trazido a juízo pelo autor.<sup>1</sup>

## **2. Requisitos da petição inicial**

Como já se disse, a petição inicial é documento formal. Isso, porém, só significa que a petição deve conter os elementos indicados no texto legal. Nada mais se pode exigir da parte além de a apresentação de uma petição “escrita” e que: a) apresente os elementos contidos nos arts. 319, 330 e 332 do CPC (estes dois últimos a contrario sensu), b) não contenha defeitos ou irregularidades que dificultem a análise do mérito (art. 321 do CPC) e c) que venha acompanhada dos documentos a que alude o art. 320, do CPC. Não há, por isso, qualquer cabimento em se impor outras exigências ou em se adotar certa estrutura que, embora de praxe, não é imposta por lei.

Não se impõe, ademais, que a parte dê nome à ação – mesmo porque o direito de ação não é classificável – que apresente opiniões doutrinárias ou jurisprudenciais ou que traga seus argumentos dessa ou daquela forma. Só se pode impor à parte que satisfaça os requisitos legais.

É certo que, hoje, há movimentos que buscam restringir o número de páginas da petição inicial ou a fazer com que ela assuma essa ou aquela forma determinada. Isso tudo, porém, pode até contribuir para facilitar a análise judicial dos argumentos apresentados. Todavia, essas tendências não são e não podem ser compulsórias porque não previstas em lei. Assim, desde que a petição seja compreensível, isto é, que não contenha defeitos ou irregularidades que dificultem a análise do mérito, que cumpra com os requisitos legais e que venha acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, deve ser processada.

Dos requisitos expostos no art. 319, do CPC, é necessário perceber, ainda, que os conceitos de partes, causa de pedir, e pedido, são fundamentais para a correta individualização da ação, já que são seus elementos, segundo o próprio Código de Processo Civil (art. 337, § 2.º, do CPC) – nossa legislação adotou o critério da tríplice identidade para identificação das ações (tria eadem). Por consequência, esses conceitos são importantes para a identificação da litispendência e da coisa julgada, pois, como também diz o Código de Processo Civil, há litispendência, quando se repete ação que está em curso, e há coisa julgada quando se repete ação que foi decidida por sentença de que não caiba recurso (art. 337, §§ 3.º e 4.º, do CPC).

É certo que o Código de Processo Civil reduz a rigidez com que se examinavam esses elementos, sobretudo para a avaliação da coisa julgada. De fato, o art. 506 do CPC permite que terceiros possam beneficiar-se da coisa julgada formada inter alios. Por outro lado, a análise do pedido deixa de ser tomada de forma restritiva, devendo observar o “conjunto da postulação” e a boa-fé (art. 322, § 2.º, do CPC). Com relação à causa de pedir, também a lei atual impõe reformulação de sua leitura, tanto porque estende a coisa julgada a parte dessa fundamentação (art. 502 do CPC), como porque novos fatos podem – e devem – ser tomados em consideração para a análise da controvérsia (arts. 493 e 933, do CPC).

Ainda assim, e demonstrando certo paradoxo interno no sistema do Código, permanece a lei afirmando que a identificação da coisa julgada e da litispendência se dá a partir da análise da tríplice identidade (art. 337, §§ 1.º a 4.º, do CPC).

## **3. Competência**

A primeira imposição feita pelo dispositivo em apreço é a indicação do órgão jurisdicional a quem se destina a petição inicial.

Afirma o código que a parte deve indicar o “juízo” ao qual é dirigida a petição. Trata-se de óbvio excesso, já presente no código anterior e cujo cumprimento é comumente impossível no direito brasileiro. Isso porque a determinação do “juízo” dentro do foro é muitas vezes feita por sorteio, de modo que a parte não tem condições de especificar, com antecedência, a qual juízo será

endereçada a petição inicial.

De todo modo, a previsão tem por objetivo impor à parte que especifique com a maior precisão possível o órgão jurisdicional que a seu juízo é o competente para processar a causa. Vale dizer: incidirão aqui as regras que determinam a competência, de maneira a especificar, e na medida do possível, escolher o juízo/foro que processará a demanda.

Recorde-se, nesse particular, que em relação à competência relativa é possível que as partes convençionem o foro (mas não o juízo) em que tramitará o processo. No que tange ao autor, é na petição inicial que ele se manifesta a propósito desta escolha. Assim, ainda que convençionado outro foro anteriormente (por cláusula de eleição de foro), na petição inicial poderá o autor indicar outra competência territorial para o curso do processo. Nesse caso, não havendo oposição da parte contrária, este novo foro será o competente para a causa.

#### 4. Partes

Parte é quem pede e contra quem se pede tutela jurisdicional. A petição inicial deve identificar quem são as partes no processo (art. 319, II, do CPC). Essa identificação deve ser a mais precisa possível. Por isso, afirma o dispositivo em exame que se deve apontar

os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.

A intenção dessas exigências é, em primeiro lugar, evitar que participe do processo homônimo daquele que efetivamente deveria ali intervir. A maior determinação do sujeito a integrar a relação processual evita chamar para o processo quem não é o sujeito apropriado. Algumas das exigências postas têm ainda interesse específico, tal como ocorre com a indicação do estado civil da parte (ou mesmo da existência de união estável), que objetiva avaliar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo ou de exigência de autorização para ajuizar certas demandas (art. 73 do CPC). Outras, como a descrição da profissão da parte, podem ser relevantes para apurar eventual cabimento do pedido de assistência judiciária gratuita ou mesmo para analisar a necessidade de possíveis cautelas na citação ou na intimação do sujeito. Por fim, algumas das disposições legais têm em mente a evolução do processo por autos eletrônicos (a exemplo da exigência da apresentação de endereço eletrônico das partes).

Não dispondo dessas informações, poderá o autor requerer que o juiz o auxilie, determinando as diligências necessárias para a sua obtenção (tem-se aí o dever de auxílio do juiz, decorrente da necessidade de colaboração no processo, art. 319, § 1.º, do CPC).<sup>2</sup> O que interessa para o desempenho do ônus de indicação das partes, porém, é que seja possível, a partir das informações prestadas pelo autor, localizar o réu a fim de citá-lo. É por essa razão que o art. 319, § 2.º, do CPC, refere que, a despeito de não estarem completas as informações, a petição inicial não será indeferida, se for possível a citação do réu.

As partes no processo, tendencialmente, refletem as partes na relação de direito material que se afirma existente ou inexistente em juízo [ressalvados os casos de legitimação extraordinária, art. 18 do CPC]. Por exemplo, em uma ação de despejo por falta de pagamento, são tendencialmente partes o locador (autor) e o locatário (réu). Diz-se que são tendencialmente partes no processo em que se discute a relação de locação o locador e locatário, porque, à luz do direito material, esses figurantes são as partes legítimas para tanto. Obviamente, porém, a noção de parte não depende do direito material: uma coisa é o conceito de parte; outra, o conceito de parte legítima. O art. 319, II, do CPC, exige apenas a identificação das partes – quem pede e contra quem se pede tutela jurisdicional, isto é, a identificação das pessoas que irão litigar. Saber se as partes são legítimas para a causa – ou não – é uma questão que tem de ser decidida pelo juízo durante o processo.

Recorda Calmon de Passos que nem sempre é necessário individualizar o réu da demanda, na forma exigida por lei. Há diversos casos disciplinados pelo direito processual que tratam da existência de interessados incertos, que não podem ser identificados previamente. Tal sucede, por

exemplo, com uma das hipóteses de citação por edital (arts. 256, I e 259, III, do CPC) ou com a usucapião extrajudicial (art. 216-A, da Lei 6.015/1973). Nesses casos, evidentemente, será dispensável o cumprimento da imposição contida no art. 319, II, do CPC em relação ao réu; em relação ao autor, porém, a determinação é sempre necessária.<sup>3</sup>

## 5. Causa de pedir

Na petição inicial, exige o art. 319 do CPC que o autor apresente uma causa ou razão que justifique o pedido que é dirigido ao órgão jurisdicional. Trata-se da causa de pedir, ou seja, das razões fático-jurídicas que justificam o pedido.<sup>4</sup>

O autor deve afirmar um fato essencial juridicamente qualificado e apresentar o seu nexo com um efeito jurídico. Deve oferecer o fato constitutivo do direito que reclama em juízo.<sup>5</sup> O autor, em outras palavras, narra o fato jurídico que constitui o direito por ele afirmado. Esse fato jurídico é o chamado fato essencial, que é todo aquele do qual decorre a consequência jurídica pretendida pela parte em juízo. Apenas o autor, por meio da causa de pedir, e o réu, por meio da alegação de defesas indiretas na contestação, podem trazer fatos essenciais a juízo a fim de delimitar o litígio que deve ser examinado pelo juiz (art. 141 do CPC).

Inexistem fatos puros<sup>6</sup> – assim como não existem ontologicamente direitos que independem dos fatos. A norma é sempre um programa para a interpretação dos fatos. Os fatos são sempre alegações que aparecem já formuladas através de determinada visão normativa no processo. É por essa razão que a causa de pedir, longe de ser uma neutra narrativa em que se pode separar com precisão alegações de fato de fundamentos jurídicos, constitui uma unidade fático-jurídica em que as razões apresentadas em juízo pela parte são concebidas a partir de uma determinada visão a respeito do caso. Daí a razão pela qual é correto afirmar que a causa de pedir é uma unidade fático-jurídica denotada por um fato essencial juridicamente qualificado, não constituindo uma simples junção de fatos e de direito.<sup>7</sup>

O Código de Processo Civil cataloga os fatos essenciais em fatos constitutivos e em fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito. É importante, portanto, saber a natureza de determinado fato – até mesmo porque o autor tem o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos e o réu quanto aos demais (art. 373 do CPC).

Escrevendo sobre os fatos jurídicos, afirma Chiovenda que os fatos constitutivos são aqueles que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém, exemplificando-os aludindo ao empréstimo, ao testamento, ao ato ilícito e ao matrimônio. Os fatos extintivos são aqueles que “fazem cessar uma vontade concreta da lei e a consequente expectativa de um bem. Por exemplo: pagamento; remissão de dívida; perda da coisa devida”.<sup>8</sup>

Como já foi dito, as circunstâncias de fato que têm por escopo específico dar vida a um direito, e que normalmente produzem esse efeito, devem ser chamadas de “fatos constitutivos”. Entretanto, para que essas circunstâncias possam realmente dar vida a um direito, devem apresentar-se outras, cuja falta impede que o direito possa ter vida. Quando falta uma das circunstâncias que devem concorrer com os fatos constitutivos, há um fato impeditivo. Segundo Chiovenda,

Todo direito nasce de determinadas circunstâncias que têm por função específica dar-lhe vida; contudo, para produzirem o efeito que lhes é próprio, normal, devem concorrer outras circunstâncias.

Existindo uma circunstância que impeça um determinado fato de produzir o efeito que lhe é normal, há fato impeditivo.<sup>9</sup>

Já os fatos modificativos são aqueles que pressupõem válida a constituição do direito, mas tendem a alterá-lo, tal como ocorre, por exemplo, com a moratória concedida ao devedor.<sup>10</sup> Se o autor pede o pagamento da dívida, e o réu alega que ela foi parcelada, somente podendo ser exigida em parte, o fato é modificativo; se o réu alega pagamento, o fato é extintivo; se o réu alega exceção de contrato não cumprido, o fato é impeditivo.<sup>11</sup>



Como diz Proto Pisani, não há grande dificuldade para distinguir entre fatos constitutivos e fatos modificativos ou extintivos. Todavia, problemática, e de imensa dificuldade, é a distinção entre fatos constitutivos e impeditivos. O processualista afirma que, na ausência de critérios lógico-formais, a distinção entre fatos constitutivos e fatos impeditivos deve ser efetuada com base em critérios empíricos.<sup>12</sup>

Costuma-se dividir a causa de pedir em remota e próxima. A primeira seria o título aquisitivo do direito (a origem do direito). Já a segunda seria a ameaça ao direito que se pretende evitar ou a violação ao direito que se pretende reparar. Assim, em uma demanda que visa à cobrança de determinada quantia em dinheiro, a causa de pedir remota seria a origem do crédito (um empréstimo, por exemplo, falando-se aí em direitos heterodeterminados), enquanto a causa de pedir próxima seria o não adimplemento, no prazo, da obrigação. Afirma-se também que algumas demandas dispensam a indicação da causa de pedir remota, exigindo apenas a próxima (a exemplo das demandas fundadas em direito real – falando-se aí em direitos autodeterminados).

A rigor, desde que bem compreendida a noção de causa de pedir – vale dizer, desde que compreendida a partir do direito material – a divisão é desnecessária. Basta recordar que o processo trabalha com a noção de pretensão, de modo que a causa de pedir deve espelhar os fatos jurídicos que dão origem à pretensão cuja satisfação ou prevenção se deseja. Assim, se para o exercício de uma pretensão for desnecessário indicar a origem remota do direito ameaçado ou violado, então é evidente que esses fatos não comporão a causa de pedir desta demanda. Por outro lado, se a indicação dessa origem compuser a norma de onde ressaí a pretensão que se exerce, então esses fatos também serão fundamentais para a determinação da causa petendi. Enfim, ciente dos fatos que determinam a existência de uma pretensão, todos esses deverão compor a causa de pedir de uma demanda.

É possível, contudo, que a petição inicial invoque mais de uma causa de pedir. Isso pode ocorrer quando: (i) são invocados fatos de igual estrutura, que repercutem na esfera jurídica de uma pessoa: pede-se anulação de contrato alegando que o réu, por diversas vezes, violou determinada cláusula de contrato;<sup>13</sup> (ii) são invocados fatos de igual estrutura, que conduzem a efeitos jurídicos que repercutem em diferentes esferas jurídicas: dois autores, proprietários de casas vizinhas, afirmam que o réu, por culpa, causou danos a seus imóveis; e (iii) são invocados fatos de estrutura diferente: pede-se o despejo do réu com base no não pagamento do aluguel e no uso indevido do imóvel.<sup>14</sup>

Como se vê, pode ocorrer a existência de: (i) vários fatos de igual estrutura com repercussão na esfera jurídica de uma pessoa; (ii) vários fatos de igual estrutura com repercussão nas esferas jurídicas de diversas pessoas; e (iii) vários fatos de diferente estrutura com repercussão na esfera jurídica de uma pessoa. Frise-se que, quando se fala em fato com repercussão em esfera jurídica, alude-se a uma causa de pedir.

O relevo que a legislação brasileira oferece a respeito do fato jurídico para determinação da causa de pedir permite que se afirme que o nosso direito adotou a teoria da substanciação para a caracterização da causa de pedir. Vale dizer: como regra, a causa de pedir pode ser considerada delineada com a invocação do fato jurídico essencial que dá lugar ao pedido. É o que ocorre com a maioria dos direitos, cuja demonstração depende da exposição do fato que lhe deu origem (os chamados direitos heterodeterminados). Excepcionalmente, porém, nos casos em que a própria legislação dispensa a caracterização do fato para prova da aquisição do direito – como ocorre com os direitos reais, chamados por essa razão de autodeterminados – é que se tem a adoção da teoria da individualização, em que basta a invocação do título para delimitação do direito alegado em juízo.<sup>15</sup>

Assim como é vedado ao juiz julgar a causa genericamente, fundamentando de forma vaga e desligada do caso concreto a sua decisão (art. 489, §§ 1.º e 2.º, do CPC), também é defeso à parte alegar genericamente na petição inicial o seu direito. Em outras palavras, assim como há dever judicial de fundamentação analítica, há simetricamente ônus de alegação específica das partes. Isso quer dizer que a parte tem o ônus de sustentar justificadamente suas posições jurídicas na petição inicial (art. 319, III, do CPC) – e o mesmo vale, por uma questão de igualdade (arts. 5.º, I,

CF/1988 e 7.º do CPC), para o réu na contestação (art. 336 do CPC). Não tendo a parte desempenhado adequadamente o seu ônus de alegar justificadamente, tem o juiz o dever de determinar o esclarecimento das suas alegações (art. 321 do CPC).

Sob outro ângulo, para atender ao art. 319, III, do CPC, é correto afirmar que o autor deve afirmar um fato e apresentar o seu nexos com um efeito jurídico. Não atende ao art. 319, III, do CPC, a simples indicação, reprodução ou paráfrase de texto normativo: é preciso que a parte contextualize as suas afirmações, mostrando qual a sua relação concreta com o caso que pretende ver julgado a seu favor (analogicamente, art. 489, § 1.º, I, do CPC). Ainda, por força da adoção da técnica legislativa aberta em muitos passos na legislação brasileira, seja pelo emprego de cláusulas gerais, seja pelo emprego de conceitos jurídicos indeterminados, não basta a simples alusão a normas que contenham termos vagos (por exemplo, dignidade da pessoa humana, função social e boa-fé) para solução dos casos: é preciso mostrar em primeiro lugar qual é o significado que está sendo adscrito ao termo vago e é necessário mostrar por qual razão o caso que se pretende debater em juízo está dentro da moldura normativa proposta na petição inicial (analogicamente, art. 489, § 1.º, II, do CPC). Ademais, assim como é vedado ao juiz valer-se de postulados como a proporcionalidade, a razoabilidade e a ponderação sem justificar adequadamente a maneira como essas normas incidem para solução de conflitos entre outras normas, também é vedado à parte invocar semelhantes normas sem justificar apropriadamente por qual razão incidem e como contribuem para interpretação e aplicação de outras normas (analogicamente, art. 489, § 2.º, do CPC). O mesmo vale obviamente para a aplicação dos princípios: é preciso mostrar quais são os estados de coisas que os princípios visam a promover e de que modo essas finalidades determinam ou não a solução do caso apresentado na petição inicial (analogicamente, art. 489, §§ 1.º, I e 2.º, do CPC).

De outra parte, é tradicional no direito brasileiro reconhecer que não pertence à causa de pedir o nomen iuris dado ao efeito jurídico pretendido pela parte, ou o dispositivo de lei que é eventualmente usado para basear os argumentos. É evidente que não existem fatos puros, como já dito, de modo que sempre a alegação de fatos no processo se faz com vistas a atingir certo objetivo. Porém, a circunstância de a parte indicar equivocadamente certa legislação para basear os efeitos pretendidos, ou qualificar de modo errôneo a categoria em que o fato se insere é absolutamente irrelevante para o processo.<sup>16</sup> Fundamental será apenas examinar se dos fatos indicados efetivamente decorre ou não o efeito buscado.<sup>17</sup>

Por fim, embora não conste no rol do art. 319, constitui requisito da petição inicial e, especificamente, requisito concernente à causa de pedir, a discriminação das obrigações contratuais controvertidas e a quantificação do valor incontroverso do débito nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens (art. 330, § 2.º). Obviamente, o valor incontroverso não constitui matéria judicializada e, portanto, não pode modo algum ser alcançado pelo resultado do processo – pela simples razão de que não compõe o mérito da causa. Por essa razão, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados, de acordo com o direito material que rege a espécie (art. 330, § 3.º).

## **6. Pedido**

O pedido consiste naquilo que, em virtude da causa de pedir, postula-se ao órgão julgador. O autor postula ao juízo basicamente o emprego de uma técnica processual que permita a prestação da tutela do direito. Pede, em outras palavras, uma providência processual a fim de que o direito material possa ser tutelado. Nessa linha, como o pedido tem duas faces essenciais. Diz-se que o pedido divide-se em pedido imediato e pedido mediato – o primeiro concerne à técnica processual, ao passo que o segundo diz respeito à tutela do direito.

Assim, quando se alude ao pedido imediato, pensa-se na espécie de sentença – e consequentemente no tipo de pedido – que é requerida ao órgão jurisdicional. Nesse sentido, fala-se em pedido declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental e executivo. Essas cinco espécies de pedido são capazes de veicular a satisfação ou o acautelamento de qualquer espécie de tutela do direito.<sup>18</sup> Essas categorias serão pormenorizadamente examinadas adiante (comentários

à Seção II – Do pedido), remetendo-se o leitor aos respectivos comentários. Por ora, basta observar que esse pedido imediato também compõe o pedido que deve ser formulado pela parte autora, embora sua importância tenha sido substancialmente reduzida no modelo atual.

O pedido mediato é o bem da vida pretendido pelo autor. Assim, por exemplo, a declaração da certeza jurídica (sentença declaratória); a criação de nova situação jurídica, a modificação de um contrato ou sua anulação (sentença constitutiva ou desconstitutiva); o pagamento da quantia (sentença condenatória); a abstenção da adoção de comportamentos poluidores do meio ambiente (sentença mandamental); a coisa reivindicada (sentença executiva).

Portanto, na petição inicial, precisa o autor relacionar a técnica processual com a tutela do direito: deve pedir a prolação de uma determinada sentença a fim de que possa obter determinado bem da vida. Assim como o processo serve de instrumento para realização do direito material, o pedido imediato serve como meio para obtenção do pedido mediato. Daí a razão pela qual se tem que entender que o pedido imediato tem de ser idôneo para realização do pedido mediato, ao mesmo tempo em que tem de ser formulado de modo que a sua concretização cause a menor restrição possível à esfera jurídica do demandado.

## **7. Valor da causa**

Ao litígio posto em juízo deve ser dado um valor. Ainda que o litígio não tenha valor econômico imediatamente aferível, ou não configure propriamente um litígio – por não haver conflito entre as partes –, toda causa que deva ser objeto de prestação jurisdicional deve ser valorada (art. 291).

O valor da causa – que é requisito obrigatório da petição inicial (arts. 291 e 319, V) – pode ser legal ou estimado. A primeira hipótese ocorre quando a lei apresenta critérios para que o valor da causa seja fixado, sendo que, na outra hipótese, diante da ausência desses critérios, somente resta ao autor estimá-la.

O art. 292 encarrega-se de estabelecer critérios para que sejam fixados os valores de algumas causas. Na ausência de critérios legais para que seja fixado o valor da causa, o autor deve proceder por estimativa.

O valor da causa sempre deve retratar o estado fático-jurídico da causa que existe no momento da apresentação da petição inicial. Isto significa que qualquer alteração posterior à propositura da ação que possa repercutir no valor atribuído à causa não deve ser tomada em conta.

Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano. Se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Nesse caso, determinará de imediato o recolhimento das custas correspondentes.

## **8. Requerimento de provas**

Tem o demandante o ônus de indicar na petição inicial os meios de prova com que pretende mostrar a veracidade do que alega em juízo. Nesse momento, porém, pode a parte formular um pedido genérico de produção de provas, na medida em que, sem a contestação do demandado, ainda não dispõe de todos os elementos necessários para saber qual será a matéria controvertida. A ausência de indicação precisa do meio de prova na petição inicial, portanto, não torna preclusa a possibilidade de indicá-lo oportunamente. Não estando especificados os meios de prova com que as partes pretendem provar suas alegações até o momento oportuno para a organização do processo, tem o juiz de intimá-las a fim de que essas as especifiquem, a fim de que o juiz possa decidir a respeito (art. 321).

A doutrina formada na vigência do Código anterior criticava veementemente a exigência,

diante de sua absoluta inutilidade.<sup>19</sup> De fato, em se tratando de mero requerimento genérico, a medida se torna absolutamente imprestável, sobretudo neste momento do processo. As partes não têm ainda a exata noção dos fatos controvertidos sobre os quais deverá incidir a atividade probatória e por isso não tem como fazer um prognóstico sobre os meios de prova a serem empregados. Por isso, de regra, esse requisito costuma se traduzir em um rol amplo e sem nenhum sentido de todos os meios de provas disponíveis. Só depois, à vista do estado da controvérsia, é que realmente se concretizarão os fatos cuja afirmação ainda depende de prova e, portanto, que haverá novo momento para requerimento das provas a serem efetivamente empregadas.

Por outro lado, recorde-se ainda que, quanto à prova documental do autor, ela é de regra anexada à petição inicial (art. 434, do CPC). Desse modo, o requerimento de prova documental, na inicial, desacompanhado dos respectivos documentos significa, de regra, preclusão em relação a esse meio de prova. Por outro lado, a juntada dessa prova com a inicial sem o correspondente requerimento na peça deve ser interpretado como simples irregularidade, sem qualquer consequência. De todo modo, absolutamente sem função o requerimento. O Código, que já retirou a previsão da lei anterior que impunha que constasse da petição inicial o requerimento de citação do réu – já que percebeu que, ainda que ausente esse requerimento, a citação é imposição constitucional – poderia também ter evoluído para retirar a exigência do requerimento de prova.

### **9. Opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação**

A fim de facilitar a solução consensual do litígio (art. 3.º, § 2.º), o legislador desenhou o procedimento comum de modo a proporcionar às partes uma oportunidade de diálogo antes de se encontrar bilateralmente estabelecido o litígio no processo, isto é, antes de oferecida a contestação. A oportunidade para tanto é a audiência de conciliação ou de mediação (art. 334). Essa audiência, no entanto, não será realizada se “ambas as partes” manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou se a natureza do direito não admitir a autocomposição (art. 334, § 4.º, I). Daí a razão pela qual tem o autor de manifestar expressamente a sua opção ou não pela realização da audiência de conciliação ou de mediação (art. 319, VII).

Sublinhe-se, porém, que a manifestação do autor, sozinho, no sentido do desinteresse na autocomposição não autoriza o magistrado a dispensar essa audiência. Somente a manifestação de “todas as partes” autoriza o juiz a dispensar a fase de autocomposição preliminar, de modo que a intenção posta na petição inicial serve apenas para sinalizar ao réu o desejo do autor. O réu tem toda liberdade para anuir ou não a essa proposta inicial.

Ausente qualquer manifestação expressa do autor, presume-se seu interesse na fase de autocomposição, mesmo porque essa é a opção preferencial do Código de 2015 (art. 3.º, §§ 2.º e 3.º, do CPC). A omissão no preenchimento desse requisito da petição inicial, portanto, não deve importar o dever de emenda à inicial (art. 321), nem será entrave à instauração da audiência. Ao contrário, será sinal de que a audiência de autocomposição é etapa necessária no processo.

### **10. Outros requisitos da petição inicial**

O art. 319 não esgota os requisitos que a petição inicial deve preencher. Vários outros preceitos indicam manifestações que devem (ou podem) estar contidas na inicial, de modo que se deve sempre estar atento ao conjunto da legislação processual.

Em primeiro lugar, é necessário, conforme estabelece o art. 321, do CPC, que a petição inicial descreva o conflito de modo que permita ao magistrado a análise do mérito. Por isso, a petição não pode conter defeitos ou irregularidades que dificultem esse exame.

Também é elemento necessário da petição inicial a indicação pelo advogado da sua capacidade postulatória, o que se faz por meio da indicação de seu número de inscrição válido na Ordem dos Advogados do Brasil. Ademais, seja na petição inicial ou na procuração, deve ser apresentado o endereço do advogado, eletrônico e não eletrônico (art. 287, do CPC), para viabilizar sua intimação dos atos processuais.

A petição inicial ainda deve indicar, se for o caso, o interesse em, diante do requerimento de tutela antecipada antecedente, realizar o aditamento a que se refere o art. 303, § 1.º, I (art. 303, § 5.º).

Também é a petição inicial o veículo adequado para a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita inicial (art. 99, do CPC).

Os requerimentos de intervenção de terceiros, formulados pelo autor, de regra, também são apresentados na petição inicial. Assim, por exemplo, havendo interesse na denúncia da lide, cabe ao autor formular o requerimento da citação do litisdenunciado na inicial (art. 126); o mesmo pode ocorrer se o autor tiver interesse na desconsideração da personalidade jurídica do réu (art. 134, § 2.º).

**Art. 320.** A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

### **1. Documentos indispensáveis à propositura da ação**

Afirma o preceito em exame que a petição inicial deve estar acompanhada de alguns documentos.

Evidentemente, esses documentos não se confundem com a prova documental eventualmente anexada à petição inicial. A prova documental é simples meio de prova. Sua anexação ao processo satisfaz *ônus* da parte – e eventualmente até dever processual – ligando-se à conduta realizada em seu próprio interesse, no sentido de demonstrar a ocorrência dos fatos deduzidos no processo.

Já os documentos a que alude o art. 320, do CPC, tratam a rigor de condição para o prosseguimento do processo. Por outras palavras, tais documentos não se dirigem a satisfazer *ônus* processual. Destinam-se simplesmente a permitir que a causa possa ser processada. Recorde-se que a infração ao art. 320, do CPC, pode resultar na aplicação do art. 321, levando em última análise ao indeferimento da petição inicial.

Sem qualquer sombra de dúvida, a falta de juntada de prova documental anexa à petição inicial jamais redundaria nessa mesma consequência. Como meio de prova, estes documentos só se destinam a demonstrar os fatos discutidos no processo. Assim, a não apresentação desse meio de prova pode até mesmo ser irrelevante, se o fato puder ser provado por outro meio (prova testemunhal, depoimento da parte, prova pericial) ou até mesmo se o fato sequer se tornar controvertido (art. 374, do CPC).<sup>20</sup>

Desse modo, não se pode confundir a previsão do art. 320, do CPC, com aquela do seu art. 434. Os prazos a que aludem o art. 434, por tratarem da prova documental, implicam, se descumpridos, simples preclusão temporal à juntada da prova. Desse modo, se o autor não juntar a “prova documental” que queira com a petição inicial, isso importará apenas em preclusão quanto ao emprego desse meio de prova para a demonstração dos fatos alegados com a petição inicial.

Ao contrário, desobedecida a juntada dos documentos a que se refere o art. 320, do código, deve o juiz determinar ao autor que corrija o defeito; e, não havendo a correção no prazo de quinze dias, a petição inicial deve ser indeferida (arts. 321 e 330, IV, do CPC).

Desse modo, sobretudo diante das consequências distintas na ausência de juntada de um ou de outro documento, é necessário distinguir entre a prova documental e os documentos indispensáveis. E a diferença reside justamente na avaliação de documentos que são tão imprescindíveis para o processo que, se não juntados, devem determinar a extinção prematura do feito.

Quais seriam então esses documentos indispensáveis?

### **2. Prova dos pressupostos processuais**

A primeira espécie de documento indispensável ao ajuizamento da demanda é aquela que tem

por objetivo demonstrar a satisfação dos pressupostos (positivos e negativos) de constituição da relação processual.<sup>21</sup>

Como cediço, ausentes os pressupostos processuais, não se consegue validamente instaurar ou dar prosseguimento à relação processual. Por isso, para a instauração do processo, deve a parte demonstrar a satisfação desses requisitos, sendo esses documentos indispensáveis à propositura da demanda.

É o caso, por exemplo, da comprovação do pagamento das custas do processo anterior, caso ele tenha sido extinto sem resolução de mérito (art. 486, § 2.º).

É este também o caso da prova da capacidade processual (de ser parte e de estar em juízo) do autor. A prova da regular constituição da empresa demandante, ou dos poderes de representação que exerce o seu representante legal (e que o autoriza a, em nome da empresa, manifestar a vontade desta na propositura da demanda), é documento que, ausente, não permite a propositura da demanda, uma vez que subtrai do magistrado o poder de avaliar a capacidade de ser parte ou de estar em juízo do postulante. A prova da representação do incapaz, dos poderes outorgados aos apoiadores ou do termo de curatela, na mesma linha, é indispensável para que se possa aferir se a parte está adequadamente representada ou assistida ou apoiada e para que se possa avaliar se o desempenho dos atos processuais é e será adequadamente realizado.

Também entra nesta mesma hipótese a prova do mandato judicial, que deve instruir necessariamente a petição inicial, a fim de demonstrar que o advogado realmente representa a parte autora em juízo (arts. 104 do CPC e 5.º da Lei 8.906/94). É certo que este documento tem regime especial, mas ainda assim sua função no processo certamente o coloca como documento indispensável à propositura da demanda. Especificamente em relação a este documento, vale lembrar que a própria lei autoriza a prática de atos urgentes pelo advogado sem procuração, desde que se comprometa a juntar o instrumento de mandato em quinze dias, prorrogável por igual período (arts. 104, in fine, do CPC e 5.º, § 1.º, da Lei 8.906/1994).

### **3. Documento exigido pela lei para o uso de certo procedimento**

Também devem considerar-se documentos essenciais aqueles cuja apresentação é requisito necessário para a utilização de determinado tipo de procedimento ou para que se possa postular certa variação procedimental.<sup>22</sup>

Tal é o caso da execução, que exige a exibição de título executivo.

É, ainda, o que sucede, por exemplo, com a ação monitória que, para sua propositura, exige que a parte instrua a petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo de qualquer modalidade de obrigação (art. 700). Semelhante também é a imposição presente para a ação de consignação em pagamento. Segundo o art. 539, § 3.º, do Código, para esta demanda é necessário que o autor instrua a petição inicial com prova do depósito e da recusa (art. 539, § 3.º). Também assim ocorre com a ação demarcatória (art. 574) ou com a ação divisória (art. 588), que só podem ser propostas se a inicial vier instruída com os títulos de propriedade, ou com a ação de dissolução parcial de sociedade, que obrigatoriamente deve estar instruída com o contrato social consolidado (art. 599, § 1.º).

Em todos estes exemplos observa-se que a lei condiciona o uso de certo procedimento especial à exibição *in initio* de algum documento. Sem ele, o rito não pode ser empregado, de modo que a inicial deve ser indeferida.

Também se insere nessa hipótese o caso da tutela provisória a que alude o art. 311, III, do CPC. Para sua viabilidade, exige-se prova documental do contrato de depósito, de modo que o emprego dessa variação do procedimento só pode surgir a partir desse documento específico.

### **4. Documento objeto da demanda**

Outro caso em que será indispensável a juntada de documento com a petição inicial será



quando este documento represente o próprio objeto da ação.

É o que ocorre com a ação declaratória (principaliter) de falsidade documental. Aqui, o documento questionado não é apenas a prova da alegação feita pela parte. É o próprio objeto da demanda. Sem ele não se pode sequer cogitar da possibilidade de exercer a pretensão. É, então, este documento, essencial à propositura da ação.

O mesmo sucede no procedimento de homologação de sentença estrangeira, em que é essencial a anexação ao processo da sentença cuja homologação se pretende, já que esta é, precisamente, o objeto sobre a qual recairá a atividade jurisdicional.<sup>23</sup>

## **5. Documento da substância do ato**

Em doutrina, há ainda quem considere que ingressa nessa categoria os documentos que sejam da substância do ato.<sup>24</sup> Calmon de Passos,<sup>25</sup> por exemplo, afirma que não se pode propor ação reivindicatória de imóvel sem a prova do domínio, a qual somente pode ser feita por escritura pública ou particular regularmente transcrita no Cartório de Registro de Imóveis. Da mesma forma, segundo o autor, não se poderia pensar em ação de divórcio sem a prova da existência do casamento, a qual só é feita com o registro civil de casamento.

A rigor, poder-se-ia pensar que esses documentos deveriam ter tratamento diverso. De fato, esses documentos “são prova documental das afirmações postas na inicial”. Embora constituam única prova admissível (art. 406) – porque integrantes da própria validade do ato praticado – não perdem seu caráter de simples prova das alegações. Sua ausência, portanto, deveria redundar na aplicação do ônus da prova e, de consequência, importar a conclusão de que o fato (v.g., propriedade ou casamento) não existiu.

Porém, parece que a solução preconizada por Calmon de Passos tem franca vantagem sobre a estrita aplicação da regra do ônus probatório. De fato, não parece razoável que se extinga um processo com resolução de mérito, em prejuízo do autor, porque ele não anexou à inicial documento essencial.

Aliás, veja-se que a aplicação do ônus da prova não exige a prévia concessão de prazo para sanar o defeito, já que não se trata propriamente de um defeito processual. Segue daí que, não juntada a prova do casamento, a se aplicar a regra do ônus probatório, haveria preclusão quanto a essa prova que, por ser da substância do ato, implicaria de antemão a conclusão da inexistência do casamento, tornando totalmente inútil o prosseguimento do processo. Parece que essa solução seria drástica demais e sequer se amoldaria ao princípio da cooperação que preside a relação processual.

Por isso, considerar esse tipo de prova documental como “documento indispensável” parece conferir-lhe tratamento mais adequado.

## **6. Documentos indispensáveis e polo passivo do processo**

Embora o código não o diga expressamente, é certo que não é só o autor que tem que apresentar, desde logo, documentos que são fundamentais para o seguimento adequado da relação processual. O mesmo raciocínio que leva a concluir pela existência de documentos indispensáveis à “propositura da ação” faz com que se afirme que há documentos indispensáveis ao “oferecimento da defesa”.

Sem dúvida, o réu não pode defender-se nos autos sem a prova da sua constituição regular e da legitimidade da representação, ou “apresentação”, de quem a expressa (em caso de pessoa jurídica), ou também sem a prova do mandato do advogado constituído. Tratando-se de pessoa incapaz, será necessário que a defesa venha acompanhada de documentos que demonstrem a conformação adequada da capacidade de estar em juízo, por exemplo, com a prova da tutela ou da curatela.

Eventualmente, as mesmas exigências do art. 320 podem impor-se sobre o réu na hipótese em que deduz pretensão nos autos, a exemplo do que ocorre quando oferece reconvenção ou no caso



de ações dúplices.

## **7. Impossibilidade de juntada dos documentos indispensáveis**

Calmon de Passos recorda ainda que, na vigência do Código de 1939, previa o art. 159, parágrafo único, que a parte não tinha o dever de juntar com a inicial os documentos existentes em notas, registros, repartições ou estabelecimentos públicos e houvesse demora ou inviabilidade em extrair certidões ou pública-forma ou ainda quando esses documentos estivessem em posse do réu.<sup>26</sup>

O dispositivo não foi repetido nem pelo Código de 1973, nem pela lei atual.

No entanto, a questão não apenas merece atenção, como certamente a incidência do art. 320, aqui, é inadequada. Sem dúvida, não se pode impor uma obrigação à parte autora que lhe seja impossível e que, ao mesmo tempo, inviabilize o ajuizamento de uma demanda. Isso violaria claramente o contido no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

Por isso, nesses casos, se a parte não dispõe do documento e não tem condições de obtê-lo, deve-se autorizar o ajuizamento da demanda sem esse “documento indispensável”, que será anexado posteriormente no processo.

Calmon de Passos sugeria, perante o Código de 1973, que fossem usados nesse tipo de caso as regras sobre a exibição de documentos em posse de órgãos públicos (art. 399, do CPC/1973), entendendo ainda que não poderia haver preclusão nesse caso porque haveria justa causa para extrapolar o prazo legal.<sup>27</sup>

Parece que a mesma solução merece ser aplicada perante o Código atual. Não há dúvida de que a impossibilidade de juntada dos documentos indispensáveis com a inicial, nesses casos, implica justa causa, nos termos do art. 223, § 1.º, do CPC. Por isso, é possível que o ato – a juntada dos documentos indispensáveis – seja feito depois do momento legal, em prazo a ser assinalado pelo juiz à luz das circunstâncias concretas (art. 223, § 2.º). E, nesse prazo, deverá a parte autora seja requerer a exibição de documento ou coisa, contra a parte ou contra terceiro, nos moldes dos art. 396 e ss., se o documento indispensável estiver em mãos do réu ou de terceiro, seja requerer a apresentação do documento na forma do art. 438, se ele estiver guardado em repartição pública.<sup>28</sup>

Evidentemente, tudo isso pressupõe a inviabilidade de busca do documento indispensável antes do ajuizamento da ação. Se, ao contrário, inexistir essa urgência, então deverá a parte lançar mão dos mecanismos existentes para a obtenção do documento – a exemplo do habeas data, da produção antecipada de prova ou de outra medida extrajudicial – e só então ajuizar a demanda munido do documento indispensável.

**Art. 321.** O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

### **1. Determinação de emenda à petição inicial**

Atendendo à ideia da aproveitabilidade dos atos processuais, impõe o código que, percebendo o juiz defeitos na petição inicial que inviabilizem o prosseguimento da demanda, deva ele alertar o problema ao autor, assinando-lhe prazo para correção. Por outras palavras, a inobservância dos requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320, do CPC, ou mesmo a elaboração de petição que contenha problemas que dificultem a análise do mérito, não devem implicar, ipso facto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.

Ao contrário, tem o juiz o “dever” de permitir que a parte corrija o problema, concedendo-lhe prazo de quinze dias para tanto. Assim deve ser porque o direito à tutela jurisdicional é garantia fundamental, de sorte que, sempre que possível, ela deve ser prestada.<sup>29</sup>

O prazo de quinze dias, por óbvio, não é impositivo para o juiz. Nos termos do que prevê o art. 139, VI, do Código, pode o juiz dilatar prazos processuais, o que significa dizer que o prazo estabelecido no art. 321 é o mínimo que deve ser concedido para a correção do defeito. Porém, à vista da complexidade da questão, nada impede que o juiz outorgue prazo maior do que o legal.

Identicamente, nada impede que o juiz, verificando que o autor tentou corrigir o defeito, sem sucesso, conceda novo prazo para sanar o problema.<sup>30</sup>

Em todos os casos, o prazo é contado na forma do art. 219, do CPC, ou seja, apenas em dias úteis.

Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito.

As duas primeiras hipóteses não põem maiores dificuldades. Com relação aos requisitos da petição inicial, “faltando” esses elementos – a exemplo da indicação das partes, da causa de pedir ou de pedido – é evidente a irregularidade, por violação ao art. 319, do CPC. O mesmo se diga em relação aos documentos indispensáveis, a que alude o art. 320. Faltando esses dados – que são fundamentais para a propositura da ação – não há como prosseguir na análise da controvérsia. Por isso, impõe-se a correção do problema, para que o processo tenha seguimento.

Em relação, porém, à presença de “defeitos e irregularidades” que dificultam o julgamento de mérito, a questão é mais problemática. O que seriam, afinal, esses defeitos e irregularidades que autorizam a emenda da petição inicial? Ao contrário da verificação dos elementos arrolados nos arts. 319 e 320, do código, que implicam simples avaliação formal, a análise dos “defeitos e irregularidades” exige avaliação de conteúdo da petição inicial. Em especial, impõe a consideração da consistência dos argumentos trazidos com a inicial e, em particular, a verificação sobre se, neles, há defeitos e irregularidades que dificultem o julgamento do mérito da controvérsia.

Segundo Calmon de Passos, a diferença entre “defeitos e irregularidades” está em que o defeito se liga ao “modo de enunciar” as afirmações contidas na petição inicial; já as irregularidades estão atreladas ao “modo de dispor”.<sup>31</sup> A distinção, a rigor, é irrelevante. O que importa é saber se, das afirmações contidas na petição inicial, é possível compreender adequadamente o pedido, a causa de pedir e, enfim, os elementos do conflito. Não o sendo, havendo dificuldades na compreensão desses elementos – que gizam os contornos do litígio – então é o caso de emenda à inicial. Sendo compreensíveis o litígio e seus elementos, por mais que a petição inicial esteja mal redigida ou não agrade a autoridade judicial, deve ela ser processada.

Por isso, é indispensável que esses “defeitos ou irregularidades” sejam fundamentais à análise da controvérsia.<sup>32</sup> Havendo problema apenas circunstancial, lateral, que não atrapalhe a análise da controvérsia, a petição inicial deve ser recebida.

Finalmente, por questão de lógica, a aplicação do art. 321, do CPC, pressupõe que o defeito “possa e precise efetivamente ser corrigido”.

Assim, por exemplo, se a petição inicial não declara expressamente se pretende ou não a realização de audiência de conciliação ou mediação (art. 319, VII), evidentemente não se exige a emenda. Esse silêncio implica a conclusão pela viabilidade da autocomposição, sendo desnecessário oferecer à parte prazo para a emenda e, a fortiori, incabível o indeferimento da petição inicial. Na mesma linha, se a parte deixa de juntar prova escrita da obrigação (art. 700), ainda que pretenda submeter seu pleito ao regime da ação monitória, não há a necessidade de emenda à inicial, bastando que o feito seja processado sob o rito comum, e não pelo especial.

Sob outro ângulo, se o autor não junta documento indispensável porque declaradamente ele

não existe, seria ilógico conceder prazo para sanar o defeito, já que, mesmo assim, o defeito persistiria. Suponha-se a declaração, na petição inicial, da inexistência de instituição da tutela da parte; faltarão documento indispensável, nos termos do art. 321. Porém, a outorga de prazo para a sanção do defeito seria totalmente inútil, já que o documento não existe e, por isso, nem no prazo dado pela lei seria ele juntado aos autos.

## **2. Deveres de prevenção e de esclarecimento e emenda à inicial**

Afirma a doutrina que o defeito que autoriza a emenda é aquele que dificulta a análise do mérito. Se impede, seria inaplicável o art. 321, sendo o caso de indeferimento imediato da petição inicial, por inépcia (art. 330, § 1.º, do CPC).<sup>33</sup>

Não parece que essa solução encontre respaldo no modelo atual. Considerando que, em todos os casos nos quais haja defeitos sanáveis, é dever do magistrado permitir a correção do problema antes de extinguir o processo (art. 317), não há dúvida de que, ainda que o “defeito ou irregularidade” impeça [e não apenas dificulte] a análise do mérito, deve-se – se possível – permitir a emenda.

Mais do que isso, os deveres inerentes ao processo cooperativo (art. 6.º, do CPC) – especialmente os de prevenção e de esclarecimento – impõem que o magistrado, notando a viabilidade de uma demanda, “sempre” permita a correção de defeitos ou de irregularidades, de forma a garantir o processamento da discussão. Assim, desde que a inicial reflita um conflito que possa ser submetido à análise do Poder Judiciário, qualquer defeito encontrado na petição só deve levar à extinção do processo se for absolutamente impossível o aproveitamento daquilo que foi apresentado.

Do contrário, impõe-se a permissão de emenda à inicial.

Ademais, o dever de cooperação ainda justifica a cláusula final do art. 321, caput. Segundo essa regra, deve o juiz indicar com precisão aquilo que exige correção ou complementação.

Vale dizer: o juiz não pode, simplesmente, determinar a emenda à inicial com decisão genérica. O dever de fundamentação impõe que essa decisão venha com a identificação precisa daquilo que exige correção, sob pena de, sequer, permitir à parte que elimine o problema encontrado.<sup>34</sup>

## **3. Indeferimento da petição inicial**

Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). Como já se disse, porém, o indeferimento da petição inicial – quando cabível a emenda – só pode ocorrer depois de ultimado o prazo para a correção do defeito. É direito da parte a emenda à petição inicial nos casos do art. 321, não havendo aí qualquer discricionariedade para o juiz.

Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação. Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. Nesse sentido, a sentença de indeferimento da petição inicial difere de outras sentenças terminativas, que possam ser proferidas também com base nos mesmos defeitos aqui examinados (ou adiante vistos, na análise do art. 330, do CPC). Embora sempre seja cabível a apelação dessas sentenças, só as sentenças de indeferimento da petição inicial – proferidas, portanto, “antes da citação dos réus” – é que se sujeita ao modelo especial de apelação de que trata o art. 331, do CPC.

Caso o indeferimento seja apenas parcial, constituirá decisão interlocutória. Nesse caso, a despeito da falta de previsão legal expressa no art. 1.015, do CPC, estará sujeita a agravo de instrumento. Esta é, com efeito, a única solução plausível, sobretudo em se pretendendo evitar a banalização do mandado de segurança. Com efeito, aguardar até o fim do processo para discutir essa questão em preliminar da apelação seria, no mínimo, franca violação à garantia da duração razoável do processo. Por outro lado, supor irrekorível essa decisão seria, de um lado, criar inadmissível discriminação entre o indeferimento total (rekorível) e o parcial da petição inicial.

Ademais, é certo que muitas das hipóteses de indeferimento parcial da petição inicial estão abrangidas por casos a que o Código expressamente confere o cabimento de agravo. Assim, por exemplo, é o caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII).

Por isso, a única solução viável é concluir que o caso desafiará agravo de instrumento, já que esse indeferimento parcial implicará prejuízo irreparável à parte, necessitando de correção pronta.

#### **4. Preclusão da decisão de recebimento da inicial**

A decisão do juiz que recebe a petição inicial não implica preclusão pro judicato em relação ao preenchimento adequado dos requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC. Por outras palavras, ainda que, por equívoco, o juiz receba a petição inicial viciada – que não preencha os requisitos legais ou que tenha defeitos ou irregularidades que dificultem a análise do mérito – isso não impede que, futuramente, o defeito seja reconhecido.

Não se pode imaginar que o erro judiciário possa convalidar irregularidades processuais e tornar viável demanda que seja claramente inadmissível.

De todo modo, verificada posteriormente a irregularidade ou o defeito sanável da petição inicial, ainda assim não tem sentido a extinção automática do processo. É necessário, em observância ao que prescreve o art. 317, do CPC, que seja oportunizada a correção do problema. Somente depois de escoado o prazo para essa complementação é que se autorizará a extinção do processo.

### *Seção II*

#### *Do pedido*

##### **1. Inércia da jurisdição e pedido**

A jurisdição é função inerte do Estado, que não age senão após ser provocada. Exige-se, pois, a iniciativa de alguém para a atuação jurisdicional, sendo esta determinante para o Estado, na medida em que este somente agirá segundo aquilo que for delimitado pelo interessado. Essa ideia é corrente no direito nacional, havendo mesmo quem a entenda como fundamento basilar da atuação jurisdicional. Considerando que a inércia pode representar proteção à imparcialidade do juiz, é frequente a conclusão de que a se permitir a atuação sponte própria da atividade jurisdicional, seria impossível evitar que o magistrado se tornasse parcial.

Embora pareça exagerado dar a esta característica o papel de essência da jurisdição, é ponto incontroverso que este caráter inercial domina completamente os sistemas processuais modernos.

Justamente em razão deste caráter, e como sua contrapartida, coloca-se o princípio da demanda como elemento fundamental do Código de Processo Civil de 2015. Se a jurisdição não atua, a não ser quando estimulada, o estímulo em questão exerce função considerável, determinando quando e a que respeito atuará o Estado, em sua função jurisdicional.

Daí a importância dedicada pelo Código ao pedido. É por esse elemento que o autor extravasa sua pretensão e demonstra aquilo que pretende do Estado-juiz.

##### **2. Princípio da demanda<sup>35</sup>**

A doutrina expressa o princípio da demanda através da ideia de que o pedido formulado pela parte determina os limites da atuação jurisdicional, importando na razão da atuação do Estado e também na fixação do objeto a ser decidido.

Dois são os fundamentos mais essenciais para a outorga ao interessado do poder de iniciar a prestação jurisdicional e determinar o seu objeto. De um lado, tem-se a clássica concepção de que,

por tratar o Código de Processo Civil predominantemente de interesses privados, é razoável que se dê às partes a prioridade na escolha do momento em que a proteção ao interesse deve ser realizada, bem como a determinação do litígio que será examinado pelo Poder Judiciário. Afinal, se os interesses privados são, em princípio, disponíveis, disponível também deve ser a sua forma de proteção. Como lembra Liebman, a respeito do tema, tomando-se por pressuposto que o objeto do processo apenas trate de interesses privados das partes, o princípio da demanda (e também o dispositivo) nada mais é que decorrência do princípio geral que reserva à vontade das partes a disposição de suas relações jurídicas privadas.<sup>36</sup> Por outras palavras, o princípio da demanda, aplicável de regra ao Código de Processo Civil, decorre naturalmente da essência dos direitos subjetivos sujeitos à atuação jurisdicional civil: tratando-se de direito disponível, fica a atuação estatal condicionada ao pedido formulado pela parte.<sup>37</sup> E, se esta condição impõe-se como dever ao juiz, logicamente a atividade jurisdicional estará também limitada àquilo que fora pedido pela parte.

Diante disso, a noção da inércia da jurisdição – e do correlato princípio da demanda – tem clara raiz no caráter disponível do direito material. Se é certo que o direito subjetivo tem caráter privado e é de cunho disponível, não teria sentido autorizar-se o Estado a interferir na vontade do particular, impondo-lhe a proteção de interesse deste, quando este assim não o desejasse. Consequência natural deste raciocínio é a conclusão de que, se o Estado não pode impor ao particular a defesa de interesse seu, também não poderá exigir deste que peça proteção além daquilo que explicitamente solicitou, razão pela qual se impõe ao magistrado ater-se ao pedido formulado pelo autor. Nessa toada, adverte Chiovenda que a garantia em questão, decorrente do clássico brocardo “*sententia debet esse conformis libello*”, é uma implicação natural do princípio geral no *procedat iudex ex officio*.<sup>38</sup>

Por outro lado, o princípio em questão também tem a função de resguardar a imparcialidade do magistrado.<sup>39</sup> Afinal, se tocasse ao juiz determinar quando agir e em que medida e extensão decidir, abrir-se-ia grande flanco para que o juiz se apresentasse na causa como partidário de uma tese, esposando, já no início do processo um objetivo quanto ao litígio e uma opinião formada a seu respeito.

Sob este ponto de vista, pois, o princípio da demanda exerce papel preponderantemente psicológico, tendente a separar as funções de pedir e de julgar. Procura-se, assim, evitar que o juiz que decidirá a controvérsia já inicie o processo de convencimento predisposto a acolher uma tese ou outra das apresentadas no feito.

### 3. Origens do princípio

Embora seja corrente associar-se o nascimento deste princípio ao direito romano, parece inexata a conclusão, especialmente porque naquele estágio a finalidade da demanda não tinha a mesma roupagem atual. Com efeito, embora também naquele período (em especial, no período formulário) o juiz estivesse limitado em sua atuação decisória, esta vinculação não se fazia tanto com o pedido formulado pelo interessado diante do pretor, mas, sobretudo, com a fórmula emitida por este. Como salienta Scialoja, a sentença no direito romano não era submetida a requisitos formais específicos (sequer sendo obrigatória a motivação da decisão); exigia-se, todavia, que “*el juez diese cumplimiento a la obligación que le había impuesto el pretor, esto es, que dijera si el demandado debía ser absuelto o condenado*”.<sup>40</sup> A propósito, Gaio já advertia que, em havendo pedido determinado, o juiz estava proibido de condenar em quantia superior ou inferior ao solicitado (contido na fórmula), sob pena de incorrer em prevaricação por ser parcial. Somente poderia condenar a menos do que requerido se assim fosse autorizado pela fórmula (Gai, IV, § 52).<sup>41</sup>

De fato, embora a fórmula expedida pelo pretor devesse refletir o pedido realizado pelo interessado, era aquela [e não esta] que determinava a extensão do trabalho do juiz.<sup>42</sup> Justamente em razão dessa particularidade é que se dava tratamento especial às hipóteses em que a sentença extrapolava o pedido, decidia fora dele ou não avaliava toda extensão da fórmula outorgada. Aludia-se, nesse campo, no direito romano, à ideia da *plus petitio* e da *minus petitio*.



O tratamento da *plus petitio*, cuja fonte principal é Gaio, buscava descrever o que ocorria nos casos em que a parte solicitava algo a par do que merecia ou em que a fórmula descrevia equivocadamente a intenção da parte. Dizia-se ocorrer a *plus petitio* por quatro razões: em razão do objeto, do tempo, do lugar ou da causa (Gai, IV,53a). Em razão do objeto, a *plus petitio* se caracterizava quando a parte demandava (na fórmula) mais do que tinha direito; em razão do tempo, esta se caracterizava quando alguém pedia a satisfação de um direito antes de seu vencimento; em razão do lugar, estava ela caracterizada quando se pedia a satisfação de uma prestação em lugar distinto daquele que havia sido escolhido na obrigação; e em razão da causa, havia *plus petitio* quando se descaracterizava a natureza própria da obrigação (por exemplo, afastando o caráter alternativo da obrigação, ou exigindo a espécie em obrigação de gênero).<sup>43</sup> Do que se tem dos textos antigos, a existência desta extrapolação do direito – seja no pedido formulado pelo interessado, seja especialmente na fórmula outorgada pelo pretor – importava não apenas na rejeição da demanda, mas, o que é mais grave, na possível privação do direito demandado.<sup>44</sup> Considerava-se, mais, passível de *restitutio in integrum* a sentença que outorgava ao autor mais do que ele tinha direito, especialmente porque, neste caso, a sentença se fundava em uma fórmula injusta.<sup>45</sup>

Por outro lado, a *minus petitio* ocorria quando alguém demandava menos do que poderia obter. Neste caso, ao contrário do que sucede hoje – e também de forma distinta do que sucedia com a *plus petitio* –, não se entendia como renunciada a parte excedente (não pedida em juízo). A consequência de se solicitar menos do que podia obter era, apenas, a impossibilidade de requerer o excedente “durante o mesmo mandato do pretor que processara o primeiro pedido”. Vale dizer que a parte poderia perfeitamente solicitar o restante de seu direito depois de vencido o prazo do mandato do primeiro pretor, considerando-se que a ausência de pleito integral, na primeira demanda, apenas importaria ao restante do direito (não pleiteado) uma moratória, por um ou cinco anos, dependendo do caso.<sup>46</sup> Falava-se, então, em *exceptio litis dividuae* e em *exceptio rei residuae*. A seu respeito, conclui Bülow que

así, se consideraba que al acreedor que demandaba por un solo derecho (en el caso que tuviere vários) o por una parte de éste, había renunciado a exigir el resto judicialmente durante el año que correspondía al mandato del pretor. Que una demanda por el saldo no tendría posibilidad de éxito durante el período anual mencionado, el mismo pretor lo hizo saber públicamente. Si, con todo, el acreedor prefería demandar sólo una parte de su crédito, se entendería que, libremente, decidía exigir lo restante sólo en el próximo año judicial; esto es, que había concedido a su deudor una prórroga por el saldo hasta aquella época.<sup>47</sup>

Note-se que, em todo caso, a limitação de atuação do juiz se dava, especificamente, com a fórmula ditada.<sup>48</sup> Esta, logicamente, deveria refletir o pedido formulado pelo autor, do que se extrai que, mediatamente, vinculava também a atuação do *iudex*. O princípio da demanda, todavia, como se tem hoje, não tem exata correspondência no direito romano.<sup>49</sup>

Seja como for, ainda que não se possa situar no direito romano tamanha força para o pedido formulado pela parte, o fato é que a história demonstra, há muito tempo, a predominância absoluta deste princípio. Com efeito, as Ordenações do Reino já admoestavam o magistrado para que não julgasse fora do pedido, mesmo porque seriam inexistentes (seria de “nenhum direito”, como rezavam as Ordenações Manuelinas – Livro III, Tít. XXXIX – e as Ordenações Filipinas – Livro III, Tít. LXIV) as sentenças que deixassem de cuidar para este limite.

#### 4. Princípio da demanda e princípio dispositivo

É comum se ter como idênticos os princípios da demanda e dispositivo, normalmente associados à mesma ideia, reconduzida ao brocardo romano “*iudex iudicare debet iuxta allegata et probata partium*”. De fato, o direito suíço<sup>50</sup> e também o alemão<sup>51</sup>, em regra, não distinguem os dois conceitos, abarcando as ideias contidas em cada qual dentro da mesma noção de princípio dispositivo (*Dispositionsgrundsatz*).<sup>52</sup> Carnelutti, aliás, compreende as duas ideias como fases de um único princípio, sendo uma só a razão que justifica o poder da parte de iniciar o processo ou aquele de propor determinada prova.<sup>53</sup>

Todavia, a melhor doutrina separa nitidamente os conceitos, estabelecendo, até mesmo, gênese e função diferentes para cada um deles.<sup>54</sup>

O princípio da demanda (*Verhandlungsmaxime*) associa-se, sobretudo, ao “objeto do processo”, indicando o momento em que a atuação jurisdicional é exigida e determinando sobre o que deverá ela incidir (ne procedat iudex ex officio et sine actore). Inclui-se aqui o poder entregue à parte de dar início ao processo – poder este quase exclusivo, já que em regra não se admite que o juiz possa atuar de ofício, sem haver requerimento de alguém – bem como o de determinar a extensão do julgamento do juiz – o chamado princípio da congruência ou correlação, que impõe uma correspondência necessária entre o solicitado e o decidido (ne eat iudex ultra et extra petita partium).

Como se vê, este princípio se antagoniza com a prerrogativa dada ao magistrado de atuar de ofício, instaurando um processo e decidindo a respeito daquilo que entende ser cabível. Trata-se, portanto, de tema afeto, especialmente, ao “direito material”, já que, indiretamente, busca determinar qual direito [ou qual dimensão do direito] será levada para a proteção do Estado. Além disso, diante desse princípio, determina-se que o processo exige a iniciativa do interessado para formar-se, não se podendo obrigar ninguém a provocar a atuação jurisdicional (*invitus agere nemo cogatur*).

Já o princípio dispositivo (*Dispositionsmaxime*) está relacionado de forma específica à tratativa processual da demanda. A questão aqui se põe prioritariamente em determinar de que modo deve ser conduzido o processo, se com predominante atuação do juiz ou se prioritariamente segundo as determinações e impulsos das partes. No primeiro caso, fala-se em processo de tipo inquisitório e no segundo, de processo dispositivo ou do tipo acusatório. Assim, se o processo impõe a prevalência da vontade das partes na condução dos atos do processo, inibindo ao magistrado papel ativo na colheita da prova e no andamento do feito, tem-se a predominância do princípio dispositivo. Se, ao revés, prevalece a atuação oficiosa do juiz, tanto na instrução da causa, como no impulso da sequência dos atos do processo, então se verifica um processo de perfil inquisitório.<sup>55</sup>

Verificada a diferença, é fácil perceber, como anota Ovídio Baptista da Silva, que, conquanto o princípio da demanda esteja presente de forma plena em quase todos os sistemas processuais atuais – sendo raros os casos em que o juiz possa atuar de ofício – o princípio dispositivo (assim como o princípio inquisitório) não se verificam de maneira pura em nenhum sistema moderno. Todos os sistemas processuais, de fato, apresentam um misto destes dois últimos princípios, com prevalência eventual de um ou de outro, sem, contudo, ser possível enxergar a “exclusiva” aplicação de qualquer um deles.<sup>56</sup>

Esta constatação reflete, a propósito, a própria determinação da raiz de cada um destes princípios. Como observa Liebman, o princípio da demanda recorda a característica fundamental dos direitos postos à apreciação jurisdicional pelo Código de Processo Civil, que é o seu caráter disponível; já o princípio dispositivo nada mais é que um princípio “técnico” instituído para regular o processo e, especificamente, a conduta das partes neste.<sup>57</sup> Também Trocker considera que a determinação do sujeito responsável por trazer os meios de prova no processo é tema que respeita apenas à política legislativa – que tanto pode optar por uma solução extrema ou por algo intermediário – ao passo que a garantia da ação (demanda), assim como da defesa, são elementos fundamentais e intangíveis de todos os sistemas judiciários.<sup>58</sup>

De fato, enquanto o princípio da demanda pretende ligar-se à proteção dos interesses vistos no item precedente (o caráter disponível dos direitos privados e a preservação da imparcialidade do juiz), o princípio dispositivo tem em vista, sobretudo, permitir uma mais rápida e segura fixação dos fatos no processo, deixando à atividade preponderante das partes essa determinação.<sup>59</sup>

## 5. Princípio da correlação

Claramente vinculado ao princípio da demanda é o princípio da correlação, que impõe a necessária vinculação do conteúdo da sentença com o litígio exposto pelas partes.<sup>60</sup> Segundo Echandía, há várias explicações para a previsão do princípio ora estudado.<sup>61</sup> Há alguns que



compreendem que a correlação é apenas uma expressão do princípio dispositivo; outros veem na congruência apenas um desdobramento do princípio do contraditório; outros ainda consideram que ele trata apenas da necessidade de conter o excesso de poder pelo juiz. Todas estas explicações, porém, embora também componham a base da ideia da congruência, são insuficientes para justificar sua previsão. Na realidade, a noção de congruência liga-se, historicamente, à própria visão da jurisdição. Se os direitos de ação e de defesa impõem ao Estado o dever de prover dentro de um processo, cujo alcance está delimitado pelas pretensões e pelas exceções formuladas, natural é à prestação desta função a ideia da congruência.<sup>62</sup> Em última análise, sendo os direitos postos à solução judicial de natureza privada, não se legitima que o Estado vá além do limite pretendido pelas partes.<sup>63</sup> Se o direito processual se preocupa com a contenção ao poder do Estado, beira o óbvio que este poder somente possa ser exercido nos confins determinados pela parte.

Por conta disso, o juiz não pode decidir fora ou além do pedido formulado pela parte. Não é, porém, somente isso que se exige por esse comando. O princípio da correlação não se limita a impedir o magistrado de julgar fora do pedido, mas lhe impõe o dever de examinar o pedido em toda sua extensão. Não se pode imaginar que, ao ter a parte indicado os limites da atuação jurisdicional, possa o juiz eleger, dentro deles, o que gostaria de apreciar. Desse modo, o princípio da demanda não representa apenas uma garantia “negativa” – consistente em impedir o juiz de ir além do pedido da parte –, mas configura também um dever “positivo” – que impõe a apreciação da totalidade do pedido.<sup>64</sup>

Aliás, o dever imposto ao magistrado de examinar integralmente o litígio a ele submetido decorre não apenas do princípio da demanda e de seu consectário princípio da correlação, mas também da proibição da autotutela privada. Se o Estado proíbe ao particular a proteção de seus interesses, tomando para si o monopólio da atuação do Direito, não pode haver espaço para que, quando o interessado solicite a atuação jurisdicional, o magistrado desconsidere parte do pedido formulado, examinando apenas aquilo que lhe aprouver. Em verdade, por conta do monopólio estatal da jurisdição, é dever do Estado responder ao pleito da parte integralmente, ou seja, em toda a extensão do deduzido. Embora antiga, é precisa a lição de Paula Baptista, que esclarece que

a sentença deve ser (...) restrita à matéria em litígio, não a deixando sem decisão, nem julgando mais do que se contém nas conclusões das partes, exceto o que está virtualmente compreendido nelas, como os frutos e acessões do principal ou o que pertence ao ofício do juiz, como as custas, acessões e mais interesses acrescidos depois da litiscontestação.<sup>65</sup>

A par de tudo isso, o princípio da correlação submete o magistrado aos fundamentos de fato trazidos pelas partes. Em princípio, pois, não apenas o juiz está adstrito aos pedidos formulados, mas também à causa de pedir deduzida pela parte, não podendo atender ao pleito apresentado invocando outra razão que não aquela apresentada na inicial.

É preciso tomar certa cautela com a afirmação acima feita, para que não se lhe dê maior amplitude do que o devido. A proibição mencionada diz respeito à vinculação do juiz à “causa de pedir deduzida”. Isto não significa que o juiz esteja proibido de conhecer, ex officio, de qualquer fato não alegado. Em verdade, poderá o juiz examinar “todos os fatos pertencentes à causa de pedir”, tenham eles sido alegados ou não, bastando que estejam provados no processo (por atividade da parte, do juiz ou de outrem).<sup>66</sup> O que lhe é vedado, todavia, é examinar fatos “externos à causa petendi”, já que esta outra razão (que corresponde, por consequência natural, a outra ação) não foi apresentada em juízo.

Em síntese, pois, pode-se dizer, com fulcro no ensinamento de Chiovenda, que o princípio em questão significa: a) a impossibilidade de o juiz decidir a respeito de pessoas que não sejam sujeitos do processo; b) a proibição de que o juiz confira ou denegue coisa distinta da solicitada; c) a vedação ao juiz de alterar a causa de pedir.<sup>67</sup>

Por outro lado, esta vinculação decorrente do comando da correlação – assim como ocorre em relação à vinculação ao pedido – vai além de impedir o juiz de apreciar fatos não alegados, impondo-lhe o exame de todos os fatos alegados pelas partes, tanto para a rejeição como para o

acolhimento do pedido. Como demonstra Carnelutti, a imposição da afirmação unilateral e a suficiência da afirmação bilateral para que um fato possa ser examinado na sentença é, em relação ao fato principal, realmente um reflexo dos princípios *ne procedat iudex ex officio* e *ne eat iudex ultra petita partium*.<sup>68</sup>

Ou melhor, para que uma afirmação de fato, constante da petição inicial – ou ainda de outro ato, oferecido no curso do processo – deva ser apreciada pelo juiz, basta que tenha sido deduzida pela parte e possa conduzir ao acolhimento da pretensão ou da exceção (fato principal).<sup>69</sup> Logicamente, porém, poderá suceder que a conclusão judicial dispense o exame de tais fatos, seja porque não se chega a apreciar o mérito – terminando o processo por alguma causa processual – seja porque, na apreciação do mérito, a análise se detém em questão prévia ou prejudicial (a exemplo da prescrição, da decadência ou da nulidade do contrato em que se baseia a pretensão), seja porque, no exame de mérito, o acolhimento da pretensão do autor pode dar-se por outro fundamento, seja ainda por conta de eventual ordem de cognição de pedidos imposta pela parte (como na ocorrência de cumulação alternativa de pedidos).

O raciocínio também se aplica no polo contrário do processo, ou seja, para as defesas apresentadas pelo réu. Também o juiz fica vinculado às exceções próprias<sup>70</sup> apresentadas pelo réu, não podendo suprir sua falta, mas devendo apreciá-las integralmente.<sup>71</sup> Da mesma forma, aqui incidem limitações, semelhantes àquelas aplicadas para os fundamentos do autor, conforme visto no parágrafo acima.

De outra parte, como também cediço, a regra em comento não se aplica no que diz respeito à interpretação dos fatos ou à qualificação jurídica atribuída aos fatos pelas partes. Pode o magistrado sempre atribuir outra interpretação ou qualificação livremente, não ficando vinculado àquela sugerida pela parte (*narra mihi factum dabo tibi ius; iura novit curia*).<sup>72</sup> Trata-se daquilo a que Pontes de Miranda denominou de “princípio da fungibilidade da forma do fundamento”.<sup>73</sup> Excepciona-se dessa faculdade, segundo a doutrina amplamente majoritária, a hipótese em que a alteração na qualificação jurídica deveria também importar a modificação no pedido formulado. Em tais casos, não poderá, segundo a ótica dominante, o magistrado alterar a qualificação jurídica, restando-lhe apenas rejeitar o pedido formulado.<sup>74</sup>

Ao final, é inescapável a conclusão de Trocker, que indica que o princípio da demanda – e, especialmente, o da correlação – atende, sobretudo, à preservação da garantia do contraditório (*rechtliches Gehör*). Isto porque esta garantia deve ser vista como a oportunidade de “participação efetiva” na formação da decisão judicial de todos os envolvidos.<sup>75</sup> De fato, a preservação do direito de colaboração das partes – e a efetiva consideração pelo juiz dos atos praticados pelos interessados – na decisão estatal é fundamental para a legitimação da decisão.<sup>76</sup> E esta colaboração só é possível se as partes têm prévia ciência do objeto que será decidido pelo Judiciário. Logicamente, portanto, é essencial para a realização adequada da garantia do contraditório que se dê as partes a prévia ciência “da totalidade” daquilo que será objeto de decisão pelo juiz e, para tanto, fundamental é a preservação da correlação entre o pedido e a sentença.

## **6. A necessidade de atenuação do princípio da demanda**

Embora se tenha ainda hoje, no princípio da demanda, verdadeiro axioma do Código de Processo Civil moderno, é importante salientar que ele não impera [e nem pode imperar] absoluto. Há hipóteses em que se autoriza ao magistrado alterar o objeto do processo ou mesmo considerar causas de pedir diversas da deduzida em sua sentença, sem qualquer provocação. Estas exceções, a propósito, não se limitam ao direito nacional, sendo encontradas também em outros ordenamentos, com certa frequência.

Apenas para se verificar o que ocorre em alguns outros sistemas, convém lembrar que o direito canônico autoriza que nas ações declaratórias de nulidade de casamento seja possível deduzir novo fundamento para a demanda mesmo em grau de apelação (can. 1.683).<sup>77</sup>

Também no direito suíço, admite-se que o tribunal, em ação de divórcio, adote de ofício, medidas de proteção aos filhos do casal (art. 156, i, e 275, 2, do CC Suíço), permitindo-se ainda que

em ação tendente à resolução de contrato de compra e venda, possa o magistrado limitar-se a reduzir o preço (art. 205, 2, do Código de Obrigações).<sup>78</sup> De modo semelhante, o direito alemão contém diversas atenuações ao princípio da demanda, permitindo ao juiz suprir de ofício a falta de alegações das partes ou mesmo sugerindo a elas a alteração da causa de pedir ou do pedido.<sup>79</sup>

O direito italiano também não é infenso a estas exceções. Como relata Proto Pisani, estas se verificam, sobretudo, no campo dos processos falimentares e nos procedimentos de jurisdição voluntária.<sup>80</sup> No campo falimentar, autoriza-se ao magistrado decretar de ofício a falência “se risulta lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale”.<sup>81</sup> Na esfera da jurisdição voluntária, autoriza-se ao juiz a proteção, de ofício, do interesse de menores (art. 336, § 3.º, do CC Italiano), bem como iniciar de ofício o processo de reconhecimento do estado de adoção em casos de abandono de menor (art. 8.º e ss., da Lei 184/1983).

No direito português também é fácil encontrar exceções ao princípio da demanda. Como assinala António Santos Abrantes Gerales,<sup>82</sup> não vigora este princípio no processo trabalhista – em que o legislador autoriza que a sentença condene além do pedido formulado pela parte – sendo ainda entendimento jurisprudencial que, em ações de indenização decorrentes de acidentes viários, pode a condenação basear-se em responsabilidade objetiva pelo risco, ainda que o autor tenha fundado sua demanda em responsabilidade subjetiva. Enumera, ainda, o autor outras exceções, como o poder dado ao juiz de, em ações de interdição, adequar a decisão final ao grau de incapacidade verificado (art. 954, 1, do CPC Português), ou o de, em ação de divórcio, fixar de ofício, provisoriamente, o regime de alimentos, o exercício do poder paternal e o destino da moradia da família (art. 1.407, 7, do CPC Português). Constituiriam, enfim, exceções ao preceito em estudo [semelhantes a previsões contidas no direito brasileiro] a possibilidade de o juiz – independentemente de pedido da parte – proferir sentença tendente a evitar o uso do processo para a prática de atos simulados ou proibidos pela lei (art. 665, do CPC Português), bem como a autorização para que o magistrado, no campo dos processos cautelares, confira a providência que mais se ajuste à situação de fato alegada (art. 392, 3, do CPC Português).

Ainda, como informa Echandía, nos países socialistas também é comum autorizar-se ao juiz iniciar de ofício processos civis.<sup>83</sup> Não obstante isso, Terebilov, Poutchinski e Tadevosian ponderavam que no direito russo (ainda sob o regime comunista), o processo se inicia por provocação da parte interessada ressalvada, apenas, a prerrogativa de o Ministério Público iniciar o processo ou intervir nele, para a salvaguarda dos interesses dos Estados ou dos trabalhadores.<sup>84</sup>

No direito brasileiro, também é possível encontrar situações em que a lei autoriza a atuação excepcional do magistrado afastando-se do princípio da demanda. Sem considerar hipóteses revogadas<sup>85</sup>, e ainda a questão do chamado pedido implícito<sup>86</sup>, menciona a doutrina a hipótese da convalidação da concordata preventiva (negada) em falência (conforme previa o art. 16, da antiga Lei de Falências e Concordatas – Dec.-lei 7.661/1945 e estabelece hoje o art. 56, § 4.º, da Lei 11.101/2005)<sup>87</sup>, da incoação de ofício da execução trabalhista (art. 878, da CLT). Ainda que o Código de 2015 tenha eliminado hipóteses clássicas de atuação judicial de ofício, remanescem casos evidentes, a exemplo da possibilidade de alienações judiciais sem requerimento (do art. 730, do CPC) da arrecadação “imediata” de herança jacente (art. 738, do CPC)<sup>88</sup>, ou ainda a arrecadação de bens dos ausentes (art. 744, do CPC)<sup>89</sup> O mesmo se dá em relação ao procedimento de arrecadação das coisas vagas (art. 746, do CPC).

Ainda poderia ser invocada aqui a possibilidade de o juiz conceder de ofício habeas corpus (art. 654, § 2.º do CPP), tanto no plano criminal como no cível.

Mais abundantes são os casos em que o juiz está legalmente habilitado a agir fora de eventual pedido da parte.

Nesse sentido, deve-se sublinhar a hipótese descrita pelo art. 142, do CPC, que autoriza o juiz a afastar-se dos limites do pedido do autor, quando convencer-se que as partes se valem do processo para obter fim proibido por lei ou para praticar ato simulado.

A tutela provisória, nesse passo, oferece diversas situações em que o juiz se desvincula do pedido formulado pela parte. Com efeito, como se vê do art. 297, do Código de Processo Civil, toca ao juiz da causa a adoção das providências que sejam mais adequadas “para efetivação da tutela provisória”. De outra parte, o art. 305 afirma que a petição inicial da demanda por medida cautelar antecedente “indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sendo assim, dispensada que é a formulação de pedido, logicamente, também não tem cabimento falar-se na aplicação do princípio da correlação, estando autorizado o juiz a conceder a providência que lhe pareça mais apropriada para enfrentar a situação de perigo descrita pelo requerente. Vê-se aí, pois, mais uma exceção ao princípio aqui examinado.

No tocante ao Código Civil, pode-se referir à hipótese descrita no art. 1.637, que, embora não autorize o magistrado a incoar processo, permite-lhe outorgar a proteção que entenda mais adequada ao caso, desvinculando-o, pois, do pedido eventualmente formulado pela parte.<sup>90</sup>

Também na prática previdenciária, tem-se tornado comum a atenuação do princípio da demanda, em favor do segurado. Sobretudo tendo em vista a condição de hipossuficiente da parte segurada, a jurisprudência brasileira tem flexibilizado o princípio da demanda, autorizando em diversas vezes a concessão de vantagem não postulada expressamente pela parte.<sup>91</sup>

Ao que parece, porém, o exemplo mais eloquente encontrado hoje, de exceção ao princípio da demanda, vem exposto pela disciplina conferida à tutela específica das prestações de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar soma em dinheiro (arts. 139, IV, 536, 537 e 538, do CPC e art. 84, do CDC). Esta forma de tutela pode ser adaptada às circunstâncias do caso concreto, ainda que o pedido da parte autora tenha sido outro, sem que, com isso, haja ofensa ao princípio da demanda.<sup>92</sup>

A conclusão, com efeito, decorre da dicção expressa dos preceitos mencionados, que claramente autorizam o magistrado a conferir a providência cabível no caso, ainda que outro tenha sido o pedido formulado pela parte. O pedido que se exige seja formulado pela parte é apenas a tutela específica (ou o resultado prático equivalente) do direito (arts. 497 e 498, do CPC e art. 84, do CDC).<sup>93</sup> Este pedido preencherá o requisito de certeza e determinação, imposto pelo Código de Processo Civil desde que o autor individualize, na petição inicial, qual precisamente é a prestação buscada. Para que se possa atender ao pedido do autor, compete ao juiz eleger o meio de indução ou de sub-rogação que se mostre mais idôneo ao caso concreto, ainda que outro tenha sido indicado pela parte requerente. As técnicas a serem aplicadas pertencem totalmente ao domínio do Poder Judiciário, porque implicam expressão de sua autoridade. Por isso essas técnicas são determinadas ex officio pelo juiz, independentemente de pedido da parte e, demais disso, de forma desvinculada de eventual existência de requerimento (por uma técnica ou outra), formulado pelo autor.

Desta forma, uma vez respeitado o pedido de tutela solicitado pela parte autora pode o magistrado valer-se do mecanismo mais apropriado para atingir este objetivo, independentemente da existência – ou não – de pedido de técnica especificamente constante da petição inicial.<sup>94</sup>

Problema maior, mas também vinculado à questão das “tutelas específicas”, representa a hipótese de pretender a parte tutela inibitória da violação e o magistrado, vendo que o ilícito que se pretendia evitar já ocorreu, considerar a possibilidade de outorga de tutela reintegratória.<sup>95</sup> Exemplifique-se: a parte formula pedido no sentido de impedir que certa empresa possa comercializar determinado produto, por lesar à saúde pública; surgindo, da prova dos autos, a constatação de que a mercadoria já está sendo comercializada, poderia o magistrado determinar a sua retirada do mercado?

Em princípio, dentro da sistemática atual do Código de Processo Civil de 2015 brasileiro, ao menos em termos de tutela preventiva, sem que haja pedido subsidiário neste sentido, tal solução não seria possível, a não ser por via de ação autônoma. Ocorrido o ilícito que se pretendia evitar, perde a ação seu objeto, sendo que a retirada dos efeitos nocivos do ilícito do mundo concreto deve ser objeto de outra demanda. Com efeito, o pedido da demanda exige que o juiz se atenha ao

pedido formulado pela parte, que é, na tutela inibitória, de impedimento do ilícito que se teme; certamente extravasaria este campo a tutela que ordenasse o desfazimento dos efeitos do ilícito já praticado, tornando então esta tutela violadora do princípio da demanda.

Esta ótica, porém, embora pareça ser a solução mais lógica, não é a adequada para lidar com a situação em tela. Ao contrário, mesmo diante da redação do art. 84, do Código de Defesa do Consumidor (bem como do regime adotado pelos arts. 497 e 498, do Código de Processo Civil), parece ser perfeitamente possível a fungibilidade aqui mencionada, ainda que possa, em exame perfunctório, assemelhar-se o caso a uma sentença extra petita.

A fungibilidade entre tais tutelas – inibitória, reintegratória, ressarcitória – é possível por uma estrita questão de lógica, sendo ademais uma imposição necessária em concessão ao princípio da instrumentalidade, que preside o sistema processual brasileiro. Realmente, não fosse a sustentação teórica que esta fungibilidade encontra, como se verá a seguir, esta plasticidade é fundamental para o próprio direito brasileiro e para a efetividade da jurisdição nacional, sob pena de, mais uma vez, ceder-se ao formalismo em detrimento da solução dos conflitos e da realização dos escopos da jurisdição. Com efeito, impor ao autor, que pleiteia uma tutela inibitória, mas não a obtém em tempo, que proponha nova ação para que sejam removidos os efeitos nocivos do ilícito, ou para que veja indenizados os prejuízos sofridos, é, no mínimo, absurdo revelador da insuficiência e da inadequação do sistema. Ceder a esta solução é, conquanto cômodo, aquiescer que o formalismo deve sobrepor-se à tutela adequada (ou, então, menos inadequada) do interesse e dos objetivos do processo.

Mais do que esta exigência feita em homenagem ao princípio da instrumentalidade, esta solução decorre do próprio teor da legislação nacional. Realmente, importa lembrar que a classificação anteriormente feita (entre tutelas repressiva contra o dano ou o ilícito e preventiva contra o dano ou o ilícito, equivalente à classificação que se faz entre tutelas inibitória, ressarcitória, reintegratória, do adimplemento e preventiva executiva) tem exclusivo fim “didático”, calcado na dimensão da cognição judicial a respeito das questões da lide, importantes para que se confira a proteção adequada ao interesse submetido à apreciação judicial. É dizer, por outras palavras, que a menção a tais formas de tutela importa para que se tenha consciência de que, para a tutela contra o ilícito, mostram-se em regra desnecessárias quaisquer ponderações a respeito de dano ou de culpa pelo agente; por outro lado, para que esta tutela seja preventiva, importa dispor de mecanismos para impor ao requerido certa conduta (positiva ou negativa), a fim de que se confira o tratamento adequado a esta pretensão. A classificação em tela tem, pois, a exclusiva função de mostrar, aos operadores do Direito, o perfil do interesse submetido à proteção, os requisitos necessários para que surja o direito à tutela (ação de direito material) e a forma como esta proteção deve ser dada. Não há, então, nenhuma vinculação de pretensão (à satisfação do direito) à classificação, no sentido de que, quem pede tutela inibitória, fique limitado a esta “espécie” de proteção, inserida na classificação.

Em verdade, aquele que pede em juízo a proteção inibitória do direito, pede a proibição da violação de seu interesse. Este é o pedido formulado, independentemente da avaliação sobre seu caráter inibitório, ressarcitório ou reintegratório (que só são relevantes para o estudo dos requisitos para que a tutela seja prestada). Este é o pedido formulado, mas, como preceitua o art. 499, do CPC (ou ainda o art. 84, § 1.º, do CDC), caso, por circunstâncias externas ao interesse do autor, mostrar-se “impossível” o atendimento a este pleito, pode ele resolver-se em perdas e danos. A primeira conclusão evidente, da leitura desta regra, é de que no sentido da tutela específica (inibitória) para a tutela por equivalente (ressarcitória, pela indenização por perdas e danos) a fungibilidade (ainda que “subsidiária”, ou seja, quando impossível atender ao direito em sua natureza específica) é expressa em lei, e independe de pedido da parte autora (que também pode formular o pedido neste sentido). Implica isto dizer que a própria lei determina a fungibilidade subsidiária entre a tutela inibitória e a tutela ressarcitória, autorizando o magistrado a oferecer esta no lugar daquela sempre que se mostrar, no caso concreto, impossível a tutela específica ou o resultado prático equivalente. Assim, se requerida a tutela inibitória, não for ela concedida em tempo, ou se, mesmo quando concedida, o réu não se comportar como determinado pela ordem judicial, caberá ao juiz converter a prestação de abstenção (ou a conduta positiva que geraria a inibição do ilícito) em perdas e danos, prosseguindo no processo para a apuração do dever de



reparar o prejuízo e do quantum dos danos indenizáveis, oferecendo tutela ressarcitória ainda que o pedido inicial fosse de conteúdo inibitório.

O mesmo também se dá entre a tutela inibitória e a tutela reintegratória. Também a lei impõe esta fungibilidade subsidiária, sendo possível chegar a esta conclusão por dois raciocínios diferentes. De um lado, esta conclusão decorre identicamente ao que se viu acima, do disposto nos arts. 499, do CPC e 84, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor. Se a lei permite que, quando for impossível a prestação da tutela específica, resolva-se ela em perdas e danos – estando ciente de que a tutela ressarcitória é subsidiária, somente tendo cabimento quando não seja possível recorrer a caminho alternativo –, não haveria sentido em negar a possibilidade da tutela reintegratória, que visa a retirar os efeitos perniciosos do ilícito do mundo concreto. De outra parte, porém, e o que é mais importante, a possibilidade desta fungibilidade subsidiária vem expressa no texto legal dos dispositivos em exame. Como se vê da redação desta regra, prevê-se que em qualquer ação em que se pleiteie a tutela de prestações positivas ou negativas, o juiz deve ou conceder a “tutela específica” ou oferecer o “resultado prático equivalente ao adimplemento”.

Alguém poderá imaginar que esta segunda previsão diz respeito exclusivamente à possibilidade de realização da prestação específica por terceiro. Esta interpretação, porém, acaba por restringir o conteúdo da redação expressa da lei, já que a intenção da regra é, simplesmente, permitir que se obtenha o “mesmo resultado prático” da prestação feita pelo ordenado. Este resultado idêntico pode-se obter: a) pela realização da conduta específica por terceiro (realização por sub-rogação da prestação a terceiro, às expensas do ordenado ou obrigado); b) mas também, no caso da tutela inibitória, pela criação no mundo concreto (veja-se a alusão no texto legal ao resultado “prático” e não jurídico) das mesmas condições existentes antes da prática da conduta que se queria evitar. Ora, esta segunda possibilidade é atendida pela tutela reintegratória, já que esta, ao remover do mundo físico, os efeitos nocivos da atividade ilícita, faz com que se tenha situação praticamente idêntica àquela existente antes da prática do ato ilícito. Criar o resultado prático equivalente à tutela específica pode, pois, significar agir posteriormente à prática do ilícito (tutela repressiva), restituindo as coisas à sua situação original. Por isso, é de se considerar viável a fungibilidade (ainda que pautada pelo critério da subsidiariedade, sendo sempre desejável, em primeiro lugar, a outorga da proteção específica, com a proibição da conduta que se quer inibir) mesmo entre tutelas de diferentes categorias, porque ela vem prevista expressamente em disposição legal.

## **7. Análise crítica do princípio da demanda**

A partir das premissas acima lançadas, é possível revisitar a figura do “pedido” e sua finalidade no modelo processual atual. É possível também lançar as premissas – que serão desenvolvidas adiante – sobre a função da “boa fé” e do “conjunto da postulação” (art. 322, § 2.º) na avaliação do pedido dentro do código atual.

Desde logo, parece conveniente ponderar que a previsão atinente à tutela específica – com a possibilidade de o magistrado adequar a proteção judicial às peculiaridades do caso concreto, e oferecer a parte a “melhor tutela possível ao seu interesse” – já corresponde significativa concessão à oficialidade da prestação jurisdicional.<sup>96</sup> Sua previsão moderna dá ao juiz poderes que extrapolam, e muito, os limites do pedido da parte, colocando em dúvida a aceitação [ao menos em sua integralidade] do princípio da demanda. Isso impõe reexaminar se os pressupostos que determinaram a colocação deste princípio como verdadeiro axioma do Código de Processo Civil moderno.

Nesse particular, cumpre lembrar o duplo fundamento em que se apoia este princípio: a natureza disponível dos direitos envolvidos no processo civil e a preservação da imparcialidade do juiz. A questão que se põe é saber se, atualmente, para a sociedade brasileira, permanece justificada a permanência do princípio indicado, na sua forma tradicional.

Quanto à primeira razão invocada – a disponibilidade dos direitos objeto do processo civil brasileiro – parece evidente que o motivo é insuficiente. Como é óbvio, o Código de Processo Civil (especificamente o brasileiro) lida tanto com direitos disponíveis como com indisponíveis. Por

outro lado, mesmo nos casos em que a lide versa exclusivamente sobre direitos disponíveis, não se deve esquecer o manifesto interesse do Estado (de cunho nitidamente indisponível) de aplicar o direito objetivo e manter a paz social. Nesse sentido, recorda Devis Echandía, também criticando esse suporte para o princípio da demanda, que a função do processo sempre será

ejecutar justicia y obtener una sentencia que se acomode a la verdad y al derecho es cuestión de interés social, cualquiera que sea la rama del derecho objetivo a que corresponda la cuestión que constituye el objeto del proceso: penal, civil, laboral, etc.<sup>97</sup>

Fosse, portanto, este o único fundamento para o princípio da demanda, forçoso seria concluir que ele não se sustenta no processo moderno, em que há clara prevalência do papel público desempenhado por este instrumento. Calamandrei, apreciando a questão aqui posta, chega a intuir essa mesma conclusão, quando considera que

de cuanto se ha dicho en el capítulo precedente sobre la naturaleza pública del interés que mueve a la jurisdicción, se podría pensar que el Estado, para poner en ejercicio la justicia no tuviera necesidad de ser solicitado por el individuo que la invoca en favor propio: si el fin de la jurisdicción no es la defensa de los derechos subjetivos, sino, antes de todo, la exacta observancia del derecho objetivo, parecería natural que el Estado, aun dando al individuo la facultad de invocar justicia en favor propio cuando su derecho subjetivo apareciese sin satisfacer, no considerase, sin embargo, tal invocación como condición indispensable para poner en movimiento la jurisdicción; y atribuyese a los órganos judiciales un poder de iniciativa que permitiese a los mismos moverse de oficio, sin petición de parte, siempre que observasen una violación del derecho objetivo y considerasen poder proceder útilmente para restablecer su observancia.<sup>98</sup>

Notou Calamandrei que a pacífica relação feita pela doutrina entre o processo penal e o princípio inquisitório, de um lado, e o processo civil e o princípio dispositivo, de outro, é absolutamente falsa. Isto porque há processos civis de cunho eminentemente inquisitório, assemelhando-se em tudo [se não se identificando] com a ampla maioria dos processos penais, podendo também ocorrer o inverso.<sup>99</sup> A ideia, com efeito, de que a disponibilidade do direito material pelas partes é “natural” ao Código de Processo Civil e, portanto, impõe o princípio dispositivo (e também o da demanda), ou de que a indisponibilidade do objeto é “intrínseca” ao processo penal e, assim, exige o princípio inquisitorial é falsa, ao menos na ligação feita entre o caráter disponível/indisponível do direito e o ramo processual que com ele deve lidar.<sup>100</sup>

Resta, entretanto, o outro fundamento – indubitavelmente de maior peso – que sustenta o princípio da demanda, que é a busca na preservação da imparcialidade do juiz. Liebman, a propósito, considerando eventual possibilidade de ampliar os poderes do juiz, em detrimento da atividade das partes, afirma que retraindo os poderes das partes para ampliar os poderes inquisitórios do juiz significaria atenuar a diferença entre a função jurisdicional e a administrativa do Estado, introduzindo tendência paternalista que seria de todo indesejável.<sup>101</sup>

Não há dúvida de que, no geral, autorizar o magistrado a agir sempre de ofício põe em risco a garantia de sua imparcialidade. Justifica-se, assim, plenamente, a manutenção do princípio da demanda, mas apenas como princípio (que há, então, de admitir exceções). De fato, o papel “paternalístico”, a que aludia Liebman, a ser exercido pelo juiz deve ser, de regra, visto com certa reserva. Em casos excepcionais, todavia, parece ter ele cabimento, especialmente tendo em conta a realidade do Estado brasileiro, a pobreza (especialmente cultural) reinante, e a deficiente assistência jurídica por ele ofertada aos necessitados (embora prometida categoricamente – art. 5.º, inc. LXXIV, da CF).<sup>102-103</sup>

Nesse campo, vale sublinhar que a imparcialidade judicial não pode ser equiparada à sua neutralidade. O juiz imparcial não é aquele que se mantém como espectador da contenda judicial, sem nela interferir a não ser ao final, para declarar o vencedor;<sup>104</sup> o juiz imparcial é, apenas, aquele que não está previamente comprometido com alguma das partes ou das teses por elas esposadas. Hoje não se duvida mais que o magistrado tenha suas pré-convicções, suas opiniões, sua ideologia e que isso é intrínseco à sua atividade. Não se espera mais um juiz alienado, totalmente alheio a qualquer influência externa, ou ao resultado do processo.<sup>105</sup> Exige-se apenas um juiz capaz de decidir de forma aceitável, mediante critérios objetivados – e expressos em sua



motivação – a causa a ele submetida.

A imparcialidade que se exige do juiz hoje, deve ser vista como contraponto ao direito de contraditório, considerado como o direito das partes de “influir efetivamente” na decisão judicial. A decisão judicial deve ser produto do diálogo entre as partes e destas com o juiz. Por isso, a garantia de imparcialidade deve significar a possibilidade real de o magistrado se impressionar com os argumentos “de ambas as partes”, considerando-as para formar sua convicção. Não há como afastar o juiz de seus conceitos, preconceitos, preferências e experiências; espera-se, todavia, que tenha ele a capacidade de, apesar destas suas impressões prévias, estar aberto a receber as informações trazidas pelas partes e decidir com a influência destas.<sup>106</sup>

Assim, desde que preservada a imparcialidade do juiz – sob este aspecto – nenhum problema haverá com o abrandamento do rigor do princípio da demanda, especialmente se objetivar oferecer melhor prestação jurisdicional, mais adequada satisfação dos escopos da jurisdição, mais exata realização dos direitos ou mais precisa execução dos objetivos almejados pelo Estado brasileiro (arts. 1.º e 3.º, da CF).<sup>107</sup>

A imparcialidade exigida do juiz, portanto, não pode comprometer a sua tarefa de, como agente político, realizar os fins do Estado moderno.<sup>108</sup> O juiz, assim, que dispõe de poderes para melhor atender ao direito posto à sua apreciação não pode ser taxado de parcial quando opta por um ou outro meio de realizá-lo. Do mesmo modo, parece estranho considerar o magistrado parcial somente porque sai de sua postura passiva para, suprimindo deficiência (“evidentemente não desejada”) da parte oferece condições para realizar melhor seu mister. O juiz, afinal, não precisa mais ser visto com desconfiança, como alguém que precisa ser limitado pois representa faceta do Estado a ser manietada, como se via no direito liberal burguês. Hoje o juiz deve assumir a condição de autoridade – que lhe é própria – exercendo os poderes conferidos ao Estado – e atribuídos a este agente político em específico – para reconhecer, realizar e, enfim, atribuir, os direitos proclamados pela ordem jurídica. Com efeito, a respeito do afastamento do princípio da congruência no campo das tutelas específicas, pode-se dizer que

essa proibição [de decidir fora do pedido da parte] tinha que ser minimizada para que o juiz pudesse responder à sua função de dar efetiva tutela aos direitos. Melhor explicando, essa regra não poderia mais prevalecer, de modo absoluto, diante das novas situações de direito substancial e da constatação de que o juiz não pode mais ser visto como um ‘inimigo’, mas como representante de um Estado que tem consciência que a efetiva proteção dos direitos é fundamental para a justa organização social.<sup>109</sup>

É evidente que todo afastamento do princípio da demanda recomenda previsão expressa em lei. Não se advoga, por conta disso, que o magistrado seja investido de poder absoluto, de instaurar o processo e julgar-lhe o mérito, realizando a seu exclusivo juízo aquilo que entende ser o correto.

Parece, todavia, possível [e mesmo recomendável] que o legislador amplie os poderes do magistrado – não apenas no campo da prova (princípio dispositivo) como se tem constantemente visto – também no que respeita ao princípio da demanda, “não tanto para iniciar de ofício o processo”, mas quiçá para esclarecer às partes – especialmente àquelas em estado fragilizado ou em clara desvantagem – sobre a potencial extensão de seu direito e sobre possíveis consequências de sua exposição apenas parcial da causa de pedir ou do pedido, ou ainda da apresentação equivocada da causa petendi ou do pedido. Afinal, como salienta, a respeito, Menger que

tal condición jurídica [refere-se ele ao Verhandlungsmaxime] es cómoda y ventajosa para las clases pudientes, porque siendo cultas y estando bien asesoradas, saben tomar siempre a tiempo y oportunamente las iniciativas. Las clases pobres, en cambio, que para hacer valer su derecho se encuentran frente a un mecanismo de procedimiento tan complicado, sin asesoramiento y mal representadas o no representadas de modo alguno, deben por esa innatural pasividad del juez experimentar un gravísimo perjuicio.<sup>110</sup>

Essa possibilidade alinha-se ao princípio da cooperação (art. 5.º, do CPC) e parece ter sido expressamente acolhida em alguns preceitos do código. Assim, por exemplo, merece ser lida a previsão contida no art. 322, § 2.º, do CPC, a estabelecer que o pedido deve ser interpretado à luz da boa-fé e do “conjunto da postulação” e não mais de forma restritiva, tal como previa o Código

anterior.

No direito alemão, a propósito, impõe a lei que o tribunal deve sugerir a alteração das alegações ou dos pedidos, em certos casos. Lent, a respeito, menciona a hipótese em que se pede o pagamento de mercadorias pedidas e entregues, sem o oferecimento da prova do pedido, quando o comprador já consumiu tais bens; em tais casos a demanda fundada no contrato não seria admissível, mas poderia sê-lo aquela baseada em enriquecimento sem causa, o que autorizaria o juiz a advertir esta circunstância à parte.<sup>111</sup> Othmar Jauernig menciona outras hipóteses desta possibilidade, afirmando que

em processo de responsabilidade funcional, o autor pede a restituição em espécie, ainda que apenas possa pedir a indemnização em dinheiro. Aqui, o tribunal deve sugerir que o autor peça a indemnização pecuniária como pedido principal ou acessório; pois com isso se evita uma nova ação ao autor rejeitado no seu pedido de restituição em espécie, agora orientado a dirigi-la à indemnização pecuniária. Outros exemplos in BGH NJW 81,979: em vez da acção de reforma (§ 323) agora embargos à execução (§ 767); NJW 84,480: em vez do pedido de entrega da proposta de contrato, agora pedido de declaração de aceitação; BB 84,1314; modificação da parte (!); NJW 90, 2755: em vez da prestação ao autor, agora prestação ao sucessor; NJW 93, 325: acção declarativa, em vez de acção de condenação. – Limitativo com razão BGHZ, 7, 211 e seg.: não há, segundo o § 139, o dever de motivar a parte a propor outro pedido com fundamentos diversos dos anteriormente alegados; assim, BGH NJW 89, 171 (apenas?) para o processo de advogado.<sup>112</sup>

Para o direito brasileiro, seria possível conceber, de lege ferenda, a ampliação para o Código de Processo Civil da regra já existente no campo do processo penal, que prevê a *mutatio libelli* (art. 384, do CPP).<sup>113</sup> Assim, tratando-se de direito indisponível, ou sendo evidente o equívoco da parte, na fixação da causa de pedir ou no pedido, poderia o magistrado sugerir à parte a alteração de tais elementos, oferecendo nova oportunidade de defesa ao réu. Se é interesse do Estado aplicar da melhor forma possível o direito objetivo, oferecer justiça e promover a paz social, deve o juiz estar autorizado a, incoado o processo, oferecer condições às partes para que saibam exatamente o que estão discutindo e, especificamente, para que tenha ele certeza de que a existência de demanda parcial (com apenas parte do pedido possível, ou parte da causa de pedir viável) ou ainda de pretensão aparentemente inviável [pela exposição de pedido a princípio insustentável ou de causa de pedir incabível] “decorre efetivamente da intenção da parte e não de erro seu”.

Afinal, e apenas para lembrar, se é entendimento corrente que exercício apenas parcial da pretensão cabível pelo autor é inerente ao poder de disposição do direito (se o titular pode renunciar ao seu direito, ou transigir sobre ele, poderia também demandar apenas por parte dele, abdicando do restante), é preciso lembrar que, mesmo para esta disposição, é preciso a “manifestação da vontade”. Havendo vício nesta manifestação de vontade, parece razoável sustentar não ter havido genuíno ato de disposição, autorizando maior cautela na interpretação da pretensão parcial.

Vale recordar, a propósito, que este papel, atribuído ao magistrado, de orientar e advertir as partes não constitui novidade em nosso ordenamento jurídico. Com efeito, ele já existia e continua a existir na orientação dos efeitos da revelia – que acompanham a comunicação ao réu para se defender – ou na admoestação quanto aos efeitos decorrentes do não comparecimento para prestar o depoimento da parte (art. 385, § 1.º, do CPC), ou ainda no aviso judicial sobre possível modificação do regime do ônus da prova (arts. 373, § 1.º e 357, III, do CPC e art. 6.º, VIII, do CDC)<sup>114</sup>. Em todos estes casos, avisa o magistrado à parte dos efeitos eventualmente decorrentes de sua inação ou de sua ação defeituosa, sem que se veja aí qualquer lesão a interesse da parte, ao princípio da imparcialidade ou a outro critério diretor do processo. No tocante ao assunto, Tarzia, em interessante estudo voltado ao direito italiano, recorda a existência destes poderes (atribuídos ao juiz naquele ordenamento, ou a outro agente judiciário), mencionando decisões da Corte Constitucional italiana que tratam, positivamente, da matéria, ligando esse dever especialmente à condição de miserabilidade da parte, ou a seu déficit econômico ou cultural ou ainda, ao possível desconhecimento da lei.<sup>115</sup> Recorda, ainda, o autor, a previsão contida no art. 37, do Decreto real 289, de 1913, que dispunha que “il giudice dà alle parti ignare del diritto le istruzioni necessarie per giudizio, ammonendole sulle conseguenze dei loro atti e delle loro omissioni”, indicando ainda soluções semelhantes em outros países.<sup>116</sup>

Por outra parte, embora a previsão em questão se ligasse, primariamente, à conduta processual da parte, não há dúvida de que a mesma gerava claros reflexos sob o plano material. De fato, a conduta processual adotada pela parte poderia, não raro, apresentar-se com efeitos semelhantes (embora não idênticos) ao da renúncia ao direito.<sup>117</sup>

Se esta visão assistencialista do magistrado pode ser vista como exagerada e inadequada na normalidade dos casos, certamente haverá situações excepcionais em que ela poderá ser aplicada especialmente visando a equiparação das partes ou a perquirição da efetiva existência de vontade da parte na renúncia parcial do direito.

É claro que, em princípio, o legislador poderia atribuir este papel a outra pessoa, que não o juiz. Em outros sistemas, confere-se ao Ministério Público este papel, devendo, no Brasil, prestar-se a isto a Defensoria Pública. Todavia, até que estes órgãos estejam capacitados a atender a demanda enorme (considerada a parcela da população brasileira que seria destinatária desse papel assistencial), ou mesmo supletivamente, não há razão, ao que parece, para se desautorizar tal conduta ao magistrado. Se o juiz deve assumir seu papel de agente político, comprometido com os objetivos do Estado, parece razoável que ele deva zelar pela prestação de justiça (efetiva) e pela adequada realização dos direitos.

Como já se disse, é possível extrair da abordagem dada pelo Código ao pedido uma tendência no sentido aqui postulado. A interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação e sob o ângulo da boa-fé autoriza ver aí a tendência à cooperação judicial e a possibilidade (*rectius*, o dever) de o magistrado auxiliar a parte autora a compreender adequadamente a extensão do pedido feito.

É certo que essa abordagem, além de favorecer a adequada apresentação do litígio no processo, também contribui para a própria prestação jurisdicional. Evita que as partes voltem a litigar – por aspectos não trazidos na primeira demanda – e colabora para reforçar o compromisso estatal com a adequada solução do conflito.

É medida que merece ser prestigiada, sem que se possa apontar qualquer objeção séria a essa postura judicial.

## **8. Pedidos imediatos e pedidos mediatos**

Já se disse que o pedido pode ser examinado, para a ótica clássica, sob dois aspectos diversos. Fala-se aí em pedido “imediato” e em pedido “mediato”.

O pedido mediato é a vantagem que o autor espera obter, no mundo real, a partir do acolhimento de sua demanda. É o bem cuja propriedade reivindica; é o crédito que pretende cobrar; é a estabilidade que busca com a certeza jurídica.

Já o pedido imediato é a providência que a parte espera “do Estado-jurisdição”. Como se sabe, a ação é destinada, primeiramente, contra o Estado. O autor pede que o Estado tome certa providência, a fim de assegurar seu interesse. A essa providência buscada junto ao Estado, liga-se o denominado “pedido imediato”.

Essa figura deveria, atualmente, ter papel estritamente didático, já que o que realmente interessa à parte é a obtenção da proteção ao interesse descrito na demanda; é, enfim, satisfação à pretensão deduzida no processo. Todavia, ainda é comum considerar que o pedido imediato vincula a prestação jurisdicional, de modo que, se pedida providência declaratória, o juiz não pode outorgar providência constitutiva ou condenatória e assim por diante. Essa conclusão merece profunda revisão, porque não se pode tolerar que a proteção ao direito material seja deixada de lado, em prol de formalismos que se assemelham àqueles existentes no período das legis *actionem*.<sup>118</sup> Soa arcaico que um sistema processual tão preocupado com a efetiva tutela dos direitos ainda esteja preso ao pedido imediato formulado pela parte, de sorte que, formulado pedido “declaratório”, seja inviável ao juiz deferir medida “constitutiva”, ainda que esta seja a única capaz de atender ao pedido mediato formulado. Mais arcaico ainda parece esse sistema

diante das críticas recém vistas e que demonstram que, até mesmo em relação ao pedido *mediato* se tem admitido, muitas vezes, alguma flexibilização.

Porém, não é este o espaço para tal debate. Por ora, basta apontar a doutrina vigente e suas consequências.

## 9. Classificação dos pedidos

Costuma-se classificar os pedidos “imediatos” – deduzidos em face do Estado-jurisdição – a partir da providência desejada com a demanda. Nesse sentido, fala-se em pedidos declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental e executivo.

O pedido declaratório é aquele por meio do qual o autor pede a declaração da existência ou da inexistência de uma relação jurídica ou de seus efeitos (art. 19, I, do CPC), podendo excepcionalmente ser requerida uma declaração sobre um fato – o fato da falsidade ou inautenticidade documental (art. 19, II, do CPC).

O objetivo dessa forma de pedido imediato, destarte, é eliminar uma situação de incerteza que paira sobre determinada situação jurídica. O bem da vida outorgado ao autor, através da sentença declaratória acobertada pela autoridade da coisa julgada, é a eliminação da incerteza que recaía sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser da situação jurídica.

Frise-se, porém, que o interesse que legitima a postulação da providência declaratória é a dúvida objetiva que paira sobre a relação jurídica. É a dúvida resultante da controvérsia com alguém sobre a situação jurídica e não apenas a dúvida meramente subjetiva.<sup>119</sup>

Todas as sentenças de procedência implicitamente declaram que o autor tem razão. Portanto, é correto dizer que todas elas contêm declaração. Porém, as sentenças constitutiva, condenatória, mandamental e executiva, além de declarar, vão além. Somente a sentença declaratória contém apenas declaração, que é uma declaração sobre a existência ou a inexistência de um direito [em regra], com a qual se objetiva eliminar uma situação objetiva de dúvida.

O pedido é constitutivo quando se postula a criação, a extinção ou a modificação de uma situação jurídica. Ou seja, nesses casos, não basta a simples certificação feita pelo Estado a respeito de uma certa relação jurídica; impõe-se que a jurisdição atue para alterar a realidade normativa.

Todas as sentenças, até porque oferecem resposta a pedido formulado, contêm declaração. A sentença constitutiva, por exemplo, antes de formar, modificar ou extinguir uma situação jurídica, declara algo que possibilita a constituição ou a desconstituição.

A sentença declaratória difere da constitutiva, na medida em que ela é apenas declaratória, e por isso é chamada de declaratória *stricto sensu*. Assim, se o autor pretende desconstituir sua relação conjugal, e é proposta ação de divórcio, é lógico que, por exemplo, se a ação é fundada em conduta desonrosa, o pedido e a correspondente sentença tenderão a declarar tal conduta como pressuposto para a desconstituição da sociedade conjugal, que é o pedido realizado e que deve ser atendido pela sentença de procedência – frise-se que a conduta desonrosa é apenas fundamento do pedido. “Na sentença declaratória, ao contrário do que acontece na constitutiva, apenas se declara, bastando para se atender ao pedido declaratório a sentença declaratória *stricto sensu*”.

As sentenças declaratória e constitutiva, ao contrário das sentenças condenatória, mandamental e executiva, “bastam como sentenças por si” para atender ao direito substancial afirmado, enquanto as sentenças condenatória, mandamental e executiva “exigem atos posteriores” para que o direito material seja efetivamente realizado.

Há pedido condenatório quando se pede que o juiz condene o réu ao pagamento de certa quantia – por exemplo, ao pagamento de uma indenização. O juiz declara a responsabilidade, condena o réu ao pagamento de uma prestação, exortando-o ao cumprimento, ao mesmo tempo em que abre as portas da execução para o autor ao aplicar a chamada sanção executiva, que consiste na possibilidade de o autor do pedido condenatório, no caso de inadimplemento da

sentença, requerer a sua execução da sentença. Nessa linha de pensamento, a condenação opera um fenômeno complexo e vasto, que consiste na constituição de uma nova situação jurídica, autônoma no que concerne à relação substancial obrigacional, fundada na decisão estatal preordenada a que a sanção executiva seja atuada, a qual se resolve subjetivamente no poder do órgão processual de proceder posteriormente à atuação da sanção executiva, no poder do credor de provocá-la (ação de execução) e na sujeição do devedor a suportá-la (responsabilidade executiva).

Nessa perspectiva, do ponto de vista teórico, não há qualquer distinção entre a sentença condenatória que exige a propositura de ação de execução e a sentença condenatória, que pode ser executada como uma simples fase posterior, no próprio processo em que se desenvolveu a atividade de conhecimento. Ambas contêm a sanção executiva, embora uma exija a propositura de ação e a outra se contente com mero requerimento de execução, que se processa sem a necessidade de citação e como simples fase do processo em que também se desenvolveu a atividade de conhecimento. Dito de outro modo: constitui uma opção técnica ligada à política processual ter um processo autônomo de execução ou anexar a fase destinada à atividade executiva ao processo em que igualmente se desenvolveu a fase de conhecimento. O Código vigente adotou adequadamente a segunda opção (art. 513 e ss.).

Para que se compreenda com menor esforço o conceito de pedido condenatório, nada melhor do que um exemplo: no caso de acidente automobilístico, o autor pode pedir que seja declarada a responsabilidade do réu ou pedir que ele seja condenado a pagar uma soma pelo dano que foi provocado. A sentença condenatória contém um plus em relação à declaratória, pois, além de declarar a responsabilidade, impõe a sanção, permitindo ao vencedor requerer a sua execução na hipótese do seu não cumprimento. Caso a condenação seja cumprida, sendo desnecessária a atividade executiva posterior, a sentença condenatória diferirá da declaratória apenas porque o condenado sabe que, se não pagar voluntariamente, será requerida a execução, ou seja, porque a sentença condenatória contém mecanismo que abre as portas da execução. Efetivamente, quando se pede que o juiz condene, implicitamente se pede que o juiz aplique a sanção executiva: quando o juiz condena, implicitamente essa é aplicada.<sup>120</sup>

A ação condenatória – e a correspondente sentença condenatória – tem nítida relação com os valores do Estado liberal, não só pela razão de que não admite a coerção da vontade dos litigantes mediante a multa, como também pelo motivo de que os direitos que eram objeto da preocupação desse Estado podiam ser convertidos em pecúnia, podendo assim ser por ela tutelados.<sup>121</sup>

Além disso, é preciso notar que, se a ação condenatória é correlacionada com a execução por sub-rogação e pressupõe a violação do direito, ela jamais poderá buscar prevenir o ilícito. Como diz Liebman, a condenação é o ato que aplica, impõe, determina in concreto a sanção que o transgressor deverá sofrer pelo ato cometido.<sup>122</sup> “Como se vê, a condenação pressupõe o ato cometido, e, portanto, é eminentemente repressiva”.

Com efeito, a condenação “pressupõe” a violação do direito. A elaboração dogmática da ação e da sentença condenatória não teve qualquer preocupação com a prevenção do ilícito, mas apenas com a necessidade de reparação do direito violado.<sup>123</sup> Além disto, por incrível que pareça, a doutrina clássica supunha que a ordem do juiz, determinando que alguém não praticasse um ato ilícito, agrediria a liberdade do indivíduo.<sup>124</sup> Portanto, a sentença condenatória tem nítido escopo repressivo, estando longe de constituir ordem sob pena de multa, pois foi elaborada à luz de valores que não admitiam o seu uso (preocupação com a neutralidade do juiz e com a liberdade dos litigantes).

O pedido é mandamental quando o autor pede que o juiz “ordene” sob pena de coerção indireta [por exemplo, multa coercitiva]. Quando isso ocorre, pede-se algo diverso da simples condenação, pois o autor não quer apenas ter a possibilidade de requerer a execução – por expropriação – desejando que o juiz ordene que o réu faça [ou não faça] alguma coisa sob pena de coerção indireta. Em outros termos: nesse último caso deseja-se que a sentença pressione o réu (atue sobre a sua vontade) a fazer ou a não fazer algo (art. 497 do CPC). Enquanto o pedido condenatório visa apenas a que se abra oportunamente as portas da execução diante do inadimplemento do



demandado, autorizando a adoção de técnicas processuais executivas posteriores, o pedido mandamental está preordenado a que a própria sentença contenha desde logo as técnicas processuais capazes de induzir o demandado ao cumprimento do que é devido.

Se a sentença condenatória difere da declaratória por abrir oportunidade à execução forçada, a sentença mandamental delas se distancia por tutelar o direito do autor, forçando o réu a adimplir a ordem do juiz. Na sentença mandamental há ordem, ou seja, imperium, e existe também coerção da vontade do réu. Tais elementos não estão presentes no conceito de sentença condenatória, compreendida como sentença que abre oportunidade para a execução por expropriação, ainda que mediante simples requerimento do credor.

No sistema atual, as técnicas mandamentais podem ser empregadas para qualquer forma de prestação, de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar (arts. 139, IV, 537 e 538, do CPC).

Por fim, há o pedido executivo, que faz surgir a sentença executiva, que tem por objetivo corrigir as linhas que separam as esferas jurídicas do autor e do réu, por meio da atuação direta sobre o seu patrimônio, por meio de técnicas processuais atípicas, que independem de uma fase de cumprimento de sentença, estruturada a partir da técnica expropriatória.

É importante deixar claro que há duas maneiras de considerar a ação e a sentença executivas.

A primeira, devida a Pontes de Miranda, é a que parte da premissa de que a executividade, por si só, altera a denominada linha discriminativa das esferas jurídicas, ao passo que, no caso de condenação, tal alteração somente ocorre com a execução por expropriação, pois é esta que retira um bem da esfera jurídica do devedor e o transfere para a esfera jurídica do credor.<sup>125</sup>

Pontes de Miranda afirma que o autor da ação reivindicatória pede a coisa que está, contrariamente ao direito, na esfera do demandado, não ocorrendo o mesmo na condenação e na execução que a segue, já que aí os bens estão, de acordo com o direito, na esfera do “devedor”. Na execução, com efeito, há a retirada do bem da esfera jurídica do devedor para a esfera jurídica do credor, ocorrendo o que Pontes de Miranda chama de modificação da linha discriminativa.<sup>126</sup> Mas essa modificação, no caso de ação reivindicatória, ocorre no momento em que a sentença é proferida, pois aí, como bem disse Satta, o proprietário é reconhecido como tal no confronto do possuidor ilegítimo.<sup>127</sup>

De acordo com Satta, aquele que, na ação reivindicatória, é reconhecido pela sentença como proprietário, precisa apenas exercer o direito de propriedade para retomar a coisa que lhe pertence, sendo-lhe vedado agir privadamente apenas porque a posse do réu, “ainda que ilegítima”, é tutelada pelo ordenamento jurídico.<sup>128</sup> Não seria necessária a execução por expropriação, pois essa somente seria exigível quando houvesse a necessidade da retirada de um bem que está legitimamente na esfera jurídica do réu, lembrando que o direito de propriedade, diante da execução por expropriação, pertence ao devedor, sendo sua posse legítima, ao contrário do que ocorre na sentença reivindicatória, que estabelece, por si só, que o direito de propriedade pertence ao autor e que a posse do réu é ilegítima. É nesse sentido que, para Pontes de Miranda, existiria diferença entre a sentença executiva e a sentença condenatória.

Mas não é essa a nossa visão acerca da natureza da sentença executiva. Os pedidos imediatos e, conseqüentemente, as sentenças, a nosso ver, tomam em consideração para serem classificados sob essa forma critérios processuais, e não elementos de direito material. A distinção entre as sentenças condenatória, mandamental e executiva toma em conta os meios de execução e os valores e princípios que se ligam a cada uma delas.

A sentença condenatória é uma técnica despreocupada com a proteção da integridade dos direitos (com a tutela específica) e com o caso concreto, pois objetiva a tutela prestada através do pagamento de quantia certa, especialmente a tutela pelo equivalente monetário ao valor da lesão, e por isso foi ligada a uma única forma de execução direta – a execução por expropriação – expressamente tipificada pelo legislador, sem dar ao juiz qualquer possibilidade de consideração das peculiaridades da situação litigiosa.

A sentença executiva se realiza através dos meios de execução direta, adequados à tutela específica do direito e ao caso concreto, que devem ser utilizados pelo autor e pelo juiz, segundo as regras do meio idôneo e da menor restrição possível, ou segundo a lógica de que a modalidade executiva deve ser idônea à tutela do direito, sem deixar de ser a menos gravosa ao réu. O fundamento da sentença executiva, especialmente do poder de determinar o meio executivo adequado ao caso concreto, está no art. 536, que expressamente alude às “medidas necessárias”, exemplificando ao fazer referência a algumas delas, como a busca e apreensão, que pode ser determinada na sentença de procedência.

É o que ocorre, por exemplo, para a tutela do direito à coisa (art. 498) e para a tutela destinada a suprir a prestação da declaração de vontade (art. 501). O instrumento, porém, pode ser empregado para qualquer modalidade de prestação, seja ela de fazer, de não fazer, de entregar coisa, ou de pagar (arts. 139, IV, 536 e 538, do CPC).

**Art. 322.** O pedido deve ser certo.

§ 1.º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2.º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

### **1. Pedido certo**

A primeira imposição feita pelo código em relação ao pedido é que ele seja “certo”. Como se verá adiante, ele também deve ser determinado (art. 324, do CPC). Corrigindo falha de redação do Código anterior e do código de 1939<sup>129</sup> – que afirmavam que o pedido deveria ser certo “ou” determinado – a lei atual claramente afirma que o pedido deve contemplar ambas as qualidades, não bastando apenas uma delas, salvo nos casos previstos em lei.

Considera-se “certo” o pedido que é expresso,<sup>130</sup> não se tolerando, em regra, pedidos implícitos, salvo quando haja previsão de lei.

Afirma-se que a certeza (bem como a determinação) deve atingir tanto o pedido mediato, como o imediato. Não há dúvida de que o pedido mediato deve ser certo. Não se pode pretender “qualquer coisa” ou “aquilo que o juiz entender mais adequado”. É necessário saber-se o interesse que deve ser protegido e, portanto, aquilo que o autor pretende. Porém, em relação ao pedido imediato, já se teve a oportunidade de indicar o anacronismo da exigência de sua certeza e determinação.

Não parece haver sentido em negar tutela jurisdicional à parte apenas porque, buscando a nulidade de certo contrato, formulou ela pedido desconstitutivo quando deveria ter formulado pedido declaratório. Se é certo que sua pretensão se dirige à nulidade [ou à anulação, ou à ineficácia, ou mesmo à inexistência] da relação jurídica, então o pedido imediato formulado deve ser tido como indiferente. É suficiente para a defesa do réu entender aquilo que efetivamente é buscado pela parte, não sendo razoável negar a proteção apenas porque o pedido imediato formulado não está de acordo com aquilo que normalmente se supõe seria o provimento judicial a respeito do assunto.<sup>131</sup>

Assim, embora efetivamente se deva exigir a certeza quando ao pedido mediato, parece excessivo impor a certeza também quanto ao pedido imediato, sobretudo quando haja dúvida razoável em relação à sua natureza ou quando irrelevante para a defesa adequada do réu.

Assim, basta que a parte tenha formulado expressa e claramente a pretensão que exerce para que se tenha por satisfeito o requisito de certeza imposto pelo art. 322, do CPC. Bastará, portanto, que se saiba aquilo que a parte deseja para que haja pedido certo.

### **2. Pedido implícito**

Embora, como regra geral, se exija a certeza quanto ao pedido, ou seja, sua explicitação clara,



em certos casos a própria lei presume a formulação de certos pedidos.

Assim, por exemplo, ocorre com o art. 322, § 1.º, que inclui do pedido, ainda que não haja expresso requerimento nesse sentido, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, aí também considerados os honorários advocatícios.

Os juros que se consideram incluídos no pedido são apenas os juros legais.<sup>132</sup> Estes são apenas os juros moratórios, embora na vigência do código civil anterior se considerassem aí também incluídos os juros compensatórios.<sup>133</sup> Não constitui pedido implícito, por outro lado, aquele que se refere aos juros contratuais, já que estes não decorrem de lei, mas do negócio jurídico. Por outro lado, algumas hipóteses legais admitem, como pedido implícito, também os juros remuneratórios, a exemplo do que faz o art. 591, do CC, que trata do mútuo com finalidade econômica.

Nos termos do que dispõe o art. 406, do CC, os juros legais são estipulados “segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.<sup>134</sup> Inicialmente, houve muita polêmica sobre a interpretação desse dispositivo. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havia decisões que aplicavam, para a fixação do parâmetro indicado no Código Civil, o art. 161, § 1.º, do CTN, ou seja, o índice de 1% ao mês.<sup>135</sup> Em sentido diverso, outros julgados daquela Corte que se valeram da taxa SELIC (e, portanto, de um índice variável) como o índice referido pelo art. 406, do CC, embora com a advertência de que esse índice reflete tanto a correção monetária como os juros de mora.<sup>136</sup> Esta última corrente é a predominante, atualmente, de modo que, por juros legais, no entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar o índice SELIC, que incorpora tanto juros de mora, como correção monetária.

Quanto à correção monetária, dispõe o art. 1.º, da Lei 6.899/1981 que “a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios”.<sup>137</sup> Não há dúvida, portanto, de que a imposição desse ajuste é oriundo de disposição expressa de lei. Por isso, evidentemente seria natural que se considerasse implícito esse pedido já que, ainda que não formulado, sua outorga decorreria de determinação legal.

Também se considera implícito o pedido referente às prestações vincendas (art. 323, do CPC) e o pagamento das despesas do processo (art. 82, § 2.º, do CPC), aí incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, do CPC).

Atualmente, pode-se ainda dizer que há pedidos implícitos que decorrem do “conjunto da postulação” ou da boa-fé, tal como preconiza o art. 322, § 2º, do CPC. Assim, a solução de questão que seja reflexo do pedido expressamente formulado ou de pretensão que decorra de interpretação lógico-sistemática dos fatos descritos nas postulações não leva a decisões *extra* ou *ultra petita*.<sup>138</sup>

Afirma-se que o pedido implícito não deve ser confundido com a “condenação implícita”. Por outras palavras, diz-se que, nos casos aqui estudados, ainda que omissa a petição inicial, pode e deve o juiz incluir tais verbas na condenação; porém, se omissa a decisão, não seria lícito à parte incluir esses valores na execução.<sup>139</sup>

Não parece que essa orientação caiba mais no direito vigente. Se a inclusão desses valores é, como visto, imposição legal, a omissão da sentença em se referir especificamente à sua inclusão não pode implicar a conclusão de que tais valores deixem de ser devidos. A ausência de referência expressa deve apenas ser tomada como suposição de que esses valores já estão, por lei, incluídos no montante devido. De certa forma, o art. 85, § 18, do CPC, corrobora essa conclusão, ao permitir o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança de honorários ainda diante da omissão da sentença. Se isso vale para essa verba, nada explica que se desse tratamento diverso aos outros valores, cuja inclusão na condenação é imposta por lei.<sup>140</sup>

Diverso seria o problema caso a sentença houvesse incluído “outro índice ou outro valor” em resposta a tais “pedidos implícitos”. Assim, por hipótese, se a sentença houvesse atribuído índice de correção monetária diferente do estipulado em lei ou taxa de juros diversa daquela

efetivamente devida. Aí não há omissão; há expressa condenação que, se transitada em julgado, não autoriza nova discussão.

### 3. Interpretação do pedido

Havendo dúvida a respeito do alcance do pedido, deve o juiz interpretá-lo considerando o “conjunto da postulação” e de acordo com o “princípio da boa-fé” (art. 322, § 2.º). Vale dizer: deve-se interpretá-lo sem “formalismo excessivo”, e considerando as declarações de vontade do autor que ressaem da sua manifestação na petição inicial – e, também, no restante dos atos praticados no curso do processo, já que a postulação não se resume, como parece ser evidente, à petição inicial, sendo formada também por todos os demais atos praticados pela parte ao longo do procedimento – como um todo.<sup>141</sup>

Quando se afirma que a análise do pedido deve considerar o conjunto da postulação, é preciso considerar que a postulação não se confunde apenas com a petição inicial. Embora ali se apresente o núcleo mais fundamental da “postulação”, é certo que essa postulação é desenhada ao longo de todo o processo. Por isso mesmo é que o art. 493, do CPC, afirma que qualquer fato “constitutivo”, modificativo ou extintivo do direito influenciar na análise do litígio, deve o juiz tomá-lo em consideração, seja de ofício ou a requerimento, ao examinar a pretensão deduzida. Vale dizer que a postulação é ato complexo, que pode ser construído no curso do processo ou que, pelo menos, pode sofrer alterações no decorrer da relação processual.

Por isso, não é de se estranhar que, muitas vezes, o pedido formulado inicialmente não é mais útil ao final do processo e, por isso, exige outro tipo de resposta. No campo previdenciário, por exemplo, têm sido recorrentes decisões que autorizam, para fins de outorga de benefício previdenciário mais vantajoso, a contagem de tempo de serviço ocorrido durante o processo.<sup>142</sup> Ademais, há casos clássicos de fungibilidade de pedidos no curso do processo, tal como sucede nas ações possessórias (art. 554, do CPC) ou nas ações acidentárias. Não se esqueça ainda a figura da conversão da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente em execução, se não encontrado o bem gravado (art. 4.º, Dec.-lei 911/1969, na redação dada pela Lei 13.043/2014), que autoriza troca de procedimento no curso de demanda, à luz dos acontecimentos da causa.

Enfim, não deve assustar a ninguém a possibilidade de se tomar todo o arco do desenvolvimento do processo para avaliar a extensão e a amplitude dos pedidos formulados. Ao contrário, é só assim que realmente se terá condições de saber qual providência será efetivamente útil ao momento da prolação da decisão final.

Por fim, recorde-se que o Código vigente não determina interpretação “restritiva” do pedido – como o Código anterior. Embora o Código enuncie esse postulado interpretativo do pedido como um parágrafo do art. 322, é certo que esse se aplica não só para a interpretação do pedido mediato, mas constitui uma norma geral para interpretação de todo e qualquer pedido ou requerimento formulado no curso do processo.

**Art. 323.** Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

#### 1. Prestações sucessivas

Por razões de economia processual – e visando a evitar a desnecessária propositura de ações sucessivas – o código considera como mais uma hipótese de pedido implícito a das prestações sucessivas, na demanda que tiver por objeto do cumprimento daquelas já vencidas. Regra semelhante foi prevista para a ação de consignação em pagamento (art. 541, do CPC) e para a ação de consignação de aluguéis (art. 67, III, da Lei 8.245/1991).

Considera-se obrigação de prestação sucessiva aquela que contém prestações que se sucedem periodicamente para o obrigado.<sup>143</sup> Por isso, logicamente, a regra em exame só incide quando constituir objeto do processo a exigência de prestação sucessiva. Se, em um contrato contendo

obrigações sucessivas, surge controvérsia judicial a respeito de outro aspecto seu ou de outra obrigação ali contida, por certo não pode haver a condenação às prestações sucessivas. Também não incide a regra se a obrigação periódica tem caráter acessório e só se demanda no processo pela obrigação principal (não periódica).<sup>144</sup>

Todavia, para que se caracterize o pedido implícito aqui examinado, não é necessário que as prestações vincendas assumam a mesma natureza ou o mesmo valor das expressamente demandadas. Bastará que sejam prestações sucessivas para que a regra incida. Em razão disso, ainda que as prestações vincendas tenham natureza diversa da vencida ou valor distinto, caracteriza-se o pedido implícito e estas devem ser presumidas como integrantes da condenação.

Por outro lado, é necessário que se trate de prestações periódicas e não, simplesmente, de prestações futuras. Prestações futuras que não se liguem à raiz da prestação requerida na inicial, e que não tenham a característica de renovar-se periodicamente, não podem ser qualificadas como “prestações sucessivas” e assim estão fora do art. 323, do CPC.

## **2. Condenação para o futuro**

Afirma o art. 323 que a presunção de inclusão no pedido das parcelas vincendas segue “enquanto durar a obrigação”.

Isso significa dizer que, aqui, a condenação existente pode, eventualmente, gerar efeitos prospectivos, ou seja, para além de sua prolação e até mesmo além do seu trânsito em julgado. Como afirma Calmon de Passos

justifica-se a exceção, em primeiro lugar, pela conveniência de evitar a repetição de litígios idênticos (vantagem de economia processual e de uniformidade de julgamentos) e, em segundo lugar, pelo interesse que pode ter o credor em possuir já um título executivo no momento do vencimento da obrigação (formação antecipada do título executivo). A lei considera digno de proteção esse interesse do credor.<sup>145</sup>

Significa isso dizer que a sentença condenatória que impuser o adimplemento das prestações expressamente postuladas servirá de título executivo para as prestações vincendas, ainda que estas venham a vencer depois do trânsito em julgado da sentença, ou mesmo, que venham a vencer quando já iniciada a execução das parcelas vencidas, até o início da fase do cumprimento. Enquanto durar a vigência da obrigação, a sentença serve como título executivo das parcelas que forem exigíveis, independentemente da propositura de nova ação de conhecimento.

Trata-se aí de típica condenação para o futuro. Havendo adimplemento tempestivo das prestações vincendas, nada haverá a ser exigido. Porém, tornando-se exigível parcela vincenda não adimplida, será desnecessária nova ação de conhecimento, servindo a condenação já havida como título para a efetivação destas prestações.<sup>146</sup>

Logicamente, porém, embora essa condenação para o futuro faça coisa julgada sobre aquilo que foi efetivamente discutido e o que poderia ter sido (art. 508), não impedirá que no futuro cumprimento das prestações que se vencerem, por exemplo, depois do trânsito em julgado, venham as partes a discutir questões que não estavam abrangidas por essa eficácia preclusiva. Fatos novos ou questões externas ao material discutido na demanda de conhecimento certamente poderão prestar-se como matéria de defesa para o executado, na linha do que prevê o art. 525, § 1.º, VII, do CPC. Identicamente, fatos novos poderão subsidiar nova ação por parte do credor, tendente seja a majorar as prestações novas, seja a postular outro provimento.

Por fim, vale reafirmar, com base nas considerações já desenvolvidas nos comentários ao artigo anterior, que o pedido implícito aqui examinado se considera incluído na condenação “ainda que a sentença não disponha expressamente a seu respeito”. Isso é evidente com relação às prestações a vencerem depois do trânsito em julgado, mas é lógico que a mesma ratio se aplica às anteriores a esse momento.

Assim, ainda que a sentença não haja expressamente disposto sobre essa condenação, o efeito

permanecerá e o título estará formado.

### 3. Consignação das prestações vincendas

O código diz que as prestações vincendas serão incluídas na condenação e podem ser ulteriormente exigidas se não houver seu pagamento ou sua “consignação”.

Propriamente, não se exige a “consignação” das parcelas vincendas, sobretudo porque não há recusa do credor em recebê-las. A consignação mencionada significa apenas o seu depósito, caso a parte deseje controverter a seu respeito.

Assim, não havendo o pagamento das prestações vincendas ou – se a parte pretender discutir sobre elas no processo ou em ulterior demanda judicial – o seu depósito, incidirá o efeito condenatório e, a seu tempo (quando exigível a prestação) poderá ela ser objeto de cumprimento de sentença.

**Art. 324.** O pedido deve ser determinado.

§ 1.º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I – nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III – quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2.º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

#### 1. Pedido determinado

Além de certo, o pedido deve ser determinado. Considera-se determinado o pedido que tem seus limites bem definidos. Sabe-se o que se pede, de quem se pede e, no caso de condenação, quanto se pede. O pedido, assim, deve especificar com clareza a quantidade e a qualidade daquilo que se pretende. Por outras palavras, o pedido deve vir definido, de forma individualizada, com especificação precisa daquilo que se busca. Na lição de Frederico Marques, “pedido determinado é o que externa uma pretensão que visa um bem jurídico perfeitamente caracterizado”.<sup>147</sup>

No direito brasileiro, a regra é que o pedido seja determinado. Assim se permite que o juiz também ofereça julgamento determinado, que dispense determinação (liquidação) ulterior. Aliás, ainda quando formulado pedido indeterminado, o sistema dá clara preferência a julgamentos “determinados” (líquidos), como se infere do disposto no art. 491, do CPC.<sup>148</sup> Ou seja, em prol de decisões líquidas e determinadas, o código chega até mesmo a transpassar os limites do pedido, outorgando sentença precisa ainda que o pedido tenha sido indeterminado.<sup>149</sup>

Isso implica dizer que há clara preferência legal para que o requerente da tutela jurisdicional do direito formule pedido o mais específico possível. Isso, de um lado, facilita a compreensão da pretensão pelo réu e, conseqüentemente, sua defesa. De outro, isso promove a economia processual, evitando ou simplificando a fase de eventual liquidação do título judicial.

Por isso, se o autor formula pedido determinado, a decisão judicial também deve guardar essa qualidade. Porém, ainda que o autor tenha formulado – nos casos autorizados – pedido indeterminado, sempre que possível deve o juiz oferecer sentença determinada. Com efeito, pode suceder que, no curso do processo, a prova dos autos ou a determinação dos fatos permita a especificação do pedido, o que determinará a prolação de sentença líquida. Sempre que assim ocorrer, deve o juiz buscar a determinação da sentença. A indeterminação – sobretudo da sentença –, por isso, é exceção a ser evitada ao máximo.

#### 2. Pedido “genérico”

Embora a regra seja a veiculação de pedido determinado, excepcionalmente autoriza a lei que o

autor formule pedido “genérico”. A expressão é criticada há muito, mas foi mantida no Código de 2015.

Seja como for, não é verdade que a lei admita a elaboração de pedido “genérico”. Não se tolera que a parte formule pedido da espécie “dê-me o que for de direito” ou “conceda-me o que for justo”. O que se admite é uma “relativa” indeterminação do pedido, incidente, “exclusivamente”, sobre o elemento quantitativo do pedido.

Assim, essa indeterminação só tem cabimento em relação aos pedidos que impõem prestação fática (fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar), e jamais quanto a pedidos declaratórios e constitutivos. De forma mais precisa, pode-se afirmar que só o pedido mediato pode sofrer de certa indeterminação, já que o pedido imediato será sempre definido, ainda que a vinculação judicial a essa definição possa receber atenuações, como já visto. Mais do que isso, porém, só é possível que a indeterminação incida sobre o quantum debeatur, mas nunca sobre os outros elementos da condenação, a exemplo do an debeatur.

Ademais, em todos os casos em que é admissível pedido “indeterminado”, a indeterminação será apenas temporária, já que haverá um momento em que será possível a perfeita quantificação da pretensão deduzida.

A indeterminação parcial do pedido pode ocorrer basicamente diante de duas situações previstas no texto legal. Em primeiro lugar, em razão da alternatividade do objeto da prestação pretendido (art. 325, do CPC), tema a ser examinado nos comentários ao artigo subsequente. Em segundo, quando impossível a determinação do quantum debeatur.

O Código arrola hipóteses dessa segunda situação no art. 324, § 1.º, permitindo a formulação de “pedido genérico” em três circunstâncias: a) nas ações universais, se não for possível precisar os bens a serem exigidos; b) quando as consequências do fato – ou do ato – ainda não estiverem determinadas; c) quando a especificação do objeto ou do valor da condenação depender de fato a ser prestado pela parte contrária.

Todavia, não são apenas esses os casos em que a lei autoriza a formulação de “pedido genérico”.<sup>150</sup>

No campo da tutela coletiva, por exemplo, autoriza-se a prolação de sentença coletiva de condenação genérica (art. 95, do CDC), como uma das técnicas admissíveis para a proteção de direitos individuais homogêneos. Ademais, embora sem previsão de lei, a jurisprudência nacional permite que, em ação que pretende a reparação de danos morais, seja formulado “pedido genérico”, sobretudo à vista da dificuldade em arbitrar com precisão o valor da indenização.<sup>151</sup>

Enfim, o Código não esgota, nos casos descritos no art. 324, § 1.º, as situações que admitem “pedido genérico”. Apenas a análise das circunstâncias concretas e a verificação da impossibilidade de pronta definição dos limites do pedido mediato é que poderão permitir ao Judiciário verificar a legitimidade ou não do pedido indeterminado formulado.<sup>152</sup> Logicamente, daí não deflui a conclusão de que a parte possa, por desleixo ou por inépcia, deixar de formular pedido certo e determinado. Sempre que possível, a determinação legal é por esse tipo de pedido. Porém, não sendo viável, deve-se abrir espaço para a formulação de pedido indeterminado, que será especificado adiante.

### **3. Ações universais**

O primeiro caso em que a lei autoriza a formulação de pedido indeterminado é a hipótese de ações universais, desde que o autor não possa desde logo individualizar os bens pretendidos.

Ações universais são ações em que a parte pretende uma universalidade. Segundo o Código Civil, as universalidades podem ser de fato ou de direito. São universalidades de fato “a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária” (art. 90, do CC). Constituem universalidade de direito, por outro lado, “o complexo de relações



jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico” (art. 91, do CC). São exemplos de universalidade de direito o patrimônio e a herança; seriam, ao contrário, universalidades de fato uma biblioteca, um rebanho ou uma coleção de selos. As universalidades de direito, ao contrário das universalidades de fato, têm conteúdo juridicamente certo, estabelecido em lei.<sup>153</sup>

Várias ações podem pretender universalidades, total ou parcialmente. É assim a petição de herança ou com a ação tendente à entrega de certo conjunto de bens, a exemplo de um rebanho.

Sempre que possível, o autor deve, mesmo nas ações universais, individualizar os bens que pretende. Todavia, há vários casos em que isso não é possível, exatamente porque a lei ou o negócio jurídico não atribuem, previamente a ele, determinados bens do conjunto.

Nesses casos, autoriza-se a formulação de pedido genérico.

Note-se, de todo modo, que é indispensável para que incida a autorização legal que seja impossível ao autor individuar, na petição inicial, os bens buscados. Sendo isso possível, não cabe o pedido indeterminado. Assim, o pedido indeterminado é sempre excepcional, só incidindo quando as circunstâncias concretas não permitirem a individualização dos bens pretendidos.

Ademais, é importante notar que o código não faz qualquer distinção entre ações universais para pretensões destinadas a universalidades de direito ou de fato. Assim, ambas as situações comportam pedido indeterminado, desde que, sempre, seja inviável a determinação dos bens pretendidos.

Calmon de Passos questiona quais seriam as consequências de, em sendo possível a determinação do pedido, ter o autor formulado pedido indeterminado nesses casos. A seu ver, essa irregularidade não geraria qualquer vício ao processo, na medida em que o juiz poderia sempre, nesses casos, outorgar sentença determinada, fixando o quantum debeatur. Diante da ausência de sanção específica para essa situação, o fato passaria como simples irregularidade formal.<sup>154</sup>

Tem razão essa orientação. Efetivamente, sendo possível a prolação de sentença líquida (art. 491, do CPC), é imposição feita ao juiz que assim proceda, ainda que o pedido tenha sido indeterminado. Logo, não há nulidade nesse tipo de caso, nem se cogita aí de sentença extra ou ultra petita.

Por outro lado, ainda que possível, seria sempre desejável que o juiz – em face do princípio da cooperação – advirta a parte das consequências desse pedido indeterminado, até para que, podendo, supra a omissão e, sendo possível, identifique os bens pretendidos.

#### **4. Determinação imediata das consequências do ato ou do fato**

Outro caso em que é autorizado pelo dispositivo em exame, a formulação de pedido indeterminado ocorre diante do não exaurimento, quando da propositura da ação, das consequências do ato ou do fato que constitui a razão da demanda.

Várias situações concretas operam efeitos ao longo do tempo e não seria razoável exigir que a parte aguardasse o acontecimento de todas essas consequências para só então – podendo formular pedido determinado – ser admitida a ajuizar sua demanda. Por isso, autoriza a lei que, ainda que não ocorridas as consequências – ou ainda que não ocorridas “todas” as consequências – seja possível propor desde logo a ação, deixando-se a apuração desses efeitos para momento futuro.

É o que sucede, comumente, em ações nas quais se pretende o ressarcimento de prejuízos ainda não consumados integralmente. Os lucros cessantes ainda não estão definitivamente conformados ou as consequências da lesão havida ainda não têm efeitos estabilizados (não se sabe se, diante do acidente, a pessoa perderá alguma de suas capacidades ou mesmo se morrerá etc.). Não há, enfim, a determinação precisa da extensão das consequências a que se refere o ato ou o fato que constitui a causa da ação.

Esta espécie de pedido indeterminado decorre, como é fácil notar, da própria natureza das

coisas e da falta de definição precisa das consequências que devem ser atribuídas ao fato ou ao ato que constitui a causa petendi da demanda. Por isso, não há propriamente necessidade de a parte comprovar essas circunstâncias para que possa formular pedido indeterminado. Isso decorre das regras de experiência, que o juiz deve aplicar de forma autônoma.

O Código de 2015 supera o anterior ao excluir a referência a “ato ou fato ilícito” do texto legal. Com efeito, é evidente que tanto o ato [ou o fato ilícito], como o lícito, operam consequências e, por isso, ambos podem ser objeto de discussão judicial. Logo, não é necessário, para a incidência da hipótese de pedido indeterminado, que a discussão do processo constitua “ato” ou “fato ilícito”. Basta que haja ato ou fato (lícito ou ilícito) do qual surjam consequências ainda não determinadas de forma definitiva, para que seja lícita a formulação de pedido indeterminado. Pense-se, por exemplo, no caso da ação de indenização por desapropriação indireta. É certo que o ato ocorrido aí, em si, é ato lícito; é também certo que desse ato podem surgir consequências ainda não delimitadas quando do ajuizamento da ação. Aí é, sem dúvida, possível a formulação de pedido indeterminado.

Sob outro viés, pode ocorrer que o ato ou o fato opere consequências em parte determinadas e em parte indeterminadas. Nesse caso, deve o autor formular pedido determinado até a extensão do possível, deixando indeterminado o restante da postulação. Assim ocorre, por exemplo, quando os danos emergentes já são inteiramente conhecidos, mas os lucros cessantes ainda não. Nesse caso – até para que se possa determinar de forma mais precisa o valor da causa e as consequências daí decorrentes (a exemplo da competência) – deve o autor pedir de forma precisa o valor já apurado, deixando em aberto o restante.

Calmon de Passos questiona, com apoio no direito português, se poderia o autor, no caso de consequências ainda não definitivas, formular pedido líquido ou “o que vier a liquidar-se em execução de sentença”. Conclui que isso é sim possível, dizendo que “se acaso há dúvida no que diz respeito ao quantum devido, nada impede que se ponha a definição quantitativa do pedido em alternativa”.<sup>155</sup> A seu ver, portanto, essa modalidade de cumulação alternativa de pedidos seria viável, sobretudo porque ainda impossível a determinação precisa das consequências do ato ou do fato discutido no processo. Parece que essa solução encontra respaldo ainda maior no CPC vigente, à luz do que prevê o art. 326, parágrafo único.

Em todo caso, formulado pedido indeterminado diante dessas consequências futuras, pode suceder que esses efeitos sejam integralmente concretizados ao longo do processo. Nesse caso, se essas consequências são apuradas antes da sentença, devem ser consideradas pelo juiz, de forma a levar à prolação de sentença líquida. Só se admite sentença ilíquida se, no momento em que ela é proferida, ainda não estiverem completos os elementos para a definição dessas consequências. Como já se disse, a regra é sempre o pedido e a sentença líquidos, sendo excepcional a situação diversa.

## **5. Ato a ser praticado pelo réu**

O terceiro caso em que é admitido o pedido indeterminado é aquele em que o pedido “determinável” só se torna “determinado” depois de ato a ser praticado pelo réu. Seria, nesses casos, evidentemente absurdo e contrário à regra da economia processual, impor ao autor que propusesse duas ações – uma tendente à prática do ato pelo réu e outra que buscasse a satisfação da pretensão subsequente, v.g., à reparação do prejuízo. Por isso, nesse caso, a lei autoriza uma espécie peculiar de cumulação eventual de pedidos; no pedido formulado estará embutido outro pleito antecedente, consistente na conduta que se espera do réu, ou sucessivo, consistente nas consequências apuradas depois do fato prestado pelo réu. Por outras palavras, postula-se, em primeiro lugar, a prática de ato pelo réu e, depois, se necessário, a satisfação de outra pretensão.

É o que ocorre, tradicionalmente, com a ação de exigir contas (art. 550 e ss., do CPC). Antes de prestadas as contas pelo réu, dificilmente o autor tem condições de estimar se algo lhe é devido e, muito menos, quanto lhe é devido. O procedimento, por isso, desenvolve-se em dois momentos: o primeiro para que o réu preste as contas e o segundo para que se examine se há consequências exigíveis a partir das contas prestadas.



Embora esse seja o exemplo clássico, pode-se também considerar que entra nessa hipótese a ação que tende à prestação de fazer. Prestado o fato, pode-se verificar que a prestação é incompleta, insuficiente ou defeituosa. Nesses casos, haverá o processo de prosseguir, seja para que a prestação seja realizada de forma perfeita, seja para que se indenizem eventuais prejuízos decorrentes dessa falta. Veja-se que o próprio CPC vislumbra essa possibilidade, regendo essa situação para processos de execução – mas em hipótese absolutamente aplicável também para ações de conhecimento tendentes a essa prestação – no art. 819. Neste caso, então, o autor formulará o pedido de prestação de fazer, sendo a indenização um *posterius* eventual.

O CPC aperfeiçoa a redação do artigo correspondente do Código de 1973 (art. 286, III), ao ampliar essa hipótese de pedido indeterminado. A lei anterior referia-se exclusivamente à “determinação do valor da condenação” que dependesse de ato a ser praticado pelo réu. O Código atual, acertadamente, alude à “determinação do objeto ou do valor da condenação”, deixando claro que a regra não se limita a dívidas de valor e, portanto, a obrigações pecuniárias.

## **6. Pedido reconvenicional**

Afirma o art. 324, § 2.º, do CPC, que as hipóteses de pedido indeterminado se aplicam também ao pedido reconvenicional.

A previsão soa redundante, na medida em que a reconvenção é, sempre, ação nova, proposta pelo réu. Nessa condição, ela sempre apresenta pedido que deverá, por óbvio, respeitar “todos” os ditames da lei processual a respeito desse requisito.

Assim, seria de lógica que o pedido reconvenicional também fosse, em regra certo e determinado, podendo excepcionalmente – nos mesmos casos em que o pedido principal pudesse sê-lo – ser indeterminado.

## **7. Liquidação zero**

Nos casos de pedido indeterminado, já que não se tem condições de, no momento do ajuizamento da ação, especificar com precisão aquilo que será demandado, o processo acaba se desdobrando em dois momentos distintos. Um primeiro, para a apuração do direito “em abstrato” do autor à providência solicitada. E um segundo, para a concreta definição dos parâmetros que importarão na satisfação de sua pretensão.

Essa especificação poderá ocorrer no curso do próprio processo de conhecimento (o que é desejável) ou ficar postergado a uma fase subsequente, a de liquidação.

Quando a concretização do quantum debeatur é deixada à fase de liquidação, pode surgir situações em que se apure que “nada é devido”. Ao contrário da suposição inicial, de que haveria quantum a ser apurado ulteriormente, chega-se à conclusão de que não havia nada a ser outorgado ao autor. Chama-se a esse fenômeno de “liquidação zero”<sup>156</sup> e sua análise pode repercutir sensivelmente sobre a natureza da sentença que examina pedido indeterminado e sobre as suas consequências.

Haverá casos, é certo, em que esse resultado igual a zero decorrerá da insuficiência de dados capazes de indicar o valor da condenação. Nessas hipóteses, o julgamento não fixa quantum igual a zero, mas pronuncia espécie de conclusão de *non liquet*. Na verdade, diante da insuficiência de dados para afirmar um valor exato para a execução, a decisão rejeita a liquidação.

Porém, outros casos poderão ocorrer em que, ao se proceder à liquidação, encontre-se verdadeiramente resultado igual a zero porque nada há a ser pago. É o que sucederia, por exemplo, se na liquidação, fosse apurado que não houve qualquer dano, de modo que nada há a ser ressarcido.<sup>157</sup>

Grande parte da doutrina considera que esta situação não importa alteração na sentença condenatória – em razão do princípio da fidelidade ao título –, de forma que a eventual apuração de resultado igual a zero ainda significaria a “existência de condenação”.<sup>158</sup> Segundo pensa a

ampla maioria da doutrina, em tal caso o juiz deveria rejeitar a liquidação, sem, todavia, alterar a sentença condenatória. Não haveria violação à coisa julgada, pois apenas se chegaria à conclusão de que o quantum devido é igual a zero.

Porém, para outros, é contraditório imaginar que o juiz possa condenar alguém a nada. Calamandrei, em clássico estudo sobre o assunto, afirma ser um absurdo lógico – decorrente da cisão entre os juízos sobre o an debeatur e sobre o quantum debeatur – a conclusão de que alguém tem obrigação de reparar dano de valor igual a zero.<sup>159</sup>

Efetivamente, do ponto de vista lógico, não se sustenta a conclusão de que possa haver condenação a valor igual a zero. E, sob o ponto de vista jurídico, o óbice da coisa julgada impediria a rediscussão da condenação havida, o que levaria à prevalência do princípio da fidelidade ao título. Contudo, parece razoável a posição adotada por Calamandrei. Segundo ele, a sentença condenatória reconheceria a “responsabilidade” por danos causados diante do ilícito descrito, mas possuiria, nos casos de pedido genérico, apenas “cognição sumária” em relação aos danos. Portanto, não haveria declaração (accertamento) sobre os danos eventualmente existentes. Assim, a coisa julgada incidiria sobre uma “hipótese” – se houver danos, estes deverão ser indenizados – que, se não confirmada posteriormente, em juízo de cognição exauriente, implicaria o reconhecimento de que nada havia a ser indenizado e, portanto, de que não teria ocorrido condenação alguma. Não haveria ofensa à coisa julgada, pois na sentença “condenatória” nada teria sido declarado (com base em cognição exauriente) a respeito dos danos. A sentença teria conteúdo declaratório, estabelecendo o seu preceito específico apenas que, caso subsistissem danos de certo evento, estes deveriam ser reparados. Haveria, a rigor, falsa condenação.<sup>160</sup>

A sentença, que afirma que o demandado deverá indenizar se o dano mais tarde for declarado, exige, para ser executada, posterior declaração do dano e do seu valor. A sentença que, para ser executada, necessita da declaração do dano, não concede a tutela ressarcitória. Por outro lado, uma vez que a sentença é dependente de ulterior declaração de pressuposto imprescindível para a configuração do direito à tutela ressarcitória, ela é “quase-condenatória”. Ou seja, não há tutela ressarcitória, mas sim declaração de um dos seus pressupostos; e também não há condenação, pois essa exige a configuração de todos os requisitos para a execução, exceto a definição do quantum debeatur.

Uma sentença assim deixa para momento posterior algo (o dano) que diz respeito ao mérito ou ao litígio. Nesse sentido, a sentença trata de parte do mérito, deixando a questão do dano para fase subsequente, isto é, para a liquidação. Exatamente por isto não presta a tutela ressarcitória, que, como é óbvio, depende da configuração do dano. Porém, “se não há dúvida de que a sentença trata de parcela do mérito, não há porque pensar em obrigatoriamente classificar a sentença como condenatória ou declaratória”.

Assim como a sentença deixa de afirmar todos os pressupostos da tutela ressarcitória, ela não se torna imediatamente condenatória, ou seja, hábil para ser imediatamente executada ou para permitir a liquidação “do valor” do dano. A sentença que requer a declaração da existência do dano ainda não contém os requisitos próprios à condenação. Porém, “se a sentença é vocacionada à tutela ressarcitória, e, assim, à execução, ela é “quase-condenatória”, e não declaratória”.

Nem se pense que, pelo fato de a sentença não ser condenatória, deve ela ser classificada como declaratória. Ora, sabe-se que toda sentença contém declaração. Assim, “não é porque uma sentença não contém todos os requisitos da condenação que vai se tornar declaratória”. A “sentença” declaratória, como já dito, presta a “tutela” declaratória, que elimina uma situação de incerteza que paira sobre uma situação jurídica. Porém, a sentença que afirma o dever de indenizar para a eventualidade do reconhecimento do dano não presta “tutela” declaratória, mas sim declara um dos pressupostos da “tutela”ressarcitória almejada pelo autor, que, por isto mesmo, é carecedora da declaração da existência do dano, a ser pronunciada na fase de liquidação.

Como está claro,

sentença de parcela do mérito e sentença quase-condenatória são aspectos de um mesmo problema: a existência de duas decisões, uma tratando da responsabilidade por eventual dano e outra, que lhe é complementar, verificando a existência do dano.

Portanto, não há como pensar que a declaração de não existência de dano possa ofender a lógica, por admitir uma condenação a nada. Como visto, ao invés de condenação, há uma quase condenação que depende da definição do dano. Também não há qualquer problema em relação à coisa julgada, pois a primeira sentença não declara a existência do dano, mas apenas a probabilidade deste existir e poder ser declarado posteriormente. Na primeira sentença, o juízo sobre o dano é de cognição sumária, similarmente ao que ocorre na sentença cautelar ou na tutela antecipatória, de modo que o juízo da liquidação, ao afirmar, com base em cognição exauriente, a inexistência do dano, evidentemente não viola a coisa julgada. Na verdade, a partir do instante em se compreende a questão a partir da ótica da tutela dos direitos e da técnica da cognição, torna-se, até mesmo enfadonho, discutir sobre eventual violação da coisa julgada material.

Enfim, essa sentença é de procedência e sua natureza não é alterada pela circunstância de, na fase de liquidação, apurar-se quantum igual a zero. A liquidação igual a zero não “desconstitui” ou “rescinde” a sentença de conhecimento. Apenas a complementa, para negar os danos que se supunha existentes. Não há, por isso, que se cogitar de inversão de sucumbência ou de uma forma particular de ação rescisória aí.

**Art. 325.** O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.

Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo.

## 1. Pedido alternativo

O direito material disciplina, em seus arts. 252 a 256, do CC, a chamada obrigação alternativa. Essa espécie de obrigação é caracterizada pela escolha por um dos contratantes do objeto sobre o qual recai a obrigação. Por outras palavras, é “aquela em que duas ou mais prestações são devidas de tal maneira que uma ou outra somente deve ser efetuada”.<sup>161</sup>

Como o processo deve dar conta dos institutos concebidos pelo direito material, é necessário que o direito processual crie técnicas capazes de veicular esse tipo de obrigação também. Por isso, dentro do Código de Processo Civil, como resposta às obrigações alternativas, concebeu-se a figura do “pedido alternativo”, de que trata o dispositivo em exame. Desse modo, os pedidos podem ser divididos em fixos ou alternativos. O pedido é fixo quando o direito material permite apenas um modo de realização da prestação, ao passo que pode ser alternativo “quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo” (art. 325 do CPC).

A rigor, o pedido alternativo se presta a, pelo menos, duas formas de obrigações. Em primeiro lugar, como é evidente, às “obrigações alternativas”, ou seja, àquelas que possuem objeto múltiplo e que, assim podem ser cumpridas de mais de uma forma. Em segundo lugar, porém, esse tipo de pedido alternativo também se aplica às “obrigações facultativas”, isto é, às obrigações com faculdade de substituição da prestação.<sup>162</sup>

Calmon de Passos salienta que, para que uma obrigação seja tida como alternativa, é necessário que haja “prestações distintas”. Não basta que a forma do cumprimento seja diverso, se o objeto é único, ou ainda se a incerteza quanto ao objeto não pode ser eliminada pela vontade do credor ou do devedor, dependendo de circunstâncias alheias à vontade das partes.<sup>163</sup>

Não há dúvida do acerto da lição do autor. Porém, é necessário convir que, para o pedido alternativo, essas distinções podem mostrar-se irrelevantes. Para o pedido alternativo, importa somente se, nos termos da obrigação assumida, há ou não o condicionamento da satisfação à manifestação da vontade das partes, seja em relação ao objeto, seja quanto à forma do cumprimento.

Em se tratando de pedido alternativo ligado à obrigação alternativa, é importante atentar ao tratamento legislativo da figura. Assim, por exemplo, a obrigação, ainda que alternativa, constitui uma unidade. Por isso, não pode o devedor esperar que o credor receba parte de uma prestação e parte de outra (art. 252, § 1.º, do CC).<sup>164</sup>

O “pedido alternativo” não deve ser confundido com a “cumulação alternativa de pedidos” (art. 326). Na cumulação existe *mais de um pedido*; ademais, existe uma ordem de preferência expressa pelo autor: o autor quer a procedência do pedido principal, mas também lhe serve a procedência do pedido alternativo. Essa multiplicidade de pedidos e essa ordem de preferências não existem no pedido alternativo – qualquer um dos objetos do pedido serve à satisfação do demandante, até porque há, no plano material, direito do requerido de optar pela forma de satisfação da obrigação.<sup>165</sup> A consequência prática dessa observação está em que inexistente interesse recursal do autor em pedir especificamente a procedência de um dos pedidos alternativos: se o juiz acolheu um dos pedidos alternativos, não há interesse em apelar para ver acolhido o outro. Todavia, se o juiz, podendo acolher o pedido principal formulado em regime de cumulação alternativa, acolhe o pedido formulado alternativamente, há interesse recursal do autor para ver acolhido o pedido de sua preferência.

Por fim, vale sempre a advertência de que, ao tratar do pedido alternativo, o legislador está aludindo apenas ao pedido “mediato”. Isso porque, quanto ao pedido imediato, vige a regra de que “toda e qualquer técnica processual pode ser empregada, acaso idônea e necessária, para a tutela dos direitos”.<sup>166</sup> O direito brasileiro consagrou em toda a sua extensão a regra da “atipicidade dos meios executivos” (arts. 139, IV, 536, 537 e 538), com o que tornou a atividade executiva mais “maleável” e “adaptável” às necessidades do caso concreto.<sup>167</sup>

## 2. Processamento do pedido alternativo

Se há, adjacente ao processo, obrigação que pode ser cumprida de mais de uma forma, o processo deve respeitar essa manifestação da vontade das partes (ou essa imposição de lei). Por isso, não pode a exigência do Código – no sentido de que o pedido seja certo e determinado – sobrepor-se às características da figura do direito material. Se há alternatividade prevista para a obrigação, ela deve ser internalizada no processo.

Logicamente, essa escolha pode ser atribuída ao credor ou ao devedor. Embora, em regra, a opção caiba ao devedor (art. 252, do CC), nada impede que as partes tenham estipulado em outro sentido.

Se é do autor o direito de escolha da prestação, então propriamente não haverá, em regra, pedido alternativo. O autor, ao elaborar a petição inicial, manifestará sua vontade e escolherá a prestação que prefere. O pedido, aí, será certo e determinado.<sup>168</sup>

Eventualmente, porém, poderá o autor – a quem se facultou a escolha – abrir mão desse direito, formulando pedido alternativo. Já que se trata de simples acordo de vontades, essa alternatividade não é impositiva para o beneficiário, que pode renunciar a essa vantagem. Nesse caso, como é lógico, não há nenhuma irregularidade na petição inicial, nem pode ela ser considerada como inepta. Formulando, nesse caso, pedido alternativo, é de se presumir que renunciou ao benefício da escolha, em favor do réu, de modo que tocará a este a determinação da prestação a ser devida.<sup>169</sup>

No entanto, se, de acordo com o negócio celebrado, a escolha competir ao réu, é certo que o autor não pode desconsiderar essa faculdade, formulando pedido determinado. Nesses casos, tem efetiva incidência o art. 325, impondo-se ao autor que apresente pedido alternativo.

Aliás, conforme dispõe o parágrafo único do art. 325, do CPC, que

quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo.

Ou seja, se, em virtude da natureza da obrigação, o devedor pode cumprir sua prestação de dois

modos, pouco importa que o autor, que pretende ver cumprida a prestação, não tenha formulado pedido alternativo, conferindo ao réu a oportunidade de escolher o modo mais conveniente para cumprir a obrigação. Nesse caso, não tendo sido formulado pedido alternativo, deve o juiz assegurar ao réu a possibilidade de cumprir a prestação de um ou de outro modo.

Ou seja, o Código aqui se afasta do princípio da demanda, permitindo que o juiz interfira sobre o pedido formulado pelo autor. Assim, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo – quando a escolha competia ao réu – é “dever” do juiz assegurar a alternatividade da prestação em sua decisão. Essa solução, ao que parece, aplica-se tanto aos casos em que o réu tenha expressamente manifestado seu interesse em realizar a escolha – nos termos do que lhe foi autorizado pela obrigação – como ainda na hipótese de revelia. A revelia, como lembra Calmon de Passos, implica apenas a incontrovérsia sobre os fatos, mas não muda a natureza da obrigação. Por isso, nesse caso, deve o juiz deferir ao réu o direito de escolha na sentença, ainda que formulado pedido determinado.

Claro está que, por simetria ao que se disse em relação ao autor, se o réu não formula a escolha no prazo que lhe é outorgado pelo juiz ou naquele estipulado no negócio jurídico, supõe-se a renúncia a essa prerrogativa. Em consequência, dá-se à parte contrária o poder de elaborar a escolha, não podendo o réu, posteriormente, impugnar a escolha feita nessas circunstâncias.

Eventualmente, ainda, a escolha poderá ser outorgada a uma pluralidade de sujeitos. Nesses casos, conforme estabelece o art. 252, § 3.º, do CC, “não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação”. Ou seja, em casos como este, caso os optantes ocupem o polo ativo do processo, havendo concordância, deverão formular pedido determinado. Não havendo unanimidade nessa escolha, deverá o juiz dar prazo para que eles deliberem e, se não chegarem a um acordo unânime, caberá ao juiz realizar a escolha. Se um só desses optantes ajuizar a demanda, os outros deverão ser convocados para que deliberem, em conjunto, sobre a escolha a ser realizada, aplicando-se no mais o que acima se disse.

Se o conjunto de optantes ocupar o polo passivo, então o pedido inicial deve ser alternativo – devendo o juiz, ainda que o pedido tenha sido certo, assegurar a opção aos réus. Estes, então, quando instados a cumprir a obrigação, terão prazo para em conjunto fazer a escolha. Não o fazendo, caberá ao juiz proceder a escolha sobre a prestação devida. Se apenas alguns deles forem convocados para o processo, deverá o juiz, no momento da realização da opção, intimar a todos para que, de forma unânime, deliberem sobre a prestação devida. Não havendo acordo, o juiz decidirá.

Enfim, poderá acontecer de o título prever que a escolha caiba a terceiro – nem credor, nem devedor. Esse terceiro, por óbvio, não participará da relação processual, já que não está em nenhum dos polos da relação processual. No entanto, quando for devida a escolha, deverá ser intimado para proceder a escolha, no prazo fixado em lei, no negócio ou naquele estabelecido pelo juiz. Não havendo pronunciamento oportuno desse terceiro, incidirá o contido no art. 252, § 4.º, do CC, de modo que a escolha passará inicialmente às partes envolvidas na obrigação ou, se não houver acordo entre eles, ao juiz.

Recorde-se, por derradeiro, que pode suceder a impossibilidade do cumprimento de uma, ou das várias prestações alternativas. A obrigação, nesses casos, acaba por perder sua característica de alternatividade, transformando-se, se possível, em simples. Se isso ocorrer sem culpa das partes, ou será extinta a obrigação – se todas as prestações se tornarem inexecutíveis (art. 256, do CC), ou a obrigação subsistirá apenas em relação às prestações possíveis (art. 253, do CC). Caso todas as prestações se mostrem impossíveis por culpa do devedor, será necessário saber se a escolha competia ao credor ou não. No primeiro caso, poderá o credor reclamar o valor da prestação que entender conveniente, mais perdas e danos (art. 255, segunda parte, do CC). Se não lhe competia a escolha, ficará o devedor “obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar” (art. 254, do CC). Se só algumas das prestações se tornarem impossíveis por culpa do devedor, então “o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos” (art. 255, primeira parte, do CC).

### 3. Processamento e pedido facultativo

A hipótese de obrigação facultativa pode também acoplar-se a pedido alternativo. Nesse caso, porém, há algumas variações decorrentes da própria natureza da obrigação envolvida.

Salienta Orlando Gomes três características básicas da obrigação facultativa:

1.<sup>a</sup>, o credor não pode reclamar a prestação facultativa; 2.<sup>a</sup>, a impossibilidade de satisfazer a prestação devida extingue a obrigação; a subsistência da prestação facultativa é irrelevante; 3.<sup>a</sup>, só o defeito da prestação devida pode acarretar a invalidade da obrigação.<sup>170</sup>

Evidentemente, essas características refletem-se no procedimento judicial diante do pedido alternativo. Não haverá jamais a possibilidade de o autor-credor realizar a opção, ainda que tenha o devedor se omitido em realizar a prestação. Omissa a escolha do réu-devedor em realizar a escolha, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos, com a extinção da obrigação original. O mesmo ocorrerá caso se torne impossível a prestação “principal”.

**Art. 326.** É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

#### 1. Cumulação imprópria

O art. 326, do CPC, regula a chamada cumulação imprópria, também chamada de cumulação alternativa. Como já se disse nos comentários ao artigo anterior, a cumulação alternativa não guarda qualquer semelhança com o pedido alternativo.

Na cumulação alternativa há, efetivamente, a formulação de “mais de um pedido”. Esses pedidos vários podem ter natureza diversa e visar a fins diferentes. Porém, ao contrário da cumulação tradicional (simples), em que não há vinculação entre os pedidos, aqui o acolhimento de um influencia na análise do outro. Por isso, essa espécie de cumulação pode ser chamada de “imprópria”, na medida em que não se deseja propriamente que o juiz examine todos os pedidos formulados.<sup>171</sup> Acolhido um deles, normalmente aquele que se aponta como o mais desejado, resta prejudicada a análise do(s) outro(s).

Como se vê, há dois tipos distintos de cumulação imprópria ou alternativa.

Ela pode ser apresentada “com ordem prioritária” (chamada por parte da doutrina de cumulação eventual ou subsidiária), acontecendo quando o autor estabelece ordem preferencial entre a satisfação dos pedidos formulados. Há um pedido principal e outro (ou outros) subsidiários. Acolhido o pedido principal, tornam-se irrelevantes os pedidos subsidiários, cuja análise restará prejudicada. Se, porém, for rejeitado o pedido principal, então serão examinados os pedidos subsidiários, que poderão vir a ser acolhidos ou não.

O Código de 2015 criou, ainda, a cumulação eventual “sem ordem prioritária” (chamada por parte da doutrina atual de cumulação alternativa). Nesse caso, o autor não formula ordem de prioridade entre os pedidos formulados. O tema é disciplinado pelo art. 326, parágrafo único, que afirma que “é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles”. Nesse caso, qualquer pedido que for acolhido satisfaz o demandante. No fundo, o parágrafo único do art. 326 constitui uma espécie de atipicização da regra do pedido alternativo (art. 325), permitindo ao juiz a escolha – dentre as várias alternativas possíveis – da resposta que pareça mais adequada.

Duas razões podem levar à cumulação imprópria de pedidos.

Em primeiro lugar, certa particularidade do direito material, que atribua consequências várias a um mesmo fato ou ato jurídico. É o que sucede, por exemplo, na ação quanti minoris. Havendo vício redibitório na coisa recebida em razão de contrato comutativo, pode o adquirente optar em



rejeitá-la ou pretender o abatimento do preço (arts. 441 e 442, do CC). A escolha da solução cabe ao adquirente, mas pode ele formular pedido subsidiário correspondente à outra possibilidade, para a eventualidade de não ser viável o atendimento à sua “pretensão principal”.

Nesse caso, o pedido subsidiário atende a critério de economia processual, evitando que seja necessário eventual nova ação futura, diante da impossibilidade de atendimento do pedido “principal”.

Porém, o pedido subsidiário também pode estar atrelado a certa dúvida na tipificação do suposto, ou da consequência jurídica a ser atribuída a um ato ou fato.<sup>172</sup> Assim, por hipótese, não tendo o autor certeza quanto à caracterização do ato ou do fato que constitui a causa de pedir da demanda, apresentará cumulação impropria de pedidos, almejando sucesso em uma das possíveis pretensões.

Retornando ao exemplo dos vícios redibitórios, pode-se imaginar [para a aplicação do art. 443, do CC<sup>173</sup>] que o autor tenha dúvida sobre se o alienante tinha ou não conhecimento do defeito da coisa. Se o alienante tinha esse conhecimento, é direito do adquirente, ao resolver o contrato, exigir a restituição do que foi pago e ainda obter indenização por perdas e danos. Do contrário, possui o adquirente apenas o direito de receber de volta o que pagou, juntamente com as despesas do contrato. Diante dessa dúvida, que só pode ser resolvida pelo juiz na avaliação do caso, pode o autor formular cumulação eventual, postulando, além da restituição do valor pago, as perdas e danos ou, subsidiariamente, apenas as despesas do contrato.

Em todos os casos, como se vê, pressupõe a lei certa incompatibilidade entre os pedidos (art. 327, § 3.º, do CPC). Essa incompatibilidade, porém, não significa dizer que se autorize a formulação de pedidos aleatórios. A incompatibilidade de que fala a lei só se refere à existência de certa prejudicialidade entre os pedidos, de sorte que, atendido o principal [ou o anterior], o sucessivo não deve mais ser examinado. Porém, é evidente que as circunstâncias do caso e do direito material incidente demonstram a existência de certo nexo entre os pedidos.

Ressalvado esse requisito do art. 327, a observância dos demais (competência do juízo e adequação do procedimento) é obrigatória. Assim, é necessário que o juiz seja absolutamente competente para todos os pedidos formulados e também é obrigatório que o mesmo procedimento seja adequado para todos os pedidos – ou, ao menos, que todos possam ser veiculados pelo procedimento comum.

## **2. Regime da cumulação eventual ou subsidiária**

A cumulação eventual, como se disse, pressupõe escalonamento entre os pedidos, de modo que há ordem de preferência entre eles. O autor pretende alguma coisa, mas se não for possível a outorga dessa proteção, satisfaz-se com algo outro.

Essa relação de preferência repercute de forma importante na avaliação de eventual interesse recursal, diante do acolhimento do pedido subsidiário. Julgando procedente o pedido principal, logicamente, não deve o juiz conhecer do pedido subsidiário. Caso o faça, procede extra petita, merecendo essa análise ser desconsiderada ou eventualmente corrigida em grau de recurso.

Todavia, não podendo acolher o pedido principal, tem o juiz o dever de examinar o pedido subsidiário, acolhendo-o ou rejeitando-o. Se o juízo julga improcedente o pedido principal, mas acolhe o pedido subsidiário, tem o autor interesse recursal na reforma da decisão para provocar, na instância revisora, o acolhimento do pedido principal, porque esse prefere ao pedido subsidiário. Pela mesma razão, tem também interesse recursal o autor no caso em que o juiz só “examine” o pedido subsidiário, sem “apreciar” [ainda que fosse para rejeitar] o pedido principal. Se o pedido principal era preferencial para a parte, a omissão do juiz importa prejuízo para a parte, que tem interesse recursal em sanar esse defeito.

De outra parte, se o pedido principal é rejeitado, mas o subsidiário não é examinado, há clara situação de sentença citra petita. A omissão judicial em apreciar o pedido subsidiário, nesse caso,

viola o art. 326, do CPC, e autoriza também recurso.

Parece útil recordar, por fim, que, quando se fala que a análise do pedido subsidiário depende da impossibilidade de acolher o anterior, o termo “acolhimento” é empregado de forma genérica. Ou seja, o pedido subsidiário (ou seguinte) será examinado em duas circunstâncias: a) quando o pedido principal tiver sido rejeitado no mérito, ou b) o pedido principal não foi conhecido, por problema processual a exemplo da falta de condição da ação ou de pressuposto processual. O fundamental, portanto, é que não tenha havido efetivo acolhimento da pretensão deduzida como principal.

Por outro lado, o acolhimento de que trata a lei pode ser parcial ou integral. Vale dizer: ainda que o juiz tenha acolhido apenas em parte o pedido principal, restará prejudicada a análise do pedido subsidiário.

Perante o tribunal, porém, o recurso da sentença devolver-lhe-á a análise de todos os pedidos, ainda que com a mesma ordem de prioridade estabelecida inicialmente pelo autor. Isso significa dizer que, acolhido o pedido principal em 1.º grau, a apelação do réu impõe ao tribunal que examine a viabilidade daquele pedido e, em não sendo viável, que também aprecie os subsidiários. A hipótese amolda-se ao contido no art. 1.013, § 3.º, III, do CPC [por analogia], de modo que o efeito devolutivo em profundidade da apelação imporá ao tribunal a análise dos pedidos não apreciados na instância a quo.

### **3. Regime da cumulação alternativa**

Na cumulação alternativa (aquela regulada pelo art. 326, parágrafo único, do CPC), o autor não formula ordem de preferência entre os vários pedidos concatenados. O autor limita-se a formular vários pedidos, esperando que “o juiz acolha um deles”.

Por não haver ordem de preferência estabelecida, presume-se que o autor se satisfaz com o acolhimento de qualquer dos pedidos. Por isso, o acolhimento de um deles implica a plena satisfação do autor, de modo que ele não tem interesse recursal para buscar a satisfação de outro perante o tribunal. Identicamente, acolhido um dos pedidos, a omissão quanto aos demais é aqui absolutamente irrelevante, não se podendo cogitar de defeito na sentença ou de omissão que justifique embargos de declaração.

Assim, só a rejeição ou o não conhecimento de todos os pedidos formulados é que ensejará interesse recursal para a parte autora.

De outro lado, o acolhimento de um dos pedidos impede a análise dos demais (a fortiori seu acolhimento). Procedente, ainda que em parte, um dos pedidos formulados, exaure-se o objetivo da demanda, de modo que os outros se tornam irrelevantes.

Logicamente, todos os pedidos cumulados, nesse caso, poderão ser reexaminados, diante de eventual recurso da parte prejudicada. O tribunal, portanto, não concordando com o pedido acolhido em primeiro grau, deverá examinar os outros, a fim de avaliar se algum destes pode ser outorgado à parte autora.

**Art. 327.** É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1.º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

- I – os pedidos sejam compatíveis entre si;
- II – seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
- III – seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2.º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos

cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

§ 3.º O inciso I do § 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326.

## 1. Cumulação de pedidos

Por razões de economia processual, a lei brasileira sempre autorizou a cumulação de pedidos em um único processo.

Pode-se cogitar basicamente de três grandes grupos de cumulação, atendendo à variação dos elementos da ação proposta.

Assim, é possível ter a cumulação subjetiva, decorrente da presença de vários sujeitos no processo. Se há vários sujeitos em um dos polos do processo, logicamente há também vários pedidos formulados (um para cada um desses sujeitos). A cumulação subjetiva, portanto, implica também a cumulação objetiva.

Embora em regra isso dê origem à figura do litisconsórcio (art. 113 e ss., do CPC), é possível que ocorra cumulação subjetiva sem que aí se veja propriamente um “litisconsórcio”. Isso porque o litisconsórcio normalmente pressupõe certa afinidade entre os sujeitos consorciados, mas há casos em que inexistente esse liame entre eles. É o que pode ocorrer, por exemplo, na cumulação subjetiva derivada da denunciação da lide ou mesmo do chamamento ao processo.

É possível ainda pensar na cumulação de ações por acúmulo de causas de pedir. Chamada, por parte da doutrina nacional de “concurso de ações”,<sup>174</sup> essa situação decorre da coexistência de múltiplas causas de pedir que apontam para o mesmo pedido. Imagine-se uma ação rescisória fundada em duas distintas causas de pedir [violação à norma jurídica e ofensa à coisa julgada, por exemplo], ou uma ação de despejo baseada em não pagamento do aluguel e em infração contratual.

Por fim, pode-se pensar na cumulação em razão da formulação de vários pedidos dentro de um só processo.

Destas *duas últimas modalidades de cumulação* trata o art. 327, do CPC. Enquanto a cumulação subjetiva é tratada amplamente pelas figuras do litisconsórcio e das intervenções de terceiros, a cumulação de ações por agregação de pedidos e a cumulação de ações por agregação de causas de pedir são tratadas pelo dispositivo em exame.<sup>175</sup>

Em particular, no que se refere à cumulação de ações por pedidos distintos, é possível ver que ela pode assumir algumas formas distintas. Para fins didáticos, a doutrina tem separado essas formas em basicamente quatro grupos: a) aparente; b) simples; c) alternativa (eventual); e d) sucessiva.

Da cumulação eventual já se tratou nos comentários ao art. 326, sendo desnecessário reexaminar a matéria. Viu-se que, a rigor, não se trata aí de cumulação de pedidos, na medida em que o autor apenas deseja uma das providências enumeradas por ele. Todavia, como há, de todo modo, a elaboração de vários pedidos no processo, a figura é tratada juntamente com as outras hipóteses de cumulação, submetendo-se ademais aos requisitos exigidos pelo art. 327, do CPC.

Quanto à cumulação aparente, ela só ingressa nesta classificação para demonstrar que há situações de “falsa cumulação”, em que, ao lado do pedido de mérito formulado, o autor apresenta outros “requerimentos”, de cunho processual. Aí se inserem os requerimentos de condenação do vencido nos ônus sucumbenciais, de elaboração de provas, de intervenção de terceiros etc. Embora esses pleitos sejam (ou possam ser) apresentados com a petição inicial, é certo que eles não tratam do mérito da controvérsia. Há solicitação de resposta jurisdicional, mas que não diz propriamente com o conteúdo do litígio posto à análise judicial.

A cumulação, aqui, é apenas aparente, já que há apenas um pedido formulado em relação ao mérito da controvérsia. Os outros pleitos envolvem exclusivamente matéria processual. Por isso,

prefere a doutrina o vocábulo “requerimento” para expressar esse pleito, de forma a não os confundir com os pedidos efetivamente formulados.

Logicamente, em se tratando de requerimentos processuais, muitos deles podem (e devem) ser examinados de ofício, independentemente de qualquer provocação da parte. Assim ocorre, por exemplo, com a condenação do vencido nos ônus da sucumbência, aí incluídos os honorários sucumbenciais (arts. 82, § 2.º, e 85, do CPC). O dever de ressarcir esses valores constitui verdadeiro efeito anexo da sentença, semelhantes à hipoteca judiciária (art. 495, do CPC), de sorte que, ainda que omissa a sentença, a imposição subsiste, porque decorre de lei. Se é a lei que atribui, automaticamente, essa consequência à sentença de procedência, é certo que a omissão da sentença é absolutamente irrelevante e não pode afastar a incidência da regra específica. Assim como é indiscutível que a hipoteca judiciária incide ainda que a sentença nada disponha a seu respeito, também é certo que a condenação nos ônus de sucumbência não depende de manifestação expressa na decisão judicial.

De toda forma, a ideia da cumulação aparente só tem finalidade didática neste contexto. Pretende-se apenas demonstrar que a cumulação só existe de fato se há a formulação de vários pedidos “em relação à controvérsia objeto do processo”. Não se cogita de cumulação se há pedido ao qual se agrega requerimentos processuais.

## **2. Cumulação simples**

A cumulação simples é a mais comum na praxe processual. Caracteriza-se essa forma de cumulação de pedidos pela autonomia existente entre os pedidos cumulados – a apreciação de um é totalmente independente em relação à apreciação do outro. Em outras palavras, permite-se ao autor, via cumulação simples, formular dois ou mais pedidos contra o réu que poderiam ser objeto de ações distintas.

Na cumulação simples, o juiz tem o dever de examinar todos os pedidos formulados, sendo por essa razão hipoteticamente possível a procedência simultânea de todos os pedidos cumulados. Por essa razão, na cumulação simples, o valor da causa corresponde à soma de todos os pedidos cumulados (art. 292, VI, do CPC).

Tratando-se de pedidos rigorosamente autônomos (que poderiam constituir objeto de processos separados), a reunião desses pleitos em um só processo responde a um imperativo de economia processual. Busca-se evitar a replicação de atos, concentrando-os em um único processo. Por isso, parece correto entender que essa cumulação exige ponderação a respeito de sua oportunidade ou não, como se verá adiante.

Tratando-se de situação que implica conveniência para o próprio processo, a lei sequer exige que exista conexão entre os pedidos cumulados (art. 327, caput, do CPC). Não é necessário que haja relação entre os pedidos, nem que tratem de assuntos assemelhados. Basta a satisfação dos requisitos impostos pelo art. 327, do Código, para que a cumulação seja possível.

Porque os pedidos são autônomos, sucumbindo o autor quanto a qualquer um dos pedidos cumulados, tem interesse recursal.

## **3. Cumulação sucessiva**

Há cumulação sucessiva de pedidos quando o autor formula dois pedidos pretendendo o acolhimento de ambos, sendo o “acolhimento” do primeiro pedido pressuposto lógico e essencial para a análise do pedido sucessivo. Trata-se de figura oposta à cumulação alternativa (eventual). Enquanto na cumulação eventual, o pedido subsidiário só é analisado na eventualidade de improcedência do pedido principal, na cumulação sucessiva o pedido sucessivo só é analisado na eventualidade de julgar-se procedente o primeiro pedido formulado. O juiz só analisa o pedido sucessivo se acolher o primeiro pedido.

Isso significa dizer que o primeiro dos pedidos formulados é, além de objeto do processo, etapa lógica necessária para a avaliação do segundo [e assim sucessivamente]. Por isso, a caracterização

da cumulação sucessiva exige mais do que simplesmente uma concatenação de pedidos. É indispensável que um seja prejudicial em relação ao outro, de modo que seu desacolhimento (ou não conhecimento) implica a inviabilidade de analisar o subsequente. Como pondera Calmon de Passos, há entre os pedidos envolvidos uma relação de

prejudicialidade sem acessoriedade, pois ambos os pedidos guardam sua própria autonomia, embora o acolhimento de um deles seja premissa necessária para o acolhimento do outro.<sup>176</sup>

Acolhendo o primeiro pedido e julgando improcedente o segundo, a parte deve ser considerada parcialmente sucumbente (art. 86) e há, evidentemente, interesse em recorrer. Em sendo o caso, todavia, de cumulação sucessiva, a fixação do valor da causa obedece à soma de todos os pedidos cumulados (art. 292, VI).

O Código não disciplina especificamente essa modalidade de cumulação. Ela é antes uma decorrência da situação concreta e de eventual regime de prejudicialidade entre um pedido e outro.

#### **4. Requisitos da cumulação de pedidos**

O art. 327, do CPC,<sup>177</sup> disciplina os requisitos para a cumulação de pedidos “em face de um mesmo réu”.<sup>178</sup> Isso significa dizer que a primeira imposição para a incidência dos requisitos aqui expressos é que todos os pedidos sejam deduzidos em face do mesmo réu.

A cumulação de pedidos em face de réus distintos (cumulação subjetiva) sujeita-se aos requisitos arrolados no código para a figura do litisconsórcio ou, eventualmente, para as intervenções de terceiros.

Em consequência, havendo interesse em formular vários pedidos, sem conexão, em face de vários réus, é necessário satisfazer, concomitantemente, os requisitos do art. 327 e aqueles exigidos para o litisconsórcio ou para as intervenções de terceiros.

Para que seja possível, porém, cumular-se vários pedidos contra um só réu, basta satisfazer os requisitos estipulados no preceito em exame.

A cumulação aparente, como é intuitivo, não precisa observar os requisitos aqui discutidos, já que propriamente não se trata de cumulação. Os requisitos para a cumulação eventual, por outro lado, já foram examinados nos comentários ao art. 326, do CPC, de modo que aqui interessarão apenas os requisitos para a cumulação simples e para a sucessiva.

##### **a) dispensa de conexão objetiva**

De acordo com o caput do art. 327, a cumulação de pedidos dispensa a conexão entre eles. A conexão mencionada, evidentemente, é apenas a conexão objetiva (pelo pedido ou pela causa de pedir), já que, pelo menos em relação ao sujeito, todos os pedidos devem provir de um único sujeito e dirigir-se a outro.

##### **b) conexão subjetiva**

Para a cumulação de que trata o artigo em exame, conforme se observou logo acima, impõe-se que os pedidos sejam deduzidos em face do mesmo polo passivo.

Mais do que a identidade “física” do sujeito, é necessário que haja também identidade “jurídica”, considerada a condição em que a parte se apresenta no processo. Para os fins do artigo em exame, não é possível a cumulação se, para um pedido a parte se apresenta como legitimado ordinário, e para o outro está na condição de substituto processual ou, a fortiori, de representante. É imprescindível que, para todos os pedidos, as partes estejam exatamente na mesma condição jurídica.<sup>179</sup>

Por outro lado, em analogia ao que prevê os arts. 343, §§ 3.º e 4.º, do CPC, deve-se admitir a

cumulação de pedido ainda quando haja identidade apenas “parcial” entre os polos do processo. Isto é, deve ser admitida a cumulação de pedidos formulados contra todos os réus com pedidos formulados em face de apenas alguns deles. Do mesmo modo, deve-se tolerar a cumulação de pedidos formulados por todos os autores em face do réu comum, com outros formulados apenas por alguns dos autores contra esse mesmo réu.<sup>180</sup>

#### c) compatibilidade dos pedidos

Como o demandante pretende, com a cumulação simples, a procedência simultânea dos pedidos cumulados, é imprescindível que os pedidos sejam compatíveis entre si. Pedidos compatíveis são aqueles que não se excluem mutuamente.

A compatibilidade exigida pelo Código não é necessariamente uma compatibilidade lógica. Antes, é uma compatibilidade jurídica. Vale dizer, para que exista esse requisito, é necessário que juridicamente os pedidos possam ser somados e que a avaliação de um não tenha influência necessária sobre a dos demais. Por outras palavras, “o que o sistema não admite é que os pedidos cumulados inviabilizem-se ou excluam-se uns aos outros”.<sup>181</sup>

Também no caso de cumulação sucessiva a compatibilidade é necessária. Evidentemente, se o acolhimento de um pedido é pressuposto para a análise do seguinte, é porque eles são muito mais do que compatíveis: são, sob certo ponto de vista, etapas de um só raciocínio ou de uma mesma intenção. É evidente que, em uma demanda que pretenda a declaração de paternidade e alimentos, o primeiro pedido é prejudicial em relação ao outro. A compatibilidade entre os pedidos, aqui, é tão forte que a rejeição do primeiro implica, naturalmente, também a do seguinte.

Por isso, também na cumulação sucessiva a compatibilidade entre os pedidos é uma exigência – talvez ainda mais forte do que aquela imposta para a cumulação simples.

Diz o art. 327, § 3.º, do CPC, que o requisito da compatibilidade não se aplica à cumulação eventual (art. 326). A intenção da regra foi apenas a de deixar claro que, nesta forma de cumulação, o acolhimento de um pedido implica a inviabilidade de análise dos demais. Os pedidos se excluem e por isso, no entender da lei, haveria incompatibilidade entre eles. Na realidade, a regra é claramente desnecessária, já que o tema já era suficientemente resolvido pela doutrina brasileira. Sempre se considerou que a compatibilidade exigida, por ser jurídica, abrange também a hipótese da cumulação eventual. E isso porque também na cumulação eventual os pedidos aproximam-se pela causa de pedir comum. São soluções possíveis diante da narrativa dos fatos apresentados e o pleito deixa claro que busca apenas uma das alternativas possíveis. Sob esse ângulo, são também compatíveis.<sup>182</sup>

Dessa forma, em todos os casos de cumulação, inclusive na eventual, há compatibilidade entre os pedidos, desde que adequadamente entendido o requisito.

Havendo pedidos cumulados incompatíveis, deve o juiz intimar a parte para que proceda à escolha do que melhor lhe parece, sendo vedado ao órgão jurisdicional indeferir desde logo a petição inicial.

#### d) competência do juízo

Para a cumulação de pedidos – simples ou alternativa – impõe-se também que o juízo seja competente para todos os pedidos.

Mais precisamente, o juízo tem de ser “absolutamente” competente para conhecer de todos os pedidos cumulados. Se o juiz é relativamente incompetente, incidem as normas sobre prevenção e conexão, não havendo, em princípio, óbice à cumulação.

Por outras palavras, o que não se admite é que se possa cumular pedidos que correspondam a competências absolutas (funcional e material) distintas. Não tem cabimento cumular pedidos cível e criminal, ou eleitoral e trabalhista.



Se o óbice é de competência relativa, porém, considerando a natureza disponível da regra, o problema pode ser superado. Se os pedidos cumulados correspondem a competências relativas diversas e não houver a insurgência da parte contrária (por meio da tempestiva alegação de incompetência), prorrogar-se-á a competência do juízo perante o qual o processo tramita, o que conduzirá à satisfação do requisito posto pelo art. 327, § 1.º, II, do CPC.

Por outro lado, se houver conexão entre os pedidos, impor-se-á a reunião dos pedidos, de sorte que o juízo em que proposta a demanda será competente para todos. Aplica-se aí a causa de modificação de competência prevista pelo art. 54, do CPC.

O problema, portanto, é antes uma discussão de competência absoluta, só importando a competência relativa se houver oposição da parte ré.

Pode ocorrer de o juiz ser absolutamente competente para conhecer apenas um ou alguns dos pedidos cumulados. Nesse caso, deve o juiz julgar aquele ou aqueles para os quais é competente, não conhecendo daquele ou daqueles para os quais é absolutamente incompetente (essa é a ratio subjacente à da Súmula 170, STJ):

compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio).

Se o problema envolver apenas a competência relativa e “houver” a oposição tempestiva do réu, então o juiz se tornará incompetente para julgar um ou alguns dos pedidos cumulados. Nesse caso, em face da primazia da análise do mérito e do princípio do aproveitamento dos atos processuais, não deve o juiz extinguir o processo em relação aos pedidos para os quais se mostra incompetente. Deve extrair cópia dos autos e remetê-la ao juízo competente para a análise dos pedidos que não podem ser apreciados por ele.

#### e) adequação do procedimento

Impõe-se ainda que o mesmo procedimento seja adequado para a tramitação de todos os pedidos cumulados.

Como se sabe, o código prevê o procedimento comum e procedimentos especiais; o processo de conhecimento e o processo de execução; os procedimentos de jurisdição contenciosa e os de jurisdição voluntária. A cumulação de pedidos depende da identidade de procedimento para todos os pedidos que se postula em conjunto. Assim, em princípio, só se admite a cumulação se todos os pedidos usarem do mesmo procedimento comum, especial etc.

Nos termos do que faculta o art. 327, § 2.º, do CPC, é possível ao demandante cumular pedido que siga o procedimento comum com pedido sujeito a procedimento especial, desde que o demandante opte pela adoção do procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições do procedimento comum.

Por outras palavras, ainda que feita a opção pelo rito comum, isso não impede o emprego das técnicas diferenciadas, descritas no rito comum, que sejam compatíveis com o rito geral. De um lado, isso implica dizer que a opção pelo procedimento comum não exclui – e nem poderia – o emprego das técnicas de efetivação de decisões, descritos nos arts. 139, IV, 536, 537 e 538, do CPC. De outro, isso leva à conclusão de que as modificações dos ritos especiais – v.g., liminar possessória, consignações inicial e ulterior de valores controvertidos – se elas não forem incompatíveis com o procedimento comum.<sup>183</sup> Haverá, portanto, certa dose de maleabilidade neste procedimento comum, que poderá ser adaptado aos pedidos que podem submeter-se a ritos especiais, de modo que não percam os contornos necessários à sua proteção.

Sob outro ângulo, note-se que, no regime do Código de 2015, resta absolutamente superada, a polêmica de saber se é possível ou não se cumularem pretensões satisfativa e asseguratória. Em que pesem os objetivos distintos de cada uma destas tutelas, prevaleceu no Código a orientação da

cumulabilidade (art. 308, § 1.º, do CPC), de forma que eventual óbice de procedimento, aqui, não impedirá a cumulação.

Se cada um dos pedidos cumulados se sujeita a procedimentos especiais diferentes e não se mostra adequado o emprego do procedimento comum para todos, o que impõe ao juiz oportunizar ao autor a opção por um dos pedidos, sendo-lhe vedado indeferir desde logo a petição inicial.

#### f) oportunidade da cumulação

Embora o Código não o preveja, é da essência da cumulação que ela se dê em favor da economia processual. Para tanto, porém, é necessário que essa cumulação seja também “oportuna”.<sup>184</sup>

Se a cumulação comprometer a defesa do demandado ou a rápida solução do litígio (por analogia, art. 113, § 1.º, do CPC, já que o litisconsórcio facultativo simples implica cumulação objetiva), pode o juiz intimar o autor para que escolha qual o pedido que deve ser analisado no processo, não conhecendo dos demais.

Pode o réu, ainda, requerer a inadmissibilidade da acumulação simples por idênticos fundamentos, inclusive em momento anterior à contestação, mediante mero requerimento nos autos, hipótese em que se interrompe o prazo para resposta à demanda (por analogia, art. 113, § 2.º). Trata-se de possibilidade que se adjudica ao demandado como decorrência direta do direito fundamental à paridade de armas no Código de Processo Civil (art. 5.º, I, da CF).

### 5. Cumulação inicial e cumulação ulterior

Calha ainda lembrar que a cumulação de pedidos pode dar-se desde logo, na petição inicial, ou ocorrer ulteriormente, no curso do processo.<sup>185</sup>

A cumulação ulterior, para ser viável, depende – ademais da satisfação dos requisitos já vistos – da satisfação de pressupostos legais específicos, referidos por diversos dispositivos legais para casos pontuais.

Assim, por exemplo, a reconvenção implica cumulação ulterior de pedidos. Para sua admissão, porém, além do preenchimento dos requisitos do art. 327, do CPC, impõe-se a observância do art. 343, do Código.

Na denunciação da lide, há clara hipótese de cumulação de pedido, formulada em face do denunciado. Para tanto, porém, além dos requisitos aqui examinados, é necessário atender ao que preveem os art. 125 e ss., do CPC.

Também, no caso de aditamento à petição inicial – com a inclusão de novos pedidos – tem-se cumulação ulterior de pedidos. Esta, porém, para ocorrer depende da satisfação do que prevê o art. 329, adiante examinado.

### 6. Requisitos para o concurso de ações

Como já se observou, a cumulação a de ações pode ocorrer em razão da apresentação de mais de uma causa de pedir para um pedido comum. Esse fenômeno, denominado tradicionalmente de concurso de ações, constitui, de certo modo, derivação da cumulação de pedidos.

Por isso, seus requisitos são os mesmos expostos acima para a cumulação de pedidos, embora aqui a presença de conexão seja natural (pela identidade do pedido).

Assim, só se admite esse concurso se o juiz for competente, se as causas de pedir forem compatíveis e se o procedimento for adequado para todas as causas de pedir (que, em última análise, importam cada uma em um pedido próprio, que por uma eventualidade, é o mesmo).

É importante notar que, também aqui, há cumulação de pedidos. Na verdade, cada causa de

pedir implica um pedido (que é, ocasionalmente, o mesmo para todas as causas), o que conduz à conclusão de que se está diante de várias ações diversas “e autônomas”, que poderiam bem ser veiculadas separadamente, ainda que sempre com o mesmo pedido.

Segue daí a conclusão de que “todas estas ações devem ser examinadas pelo juiz”. Ainda que o magistrado acolha o pedido por uma causa de pedir, será imprescindível que examine as outras causas petendi, já que a estas correspondem outras ações. Em consequência, se essas outras causas não forem examinadas, há omissão judicial, a caracterizar sentença citra petita. Com efeito, basta lembrar que, se as ações fossem ajuizadas separadamente, cada uma das causas de pedir seria examinada de forma autônoma. Não é porque foram as ações reunidas em um só processo, que se autoriza o juiz a desconsiderar algumas ações, só porque outras foram examinadas.

De toda sorte, o recurso interposto da sentença devolverá ao tribunal a análise de todas as causas de pedir apontadas, por força do que prevê o art. 1.013, § 2.º, do CPC.

## **7. Negócios processuais e cumulação de pedidos**

Pode-se cogitar da celebração de negócios processuais (art. 190, do CPC) para alterar os critérios estabelecidos em lei para a cumulação de demandas.

É certo que esses negócios podem implicar a alteração de competência relativa – pelo estabelecimento de foro convencional – e, nesse sentido, permitir certa superação do requisito legal inscrito no art. 327, § 1.º, II, do CPC.

Também é verdade que esses negócios podem estabelecer, sob alguns limites, modificações de procedimentos, de modo a permitir a cumulação de pedidos que fossem submetidos a ritos distintos, desde que essas modificações não ofendessem a interesse público ou colocassem a parte em condição de manifesta desvantagem.

Porém, parece também correto concluir que, se a cumulação tem, em sua essência, fundamento na economia processual, negócios processuais que autorizem a cumulação de pedidos fora das hipóteses legais devem ser vistos com ampla ressalva, na medida em que se opõem a interesse público e à garantia fundamental da duração razoável do processo. Assim, embora pareça razoável que se altere, por negócio processual, o momento em que se há de admitir a cumulação, ou o procedimento a ser adotado quando ela for efetuada, não parece lógico que se possa admitir o seu cabimento quando puder retardar ou dificultar a prestação jurisdicional.

**Art. 328.** Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.

### **1. Obrigação indivisível com pluralidade de credores**

Segundo prevê o art. 258, do CC,

a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico.

Para os fins processuais, porém, o que importa é saber se a obrigação admite ou não cumprimento fracionado, especificamente quando presente a circunstância da pluralidade de credores.<sup>186</sup>

Uma obrigação divisível, quando haja pluralidade de credores, permite que cada um reclame seu quinhão, mas certamente não autoriza que um deles venha em juízo para pretender ou para tutelar a parcela dos demais (art. 18, do CPC). Em se tratando de obrigação indivisível, porém, a lei pode – e normalmente o faz – autorizar que apenas um dos credores se apresente para a proteção do crédito como um todo. É o que prevê o art. 260, primeira parte, do CC, a dizer que “se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira”.

Desse modo, pode suceder que apenas um dos credores da obrigação indivisível se apresente

em juízo, em busca da proteção do interesse seu e dos demais. Ele será parte legítima e terá permissão legal para agir em nome de todos os demais credores. Assim ocorre porque a dívida é indivisível, não podendo o credor reclamar apenas a parcela que lhe toca.

Ocorre, porém, que nesse caso o art. 260, segunda parte, do CC, afirma que o devedor – sendo cobrado por um dos credores da obrigação indivisível – poderá pagar a obrigação “I – a todos, conjuntamente; II – a um, dando este caução de ratificação dos outros credores”. Por outro lado, afirma o art. 261, do CC, que, “se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total”.

Assim, facultado que é a um dos credores reivindicar a totalidade da obrigação em juízo, é necessário que o processo crie instrumento capaz de tutelar os interesses dos outros credores, que não se apresentaram para o processo. E isso é feito pelo art. 328, que permite que esses credores recebam sua quota-parte, desde que deduzidas as despesas na proporção de seus créditos.<sup>187</sup>

Com isso, o autor da demanda tem direito “apenas” à sua parte do crédito indivisível. O restante caberá aos outros credores. Isso, porém, não significa que o credor-autor não possa receber a totalidade da dívida. Como afirmam expressamente os arts. 260, II e 261, do CC, isso é sim possível, desde que o credor que receber a dívida toda preste caução de ratificação. Recebendo o total da dívida, os outros credores terão direito de buscar junto ao autor a sua quota, em dinheiro, deduzidas as despesas de que trata o art. 328, do CPC. Do contrário, optando o autor por não prestar a caução e por levantar apenas a sua quota-parte, o restante ficará depositado para que os outros credores recebam suas parcelas em juízo, também deduzidas as despesas eventualmente remanescentes. Raciocínio idêntico sucederá caso seja necessária a fase do cumprimento de sentença. Poderá o autor executar o total da dívida, se prestada a caução a que se refere o art. 260, II, do CC, ou apenas a sua quota-parte, caso em que os outros credores terão legitimidade para postular individualmente sua parte no crédito.<sup>188</sup>

Soa estranha a previsão de que, nesse caso, as despesas devem ser rateadas entre os credores, de forma que aqueles que não participaram do processo só podem receber sua parte quando “deduzidas as despesas na proporção de seu crédito”. Ora, se a demanda é de procedência, as despesas do processo devem ser reembolsadas pela parte vencida (o devedor), nos termos do que prevê o art. 82, § 2.º, do CPC. Aparentemente, portanto, não haverá o que deduzir.

Todavia, parece que a regra deve ser interpretada de modo mais amplo, a fim de que sua ratio seja atingida. A fim de evitar o enriquecimento sem causa, não parece justo que o autor da demanda – que teve despesas em sentido largo – para a obtenção do crédito comum deva arcar exclusivamente com esse prejuízo. Se houve gastos para a recuperação do crédito comum – e se todos os credores beneficiar-se-ão dessa atitude – então todos devem contribuir com essas despesas na proporção da vantagem que receberão.

Por isso, não parece correto concluir que as “despesas” a que alude a parte final do art. 328, do CPC, sejam só as despesas do processo. Devem, sim, implicar todas as despesas havidas com a reivindicação do crédito, sejam judiciais ou extrajudiciais. Mais rente a essa ideia era a previsão do art. 156, do CPC de 1939, que aludia às despesas “para sustentação do pleito”. Aí se incluem, portanto, as eventuais despesas do processo não reembolsadas da parte vencida, mas também aquelas com o advogado do autor (eventuais honorários contratados) e outras que possam ser diretamente ligadas à recuperação da obrigação indivisível.

## **2. Obrigação indivisível com pluralidade de credores e sentença de improcedência**

O texto legal regula a hipótese em que se tenha sentença de procedência. Nesse caso, todos os credores se beneficiarão da decisão judicial, ainda que não tenham participado do processo. Porém, o que ocorre se a sentença é de improcedência?

Como se sabe, o Código só admite a expansão da coisa julgada “quando ela favoreça a terceiros”, mas nunca para prejudicá-los (art. 506, do CPC). Por isso, diante de uma sentença de improcedência de obrigação indivisível, proposta por um só credor, os outros credores não podem

ser prejudicados, guardando suas respectivas ações de forma autônoma. Situação análoga é disciplinada pelo art. 274, do CC (na redação dada pelo Código de Processo Civil), a afirmar que

o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles.

Embora não se confundam as hipóteses de solidariedade e de indivisibilidade, a solução aqui deve ser a mesma.

Diante disso, só as decisões favoráveis aos credores da obrigação comum podem afetar as esferas jurídicas dos credores que não participaram da relação processual – e, ainda assim, reservadas eventuais exceções pessoais que o devedor tiver em relação a estes. Decisões desfavoráveis não lhes atingirão.

**Art. 329.** O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

## **1. Estabilidade da demanda**

É da tradição do Código de Processo Civil brasileiro a existência de um “procedimento rígido” estruturado por fases marcadas pela “preclusão”. Trata-se de opção legislativa inspirada no direito fundamental ao processo com duração razoável (arts. 5.º, LXXVIII, da CF, e 4.º do CPC), na medida em que a limitação da possibilidade de modificação da causa de pedir e do pedido impede tendencialmente contramarchas derivadas da necessidade de reabertura do contraditório e da instrução das questões oriundas da alteração objetiva do material litigioso.<sup>189</sup>

Em virtude disso, o Código de 1973, na redação original do seu art. 294, estipulava que “quando o autor houver omitido, na petição inicial, pedido que lhe era lícito fazer, só por ação distinta poderá formulá-lo”. O preceito foi alterado em 1993, por meio da Lei 8.718, que previu a possibilidade de aditamento da petição inicial “sempre antes da citação do réu”, correndo à conta do autor as custas acrescidas em razão dessa iniciativa.<sup>190</sup>

Diante disso, a lei então vigente passou a admitir que, em que pese a rigidez que presidia o procedimento então concebido, fosse permitida certa maleabilidade desde que não houvesse prejuízo à defesa do réu. Por isso, passou-se a autorizar que o autor pudesse, até a citação do réu, acrescentar ou retirar pedidos da petição inicial.

As polêmicas, porém, ainda eram importantes, na medida em que os arts. 264 e 294 daquele código aparentemente se sobrepunham. Embora um deles falasse em “aditamento” do pedido e o outro aludisse a “modificação” do pedido ou da causa de pedir, havia dúvida sobre a extensão desses conceitos.

Alguns autores concluíam que os termos deveriam ser assimilados, o que conduziria à predominância do art. 264, daquele Código, que permitiria a modificação (lato sensu) da petição inicial antes da citação do réu, independentemente de qualquer manifestação deste; e entre a citação do réu e o saneamento do processo, desde que houvesse a anuência deste.<sup>191</sup> Outros, entretanto, faziam uma distinção entre a modificação da petição inicial e o seu aditamento. A modificação importaria a simples alteração “qualitativa” do conteúdo da inicial, sem que novos pleitos fossem acrescentados ou que pedidos fossem retirados. O aditamento, ao contrário, seria a modificação “quantitativa” da petição inicial para que se somassem pedidos [que antes haviam sido omitidos ou para que se retirassem pedidos que constavam na peça inicial].<sup>192</sup>



## 2. Modificação e aditamento da petição inicial no Código

Buscando superar a polêmica existente no Código anterior, a lei de 2015 apresenta nítido avanço no tema, uniformizando o tratamento das duas figuras e espancando qualquer dúvida de que o regime, tanto para o “aditamento”, como para a “modificação”, deve ser o mesmo.

Seguindo essa linha, o art. 329 refere que o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir: I – até a citação, independentemente do consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias, facultado o requerimento de prova suplementar – obviamente por quaisquer das partes.

Ou seja, não há mais dúvida de que, no regime atual, a modificação – tanto qualitativa, quanto quantitativa – submete-se a um só regime. Ademais, deve-se considerar inserida na cláusula legal a possibilidade de alteração dos sujeitos do processo, já que isso, de certo modo, repercute no pedido ou na causa de pedir da demanda.<sup>193</sup>

A estabilidade da demanda pode ser relativizada, seja para a modificação do pedido ou da causa de pedir, até a citação do réu, independentemente de sua manifestação. Pode também ocorrer, depois de citado o réu, desde que ele consinta, até o saneamento do processo. Por modificação, assim, no regime atual, compreendem-se tanto os casos de aditamento, como de alteração do conteúdo da inicial. Pode-se, portanto, acrescentar causas de pedir, pedidos ou até mesmo as partes; pode-se também modificar todos esses elementos, desde que respeitadas as condições estabelecidas no preceito. É evidente que não há modificação (em sentido lato) se a parte, ao longo do processo, limita-se a melhorar, a aperfeiçoar ou a esclarecer a narrativa das circunstâncias não essenciais. Também não há se, no curso do processo, a parte modifica a qualificação jurídica que havia inicialmente atribuído a esses fatos ou invoca norma jurídica distinta, para subsidiar sua argumentação. Identicamente, não se deve considerar como modificação da petição inicial a correção de simples erros materiais constantes na peça inaugural.<sup>194</sup>

Observe-se, ainda, que essa modificação pode dar-se de forma espontânea, tal como prevê o artigo em exame, como por provocação judicial, nos termos já examinados nos comentários ao art. 321. Assim sendo, nem toda modificação decorre da manifestação exclusiva da parte e se atrela a simples “vontade” do autor. Há casos em que essa modificação é impositiva.

Ademais, há também situações especiais de modificação que não se inserem na cláusula do dispositivo em exame. A exibição de documento ou coisa contra terceiro, por exemplo (art. 401 e ss., do CPC), trata de regime especial de aditamento de pedido, acrescentando-se até mesmo novo sujeito à relação processual, que não se sujeita, evidentemente, ao regime preclusivo do art. 329, do Código.

Segundo afirma o dispositivo em exame, a modificação do pedido ou da causa de pedir tem por momento final o saneamento do processo. Esse saneamento é marcado pela decisão de saneamento ou pela audiência de saneamento, quando ocorrer (art. 357, do CPC). Logicamente, sendo o caso de julgamento antecipado da lide (art. 355) ou de extinção do processo (art. 354), não se cogitará de modificação da petição inicial, porque aí a modificação poderá ocorrer até a prolação da sentença.

Por outro lado, note-se que não basta a concordância do réu, para que haja a modificação do pedido depois da citação dele. É necessário que se lhe dê a oportunidade de exercitar plenamente o contraditório, com a possibilidade de nova manifestação no prazo mínimo de quinze dias, facultando-se a ambas as partes a instrução dos elementos acrescentados ou modificados.

No mais, o art. 329 fala em “aditar ou alterar” o pedido ou a causa de pedir. Porém, o Código não veda a possibilidade de a parte autora pretender “reduzir” a causa de pedir ou o pedido. A redução da causa de pedir e do pedido pelo autor é lícita e não se submete aos limites temporais da citação e do saneamento da causa. Com efeito, o pedido pode ser reduzido em virtude de: (i)



desistência da ação no tocante a uma parte do pedido ou a um dos pedidos (quando houver cumulação de pedidos); (ii) renúncia a uma parte do direito postulado; (iii) transação parcial na pendência do processo; (iv) convenção de arbitragem em relação a uma parte do objeto do litígio e (v) recurso em relação a uma parte da sentença. Em todos esses casos, fica claro que há autorização legal para a redução do pedido, de modo que a sua ocorrência não fica subordinada aos limites temporais definidos pelo art. 329.

### **3. Modificação convencional**

No direito anterior, porém, dizia-se que em “nenhuma hipótese” seria admitida modificação da causa de pedir e do pedido depois do saneamento da causa. O direito vigente não repetiu semelhante vedação e, por isso, abre a brecha para que outra solução seja buscada.

Um dos casos em que isso pode ocorrer será, evidentemente, a hipótese de modificação convencional. Assim, versando a causa sobre direitos disponíveis e sendo as partes capazes, nada obsta à “modificação acordada” da causa de pedir e do pedido (art. 190). Modificado o material litigioso, tem-se que se seguir nova oportunidade de debate e de prova, inclusive determinada de ofício, em sendo o caso, pelo magistrado.<sup>195</sup>

Importa notar, ainda, que o direito brasileiro não submeteu a validade do acordo processual sobre a modificação da causa de pedir e do pedido pelas partes à perspectiva judicial de sua utilidade em termos procedimentais – e nem mesmo permitiu a modificação do objeto litigioso do processo por força de requerimento do demandante e à percepção judicial da sua utilidade (como no direito alemão, § 263, ZPO). Em outras palavras, não deferiu ao órgão judicial qualquer juízo de valor a respeito da conveniência ou não da realização do acordo processual sobre a modificação da causa de pedir e do pedido. Assim, o juiz só poderá negar validade a acordo dessa ordem nos casos expressamente mencionados no art. 190, parágrafo único, ou quando isso possa violar garantia fundamental.

### **4. Estabilidade do pedido reconvenicional**

A mesma possibilidade de modificação da causa de pedir e do pedido aplica-se à reconvenção.

A previsão, contida no parágrafo único do art. 329, seria desnecessária, na medida em que, tratando-se a reconvenção de nova ação, seria intuitiva a aplicação da regra em estudo também a essa figura. Aliás, a possibilidade de modificação do pedido ou da causa de pedir “não se aplica apenas à petição inicial e à reconvenção”. Incide sobre “todas as ações propostas no curso do processo”. Assim, por exemplo, também à petição inicial da exibição de documento ou coisa em face de terceiro é possível que se modifique o pedido ou a causa de pedir.

Em todos esses casos, autoriza a lei que a parte modifique seu pedido ou sua causa de pedir até a intimação da parte contrária ou a citação do terceiro, independentemente de seu consentimento, ou até o saneamento do processo, desde que haja a concordância do sujeito requerido.

Particularmente, no caso da reconvenção, a modificação ou o acréscimo do pedido reconvenicional, portanto, pode ocorrer sem a anuência do autor antes de sua intimação para manifestar-se sobre a questão, ou entre esse momento e o saneamento, desde que com a concordância do reconvindo.

### **5. A necessidade de uma visão sistêmica da estabilidade da demanda**

Ao adotar expressamente a lógica da estabilidade inicial da demanda, o Código responde a uma determinada visão de processo, muito atrelada a litígios individuais, de cunho patrimonial disponível. Para essas demandas, é fácil justificar que se dê ao autor uma oportunidade pequena de alteração dos limites da controvérsia, sobretudo em razão do caráter disponível do direito, da preservação do contraditório.

Porém, vários conflitos comuns na praxe atual transbordam esses limites clássicos.<sup>196</sup> Por isso é mais do que necessário reexaminar o dogma da estabilidade, sobretudo para certos tipos de

conflitos. Se o fundamental é a preservação do contraditório, então desde que ele seja preservado, não se justifica a vedação à modificação do pedido ou da causa de pedir, sobretudo quando essa alteração é essencial para traduzir a atualidade do conflito.

Seria, portanto, desejável flexibilizar a ideia de estabilidade. Para tanto, uma ampliação da lógica trazida pelo art. 493, no sentido de permitir que esses fatos novos possam ultrapassar os limites da causa de pedir,<sup>197</sup> contribui decisivamente. Caso se compreenda que, na noção desses fatos novos está embutida a possibilidade de se modificar o pedido ou a causa de pedir – desde que respeitado o contraditório – haverá grande passo dado em prol da proteção adequada desses interesses, cada vez mais frequentes e, sem dúvida, absolutamente relevantes.<sup>198</sup>

### *Seção III*

#### *Do indeferimento da petição inicial*

**Art. 330.** A petição inicial será indeferida quando:

- I – for inepta;
- II – a parte for manifestamente ilegítima;
- III – o autor carecer de interesse processual;
- IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1.º Considera-se inepta a petição inicial quando:

- I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;
- II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
- III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
- IV – conter pedidos incompatíveis entre si.

§ 2.º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3.º Na hipótese do § 2.º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

#### **1. Juízo de admissibilidade da petição inicial**

Apresentada a petição inicial, ela ficará sujeita a prévia análise judicial, momento em que, basicamente, quatro providências podem ser tomadas. Em primeiro lugar, notando que a petição está formalmente adequada, ela será admitida e processada, determinando-se a citação do réu para o processo. Em segundo lugar, pode-se cogitar da aplicação do art. 321 do CPC, ou seja, caso a petição inicial não preencha os requisitos formais, ou contenha defeitos ou irregularidades que dificultem a análise da controvérsia, deverá o juiz instar a parte a corrigir o defeito. Em terceiro lugar, poder-se-ia imaginar a presença de defeito processual tão grave na petição inicial que sequer seria viável tentar corrigi-la; nesse caso, a petição poderia desde logo ser indeferida. Por fim, pode suceder que a inicial reflita pretensão manifestamente inviável, à luz da orientação jurisprudencial vigente, caso em que será possível o julgamento imediato de improcedência do pedido.

Desta última hipótese trata o art. 332, a ser adiante examinado. Haverá, nesses casos, sentença de mérito, catalogada dentre as hipóteses do art. 487 do Código (em particular, nos seus incs. I ou II), apta a receber o selo de imutabilidade típico da coisa julgada.

No artigo aqui analisado, trata-se da terceira hipótese, ou seja, da situação em que a petição

inicial contém irregularidades tamanhas que devem impor sua pronta rejeição, ainda que sem a apreciação do mérito da controvérsia. Aqui, a sentença será meramente terminativa, de modo a enquadrar-se em um dos casos do art. 485 do CPC. Em verdade, o indeferimento da petição inicial de que aqui se cogita será sempre uma sentença de extinção do feito sem resolução do mérito; divergir, porém, das situações clássicas em que essas sentenças são proferidas porque, aqui, a extinção se dá in limine litis, ou seja, antes mesmo de citado o réu. Essa situação particular conduz também a uma consequência no plano recursal: a apelação interposta contra essa sentença tem as particularidades descritas pelo art. 331 do CPC. Assim, uma sentença que reconheça a ilegitimidade da parte amolda-se ao art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sujeitando-se à apelação tradicional. Porém, se essa mesma sentença for proferida no início do processo, antes de citado o réu, haverá hipótese de “indeferimento da petição inicial”, de forma que a apelação conerá as particularidades descritas pelo art. 331, do CPC.

De todo modo, cogita-se aqui de casos em que o processo não seguirá. As irregularidades detectadas são de tal monta que impedirão o prosseguimento da marcha processual.

A rigor, como se verá, mesmo nesses casos, deve-se deferir à parte o direito de tentar sanar o defeito, a fim de que o processo se torne viável, ou, ao menos, deve-se ouvir, primeiramente, o autor, para que possa esclarecer se o problema realmente existe ou se o defeito não é mais aparente do que real.

Ainda assim, cogita-se aqui de hipóteses que fazem com que o processo não deva seguir, porque é manifestamente inviável.<sup>199</sup> A regra é que o processo prossiga, para se avaliar se o autor tem ou não razão. Por isso, as causas de indeferimento são excepcionais e devem ser assim interpretadas. Trata-se de rol exaustivo, que não admite interpretação ampliativa. Se o Estado nega a autotutela privada e confere aos particulares o direito de ação, a negativa em analisar as pretensões deduzidas pela ação só pode ocorrer diante de expressa autorização legal.

## **2. Inépcia da inicial**

A primeira das causas que autoriza o indeferimento da petição inicial é a sua inépcia. Inépcia é termo que designa algo ininteligível ou incompreensível, com incapacidade de prestar-se à sua finalidade. Para os fins do Código, porém, o termo tem extensão muito mais restrita. A inépcia de que trata o Código é a legal, processual, especificamente definida pelo § 1.º do art. 330, em exame.

Por isso, só se considera inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, fora das hipóteses em que permitido, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis (art. 330, § 1.º, CPC), ressalvada a possibilidade de cumulação alternativa (art. 326, CPC).

Uma petição mal feita, mal redigida, truncada, certamente conerá defeitos que inviabilizam – e não só dificultam (na expressão do art. 321 do CPC) – a análise do mérito. Porém, não é, nos termos da legislação processual, inepta.<sup>200</sup>

É certo que, no modelo atual, a distinção perde grande parte do seu interesse, na medida em que, sempre, deve o juiz antes de rejeitar a petição inicial permitir à parte que sane o defeito. Assim, tratando-se de petição inicial que contenha defeitos que inviabilizem ou que dificultem a análise de mérito, as consequências são as mesmas: o juiz não poderá indeferir a petição inicial sem dar à parte a oportunidade de sanar o problema, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil.

Apesar disso, é de se concluir que só será inepta a petição inicial nos casos descritos em lei.

O primeiro caso enunciado no texto legal diz respeito à ausência de pedido ou de causa de pedir. Logicamente, partindo da premissa de que, segundo a óptica tradicional, a atuação jurisdicional está limitada àquilo que é trazido como pedido e como causa de pedir, torna-se inviável a prestação do Estado se não há delimitação desses aspectos. Por isso, uma petição inicial que não descreva esses elementos torna inviável o prosseguimento da atividade jurisdicional.

Ademais, é certo que, sem esses elementos, torna-se praticamente impossível ao juiz conhecer a extensão do conflito e, assim, decidir sobre ele. Logo, esses são os elementos mínimos que devem ser oferecidos para que uma demanda possa ser processada.

Como já dito, em doutrina costuma-se assimilar à hipótese de ausência de pedido ou de causa de pedir o caso em que, embora presente, o elemento seja incompreensível. A discussão soa, para o Código atual, estéril, na medida em que, ausente o requisito ou sendo ele ininteligível, jamais estará autorizado o indeferimento da petição inicial sem que se oportunize à parte sanar a irregularidade, a menos que seja impossível a sua correção.

De toda sorte, recorde-se que não integra a causa de pedir a qualificação jurídica do fato o apontamento da regra jurídica aplicável ou ainda a indicação de doutrina ou de jurisprudência sobre os aspectos debatidos na inicial. Logo, a ausência desses elementos não constitui defeito da petição inicial, nem autoriza determinação de emenda ou seu indeferimento.

Por outro lado, o Código considera inepta a petição inicial que formula pedido indeterminado fora dos casos autorizados em lei. O tema já foi tratado nos comentários ao art. 324, valendo aqui recordar apenas que os casos em que esse pedido indeterminado é admissível são apenas os previstos no dispositivo mencionado, mas incluem ainda a ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos e a ação para a reparação de dano moral.

Em terceiro lugar, haverá inépcia sempre que, da narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão. Trata-se aqui de hipótese específica de ininteligibilidade que, mais do que inviabilizar o julgamento da controvérsia, impede o próprio conhecimento do litígio. Se a parte narra certo problema, mas formula pedido totalmente distinto, não há como saber se a tutela jurisdicional buscada diz respeito ao conflito narrado ou ao pedido formulado. Em qualquer dos casos, haverá situação que pode ser assimilada à ausência de pedido ou de causa de pedir, já que se a narração dos fatos não induz à conclusão é porque ou falta a narração dos fatos adequadas, ou a conclusão correta.

Como aponta Calmon de Passos, esse defeito lógico pode decorrer: a) de ter o autor narrado na inicial fatos não qualificados pelo direito, ou seja, juridicamente irrelevantes, de onde não decorrerá qualquer conclusão jurídica viável; b) embora o fato seja juridicamente relevante, a consequência jurídica atribuída não é autorizada; c) houve tipificação inadequada do fato narrado, que resulta na atribuição equivocada das consequências jurídicas cabíveis.<sup>201</sup>

Em todos esses casos, só haverá inépcia se desses defeitos advier a impossibilidade de identificar adequadamente o litígio, pronunciando-se a seu respeito. Do contrário, ainda que a petição seja mal elaborada ou contenha erros ou omissões, não poderá ser qualificada como tal.<sup>202</sup>

Em qualquer desses casos, há defeito lógico na construção da petição inicial. Esse defeito precisa ser sanado, sob pena de não permitir ao juiz conhecer adequadamente a controvérsia e manifestar-se a seu respeito.

O último caso de inépcia descrito na lei é a existência de pedidos incompatíveis entre si. A rigor, esse não é normalmente um caso de indeferimento da petição inicial, nem de sua inépcia.

Em primeiro lugar, recorde-se que a própria lei admite a formulação de pedidos incompatíveis, no caso da cumulação eventual (arts. 326 e 327, § 3.º, do CPC). Ora, se essa cumulação é admissível por lei, não se pode cogitar da inépcia da petição inicial que se vale dessa faculdade.

Em segundo lugar, ainda que não seja o caso de cumulação eventual, fato é que a presença de cumulação de pedidos incompatíveis acarreta, em princípio, a vedação da cumulação, por ofensa ao art. 327, § 1.º, I, do CPC. Logo, a consequência natural será a proibição judicial a que o autor proceda à cumulação, *mas não o indeferimento da petição inicial*.

Assim, a cumulação de pedidos incompatíveis só será caso de inépcia da petição inicial se, intimado o autor a adequar sua demanda, deixar ele transcorrer in albis o prazo para tanto, não sendo possível ao órgão jurisdicional verificar se há algum dos pedidos para o qual pode o

processo prosseguir.

Como se vê, portanto, em todos os casos aqui descritos, não tem cabimento – salvo se absolutamente impossível – a rejeição imediata da petição inicial. É necessário, em primeiro lugar, que se faculte à parte corrigir o defeito e, só diante da sua omissão, é que cabe o indeferimento da inicial.

### 3. Falta de condição da ação

Outro caso apontado no Código para o indeferimento da inicial é a ausência de condição da ação. Embora o Código de Processo Civil vigente não aluda mais à expressão “condições da ação”, o que poderia significar a superação dessa categoria, fato é que, em várias passagens, ele mantém a ratio dessas figuras, tratando-as como questões prévias ao juízo de mérito (art. 485, VI) que não podem, então, ser confundidas com aspectos da controvérsia.

A solução é discutível, na medida em que o debate sobre a natureza das condições da ação, no direito processual atual, é importante e já permitiria superar essa categoria.<sup>203</sup>

Porém, ainda que fosse desejável a abolição das condições da ação, é indiscutível que o Código ainda titubeia em afastar-se dessa figura. Faz alusão expressa às duas figuras mantidas pela teoria de Liebman a seu respeito e colocando-as como questões antecedentes à análise do mérito.<sup>204</sup> Por isso, ainda que se possa superar essa categoria, assim devem ser tratadas as figuras em exame, ao menos para a análise do indeferimento da petição inicial.

Segundo Liebman, a ação – ao contrário do direito de petição – não é atribuída a qualquer pessoa, mas apenas a quem pode demonstrar uma situação determinada e perfeitamente individualizada.<sup>205</sup> Por isso, no intuito de evitar que a jurisdição atue no vácuo, é necessário satisfazer algumas condições específicas, capazes de permitir ao magistrado conhecer do mérito da controvérsia. Essas condições, segundo a orientação última do autor, seriam o interesse processual e a legitimidade de parte.<sup>206</sup>

#### a) legitimidade

Atendendo a essa orientação, afirma o Código de Processo Civil de 2015 que a petição inicial deve ser indeferida se “a parte for manifestamente ilegítima”.

A legitimidade, na ótica de Liebman, é a titularidade, ativa ou passiva, da ação.<sup>207</sup> Implica avaliar se os sujeitos do processo e os sujeitos do conflito são equivalentes ou, ao menos, se há autorização legal para que haja diversidade entre esses sujeitos. De acordo com o art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Como regra, portanto, somente aquele que se alega titular de um direito pode postular sua tutela. E só pode fazê-lo em face daquele que, alegadamente também, viola ou ameaça o direito. Apenas em casos excepcionais, quando expressamente autorizado por lei, poderá alguém discutir em juízo, no polo ativo ou no passivo, direito alheio.

Assim, por exemplo, se A vai a juízo, alegando que B é credor de C e que C deve satisfazer essa obrigação, será reconhecida sua ilegitimidade, na medida em que ele não pode postular a tutela do direito alheio, seja porque ele não se atribui essa pretensão, seja porque não há autorização legal para a proteção de interesse de outrem.

Para parte da doutrina nacional, a alusão à legitimidade prevista pelo Código abrangeria tanto a legitimidade ad causam (condição da ação) como a legitimidade ad processum (a capacidade, que constitui pressuposto processual subjetivo).<sup>208</sup>

Não parece que o Código tenha empregado a expressão nesse sentido amplo. Ao contrário, parece claro que a referência se limita a tratar da condição da ação, até mesmo pela referência posterior feita ao interesse processual. Daí não decorre, porém, a conclusão de que a incapacidade

da parte deva ser irrelevante ou desautorize a extinção prematura do processo. Como pressuposto processual que é, sem ele o processo não pode instaurar-se validamente. Por isso, ausente a capacidade da parte – e não sanado o defeito tempestivamente –, impõe-se também o indeferimento da petição inicial, mas com base no art. 330, IV, do CPC, já que ausente documento indispensável à propositura da demanda, que indique o preenchimento desse pressuposto.

#### b) interesse processual

A outra condição da ação indicada no Código é o interesse processual. Este interesse corresponde à relação de utilidade existente entre a lesão ao direito que é afirmada e o provimento judicial que é postulado.<sup>209</sup> Envolve, basicamente, a cogitação de dois aspectos da demanda. Inicialmente, a necessidade da proteção demandada, ou seja, a necessidade de se obter em juízo a proteção a certo interesse afirmado como existente. Envolve, também, a cogitação sobre a idoneidade da tutela almejada para a proteção buscada.<sup>210</sup>

Se alguém demanda por dívida alegadamente já paga, não tem necessidade na prestação jurisdicional. Por outro lado, se pretende a dívida não paga, mas o faz por meio de pedido que espera a interdição do réu, falta-lhe interesse por inadequação da via escolhida.

Ambas as condições da ação aceitas – e como tal descritas acima –, como se vê, poderiam muito bem ser assimiladas a hipóteses de inépcia da petição inicial. Quem afirma que uma demanda já foi paga, mas mesmo assim postula sua satisfação, evidentemente formula argumentação na qual, das premissas, não decorre a conclusão. O mesmo se dá se alguém diz não ser titular de um direito, mas busca a sua satisfação.<sup>211</sup>

Para tentar salvar a categoria, como instituição autônoma, parte da doutrina nacional tem afirmado que as condições da ação só assumem esse adjetivo se tomadas in statu assertionis. Ou seja, para essa parte da doutrina, a diferença entre a análise de mérito e a análise de condição da ação está em que, nestas, a avaliação se faz apenas com base na afirmativa feita pela parte, que será contrastada com a lei, sem considerar as provas eventualmente carreadas aos autos.<sup>212</sup> Haveria aí, apenas por razões de economia processual, a instituição de técnica que permite uma forma de “julgamento antecipado”.<sup>213</sup>

Mesmo utilizando desse método, as condições da ação continuam sendo uma artificialidade desnecessária, sobretudo porque sua análise de regra se confunde com o exame de mérito. Mais precisamente,

as condições da ação somente podem ser requisitos para a viabilização do exame do pedido. Esses requisitos têm relação com o mérito e, dessa forma, não podem ser considerados requisitos para a existência da ação. Tais requisitos são os primeiros degraus ligados à apreciação do mérito – e, nessa direção, para a tutela do direito.<sup>214</sup>

Nesse sentido, a avaliação dessas “condições da ação” – caso queira-se separar esse conceito da análise de mérito – só tem sentido se realizada initio litis. Depois de instaurado o contraditório, não se justifica mais a declaração de “carência de ação”, exatamente porque aí a causa já está pronta para definição do conflito.

Por isso, a ausência dessas condições ou recai em um caso de inépcia da petição inicial, ou deveria ser absorvida pelos casos descritos no art. 332, adiante examinados.

#### 4. Descumprimento do dever de emenda da inicial

A última hipótese descrita no dispositivo em exame como autorizador do indeferimento da petição inicial decorre de uma sanção pelo descumprimento do dever de correção, imposto pelo juiz com base nos arts. 106 e 321 do CPC.

O primeiro dos dispositivos indicados alude ao dever de o advogado indicar o endereço (físico e, sempre que possível, eletrônico<sup>215</sup>), o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogado da qual participa (bem como eventuais alterações subsequentes



de endereço) para fins de intimação.

Conforme estabelece o art. 106, § 1.º, do CPC,

se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará que se supra a omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição.

Logo, como se vê o preceito colocado no art. 330, IV, primeira parte, é simples repetição do contido no art. 106, § 1.º, do Código.

Seja como for, vale uma advertência: o art. 106 conta com duas diferentes sanções para o descumprimento dos deveres estabelecidos ali. Em primeiro lugar, conforme o § 1.º já mencionado, estabelece-se a possibilidade do indeferimento da petição inicial. Em segundo lugar, porém, nos termos do § 2.º do mesmo preceito, afirma o Código que, se o advogado deixar de comunicar eventuais mudanças de endereço, a consequência não será o indeferimento da inicial. Será, sim, a validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos.

Em consequência, apenas a ausência de indicação, na petição inicial, do endereço, do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e da sociedade de advogados da qual o patrono participa é que poderão ensejar o indeferimento da petição inicial, ao contrário do que faz supor o art. 330, IV, primeira parte, do CPC. Caso não haja comunicação de mudança de endereço (art. 106, II, do CPC), quando muito isso pode repercutir na validade das comunicações encaminhadas ao endereço desatualizado, mas jamais implicará o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo.

A outra situação descrita no dispositivo (não atendimento das determinações a que alude o art. 321, do Código), também já está prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. Ali já consta a advertência de que, não cumpridas as diligências determinadas pelo juiz no prazo de quinze dias, caberá ao juiz indeferir a petição inicial. Mais uma vez, há aí redundância injustificável.

Porém, além da redundância, impõe-se notar que também o dispositivo não é preciso, como, aliás, consigna a doutrina há muito tempo. Como demonstra Calmon de Passos,<sup>216</sup> com precisão, dos elementos enumerados no art. 319 do CPC, apenas a indicação das partes, da causa de pedir, do pedido e eventualmente do valor da causa ensejarão o indeferimento da petição inicial, se não houver a correção no prazo legal.

De fato, a ausência de indicação do juízo a quem se dirige a inicial implica, quando muito, um problema de competência, que pode e deve ser reconhecida de ofício. A omissão quanto a esse elemento, portanto, não levará ao indeferimento da inicial, ainda que não suprida a falta no prazo de quinze dias, mas sim à remessa dos autos ao juízo competente.

Quanto à ausência de qualificação das partes, como se vê dos §§ 1.º a 3.º do art. 319 do CPC, não é causa de indeferimento da inicial, sobretudo se for possível a citação do réu ou se a obtenção dessas informações puder repercutir negativamente no acesso à justiça.

A ausência de indicação das provas a serem empregadas pela parte para a demonstração de suas alegações, obviamente, não implica causa de indeferimento da inicial. Aliás, sequer é razão para a emenda à inicial, como regra, já que é direito da parte determinar o conteúdo da instrução que pretende obter. Particularmente quando se pensa que esse requerimento de provas é, apenas, um “requerimento genérico”, mostra-se a inutilidade da imposição e, consequentemente, o absoluto descabimento do indeferimento da inicial pela ausência desse elemento.

Finalmente, em relação à opção pela realização ou não da audiência de autocomposição, também já se disse que, omissa a petição, é de se presumir o desejo em que o ato seja realizado. Logo, mais uma vez, a hipótese não é razão para a emenda e, a fortiori, o indeferimento da inicial.

Não é correto, por isso, supor que o descumprimento do dever de emenda em relação a todos os requisitos da inicial implique o indeferimento da peça. Apenas haverá indeferimento quando isso efetivamente prejudicar o seguimento do processo.

Em conta disso, como é lógico, a falta dos documentos indispensáveis ou a presença de defeitos que dificultem a análise de mérito – além da ausência dos elementos acima indicados – certamente importarão a necessidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento.

Em síntese, o fundamental aqui é examinar se a falta do elemento – qualquer um daqueles a que se referem os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil – realmente inviabiliza ou dificulta a análise da controvérsia ou não. Se não prejudicarem, nem inviabilizarem, então o defeito deve ser superado, não podendo gerar o indeferimento da inicial.

Por isso, também, não pode o juiz exigir, para o recebimento da inicial, a satisfação de outros requisitos não impostos em lei. Assim, por exemplo, mesmo que a parte não cumpra a decisão judicial de esclarecer se certo procedimento deveria ou não ser empregado, isso não pode acarretar o indeferimento da inicial.

## **5. Outros casos**

Afirmou-se anteriormente que o rol de hipóteses que autorizam o indeferimento da inicial é *numerus clausus*. E efetivamente o é. Porém, isso não significa dizer que todas as hipóteses de indeferimento estão previstas no art. 330 do Código.

A lei processual apresenta várias outras razões para o indeferimento da inicial, disseminadas ao longo do Código, que devem ser integradas às hipóteses aqui examinadas.

Assim ocorre, por exemplo, com a ausência de depósito preliminar, na ação de consignação em pagamento (art. 542, I, c/c o seu parágrafo único, do CPC), ou com a ausência de determinação do valor devido, juntamente com a respectiva memória de cálculo, na ação monitória (art. 700, §§ 2.º, I, e 4.º, do CPC).

Além disso, algumas das hipóteses descritas no art. 485 do Código de Processo Civil, como razões para o indeferimento da petição inicial, também devem autorizar o indeferimento da inicial.

É o que sucede, por exemplo, com a falta de pressuposto processual de formação válida do processo, desde que não suprida após determinação judicial (art. 485, IV, do CPC) ou com o reconhecimento da perempção, da litispendência ou da coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

## **6. Sanabilidade**

O indeferimento da petição inicial só é legítimo se precedido da oportunidade de emenda a fim de sanada a inépcia, a omissão na qualificação do advogado e se devidamente oportunizado o contraditório a respeito das questões concernentes à legitimidade da parte e ao seu interesse de agir.

Em outras palavras, mesmo nas questões que o juiz pode conhecer de ofício, como a legitimidade e o interesse (art. 337, § 5.º, do CPC), tem o juiz, primeiramente, o dever de oportunizar o contraditório antes de decidi-las (arts. 5.º, LV, da CF/1988, e 9.º do CPC).

Posto não se tratar propriamente de determinar emenda à petição inicial – tendo em conta que o problema aí está apenas em oportunizar ao autor que convença o juiz da ausência de qualquer defeito de legitimidade ou interesse –, é possível veicular o dever de diálogo judicial mediante emenda à petição inicial, porque o que interessa é viabilizar o contraditório sobre a questão da legitimidade ou do interesse. Inexistindo oportunidade para o contraditório, há violação do dever de diálogo do juiz, inerente à colaboração no processo civil (arts. 6.º, 9.º e 10, do CPC).

## **7. Determinação das obrigações controvertidas**

Os §§ 2.º e 3.º do art. 330 do CPC preveem ainda outra hipótese de “inépcia” da petição inicial. Afirma-se que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigações ligadas a empréstimo, financiamento ou alienação de bens, impõe-se ao autor determinar, na petição inicial, as

obrigações sobre as quais pretende controverter, além de indicar o valor incontroverso da dívida, sob pena de ser reconhecida a inépcia da inicial.

O preceito já constava do art. 285-B do CPC/1973, introduzido pela Lei 12.810/2013, e, em grande medida, decorre de concretização dos deveres de lealdade e de boa-fé processuais. Se a parte pretende impugnar apenas algumas das obrigações de um contrato, é evidente que deve ela destacar, com precisão, as obrigações que pretende controverter. Ademais, também é certo que, se só sobre estas incide o litígio, o restante do contrato deve ser presumido como legítimo, de maneira que impõe seu cumprimento.

Assim, a própria noção de causa de pedir implica a exata determinação, com a maior precisão possível, dos fatos sobre os quais incide a controvérsia. Por isso, seria inquestionavelmente necessário que, se apenas algumas das obrigações são objeto de discussão, sejam elas especificamente determinadas na petição inicial.

O preceito, portanto, tem mais uma finalidade didática, de demonstrar que a boa-fé e a lealdade processual implicam, também, o dever de a parte prosseguir adimplindo o contrato naquilo que não é objeto de litígio. Afinal, não é porque existe processo judicial sobre algumas das cláusulas ou das obrigações do contrato que todo ele fica inviabilizado.

Assim, os valores incontroversos devem continuar a ser pagos, na forma do contrato (art. 330, § 2.º, do CPC). Se as obrigações sobre as quais não incide a demanda presumem-se legítimas e exigíveis, então não pode haver dúvida de que elas devem ser adimplidas, na forma pactuada.<sup>217</sup> Logicamente, por “pagamento” deve-se entender não apenas o efetivo pagamento, mas também o depósito judicial, quando a efetiva determinação do valor exigir a prévia definição da controvérsia ou quando autorizado judicialmente.<sup>218</sup>

Recorde-se, por fim, que o rol de contratos indicados no texto legal (empréstimo, financiamento ou alienação de bens), por óbvio, é meramente exemplificativo. Se a imposição da descrição exata daquilo sobre que se controverte é inerente à ideia da causa de pedir, e se os deveres de lealdade e de boa-fé impõem o adimplemento dos aspectos não discutidos, então é evidente que não é só para os contratos arrolados no texto legal que a determinação se aplica. Qualquer contrato que contenha obrigações múltiplas exige semelhante providência, em relação àquelas que não forem objeto de discussão judicial.<sup>219</sup>

Ausente essa discriminação e/ou a indicação do valor incontroverso, impõe-se ordem de emenda da inicial (art. 320 do CPC). Não atendido o comando, haverá inépcia da inicial, nos termos do art. 330, § 2.º, do CPC, com o indeferimento da petição inicial, salvo quando não implicar prejuízo ao prosseguimento do contrato ou à compreensão da exata extensão do litígio.

**Art. 331.** Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1.º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2.º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.

§ 3.º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.

### **1. A apelação contra o indeferimento da petição inicial e retratação**

Já se disse que o indeferimento da petição inicial constitui hipótese especial de sentença, que não deve ser confundida com qualquer outra sentença de extinção do processo.

Isso decorre, em especial, não porque essa sentença contenha aspectos próprios, mas, sim, porque está sujeita a recurso que possui regime peculiar. Como se lê do caput do art. 331 do CPC, esta apelação, ao contrário do que sucede com esse recurso como regra, admite juízo de retratação. Assim, interposto o recurso, deve o juiz, antes mesmo de ouvir a parte contrária – que sequer foi citada ainda para o processo –, reexaminar sua decisão de indeferimento.

Somente se mantida a sentença impugnada é que o réu será citado para apresentar, querendo, contrarrazões. Depois disso, o recurso será, independentemente de juízo de admissibilidade, encaminhado ao tribunal.

A ausência de juízo de admissibilidade na instância a quo, no direito atual, é a regra. Desse modo, não se deve estranhar que aqui também o processamento da apelação independa de juízo de admissibilidade no 1.º grau. Porém, a doutrina questiona se, interposta apelação irregular, possa o juiz examinar a admissibilidade do recurso ao menos para que possa formular seu juízo de retratação. A doutrina tem considerado que, no caso de intempestividade da apelação interposta, deve-se outorgar ao juiz de 1.º grau a prerrogativa de examinar esse defeito, pelo menos para não proceder ao juízo de retratação.<sup>220</sup> Com efeito, sendo intempestivo o recurso, a retratação violaria a preclusão pro judicato da sentença (art. 494 do CPC), fazendo com que o juiz atuasse fora dos limites de sua atribuição. Por isso, é lógico que a análise de admissibilidade do recurso deve ser feita pelo menos para que o juiz possa exercer essa faculdade que a lei lhe atribui. Essa análise de admissibilidade, evidentemente, jamais poderá inviabilizar a tramitação do recurso, tendo consequências apenas para o exercício do poder de retratação outorgado pelo código.

É certo que a intempestividade do recurso deve implicar a inviabilidade do juízo de retratação. Porém, parece também correto que a falta de qualquer outro pressuposto recursal deve ser considerado pelo juízo a quo, ao receber a apelação. A análise, como dito, não tem por objetivo negar seguimento ao recurso, mas, sim, inviabilizar o exercício do juízo de retratação sobre a decisão de indeferimento da inicial. Por outras palavras, verificando o juiz recorrido que falta pressuposto recursal, haverá simplesmente de processar a apelação, dando-lhe o encaminhamento oportuno ao tribunal, sem, todavia, exercer qualquer juízo de retratação.

## **2. A citação do réu para contrarrazões**

Segundo o art. 331, § 1.º, do CPC, se não houver retratação do juiz (ou se for ela impossível, na forma acima vista), deverá o réu ser citado para apresentar contrarrazões.

A previsão elimina antiga polêmica instaurada no Código anterior, sobre o regime da apelação contra o indeferimento de petição inicial. Perante o Código de 1973, o art. 296, parágrafo único, limitava-se a afirmar que, não havendo retratação, os autos seriam encaminhados ao tribunal. Para alguns, essa previsão implicava dizer que seria desnecessária a oitiva do réu, até porque ele sequer teria ainda sido citado para o processo. Outros, porém, criticavam duramente essa previsão, seja porque violaria o contraditório, seja porque permitiria a renovação da discussão depois de citado o réu.<sup>221</sup> Ademais, o Código anterior dava tratamento diferente para a apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial e contra a sentença cabível na hipótese de improcedência initio litis da demanda; enquanto previa o contraditório para esta, negava-o para aquela.

A lei atual espanca qualquer dúvida a respeito do tema e dá tratamento homogêneo à rejeição inicial da demanda, seja com ou sem resolução do mérito. O réu será sempre citado para, querendo, poder apresentar contrarrazões.

Logicamente, trata-se de simples faculdade dada ao réu. Não há, aqui, ônus e muito menos se cogita de eventual “revelia” diante do não oferecimento dessas contrarrazões.

Trata-se apenas de oportunidade de participação dada ao réu, que certamente tem interesse na manutenção da sentença de indeferimento.

Por razões de lógica, sendo o réu citado para participar do recurso, a decisão desta apelação implicará preclusão para o réu a respeito da matéria julgada. Assim, se a sentença havia considerado o autor carecedor de interesse processual e o tribunal reforma esse entendimento, a matéria estará preclusa também para o réu, na medida em que ele integra – efetiva ou virtualmente – o processo no momento do julgamento.

Por outro lado, a citação em questão é a citação para o processo. Não haverá outra citação do

rêu, caso o processo retome seu curso regular. Caso o tribunal entenda por admitir a inicial, o processo será restituído à instância originária, sendo o réu intimado para a audiência de autocomposição ou para a contestação, conforme o caso. Aí, sim, não tendo constituído advogado, ou não apresentando contestação, será considerado revel, com as consequências cabíveis.<sup>222</sup>

### **3. Indeferimento parcial da petição inicial e recurso**

A apelação é o recurso cabível contra sentença. E só se considera sentença o ato judicial que conduz à conclusão de uma das fases do processo, em 1.º grau.<sup>223</sup>

Tomando por base essas premissas, é fácil notar que a lógica do art. 331 do CPC só se aplica aos casos de indeferimento total da petição inicial. Caso a inicial seja indeferida apenas em parte, o ato judicial não poderá constituir sentença e, portanto, não estará sujeito à apelação. Imagine-se a hipótese de o juiz indeferir, desde logo, a formação de litisconsórcio passivo ou certa cumulação de pedidos. Nesses casos, o processo prosseguirá em relação às partes ou aos pedidos remanescentes. Por isso, o ato judicial não poderá ser considerado sentença.

Esse ato terá natureza de decisão interlocutória e, por isso, desafiará agravo de instrumento.<sup>224</sup>

É bem verdade que o Código não arrola essa hipótese como um dos casos que admite agravo de instrumento, no art. 1.015. Porém, impõe-se análise ampliativa do rol trazido por esse dispositivo legal, sob pena de abrir espaço para a banalização do mandado de segurança contra ato judicial. De um lado, porque seria evidente que semelhante decisão não pode ser tomada como irrecorrível. De outro, porque também não teria cabimento supor que a questão só devesse ser enfrentada pelo tribunal por ocasião da apelação da sentença final (art. 1.009, § 1.º, do CPC) quando o processo em 1.º grau já está terminado. Exige-se, portanto, que o ato seja impugnável de imediato.

Ora, não há nenhum sentido em se admitir que a decisão judicial, proferida no curso do processo, que exclua litisconsorte é agravável (art. 1.015, VII, do CPC), mas não o seria a decisão de indeferimento parcial da petição inicial pelo mesmo motivo. O mesmo deve passar-se com as outras causas de indeferimento parcial da inicial.

Por isso, esse ato deve comportar agravo de instrumento, em que pese a ausência de previsão expressa no texto legal.

Também nesse caso, por aplicação seja do regime tradicional do agravo, seja do art. 331, § 1.º, do CPC, deve o réu ser citado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo antes da análise pelo tribunal.

### **4. Deferimento da petição inicial e recurso**

A admissão da petição inicial não enseja recurso, haja vista a falta de previsão legal e a inexistência de interesse recursal. É assim porque a análise das causas descritas no art. 330 do Código constitui objeções processuais, que podem ser reapreciadas a qualquer momento, não gerando preclusão para o juiz.

Assim, por exemplo, reconhecida a legitimidade das partes e, em consequência, admitida a petição inicial, nada impede que o juiz venha, posteriormente, de ofício ou mediante provocação do réu, a reconsiderar esse entendimento. O mesmo sucede com as outras causas enumeradas pelo Código para o indeferimento da inicial. Assim, ainda que, em um primeiro momento, afirme o juiz a presença de todos esses elementos, nada obsta a que o juiz conclua diversamente no curso do processo. Certamente, a parte ré não fica proibida de discutir esses temas – que não pode até então invocar – seja perante o juízo de 1.º grau, seja em grau de recurso, na forma da lei de regência.

Daí a inexistência de interesse recursal para o agravo desde logo da decisão que admite a petição inicial. Só depois de arguida a matéria pelo réu e rejeitada pelo juízo é que se formará esse requisito, o que abrirá as portas para o recurso.

## 5. Retratação e recurso do réu

Raciocínio idêntico àquele acima desenvolvido merece ser aplicado caso o juiz, tendo indeferido a inicial, haja reconsiderado esse entendimento diante da apelação do autor.

Nesse caso, como se vê do art. 331, § 1.º, do CPC, a apelação fica prejudicada. O processo, então, seguirá com a citação do réu para a audiência de autocomposição ou para a contestação. Não haverá, por isso, citação para o recurso, que desaparecerá.

O réu, então, citado, poderá arguir o defeito – inicialmente encontrado pelo juiz, mas depois objeto da reconsideração – para o próprio magistrado ou, desacolhida a alegação, por meio de recurso oportuno.

## 6. Prazo do réu para contestação

Afirma o art. 331, § 2.º, do CPC, que, diante da apelação do autor, se o tribunal entender por reformar a decisão de indeferimento da inicial, os autos serão restituídos à origem, passando a correr o prazo para a contestação.

A redação ruim do preceito não é capaz de dar conta da complexidade da situação em exame e, por isso, merece reflexão mais pausada.

Recorde-se que, na sistemática atual, o réu, em regra, não é citado para contestar. Segundo o art. 334 do CPC, admitida a petição inicial, o juiz deve designar audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de trinta dias, devendo-se citar o réu com pelo menos vinte dias de antecedência. Essa audiência só não será designada se houver manifestação de ambas as partes no sentido de seu desinteresse ou se o interesse não admitir autocomposição (art. 334, § 4.º, do CPC).

Trazendo esse procedimento para a situação aqui versada, tem-se o seguinte cenário: provido o recurso pelo tribunal, ter-se-á por admitida a petição inicial.<sup>225</sup> Em consequência, os autos devem ser restituídos ao 1.º grau, para processamento da demanda. Ali, deverá o juiz intimar as partes do retorno dos autos. Não há nova citação do réu, mas é sem dúvida indispensável sua intimação de que os autos foram restituídos. Porém, não é verdade, ao contrário do que afirma o art. 331, § 2.º, do CPC, que o prazo para contestação do réu tenha início a partir dessa intimação.

Na verdade, há que se considerar o disposto no art. 331, § 2.º, do CPC, à luz do procedimento a ser observado. Tratando-se de procedimento especial, é evidente que seus ditames específicos devem ser aplicados. Quando se tratar, porém, de procedimento comum, como já dito, a regra é que o processo passe, inicialmente, por uma fase de autocomposição. Assim, retornando os autos ao 1.º grau, em regra, deverá o juiz designar audiência de conciliação ou mediação, com antecedência mínima de trinta dias, intimando-se (e não citando, como dito) ambas as partes, pelo menos vinte dias antes da data apazada. Somente depois de ocorrida a audiência, diante de seu insucesso, é que fluirá o prazo de defesa do réu (art. 335, I, do CPC).

Caso não seja cabível a audiência de conciliação ou mediação (art. 334, § 4.º, II, do CPC), aí, sim, deverá o juiz intimar as partes do retorno dos autos e o réu, especificamente, para que possa apresentar contestação, sob pena de revelia. Restituídos os autos, o juiz decidirá pelo não cabimento da audiência e dará ciência dessa decisão às partes, nos termos mencionados. Da juntada aos autos do instrumento de intimação (quando pessoal) ou, enfim, nos termos do art. 231 do CPC, começará a fluir o prazo para a defesa do réu.

No caso em que seja dispensável a audiência de conciliação ou mediação, uma situação particular, porém, ainda merece atenção. É a hipótese em que ambas as partes, intimadas do retorno dos autos ao 1.º grau, optam por dispensar a fase conciliatória (art. 334, § 4.º, I, do CPC). Isso pode ocorrer quando o réu adere à manifestação do autor, apresentada na petição inicial, no sentido de não lhe ser interessante a fase conciliatória, ou quando ambas as partes apresentam documento conjunto comunicando essa intenção. Intimadas do retorno dos autos, as partes podem manifestar seu desinteresse na autocomposição, de forma expressa nos autos. Aí, nos termos do



que prevê o art. 335, II, do Código, do protocolo desse requerimento começa a correr o prazo de quinze dias para a defesa do réu. Caso ocorra a outra hipótese – o réu adere à manifestação do autor, que havia sido feita na petição inicial (art. 319, VII, do CPC) –, o prazo para a contestação começa a correr do protocolo nos autos da manifestação do réu (art. 334, § 5.º, parte final, c/c art. 335, II, do CPC).

Em todos os casos, como é evidente, a intimação do réu deve vir acompanhada da advertência de que sua omissão importa em revelia, sob pena de não serem aplicáveis as sanções correspondentes.<sup>226</sup>

## **7. Ciência para o réu do trânsito em julgado**

Havendo o indeferimento da petição inicial, pode suceder de a parte autora resignar-se com esse julgamento. Nesse caso, a sentença transitará em julgado, implicando a extinção do processo.

A situação, porém, levará a um processo do qual o réu não participou e a respeito do qual, provavelmente, sequer tem ciência. Em princípio, o réu não terá nenhum prejuízo dessa conclusão, motivo pelo qual, na vigência do Código anterior, não se cogitava da sua intimação a respeito do indeferimento da inicial. Remotamente, porém, pode ser útil a ciência ao réu, seja para que possa ao menos saber da existência da ação deduzida, seja até mesmo para alegar eventual defesa caso a ação seja reproduzida.

Por isso, prevê o Código que, se não for interposta a apelação, deve o réu ser intimado do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3.º, do CPC).

Sua intimação não tem, propriamente, função no processo, prestando-se apenas a dar-lhe ciência do ocorrido. Ainda assim, querendo, poderá extrair cópias do processo ou requerer certidões, se entender conveniente.

---

## **NOTAS DE RODAPÉ**

---

1

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários ao código de processo civil, 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, vol. III, p. 154.

2

Daniel Mitidiero, Colaboração no processo civil, ob. cit., p. 85.

3

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 156.

4

Sobre o assunto, José Rogério Cruz e Tucci. A causa petendi no processo civil, passim; José Rogério Cruz e Tucci e José Roberto dos Santos Bedaque (coords.), Causa de pedir e pedido no processo civil, passim; Ricardo de Barros Leonel. Causa de pedir e pedido: direito superveniente, passim; Daniela Monteiro Gabbay, Pedido e causa de pedir, passim; Fabio Peixinho. O objeto litigioso no processo civil, passim; Augusto Tanger Jardim, A causa de pedir no direito processual civil, passim. Na doutrina estrangeira,

Cerino Canova. La domanda giudiziale ed il suo contenuto, Commentario del Codice di Procedura Civile, passim; Karl Heinz Schwab, Der Streitgegenstand im Zivilprozeß, passim.

---

5

Remo Caponi, Andrea Proto Pisani, Lineamenti di diritto processuale civile. Napoli: Jovene, 2001, p. 73.

---

6

Michele Taruffo, La prova dei fatti giuridici, p. 67 e ss.

---

7

Sobre o assunto, Júlio Lanes. Fato e direito no processo civil cooperativo, p. 144 e ss. Amplamente, ainda, Joachim Hruschka, Die Konstitution des Rechtsfalles, Studien zum Verhältnis von Tatsachenfeststellung und Rechtsanwendung, passim.

---

8

Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, vol. 1. p. 7.

---

9

Idem, ibidem, p. 8.

---

10

Egas Dirceu Moniz de Aragão, Exegese do código de processo civil, ob. cit., p. 92.

---

11

Segundo Manuel de Andrade (Noções elementares de processo civil, 1979, p. 131), são impeditivos os fatos suscetíveis de obstar a que o direito do autor se tenha validamente constituído (v.g. incapacidade, simulação, erro, dolo etc.), e, ainda, ao menos parcialmente, os que, operando ab initio, apenas retardem o surgir desse direito ou sua exercibilidade; são modificativos os que podem ter alterado o direito do autor tal como ele validamente se constituiu (v.g. a mudança de local de uma servidão); são extintivos os que tenham produzido a cessação do direito do autor, depois de este já validamente formado (v.g. condição resolutiva, termo peremptório, pagamento, prescrição etc.).

---

12

De acordo com Proto Pisani, o legislador italiano ajuda o intérprete através do emprego de duas técnicas: (i) indicando claramente, sobre o plano lexical, o sujeito que deve provar um determinado fato; (ii) fazendo recurso à técnica das presunções legais relativas (Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 487489).

---

13

José Carlos Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, 20. ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 16.

---

14

Idem, p. 16-17.

---

15

José Rogério Cruz e Tucci, A causa petendi..., p. 112 e ss.

---

16

Assim, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. 2. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius” (STJ, REsp 1537996/DF, 3.a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 28.06.2016).

---

17

Como aponta Pontes de Miranda, “tanto ao juiz quanto à parte é permitido referir-se a outro texto de lei, a categoria ou figura jurídica diferente daquela a que a petição inicial se referia. Duas consequências desse princípio da fungibilidade da *forma* do fundamento: a) pode ser condenado o réu mesmo se não é exato, em boa técnica e adequada terminologia, o nome que se deu à situação jurídica ou a ela; b) mudando-se o nome da relação de direito material, ou o texto de lei, não se evita, somente por isso, a exceção de coisa julgada” (*Comentários ao código de processo civil*. 3.ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, tomo IV, p. 14).

---

18

Sobre o assunto, Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado das ações, tomo I, p. 117; Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, vol I, p. 407; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Teoria e prática da tutela jurisdicional, p. 137-142. Para uma visão crítica, Marcelo Lima Guerra, Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil, p. 44 e ss.

---

19

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., p. 163. Mantendo a crítica, no código de 2015, v. José Manoel Arruda Alvim, Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 153.

---

20

Cândido Rangel Dinamarco. Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, tomo I, p. 450 e ss.

---

21

De modo semelhante ao que aqui se defende, afirmou o Superior Tribunal de Justiça que “indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes” (STJ, REsp 1.262.132/SP, 4.a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.02.2015).

---

22

Cf. José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários...*, p. 166.

---

23

STJ, CE. SEC 7.204/EX. Rel. Min. Benedito Gonçalves. *DJe* 21.02.17.

---

24

Cf. José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários ...*, ob. cit., p. 166. Diz o autor que, “nestas hipóteses, é o próprio fato título da demanda que está em jogo, porquanto sua prova se vincula, de modo essencial, ao documento que o manifesta”.

---

25

Idem, *ibidem*.

---

26

José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários...*, ob. cit., p. 167.

---

27

Idem, *ibidem*.

---

28

Nesse sentido, STJ, 2ª Turma. AgInt no AREsp 953.514/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. *DJe* 23.06.17).

---

29

Interessante, nessa linha, é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, tomada no REsp 1.279.586/PR. Ainda que a argumentação tenha tomado em conta, principalmente, a relevância para a própria administração da Justiça na preservação de ação civil pública, afirmou o julgador que “O princípio da efetividade está intimamente ligado ao valor social e deve ser utilizado pelo juiz da causa para abrandar os rigores da inteligência vinculada exclusivamente ao Código de Processo Civil – desconsiderando as especificidades do microsistema regente das ações civis –, dado seu escopo de servir à solução de litígios de caráter individual. Deveras, a ação civil constitui instrumento de eliminação da litigiosidade de massa, capaz de

dissipar infintos processos individuais, evitando, ademais, a existência de diversidade de entendimentos sobre o mesmo caso, possuindo, ademais, expressivo papel no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, diante de sua vocação inata de proteger um número elevado de pessoas mediante um único processo. A orientação que recomenda o suprimimento de eventual irregularidade na instrução da exordial por meio de diligência consistente em sua emenda, prestigia a função instrumental do processo, segundo a qual a forma deve servir ao processo e a consecução de seu fim. A técnica processual deve ser observada não como um fim em si mesmo, mas para possibilitar que os objetivos, em função dos quais ela se justifica, sejam alcançados” (STJ, 4ª Turma. REsp 1.279.586/PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. *DJe* 17.11.17).

---

30

Wellington Moreira Pimentel, Comentários ao código de processo civil, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1979, vol. III, p. 166.

---

31

“Para facilitar o entendimento, portanto, poderemos dizer que o defeito se prende ao modo de enunciar; e a irregularidade ao modo de dispor. Enunciar e dispor, tanto os fundamentos de fato e de direito do pedido, quanto o próprio pedido, ou algum requisito da inicial que a eles se vincule de tal modo que possa refletir, quando deficiente, sobre o julgamento do mérito, dificultando-o” (José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 237).

---

32

Joel Dias Figueira Jr, Comentários ao código de processo civil, São Paulo: Ed. RT, 2001, vol. 4, tomo II, p. 73.

---

33

Por todos, v. José Joaquim Calmon de Passos, ob. cit., p. 237.

---

34

Assim, tb. Susana Henriques da Costa, Comentários ao novo código de processo civil. Coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 510.

---

36

Enrico Tullio Liebman, “Fondamento del principio dispositivo” in Problemi del processo civile. Napoli: Morano, p. 3. V. a respeito desse fundamento do princípio da demanda, Mauro Cappelletti, El testimonio de la parte em el sistema de la oralidad. Primeira parte. Trad. Tomás A. Banzhaf. La Plata: Librería Editora Platense, 2002, p. 300 e ss.

---

37

Nesse sentido, Giuseppe Chiovenda, “L’azione nel sistema dei diritti” in Saggi di diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, vol. I. p. 5-6; Luigi Paolo Comoglio. Corrado Ferri, Michele Taruffo, Lezioni sul processo civile, 2. ed., Bologna: il Mulino, 1998, p. 236; Piero Calamandrei, “Líneas fundamentales del

proceso civil inquisitorio”. Estudios sobre el proceso civil. Trad. Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires: Editorial Bibliografico Argentina, 1945, p. 229-231; António Santos Abrantes Geraldès, Temas da reforma do processo civil. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998, vol. I, p. 50.

---

38

Giuseppe Chiovenda, “Identificazione delle azione. Sulla regola ‘ne eat iudex ultra petita partium’” in Saggi di diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, vol. I., p. 157-158.

---

39

Nesse sentido, v. entre outros, Luigi Paolo Comoglio, “Note riepilogative su azione e forme di tutela, nell’ottica della domanda giudiziale”. Scritti in onore di Elio Fazzalari. Milano: Giuffrè, 1993, vol. II. p. 79; Piero Calamandrei, Instituciones de derecho procesal civil. Trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: El Foro, 1996, vol. I, p. 233; Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri, Michele Taruffo, Ob. cit. p. 236; Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 3. ed., Napoli: Jovene, 1999, p. 204-205; Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, Sampaio e Nora, e. manual de processo civil. 2. ed., Coimbra: Coimbra, 1985, p. 243; José Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 1971, p. 97-98.

---

40

Vittorio Scialoja, Procedimiento civil romano. Trad. Santiago Sentís Melendo e Marino Ayerra Redin, Buenos Aires: EJEa, 1954, p. 254.

---

41

“El juez, cuando se le plantee una condemnatio de cantidad cierta de dinero, debe prestar mucha atención a no condenar ni a más ni a menos de dicha suma, ya que en otro caso responde por prevaricación al incurrir en parcialidad. Asimismo, si hay establecido un límite, no puede excederlo al condenar, pues, en otro caso, incurre en lo mismo. Pero si también... que admitió la fórmula, y no a más... queda obligado por la condena cierta...hasta lo que quiera” (Gaio, Instituciones. Trad. Manuel Abellan Velasco et alli. Madrid: Civitas, 1985, p. 333).

---

42

Como observa Scialoja, “... el juez, aun teniendo la máxima libertad para formarse, sobre la base de los hechos y de las pruebas deducidos em juicio, su próprio convencimiento sobre la existencia del derecho que se quiere hacer valer, no por ello está menos estrechamente sometido a los límites qu ele señala la fórmula; tanto, que si ésta está viciosamente concebida, de manera que no corresponda exactamente a la acción que quiere ejercitar el actor, el juez está obligado a absolver al demandado; por más que, si fuera libre para juzgar saliéndose de los límites señalados por la fórmula, pudiera muy bien estar dispuesto a condenarlo” (Vittorio Scialoja, ob. cit., p. 261).

---

43

Gai, IV, 53.



---

44

Cf. Vittorio Scialoja, ob. cit., p. 261.

---

45

Vittorio Scialoja, ob. cit. p. 268, esp. nota \* 13.

---

46

Cf. Oskar von Bulow, Teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, Trad. Miguel Angel Rosas Lichtschein, Buenos Aires: EJE, 1964, p. 83.

---

47

Cf. Oskar von Bulow, ob. cit., p. 84-85.

---

48

“A fórmula – que altera a característica eminentemente oral do sistema anterior – correspondia ao esquema abstrato contido no edito do pretor, e que servia de paradigma para que, num caso concreto, feitas as adequações necessárias, fosse redigido um documento (iudicium) – pelo magistrado com o auxílio das partes –, no qual se fixava o objeto da demanda que devia ser julgado pelo iudex popular” (José Roberto Cruz e Tucci, Luiz Carlos de Azevedo, Lições de história do processo civil romano, 2. tiragem, São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 47).

---

49

Chiovenda, aliás, reconhece a ausência de relação direta entre o princípio em questão e os textos romanos usados para justificar sua adoção, embora conclua que também no direito romano o princípio tivesse aplicação (Giuseppe Chiovenda, “Identificazione delle azioni. Sulla regola ‘ne eat iudex ultra petita partium’”, ob. cit., p. 157).

---

50

V.g. Walther J. Habscheid. Droit judiciaire privé suisse, Genève: Librairie de l’Université Georg, 1981, p. 346-350.

---

51

Cf. James Goldschmidt, Derecho procesal civil, Trad. Leonardo Prieto Castro, Barcelona: Labor, 1936, p. 82 e ss. Friedrich Stein, embora advirta para a diferença entre o princípio da Dispositionsmaxime e a Verhandlungsmaxime, não chega a aplicá-la concretamente, preferindo tratar ambas as idéias sob a noção do princípio da contradição (Friedrich Stein, El conocimiento privado del juez, 2. ed., Bogotá: Temis, 1999, p. 106-107). Friedrich Lent e, posteriormente, Othmar Jauernig, todavia, buscam fazer a diferença entre o princípio dispositivo e o princípio da instrução por iniciativa das partes (v. a respeito, Friedrich Lent,

Diritto processuale civile tedesco, 1.<sup>a</sup> parte, Trad. Edoardo Ricci, Napoli: Morano, 1962, p. 87 e ss.; Othmar Jauernig, Direito processual civil, 25. ed., trad. F. Silveira Ramos, Coimbra: Almedina, 2002, p. 131 e ss.).

---

52

Não fazendo a distinção aqui proposta, v. tb. entre outros, Hernando Devis Echandía. Teoria general del proceso, 2. ed., Buenos Aires: Editorial Universidad, 1997, p. 60 e ss.; Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, Sampaio e Nora, ob. cit., p. 243; José Frederico Marques, ob. cit., p. 97 e ss.

---

53

Egas Dirceu Moniz de Aragão, La prova civile, 2. ed., Roma: Ateneo, 1947, p. 16-17, nota 2.

---

54

Nesse sentido, v. entre outros, Enrico Tullio Liebman, ob. cit. p. 4-6; Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, 5. ed., 2. tiragem, São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 63; Celso Agrícola Barbi, Comentários ao código de processo civil, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 15. Mauro Cappelletti, embora faça a distinção, não se utiliza dos predicados demanda e dispositivo, tratando ambas as situações como expressões distintas do princípio dispositivo, estando o princípio da demanda vinculado à idéia de substanciação, válida para o processo civil atual (cf. El testimonio... Primeira parte, ob. cit., p. 291 e ss.).

---

55

Atualmente, como se sabe, há tendência em rearranjar os papéis desempenhados pelos sujeitos do processo. Fala-se aí em princípio cooperativo, como uma tentativa de superar o dualismo mencionado no texto. Sobre isso, v., Mirjan Damaska. The faces of justice and state authority, New Haven: Yale University Press, 1986, passim; Daniel Mitidiero, Colaboração no processo civil, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, passim.

---

56

Nesse sentido, v. Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, Trad. José Casais y Santaló, Madrid: Réus, 1925, vol. II, p 181.

---

57

“Perciò, mentre riportano il principio della domanda al potere esclusivo del titolare di disporre della tutela giurisdizionale del diritto soggettivo, intendendolo quindi come un riflesso necessario di strutture tipiche fondamentali dell’ordinamento giuridico, così come è oggi costituito, considerano invece il principio dispositivo come un principio esclusivamente tecnico del processo, cioè come una di quelle regole che le parti devono osservare per adeguarsi alle esigenze proprie del meccanismo che esse medesime hanno posto in movimento” (Enrico Tullio Liebman, ob. cit., p. 6).

---

58

Nicolò Trocker, Processo civile e costituzione, Milano: Giuffrè, 1974, p. 375-376.

---

59

“...ma è invece prevalentemente determinato da un intento pratico di sfruttamento della iniziativa delle parti per una più rapida e più sicura posizione del fatto conforme alla realtà medesima: il contrasto degli interessi, che determina e vivifica il processo, consente di ritenere che il fatto taciuto da tutte le parti non possa essere e che il fatto affermato da tutte le parti non possa non essere reale, mentre la possibilità che questa previsione sia fallace in qualche raro caso non sminuisce sensibilmente il rilevato vantaggio di sicurezza e di economia” (Egas Dirceu Moniz de Aragão, *La prova civile*, ob. cit., p. 17-18).

---

60

Segundo Echandía, o princípio da correlação deve abarcar tanto as pretensões, como as exceções que complementam o exercício do direito (Hernando Devis Echandía, ob. cit., p. 435).

---

61

Idem, ibidem, p. 434-435.

---

62

Idem, p. 435.

---

63

Cf. Eduardo J. Couture, *Fundamentos del derecho procesal civil*, 3. ed., Buenos Aires: Depalma, 1958, p. 186.

---

64

Barbosa Moreira, aliás, respaldado na doutrina de José Frederico Marques, Moacyr Amaral Santos e Wellington Moreira Pimentel, considera inexistente a sentença na parte em que deixa de examinar parte do pedido, autorizando mesmo a repropositura da demanda, quanto à parcela não julgada (José Carlos Barbosa Moreira, “Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo”. *Temas de direito processual*, 2.a Série, 2.a ed., São Paulo: Saraiva, 1988, p. 246-249). No mesmo sentido, v. Teresa Arruda Alvim Wambier, *Nulidades do processo e da sentença*, São Paulo: Ed. RT, 1998, p. 32.

---

65

Francisco de Paula Baptista, *Teoria e prática do processo civil e comercial*, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 130.

---

66

Como diz Devis Echandía, ressalvadas hipóteses expressamente previstas em lei, “el sentido y alcance de la congruencia en relación con la pretensión puede resumirse en dos principios: a) el juzgador debe resolver sobre todo lo pedido en la demanda, sin conceder cosa distinta ni más de lo pedido; b) la resolución debe basarse en los hechos sustanciales aducidos en la demanda y en los circunstanciales o

accesorios simplemente probados” (Hernando Devis Echandía, ob. cit., p. 438). No mesmo sentido, v. José Carlos Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, 22. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 16-17; Bruno Cavallone, Il giudice e la prova nel processo civile, Padova: CEDAM, 1991, esp. p. 107 e ss.

---

67

Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, Trad. J. Guimarães Menegale, São Paulo: Saraiva, 1943, vol. II, p. 461-462.

---

68

“la necessità della affermazione unilaterale e la sufficienza della affermazione bilaterale perchè un fatto venga posto nella sentenza è, per quanto riguarda il fatto principale, veramente un riflesso del principio ne procedat iudex ex officio e ne eat iudex ultra petita partium” (F. Carnelutti, La prova civile, 2.a ed., Roma: Ateneo, 1947, p 19-20).

---

69

Assim, entre outros, v. José Carlos Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, ob. cit., p. 10; Idem. “O que deve e o que não deve figurar na sentença”. Temas de direito processual, 8.ª série, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 120; Michele Taruffo, “La motivazione della sentenza”. Revista de Direito Processual Civil, v. 31, p. 680 e ss.; Idem. La prueba de los hechos, 2. ed., Madrid: Trotta, 2005, p. 105; Juan Igartua Salaverría. La motivación de las sentencias, imperativo constitucional, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 158.

---

70

Por exceções, toma-se aqui o termo em seu sentido próprio, ou seja, as defesas que exigem invocação pela parte, não podendo ser supridas pelo juiz.

---

71

“O que se afirma com respeito à demanda do autor cabe afirmar com relação à demanda do réu, quando for condição a provimento do juiz. Não pode, pois, o juiz argüir de ofício o que é um direito exclusivo do réu argüir (exceção). Enfim, se o autor desistisse da demanda, não poderia o juiz manifestar-se sobre ela sem que o réu instasse por uma decisão” (Giuseppe Chiovenda, Instituições..., vol. II, ob. cit., p. 461).

---

72

Por um aprofundamento do tema, v. Guillermo Ormazabal, Iura novit curia, Madrid: Marcial Pons, 2007, passim; Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, Iura novit curia y aplicación judicial del derecho, Valladolid: Lex Nova, 2000, passim. No direito brasileiro, por uma visão crítica dessa ideia, v. Otávio Augusto Domit, Iura novit curia e causa de pedir, São Paulo: Ed. RT, 2016, passim.

---

73

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Comentários ao código de processo civil, Rio de Janeiro: Forense,

74

Idem, ibidem, p. 15. Apreciando outras hipóteses de exceção ao princípio *iura novit cúria*, especialmente no caso de concurso de direitos, v. Andrea Proto Pisani, Ob. cit. p. 77-79 e 209. Embora se reconheça que a tendência majoritária é admitir a inviabilidade da alteração da interpretação dos fatos nesses casos, parece absolutamente anacrônica essa orientação. Veja-se que, segundo essa lógica, se a parte, descrevendo hipótese de coação irresistível supõe que ela seja “resistível”, formulará pedido desconstitutivo (já que viciada a manifestação da vontade). Todavia, o juiz, examinando melhor a questão e concluindo que se trata de coação irresistível, concluirá que houve exclusão da vontade e que, portanto, o ato era inexistente, o que exigiria um pedido “declaratório” de inexistência. Por conta disso, segundo esse pensamento, deveria julgar improcedente a demanda, porque não se trataria de desconstituir o que não existe! Ora, é evidente o formalismo exagerado que permeia essa orientação. Não há dúvida de que a parte autora mereceria a proteção judicial e que, por simples filigrana jurídica, terá sua pretensão rejeitada, devendo ajuizar outra ação. É preciso revisitar essa questão, porque não se pode tolerar que no estágio atual do direito processual a doutrina continue sustentando conclusões como essas.

---

75

“Dal momento che ad ogni pronuncia giudiziale avente contenuto decisorio conseguono potenzialmente effetti per la sfera personale o patrimoniale di un soggetto, il destinatario deve avere la possibilità di influire e di incidere sulla formazione del relativo provvedimento. È il rispetto stesso della personalità umana e della sua dignità come valore fondamentale di un ordinamento giuridico che impone di assicurare al soggetto interessato l'esercizio di poteri di azione, contraddizione e difesa” (Nicolò Trocker, ob. cit., p. 378).

---

76

“Il problema dei rapporti tra attribuzioni del giudice e poteri delle parti, mentre porta a risultati radicalmente diversi a secondo che lo si esamini nella prospettiva dell'uno o dell'altro dei principi processuali sudetti, ammette tendenzialmente una sola soluzione alla luce del precetto costituzionale: in ogni specie di giudizio la decisione deve scaturire da un 'dialogo', o se si preferisce da una 'collaborazione' fra i rispettivi protagonisti” (Nicolò Trocker, ob. cit., p. 389).

---

77

V. a respeito, José Roberto Cruz e Tucci, Luiz Carlos de Azevedo, Lições de processo civil canônico, São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 116.

---

78

Cf. Walther J. Habscheid, ob. cit., p. 348.

---

79

Sobre o tema, v. Friedrich Lent, ob. cit., p. 96-97. Friedrich Stein, ob. cit., p. 108.

---

80

Andrea Proto Pisani, ob. cit. p. 205-206.

---

81

Idem, p. 206.

---

82

Ob. cit., p. 53 e ss.

---

83

Hernando Devis Echandía, ob. cit., p. 62. Diz o mesmo autor, ainda, que na Colômbia há três formas de processo que podem ser iniciados de ofício: o de privação de pátrio poder, o de remoção de curador e o de interdição de “demente furioso o que cause notable incomodidad a los habitantes del lugar” (ob. cit., p. 63).

---

84

Terebilov, V. Poutchinski, V. K. Tadevosián, V. Princípios de processo civil da U.R.S.S. e das repúblicas federadas, Coimbra: Centelha, 1978, p. 69. De fato, sabe-se que a legislação prussiana de Frederico, o Grande (do século XVII) é exemplo clássico de exceção ao princípio da demanda, mas por seu período curto de vigência (40 anos), não merece maior atenção (cf. José Frederico Marques, ob. cit., p. 100).

---

85

Como era o caso da possibilidade de o magistrado, de ofício, iniciar o processo penal referente às contravenções penais, que se entende hoje incompatível com a Constituição Federal (CPP, art. 26).

---

86

Que, ao lado de importar o exame de questões tipicamente processuais (como o regime das custas e honorários de sucumbência), pode também autorizar a concessão de efeitos não expressamente pedidos pela parte – como é o caso do efeito de restituição da coisa alienada, diante do pedido de declaração de nulidade do contrato de compra-e-venda. O tema será examinado mais adiante, nos comentários ao art. 322.

---

87

Cf. Celso Agrícola Barbi, ob. cit., p. 15; Ovídio Baptista da Silva, ob. cit., p. 65.

---

88

Cf. Celso Agrícola Barbi, ob. cit., p. 16.

---



---

89

Cf. José Manoel Arruda Alvim, ob. cit., p. 281.

---

90

Código Civil, art. 1.637. “Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.”

---

91

STJ, 1ª Turma. AgInt no REsp 1.412.645/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. *DJe* 31.10.17; STJ, 1ª Turma. REsp 1.320.820/MS. Rel. Min. Regina Helena Costa. *DJe* 17.05.16; STJ, 2ª Turma. REsp 1.568.353/SP. Rel. Min. Herman Benjamin. *DJe* 05.02.16.

---

92

V. entre outros, José Carlos Barbosa Moreira, “Reformas processuais e poderes do juiz”. Temas de direito processual, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 62-63; Sérgio Cruz Arenhart, Perfis da tutela inibitória coletiva, São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 337 e ss.; Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 80-90. Idem. Técnica processual e tutela dos direitos, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 134-137.

---

93

Poderá, ainda, o requerente formular o pedido de perdas e danos, quando não lhe pareça mais interessante a tutela específica (art. 499 do CPC, e 84, § 1.º do CDC).

---

94

Eventualmente, como decorre do preceito colocado no art. 499, do Código de Processo Civil (bem assim do § 1.º, do art. 84, do Código de Defesa do Consumidor), pode até o magistrado fugir completamente do pedido formulado pela parte, ao conceder-lhe indenização, ao invés da prestação do fato desejada – se for impossível a tutela específica –, demonstrando ainda de forma mais clara a desvinculação da regra ao princípio da demanda.

---

95

A questão foi tratada, anteriormente, em Sérgio Cruz Arenhart. Perfis da tutela inibitória coletiva (ob. cit., p. 337 e ss.), reproduzindo-se aqui as conclusões antes expostas.

---

96

De fato, como salienta Barbosa Moreira, “o direito processual civil brasileiro move-se no sentido da

atribuição de maior soma de poderes ao juiz, quer no plano da ‘direção formal’, quer (embora com menor intensidade) no da ‘direção material’ do processo” (José Carlos Barbosa Moreira, “Os novos rumos do processo civil brasileiro”, *Temas de direito processual civil*, 6.ª série, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 71).

---

97

Hernando Devis Echandía, *ob. cit.* p. 61. Assim, também, entre tantos outros, v. Hervé Croze. Cristian Morel, *Procédure civile*, Paris: PUF, 1988, p. 167; José Carlos Barbosa Moreira, “O processo, as partes e a sociedade”, *Temas de direito processual*, 8.ª série, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 29 e ss.; Idem. “As bases do direito processual civil”, *Temas de direito processual*, 1.ª série, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1988, p. 11.

---

98

Piero Calamandrei, *Instituciones...*, vol. I, p. 231-232. Conclui, todavia, Calamandrei pela prevalência do princípio da demanda no direito italiano, no intuito de garantir a imparcialidade do juiz.

---

99

Piero Calamandrei, “Lineas fundamentales...”, p. 228 e, posteriormente, 232-233. V. tb. José Carlos Barbosa Moreira, “Processo civil e processo penal: mão e contramão?”. *Temas de direito processual*, 7.ª série, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 211-212.

---

100

Confira-se, novamente, o que bem ponderou Calamandrei a respeito do assunto (“Líneas fundamentales”, p. 232-233 e depois 235-237).

---

101

“Restringerne il dominio, per accrescere invece i poteri inquisitori del giudice, significherebbe in sostanza attenuare la distinzione tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa ed introdurre nel processo una tendenza paternalistica che non merita alcun incoraggiamento” (Enrico Tullio Liebman, *ob. cit.*, p. 16).

---

102

Como lembra Barbosa Moreira, “resta lutar para que a bela promessa constitucional transborde do papel e se converta em realidade. A Defensoria Pública – onde militam inúmeros servidores zelosos e competentes – não está aparelhada é óbvio para desincumbir-se de modo satisfatório das relevantíssimas atribuições que recebeu; e não em último lugar, ironicamente, por causa da escassa disposição de proporcionar-lhe condições razoáveis de trabalho, exibida por governos que entretanto apregoam fazer do social sua máxima prioridade” (José Carlos Barbosa Moreira, “A desinformação jurídica”, *Temas de direito processual*, 6.ª série, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 299). V. tb. José Carlos Barbosa Moreira, “Por um processo socialmente efetivo”. *Temas de direito processual*, 8.ª série, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 21-22. Por um exame geral da assistência jurídica e judiciária, v. Mauro Cappelletti, James Gordley. Earl Johnson Jr., *Toward equal justice: a comparative study of legal aid in modern societies*, Milano: Giuffrè, 1981, *passim*.

104

V. entre outros, Giuseppe Tarzia. “Parità delle armi tra le parti e poteri del giudice nel processo civile”. *Problemi del processo civile di cognizione*, Padova: CEDAM, 1989, p. 312-313.

---

105

Joan Pico i Junoy, *La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la recusación*, Barcelona: Bosch, 1998, p. 80; Rui Portanova, *Motivações ideológicas da sentença*, 2. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994, p. 16; Nelson Nery Jr. “Imparcialidade e juiz natural”, *Estudos de direito processual civil – homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão*, São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 180; José Carlos Barbosa Moreira, “Reflexões sobre a imparcialidade do juiz”, *ob. cit.*, p. 29-30.

---

106

Nesse sentido, v. Nicolò Trocker, *ob. cit.*, *passim*; Giuseppe Tarzia, “Parità delle armi...”, *ob. cit.*, p. 316-319; Luigi Paolo Comoglio, *La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile*, Padova: CEDAM, 1970, p. 152.

---

107

Seria obviamente desnecessário demonstrar a existência concreta de gritante desigualdade social brasileira, que também determina inescandível (e de necessária consideração) desigualdade processual. Ainda assim, vale examinar, entre tantos outros, José Carlos Barbosa Moreira, “A desinformação jurídica”, *ob. cit.*, *passim*; Idem. “Por um processo socialmente efetivo”, *ob. cit.*, *passim*.

---

108

Propugnando o exercício deste papel político pelo juiz, v. entre outros, José Eduardo Faria, “As transformações do judiciário em face de suas responsabilidades sociais”. *Direitos humanos, direitos sociais e justiça*. Org. José Eduardo Faria. São Paulo: Malheiros, 1994, esp. p. 56-57.

---

109

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual...* *ob. cit.* p. 136. Ainda nesse sentido, consulte-se a clássica orientação de Ihering, que sustentava que a luta pelo direito era dever do titular para consigo mesmo e para com o Estado e a sociedade (Rudolf Von Ihering, “A luta pelo direito”, *Questões e estudos de direito*, Salvador: Progresso, 1955, p. 13-114).

---

110

Cf. Mauro Cappelletti, *El testimonio...*, *ob. cit.*, p. 312, nota 10. Conclui, então, Cappelletti que “se comprende bastante bien, pues, que al ‘principio de sustanciación’ han permanecido rígida y anacrónicamente aferradas sólo aquellas legislaciones caracterizadas por la insensibilidad al aspecto económico y social de la libertad” (*ob. loc. cit.*). Conclui, porém, o autor ao final que a atenuação do princípio em questão não deve autorizar o juiz a suprir a deficiência da parte quanto à extensão da demanda proposta (*idem ibidem*, p. 314-315).

---

111

Friedrich Lent, ob. cit., p. 97.

---

112

Othmar Jauernig. ob. cit., p. 142-143.

---

113

“Art. 384. Se o juiz reconhecer a possibilidade de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de circunstância elementar, não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou na queixa, baixará o processo, a fim de que a defesa no prazo de oito dias, fale e, se quiser, produza prova, podendo ser ouvidas até três testemunhas.

Parágrafo único. Se houver possibilidade de nova definição jurídica que importe aplicação de pena mais grave, o juiz baixará o processo, a fim de que o Ministério Público possa aditar a denúncia ou a queixa, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, abrindo-se, em seguida, o prazo de três dias à defesa que poderá oferecer prova, arrolando até três testemunhas”.

---

114

A respeito dessa modificação do ônus da prova, v. entre outros, Sérgio Cruz Arenhart, “Ônus da prova e relações de consumo”, Repensando o direito do consumidor – 15 anos do CDC. Org. Marcelo Conrado, Curitiba: Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, 2005, p. 91 e ss.; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Comentários ao código de processo civil, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 382-435.

---

115

Giuseppe Tarzia, “Le istruzioni del giudice alle parti nel processo civile”. Problemi del processo civile di cognizione. Padova: CEDAM, 1989, p. 321 e ss. Também Cappelletti chega a cogitar essa possibilidade de aconselhar a parte a suprir eventuais defeitos em seus atos postulatórios (Mauro Cappelletti, El testimonio... ob. cit., p. 320).

---

116

Giuseppe Tarzia, “Le istruzioni del giudice alle parti nel processo civile”, Problemi del processo civile di cognizione, p. 331 e 341-344.

---

117

Assim, por exemplo, a falta de prova das afirmações feitas, ou a ausência de defesa pelo réu, poderiam – e geram normalmente – gerar a vitória da parte contrária, mesmo que, formalmente, devessem gerar consequências distintas da renúncia ou do reconhecimento.

---

118

Por uma crítica semelhante, v. Alcides Alberto Munhoz da Cunha, Comentários ao código de processo civil, ob. cit., p. 55 e ss.

---

119

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça definiu, com a edição da Súmula 181, que “é admissível ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual”.

---

120

Por uma crítica a essa figura, v. Sérgio Cruz Arenhart, Sentença condenatória para quê?, passim.

---

121

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 38 e 222 e ss.

---

122

Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, p. 1316.

---

123

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 275.

---

124

Lodovico Barassi afirmou que a “tutela puramente preventiva”, “certamente la più energica”, seria também “la più preoccupante, come è di tutte le prevenzioni che possono eccessivamente limitare l’umana autonomia” (Lodovico Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, p. 428).

---

125

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela contra o ilícito, p. 252 e ss.

---

126

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 9, p. 17 e ss.

---

127

Salvatore Satta, L’esecuzione forzata nella tutela giurisdizionale dei diritti, Scritti in onore di Francesco Carnelutti, v. 2, p. 10.

---

128

Idem, ibidem.

---

129

V., sobre a questão no Código de 1939, Pedro Batista Martins. *Comentários ao código de processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1941, vol. II, p. 109.

---

130

Wellington Moreira Pimentel, *Comentários...*, ob. cit., p. 173; Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários...*, ob. cit., p. 35.

---

131

Recorde-se, no particular, que hoje há grande espaço para a fungibilidade de pedidos imediatos (tal como ocorre com os pedidos condenatório, mandamental e executivo, como se vê dos arts. 139, IV, 536, 537 e 638, do CPC). Recorde-se, também, que em doutrina há divergência sobre a qualificação de pedidos imediatos referentes a algumas espécies de pretensão. Assim, por exemplo, não obstante a ampla maioria da doutrina considere as ações de nulidade como declaratórias, Pontes de Miranda arrola vários exemplos de ação de nulidade constitutivas (v. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Tratado das ações*, Campinas: Bookseller, 1998, tomo II, p. 368).

---

132

“Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omissos o pedido inicial ou a sentença condenatória, consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada” (STJ, REsp 402.724/SP, 4.<sup>a</sup> Turma, rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 19.04.2010 ).

---

133

“I – Conforme dispõe o art. 293, CPC, os pedidos devem ser interpretados restritivamente, considerando-se incluídos independentemente de pedido, apenas os juros legais e não os contratuais. II – Pela sistemática do Código Civil de 1916, eram “juros legais” os moratórios (arts. 1.062 e 1.064) e os compensatórios por força de lei (art. 1.063, primeira parte).” (STJ, REsp 306.353/PR, 4.<sup>a</sup> Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 07.04.2003, p. 290). Não parece que esse entendimento encontre respaldo na legislação atual, na medida em que o art. 1.063, do CC/1916 não foi repetido pelo Código Civil atual. Ademais, o art. 406, regulando os juros legais, refere-se exclusiva e expressamente apenas aos juros moratórios.

---

134

“2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda: (a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano;

(b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também

se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte.” (STJ, REsp 1112746/DF, 1.ª Seção, rel. Min. Castro Meira, DJe 31.08.2009 – julgado pelo regime de recurso repetitivo).

---

135

V.g. AgRg no REsp 727.842/SP, 3.ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 14.12.2007, p. 398; REsp 830.189/PR, 1.ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, DJU 07.12.06, p. 275.

---

136

“Conforme decidiu a Corte Especial, ‘atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/1995, 84 da Lei 8.981/1995, 39, § 4.º, da Lei 9.250/1995, 61, § 3.º, da Lei 9.430/1996 e 30 da Lei 10.522/2002)’ (REsp 727.842, DJ de 20.11.2008)” (REsp 1.102.552/CE, 1.ª Seção, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 06.04.2009 – julgado pelo regime de recurso repetitivo).

---

137

De modo semelhante, v. o art. 404, do CC.

---

138

Assim, STJ, 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.576.291/PR. Rel. Min. Herman Benjamin. *DJe* 07.03.17.

---

139

Nesse sentido, v. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários...*, ob. cit., p. 83-84; Joel Dias Figueira Jr., *Comentários...*, ob. cit., p. 152. Concordando em parte com essa ideia, v. José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários...*, ob. cit., p. 210.

---

140

Nesse sentido aponta a Súmula 254, do STF (“incluem-se os juros legais na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”).

---

141

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, ob. cit., vol. 2, p. 164-165.

---



“Previdenciário. Recurso Especial. Aposentadoria por tempo de contribuição. Implementação da carência após o ajuizamento da ação. Fato Superveniente. Recurso Especial Provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos. 2. O art. 687 e 690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de 2015, que repete as já consagradas proteções ao segurado dispostas em Instruções Normativas anteriores, dispõe que, se o postulante de uma prestação previdenciária preenche os requisitos legais somente após o pedido, o ente autárquico reconhece esse fato superveniente para fins de concessão do benefício, fixando a DIB para o momento do adimplemento dos requisitos legais. 3. Essa mesma medida deve ser adotada no âmbito do processo judicial, nos termos do art. 462 do CPC, segundo o qual a constatação de fato superveniente que possa influir na solução do litígio deve ser considerada pelo Tribunal competente para o julgamento, sendo certo que a regra processual não se limita ao Juízo de primeiro grau, porquanto a tutela jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma como se apresenta no momento do julgamento. 4. As razões dessa proteção se devem ao fato de que os segurados não têm conhecimento do complexo normativo previdenciário, sendo certo que a contagem do tempo de serviço demanda cálculo de difícil compreensão até mesmo para os operadores da área. Além disso, não é razoável impor aos segurados, normalmente em idade avançada, que intentem novo pedido administrativo ou judicial, máxime quando o seu direito já foi adquirido e incorporado ao seu patrimônio jurídico. 5. Diante dessas disposições normativas e dos princípios da economia e da celeridade processual, bem como do caráter social das normas que regulamentam os benefícios previdenciários, não há óbice ao deferimento do benefício, mesmo que preenchidos os requisitos após o ajuizamento da ação. 6. Recurso Especial provido para julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria a partir de agosto de 2006.” (STJ, REsp 1296267/RS, 1.a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe11.12.2015). Assim tb. TNU, PEDILEF 00015903220104036308, rel. Juíza Federal Susana Sbrogio Galia, DOU 01.04.2016, p. 159-258.

---

Wellington Moreira Pimentel, Comentários..., ob. cit., p. 192.

---

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Comentários..., ob. cit., p. 63.

---

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 195; Wellington Moreira Pimentel, Comentários..., ob. cit., p. 193 e 194.

---

Isso, porém, não quer dizer que essa condenação assuma função preventiva. De fato, “é fundamental que não se confunda o pedido de condenação para o futuro com o pedido mandamental com função preventiva, isto é, com o pedido de tutela inibitória. O pedido de condenação para o futuro visa à obtenção de tutela ressarcitória e pressupõe a violação do direito da parte. De modo nenhum, portanto, pode se assemelhar ao pedido mandamental com função preventiva que tenha por objetivo, por exemplo, a concessão de tutela inibitória, cujo desiderato está justamente em evitar a ocorrência de um ilícito e, pois,

a violação do direito da parte (art. 497, parágrafo único, CPC).” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Novo código de processo civil comentado, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 415, comentário 3).

---

147

José Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1972, vol. III, p. 49.

---

148

“Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: I – não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido; II – a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença”.

---

149

Antes mesmo do código de 2015, Calmon de Passos já sustentava que a existência de pedido “genérico” não impunha, por si só, sentença também genérica. Dizia ele que “tudo recomenda que a indeterminação no tocante ao quantum debeatur seja eliminada no próprio procedimento da ação de cognição, salvo se for impossível assim proceder” (José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 173).

---

150

Contra, entendendo que as hipóteses descritas no código são *numerus clausus*, v. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Comentários..., ob. cit., p. 39.

---

151

AgRg no AREsp 527.202/SP, 3.<sup>a</sup> Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.09.2015; REsp 645.729/RJ, 4.<sup>a</sup> Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.02.2013; AgRg nos EDcl no AREsp 158.865/RJ, 3.<sup>a</sup> Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29.06.2012; REsp 926.628/MT, 1.<sup>a</sup> Turma, rel. Min. Denise Arruda, DJe 18.06.2009.

---

152

A propósito, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir a formulação de pedido de danos morais genérico, sem definição inicial do quantum debeatur. 2. Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta. 3. Assim, não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência, apenas elegendo uma dentre as interpretações possíveis.” (AgRg no AREsp 527.202/SP, 3.<sup>a</sup> Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.09.2015).

---

153

Luiz Cunha Gonçalves, Tratado de direito civil, 2. ed., São Paulo: Max Limonad, 1958, vol. III, tomo I, p. 141.

---

154

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 174.

---

155

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 175.

---

156

“Agravado de instrumento. Processual civil. Nova perícia. Fase de liquidação. Apuração do quantum. Constatação da inexistência do dano. ‘Liquidação zero’. A constatação da inexistência de dano a ressarcir, em fase de liquidação de sentença, configura a denominada ‘liquidação zero’. Decisão reformada” (TJRS, AgIn 70003155454, 9.<sup>a</sup> Câm. Cív, rel. Des. Mara Larsen Chechi, j. 28.11.2001).

---

157

V. sobre isso, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Novo curso, ob. cit., p. 863 e ss.

---

158

Nesse sentido, entre tantos outros, ver Teori Albino Zavaski, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 8, p. 346-348; Egas Dirceu Moniz de Aragão, “Notas sobre liquidação de sentença”, Revista de Processo, v. 44, p. 20-30; Cândido Dinamarco, Instituições de direito processual civil, t. IV, p. 62; Luiz Rodrigues Wambier, Liquidação de sentença, p. 100 e ss.

---

159

Segundo Calamandrei, “il problema della quantità del danno, posto al giudice della seconda fase, ripresenta così, solo con qualche apparente variazione di parole, lo stesso problema della esistenza del danno, già risolto dal giudice della prima fase. Negando la quantità, non si nega un attributo accidentale di un soggetto che, anche in mancanza di tale attributo, possa continuare ad esistere; ma si nega addirittura il soggetto” (Piero Calamandrei, “La condanna “generica” ai danni”, Opere giuridiche, v. V, p. 512). Conclui Calamandrei dizendo que “in realtà il giudizio sulla esistenza generica del danno e quello sulla sua inesistenza specifica sono tra loro conciliabili nella stessa misura in cui lo sarebbero l’opinione di chi ritenesse che Tizio è genericamente vivo con quella di chi accertasse che Tizio è specificamente morto!” (idem, p. 516). Adotando essa linha, no direito brasileiro, v. Ovídio Baptista da Silva, Curso de processo civil, v. 2, cit. p. 58-60.

---

Idem, p. 60.

---

Tito Fulgêncio, Do direito das obrigações – das modalidades das obrigações, Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 145.

---

Egas Dirceu Moniz de Aragão, Comentários..., ob. cit., p. 317. Na lição de Orlando Gomes, “ao devedor não é lícito substituir a prestação, mas excepcionalmente a faculdade de substituição lhe pode ser reservada no ato constitutivo da obrigação. Quando lhe assiste esse direito, a obrigação é chamada facultativa” (Orlando Gomes, Obrigações, 8.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 93). Ainda, segundo o autor, “a obrigação facultativa distingue-se nitidamente da obrigação alternativa, que se caracteriza pela pluralidade de objetos, enquanto naquela o objeto é único. Na alternativa, duas ou mais coisas ou fatos estão in obligatione e uma in solutione: ‘duae re sunt in obligatione sed una tantum in solutione’. Na facultativa, só uma está in obligatione; a outra in facultate solutione. Uma é composta, a outra simples. Uma tem objeto plural; a outra, singular” (idem, ibidem, p. 93).

---

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 190-191.

---

Wellington Moreira Pimentel, Comentários..., ob. cit., p. 185.

---

Pondera, a respeito, Pontes de Miranda, ainda a respeito do código de 1973, que “na espécie que é assunto do art. 288, não há a acumulatividade de pedidos (art. 292), nem a complexidade da prestação (x mais y mais z), que não permite qualquer alternatividade. Se a obrigação é alternativa, o que se alterna é objeto da prestação (x ou y ou z)” (Pontes de Miranda, ob. cit., t. IV, p. 59).

---

Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual e tutela dos direitos, p. 165 e ss.

---

Seguindo nesse particular, uma tendência que emerge do direito comparado, conforme Michele Taruffo “A atuação executiva dos direitos: perfis comparados”, Processo civil comparado – Ensaio, p. 85 e ss. Trata-se de regra amplamente reclamada pela doutrina, conforme Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual e tutela dos direitos, passim.

---

168

Assim tb., ainda na vigência do CPC de 1939, v., Pedro Batista Martins, ob. cit., p. 110.

---

169

Assim, tb. José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 191.

---

170

Orlando Gomes, ob cit., p. 94.

---

171

O direito português, nesse passo, chama essa figura de pedido subsidiário (art. 554, do CPC português). Efetivamente, não há cumulação aqui, já que não se deseja a satisfação de ambos os pedidos. Faz-se, ao contrário, a indicação de várias possibilidades, de modo que o juiz possa atender àquela que pareça possível.

---

172

Cf. José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 204-205.

---

173

“Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”.

---

174

V. por todos, José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 206-207.

---

175

A propósito, calha lembrar que nada impede que ocorra cumulação objetiva e subjetiva de pedidos. Basta, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos para ambos, ou seja, que se preencha as exigências postas no art. 327 e no art. 113, do CPC.

---

176

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 203.

---

177

Sobre esses requisitos, v. tb. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Novo código..., ob. cit., p. 418-420.

---

178

A regra é aplicável apenas para o processo de conhecimento, já que para a execução há regra específica, ditada pelo art. 780, do Código.

---

179

José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários...*, ob. cit., p. 202.

---

180

Sustentando essa opinião, mesmo antes do Código de 2015, v. Sérgio Bermudes, *Direito processual civil – estudos e pareceres*, 2.<sup>a</sup> série, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 15.

---

181

Joel Dias Figueira Jr, *Comentários...*, ob. cit., p. 142. Ressalve-se, porém, nesse caso, a hipótese da cumulação eventual, que na ótica do autor sequer constituiria verdadeira forma de cumulação de pedidos.

---

182

“A lei exige que os pedidos sejam compatíveis entre si (art. 292, § 1.º, I). Se dois ou mais pedidos podem ser satisfeitos separadamente, sem que a sentença, a respeito de um deles, não seja em contradição com o outro ou os outros pedidos, são eles incompatíveis. Se podiam ser satisfeitos dois ou mais, porém, a sentença pode ser favorável a qualquer um deles, a incompatibilidade não ocorre. O autor podia pedir a, b ou c, posto que só a um deles pudesse ser favorável a sentença. Se os pedidos são alternativos e podia ser acolhida a alternatividade, não há incompatibilidade” (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários...*, ob. cit., p. 76).

---

183

Arruda Alvim exemplifica essa situação assim: “é possível que o autor requeira, por exemplo, em ação condenatória por perdas e danos cumulada com pedido de reintegração de posse, a citação por edital e a intimação do Ministério Público dispostas no art. 554, § 1.º, do CPC, relativas a ações possessórias com grande número de pessoas no polo passivo. E isso não for incompatível com o rito ordinário – e de fato não é –, não há prejuízo da adoção destas técnicas procedimentais mistas” (José Manoel Arruda Alvim, *Novo contencioso...*, ob. cit., p. 158-159).

---

184

Criticando a admissão indiscriminada de cumulação objetiva, v. tb. Wellington Moreira Pimentel, *Comentários...*, ob. cit., p. 203.

---

185

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários...*, ob. cit., p. 80.

---

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Novo código... ob. cit., p. 420.

---

A previsão remonta o art. 156, do CPC de 1939, que afirmava que “qualquer dos interessados em demanda indivisível poderá intentá-la em benefício comum, só recebendo, entretanto, o que lhe couber. Os que não tiverem sido partes receberão os respectivos quinhões, deduzida a quantia que lhes incumbir nas despesas feitas pelo autor para sustentação do pleito”.

---

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 198.

---

Sobre o assunto, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Do formalismo no processo civil, passim; José Rogério Cruz e Tucci, A causa petendi no processo civil, passim; GIANNOZZI, Giancarlo, La modificazione della domanda nel processo civile, passim; Corrado Ferri, Struttura del processo e modificazione della domanda, passim; GAMBÀ, Cinzia Domande senza risposta – Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile, passim.

---

Atendeu-se aí a crítica de Wellington Moreira Pimentel, que mesmo diante da redação original do dispositivo já extraía do sistema do código (e, em particular, do contido no art. 264, daquela lei) interpretação que conduzia à inovação legal.

---

Nesse sentido, Ernani Fidelis dos Santos, Manual de direito processual civil, 11. ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 422; RODRIGUES, Marcelo Abelha, Manual de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 322; José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 211.

---

Assim, José Carlos Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, 25. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 14; Moacyr Amaral Santos. Primeiras linhas de direito processual civil, 24. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, vol. 2, p. 157.

---

É claro que essa modificação dos polos do processo pode ser empregada como mecanismo para a “escolha” do juízo em que se vai litigar. Pode suceder que seja distribuída uma demanda com um só autor, por exemplo, na expectativa de que a causa seja atribuída a certo órgão jurisdicional; havendo sucesso nisso, poderia o advogado aditar a inicial, para acrescentar outros autores, supondo que ali o julgamento seria mais favorável a seus interesses. A hipótese, obviamente, insere-se na situação descrita no art. 142,



do CPC, impondo ao juiz que adote providências capazes de impedir que a parte se valha desta artimanha.

---

194

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Novo código..., ob. cit., p. 421.

---

195

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Novo curso... ob. cit., p. 170.

---

196

Criticando a ótica rígida da estabilidade da demanda, v. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Do formalismo no processo civil, p. 196-202; José Rogério Cruz e Tucci, A causa petendi no processo civil, p. 185-192; Daniel Mitidiero, Colaboração no processo civil, p. 126-130.

---

197

A doutrina nacional, em regra, entende que os fatos novos a que alude o art. 493, do CPC, não autoriza a modificação ou a ampliação da causa de pedir. Nesse sentido, v. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Novo código... ob. cit., p. 422; José Manoel Arruda Alvim Neto, Manual de direito processual civil, 7. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. II, p. 381; Joel Dias Figueira Jr, Comentários..., ob. cit., p. 158.

---

198

Por uma proposta de revisão do conceito de estabilidade da demanda, v. Ricardo de Barros Leonel, Causa de pedir e pedido – o direito superveniente, São Paulo: Método, 2006, passim.

---

199

Na ilustração de Wellington Moreira Pimentel, “tudo se passa como no momento da partida do trem. O maquinista verifica a pressão da máquina. Os freios. Observa se os passageiros embarcaram. Se há alguma irregularidade, manda corrigi-la. Mas tem sempre presente que o comboio deve partir. Só não o fará se o defeito não puder ser superado. Aí, então, é melhor suprimir a viagem pois, sem freios ou sem passageiros, não chegará ou de nada adiantará chegar ao destino” (ob. cit., p. 216).

---

200

Contra, entendendo que essa hipótese difere do caso em que a petição inicial contém defeitos e irregularidades que apenas dificultam (mas não inviabilizam) a análise do litígio, v. José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 214.

---

201

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários..., ob. cit., p. 216.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “não é possível falar em inépcia da petição inicial por falta de correspondência lógica entre causa de pedir e pedido quando o próprio réu é capaz de identificar esses elementos e reconhecer o liame lógico entre eles” (STJ, AgRg no REsp 1.433.054/ES, 3.<sup>a</sup> T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.12.2015).

Sobre essa discussão, v. dentre tantos outros, Egas Dirceu Moniz de Aragão, Hobbes, Montesquieu e a teoria da ação, *Revista de Processo*, vol. 108, São Paulo: Ed. RT, 2002, *passim*; Cândido Rangel Dinamarco; Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Teoria geral do novo processo civil*, São Paulo: Malheiros, 2016, p. 116 e ss.; Fabio Luiz Gomes, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. 3, p. 276-282; e *Carência de ação*, São Paulo: Ed. RT, 1999, *passim*; José Ignácio Botelho de Mesquita, *Teses, estudos e pareceres de processo civil*, São Paulo: Ed. RT, 2005, vol. I, p. 86-105; Galeno Lacerda, *Despacho saneador*, 3. ed., Porto Alegre: Fabris, 1990, p. 75 e ss.; Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso de processo civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 205 e ss.

Como se sabe, Liebman, grande sistematizador da teoria das condições da ação tal como adotadas pelo direito brasileiro, na terceira edição de seu manual, acabou por reconhecer que a “possibilidade jurídica do pedido” não pode ser enquadrada como figura autônoma e, portanto, não mereceria o status de condição da ação. Subsistiram, então, na doutrina do autor italiano, apenas o interesse processual e a legitimidade como condições da ação. E é nessa perspectiva que o Código de 2015 trata o assunto.

Enrico Tullio Liebman, *L'azione nella teoria del processo civile*, *Problemi del processo civile*, Napoli: Morano, 1962, p. 46.

Enrico Tullio Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, 5. ed., Milano: Giuffrè, 1992, vol. 1, p. 144 e ss.

“Legitimação para agir (*legitimatio ad causam*) é a titularidade (ativa e passiva) da ação. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a quem pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual [nei cui confronti] ele existe (...). Também quanto à ação, prevalece o elementar princípio segundo o qual apenas o seu titular pode exercê-la; e tratando-se de direito a ser exercido necessariamente com referência a uma parte contrária, também esta deve ser precisamente a pessoa que, para os fins do provimento pedido, aparece como titular de um interesse oposto, ou seja, aquele em cuja esfera jurídica deverá produzir efeitos o provimento pedido. A legitimação, como requisito da ação, é uma condição para o pronunciamento sobre o mérito do pedido: indica, pois, para cada processo, as justas partes, as partes legítimas, isto é, as pessoas que devem estar presentes para que o juiz

possa julgar sobre determinado objeto. Entre esses dois requisitos, ou seja, a existência do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só em presença dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos necessários” (Enrico Tullio Liebman, *Manuale...*, ob. cit., p. 147-148).

---

208

Wellington Moreira Pimentel, *Comentários...*, ob. cit., p. 217; José Manoel Arruda Alvim, *Novo contencioso...*, ob. cit., p. 159-160.

---

209

Enrico Tullio Liebman, *Manuale...*, ob. cit., p. 147.

---

210

Para o autor, o interesse de agir é “um interesse processual, secundário e instrumental com relação ao interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um interesse primário lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato objetivamente existente. Por exemplo, o interesse primário de quem se afirma credor de 100 é obter o pagamento dessa importância; o interesse de agir surgirá se o devedor não pagar no vencimento e terá por objeto a sua condenação e, depois, a execução forçada à custa do seu patrimônio. O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. Seria uma inutilidade proceder ao exame do pedido para conceder (ou negar) o provimento postulado, quando na situação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária, ou quando os efeitos jurídicos que se esperam do provimento já tivessem sido obtidos, ou ainda quando o provimento pedido fosse em si mesmo inadequado ou inidôneo a remover a lesão, ou, finalmente, quando ele não pudesse ser proferido, porque não admitido pela lei (p. ex., a prisão por dívidas). Naturalmente, o reconhecimento da ocorrência do interesse de agir ainda não significa que o autor tenha razão: quer dizer apenas que o seu pedido se apresenta merecedor de exame. Ao mérito, e não ao interesse de agir, pertence toda e qualquer questão de fato e de direito relativa à procedência do pedido, ou seja, à juridicidade da proteção que se pretende para o interesse substancial. Em conclusão, o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; deve essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito” (Enrico Tullio Liebman, *Manuale...*, ob. cit., p. 145).

---

211

Não é por outra razão que o Código de 1973 – que abertamente aceitava as condições da ação – arrolava a impossibilidade jurídica do pedido como uma das causas de inépcia da petição inicial (art. 295, parágrafo único, III).

---

212

“As ‘condições da ação’ são aferidas no plano lógico e da mera asserção do direito, e a cognição a que o juiz

procede consiste em simplesmente confrontar a afirmativa do autor com o esquema abstrato da lei. Não se procede, ainda, ao acertamento do direito afirmado” (Kazuo Watanabe, *Da cognição no processo civil*, 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000, p. 94).

---

213

Kazuo Watanabe. Ob. loc. cit. Embora a teoria da asserção contribua para dar certa sobrevida às condições da ação, fato é que nem mesmo a doutrina que aceita a categoria admite o emprego dessa teoria. Há, por exemplo, quem afirme que, “bem analisada, porém, essa teoria sustenta uma arbitrária transformação de algo que de início seria uma condição para julgar o mérito e a partir de determinado momento seria motivo para julgar a demanda improcedente – com o julgamento do mérito, pois” (Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho, *Teoria geral...*, ob. cit., p. 119).

---

214

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo curso...*, ob. cit., vol. 1, p. 213.

---

215

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo código...*, ob. cit., p. 246.

---

216

José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários...*, ob. cit., p. 235-236.

---

217

Aliás, nessa linha, prevê a Súmula 380 do STJ que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

---

218

Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello, *Primeiros comentários...*, ob. cit., p. 559.

---

219

Susana Henriques da Costa, *Comentários...*, ob. cit., p. 522.

---

220

Susana Henriques da Costa, *Comentários...*, ob. cit., p. 522.

---

221

V. a propósito, as críticas de Calmon de Passos (José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários...*, ob. cit.,

---

222

Em sentido contrário, entendendo que a não constituição de advogado para o recurso já implica revelia, v. José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários...*, ob. cit., p. 241.

---

223

V. neste volume, os comentários ao art. 316.

---

224

Contra, no regime do Código anterior, entendendo cabível aí apelação por instrumento, v. a análise de Sérgio Bermudes aos comentários de Pontes de Miranda (ob. cit., p. 107-108).

---

225

O tribunal, na análise da sentença de indeferimento da petição inicial, terá atribuição que eventualmente vai além do simples exame dessa matéria. Pode suceder que o autor tenha formulado pedido de tutela provisória fundada em urgência na inicial. “Quando o autor requer, na petição inicial indeferida, a imediata concessão da tutela antecipatória e o tribunal, diante do recurso de apelação, não só percebe que o juiz de primeiro grau cometeu equívoco ao indeferir a petição inicial, mas também que estão presentes os requisitos para outorga da tutela antecipatória, cabe-lhe não só deferir a petição inicial, mas também conceder a tutela antecipatória. Não há como pensar que o tribunal, nesse caso, apenas poderia deferir a petição inicial, sob o argumento de que a análise dos pressupostos para a concessão da tutela antecipatória caberia ao juiz de primeiro grau de jurisdição. Observe-se que a sentença, ao indeferir a inicial, também nega a tutela antecipada, de modo que o recurso de apelação devolve ao tribunal a análise dos requisitos da inicial e dos pressupostos da tutela antecipatória” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código...*, p. 424).

---

226

Susana Henriques da Costa, *Comentários...*, ob. cit., p. 524.

---

35

Sobre esse princípio, v. Sérgio Cruz Arenhart. “Reflexões sobre o princípio da demanda”. *Processo e constituição: estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira*. Coord. Luiz Fux, Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2006.

---

103

Recorde-se que a Constituição da República oferece, como “garantia fundamental”, a assistência jurídica “integral” e “gratuita” a quem necessite, por insuficiência de recursos. Tratando-se de garantia fundamental, cumpre ao Estado oferecer esta prestação com a maior qualidade possível, sem que se tolere, ademais, que o Estado possa desvestir-se deste dever (a respeito da eficácia dos direitos

fundamentais, em especial dos processuais, v. entre outros, Robert Alexy, Teoria de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, passim; Claus-Wilhelm Canaris, Direitos fundamentais e direito privado, Trad. Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto, Coimbra: Almedina, 2003, passim; José Joaquim Gomes Canotilho, Estudos sobre direitos fundamentais, Coimbra: 2004, esp. p. 69 e ss.; Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual..., ob. cit., p. 165-248; idem “A jurisdição no estado contemporâneo” in Estudos de direito processual – homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão, São Paulo: Ed. RT, 2005, passim; Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, passim; Idem Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, passim; Teresa Arruda Alvim Wambier, Controle das decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e de ação rescisória, São Paulo: Ed. RT, 2002, p. 128-176; Carlos Roberto Siqueira Castro, O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 3.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, esp. p. 141--284; Sérgio Cruz Arenhart, “Tutela coletiva e o controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário”, Processo civil coletivo, Coord. Rodrigo Mazzei e Rita Dias Nolasco, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 505-527; Luciane Gonçalves Tessler, “O papel do judiciário na concretização dos direitos fundamentais”, Estudos de direito processual civil – homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão, São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 152 e ss.

© desta edição [2018]

## **Comentários ao CPC - v. IV - Marinoni - Ed. 2018**

### **TÍTULO I - DO PROCEDIMENTO COMUM**

#### **CAPÍTULO III. DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO**

### **Capítulo III. Da Improcedência Liminar do Pedido**

**Art. 332.** Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1.º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2.º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241.

§ 3.º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4.º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

#### **1. Julgamento de mérito initio litis no Código anterior e no atual**

O Código brasileiro permite ao juiz, em casos excepcionais, extinguir o processo, antes mesmo de citado o réu, rejeitando de pronto o pedido inicial formulado e, portanto, *com análise efetiva do mérito*.

Não se trata de figura nova, já que o Código de 1973, desde sua origem, também permitia ao juiz “indeferir” a petição inicial quando reconhecesse a prescrição ou a decadência do direito buscado (art. 295, IV, do CPC/1973). Embora, naquela lei, ao menos em sua versão original, não se fizesse a diferença entre os casos em que o indeferimento da petição inicial se dava com definição do mérito ou sem, fato é que a doutrina toda notava, neste caso, típica sentença de mérito proferida inicialmente no processo.

Parte da doutrina ainda indicava como sentenças desse tipo (proferidas *in limine litis*) as hipóteses de carência de ação, sob a compreensão de que as condições da ação significariam – ao contrário da tese abertamente acolhida pelo Código de 1973, e mantida na legislação atual – hipóteses evidentes de improcedência do pedido.<sup>1</sup>

Posteriormente, a Lei 11.277/2006 incluiu naquele Código o art. 285-A, que autorizava o juiz a proferir sentença imediata de improcedência em certos casos específicos. Afirmava-se que

quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

A regra, inspirada na tentativa de dar maior celeridade a casos repetitivos, foi alvo de grandes



elogios e pesadas críticas na época. Foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade (ADIn 3.695, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil), que acabou sendo extinta sem pronunciamento sobre seu mérito, em razão da superveniência do atual Código de Processo Civil, sem que houvesse aditamento da inicial com a demonstração da persistência das inconstitucionalidades.<sup>2</sup>

Seja como for, fato é que o preceito contido no art. 332 do atual CPC não representa verdadeira novidade na legislação processual brasileira. Constitui, ao revés, o resultado de um processo evolutivo, que tende a ampliar as hipóteses em que se admite ao magistrado rejeitar, desde logo, demanda manifestamente improcedente.

Ainda que essa seja uma tendência clara, parece que a lei permanece tímida no que se refere a esse tipo de situação, afastando-se de outros modelos em que é muito mais ampla a possibilidade de rejeição liminar da pretensão inicial.<sup>3</sup> Sem dúvida, um processo que se preocupa com a gestão processual poderia ampliar ainda mais a inadmissibilidade inicial de demandas inviáveis, já que isso sobrecarrega, sem necessidade ou utilidade, o sistema jurisdicional.

## **2. Sentença de improcedência initio litis no Código atual**

Como se vê do preceito em estudo, ao lado das hipóteses de indeferimento da petição inicial, que podem conduzir à extinção do processo sem resolução de mérito, o Código prevê a possibilidade de o processo ser extinto com resolução de mérito mediante improcedência liminar do pedido.

Basicamente, é possível julgamento de improcedência liminar do pedido quando houver precedente (na definição usada pelo Código para essa figura) contrário ou jurisprudência contrária à tese em que fundado o pedido, quando o direito tiver sido extinto pela decadência ou quando a pretensão houver sido atingida pela prescrição. Por precedente, entende o Código a existência de súmula de tribunal superior, acórdão proferido por tribunal superior em julgamento de recurso repetitivo, decisão tomada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e, em se tratando da interpretação de direito local, súmula de tribunal local.

Sem ainda considerar as hipóteses em que a improcedência initio litis tem incidência, o fundamental é notar que aqui se está diante de verdadeira “sentença final de mérito”. Vale dizer: ao contrário do que ocorre com o indeferimento da petição inicial, aqui se está diante de efetivo pronunciamento sobre a controvérsia trazida a juízo, com aptidão para revestir-se da autoridade de coisa julgada.

Essa também é a diferença entre esse instituto e a tutela provisória da evidência, antes estudada. Embora a tutela provisória possa basear-se em julgamento de casos repetitivos ou súmulas vinculantes (art. 311, II, do CPC), ela é sempre baseada em cognição sumária, em juízo de aparência. Ou seja, não há aqui potencial para coisa julgada material. E isso se dá, basicamente, por uma questão de insuficiência do material probatório ou por deficiência de contraditório. Na tutela provisória da evidência, o processo ainda não permite que se julgue definitivamente a lide. E isso pode ocorrer ou porque o contraditório do réu ainda não está completo – falta ser ele ouvido ou se lhe oportunizar a produção de provas – ou porque as partes ainda precisam comprovar fatos no processo, de modo que a instrução ainda não está encerrada.

Em tais casos, entendendo o Código que não seria justo atribuir o ônus da demora do processo ao autor, outorga à tutela da evidência o papel de equilibrar esse ônus do tempo.

Na improcedência liminar, ao contrário, não se está diante de decisão provisória. O pedido do autor pode ser imediatamente examinado, porque é manifesta a sua improcedência. A oitiva prévia do réu é desnecessária, porque a decisão só virá em seu benefício.

Em todo caso, porque aqui se trata de sentença de mérito, ela só deve ter cabimento se a instrução do processo ou a oitiva do réu se mostrarem desnecessários. Havendo as hipóteses descritas no texto legal e sendo desnecessárias provas dos fatos alegados – ou já havendo provas

suficientes, pré-constituídas –, então tem o magistrado condições de examinar de pronto o pedido, para julgá-lo improcedente, nas hipóteses descritas na regra. Por outras palavras, esse julgamento liminar só tem cabimento se plenamente satisfeito o direito do autor à produção das provas que lhe competiriam, seja porque o caso as dispensa, seja porque elas já foram todas trazidas por meio de documentos anexados à inicial.

### 3. Improcedência liminar do pedido e “precedente”

Antes de prosseguir na análise do instituto, é preciso perceber de antemão que o caput do art. 332 do CPC expõe uma evidente dificuldade do legislador: a de imaginar que a formação de um precedente encontra-se atrelada à determinada forma preestabelecida ou à determinada quantidade existente de casos sobre certo assunto.<sup>4</sup> Essa dificuldade aparece igualmente quando o Código trata de alguns casos em que se admite tutela da evidência (art. 311, II, do CPC), quando disciplina os poderes do relator (art. 932, IV e V, do CPC), o incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 e ss. do CPC), o cabimento da apelação (art. 1.011, I, do CPC) e os recursos repetitivos (arts. 1.036 e ss. do CPC).

O precedente, porém, é um conceito material e qualitativo – diz respeito à completa apreciação dos argumentos que podem influir na solução da questão examinada e à autoridade de quem elabora as razões a partir de determinado caso.<sup>5</sup> Nessa linha, é claro que as razões invocadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos ou no julgamento do incidente de assunção de competência *podem* gerar precedentes. Mas é claro que pode igualmente haver a formação de precedentes a partir das razões invocadas pelas Cortes Supremas fora dessas hipóteses – por exemplo, no julgamento de um recurso extraordinário ou de um recurso especial – assim como também é certo que pode haver decisões daquelas Cortes que se enquadrem na forma indicada pela lei e *não constituam precedentes*. A mesma observação vale para a hipótese em que o tribunal de justiça se pronuncia sobre questão local – hipótese em que as suas razões devem valer como precedentes para os juízes de direito a ele submetidos: independentemente de a questão ter sido sumulada, é claro que pode haver precedente local oriundo de julgamento do tribunal de justiça. E semelhante precedente local obviamente poderá dar lugar a julgamento de improcedência liminar.

### 4. Hipóteses de cabimento da improcedência liminar do pedido

Ao contrário do Código anterior, a lei atual não acolheu a ideia de permitir ao juiz rejeitar de plano o pedido inicial com fundamento em “precedente” do próprio juiz. O art. 285-A do CPC/1973 permitia, como se viu, ao juiz julgar improcedente desde logo a demanda quando a questão fosse unicamente de direito e aquele juízo já houvesse proferido sentença de total improcedência em casos idênticos. Nesse caso, bastaria a reprodução do teor do entendimento antes manifestado para que também o caso novo fosse rejeitado. Chamava-se a isso de “autoprecedente”. A técnica facilitava a fundamentação da decisão, gerando certa uniformidade limitada ao juízo prolator da decisão. Porém, não se prestava como mecanismo capaz de gerar segurança jurídica ou estabilidade na interpretação do direito em nível macroscópico, já que lidava apenas com decisões anteriores proferidas pelo próprio juízo.

O Código atual mudou substancialmente sua orientação.

O legislador viabilizou o julgamento de improcedência liminar do pedido: (i) quando houver precedente contrário ao pedido do autor, oriundo ou não de julgamento repetitivo ou de incidente de assunção de competência, enunciada ou não a sua ratio em uma súmula (art. 332, I, II e IV, do CPC); (ii) quando houver jurisprudência contrária ao pedido do autor firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência (art. 332, III, do CPC); (iii) quando o direito do autor tiver sido extinto pela decadência (art. 332, § 1.º, do CPC); ou (iv) quando a pretensão do autor tiver sido atingida pela prescrição (art. 332, § 1.º, do CPC). Diferentemente do que ocorre com os precedentes das Cortes Supremas, a jurisprudência das Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais) só autoriza o julgamento de improcedência liminar quando formada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. O legislador erigiu aí a forma dos incidentes como

elemento distintivo de uma força particular que resolveu outorgar à força da jurisprudência.

Considere-se em maiores detalhes cada um desses casos:

a) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal de Justiça, sobre direito local

O primeiro dos casos apontados pela lei refere-se à existência de súmula de tribunal superior. Como dito, não se pode confundir súmula com precedente e, menos ainda, supor que a súmula deva sempre revelar o sentido da *ratio decidendi* utilizada em alguma decisão judicial.

De todo modo, o Código supõe que a existência de súmula de tribunal superior implica pacificação a respeito do entendimento sobre certa questão de direito. Por isso, se a única discussão presente no processo, ou se o cerne do litígio, apoia-se em discussão sobre a interpretação da questão de direito cuja orientação já está sedimentada em súmula, seria despiciendo dar prosseguimento ao processo, podendo o magistrado desde logo dar ao caso a aplicação do direito já oferecida pelo tribunal superior.

Em realidade, as súmulas foram concebidas, em sua origem, como um método de trabalho,<sup>6</sup> de modo a otimizar a solução de casos frequentes no tribunal, sobretudo daqueles mais simples, facilitando seu julgamento.<sup>7</sup> Buscam fixar um padrão de decisão e, assim, simplificar a argumentação necessária para o julgamento, especialmente de casos fáceis.

Nessa condição, entendeu o legislador que poderiam esses enunciados ser suficientes para a avaliação *ictu oculi* de demandas manifestamente inviáveis. Notando o magistrado que a pretensão deduzida vai de encontro a entendimento já sedimentado por tribunal superior, tendo a argumentação da inicial claramente sido rechaçada nas razões fundamentais que levaram a Corte a tal entendimento, não há sentido em se permitir a renovação de discussão já vencida.

Claro está que as súmulas só podem justificar a rejeição liminar da inicial se e quando a argumentação desenvolvida na petição inicial já foi apreciada pelo tribunal superior quando da elaboração da súmula.

É o que se extrai do contido no art. 926, § 2.º, do CPC, a estabelecer que “ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”. As súmulas, portanto, só têm algum valor se seu enunciado estiver em perfeita sintonia com aquilo que foi efetivamente examinado pelo tribunal nas decisões que lhe deram origem. Por isso, também, impõe o art. 489, § 1.º, V, do CPC, que toca ao juiz, ao invocar uma súmula para subsidiar sua decisão, identificar com precisão os fundamentos determinantes que levaram à sua edição e também demonstrar que o caso em análise está adequadamente ajustado àqueles fundamentos.

A aplicação da súmula, portanto, como causa para a rejeição *prima facie* da petição inicial, exige muito mais do que a singela indicação de seu conteúdo. Impõe o cotejo das razões determinantes das decisões que subsidiaram sua edição com a discussão apresentada no caso concreto, sob análise. Somente assim se consegue evitar o engessamento do direito e se permite que debates novos – sobre aspectos não apreciados no caso anterior – possam encontrar acesso ao Poder Judiciário, concretizando a garantia posta no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

Diante disso, como o importante, a rigor, não é a súmula, mas a *ratio decidendi* por detrás dela, pouco importa se a súmula (especificamente do Supremo Tribunal Federal) é ou não vinculante. Já que ambas deverão estar lastreadas em razões determinantes, ambas podem ser empregadas para fundamentar a improcedência liminar da petição inicial. Outro entendimento, aliás, tornaria incompreensível a inclusão do Superior Tribunal de Justiça no rol do art. 332 do CPC, já que é evidente que essa Corte não produz súmulas vinculantes, no sentido do texto constitucional.

Para que as súmulas dos tribunais superiores (ou do tribunal local, em matéria local) possam ser invocadas como razão para a rejeição liminar da petição inicial, é necessário que suas razões determinantes insiram-se na competência constitucional desses tribunais. Vale dizer que uma

súmula do Supremo Tribunal Federal só deve ser invocada para a improcedência liminar se tratar da interpretação da Constituição Federal; a do Superior Tribunal de Justiça só deve ser utilizada para fundamentar a improcedência liminar se versar sobre a interpretação do direito federal; e a do Tribunal de Justiça só tem cabimento se a discussão versar sobre a interpretação do direito local. Outros entendimentos, ainda que cristalizados em súmulas, embora possam ser importantes para outras finalidades, não devem ser invocadas neste campo.

Do mesmo modo, é necessário que a súmula seja atual, ou seja, que reflita o entendimento existente no tribunal na época do julgamento de improcedência liminar. Do contrário, superada que esteja a súmula – ainda que formalmente não revogada – parece claro que ela não deve ser utilizada.

Por fim, recorde-se que é certo que as decisões que uniformizam o entendimento sobre questão de direito podem incidir sobre questões de direito material ou processual. Porém, para os fins aqui examinados – já que se busca uma sentença de mérito –, somente os entendimentos sobre direito material importarão.

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos

A segunda hipótese de decisão que pode subsidiar a sentença liminar de improcedência é a existência de acórdão proferido por tribunal superior em recurso repetitivo.

O mecanismo de julgamento de recursos repetitivos – instituído ainda na vigência do CPC/1973 (arts. 543-B e 543-C, daquele Código) – foi concebido como técnica capaz de permitir o julgamento por amostragem de recursos (especiais e extraordinários) que apresentassem discussão sobre a mesma questão de direito. Aperfeiçoado no Código atual, mantém em suma a sua ideia básica.

Sua lógica está em que, se a questão de direito é a mesma, não se justificaria que o tribunal superior tivesse que reexaminar a questão múltiplas vezes. Bastaria um julgamento para que a tese fosse firmada e para que pudesse ser observada por todo o Judiciário. A técnica serve a desafogar os tribunais superiores, que deixariam de rejudgar questões já examinadas, mas que se repetissem no foro.<sup>8</sup> Entendeu-se que a concentração desses julgamentos em um único momento permitiria eliminar a gama de causas repetitivas dos tribunais superiores, dando aos magistrados daqueles órgãos mais condições de examinar questões diversas, de maior complexidade.<sup>9</sup>

Em outros termos, a técnica permite o julgamento conjunto de vários recursos que discutem a mesma questão de direito, permitindo que o tribunal superior fixe, desde logo, a tese que deve governar a interpretação dessa questão. Se, então, a orientação sobre o tema já foi sedimentada, seria razoável concluir que não há mais sentido em admitir demanda que pretendam controverter sobre ele.

Por isso, ajuizada ação em que só se discuta sobre aquela questão de direito, ou em que essa análise seja essencial para o deslinde da causa, poderia o magistrado de 1.º grau desde logo rejeitar a demanda que pretendesse outra interpretação.

As observações feitas acima, na análise da súmula como base para a improcedência liminar, valem integralmente para cá. A simples existência de julgamento proferido em recurso repetitivo é, em si, irrelevante. É necessário que o juiz do caso concreto examine o teor da inicial e avalie se a discussão pretendida é, realmente, a mesma que já foi objeto do tribunal superior. Em caso afirmativo, porque pacificada a análise do tema, haverá de rejeitar a inicial, justificando a adequação da aplicação do entendimento do tribunal superior ao caso concreto. Do contrário, não será caso de improcedência liminar.

Em princípio, segundo o Código, é necessário que o julgamento do tribunal superior se refira a caso repetitivo. Porém, como dito antes, e como será melhor analisado na sequência, não há racionalidade nessa distinção, na medida em que a sujeição de uma questão de direito ao modelo de julgamento repetitivo não transforma a decisão em precedente. Mais que isso, não é possível

que se eleja o número de causas como o fator determinante para concluir se uma decisão de tribunal superior deve ou não ser observada.

Não há dúvida, porém, de que, sendo julgamento de recurso repetitivo, o julgamento liminar de improcedência se aplica, sempre com a devida fundamentação.

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência

O incidente de resolução de demandas repetitivas é outro instrumento, concebido pelo Código, para lidar com questões de direito repetitivas. Como se vê do art. 976 do CPC, para que seja cabível esse incidente, é necessário que haja questão unicamente de direito efetivamente repetida em vários processos, com risco à isonomia e à segurança jurídica. É instituto semelhante à lógica que preside os recursos repetitivos, ainda que de competência (originária, pelo menos em regra) de tribunais locais.

Já o incidente de assunção de competência – existente há muito no ordenamento nacional<sup>10</sup> – tem por finalidade simplesmente atribuir a um colegiado amplo (supostamente, representativo de todo o tribunal) a discussão de questão de direito que possua grande repercussão social (art. 947 do CPC).<sup>11</sup>

No primeiro caso, há instrumento que opera a cisão do julgamento, atribuindo a análise da questão de direito repetitiva a um tribunal local, ficando as outras questões (sobretudo aquelas apresentadas em outros processos) afetas ao órgão jurisdicional originário. Trata-se de figura subsidiária, só aplicada se ainda não houver afetação de recurso especial ou extraordinário ao regime de repetitivos (art. 976, § 4.º, do CPC).

No incidente de assunção de competência, há verdadeiro deslocamento da competência originária para julgamento do recurso, de modo que ela passa a pertencer a órgão que deve representar o entendimento de toda Corte sobre a matéria.

Em ambos os casos, a decisão sobre questão de direito opera coisa julgada, que se projeta para qualquer outro processo futuro em que o tema venha a ser ventilado (arts. 947, § 3.º, e 985, do CPC).

Ora, se há coisa julgada, retira-se do juiz de 1.º grau a prerrogativa de reexaminar o tema, cabendo-lhe, por força do efeito positivo da res iudicata, simplesmente dar aplicação ao entendimento já firmado. Por isso, definida a interpretação da questão de direito, descabe outra ação que pretenda outro entendimento. Se assim o fizer – enquanto mantidas as mesmas condições de fato e de direito –, incidirá a coisa julgada, a determinar a improcedência liminar do pedido.<sup>12</sup>

No caso do incidente de resolução de demandas repetitivas, parece evidente que a hipótese de rejeição liminar do pedido só se aplica a casos futuros, ou seja, àqueles iniciados depois de julgado o incidente, ou para aqueles que, antes da citação do réu, tiveram sua tramitação suspensa por força da admissão do incidente. Para os outros, que estiverem pendentes, a tese evidentemente deve ser aplicada, mas não ensejará a improcedência liminar, e, sim, de regra, o julgamento antecipado da lide.

Outrossim, é claro que a tese firmada nestes incidentes só operará a improcedência liminar do pedido se não houver necessidade de instrução sobre os fatos alegados pelo autor. Ou seja, a hipótese só incidirá se for suficiente, para a análise do pedido, a aplicação da tese já sedimentada, seja porque é o único objeto de discussão do processo, seja porque a solução da tese torna prejudicada a análise do restante das alegações postas na petição inicial.

d) outros julgamentos

Como se salientou no início destes comentários, o Código incide em ampla confusão entre precedente, jurisprudência e decisão obrigatória. A rigor, qualquer decisão que bem examine



certa controvérsia e que lhe dê a adequada solução tem potencial para servir de precedente.<sup>13</sup>

Se é assim, reconhecido que alguma decisão anterior deu a mais adequada interpretação do direito, então não deve haver dúvida de que essa decisão deve orientar as próximas decisões que envolvam a mesma questão de direito.

Por isso, embora se possa aceitar que as decisões arroladas no art. 332 do CPC possam constituir precedentes e devam ser observados, não há dúvida de que estas não são as únicas decisões que merecem esse respeito. O que deve importar, portanto, não é a adequação formal de uma decisão a um certo modelo legal; deve, antes, importar a autoridade que a decisão – e, em especial, a sua fundamentação – merece no meio jurídico, como tendo dado o melhor tratamento à questão discutida.

Nesse sentido, deve-se concluir que o rol de decisões a que alude o art. 332 do CPC não deve ser tido como exaustivo. Qualquer decisão que possa receber o adjetivo de precedente – não no sentido empregado pelo Código, mas em seu sentido genuíno – deve também autorizar a improcedência liminar de demanda, porque é manifestamente inviável a pretensão deduzida.

#### e) decadência e prescrição

A última hipótese descrita no dispositivo em exame, como autorizador do julgamento de improcedência liminar do pedido, é a verificação da ocorrência de decadência ou de prescrição (art. 332, § 1.º, do CPC).

O Código de Processo Civil de 2015 corrige o defeito da lei anterior, que arrolava esse caso como um dos casos de indeferimento da petição inicial à qual, de regra, se atribuía a condição de sentença terminativa (art. 295, c/c art. 267, I, do CPC/1973). Agora, resta claro que a extinção do processo – ainda que antes da citação do réu – pelo reconhecimento da prescrição ou da decadência constitui hipótese de sentença de mérito, à qual se atribui coisa julgada material (art. 487, II, do CPC).

De fato, não deveria haver dúvida de que prescrição e decadência são temas de direito material, que interferem sobre o mérito da causa. Não são questões processuais, mas típico problema referente à existência ou à exigibilidade do direito ou da pretensão deduzida. A prescrição, como se sabe, torna ineficaz a pretensão que a parte formula; a decadência, por sua vez, faz desaparecer o próprio direito material.<sup>14</sup> São, claramente, questões referentes ao direito material, cuja apreciação sem dúvida implica análise de mérito.

Assim, resta claro que, se dos elementos presentes na petição inicial os nos documentos que a acompanham, puder o juiz verificar desde logo a prescrição ou a decadência, deverá pronunciar esses fatos, inviabilizando o prosseguimento de demanda claramente infundada. Logicamente, se os dados que permitem pronunciar a decadência ou a prescrição são aferidos posteriormente, ao longo do processo, então não será o caso de improcedência liminar, mas sim de sentença de improcedência, *que não dispensa o contraditório prévio das partes*.

Recorde-se que, no modelo atual, tanto a prescrição como a decadência podem, de regra, ser conhecidas de ofício. A inovação foi trazida pelo art. 219, § 5.º, do CPC/1973, com a redação dada pela Lei 11.280/2006, que permitiu ao magistrado conhecer da prescrição de ofício, de forma a equipará-la, sob esse aspecto, à análise da decadência. E o mesmo regime foi adotado pelo Código atual, como se vê do dispositivo em exame (art. 332, § 1.º), bem como do art. 487, II, do CPC.

Deve-se, porém, ressaltar a hipótese da decadência convencional que, a teor do art. 211 do CC, não pode ser examinada de ofício, exigindo provocação da parte. Em tal caso, evidentemente, ainda que note a implementação do prazo decadencial, não poderá o juiz julgar liminarmente improcedente o pedido, já que dependerá da manifestação do interessado para acolher o óbice.

No particular, também é interessante examinar os impactos que a regra em apreço acarretará à figura da renúncia à prescrição, de que trata o art. 191, do Código Civil. Segundo este preceito,

A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

Ora, se é possível a renúncia à prescrição já ocorrida, como se pode compatibilizar essa figura com o seu conhecimento de ofício, *initio litis*, com a extinção do processo, na forma prevista pelo art. 332, § 1º, do CPC?

Embora o Código não ofereça solução para este caso, parece que a solução pode ser encontrada no sistema de comunicações estabelecido pelo Código logo após a sentença de improcedência liminar. O réu, bem vista a sequência processual, terá duas oportunidades para manifestar-se a respeito da extinção do processo e, portanto, do eventual interesse em renunciar à prescrição, dando sequência ao processo. Em primeiro lugar, pronunciada a sentença e não apresentado recurso, afirma o Código que se deve intimar o réu do “trânsito em julgado” (art. 332, § 2º). Evidentemente, o trânsito em julgado a que se refere o texto legal *ocorre apenas para o autor*, já que o réu jamais teve, ainda, a oportunidade de participar do feito. Nesse momento, é lógico, poderá o réu manifestar sua renúncia à prescrição, insistindo para que o processo retome seu curso. Fá-lo-á por meio de apelação (possui interesse para tanto, já que não tem interesse no reconhecimento da prescrição), o que autorizará o magistrado a exercer juízo de retratação, dando sequência ao processo.<sup>15</sup> Por outro lado, tendo havido recurso da parte autora, afirma o Código que, não havendo retratação do magistrado, deve-se citar o réu para oferecer contrarrazões (art. 332, § 4º). Neste caso, também poderá o réu para valer-se dessa oportunidade tanto para apresentar recurso adesivo à apelação do autor, como para, em contrarrazões, afirmar sua renúncia à prescrição declarada. Embora o Código não oportunize novo juízo de retratação nesse momento – prevendo-o apenas antes da citação do réu – é evidente que a lógica da cooperação processual e a garantia da instrumentalidade do processo autorizam que o juiz exerça novo juízo de retratação, à vista dessa manifestação do réu, cassando sua sentença e dando seguimento ao processo.

Para a improcedência liminar do pedido por prescrição ou decadência, como estabelece claramente o art. 487, parágrafo único, do CPC, é dispensável a oitiva prévia do autor.

## **5. Julgamento liminar de improcedência e contraditório prévio**

Alguém poderia imaginar que o julgamento liminar de improcedência não poderia levar em consideração questões sobre as quais o autor não teve a oportunidade de se manifestar (arts. 5.º, LV, da CF, e 10, CPC). Isso poderia levar à conclusão de que, acaso o autor não se tenha pronunciado sobre a aplicação do precedente, da jurisprudência, da decadência ou da prescrição ao seu caso na petição inicial, teria o juiz de oportunizar que o autor se pronunciasse sobre a aplicação do precedente ou da jurisprudência ao seu caso (viabilizando a demonstração de eventual distinção ainda não realizada que o autor entenda pertinente) ou sobre a decadência do direito ou a prescrição da pretensão.<sup>16</sup>

No entanto, como nesse caso a apelação excepcionalmente viabiliza a retratação do juiz de 1.º grau (art. 332, § 3.º, do CPC), pode o contraditório ser exercido eficazmente na apelação, inclusive com a possibilidade de o juiz se retratar e reconhecer que o precedente não é aplicável, que a orientação jurisprudencial não alcança o caso, que não há decadência ou prescrição. E é justamente por essa razão que o art. 332, § 1.º, do CPC dispensa o contraditório prévio no julgamento da improcedência liminar que declara a decadência ou a prescrição (art. 487, parágrafo único, do CPC).

Pelas mesmas razões, o contraditório deve também ser dispensado quando houver a invocação de precedente não debatido ou de orientação jurisprudencial não discutida pelo autor na petição inicial.

## **6. Recurso da sentença de improcedência initio litis**

Do julgamento de improcedência liminar caberá apelação (art. 1.009, do CPC). Trata-se, à semelhança do ato judicial de indeferimento da petição inicial, de sentença, na medida em que põe



fim à etapa de conhecimento do processo em 1.º grau. Por isso, inequivocamente, é o caso de apelação, como, aliás, corretamente afirma o art. 332, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

Interposta, o juiz poderá retratar-se em cinco dias. Valem aqui as observações já feitas nos comentários ao art. 331 do CPC. Ou seja, embora o Código não contemple mais a figura do juízo de admissibilidade da apelação na instância inferior, para que o recurso tenha sua tramitação obstada, parece correto que o juízo recorrido realize a análise da presença dos pressupostos recursais, ao menos para saber se deve ou não realizar o juízo de retratação. Por uma questão de lógica, se o recurso não é admissível, a sentença proferida opera preclusão pro judicato, o que impediria que o juiz a revisasse. Como só tem cabimento a reapreciação da sentença provocada em razão da interposição (válida) de recurso de apelação, então só se esse recurso for admissível é que se pode cogitar do juízo de retratação.

Por essa razão, inadmissível que seja a apelação por falta de pressuposto recursal, o juiz deve abster-se de realizar o juízo de retratação. Com isso, limitar-se-á a citar o réu para eventuais contrarrazões, encaminhando então o processo para o tribunal – que é o único juízo que pode, efetivamente, realizar o juízo de admissibilidade do recurso.

Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, para seu curso regular. Ou seja, o réu será citado para comparecer à audiência de mediação ou conciliação (art. 334 do CPC), se cabível, ou então para contestar o feito, nas hipóteses do art. 334, § 4.º, do CPC.

Se não houver retratação, o juiz determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze dias (art. 332, § 4.º), encaminhando então o processo para o tribunal.

Caso ocorra a retratação, pode o réu insurgir-se contra essa decisão? Recorde-se que, neste caso, o réu não será citado para o recurso de apelação, que estará prejudicado. Ele será citado para o processo, ou seja, para o prosseguimento da fase postulatória em 1.º grau. Assim, é evidente que o réu pode insurgir-se contra a decisão que se retratou da improcedência liminar. Porém, essa insurgência não se dá, em primeiro lugar, por meio de recurso. Caberá ao réu discutir a questão em 1.º grau, apontando a improcedência da demanda em sua contestação e provocando o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC). Caso o juiz não acolha essa defesa, abrir-se-á espaço para o agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC) ou para outro recurso que seja adequado ao caso, oportunamente.

Não havendo a interposição da apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença (art. 332, § 2.º, do CPC), norma, aliás, repetida pelo art. 241 do CPC.<sup>17</sup> A intimação servirá, logicamente, para dar notícia à parte da existência do processo que havia sido instaurado e que foi extinto. Servirá também para dar-lhe ciência da coisa julgada operada naquele processo, até para que possa valer-se dessa objeção em eventual demanda futura. Enfim, poderá servir para que o réu, tendo havido o reconhecimento da exigibilidade de certa prestação diante da improcedência liminar da petição inicial, valha-se da decisão como título executivo, em eventual cumprimento de sentença (art. 515, I, do CPC).

Por fim, recorde-se que tem aplicação a esta apelação o contido no art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC, que determinam ao tribunal que, se o estado da causa o permitir, examine o restante do mérito, sem restituir os autos ao primeiro grau.<sup>18</sup> Isso pode ocorrer tanto no caso em que o tribunal reforme a sentença de rejeição liminar da inicial (v.g., afastando o reconhecimento da prescrição ou da decadência, nos termos do art. 1.013, § 4º), como ainda em situações diversas, a exemplo da percepção da omissão da sentença quanto ao exame de algum dos pedidos (art. 1.013, § 3º). Em todos os casos, porém, sempre que possível, deve o tribunal evitar a restituição dos autos ao primeiro grau, pronunciando-se a respeito do restante do mérito se estiver em condições de fazê-lo.

## **7. Improcedência parcial liminar do pedido**

O julgamento liminar de improcedência pode estender-se sobre todos os pedidos apresentados

na petição inicial ou apenas sobre alguns deles. É facilmente imaginável situação em que alguns dos pedidos cumulados estejam prescritos ou já tenham sido resolvidos pelas decisões mencionadas no art. 332, enquanto outros não. Nesses casos, o juiz poderá aplicar a técnica da improcedência liminar initio litis apenas em relação a alguns dos pedidos formulados inicialmente.

Neste caso, como é evidente, o juiz não estará proferindo, propriamente, sentença, já que o ato não extinguirá a fase de conhecimento de 1.º grau. O ato será qualificado como decisão interlocutória. Por isso, eventual insurgência comportará recurso de agravo de instrumento da decisão parcial (art. 1.015, II, do CPC), valendo aqui as mesmas observações já feitas nos comentários ao art. 331, aos quais se remete o leitor.

**Art. 333 (Vetado.)**

---

## NOTAS DE RODAPÉ

---

1

V. sobre isso, os comentários ao art. 330, *supra*.

2

STF, ADIn 3.695/DF. Decisão monocrática Min. Alexandre de Moraes, *DJe* 18.05.17.

3

Em Portugal, por exemplo, prevê o art. 590º do CPC atual, a possibilidade de o juiz indeferir liminarmente a petição inicial “quando o pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, de forma evidente, exceções dilatórias insupríveis e de que o juiz deva conhecer oficiosamente”. No modelo norte-americano também se admite a dismissal with prejudice, com a rejeição preliminar de uma demanda inconsistente (vexatious), apresentada de má-fé ou que não seja conduzida pelas partes em tempo razoável (v. por exemplo, Federal Rules of Civil Procedure, 37(b)(2)(v)). Embora isso ocorra, muitas vezes, a requerimento da parte contrária, é possível nesses casos a atuação do tribunal de ofício. Para uma análise ampla dessa complexa figura, v. entre outros, Almara Sepanian. Cleaning house with rule 41(b): an empirical study of the multi-factor tests for involuntary dismissals. *Southwestern law review*. 2014, vol. 44, *passim*.

4

V. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, *Novo Código...*, p. 425.

5

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, *passim*; e O STJ enquanto corte de precedentes, *passim*; Daniel Mitidiero, *Cortes superiores e cortes supremas*, *passim*.

6

Hermes Zaneti Jr., *O valor vinculante dos precedentes*, Salvador: JusPodivm, 2015, p. 192; Ravi Peixoto,

7

Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 480.

---

8

V. sobre isso, Maria Isabel Gallotti, Recurso especial como instrumento de uniformização do direito federal, O papel da jurisprudência no STJ, São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 623 e ss.

---

9

Sidnei Beneti, O Nurer – Núcleo de Recursos Repetitivos do STJ e o novo recurso especial, O papel da jurisprudência no STJ, São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 822.

---

10

No Código de 1973, a figura foi inserida pela Lei 10.352/2001 no art. 555, § 1.º, que tinha a seguinte redação: “Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso”. Porém, a técnica já era consagrada pelos regimentos internos, tanto do Supremo Tribunal Federal (art. 22, parágrafo único), como do Superior Tribunal de Justiça (arts. 12, parágrafo único, II, e 14, II).

---

11

A princípio, o incidente de assunção de competência não exige que a questão de direito seja repetitiva. Basta a sua relevância. Porém, como se vê do art. 947, § 4.º, do CPC, o incidente também pode ser aplicado para prevenir ou compor divergência na interpretação de questão de direito. Ora, se há essa divergência (potencial ou efetiva) é porque a questão de direito ou já se repetiu ou tende a repetir-se. Logo, há certa sobreposição entre o incidente de julgamento de casos repetitivos e o incidente de assunção de competência.

---

12

Sobre o efeito suspensivo do incidente de resolução de demandas repetitivas e a sua duração, v. os comentários supra, ao art. 313 do CPC.

---

13

No direito brasileiro, v. Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, ob. cit., passim; e O STJ enquanto Corte de precedentes, São Paulo: Ed. RT, 2014, passim; Daniel Mitidiero, Cortes superiores e Cortes supremas, ob. cit., passim; e Precedentes – Da persuasão à vinculação, São Paulo: Ed. RT, 2016, passim; Thomas da Rosa Bustamante, Teoria do precedente judicial, São Paulo: Noeses, 2012, passim; Estefânia Maria de Queiroz Barboza, Precedentes judiciais e segurança jurídica, São Paulo: Saraiva, 2014,

passim; Hermes Zanetti Jr., O valor..., ob. cit., passim; Paula P. Pereira, Legitimidade dos precedentes, São Paulo: Ed. RT, 2014, passim; Carlos Eduardo Rangel Xavier, Reclamação constitucional e precedentes judiciais, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 121 e ss.

---

14

V. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 2. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, t. VI, p. 98 e ss.; Antonio Luiz da Câmara Leal, Da prescrição e da decadência, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1978, passim; Agnelo Amorim Filho, Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis, Revista de Direito Processual Civil, São Paulo, vol. 3, jan.-jun./1961, passim.

---

15

Nesse mesmo sentido, v. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini. *Curso avançado de processo civil*. 16. ed., São Paulo: RT, 2016, v. 2, p. 118.

---

16

Sobre o contraditório na improcedência liminar, Denis Donoso, Julgamento prévio do mérito, passim.

---

17

Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento.

---

18

No mesmo sentido, Oreste Nestor Souza Laspro. “Julgamento liminar de improcedência”. *Código de processo civil anotado*. Coord. José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho Aprigliano, Rogéria Fagundes Dotti e Sandro Gilbert Martins. Rio de Janeiro: GZ, 2016, p. 488.

---

## Índice Alfabético-remissivo

---

(Os números em negrito referem-se ao artigo do Código de Processo Civil; os números que seguem o número do artigo dizem respeito aos itens relativos aos artigos)

Abuso de direito de defesa, 311, 5.5, 8.1

Ação

– cautelar, 305, 2

– cautelar e ação principal no mesmo processo, 305, 2; 308, 1

– condenatória, 318, 5; 319, 6; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 8; Cap. II, Seç. II, 9

– constitutiva, Liv. I, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1

– de revisão, 304, 8

– declaratória, 318, 3; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 5; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 9

– executiva, Liv. I, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1

– mandamental, Liv. I, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1; 323, 2

– penal, 313, 14; 315, 2; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 6

– ressarcitória, 297, 5.4

– universal, 324, 2; 324, 3

Acesso à justiça, 330, 4; 332, 4

Aditamento da petição inicial, 303, 3, 4; 319, 10; 329, 1, 2, 3

Administração da Justiça, 311, 5.4

Admissibilidade

– da petição inicial, 330, 1

– de recurso, 330, 1; 331, 1, 6

Agravo de instrumento, 331, 3, 4; 332, 6, 7

– efeito suspensivo, 311, 11

Angularização da relação processual; Liv. V, Tít. 1; Liv. V; Tít. 2

Antecedente, 294, 6.6

Antecipação

- da eficácia declaratória, 304, 7
- de soma, 297, 5
- de tutela, ver tutela antecipada

Apelação, 316, 3; 318, 6; 321, 3; Cap. II, Seç. II, 6; 325, 1; 326, 2; 330, 1; 331, 1; 331, 3, 4, 5, 6, 7; 332, 6

Arbitragem, 316, 3; 329, 2

Arresto, 297, 5, 5.1; 301, 2

Arrolamento de bens, 301, 2

Astreintes, 297, 3, 5.2

Audiência de conciliação ou mediação, 312, 3; 319, 9; 331, 6

Autonomia da tutela contra o ilícito, 294, 2, 4, 4.2

Auxílio direto, 313, 15

Bem da certeza jurídica, 304, 7

Capacidade processual, 313, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 330, 2

Características da tutela cautelar, 294, 1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.

Carta precatória, 313, 15

Carência de ação, 330, 3

Causa de pedir (*causa petendi*), 316, 3; 319, 5; 327, 1; 329, 1, 2; 329, 5, 330, 2

- próxima e remota, 319, 5

Cautelar idônea, 301, 2

Cautelaridade e Preventividade, 294, 1.6

Caução, 300, 8

Cessaç o

- da eficácia da tutela cautelar, 309, 1, 2, 3, 4
- em caso de improcedência do pedido principal e de extinção do processo sem resolução do mérito, 309, 4
- Responsabilidade em caso de cessação da eficácia da tutela de urgência, 302, 2

Citação, 302, 2; Liv. VI, Tít. I, 1; Liv. VI, Tít. I, 2; 318, 2; 319, 4, 8

- Não apresentação dos meios necessários à citação, 302, 2

Classificação dos processos, Lv. I, 1

Cláusula executiva aberta, 297, 1

Coerção indireta, 297, 3, 4, 5.2

Coisa julgada, 304, 10; Cap. II, Seç. II, 9; 323, 2; 324, 7; 327, 1; 328, 2; 330, 1, 5; 332, 2, 4, 6

– e tutela estabilizada, 304, 10

Compatibilidade de procedimento, 327, 4

Competência, 299, 2

– absoluta e relativa, 327, 4, 6

Conceito de tutela cautelar, 294, 1.1

Concessão de providência diversa, 301, 3

Concurso de ações (ou de pedidos), 327, 1, 6

Condenação

– com reserva, 311, 1.3

– para o futuro, 323, 2

Condições da ação, 330, 3

– Interesse processual, 330, 1, 2

– Legitimidade de partes, 319, 2, 4; 330, 2

– Possibilidade jurídica do pedido, 330, 2

Conexão, 327, 2, 4

Consideração das posições em disputa, 297, 8

Consignação (de prestações vincendas), 323, 3; 330, 7

Constituição sumária, 304, 7

Contestação, 313, 11; 327, 4; 331, 2, 5, 6; 332, 6

Controle

– da decisão, 297, 3

– da justificativa, 297, 3

Convenção das partes, 313, 10; 314, 2

Convicção, 298, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

– de probabilidade, 297, 8, 9, 10

– Justificativa da convicção de probabilidade, 297, 1, 2

Correção da petição inicial, 321, 1; 321, 2; 321, 3; 330, 4

Credibilidade das alegações, 297, 7

Critérios decisórios, 297, 1



## Cumulação

- alternativa, 326, 1; 326, 2, 3
- aparente, 327, 1
- de ações, 326, 1; 327, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- das ações cautelar e principal, 308, 5
- de pedidos, 326, 1; 327, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- eventual, 326, 1, 2, 3
- imprópria, 326, 1
- objetiva, 327, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- subjetiva, 327, 1
- sucessiva, 327, 1, 3, 4
- ulterior de pedidos, 327, 5

## Custas, 295

Decadência, 302, 2; 310, 2; 316, 3; 332, 4

Decisão apoiada, 313, 3, 8

Declaração sumária, 304, 7

Defeitos da petição inicial, 321, 1, 2, 3, 4; 330, 4

## Defesa de mérito

- de não pronta solução, 311, 1.5.1
- direta infundada, 311, 4.1
- Fragilidade da defesa, 294, 5.3; 311, 1.1, 1.5.2
- indireta infundada, 311, 1.5.2
- Incompatibilidade entre a defesa de mérito indireta e a contestação dos fatos constitutivos, 311, 2.1, 2.2, 2.3
- inconsistente, 294, 5.3; 311, 1.1, 1.4, 1.5.2
- infundada, 294, 5.3; 311, 1.1, 1.5.2
- Justificativa da tutela da evidência em caso de defesa de mérito indireta infundada, 311, 5
- Reserva da cognição da defesa indireta infundada, 311, 2

## Definição

- de tutela cautelar, 301, 1
- legislativa, 301, 1

Denúnciação da lide, 319, 10; 327, 1; 327, 5

Destinatário da petição inicial, 319, 2

Dever

– de esclarecimento da defesa, 311, 2.4

– de esclarecimento, 321, 2

– de manifestação sobre os fatos narrados na petição inicial, 311, 2.4

– de prevenção, 321, 2

– de veracidade, 311, 2.4

Diferença entre os procedimentos das tutelas antecipada e cautelar antecedentes, 305, 1

Dificuldade da prova, 298, 7

Direito

– conexo, 300, 3

– provável, 300, 4

Direitos fundamentais processuais, 311, 7

Direitos indisponíveis

– e estabilização da tutela, 304, 11

Distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada, 294, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.3; 300, 1; 301, 1

Distribuição do tempo do processo, 294, 5

Documento substancial, 320, 5

Documentos indispensáveis, 320, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 321, 1; 330, 4

Efeitos

– da revelia, 307, 1

– fáticos, 300, 9.2

– irreversíveis, 300, 9

Efetivação da tutela de urgência, 297, 3, 4, 5

Eficácia

– da tutela durante a suspensão do processo, 296, 6

– temporal da tutela de urgência, 296, 1

Eleição do meio executivo adequado, 297, 2

Emenda da petição inicial, 303, 4; 321, 1, 2, 3, 4; 330, 4, ver também petição inicial

Especificação de provas, 319, 2, 8, ver prova

Espécies de tutelas dos direitos, 294, 6.4; 298, 6

## Estabilidade

- da demanda, 329, 1, 2
- da reconvenção, 329; 4

## Estabilização da tutela

- antecipada incidente, 304, 3
- antecipada, 304, 6
- contra a Fazenda Pública, 304, 11
- e direitos indisponíveis, 304, 11
- e extinção do processo, 304, 5
- e reexame necessário, 304, 11
- Fundamentos da, 304, 1
- Requisitos, 304, 4

Evidência do direito, 311, 1.1, 1.4, 2, 3, 4, ver também tutela da evidência

Exceção, 297, 7, 319, 5; Cap. II, Seq. II, 5; 328, 2

- do contrato não cumprido, 319, 5

## Execução

- da tutela da evidência, 297, 6; 311, 12
- imediata diante da improcedência dos embargos no procedimento monitório, 311, 3.5
- provisória

Exemplo de tutela cautelar, 301, 2

Expansão da tutela cautelar, 294, 2.4

Extinção do processo, Liv. VI, Tít. III, 1; 316, 2, 3; 317, 1, 2; 330, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 331, 1; 332, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- diante do não aditamento da inicial, 303, 2, 3, 4
- e estabilização da tutela, 304, 5

Falta de aditamento da petição inicial, 303, 2, 3, 4

Fases do processo, 318, 4

## Fato

- constitutivo, 311, 2; 322, 3; 319, 5
- extintivo, 311, 2; 319, 5
- impeditivo, 311, 2; 319, 5
- modificativo, 311, 2; 319, 5

Fazenda Pública, 300, 10; 304, 11

- e estabilização da tutela, 304, 11
- Proibição de tutela urgente contra a, 300, 10
- Reexame necessário e estabilização da tutela, 304, 11

Formação do processo, Liv. VI, 1; Liv. VI, Tít. I, 1, 2; 312, 1, 2, 3, 4

Força maior, 313, 16

Fragilidade da defesa, 294, 5.3; 311, 1.1, 1.5.2

Fundamentação, 298, 1, 2

Fundamentos da estabilização da tutela, 304, 1

Fungibilidade entre as tutelas cautelar e antecipada, 305, 5

Generalização do significado de inércia do réu, 304, 2

Herdeiros, 313, 6

Hipóteses

- de cessação da eficácia, 302, 2; 309, 2, 3, 4
- de reponsabilidade objetiva, 302, 2
- do art. 311, 311, 8

Ilícito, 294, 3.1

- não danoso, 294, 3.1

Impedimento, 313, 11

Improcedência parcial liminar do pedido, 332, 7

*Inaudita altera parte*, 300, 5

Incidente, 294, 6.6

- de assunção de competência; 332, 2, 3, 4
- de resolução de demandas repetitivas, 313; 13; 332, 2, 3, 4

Incompetência, 299, 3

Inconsistência da defesa, 294, 5.3; 311, 1.1, 1.5.2

Inconstitucionalidade, 300, 10; 311, 9

- da proibição de tutela urgente contra a Fazenda Pública, 300, 10
- da tutela da evidência antes da ouvida do réu, 311, 9

Indeferimento da petição inicial, 330, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 331, 1, 2, 3, 4

Independência das instâncias cível e criminal, 315, 1

Inépcia da petição inicial, 330, 1, 2, 6, 7

Inércia do demandado, 304, 1, 2

Instrumentalidade, 294, 1.4

Interesse processual, 330, 1, 2

Interrupção do processo, Liv. VI, Tít. II, 1

Irregularidades da petição inicial, 321, 1, 2

Irreversibilidade, 300, 9

Juiz incompetente, 299, 3

Juízo

- arbitral, 316, 3; 329, 2
- de retratação, 331, 1, 5; 332, 6
- de verossimilhança, 294, 2.3

Julgamento

- liminar de improcedência, 332, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- parcial de mérito, 332, 7

Justificativa, 298, 1, 2

- da convicção de probabilidade, 297, 1, 2
- da tutela da evidência em caso de defesa de mérito indireta infundada, 311, 5
- prévia, 300, 6

Legitimidade de partes, 319, 2, 4; 330, 2

Liminar, 300, 5

Liquidação da indenização, 302, 3

Liquidação da sentença, 324, 1, 7

Litisconsórcio, 319, 4; 321, 3; 327, 1, 4; 331, 3

Litispêndência, 312, 1, 3; Liv. VI, Tít. II, 1; 313, 14; Liv. VI, Tít. III, 1; 316, 3; 319, 2; 330, 6

Medida idônea, 301, 2

Medidas de urgência, 314, 1, 2, 3, 4, 5

Meio executivo adequado, 297, 2

Meios de prova, 319, 8, ver prova

Modificação da petição inicial, 329, 1, 2, 3, 4

Modificação da tutela de urgência, 296, 3, 4, 5

Modificação da tutela estabilizada, 304, 8

Momento, 300, 5, 7

Morte

– da parte, 313, 1, 2, 4, 5, 6, 7

– do advogado da parte, 313, 1, 2, 4, 5, 6, 7

Multa, 297, 3, 5.2

– e antecipação de soma, 297, 5.2

– e entrega de coisa, 297, 3

– e fazer, 297, 3

– e não fazer, 297, 3

Não contestação, 311, 2.1

Não satisfatividade da tutela cautelar, 294, 1.3

Negócios processuais, 313, 10; 327, 7

*Nulla executio sine titulo*, 294, 5.2

Obrigação

– alternativa, 325, 1

– de propor a ação principal, 308, 3; 309, 2

– de trato sucessivo, 322, 2

– incontroversa, 330, 7

– indivisível, 328, 1, 2

Ônus

– da afirmação, 319, 1, 2, 5

– da prova, 311, 5.1

– do tempo do processo, 294, 5, 311, 5

Ônus da prova, 311, 5.1

– como critério de distribuição do ônus do tempo do processo, 294, 5, 311, 5

Origem da tutela cautelar, 294, 2.1, 2.2, 2.3

Ouvida do réu, 300, 5

Partes

– Convenção das, 313, 10; 314, 2

– Legitimidade de, 319, 2, 4; 330, 2

– na petição inicial, 319, 2, 4

– Qualificação das, 319, 2, 4

#### Pedido

– alternativo, 325, 1, 2, 3

– certo, 322, 1, 2, 3

– classificação, 319, 5; Cap. II, Seç. II, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– conceito, 319, 5; Cap. II, Seç. II, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– Concurso de pedidos (ou de ações), 327, 1, 6

– condenatório, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1

– constitutivo, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1

– Cumulação de, 326, 1; 327, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

– declaratório, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1

– determinado, 324, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

– executivo, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1

– facultativo, 325, 3

– genérico, 324, 2, 3, 4, 5, 6

– imediato, 319, 6; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 8; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1; 324, 2; 325, 1; Cap. II, Seç. II, 8; Cap. III, Seç. II, 9

– implícito, 322, 2

– Improcedência parcial liminar do, 332, 7

– Interpretação do, 322, 3

– mandamental, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1

– mediato, 319, 6; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 8; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 9; 322, 1; 324, 2; 325, 1; Cap. II, Seç. II, 8; Cap. III, Seç. II, 9

– Possibilidade jurídica do pedido, 330, 2

– principal, 305, 2; 308, 1

– reipersecutório, 311, 8.3

– Renovação do pedido cautelar, 309, 5

Penhora on-line, 297, 5.3

Perempção, 326, 3; 313, 10; 330, 5

– da prorrogação dos efeitos concretos da conduta ilícita, 300, 2

– de ato contrário ao direito, 300, 2



– de dano, 300, 1

– de ilícito, 300, 2

Perigo de irreversibilidade, 300, 9

Perspectiva

– horizontal do processo, 318; 5

– vertical do processo, 318; 6

Petição inicial

– aditamento, 303, 3, 4; 319, 10; 329, 1, 2, 3

– admissibilidade, 330, 1

– conceito de, 303, 2; 305, 4.

– Correção da, 321, 1; 321, 2; 321, 3; 330, 4

– da cautelar antecedente, 305, 4

– Defeitos da, 321, 1, 2, 3, 4; 330, 4

– Destinatário da, 319, 2

– Emenda da, 303, 4; 321, 1, 2, 3, 4; 330, 4

– Indeferimento, 330, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 331, 1, 2, 3, 4

– Inépcia da, 330, 1, 2, 6, 7

– Irregularidades da, 321, 1, 2

– Modificação da, 329, 1, 2, 3, 4

– Partes na, 319, 2, 4

– Recebimento da, 319, 1, 321, 4; 330, 1; 331, 4

Possibilidade jurídica do pedido, 330, 2

Prazo

– da ação de revisão da tutela estabilização, 304, 9

– para contestar e tutela estabilizada, 303, 3

Precedente, 332, 2, 3, 4

Preclusão, 313, 6, 7, 13; 319, 8; 320, 1, 5, 7; 321, 4; 329, 1, 2; 331, 2

– pro judicato, 316, 2; 321, 4; 331, 1, 4, 6

Prescrição, 302, 2; 310, 2; 332, 4, 5, 7

Pressupostos

– da tutela contra o ilícito, 294, 3.1

– processuais, Liv. IV, Tít. I, 2; 313, 1, 7, 9; 316, 3; 320, 2; 326, 2; 330, 3, 5

– recursais, 331, 1; 332, 6

Prestações sucessivas, 323, 1

Presunção, 312, 1; 319, 5; 323, 2

– de ocorrência dos fatos alegados, 307, 1

– de veracidade, 313, 7

Preventividade e Cautelaridade, 294, 1.6

Princípio

– da congruência (ou correlação), Liv. I, Tít. I, Seq. II, 4; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 5; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 6.

– da inércia da jurisdição, Liv. I, Tít. I, Seq. II, 1

– da tipicidade das formas executivas, 297, 1

– da instrumentalidade, Liv. VI, Tít.III, 1; 316, 2; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 6

– da sanabilidade; 317, 2

– da demanda, Liv. I, Tít. I, Seq.II, 4, 1; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 1; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 3; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 4; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 5; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 6; Liv. I, Tít. I, Seq. II, 7

Prisão, 297, 4

Probabilidade, 300, 4

– e tutela da evidência, 297, 10

– e tutela urgência, 297, 5, 9

Procedimento

– comum, 318, 1, 2, 3, 4, 5, 6

– da tutela antecipada antecedente, 303, 3, 4

– da tutela cautelar antecedente, 305, 1, 2, 4, 6

– em caso de tutela antecipada concedida, 303, 3

– em caso de tutela antecipada indeferida, 303, 4

Procurador, Liv. I, Tít. II, 1; 313, 5, 7, 9

Procuração, 314, 1; 319, 10; 320, 2

Proibição do *ne bis in idem*, 309, 5

Protesto contra a alienação de bens, 301, 2

Prova

– admissível no procedimento cautelar, 306, 6

- Dificuldade da, 298, 7
- documentada, 311, 3.1
- documental, 313, 6; 318, 5; 320, 3, 4, 5
- emprestada, 311, 4.2
- escrita, 311, 3.3
- Especificação da, 319, 2, 8
- Meios de, 319, 8
- Ônus da, 311, 5.1
- Técnica da prova dos fatos constitutivos, 311, 3
- Tutela da evidência e prova do núcleo do fato constitutivo, 311, 4.3
- Tutela da evidência e prova emprestada, 311, 4.2
- Providência diversa da requerida, 301, 3
- Provisoriedade, 294, 6.1
- Qualificação das partes, 319, 2, 4
- Querela *nullitatis*, Liv. VI, Tít. I, 2
- Questão
  - de direito, 330, 3; 332, 2, 3, 4
  - de fato, 330, 3
  - preliminar, 313, 11, 14
  - prejudicial externa, 313, 14, 18; 314, 3; 315, 1, 2
- Questão prejudicial, 313, 14, 18, 19; 314, 1, 2; Liv. I, Seq. II, 5; 327, 3
  - heterogênea, 313, 14, 18, 19
  - homogênea, 313, 14, 18, 19
  - interna, 313, 14, 18, 19
- Racionalidade, 297, 1, 3
- Reação do demandado, 304, 2, 4
- Recebimento da petição inicial, 321, 4; 330, 1; 331, 4
- Reconvenção, 316, 3; 318, 3, 5; 320, 6; 324, 6; 327, 5; 329, 4
- Recurso repetitivo, 332, 2, 3, 4
- Reexame necessário, 304
  - e estabilização da tutela, 304, 11

Referibilidade, 294, 1.5

Renovação do pedido cautelar, 309, 5

Reparação dos danos provocados pela execução, 297, 7, 302, 1, 2, 3

Representante da parte, 313, 4, 7, 9; 314, 2

Requisitos

- da inicial da cautelar antecedente, 305, 4

- da inicial da tutela antecipada antecedente, 303, 2

- da tutela da evidência, 311, 1.4

- da tutela de urgência, 296, 1

- para a estabilização da tutela, 304, 4

Reserva da cognição da defesa indireta infundada, 311, 2

Responsabilidade

- em caso de cessação da eficácia, 302, 2

- em caso de sentença desfavorável, 302, 2

- objetiva, 302, 2

- pelos danos, 302, 1

- quando acolhida a prescrição ou a decadência, 302, 2

Restituição das coisas no estado anterior, 297, 7

Revelia, 313, 7; Tít. I, Cap. II, Seç. II, 7; 325, 2; 331, 2, 6.

Revisão da tutela estabilizada, 304, 8

Revogação

- da tutela da evidência, 311, 11

- da tutela de urgência, 296, 3, 4

- no tribunal, 296, 4

Sanabilidade, 330, 6

Saneamento, 313, 15; 329, 1, 2

Sentença

- Conceito, 316, 1, 2, 3; Cap. II, Seç. II, 9

- condenatória, Cap. II, Seç. II, 9; 318, 5; 323, 2, 3; 324, 7

- constitutiva, Cap. II, Seç. II, 9

- declaratória, Cap. II, Seç. II, 9; 324, 7

- e tutela da evidência, 311, 13
- e tutela de urgência, 300, 7
- executiva, Cap. II, Seç. II, 9
- Liquidação da, 324, 1, 7
- mandamental, Cap. II, Seç. II, 9
- Sequestro, 301, 2
- Sucumbência, 313, 13; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 4; 322, 2; 324, 7, 327, 1, 2, 3
- Suspeição, 313, 11, 12; 314, 3, 5
- Suspensão
  - do processo, 313, 1, 2, 3, 4; 313; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 314, 1, 2, 3, 4, 5
  - dos efeitos da tutela da evidência, 311, 11
- Súmula, 322, 2, 3, 4
- Técnica da prova dos fatos constitutivos, 311, 3
- Teoria da substanciação, 319, 5; Liv. I, Cap. II, Seç. II, 4
- Tese firmada por Corte Suprema, 311, 8.2
- Tribunal marítimo, 313, 17; 314; 2, 3
- Tutela
  - de segurança, 294, 1.2; 301, 1, 2
  - de urgência na sentença, 300, 7
  - de remoção do ilícito, 294, 3.4, 3.6
  - do direito, 317, 1; 294, 6.4; 298, 6
  - específica, 294, 6.4
  - incidente, 299, 1
  - incidente e estabilização, 304, 3
  - inibitória, Liv. VI, Tít. III, 1; 323, 2, 3; 294, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
  - liminar, 300, 5
  - provisória, 294, 6, ver tutela cautelar e tutela antecipada
  - urgente requerida na forma antecedente, 299, 1
  - dos direitos, 294, 6.4; 298, 6
- Tutela antecipada
  - antecedente, 303, 3, 4

- concedida, 303, 3
- constitutiva, 294, 2.6; 304, 7
- contra a Fazenda Pública, 300, 10, 304, 11
- de pagamento de soma, 297, 5
- declaratória, 294, 2.6; 304, 7
- e tutela cautelar (diferença), 294, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.3; 300, 1; 301, 1
- e zona de penumbra, 294, 2.6
- Fungibilidade entre as tutelas cautelar e antecipada, 305, 5
- indeferida, 303, 4
- na ação ressarcitória, 297, 5.4
- Não apresentação dos meios necessários à citação, 302, 2
- no procedimento monitório, 311, 3.4

#### Tutela antecipada antecedente

- e tutela cautelar antecedente (diferença), 305, 1
- Indicação do pedido de tutela final; 303, 3
- Invalidação da tutela estabilizada, 304, 8
- Petição inicial, 303, 2
- Procedimento, 303, 3, 4
- Urgência justificadora, 303, 1

#### Tutela cautelar

- antecedente, 305, 1, 2, 4, 6
- Conceito, 294, 1.1
- Definição, 301, 1
- e ação constitutiva, 294, 2.6
- e ação declaratória, 294, 2.6
- e tutela antecipada (diferença), 294, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.3; 300, 1; 301, 1
- Exemplo de, 301, 2
- Expansão da, 294, 2.4
- Fungibilidade entre as tutelas cautelar e antecipada, 305, 5
- Não apresentação dos meios necessários à citação, 302, 2
- Não satisfatividade da tutela cautelar, 294, 1.3

- Origem da, 294, 2.1, 2.2, 2.3
- Petição inicial da cautelar antecedente, 305, 4
- Provas admissíveis no procedimento cautelar, 306, 6
- Renovação do pedido cautelar, 309, 5
- Requisitos da inicial da cautelar antecedente, 305, 4
- Transformação da tutela cautelar, 294, 2
- Tutela cautelar antecedente, 305, 1, 2, 4, 6
- e tutela antecipada antecedente (diferença), 305, 1
- Petição inicial, 305, 4
- Procedimento, 305, 1, 2, 4, 6
- Urgência justificadora, 305, 3
- Não efetivação da tutela em trinta dias, 309, 3
- Não propositura da ação principal, 309, 2
- Tutela contra o ilícito, 294, 3.1
- Autonomia da, 294, 2, 4, 4.2
- Pressupostos da, 294, 3.1
- Tutela da evidência, 311, 1
- antes da ouvida do réu, 311, 9
- cláusula geral da, 311, 8
- e contestação dos elementos secundários ao núcleo do fato constitutivo, 311, 4.3
- e contestação genérica, 311, 13.1
- e contrato de depósito, 311, 8.3
- e comparecimento e não apresentação de contestação, 311, 13.2
- e dever de esclarecimento da defesa, 311, 2.4
- e dever de manifestação sobre os fatos narrados na petição inicial, 311, 2.4
- e incompatibilidade entre a defesa de mérito indireta e a contestação dos fatos constitutivos, 311, 2.1, 2.2, 2.3
- e não contestação, 311, 2.1
- e probabilidade, 297, 10
- e prova do núcleo do fato constitutivo, 311, 4.3
- e prova documentada, 311, 3.1
- e prova documental, 313, 6; 318, 5; 320, 3, 4, 5



- e prova emprestada, 311, 4.2
- e prova escrita, 311, 3.3
- e técnica da prova dos fatos constitutivos, 311, 3
- em defesa de mérito direta infundada, 311, 4
- em caso de defesa de mérito indireta infundada, 311, 5
- hipóteses específicas de cabimento, 311, 8
- mediante técnica monitoria, 311, 3.6
- Execução, 297, 6
- Momento de concessão, 311, 10
- na sentença, 311, 13
- no procedimento monitorio, 311, 3.2, 3.4
- Requisitos, 311, 1.4
- Revogação, 311, 11
- Suspensão, 311, 11

#### Tutela de urgência

- Efetivação, 297, 3, 4, 5
- Eficácia temporal, 296, 1
- Manutenção, 296, 2
- Modificação, 296, 3, 4, 5
- Não apresentação dos meios necessários à citação, 302, 2
- Requisitos, 296, 1
- Revogação, 296, 3, 4

Tutela provisória, ver tutela de urgência e tutela da evidência

#### Universalidade

- de direito, 324, 3
- de fato, 324, 3

#### Urgência, 300, 1; 303, 1

- justificadora da tutela antecipada antecedente, 303, 1
- que legitima a cautelar antecedente, 305, 3

Valor da causa, 303, 2; 319, 7; 324, 4; 327, 2, 3

Zona de penumbra – tutelas cautelar e antecipada, 294, 2.6



## Referências Bibliográficas

---

ALBERTO CARBONE, Carlos. Los procesos urgentes y la anticipación de la tutela. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 21. Curitiba: Gênese, jul./set., 2001.

ALEXY, Robert. *Teoría de los derechos fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.

AMENDOLARA, Zulma; BERIZONCE, Roberto; BERMEJO, Patricia. *Tribunales y proceso de familia*. La Plata: Platense, 2001.

AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. *Revista de direito processual civil*. vol. 3. São Paulo, jan.-jun. 1961.

AMRANI-MEKKI, Soraya. *Le temps et le procès civil*. Paris: Dalloz, 2002.

ANDOLINA, Italo. “Cognizione” ed “esecuzione forzata” nel sistema della tutela giurisdizionale. Milano: Giuffrè, 1983.

\_\_\_\_\_. *Contributo alla dottrina del titolo esecutivo*. Milano: Giuffrè, 1982.

\_\_\_\_\_; VIGNERA, Giuseppe. *Il modello costituzionale del processo civile italiano*. Torino: Giappichelli, 1990.

ANDRADE, Érico; THEODORO JR., Humberto. A autonomização e a estabilização da tutela de urgência no Projeto de CPC. *Revista de Processo*. vol. 206.

ANDRADE, Manuel Domingues de. *Noções elementares de processo civil*. Coimbra: Coimbra, 1979.

ANDREWS, Neil. *Andrews on civil processes*. Cambridge: Intersentia, 2013. vol. I.

ANDRIOLI, Virgilio. Prova. *Novissimo Digesto Italiano*. vol. 143.

ARAGÃO, Egas Moniz de. *Exegese do Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: AIDE, 1986.

\_\_\_\_\_. Medidas cautelares inominadas. *Revista Brasileira de Direito Processual*. vol. 57. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

ARENHART, Sérgio Cruz. Ônus da prova e relações de consumo. In: CONRADO, Marcelo (org.). *Repensando o direito do consumidor – 15 anos do CDC*. Curitiba: Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, 2005.

\_\_\_\_\_. “Reflexões sobre o princípio da demanda”. *Processo e constituição: estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira*. Coord. Luiz Fux, Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2006

\_\_\_\_\_. Sentença condenatória para quê? In: COSTA, Eduardo José da Fonseca; MOURÃO, Luiz

- Eduardo Ribeiro; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). *Teoria quinária da ação* – estudos em homenagem a Pontes de Miranda nos 30 anos de seu falecimento. Salvador: JusPodivm, 2010.
- \_\_\_\_\_. Tutela coletiva e o controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário. In: MAZZEI, Rodrigo; NOLASCO, Rita Dias (coord.). *Processo civil coletivo*. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- \_\_\_\_\_. *A tutela inibitória coletiva*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Perfis da tutela inibitória coletiva*. São Paulo: RT, 2003.
- \_\_\_\_\_; MARINONI, Luiz Guilherme. *Execução*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Processo de Conhecimento*. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Prova e Convicção*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. MITIDIERO, Daniel. *Novo Curso de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016. vol. 2.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- ARIETA, Giovanni. *I provvedimenti d'urgenza*. Padova: CEDAM, 1982.
- ARMELIN, Donaldo. A tutela jurisdicional cautelar. *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo*. vol. 23.
- \_\_\_\_\_. Acesso à justiça. *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo*. vol. 31.
- ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. *Manual de direito processual civil*. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. II.
- \_\_\_\_\_. *Novo contencioso cível no CPC/2015*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Controle das decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e de ação rescisória*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Nulidades do processo e da sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1998.
- \_\_\_\_\_; MEDINA, José Miguel Garcia. *O dogma da coisa julgada*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- \_\_\_\_\_; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de; *Primeiros comentários ao novo código de processo civil artigo por artigo*. São Paulo: RT, 2015.
- ASSIS, Araken de. *Manual da execução*. 12. ed. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- ATTARDI, Aldo. *Le nuove disposizioni sul processo civile*. Padova: Cedam, 1991.
- \_\_\_\_\_. Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma. *Giurisprudenza italiana*, 1992.
- AZEVEDO, Luiz Carlos de; CRUZ E TUCCI, José Roberto. *Lições de processo civil canônico*. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- BARASSI, Lodovico. *La teoria generale delle obbligazioni*. Milano: Giuffrè, 1964.
- BARBERIO, Sergio. *La medida autosatisfactiva*. Santa Fé: Panamericana, 2006.
- BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao código de processo civil*. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. vol. I.

- \_\_\_\_\_. *Comentários ao código de processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1975. vol. I, t. II.
- BARBOSA, Andrea Carla. Direito em expectativa: as tutelas de urgência e evidência no projeto de novo código de processo civil: Breves comentários. *Revista de Processo*. v. 194.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A desinformação jurídica. *Temas de direito processual* – 6ª série. São Paulo: Saraiva, 1997.
- \_\_\_\_\_. As bases do direito processual civil. *Temas de direito processual* – 1ª série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
- \_\_\_\_\_. Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo. *Temas de direito processual* – 2ª Série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
- \_\_\_\_\_. O processo, as partes e a sociedade. *Temas de direito processual* – 8ª série. São Paulo: Saraiva, 2004.
- \_\_\_\_\_. O que deve e o que não deve figurar na sentença. *Temas de direito processual* – 8ª série. São Paulo: Saraiva, 2005.
- \_\_\_\_\_. Os novos rumos do processo civil brasileiro. *Temas de direito processual civil* – 6ª série. São Paulo: Saraiva, 1997.
- \_\_\_\_\_. Por um processo socialmente efetivo. *Temas de direito processual* – 8ª série. São Paulo: Saraiva, 2004.
- \_\_\_\_\_. Processo civil e processo penal: mão e contramão? *Temas de direito processual* – 7ª série. São Paulo: Saraiva, 2001.
- \_\_\_\_\_. Reformas processuais e poderes do juiz. *Temas de direito processual*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1999. vol. I.
- \_\_\_\_\_. *O novo processo civil brasileiro*. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. *Precedentes judiciais e segurança jurídica*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- BARCELLOS, Leonardo de Souza Naves. As hipóteses de tutela de evidência previstas no novo CPC. *Revista de Processo*. vol. 254.
- BARROS, Hamilton de Moraes e. *Comentários ao código de processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, s/d.
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo código de processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- \_\_\_\_\_. Tutela provisória: considerações gerais. *O novo Código de Processo Civil: Questões controvertidas*. São Paulo: Gen-Atlas, 2015.
- \_\_\_\_\_.; CRUZ E TUCCI, José Rogério (coord.). *Causa de pedir e pedido no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- BELLOCCHI, Roberto Antonio Vallim. A tutela da evidência: irreversibilidade. *Revista de Processo*. vol. 252.
- BENETI, Sidnei. O NURER – núcleo de recursos repetitivos do STJ e o novo recurso especial, In: GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia (coord.) *O papel da jurisprudência no STJ*. São Paulo: Ed. RT, 2014.

- BERIZONCE, Roberto Omar. *Efectivo acceso a la justicia*. La Plata: Platense, 1987.
- \_\_\_\_\_; BERMEJO, Patricia; AMENDOLARA, Zulma. *Tribunales y proceso de familia*. La Plata: Platense, 2001.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Tribunales y proceso de familia*. La Plata: Platense, 2001.
- BERMUDES, Sérgio. *Direito processual civil – estudos e pareceres – 2ª série*. São Paulo: Saraiva, 1994.
- BEZERRA, J. Miguel; VARELA, Antunes; NORA, Sampaio e. *Manual de processo civil*. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1985.
- BIDART, Adolfo Gelsi. Tutela procesal diferenciada. *RePro*. vol. 44.
- BIELSA, Rafael; GRAÑA, Eduardo. El tiempo y el proceso. *Revista del Colegio de Abogados de La Plata*. vol. 55.
- BORE, Louis. L'autorité provisoire de la chose jugée. In: CADIET, Loïc ; LORIFERNE, Dominique (dir.). *L'autorité de la chose jugée*. Paris: IRJS, 2012.
- BORGHESI, Domenico. L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1991.
- BORRÈ, Giuseppe. *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*. Napoli: Jovene, 1966.
- \_\_\_\_\_. Verso la riforma del codice di procedura civile? *Riflessi sulla disciplina dell'esecuzione forzata nel disegno di legge delega n. 1.463*. Foro italiano, 1983.
- BUENO, Cassio Scarpinella. *Novo código de processo civil anotado*. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2015.
- BÜLOW, Oskar von. *Teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales*. Trad. Miguel Angel Rosas Lichtschein. Buenos Aires: EJE, 1964.
- BUSTAMANTE, Thomas da Rosa. *Teoria do precedente judicial*. São Paulo: Noeses, 2012.
- BUZAID, Alfredo. *Do agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1956.
- CABRAL, Antonio do Passo. *Convenções processuais – entre publicismo e privatismo*. Tese de livre docência apresentada à Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
- CADIET, Loïc. *Code de Procédure Civile*. Paris: LexisNexis, 2016.
- \_\_\_\_\_; JEULAND, Emmanuel. *Droit Judiciaire Privé*. Paris: LexisNexis, 2016.
- CALAMANDREI, Piero. La condanna “generica” ai danni. Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1972. vol. V.
- \_\_\_\_\_. Líneas fundamentales del proceso civil inquisitorio. *Estudios sobre el proceso civil*. Trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945.
- \_\_\_\_\_. *Instituciones de derecho procesal civil*. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: El Foro, 1996. vol. I.
- \_\_\_\_\_. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Buenos Aires: EBA, 1945.
- \_\_\_\_\_. Verità e verosimiglianza nel processo civile. *Rivista di Diritto Processuale*, 1955.

- CALMON DE PASSOS, José Joaquim. *Comentários ao código de processo civil*. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. vol. III.
- CAMBI, Eduardo, DOTTI, Rogéria, PINHEIRO, Paulo Eduardo d'Arce, MARTINS, Sandro Gilbert, KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. *Curso de processo civil completo*. São Paulo: RT, 2017.
- CANARIS, Claus-Wilhelm. *Direitos fundamentais e direito privado*. Trad. Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2003.
- CANOTILHO, Joaquim Gomes. *Direito Constitucional*. Coimbra: Almedina, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Estudos sobre direitos fundamentais*. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.
- CANOVA, Augusto Cerino. La domanda giudiziale ed il suo contenuto. *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Torino: UTET, 1980.
- CAPONI, Remo. La tutela sommaria nel processo societario in prospettiva europea. *Studi in onore di Giuseppe Tarzia*. Milano: Giuffrè, 2005.
- CAPPELLETTI, Mauro. *Acesso à justiça*. Porto Alegre: Fabris, 1988.
- \_\_\_\_\_. Acesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero. *Rivista di Diritto Processuale*, 1982.
- \_\_\_\_\_. *El testimonio de la parte em el sistema de la oralidad* – Primeira parte. Trad. Tomás A, Banzhaf. La Plata: Librería Editora Platense, 2002.
- \_\_\_\_\_. La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Milano: Giuffrè, 1962. vol. 1.
- \_\_\_\_\_; GORDLEY, James; JOHNSON Jr., Earl. *Toward equal justice: a comparative study of legal aid in modern societies*. Milano: Giuffrè, 1981.
- CAPPONI, Bruno. Sull'esecuzione-attuazione dei provvedimenti d'urgenza per condanna al pagamento di somme. *Rivista di Diritto Processuale*, 1989.
- \_\_\_\_\_; VACCARELLA, Romano; CECCHELA, Claudio. *Il processo civile dopo le riforme*. Torino: Giappichelli, 1992.
- CARNELUTTI, Francesco. *La prova civile*. 2. ed. Roma: Ateneo, 1947.
- \_\_\_\_\_. *La prova civile*. Roma: Edizioni dell'ateneo, 1947.
- \_\_\_\_\_. *Teoria generale del diritto*. Roma, 1951. v. 1.
- \_\_\_\_\_. *Diritto e processo*. Napoli: Morano, 1959.
- \_\_\_\_\_. Titolo esecutivo. *Rivista di Diritto Processuale Civile*, 1931.
- CARPI, Federico. Flashes sulla tutela giurisdizionale differenziata. *Rivista trimestrale de diritto e procedura civile*. Padova: Cedam, n 1/239, 1980.
- \_\_\_\_\_. Provvedimenti interinali di condanna, esecutorietà e tuteladelle parti. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1977.
- \_\_\_\_\_. Profili sistematici della tutela cautelare. *I procedimenti cautelari*. Bologna: Zanichelli, 2013.
- CASTELO, Jorge Pinheiro. *Tutela antecipada*. São Paulo: LTR, 1999, vol. 1.
- CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. *O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.



- CAVALCANTI, Marcos de Araújo. *Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR)*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- CAVALCANTI NETO, Antonio de Moura. Possibilidade de concessão de tutela da evidência contra a Fazenda Pública no projeto de novo Código de Processo Civil: sobre acreditar ou não no acesso à justiça. *Revista de Processo*. vol. 238.
- CAVALLONE, Bruno. *Il giudice e la prova nel processo civile*. Padova: Cedam, 1991.
- CECCHIELLA, Claudio.; VACCARELLA, Romano; CAPPONI, Bruno. *Il processo civile dopo le riforme*. Torino: Giappichelli, 1992.
- CIANCI, Mirna. A estabilização da tutela antecipada como forma de desaceleração do processo (uma análise crítica). *Revista de Processo*. vol. 247.
- COLESANTI, Vittorio. Misure coercitive e tutela dei diritti. *Rivista di Diritto Processuale*, 1980.
- COLLIA, Filippo. L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro. *Rivista di Diritto Processuale*, 1994.
- COMOGLIO, Luigi Paolo. Note riepilogative su azione e forme di tutela, nell'ottica della domanda giudiziale. *Scritti in onore di Elio Fazzalari*. Milano: Giuffrè, 1993. vol. II.
- \_\_\_\_\_. *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca). Bologna-Roma: Zanichelli-Foro Italiano, 1981.
- \_\_\_\_\_; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele. *Lezioni sul processo civile*. Bologna: Il Mulino, 1995.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2. ed. Bologna: il Mulino, 1998.
- COMOGLIO, Luigi Paolo. *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*. Padova: Cedam, 1970.
- \_\_\_\_\_. Le Prove. *Trattato di diritto privato* (diretto da Rescigno). v. 19.
- CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. *Primeiros comentários ao novo código de processo civil artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- CONSOLO, Claudio. *Un codice di procedura civile "seminuovo"*. Giurisprudenza italiana, 1990.
- COSTA, Eduardo José da Fonseca. Teoria trinária vs teoria quinária: crônica sobre um diálogo de surdos. In: COSTA, Eduardo José da Fonseca; MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). *Teoria quinária da ação – estudos em homenagem a Pontes de Miranda nos 30 anos de seu falecimento*. Salvador: JusPodivm, 2010.
- COSTA, Susana Henriques da. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo código de processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del derecho procesal civil*. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1958.
- CROZE, Hervé; MOREL, Cristian. *Procédure civile*. Paris: PUF, 1988.
- CUNHA, Alcides Alberto Munhoz da. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2001. vol. 11.
- CUNHA, Guilherme Cardoso Antunes da. Tutelas de urgência satisfativas autônomas. *Revista de Processo*. vol. 227.

- CUNHA GONÇALVES, Luiz da. *Tratado de direito civil*. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1958. vol. III, t. I.
- CHAINAIS, Cécile. *La protection juridictionnelle provisoire dans le procès civil en droits français et italien*. Paris: Dalloz, 2007.
- \_\_\_\_\_; GUINCHARD, Serge; FERRAND, Frédérique. *Procédure civile*. Paris: Dalloz, 2008.
- CHIARLONI, Sergio. *Introduzione allo studio del diritto processuale civile*. Torino: Giappichelli, 1975.
- \_\_\_\_\_. *Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile* (con particolare riguardo ai provvedimenti cautelari ed interinali). Foro Italiano, 1991.
- CHIOVENDA, Giuseppe. Identificazione delle azione, Sulla regola “ne eat iudex ultra petita partium”. *Saggi di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1993. vol. I.
- \_\_\_\_\_. L'azione nel sistema dei diritti. *Saggi di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1993. vol. I.
- \_\_\_\_\_. *Instituições de direito processual civil*. Trad. J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1943. vol. II.
- \_\_\_\_\_. *Instituições de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1965. vol. 1.
- \_\_\_\_\_. *Istituzioni di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 1960. vol. 1.
- \_\_\_\_\_. *Princípios de derecho procesal civil*. Trad. José Casais y Santaló. Madrid: Réus, 1925. vol. II.
- \_\_\_\_\_. Sulla perpetuatio iurisdictionis. *Saggi di diritto processuale civile*. Roma, 1930.
- CHOLET, Didier. *La célérité de la procédure en droit processuel*. Paris: LGDJ, 2006.
- CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Ed. RT, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Ação monitória*. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- \_\_\_\_\_; AZEVEDO, Luiz Carlos de. *Lições de processo civil canônico*. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- \_\_\_\_\_; BEDAQUE, José Roberto dos Santos (coord.). *Causa de pedir e pedido no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- DAMASKA, Mirjan. *The faces of justice and state authority*. New Haven: Yale University Press, 1986.
- DENTI, Vittorio. Diritti della persona e tecniche di tutela giudiziale. *L'informazione e i diritti della persona*. Napoli: Jovene, 1983.
- \_\_\_\_\_. Il processo di cognizione nella storia delle riforme. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1993.
- \_\_\_\_\_. Intervento. *La tutela d'urgenza*. Rimini: Maggioli, 1985.
- \_\_\_\_\_. *La giustizia civile*. Bologna: Il Mulino, 1989.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Fundamentos do processo civil moderno*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. t. I.
- \_\_\_\_\_. *A reforma do Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.

- \_\_\_\_\_. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001. t. IV.
- \_\_\_\_\_. O novo Código de Processo Civil brasileiro e a ordem processual civil vigente. *Revista de Processo*. vol. 247.
- \_\_\_\_\_; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. *Teoria geral do novo processo civil*. São Paulo: Malheiros, 2016.
- DOMIT, Otávio Augusto. *Iura novit curia e causa de pedir*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito. São Paulo: Saraiva, 2011.
- ECHANDÍA, Hernando Devis. *Teoria general del proceso*. 2. ed. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1997.
- FABRICIO, Adroaldo Furtado. “Suspensão do processo”. *Código de processo civil anotado*. Coord. José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho Aprigliano, Rogéria Fagundes Dotti, Sandro Gilbert Martins. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2016.
- FARIA, José Eduardo. As transformações do judiciário em face de suas responsabilidades sociais. In: FARIA, José Eduardo (org.). *Direitos humanos, direitos sociais e justiça*. São Paulo: Malheiros, 1994.
- FERRAND, Frédérique; CHAINAIS, Cécile; GUINCHARD, Serge. *Procédure civile*. Paris: Dalloz, 2008.
- FERRI, Corrado. Struttura del processo e modificazione della domanda. Padova: Cedam, 1975.
- FERRONI, Lanfranco. *Obblighi di fare ed eseguibilità*. Pubblicazioni della Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile dell’Università di Camerino, 1983.
- FICCARELLI, Beatrice. *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.
- FIGUEIRA JR., Joel Dias. *Comentários ao código de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2001. vol. 4., t. II.
- FISCHMANN, Gerson. *Comentários ao código de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- FORNACIARI JÚNIOR, Clito. O destinatário da norma do art. 686. n. V. do Código de Processo Civil [1973]. *Revista de Processo*. vol. 6.
- FREITAS JUNIOR, Horival Marques de. Breve análise sobre as recentes propostas de estabilização das medidas de urgência. *Revista de Processo*. vol. 225.
- FRIGNANI, Aldo. Inibitoria (azione). *Enciclopedia Giuridica Treccani*. vol. 17.
- \_\_\_\_\_. *L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano*. Milano: Giuffrè, 1974.
- \_\_\_\_\_. *L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano*. Aldo Frignani, Inibitoria (azione). *Enciclopedia del diritto*. v. 21.
- FRISINA, Pasquale. La tutela cautelare d’urgenza dei diritti a prestazioni pecuniarie. *Rivista di diritto processuale*, 1986.
- FULGÊNCIO, Tito. *Do direito das obrigações – das modalidades das obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 1958.
- FURNO, Carlo. *La sospensione del processo esecutivo*. Milano: Giuffrè, 1956.

- \_\_\_\_\_. *Teoría de la prueba legal*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1954.
- GABBAY, Daniela Monteiro. *Pedido e causa de pedir*. São Paulo: Saraiva, 2010.
- GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Apontamentos para a tutela provisória (urgência e evidência) no novo Código de Processo Civil brasileiro. *Revista de Processo*. vol. 254.
- GAIO. *Instituciones*. Trad. Manuel Abellan Velasco [et alli]. Madrid: Civitas, 1985.
- GAJARDONI, Fernando da Fonseca. São Paulo: Atlas, 2008.
- GALLOTTI, Maria Isabel. Recurso especial como instrumento de uniformização do direito federal. Coord. GALLOTTI, Isabel; DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; GAJARDONI, Fernando da Fonseca; MEDINA, José Miguel Garcia. *O papel da jurisprudência no STJ*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- GAMBA, Cinzia. Domande senza risposta – Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile, Padova: Cedam, 2008.
- GANUZAS, Francisco Javier Ezquiaga. *Iura novit curia y aplicación judicial del derecho*. Valladolid: Lex Nova, 2000.
- GARBAGNATI, Edoardo. *Il procedimento d'ingiunzione*. Milano: Giuffrè, 1991.
- GARCIA REDONDO, Bruno. Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência antecipada antecedente: principais controvérsias. *Revista de Processo*. vol. 244.
- GERALDES, António Santos Abrantes. *Temas da reforma do processo civil*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. v. I.
- GIANESINI, Rita. *Da revelia no processo civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 1977.
- GIANNINI, Amedeo. Gli studi di diritto processuale civile in Italia. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1949.
- GIANNOZZI, Giancarlo. La modificazione della domanda nel processo civile. Milano: Giuffrè, 1958.
- GIORGIANNI, Michele. Tutela del creditore e tutela “reale”. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1975.
- GODINHO, Robson. *Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo código de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- GOLDSCHMIDT, James. *Derecho procesal civil*. Trad. Leonardo Prieto Castro. Barcelona: Labor, 1936.
- GOMES, Fabio Luiz. *Carência de ação*. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Comentários ao código de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 3.
- GOMES, Orlando. *Obrigações*. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.
- GRAÑA, Eduardo; BIELSA, Rafael. El tiempo y el proceso. *Revista del Colegio de Abogados de La Plata*. vol. 55.
- GRECO, Leonardo. A tutela de urgência e a tutela da evidência no Código de Processo Civil de 2015. *Revista eletrônica de direito processual*. v. 14, n. 1, 2014, disponível em [www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/14541/15862].
- GRINOVER, Ada Pellegrini [et alli]. *Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos*

autores do anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

GUASTINI, Riccardo. *Teoria e dogmatica delle fonti*. Milano: Giuffrè, 1998.

GUERRA, Marcelo Lima. *Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil*. São Paulo: Ed. RT, 2003.

\_\_\_\_\_. *Execução indireta*. São Paulo: Ed. RT, 1999.

GUILLÉN, Víctor Fairen. *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*. Barcelona: Bosch, 1953.

GUIMARÃES, Milena de Oliveira. *O contempt of Court e a efetividade da tutela executiva*. Dissertação de Mestrado, São Paulo, PUC, 2003; orientação: Professor Donaldo Armelin.

GUINCHARD, Serge; FERRAND, Frédérique; CHAINAIS, Cécile. *Procédure civile*. Paris: Dalloz, 2008.

HABSCHEID, Walter. *Der Streitgegenstand im Zivilprozess und im Streitverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit*. Bielefeld: Deutscher Heimat, 1956.

\_\_\_\_\_. *Droit judiciaire privé suisse*. Genève: Librairie de l'Université Georg, 1981.

IHERING, Rudolf Von. *A luta pelo direito. Questões e estudos de direito*. Salvador: Progresso, 1955.

JARDIM, Augusto Tanger. *A causa de pedir no direito processual civil*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

JAUERNIG, Othmar. *Direito processual civil*. 25. ed. Trad. F. Silveira Ramos. Coimbra: Almedina, 2002.

JEULAND, Emmanuel; CADIET, Loïc. *Droit Judiciaire Privé*. Paris: LexisNexis, 2016.

JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Tutela específica do art. 461 do CPC e o processo de execução. In: SHIMURA, Sérgio; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (coord.). *Processo de execução*. São Paulo: Ed. RT, 2001.

JUNOY, Joan Pico i. *La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la recusación*. Barcelona: Bosch, 1998.

LACERDA, Galeno. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

\_\_\_\_\_. *Despacho saneador*. 3. ed. Porto Alegre: Fabris, 1990.

\_\_\_\_\_; OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1980. vol. 8, t. 2.

LASPRO, Oreste Nestor Souza. "Julgamento liminar de improcedência". *Código de processo civil anotado*. Coord. José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho Apriigliano, Rogéria Fagundes Dotti e Sandro Gilbert Martins. Rio de Janeiro: GZ, 2016.

LEAL, Antonio Luiz da Câmara. *Da prescrição e da decadência*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978.

LENT, Friedrich. *Diritto processuale civile tedesco*. 1ª parte. Trad. Edoardo Ricci. Napoli: Morano, 1962.

LEONEL, Ricardo de Barros. *Causa de pedir e pedido – o direito superveniente*. São Paulo: Método, 2006.

- LIEBMAN, Enrico Tullio. Fondamento del principio dispositivo. *Problemi del processo civile*. Napoli: Morano, 1962.
- \_\_\_\_\_. L'azione nella teoria del processo civile. *Problemi del processo civile*. Napoli: Morano, 1962.
- \_\_\_\_\_. Il titolo esecutivo riguardo ai terzi. *Rivista di Diritto Processuale Civile*, 1934.
- \_\_\_\_\_. La sentenza come titolo esecutivo. *Rivista di Diritto Processuale Civile*, 1929.
- \_\_\_\_\_. *Le opposizioni di merito nel processo d'esecuzione*. Roma: Foro Italiano, 1936.
- \_\_\_\_\_. *Manuale di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1984. vol. 1.
- \_\_\_\_\_. *Processo de execução*. São Paulo: Saraiva, 1968.
- LIMA, Alcides de Mendonça. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1987. vol. 6, t. 2.
- LORENZETTI, Luis. La tutela civil inhibitoria. *La Ley*. 1995-C.
- LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Tutela provisória e julgamento parcial no CPC de 2015: avanços e perspectivas. *O novo Código de Processo Civil – Questões controvertidas*. São Paulo: Gen-Atlas, 2015.
- LUISO, Francesco Paolo. *Diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 2015. vol. 4.
- MACEDO, Lucas Buril de. Antecipação da tutela por evidência e os precedentes obrigatórios. *Revista de Processo*. vol. 242.
- MACHADO, Marcelo Pacheco. Simplificação, autonomia e estabilização das tutelas de urgência: análise da proposta do Projeto de novo Código de Processo Civil. *Revista de Processo*. vol. 202.
- MAJO, Adolfo di. *La tutela civile dei diritti*. Milano: Giuffrè, 1993.
- \_\_\_\_\_. Reintegrazione nel posto di lavoro e controllo del potere nell'impresa (a proposito di una pubblicazione). *Rivista Giuridica del Lavoro*, 1979.
- MANDRIOLI, Crisanto. *L'azione esecutiva – Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*. Milano: Giuffrè, 1955.
- \_\_\_\_\_. *L'esecuzione forzata in forma specifica*. Milano: Giuffrè, 1953.
- \_\_\_\_\_. Le nuove ordinanze “di pagamento” e “ingiunzionale” nel processo ordinario di cognizione. *Rivista di Diritto Processuale*, 1991.
- MARANHÃO, Clayton. *Tutela jurisdicional do direito à saúde*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no estado contemporâneo. *Estudos de direito processual – homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- \_\_\_\_\_. *A antecipação da Tutela*. 11. ed. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 12, ed, São Paulo: Ed. RT, 2011.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. São Paulo: Ed. RT, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Efetividade do processo e tutela de urgência*. Porto Alegre: Fabris, 1994.

- \_\_\_\_\_. *El derecho de acción como derecho fundamental*. Bogotá: Temis, 2015.
- \_\_\_\_\_. Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella prospettiva della teoria dei diritti fondamentali. *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*. Milano: Giuffrè, 2005. vol. 1.
- \_\_\_\_\_. *Il diritto di azione come diritto fondamentale*. Torino: Giappichelli, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Introducción al Derecho Procesal Civil*. Lima: Palestra: 2015.
- \_\_\_\_\_. *Julgamento nas cortes supremas*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- \_\_\_\_\_. L'evoluzione della tecnica anticipatoria e della tutela preventiva in Brasile. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*. p. 1353 e ss. 2013.
- \_\_\_\_\_. L'insufficienza di tutela normativa al diritto fondamentale di azione. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Novas linhas do processo civil*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
- \_\_\_\_\_. *O STJ enquanto corte de precedentes*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Precedentes obrigatórios*. São Paulo: Ed. RT, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Técnica processual e tutela dos direitos*. São Paulo: Ed. RT, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Técnica processual e tutela dos direitos*. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Teoria Geral do Processo*. 8. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Tutela anticipatoria y tutela inhibitoria*. Lima: Palestra, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Tutela cautelar e tutela antecipatória*. São Paulo: Ed. RT, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tutela contra o ilícito*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Tutela Inhibitoria*. Madrid: Marcial Pons, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Tutela inibitória*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- \_\_\_\_\_; ARENHART, Sérgio Cruz. *Comentários ao código de processo civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005. vol. 2.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Manual do processo de conhecimento*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. MITIDIERO, Daniel. *Novo curso de processo civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016. vol. 1.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Novo curso de processo civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016. v. 2.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Prova e Convicção*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Curso de Processo Civil (Processo Cautelar)*. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Execução*. São Paulo: Ed. RT, 2007.



- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Processo de Conhecimento*. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- \_\_\_\_\_; PEREZ RAGONE, Alvaro. *Fundamentos del Proceso Civil*. Santiago: Abeledo Perrot, 2011.
- MARQUES, José Frederico. *Instituições de direito processual civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971. vol. II.
- \_\_\_\_\_. *Instituições de direito processual civil*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972. vol. III.
- \_\_\_\_\_. *Manual de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1974. vol. 4.
- MARTINS, Pedro Batista. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1941, vol. II.
- MAZZARELLA, Ferdinando. Ancora sul titolo esecutivo. *Rivista di Diritto Processuale*, 1967.
- \_\_\_\_\_. *Contributo allo studio del titolo esecutivo*. Milano: Giuffrè, 1965.
- \_\_\_\_\_. Scienza e teologia del titolo esecutivo. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1971.
- MEDINA, José Miguel Garcia; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *O dogma da coisa julgada*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- MELLO, Rogério Licastro Torres de; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. *Primeiros comentários ao novo código de processo civil artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- MENCHINI, Sergio. Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato. *Rivista di Diritto Processuale*, 2006.
- MENDONÇA JÚNIOR, Delosmar. *Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2001.
- MERRYMAN, John Henry. *La tradición jurídica romano-canónica*. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1986.
- MESQUITA, José Ignácio Botelho de. *Teses, estudos e pareceres de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2005. vol. I.
- MICHELI, Gian Antonio. *Onere della prova*. Padova: Cedam, 1966.
- MIGLINO, Arnaldo. *La tutela giurisdizionale anticipatoria*. Roma, 1986.
- MIRANDA, Jorge. *Manual de direito constitucional*. Coimbra: Coimbra Editora, 1983. t. II
- MITIDIERO, Daniel. O processualismo e a formação do Código Buzaid. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2010. vol. 183.
- \_\_\_\_\_. *Antecipação da Tutela*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- \_\_\_\_\_. Autonomia e estabilização da antecipação da tutela no novo Código de Processo Civil. *Revista de Direito Civil e Processual Civil (Magister)*. v. 63.
- \_\_\_\_\_. *Colaboração no processo civil*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Cortes superiores e cortes supremas*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- \_\_\_\_\_; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Novo Curso de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016. vol. 2.

- \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Precedentes – da persuasão à vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Processo civil e Estado Constitucional*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007
- MÒCCIOIA, Michele. Problemi del risarcimento del danno in forma specifica nella giurisprudenza. *Rivista Critica del Diritto Privato*, Napoli: Jovene, 1984.
- MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Hobbes, Montesquieu e a teoria da ação. *Revista de processo*. São Paulo: Ed. RT, 2002. vol. 108.
- \_\_\_\_\_. Notas sobre liquidação de sentença. *Revista de Processo*. v. 44.
- \_\_\_\_\_. *Comentários ao código de processo civil*. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. vol. II.
- \_\_\_\_\_. *Exegese do código de processo civil*. Rio de Janeiro: Aide, [s.d.], vol. 4, t. I.
- MONROY PALACIOS, Juan José. Cinco temas polémicos en el proceso civil peruano. *Revista de Direito Processual Civil*. Curitiba: Genesis. vol. 21.
- \_\_\_\_\_. *La tutela procesal de los derechos*. Lima: Palestra, 2004.
- MONTELEONE, Girolamo. Recenti sviluppi nella dottrina dell'esecuzione forzata. *Rivista di Diritto Processuale* 1982.
- MONTESANO, Luigi. Considerazioni su storia moderna e proposte di riforme della giustizia civile in Italia. *Rivista di Diritto Processuale*, 1981.
- \_\_\_\_\_. La tutela giurisdizionale dei diritti. *Trattato di diritto civile italiano*. Torino: UTET, 1994.
- \_\_\_\_\_. Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgenti. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Padova: Cedam, 1995.
- \_\_\_\_\_; ARIETA, Giovanni. *Il nuovo processo civile*. Napoli: Jovene, 1991.
- \_\_\_\_\_; VACCARELLA, Romano. *Manuale di diritto processuale del lavoro*. Napoli: Jovene, 1989.
- MORELLO, Augusto. *Anticipación de la tutela*. La Plata: Platense, 1996.
- \_\_\_\_\_. Las nuevas exigencias de tutela. *RePro*. vol. 31.
- MUNHOZ DA CUNHA, Alcides Alberto. *Comentários ao código de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- NERY JUNIOR., Nelson. Imparcialidade e juiz natural. *Estudos de direito processual civil – homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- NICOLAU, Noemi Lidia. La tutela inibitoria y el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional. *La Ley*, 1996-A.
- NORA, Sampaio; VARELA, Antunes; BEZERRA, J. Miguel. *Manual de processo civil*. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1985.
- NORMAND, Jacques; AMRANI, Soraya Mekki. *Théorie générale du procès*. Paris: Presses Universitaire de France, 2010.
- OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- \_\_\_\_\_. O problema da eficácia da sentença. *Polêmica sobre a ação*. Porto Alegre: Livraria do

Advogado, 2006.

\_\_\_\_\_. *Procedimento e ideologia no direito brasileiro atual*. Ajuris. vol. 43.

\_\_\_\_\_. *Teoria e prática da tutela jurisdicional*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

\_\_\_\_\_; LACERDA, Galeno. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1980. vol. 8, t. 2.

OLIVEIRA, Weber Luiz de. Estabilização da tutela antecipada e teoria do fato consumado. Estabilização da estabilização? *Revista de Processo*. vol. 242.

ORMAZABAL, Guillermo. *Iura novit curia*. Madrid: Marcial Pons, 2007.

PAIM, Gustavo. *Estabilização da tutela antecipada*. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2012.

PAOLINI, Renata. Note sulla condanna in futuro. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1976.

PASSOS, José Joaquim Calmon de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1977. vol. 10, t. 1.

PATTI, Salvatore. *Prove, Disposizioni Generali*. Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro Italiano, 1987.

PAULA BAPTISTA, Francisco de. *Teoria e prática do processo civil e comercial*. São Paulo: Saraiva, 1988.

PEIXINHO, Fabio. *O objeto litigioso no processo civil*. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

PEIXOTO, Ravi. *Superação do precedente e segurança jurídica*. Salvador: JusPodivm, 2015.

PEREIRA, Paula P. *Legitimidade dos precedentes*. São Paulo: Ed. RT, 2014.

PEREZ GORDO, Adolfo. *La ejecución provisional en el proceso civil*. Barcelona: Bosch, 1973.

PEREZ RAGONE, Álvaro. Introducción al estudio de la tutela anticipatoria. *Revista de Direito Processual Civil*. Curitiba: Gênese. vol. 5. mai./ago., 1997

\_\_\_\_\_; MARINONI, Luiz Guilherme. *Fundamentos del Proceso Civil*. Santiago: Abeledo Perrot, 2011.

PEYRANO, Jorge. Los límites de la tutela anticipada. *Sentencia anticipada*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2001.

\_\_\_\_\_. Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia – medidas autosatisfactorias. *Revista de Direito Processual Civil*. Curitiba: Gênese. vol. 9, jul./set., 1998.

\_\_\_\_\_. Régimen de las medidas autosatisfactivas, nuevas propuestas. *Revista de Direito Processual Civil*. Curitiba: Gênese. v. 7.

PICARDI, Nicola. I processi speciali, *Rivista di Diritto Processuale*, 1982.

PIMENTEL, Wellington Moreira. *Comentários ao código de processo civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1979. vol. III.

PISANI, Andrea Proto. *Appunti sulla giustizia civile*. Bari: Cacucci, 1982.

\_\_\_\_\_. Appunti sulla tutela di condanna. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1978.

\_\_\_\_\_. *Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria*. Roma: Foro Italiano, 1983.

- \_\_\_\_\_. *I provvedimenti anticipatori di condanna*. Roma: Foro Italiano, 1990.
- \_\_\_\_\_. *L'attuazione dei provvedimenti di condanna*. Roma: Foro Italiano, 1988.
- \_\_\_\_\_. L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna. *Rivista di Diritto Processuale*, 1975.
- \_\_\_\_\_. *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*. Roma: Foro Italiano, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Le controversie in materia di lavoro*. Bologna-Roma, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Lezioni di diritto processuale civile*. 3. ed. Napoli: Jovene, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Lezioni di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Provvedimenti anticipatori di condanna*. Roma: Foro italiano, 1990.
- \_\_\_\_\_. Sulla tutela giurisdizionale differenziata. *Rivista di Diritto Processuale*, 1979.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários à Constituição de 1967*. São Paulo: Ed. RT, 1968. t. 5.
- \_\_\_\_\_. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1977. vol. 8.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Rio de Janeiro: Forense, 1974. t. IV.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 3. ed. Atual. Sérgio Bermudes. Rio de Janeiro: Forense, 1996. t. III.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 3. ed. Atual. Sérgio Bermudes. Rio de Janeiro: Forense, 1996, t. IV.
- \_\_\_\_\_. *Tratado das ações*. Campinas: Bookseller, 1998. t. I.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Campinas: Bookseller, 1998. t. II.
- \_\_\_\_\_. *Tratado de direito privado*. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. t. VI.
- PORTANOVA, Rui. *Motivações ideológicas da sentença*. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994.
- POTHIER, R. J. *Tratado de las obligaciones*. Buenos Aires: Editorial Eliasta, 1993.
- PUNZI, Carmine. *Il processo civile*. Padova: Cedam, 2010. vol. 3, p. 50.
- RAMPAZZI, Gabriella. *Le riforme del processo civile* (a cura di Sergio Chiarloni). Bologna: Zanichelli, 1992.
- RAPISARDA, Cristina. Inibitoria. *Digesto delle discipline privatistiche*. vol. 9, p. 475.
- \_\_\_\_\_. Premesse allo studio della tutela civile preventiva. *Rivista di Diritto Processuale*, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Profili della tutela civile inibitoria*. Padova: Cedam, 1987.
- \_\_\_\_\_. Tutela preventiva, inibitoria cautelare “ex” art. 700 C.P.C. ed inibitoria finale. *Rivista di Diritto Processuale*, 1986.
- \_\_\_\_\_; TARUFFO, Michele. Inibitoria. *Enciclopedia Giuridica Treccani*. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana. 1986, v. 17.
- RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. *Tutela provisória*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

- RICCI, Edoardo. A tutela antecipatória na Itália. *Revista de Direito Processual Civil* (Genesis). vol. 4.
- \_\_\_\_\_. I provvedimenti interinali e cautelari. *La riforma del processo civile*. Milano: Giuffrè, 1991.
- \_\_\_\_\_. Il progetto Rognoni di riforma urgente del processo civile. *Rivista di Diritto Processuale*, 1987.
- \_\_\_\_\_. Per una efficace tutela provvisoria ingiunzionale dei diritti di obbligazione nell'ordinario processo civile. *Rivista di Diritto Processuale*, 1990.
- RODRIGUES, Marcelo Abelha. *Manual de direito processual civil*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008.
- ROSSIELO, Giampiero. Tema di esecuzione di provvedimenti d'urgenza recanti l'ordine di corrispondere somme di denaro. *Rivista di Diritto Processuale*, 1987.
- SALAVERRÍA, Juan Igartua. *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.
- SALETTI, Achille. Le riforme del codice di rito in materia di esecuzione forzata e di attuazione delle misure cautelari. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1992.
- SALVI, Cesare. Legittimità e "razionalità" dell'art. 844 Codice Civile. *Giurisprudenza italiana*, 1975.
- SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à sociologia da administração da justiça. *RePro*. vol. 37.
- SANTOS, Ernani Fidelis dos. *Manual de direito processual civil*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- SANTOS, Moacyr Amaral. *Primeiras linhas de direito processual civil*. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. vol. 2.
- SARLET, Inglo Wolfgang. *Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
- \_\_\_\_\_. *A eficácia dos direitos fundamentais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
- SASSANI, Bruno. *Lineamenti del processo civile italiano*. Milano: Giuffrè, 2014.
- SATTA, Salvatore. L'esecuzione forzata nella tutela giurisdizionale dei diritti. Scritti in onore di Francesco Carnelutti. Padova: Cedam, 1950. vol. 2.
- \_\_\_\_\_. Provvedimenti d'urgenza e urgenza di provvedimenti. *Soliloqui e colloqui di un giurista*. Padova: Cedam, 1968.
- SCARSELLI, Giuliano. *La condanna con riserva*. Milano: Giuffrè, 1989.
- SCHWAB, Karl Heinz. *Der Streitgegenstand im Zivilprozess*. München: C. H. Beck, 1954.
- SCIALOJA, Vittorio. *Procedimiento civil romano*. Trad. Santiago Sentis Melendo e Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: EJE, 1954.
- SCOGNAMIGLIO, Renato. Il risarcimento del danno in forma specifica. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1957.
- SEPANIAN, Almara. Cleaning house with rule 41(b): an empirical study of the multi-factor tests for involuntary dismissals. *Southwestern law review*. 2014. vol.. 44.

- SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 2002.
- SILVA, Ovídio Baptista da. A “plenitude de defesa” no processo civil. *As garantias do cidadão na justiça*. São Paulo: Saraiva, 1993.
- \_\_\_\_\_. Decisões interlocutórias e sentenças liminares. *Da sentença liminar à nulidade da sentença*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
- \_\_\_\_\_. Fundamentos do procedimento ordinário. *Processo e ideologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- \_\_\_\_\_. Tutela antecipatória e juízos de verossimilhança. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *O processo civil contemporâneo*. Curitiba: Juruá, 1994.
- \_\_\_\_\_. *A ação cautelar inominada no direito brasileiro*. São Paulo: Forense, 1979.
- \_\_\_\_\_. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 11.
- \_\_\_\_\_. *Curso de processo civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1998. vol. 3.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 5. ed. 2. tir. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 3.
- \_\_\_\_\_. *Do processo cautelar*. Porto Alegre: Lejur, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 11.
- \_\_\_\_\_. *Jurisdição e execução na tradição romanocanônica*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Processo e ideologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Teoría de la acción cautelar*. Porto Alegre: Fabris, 1993.
- SILVESTRI, Elisabetta; TARUFFO Michele. Esecuzione forzata. *Enciclopedia Giuridica Treccani*. vol. 13.
- SOUZA, Artur César de. Análise da tutela antecipada prevista no relatório final da câmara dos deputados em relação ao novo CPC. *Revista de Processo*. vol. 235.
- STEIN, Friedrich. *El conocimiento privado del juez*. 2. ed. Bogotá: Temis, 1999.
- TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil: a estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. *Revista de Processo*. vol. 209.
- TARTUCE, Fernanda. *Mediação nos conflitos civis*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- TARUFFO, Michele. Esecuzione forzata. *Enciclopedia Giuridica Treccani*. vol. 13.
- \_\_\_\_\_. A atuação executiva dos direitos: perfis comparados. *Processo civil comparado: ensaios*. Apresentação, organização e tradução de Daniel Mitidiero. São Paulo: Marcial Pons, 2013.
- \_\_\_\_\_. As funções das cortes supremas: Aspectos gerais. *Processo civil comparado: ensaios*. Trad. Daniel Mitidiero. São Paulo: Marcial Pons, 2013.
- \_\_\_\_\_. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. *Rivista di Diritto Processuale*, 1997.
- \_\_\_\_\_. La motivazione della sentenza. *Revista Genesis de Direito Processual Civil*. Curitiba: Gênesis. V. 31.

- \_\_\_\_\_. *Cinco lecciones mexicanas*. México: Escuela Judicial Electoral, 2003.
- \_\_\_\_\_. *La giustizia civile in Italia dal'700 a oggi*. Bologna: Il Mulino, 1980.
- \_\_\_\_\_. La motivazione della sentenza civile. *Revista de Direito Processual Civil* (Genesis). vol. 30.
- \_\_\_\_\_. *La prova dei fatti giuridici*. Milano: Giuffrè, 1992.
- \_\_\_\_\_. *La prueba de los hechos*. 2. ed. Madrid: Trotta, 2005.
- \_\_\_\_\_. Precedente e Giurisprudenza. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*. Milano: Giuffrè, 2007.
- \_\_\_\_\_. Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione. *Rivista Critica del Diritto Privato*, 1986.
- \_\_\_\_\_; RAPISARDA, Cristina. Inibitoria. *Enciclopedia Giuridica Treccani*. vol. 17.
- TARZIA, Giuseppe. Le istruzioni del giudice alle parti nel processo civile. *Problemi del processo civile di cognizione*. Padova: Cedam, 1989.
- \_\_\_\_\_. Parità delle armi tra le parti e poteri del giudice nel processo civile. *Problemi del processo civile di cognizione*. Padova: Cedam, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*. Milano: Giuffrè, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Manuale del processo del lavoro*. Milano: Giuffrè, 2008.
- \_\_\_\_\_. Presente e futuro delle misure coercitive civile. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1981.
- \_\_\_\_\_. Rigetto e riproponibilità della domanda cautelare. *Rivista di Diritto Processuale*, 1988.
- TEIXEIRA, Salvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- TEREBILOV, V.; POUTCHINSKI, V. K.; TADEVOSIÁN, V. *Princípios de processo civil da U.R.S.S. e das repúblicas federadas*. Coimbra: Centelha, 1978.
- TESSER, André Luiz Bauml. As diferenças entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela no CPC/2015. *Coletânea Novo CPC: Doutrina Seleccionada*. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 4.
- \_\_\_\_\_. *Cautelar e antecipação de tutela*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- TESSLER, Luciane Gonçalves. O papel do judiciário na concretização dos direitos fundamentais. *Estudos de direito processual civil – homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Tutelas jurisdicionais do meio ambiente – Tutela inibitória, tutela de remoção e tutela ressarcitória na forma específica*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- THEODORO JR., Humberto. *Processo cautelar*. São Paulo: LEUD, 1976.
- \_\_\_\_\_; ANDRADE, Érico. A autonomização e a estabilização da tutela de urgência no Projeto de CPC. *Revista de Processo*. v. 206.
- \_\_\_\_\_; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. *Novo CPC – fundamentos e sistematização*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- TISCINI, Roberta. *I provvedimenti senza accertamento*. Torino: Giappichelli, 2009.
- TOMMASEO, Ferruccio. *Appunti di diritto processuale civile*. Torino: Giappichelli, 1995.



- \_\_\_\_\_. *I provvedimenti d'urgenza – Struttura e limiti della tutela anticipatoria*. Padova: Cedam, 1983.
- TORNAGHI, Hélio. *Comentários ao código de processo civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1976. vol. I.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1978. vol. II.
- TROCKER, Nicolò. *Processo civile e costituzione*. Milano: Giuffrè, 1974.
- VACCARELLA, Romano; CAPPONI, Bruno; CECCHELA, Claudio. *Il processo civile dopo le riforme*. Torino: Giappichelli, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*. 2. ed. Torino: Giappichelli, 1993.
- VARELA, Antunes; BEZERRA, J. Miguel; NORA, Sampaio e. *Manual de processo civil*. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1985.
- VARGAS, Abraham Luis. Teoría general de los procesos urgentes. *Medidas autosatisfactivas*. Coord. Jorge Peyrano. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2004.
- \_\_\_\_\_. Tutela anticipada: Perfiles actuales. *Cuestiones Procesales Modernas*, 2005.
- VERDE, Giovanni. Considerazioni sul provvedimento d'urgenza. *I processi speciali – Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi*. Napoli: Jovene, 1979.
- \_\_\_\_\_. *Profili del processo civile* (Parte generale). Napoli: Jovene, 1988.
- VIGNERA, Giuseppe. Sui rapporti tra provvedimento d'urgenza e sentenza di merito (alla ricerca di una soluzione ragionevole). *Rivista di Diritto Processuale*. 1993.
- \_\_\_\_\_; ANDOLINA, Italo. *Il modello costituzionale del processo civile italiano*. Torino: Giappichelli, 1990.
- VILLAR, Willard de Castro. *Execução de alimentos e prisão do devedor*. São Paulo: Ed. RT, 1993.
- VUITTON, Jacques; VUITTON, Xavier. *Les référés*. Paris: LexisNexis, 2006.
- WALTER, Gerhard. *Livre apreciación de la prueba*. Bogotá: Temis, 1985.
- WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação de sentença. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- \_\_\_\_\_. TALAMINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil*. 16ª ed., São Paulo: RT, 2016, vol. 2.
- WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. *Participação e processo*. São Paulo: Ed. RT, 1988.
- \_\_\_\_\_. Assistência judiciária como instrumento de acesso à ordem jurídica justa. *Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo*. v. 22.
- \_\_\_\_\_. *Da cognição no processo civil*. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000.
- \_\_\_\_\_. Filosofia e características básicas do juizado especial de pequenas causas. *Juizado Especial de Pequenas Causas*. São Paulo: Ed. RT, 1985.
- XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. *Reclamação constitucional e precedentes judiciais*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Tutela de urgência definitiva? Medidas autossatisfativas (Argentina), medidas provisionais (Brasil) e a proposta de estabilização da antecipação de tutela. *Revista de Processo*. v. 231.

ZANETI JUNIOR, Hermes. A constitucionalização do processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

\_\_\_\_\_. *O valor vinculante dos precedentes*. Salvador: JusPodivm, 2015.

\_\_\_\_\_. *Processo constitucional* (o modelo constitucional do processo civil brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

ZANUTTIGH, Lorian. La tutela cautelare atipica. *L'informazione e i diritti della persona*. Napoli: Jovene, 1983.

ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003. vol. 8.

© desta edição [2018]